

LUIZ GUILHERME MARINONI

DANIEL MITIDIERO

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

XV

ARTIGOS 926 AO 975

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRECTOR

SÉRGIO CRUZ ARENHAART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS™

2019 - 04 - 08

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

PRIMEIRAS PÁGINAS

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

VOLUME XV – ARTIGOS 926 AO 975

Autores

Luiz Guilherme Marinoni

Daniel Mitidiero

© desta edição [2018]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono

Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda

Tel.: 11 3613-8400 - Fax: 11 3613-8450

CEP 01136-000 - São Paulo

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal) com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).



Visite nosso site: www.rt.com.br

Central de Relacionamento RT (atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Fechamento desta edição: [08.08.2018]



ISBN 978-85-5321-192-0

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 08

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha Catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Marinoni, Luiz Guilherme

Comentários ao Código de Processo Civil : [livro eletrônico] (arts.926 ao 975) / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. -- (Coleção comentários ao código de processo civil ; V. XV / direção LuizGuilherme Marinoni ; coordenação Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero)

6 Mb ; ePUB

2. ed em e-book baseada na 2. ed. impressa rev. e atual.

Bibliografia

ISBN 978-85-5321-192-0

1. Processo civil - Legislação - Brasil I. Mitidiero, Daniel. II. Arenhart, Sérgio Cruz. III. Título. IV. Série.

18-19320 CDU-347.9(81)(094.46)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Código de Processo Civil comentado 347.9(81)(094.46))
2. Código de Processo Civil : Comentários : Brasil 347.9(81)(094.46)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 08

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Annados Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chisley Figueiredo

Adaptação de capa: Linotec

Controle de Qualidade de Diagramação: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastro Rosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

2019 - 04 - 08

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE OS AUTORES

Sobre os Autores

Luiz Guilherme Marinoni

Professor Titular de Direito Processual Civil – *com defesa de tese* – na UFPR.

Pós-Doutorado na Universidade Estatal de Milão e na *Columbia University*. Tem dezessete livros publicados na América Latina e na Europa e mais de trinta livros publicados no Brasil. Diretor das Revistas *Iberoamericana de Derecho Procesal* e de *Processo Comparado* – ambas publicadas pela Ed. *Revista dos Tribunais*. Diretor do Instituto Iberoamericano de *Derecho Procesal*. Membro do Conselho da *International Association of Procedural Law*. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2009 e em 2017, tendo sido indicado ao mesmo prêmio em diversas outras ocasiões. Ex-Procurador da República. Ex-Presidente da OAB-Curitiba. Advogado e parecerista, com intensa atuação nos Tribunais e nas Cortes Supremas.

Daniel Mitidiero

Pós-Doutorado pela *Università degli Studi di Pavia*. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Professor Associado de Direito Processual Civil nos cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Publicou 30 livros – quatro deles no exterior – e diversos artigos em revistas especializadas nacionais e estrangeiras, dentre as quais a *Zeitschrift für Zivilprozess International*, a *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile* e o *International Journal of Procedural Law*. Membro da *International Association of Procedural Law* – IAPL, do Instituto Iberoamericano de *Derecho Procesal* – IIBDP, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2009 e em 2017. Advogado e Parecerista, com intensa atuação nas Cortes Supremas.

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

LIVRO III - DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

TÍTULO I - DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais [Art. 926 a 928]

CAPÍTULO II - Da Ordem dos Processos no Tribunal [Art. 929 a 946]

CAPÍTULO III - Do Incidente de Assunção de Competência [Art. 947]

CAPÍTULO IV - Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade [Art. 948 a 940]

CAPÍTULO V - Do Conflito de Competência [Art. 951 a 959]

CAPÍTULO VI - Da Homologação de Decisão Estrangeira e da Concessão do *Exequatur* à Carta Rogatória [Art. 960 a 965]

CAPÍTULO VII - Da Ação Rescisória [Art. 966 a 975]

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

Livro III. Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais

1. Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais. Ao contrário do legislador do Código de 1973, o legislador do Código de 2015 resolveu destacar a matéria concernente aos processos nos tribunais e aos meios de impugnação das decisões judiciais do âmbito do processo de conhecimento. Ao mesmo tempo, resolveu agrupá-las em um livro único.

No Código de 1973 tanto a disciplina do processo nos tribunais como a dos recursos entrava no campo do processo de conhecimento: a primeira no Título IX e a segunda no Título X, ambos situados dentro do Livro I. Como o Código de 1973 não contava com uma parte geral, as disposições com esse perfil foram acomodadas dentro do processo de conhecimento.¹ A doutrina de um modo geral aprovou semelhante alocação – inclusive grifando como justificativa para a inserção, a natureza cognitiva da atividade desenvolvida pelos tribunais nessa seara.²

No Código de 2015, porém, eventual tratamento desses temas no processo de conhecimento não se justificaria, assim como não se justifica a sua disciplina em livro próprio – como estava, aliás, também disposta equivocadamente a matéria no Código de 1939.³ Tendo em conta a existência de uma Parte Geral no Código, a ordem dos processos, os processos de competência originária dos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais nessa devem ter assento: isso porque, por exemplo, todos os atos decisórios recorríveis prolatados ao longo de qualquer procedimento encontram nele sua disciplina comum.

Esse é o acertado exemplo que vem da análise que emerge da comparação com outros Códigos de Processo Civil. Nessa linha, o Code de Procédure Civile francês (1975) é emblemático, tratando dos “voies de recours” no Título XVI do seu Primeiro Livro, dedicado às “dispositions communes à toutes les juridictions”. Alguém poderia imaginar, porém, que é possível conciliar a existência de um livro consagrado à parte geral e de outro dedicado aos recursos lembrando a Zivilprozessordnung alemã (1877). Nada obstante, a justificativa para a coexistência de uma parte geral e de um livro dedicado aos recursos na ZPO não se observa na arquitetura do direito brasileiro: o direito alemão optou por disciplinar, logo em seguida das disposições gerais (Buch 1, “Allgemeine Vorschriften”), o procedimento na primeira instância (Buch 2, “Verfahren im ersten Rechtszug”), com o que faz sentido prever na sequência o direito recursal (Buch 3, “Rechtsmittel”).

O Livro III é dividido em dois títulos distintos: o primeiro trata da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais, ao passo que o segundo cuida dos recursos – a principal espécie do gênero meios de impugnação das decisões judiciais.⁴ O elemento que justifica o agrupamento da matéria está no fato de que em um e em outro caso a atividade jurisdicional desenvolve-se perante os Tribunais.⁵ Enquanto nos Livros I e II da Parte Especial, o foco está nas atividades de conhecimento e de execução que se desenvolvem no procedimento perante os juízes de primeiro grau (vale dizer, na perspectiva horizontal do procedimento), o Livro III cuida das atividades realizadas no procedimento perante as Cortes de Justiça e as Cortes Supremas (vale dizer, na perspectiva vertical do procedimento).⁶

1.1. Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais. A

disciplina do Título I do Livro III é composta de nove capítulos: i) Capítulo I (disposições gerais, arts. 926 a 928); ii) Capítulo II (da ordem dos processos no tribunal, arts. 929 a 946); iii) Capítulo III (do incidente de assunção de competência, art. 947); iv) Capítulo IV (do incidente de arguição de inconstitucionalidade, arts. 948 a 950); v) Capítulo V (do conflito de competência, arts. 951 a 959); vi) Capítulo VI (da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória, arts. 960 a 965); vii) Capítulo VII (da ação rescisória, arts. 966 a 975); viii) Capítulo VIII (do incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 a 987); e ix) Capítulo IX (da reclamação, arts. 988 a 993).

No confronto com o Código de 1973, o Código de 2015 apenas não repetiu o incidente de uniformização de jurisprudência. Nada obstante, procurou substituí-lo e por assim dizer reforçá-lo pelo incidente de assunção de competência e, de certo modo, pelo incidente de resolução de demandas repetitivas⁷ – isso porque, em ambos os casos, o legislador confere ao resultado do julgamento desses incidentes, força vinculante (art. 927, III, CPC/2015).

Ao lado das disposições gerais e da reclamação, os incidentes de assunção de competência e de incidente de resolução de demandas repetitivas constituem as inovações do Código de 2015 em relação ao desenho original do Código de 1973 a respeito da matéria.⁸ A título de disposições gerais, procurou densificar a função constitucional das Cortes Judiciárias e disciplinar o valor do precedente e da jurisprudência no nosso ordenamento jurídico. Em termos de inovação, ainda, previu dentro da ordem dos processos no tribunal a possibilidade de ampliação do debate diante da não unanimidade de julgamento (art. 942, CPC/2015). Trata-se de técnica processual que visa a alcançar de forma mais simples os mesmos objetivos outorgados ao recurso de embargos infringentes no Código de 1973, o qual o Código de 2015 não previu (art. 944, CPC/2015). Ainda na comparação com o Código de 1973, o Código de 2015 passou a regular no âmbito do título concernente à ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais, a ordem do processo nos tribunais – que no Código de 1973 constituía um dos capítulos do título atinente aos recursos (Capítulo VII do Título X do Livro I) – e o conflito de competência – que era disciplinado no âmbito da competência interna (Seção V do Capítulo III do Título IV do Livro I). Ao fazê-lo, o Código foi fiel ao seu intento de concentrar a disciplina de todos os processos de competência originária e a ordem de desenvolvimento dos trabalhos perante as Cortes Judiciárias em um único momento.

O Código poderia ter organizado de forma mais adequada à matéria. Embora se possa compreender o tratamento dos precedentes e da jurisprudência a título de disposições gerais por conta da necessidade de assinalar aos Tribunais determinadas funções dentro da ordem jurídica (arts. 926 a 928, CPC/2015), com o que sobrelevou para a organização da matéria aí, mais os “Tribunais” e menos – por assim dizer – as “razões das suas decisões”, tônica que recomendaria a alocação da matéria logo em seguida à disciplina da sentença, não se entende a razão pela qual os incidentes e as ações originárias não foram sequenciados logo após as disposições gerais e a ordem dos processos. Para não deixar transparecer certa desordem, o ideal é que o legislador tivesse regulado sequencialmente: i) as disposições gerais; ii) a ordem do processo nos tribunais; iii) os incidentes (de arguição de inconstitucionalidade, de conflito de competência, de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas); e iv) as ações originárias (a ação para a homologação de decisão estrangeira e para a concessão do exequatur à carta rogatória, a ação rescisória, a ação anulatória de ato processual e a ação de reclamação).

1.2. Dos Recursos. A disciplina do Título II do Livro III é composta de seis capítulos: i) Capítulo I (disposições gerais, arts. 994 a 1.008); ii) Capítulo II (da apelação, arts. 1.009 a 1.014); iii) Capítulo III (do agravo de instrumento, arts. 1.015 a 1.020); iv) Capítulo IV (do agravo interno, art. 1.021); v) Capítulo V (dos embargos de declaração, arts. 1.022 a 1.026); e vi) Capítulo VI (dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, arts. 1.027 a 1.044).

No confronto com o Código de 1973, o Código de 2015 deixou de prever o agravo retido e os embargos infringentes como recursos (art. 994, CPC/2015). O papel desempenhado pelo agravo retido – impedir a preclusão de determinada questão resolvida por decisão interlocutória – é agora desempenhado pela própria lei, que permite a impugnação de qualquer questão decidida ao longo do procedimento não impugnável mediante agravo de instrumento como preliminar de apelação

ou como preliminar nas suas contrarrazões (arts. 1.009, § 1.º, CPC/2015); o desenvolvido pelos embargos infringentes, consubstanciado no fomento ao diálogo judicial diante da ausência de unanimidade no colegiado, pela técnica de ampliação de julgamento não unânime (art. 942, CPC/2015).

Ao deixar de prever dois recursos, o Código de 2015 enquadra-se em uma tendência mundial que visa à simplificação e à eficiência da administração da justiça civil.⁹ Nada obstante, ao manter a ampla devolutividade da apelação e não abolir o seu efeito suspensivo ope legis, manteve-se alheio ao movimento realizado por importantes ordenamentos jurídicos, como o alemão e o italiano,¹⁰ perdendo infelizmente a oportunidade de conferir sentido à atividade desenvolvida pelos juízes de primeiro grau – que com o Código de 2015 permanecem com as suas decisões amplamente suscetíveis de revisão – e de permitir a imediata execução da sentença como meio para promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º, CPC/2015).¹¹

2. A Tutela dos Direitos no Processo nos Tribunais. O processo civil visa à prestação da tutela dos direitos. Trata-se de tutela que se manifesta em duas dimensões: uma dimensão particular, ligada à viabilização de uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva do caso concreto (art. 6.º, CPC/2015), e outra dimensão geral, atinente à promoção da unidade da ordem jurídica (art. 926, CPC/2015). Se adequadamente lido, é possível perceber que a tutela dos direitos é o eixo a partir do qual o Código de 2015 deve ser sistematizado.¹²

Isso quer dizer que a tutela dos direitos é o fim do processo civil, desdobrando-se em dois discursos: o primeiro concernente ao caso concreto e o segundo ao ordenamento jurídico.¹³ Visando ao alcance de uma decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável, a ordem jurídica erigiu como lema do processo civil a colaboração do juiz para com as partes, buscando transformá-lo em uma efetiva comunidade de trabalho, isto é, em uma “chose commune des parties et du juge”,¹⁴ em uma dinâmica “Arbeitsgemeinschaft”¹⁵ (art. 6.º, CPC/2015).¹⁶ Objetivando a busca pela unidade do direito, o legislador procurou traçar um sistema de precedentes obrigatórios para o direito brasileiro (arts. 926 e 927, CPC/2015).¹⁷ Em outras palavras, a colaboração é um meio para a obtenção de uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva, ao passo que os precedentes constituem um meio para a promoção da unidade do direito.

Como eixo sistemático do Código, a tutela dos direitos – e seus instrumentos centrais, a colaboração e os precedentes – permeia não só o processo perante os juízes de primeiro grau, mas também o processo diante dos Tribunais. Assim, o relator do caso tem deveres de prevenção (por exemplo, arts. 932, parágrafo único, 938, 1.007, §§ 2.º, 4.º e 7.º, 1.017, § 3.º e 1.032, CPC/2015) e de diálogo (por exemplo, arts. 489, § 1.º, IV, e 933, CPC/2015) na condução do processo, os quais são inerentes à colaboração no processo civil. Igualmente, tanto as Cortes de Justiça como as Cortes Supremas estão obrigadas a respeitar precedentes, na medida em que o Código reconheceu um sistema de stare decisis horizontal e vertical (arts. 926 e 927, CPC/2015). Colaborar visando a prolação de uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva e respeitar precedentes são deveres inerentes à atuação das Cortes Judiciárias diante do Código de 2015 – vale dizer, inerentes ao modo como o Código de 2015 concebeu o dever de dar tutela aos direitos mediante o processo civil.

NOTAS DE RODAPÉ

1

O Código de 1973 estava organizado em cinco livros: livros I (do processo de conhecimento), II (do processo de execução), III (do processo cautelar), IV (dos procedimentos especiais) e V (das disposições finais e transitórias). Sobre as influências teóricas que conduziram Alfredo Buzaid a essa organização, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 557-568, vol. I;

Daniel Mitidiero, “O Processualismo e a Formação do Código Buzaid”, Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2010, n. 183.

2

Por todos, José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil (1974), 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1, vol. V.

3

O Código de 1939 estava organizado em dez livros: livros I (disposições gerais), II (do processo em geral), III (do processo ordinário), IV (dos processos especiais), V (dos processos acessórios), VI (dos processos da competência originária dos tribunais), VII (dos recursos), VIII (da execução), IX (do juízo arbitral) e X (disposições finais e transitórias).

4

Por todos, Pontes de Miranda (1892 – 1979), Comentários ao Código de Processo Civil (1975), 3. Ed., atualizada por Sérgio Bermudes. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 4, tomo VII.

5

José Carlos Barbosa Moreira, Op. Cit., p. 3.

6

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 142-146, vol. II. Sobre a distinção entre Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais) e Cortes Supremas (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), Luiz Guilherme Marinoni, O STJ enquanto Corte de Precedentes, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

7

Lembre-se que a própria proposta de inserção do incidente de resolução de demandas repetitivas no direito brasileiro, formulada originariamente na doutrina por Antonio do Passo Cabral, procurava adaptá-lo à luz do incidente de uniformização de jurisprudência. (O Novo Procedimento-Modelo (Musterverfahren) Alemão: uma Alternativa às Ações Coletivas. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 123-146, especialmente p. 144, n. 147).

8

Em relação ao desenho original, na medida em que o incidente de assunção de competência foi introduzido posteriormente pela Lei 10.352, de 2001, sofrendo ainda ulterior intervenção da Lei 11.280, de 2006 (Código de 1973, art. 555, §§ 1.º a 3.º).

Como registram Dondi, Ansanelli e Comoglio, *Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata*. Milano: Giuffrè, 2015, p. 292; Uzelac-van Rhee, “Appeals and other Means of Recourse against Judgments in the Context of the Effective Protection of Civil Rights and Obligations”. In: Uzelac-van Rhee (coords.), *Nobody’s Perfect – Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions Matters*. Cambridge: Intersentia, 2014, p. 4-5.

Sobre a tendência à limitação do direito ao apelo, incluída aí a sua devolutividade, Remo Caponi, “L’ Appello nel Sistema delle Impugnazioni Civili (Note di Comparazione Anglo-Tedesca)”, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 2009, p. 631-645; Idem, “La Riforma dei Mezzi di Impugnazione”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2012, p. 1153-1178; Elena Lucertini, “La Riforma dell’ Appello Civile in Germania: il Declino del Giudizio ‘de Novo’”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2006, p. 915-942; sobre a tendência à executoriedade imediata da sentença, Giuseppe Tarzia, “Il Progetto Vassalli per il Processo Civile”, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1989, p. 120-136; Idem, “I Provvedimenti Urgenti sul Processo Civile Approvati dal Senato”, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1990, p. 737-752.

Conforme Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela Antecipatória, Julgamento Imediato e Execução Imediata da Sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1997; Daniel Mitidiero, “Por uma Reforma da Justiça Civil no Brasil: um Diálogo entre Mauro Cappelletti, Vittorio Denti, Ovídio Baptista e Luiz Guilherme Marinoni”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2011, n. 199.

Conforme Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 151-152, vol. I; Idem, *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 86, vol. II.

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 151-152, vol. I; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 23-31; Idem, “A Tutela dos Direitos como Fim do Processo Civil no Estado Constitucional”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 229; Idem, “Fundamentação e Precedente – Dois Discursos a Partir da Decisão Judicial”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 61-69, n. 206; Didier Júnior, Braga e Oliveira, *Curso de Direito Processual Civil* (2007), 10. ed. Salvador: JusPodium, 2015, p. 444, vol. II.

Loïc Cadiet e Emmanuel Jeuland, *Droit Judiciaire Privé* (1992), 8. ed. Paris: LexisNexis, 2013, p. 405.

16

Amplamente, com as devidas indicações bibliográficas, Daniel Mitidiero, Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos (2009), 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015; Fredie Didier Júnior, Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português. Coimbra: Coimbra Editora, 2010; Fredie Didier Júnior, in Cabral e Cramer (coords.), Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 18-21; Antonio do Passo Cabral, Nulidades no Processo Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2009; Theodoro Júnior, Nunes, Bahia e Pedron, Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 59-139.

17

Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes Obrigatórios (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016; Idem, O STJ enquanto Corte de Precedentes (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Idem, Precedentes – da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Ed. RT, 2016.

TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

Capítulo I. Disposições Gerais

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1.º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2.º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

1. Cortes, Jurisprudência e Precedentes. O conteúdo do art. 926, CPC/2015, é muito rico. De um lado, alude-se à função dos Tribunais – uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, CPC/2015). De outro, fala-se em jurisprudência, súmulas e precedentes (art. 926, §§ 1.º e 2.º, CPC/2015). Nada obstante imbuído de excelentes objetivos, o dispositivo procede a assimilações indevidas que arriscam colocar em xeque o sistema de Cortes Supremas e precedentes obrigatórios que a partir do Código pode ser reconstruído.¹

Isso quer dizer que para uma adequada compreensão do tema é necessário: i) ver a segurança jurídica como um meio para a promoção dos princípios da liberdade e da igualdade mediante um processo racional de interpretação e aplicação do direito; ii) distinguir entre Cortes de Justiça e Cortes Supremas, entendendo cada um dos tribunais brasileiros a partir de suas respectivas funções; iii) distinguir entre precedentes e jurisprudência; iv) ver a súmula como um instrumento capaz de veicular tanto a jurisprudência como o precedente; v) entender o alcance da regra do stare decisis entre nós; e vi) entender o significado dos conceitos de integridade e coerência no contexto do Código. Daí que é imprescindível apartar semelhantes conceitos.

2. Liberdade, Igualdade e Segurança Jurídica. A percepção de que a norma é o resultado da interpretação (em outras palavras, a tomada de consciência de que o discurso do legislador não é suficiente para guiar o comportamento humano, tendo em conta a sua dupla indeterminação – textos são equívocos e normas são vagas) abriu espaço para que se pensasse na decisão judicial não só como um meio de solução de determinado caso concreto, mas também como um meio para promoção da unidade do direito. Mais precisamente, chegou-se à conclusão de que em determinadas situações, as razões adotadas na justificação das decisões, servem como elementos capazes de reduzir a indeterminação do discurso jurídico, podendo servir como concretizações reconstrutivas de mandamentos normativos. Isso despertou a doutrina e o novo Código para o significado da interpretação judicial do direito dentro da ordem jurídica.

Em primeiro lugar, é preciso perceber que o direito é indeterminado basicamente por duas razões: os textos em que vazado são equívocos e as normas são vagas. Essa é a razão pela qual se costuma afirmar a “*duplice indeterminatazza del diritto*”.² Os textos são equívocos porque ambíguos, complexos, implicativos, defectivos e por vezes se apresentam em termos exemplificativos ou taxativos. As normas são vagas porque não é possível antever exatamente quais são os fatos que recaem nos seus respectivos âmbitos de incidência.

Um texto é equívoco porque dá azo a dúvidas interpretativas a respeito do seu significado, seja porque ambíguo, complexo, implicativo, defectível ou redigido de forma aberta ou fechada. Um texto é ambíguo quando dá lugar a dois ou mais significados possíveis excludentes – significa uma coisa ou outra. É complexo quando dá lugar a dois ou mais significados possíveis concorrentes – significa uma coisa e outra. É implicativo quando dá lugar logicamente a outro. É defectível quando o texto está sujeito a exceções implícitas. Por fim, os textos podem ainda ser equívocos por força do modo com que redigidos, se aludindo a simples exemplos ou se contendo uma pretensão de taxatividade – em um e em outro caso a analogia e o argumento analógico são fatores de equivocidade textual.³

Essa potencial equivocidade dos textos, contudo, não é algo que possa ser eliminado simplesmente pelo apuramento linguístico na sua redação. Na verdade, a equivocidade não é propriamente um defeito objetivo do texto, mas uma decorrência de diferentes interesses e concepções a respeito da justiça dos intérpretes e da multiplicidade de concepções dogmáticas e métodos interpretativos por eles utilizados que interferem na atividade de individualização, valoração e escolha de significados. A interpretação varia de acordo com a posição assumida pelo intérprete na sociedade ou diante de determinado conflito (diferentes interesses), com as suas inclinações ético-políticas (concepções de justiça), com os conceitos jurídicos de que se vale (concepções dogmáticas) e com os argumentos interpretativos eleitos (métodos interpretativos)⁴ – e é justamente por essa razão que a vida do Direito, concretizada na sua interpretação e aplicação, não depende apenas da lógica, mas é antes de tudo experiência (“the life of the law has not been logic: it has been experience”).⁵

Uma norma é vaga porque dá lugar a dúvidas interpretativas a respeito dos casos que recaem ou não sob o seu campo de aplicação.⁶ As normas são vagas porque se valem de predicados para comunicar aquilo que esperam de seus destinatários. Os predicados aludem não a entidades individuais, mas a classes, isto é, um conjunto de entidades individuais, cujo significado depende das suas características (isto é, dos atributos do objeto) e da sua extensão (isto é, dos objetos que são alcançados pelas características). A vagueza normativa, portanto, deriva do fato de os predicados normativos terem seus confins de aplicação incertos por força da indeterminação das suas características e do seu alcance.⁷

Em segundo lugar, se é verdade que o direito é duplamente indeterminado e que, por essa razão, a norma constitui o resultado de um processo de reconstrução interpretativa, então o respeito à norma significa respeito à interpretação conferida. Isso quer dizer que quem quer que esteja preocupado em saber qual seu espaço de liberdade de ação e quais efeitos jurídicos são ligados às suas opções socioeconômicas (princípio da liberdade), preocupado em saber como deve fazer para aplicar o direito a partir da necessidade de que todos sejam efetivamente iguais perante a ordem jurídica (princípio da igualdade, que no âmbito do processo civil sempre é lembrado a partir da velha máxima “*treat like cases alike*”)⁸ e como tornar a interpretação e a aplicação do direito algo forjado nas fundações do princípio da segurança jurídica, não pode obviamente virar as costas para o problema da interpretação judicial do direito e dos precedentes daí oriundos.

Não é por acaso, portanto, que o art. 926, CPC/2015, exige “estabilidade” – que é um dos elementos do conceito de segurança jurídica – na interpretação judicial do direito. O resultado do trabalho interpretativo dos “tribunais” deve ser seguro justamente porque a interpretação não importa em simples descrição declaratória de uma norma prévia, tendo antes significado adscritivo e reconstutivo da ordem jurídica diante da indeterminação inerente à natureza do Direito.

A segurança jurídica é um meio de promoção da liberdade e da igualdade. A segurança jurídica pode ser decomposta analiticamente em cognoscibilidade, estabilidade, confiabilidade e efetividade da ordem jurídica.⁹ Nenhuma ordem jurídica pode ser considerada segura se inexistir cognoscibilidade a respeito do que deve reger determinada situação da vida. É necessário que o sistema jurídico viabilize certa a respeito de como as pessoas devem se comportar, sem o que não se pode saber exatamente o que é seguro ou não.¹⁰ Sem cognoscibilidade, não há como existir segurança de orientação (“Orientierungssicherheit”), isto é, segurança a respeito daquilo que nos é exigido pela ordem jurídica diante de dada situação concreta.¹¹ A segurança jurídica depende igualmente da ideia de estabilidade (continuidade, permanência, durabilidade), porque uma ordem jurídica sujeita a variações abruptas não provê condições mínimas para que as pessoas possam se organizar e planejar suas vidas.¹² Uma ordem jurídica segura constitui ainda uma ordem confiável, isto é, que é capaz de reagir contra surpresas injustas e proteger a firme expectativa naquilo que é conhecido e naquilo com que se concretamente planejou. A segurança jurídica depende, por fim, da capacidade de efetividade normativa. Vale dizer: de segurança de realização (“Realisierungssicherheit”).¹³ Isso porque só é seguro aquilo que tem a capacidade de se impor acaso ameaçado ou efetivamente violado. Isso explica a razão pela qual a ideia de segurança jurídica também é normalmente associada à noção de inviolabilidade normativa.¹⁴

Nesse quadro conceitual, a conexão existente entre segurança jurídica, liberdade e igualdade é evidente. O tratamento isonômico depende antes de qualquer coisa do prévio reconhecimento de qual é o Direito aplicável. Não é possível aplicar uniformemente um Direito que não se conhece. A possibilidade de autodeterminação está igualmente ligada à prévia cognoscibilidade normativa, porque sem conhecer o Direito não é possível fazer escolhas juridicamente orientadas. Sem cognoscibilidade, a propósito, não é possível escolher nem os atos que se pretende praticar, nem os efeitos jurídicos ligados à prática desses atos.

Essa é a razão pela qual o art. 926, CPC/2016, refere que a segurança jurídica (aí tomada por um dos seus elementos, a “estabilidade”) depende da interpretação que é conferida pelos tribunais ao direito. Se texto e norma não se confundem, é preciso uma conjugação de esforços entre o legislador, o juiz e a doutrina para que os textos adquiram significados normativos. Assim, quem quer que esteja interessado em definir seu espaço de liberdade, viabilizar o respeito à igualdade e contribuir para a promoção de um ambiente seguro, tem o dever de pensar na interpretação judicial do direito como sua fonte primária. Em outras palavras: como efetivas normas jurídicas oriundas do processo de interpretação, isto é, do processo de identificação, valoração e adscrição de sentido ao direito.

3. Tribunais. O art. 926, CPC/2015, refere que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Obviamente que semelhante comando pressupõe o valor normativo do trabalho interpretativo dessas Cortes:¹⁵ fosse a lei clara, unívoca e totalmente determinada antes da interpretação, bastaria a legislação para a densificação da segurança jurídica e promoção dos princípios da liberdade e da igualdade. Embora o dispositivo não faça qualquer diferenciação, é necessário distinguir as funções que os tribunais brasileiros exercem em nossa ordem jurídica, sob pena de incorrerem em posteriores equívocos no que tange às eficácias de suas respectivas decisões.¹⁶

Uma adequada identificação das funções das cortes judiciárias em determinada organização judicial é de fundamental importância por inúmeras razões. Duas, no entanto, merecem desde logo menção. A uma, desde uma perspectiva interna, uma adequada distribuição das competências entre as cortes judiciárias promove a economia processual ao viabilizar a racionalização da própria atividade judiciária. Importa que os tribunais trabalhem apenas na medida em que necessário o seu trabalho para consecução dos fins a que se encontram vinculados do ponto de vista da estrutura judiciária. É preciso que as cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor.¹⁷ A duas, desde uma perspectiva externa, a tempestividade da tutela jurisdicional, já que a abertura de determinadas instâncias judiciárias – que obviamente consome tempo para o seu percurso – só se justifica à luz do escopo para que foram pensadas dentro da organização dos tribunais.

Seja do ponto de vista daqueles que integram o sistema judiciário, seja do ponto de vista daqueles para os quais esse existe, é fácil perceber, portanto, que o ponto crucial para uma idônea organização das cortes judiciárias está centrado na função que essas devem desempenhar na ordem jurídica. Vale dizer: o parâmetro a partir do qual é possível aferir a pertinência de determinadas atividades desempenhadas pelas cortes – e, bem assim, analisar o grau de adequação da respectiva estruturação – está na perfeita individualização do escopo que essas devem perseguir.

É claro, no entanto, que esse escopo não é assinalado às cortes por elas mesmas. Não é a organização judiciária que impõe a si mesma a finalidade que tem de ser por ela buscada – é o direito processual civil que o faz. E sendo a finalidade do processo civil no Estado Constitucional dar tutela aos direitos, é natural que esse fim seja o mesmo perseguido pelas cortes encarregadas de aplicá-lo. Assim, a questão está em saber se todas as cortes que integram o sistema judiciário devem promover concomitantemente a tutela dos direitos nas suas duas dimensões ou se, do contrário, deve haver uma distribuição interna de tarefas entre os tribunais que integram a Justiça Civil.

O Código de 2015 parece inclinar-se por uma resposta afirmativa à questão. Aparentemente, todos os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC/2015). Trata-se, no entanto, de um equívoco que deve ser desde logo desfeito: uma análise mais profunda da função dessas Cortes revela a necessidade de distinção entre as suas funções.

A solução que melhor atende à necessidade de economia processual e tempestividade da tutela jurisdicional é a que partilha a tutela dos direitos em dois níveis judiciários distintos, correspondentes às duas dimensões da tutela dos direitos. O ideal é que apenas determinadas cortes sejam vocacionadas à prolação de uma decisão justa e que outras cuidem tão somente da formação de precedentes. Assim, uma organização judiciária ideal parte do pressuposto da necessidade de uma cisão entre cortes para decisão justa e cortes para formação de precedentes – ou, dito mais sinteticamente, entre Cortes de Justiça e Cortes de Precedentes.

Trata-se, de resto, de uma distinção normalmente traçada pela doutrina, que reconhece basicamente duas funções às cortes: i) resolver controvérsias (“resolution of disputes”) e ii) enriquecer o estoque de normas jurídicas (“enrichment of the supply of legal rules”).¹⁸ Vale dizer: i) prolatar decisões justas – e efetivá-las adequadamente, em sendo o caso – e ii) dar unidade ao direito mediante a formação de precedentes. Em um sistema que distribui adequadamente as tarefas entre as cortes que integram a Justiça Civil, pode-se dizer que os órgãos jurisdicionais ordinários devem cuidar da produção de decisões justas (art. 6.º, CPC/2015), sendo responsabilidade dos órgãos jurisdicionais extraordinários a promoção da unidade do Direito mediante a formação de precedentes (arts. 926 e 927, CPC/2015).

É claro que, em ambos os níveis, o material com que trabalham os juízes é muito semelhante – o processo civil, sendo meio para tutela dos direitos, depende sempre da afirmação de um caso sobre o qual discordam as partes a respeito da adequada solução. A distinção se estabelece, porém, nas diferentes maneiras com que os casos ganham relevo e colocam-se no influxo da atividade das cortes. Quando a corte está pré-ordenada para tutela dos direitos mediante decisão justa, a interpretação normativa é meio para obtenção do fim justa decisão do caso. Do contrário, quando está direcionada para tutela do direito mediante precedente, o caso concreto é apenas um meio – um verdadeiro “pretexto”¹⁹ – para formulação da adequada interpretação das normas nele envolvidas. E são justamente essas diferentes direções que podem ser estabelecidas entre o caso e suas dimensões fático-normativas que justificam a divisão de tarefas entre as Cortes de Justiça e as Cortes de Precedentes. Tendo diferentes funções, é natural que se valham igualmente de diferentes meios para bem desempenhá-las.

A distinção entre Cortes de Justiça e Cortes Supremas é essencial para uma adequada compreensão do Código de 2015. É a partir dela – e da distinção subjacente entre tutela dos direitos em uma dimensão particular (decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva do caso concreto) e em uma dimensão geral (unidade do direito) – que se pode inclusive bem identificar os

institutos que servem a um e a outro escopo. É com essa distinção, para ficarmos apenas com um exemplo, que se pode perceber o incidente de resolução de demandas repetitivas não como um incidente voltado à formação de precedentes, mas como um incidente destinado à solução de casos concretos.

3.1. Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais como Cortes de Justiça. Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais são Cortes de Justiça, isto é, cortes que devem interpretar o caso – os fatos, as provas e o direito – visando à prolação de uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para as partes (art. 6.º, CPC/2015) e ao fomento do debate a respeito das possíveis soluções interpretativas para as questões de direito por meio da jurisprudência. São cortes, portanto, em que a interpretação constitui um meio para a obtenção do fim decisão de mérito justa e efetiva.

O Código de 2015, porém, outorga força vinculante aos “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas” (art. 927, III, CPC/2015) e à “orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados” os juízes e tribunais (art. 927, V, CPC/2015). Com isso, insinua que essas cortes poderiam ter também uma função diversa daquela ligada à prolação de decisões justas e de fomento ao debate interpretativo, notadamente uma função ligada à formação de precedentes.

Trata-se de um equívoco, porém. Um precedente constitui o resultado de uma generalização de razões empreendida a partir de um julgamento realizado por uma corte encarregada de dar a última palavra a respeito do significado da questão de direito debatida. Daí que, nada obstante não seja possível negar valor vinculante às razões elaboradas a partir da jurisprudência que resulta desses incidentes e das orientações do plenário ou órgão especial das Cortes de Justiça, é preciso perceber que essa jurisprudência vinculante serve apenas para uniformização da jurisprudência dessas próprias cortes e das decisões dos juízes a elas vinculados. Não servem, por exemplo, para formar a confiança legítima capaz de levar à superação apenas para frente de determinado precedente.

3.2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça como Cortes Supremas. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são Cortes Supremas, isto é, cortes que visam à unidade do direito mediante a formação de precedentes (arts. 926 e 927, CPC/2015). São cortes, portanto, em que a aplicação do direito ao caso concreto – que constitui também seu encargo, dado que se consubstanciam em cortes de revisão e não de cassação (art. 1.034, CPC/2015) – constitui apenas um meio para a viabilização da interpretação da corte sobre uma questão de direito.

Como o Direito é duplamente indeterminado, sendo, a princípio admissível uma pluralidade de significados oriundos da sua interpretação, é imprescindível que exista um meio institucional encarregado de concentrar o significado final em que esse deve ser tomado em determinado contexto²⁰ e de velar pela sua unidade. E é precisamente essa a função que as Cortes Supremas devem desempenhar: dar unidade ao Direito mediante a sua adequada interpretação a partir do julgamento de casos a ela apresentados. Com isso, a função da Corte Suprema é proativa, sendo sua atuação destinada a orientar a adequada interpretação e aplicação do Direito por parte de toda a sociedade civil e de todos os membros do Poder Judiciário. A sua função tem no horizonte o futuro: ela atua de maneira proativa com o fim de guiar a interpretação do Direito, dando a ele unidade.²¹

A função da Corte Suprema, portanto, está em promover a unidade do Direito mediante a sua adequada interpretação. Como, de um lado, a interpretação jurídica pode dar lugar a uma multiplicidade de significados e como, de outro, o Direito encontra-se sujeito à cultura, a unidade do Direito que a Corte Suprema visa a promover tem duas direções distintas: essa é tanto retrospectiva como prospectiva. Vale dizer: a Corte Suprema visa à promoção da unidade do Direito tanto para resolver uma questão jurídica de interpretação controvertida nos tribunais, como para desenvolver o Direito diante das novas necessidades sociais, outorgando adequada solução para questões jurídicas novas.²² É sua função viabilizar “clarification, unification and development of the law”.²³

É importante perceber, nessa linha, que a função da Corte Suprema se encontra orientada para adequada interpretação do Direito. A função da Corte Suprema é uma função ligada à interpretação do Direito, capaz de servir de orientação para sua interpretação e aplicação futuras. A interpretação do Direito é o fim que move e legitima a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Como ensina a doutrina, a função da Corte “è d’interprete della legge, più e oltre che di controllore delle altrui interpretazioni/applicazioni”, sendo que essa “si svolge in occasione dell’esame di decisioni su casi concreti, ma è volta a definire il ‘significato proprio’ della norma, più che a verificare se questa è stata corretamente applicata nel singolo caso”, visando principalmente “agli impieghi futuri della norma”.²⁴ Daí que a decisão recorrida constitui apenas um meio pré-ordenado para viabilização da consecução da finalidade colimada à Corte Suprema: outorgar adequada interpretação ao Direito a fim de guiar a sua efetiva realização.²⁵ A Corte Suprema é uma corte de interpretação do Direito, não uma corte de controle de decisões judiciais.

Daí, interpretar adequadamente que o Direito não é um evento accidental na vida da Corte Suprema. Pelo contrário: interpretar adequadamente o Direito é a razão pela qual a corte existe, na medida em que sem a sua interpretação não há como viabilizar-se a unidade do Direito. Nesse modelo, a interpretação judicial da corte não é subserviente ao controle da legalidade da decisão recorrida. Sendo a função da Corte Suprema a outorga de unidade ao Direito, a sua adequada interpretação é ponto de chegada, sendo a decisão recorrida em que se consubstancia o caso concreto apenas seu ponto de partida. Isso quer dizer que a Corte Suprema, como corte de interpretação, é uma verdadeira corte de precedentes, sendo o precedente judicial ao mesmo tempo encarnação da adequada interpretação do Direito e meio para obtenção da sua unidade.

Consequentemente, tendo a interpretação da Corte Suprema valor em si mesma, sendo o móvel que legitima sua existência e outorga sua função, eventual dissenso na sua observância pelos seus próprios membros ou por outros órgãos jurisdicionais é encarado como um fato grave, como um desrespeito e um ato de rebeldia diante da sua autoridade, que deve ser evitado e, em sendo o caso, prontamente eliminado pelo sistema jurídico e pela sua própria atuação. E é exatamente por essa razão, no que agora interessa, que a “review on a writ of certiorari” pela Supreme Court estadunidense é admitida em questões importantes em que precedentes da corte foram violados ou não foram empregados quando deveriam (Rule 10, Rules of the Supreme Court)²⁶ e que o recurso de Revision para o Bundesgerichtshof alemão é admitido quando é necessário para assegurar a igualdade de tratamento diante da jurisprudência (§ 543, 2, 2, segunda parte, ZPO alemão).

Como a Corte Suprema pressupõe uma teoria da interpretação jurídica que reconhece a equivocidade potencial de todos os enunciados jurídicos, a negativa de adoção de suas razões para solução de casos idênticos ou similares constitui negação não só da sua autoridade como corte encarregada de dar a última palavra a respeito da adequada interpretação do Direito, mas acima de tudo negação da própria ideia de ordem jurídica – entendida como ordem vinculante. A rejeição – ou ignorância – das razões invocadas pela Corte Suprema no seu processo interpretativo para decisão de determinada questão idêntica ou similar constitui violação da ordem jurídica que a corte tem por missão tutelar, haja vista que, nesse contexto teórico, a norma jurídica não é outra coisa senão o resultado da sua interpretação. Em semelhante modelo, portanto, a regra do stare decisis é imprescindível para o adequado funcionamento do Direito e de todo o sistema encarregado de distribuir justiça. Reconhecer força vinculante ao precedente, nesse contexto, não é uma decorrência de uma norma de direito positivo, mas uma consequência direta do reconhecimento do caráter argumentativo da interpretação jurídica.²⁷

A propósito, é exatamente essa a linha que vem prevalecendo nas Cortes Supremas.

Já teve a oportunidade de decidir o Supremo Tribunal Federal: “Ingresso na Carreira da Magistratura. Art. 93, I, CRFB. EC 45/2004. Triênio de Atividade Jurídica Privativa de Bacharel em Direito. Requisito de Experimentação Profissional. Momento da Comprovação. Inscrição Definitiva. Constitucionalidade da Exigência. ADI 3.460. Reafirmação do Precedente pela Suprema Corte. Papel da Corte de Vértice. Unidade e Estabilidade do Direito. Vinculação aos

seus Precedentes. *Stare Decisis*. Princípios da Segurança Jurídica e da Isonomia. Ausência dos Requisitos de Superação Total (*Overruling*) do Precedente. 1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (*ratio decidendi*) da Corte na referida ação declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do *stare decisis*, que “densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação” (Mitidiero, Daniel. *Precedentes: da persuasão à vinculação*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do *stare decisis* relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos” (Mitidiero, Daniel. *Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do *stare decisis* ou da vinculação aos precedentes judiciais “é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária” (Ávila, Humberto. *Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário*. São Paulo: Malheiro, 2011). 7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado. 9. Tese reafirmada: “é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva”. 10. Recurso extraordinário desprovido”²⁸.

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: “Tenho dito, em votos justamente voltados a fazer prevalecer o entendimento consagrado no, agora superado, HC 84.078-MG, que nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de justiça criminal resulta da não vinculação de magistrados à clara divisão de competências entre os diversos órgãos judiciários, com base na qual cabe ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da Constituição da República. Em verdade, como acentua a doutrina mais abalizada: ‘a violação à interpretação ofertada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é uma insubordinação institucional da mais alta gravidade no Estado Constitucional. E isso não só pelo fato de existir uma divisão de trabalho muito clara entre Cortes de Justiça e Cortes de Precedentes, mas fundamentalmente pelo fato de a violação ao precedente encarnar um duplo e duro golpe no Direito – a um só tempo viola-se autoridade da legislação, consubstanciada na interpretação a ela conferida, e viola-se a autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça como Cortes Supremas, constitucionalmente encarregadas de dar a última palavra a respeito do significado da Constituição e da legislação infraconstitucional federal. Nesse contexto, afastar-se do precedente deve ser visto como uma falta grave em relação ao dever judicial de fidelidade ao Direito. Em duas palavras, deve ser visto como uma evidente arbitrariedade’ (Mitidiero, Daniel. *Cortes Superiores e Cortes Supremas. Do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente*. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 96-97). No mesmo sentido: ‘o juiz é uma “peça” no sistema de distribuição de justiça e não alguém que é investido de Poder estatal para satisfazer as suas vontades. Para que esse sistema possa adequadamente funcionar, cada um dos juízes deve se comportar de modo a permitir que o Judiciário possa se desincumbir do seu dever de prestar a tutela jurisdicional de forma isonômica e sem ferir a coerência do direito e a segurança jurídica. Portanto, a absurda e impensada ideia de dar ao juiz o poder de julgar o caso como quiser, não obstante ter o Tribunal Superior já conferido os seus contornos, é hoje completamente insustentável. Desconsidera que as Supremas Cortes, na atualidade, têm a função de dar sentido ao Direito e desenvolvê-lo ao lado do Legislativo’

(Marinoni, Luiz Guilherme. O STJ enquanto Corte de Precedentes: Recompreensão do Sistema Processual da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 129-130)”²⁹.

Enquanto Cortes Supremas, portanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm como função controlar a aplicação da Constituição e da legislação federal aos casos concretos – ou melhor, essa atividade é apenas um subproduto da sua função preponderante. Consequentemente, não têm como função uniformizar a aplicação da Constituição e da legislação federal a todos os casos: a função do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça está em outorgar unidade ao direito a fim de que inexistam decisões discrepantes (e, portanto, não uniformes) depois de assentados os respectivos precedentes constitucionais e federais.

3.3. Os Tribunais Regionais do Trabalho como Cortes de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho como Corte Suprema. Assim como se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, o processo civil (art. 15, CPC/2015), também as construções conceituais ligadas aos papéis das cortes judiciais podem servir para a compreensão da jurisdição trabalhista. Nessa linha, os Tribunais Regionais do Trabalho devem ser compreendidos como Cortes de Justiça, voltadas à prolação de uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva aos casos e ao fomento das soluções interpretativas para as questões de direito, ao passo que o Tribunal Superior do Trabalho deve ser visto como uma Corte Suprema, encarregado de dar unidade ao direito mediante a formação de precedentes.

4. Precedente e Jurisprudência. Diante da confusão empreendida pelos arts. 489, § 1.º, V e VI, 926 e 927, CPC/2015, que aludem indistintamente aos conceitos de precedente e jurisprudência, é preciso distingui-los. É a partir daí que se pode identificar o campo próprio de cada um em nosso direito.

O Código de 2015 introduziu o conceito de precedente no direito brasileiro. Os precedentes não são equivalentes às decisões judiciais.³⁰ Eles são razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir das decisões judiciais. O precedente é formado a partir da decisão judicial e colabora de forma contextual para a determinação do direito e para a sua previsibilidade.³¹

Mais precisamente, precedentes são razões necessárias e suficientes para solução de uma questão devidamente precisada do ponto de vista fático-jurídico obtidas por força de generalizações empreendidas a partir do julgamento de casos pela unanimidade ou pela maioria de um colegiado integrante de uma Corte Suprema. Como resultam de interpretações de textos dotados de autoridade jurídica ou de elementos não textuais integrantes da ordem jurídica formuladas por cortes encarregadas de dar a última palavra sobre o significado do direito constitucional ou do direito federal, os precedentes são sempre obrigatórios, isto é, têm sempre força vinculante. Não têm a função de ilustração do direito e não têm a função de persuasão judicial a respeito da bondade da solução nele encerrada.³² Precedentes são razões jurídicas necessárias e suficientes que resultam da justificação das decisões prolatadas pelas Cortes Supremas a pretexto de solucionar casos concretos e que servem para vincular o comportamento de todas as instâncias administrativas e judiciais do Estado Constitucional e orientar juridicamente a conduta dos indivíduos e da sociedade civil.

Daí que o conceito de precedente é um conceito qualitativo, material e funcional. Dele promana sempre eficácia vinculante.

É um conceito qualitativo, porque depende da qualidade das razões invocadas para a justificação da questão decidida – apenas as razões jurídicas, necessárias e suficientes podem ser qualificadas como precedentes. Daí por que também se costuma aludir ao precedente como a *ratio decidendi* da questão enfrentada pela Corte.³³ As razões que não são necessárias e nem suficientes para a solução da questão são *obiter dicta* e não integram a parte vinculante do julgado³⁴ (por questões sistemáticas, porém, tanto o conceito de *ratio*, como o de *obiter* serão enfrentados de forma mais aprofundada a propósito dos comentários ao art. 927, CPC/2015). Pouco importa para a sua configuração ainda se um caso ou vários casos são julgados. Nessa linha, o conceito de precedente não é um conceito quantitativo.³⁵

É um conceito material, porque depende de um caso devidamente delineado, particularizado e analisado em seus aspectos fático-jurídicos – os precedentes operam sobre fatos que delimitam o contexto fático-jurídico a partir do qual surgiram.³⁶ Em outras palavras, os precedentes são umbilicalmente dependentes da unidade fático-jurídica do caso. É por essa razão que normalmente se refere que os precedentes não operam sem referência a fatos.³⁷

É um conceito funcional, porque depende da função do órgão jurisdicional do qual promanam – os precedentes são oriundos de cortes institucionalmente encarregadas de dar a última palavra a respeito de como determinado desacordo interpretativo deve ser resolvido. Os precedentes decorrem da interpretação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça empreendida pelo colegiado de forma unânime ou por maioria a respeito de determinada questão controvertida.³⁸

Por fim, o precedente tem sempre efeito vinculante, porque encarna a interpretação da Constituição ou da legislação federal em que se consubstancia a própria norma. Se a Constituição é a interpretação da Constituição e a lei federal é a interpretação da lei federal, então é evidente que qualquer dissociação entre norma e interpretação – dentro da administração da Justiça Civil – só pode ser vista como um subterfúgio para escapar da eficácia vinculante da própria Constituição ou da lei federal. Vale dizer: da eficácia vinculante da própria ordem jurídica.

Os precedentes não se confundem com a jurisprudência.³⁹ O que os distingue da jurisprudência – ainda quando essa apresente força vinculante – é o fato de encerrarem a última palavra da administração judiciária a respeito da questão sobre a qual versam. Essa é a razão pela qual é um equívoco tratar as razões oriundas dos julgamentos das Cortes de Justiça como se precedentes fossem.⁴⁰

Tradicionalmente, a jurisprudência consubstancia-se na atividade de interpretação da lei desempenhada pelas cortes para solução de casos, cuja múltipla reiteração gera a uniformidade capaz de servir de parâmetro de controle, não gozando de autoridade formalmente vinculante.⁴¹ O Código de 2015, no entanto, claramente outorgou outro sentido ao termo jurisprudência – ao menos para determinados casos. Para essas situações, o Código exige a sua ressignificação: isso porque, ao emprestar força vinculante aos julgamentos de casos repetitivos e àqueles tomado em incidente de assunção de competência (art. 927, III) no âmbito das Cortes de Justiça e dispensar a múltipla reiteração de julgamentos como requisito para sua configuração, na medida em que basta um único julgamento mediante incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, o direito brasileiro rompe em grande parte com a caracterização tradicional da jurisprudência.

Isso quer dizer que, ao lado da jurisprudência – por assim dizer, tradicional – o direito brasileiro conhece igualmente a jurisprudência vinculante. A diferença óbvia entre uma e outra está na obrigatoriedade da jurisprudência vinculante.

É importante perceber que o Código de 2015, ao introduzir o conceito de precedentes e ressignificar os conceitos de jurisprudência e de súmulas, rigorosamente não está tratando de matéria atinente exclusivamente ao direito processual civil. Na verdade, está cuidando de conceitos ligados à teoria geral do direito, especificamente concernentes à teoria da norma – que por essa razão são transsetoriais, servindo a todo o ordenamento jurídico brasileiro.⁴² Vale dizer: os arts. 489, § 1.º, V e VI, 926 e 927, CPC/2015, são normas gerais que devem guiar a interpretação e aplicação do direito no Brasil como um todo. É por essa razão que esses conceitos impõem uma reconstrução da nossa ordem jurídica no plano das fontes e devem ser analiticamente trabalhados.

Isso quer dizer que é possível distinguir a jurisprudência vinculante da jurisprudência a partir de três dados distintos: a jurisprudência vinculante é formal (sua formação depende de uma forma específica), independe da reiteração de julgamentos (basta um único julgamento) e é obrigatória. Em contraste, a jurisprudência não depende de uma forma específica, depende da reiteração de julgamentos e não é obrigatória. É um equívoco, portanto, tratar do conceito de jurisprudência no Código de 2015 sem levar em consideração essas distinções.

5. Súmula. Tradicionalmente, as súmulas constituem um “método de trabalho”, um meio para “ordenar e facilitar a tarefa judicante” de controle da interpretação e aplicação do direito no caso concreto, não gozando igualmente de força vinculante.⁴³ Foi com esse significado que elas foram criadas entre nós 1963 por emenda ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – com o objetivo de servir de “horizonte da jurisprudência”⁴⁴ para a orientação dos seus próprios Ministros.

Com o Código de 2015, também as súmulas tiveram o seu significado alterado. Quando essas eram vistas apenas como um método de trabalho capaz de ordenar e facilitar a tarefa dos juízes – note-se que aí os destinatários das súmulas eram apenas e tão somente os próprios órgãos judiciais que compunham os tribunais que as emanavam – bastava redigi-las de forma abstrata, sem qualquer alusão aos casos concretos aos quais ligadas. Isso porque, em semelhante situação, os contornos dos casos eram conhecidos pelos julgadores por força do notório judicial. Ao reconhecer as súmulas como guias para a interpretação do direito para o sistema de administração da Justiça Civil como um todo e para a sociedade civil em geral (art. 927, II e IV, CPC/2015), previu-se o dever de identificação e de congruência das súmulas com as circunstâncias fáticas dos casos que motivaram suas criações (art. 926, § 2.º, CPC/2015).

Escapa ao legislador, porém, que precedentes e súmulas estão em níveis distintos. É um equívoco, portanto, tratá-los como se estivessem no mesmo plano, como o faz o art. 927, CPC/2015. Súmulas são enunciados que visam a retratar de modo simples e direto precedentes. Em uma palavra: são extratos.⁴⁵ Súmulas, portanto, são enunciados que visam a retratar precedentes, alocando-se em um nível linguístico acima do nível do precedente. Por essa razão é que obviamente devem se ater às circunstâncias fático-jurídicas que deram azo à formação dos precedentes subjacentes (art. 926, § 2.º, CPC/2015). Isso quer dizer que o legislador deveria ter dito que os precedentes – enunciados ou não em súmulas, vinculantes ou não – obrigam juízes e tribunais. Rigorosamente não são as súmulas que obrigam, mas os precedentes subjacentes.

6. Stare Decisis. Os precedentes – e, dentro dos seus limites, a jurisprudência vinculante – funcionam a partir da máxima “stare decisis et quia non movere”, isto é, mantenha-se o que foi decidido e não se disturbe a paz.⁴⁶ Stare decisis é a sua forma abreviada.

A regra do stare decisis tem duas dimensões: uma horizontal e outra vertical.⁴⁷

No primeiro caso, a regra constrange as próprias Cortes Supremas a seguirem os seus próprios precedentes. Quando, portanto, o art. 926, CPC/2015, refere que as Cortes Supremas têm o dever de estabilizar os próprios precedentes, o comando que daí emerge é bastante simples: as Cortes Supremas devem se ater aos próprios precedentes, observando-os, interpretando-os e aplicando-os no julgamento dos casos a elas submetidos. O fundamento imediato desse comando é o princípio da segurança jurídica.⁴⁸ O mesmo vale obviamente para as Cortes de Justiça no que tange à jurisprudência vinculante (arts. 926 e 927, III e V, CPC/2015).

No segundo, a regra constrange todos os juízes e tribunais a seguirem os precedentes e a jurisprudência vinculante oriundos das cortes que se encontram hierarquicamente acima na organização da Justiça Civil (arts. 926 e 927, CPC/2015). O fundamento imediato aí não está apenas na necessidade de segurança jurídica, mas na própria ideia de que é imprescindível outorgar a devida atenção para a autoridade das Cortes⁴⁹ – que decorre entre nós de expressas disposições constitucionais (arts. 102 e 105, CF/1988). Pressupõe-se aí o Poder Judiciário como uma verdadeira “cadeia de comando” (“chain of command”).⁵⁰

É interessante perceber, porém, que a regra do stare decisis decorre da compreensão do papel adscrito da interpretação e da necessidade daí oriunda em densificar a segurança jurídica, na medida em que a norma que resulta da interpretação judicial constitui a sua referência em um direito caracterizado pela sua dupla indeterminação. Portanto, não se trata propriamente de uma inovação normativa do Código de 2015, nada obstante constitua seguramente um acréscimo textual.

Isso quer dizer que a regra do stare decisis constitui uma norma que densifica a segurança

jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação. Nessa linha, *stare decisis* constitui uma expressão que visa a promover um estado de coisas seguro (segurança) – que de seu turno visa a viabilizar a autodeterminação pessoal (liberdade) e o tratamento isonômico (igualdade). Assim, os arts. 926 e 927, CPC/2015, apenas tornam mais visível a adoção da regra do *stare decisis* entre nós: o deslocamento de uma perspectiva cognitivista (do *juge bouche de la loi*) para uma perspectiva adscritivista da interpretação (em que se reconhece que os juízes concorrem para definição do significado do direito e que em certa medida – e apenas em certa medida⁵¹ – há *judge-made-law*) exige a alteração do referencial da segurança jurídica: não mais apenas a estática declaração da lei ou dos precedentes, mas a dinâmica reconstrução da relação entre a lei, a doutrina e os precedentes a partir de parâmetros racionais de justificação.

A conclusão que se pode retirar daí é bastante simples. A vigência de um sistema de precedentes obrigatórios independe de autorização textual da Constituição.⁵² Compreendida a interpretação como uma atividade de reconstrução e de outorga de sentido ao material legislativo, a segurança jurídica só pode ser adequadamente densificada, se levar em consideração o significado normativo dos textos fixado pelas Cortes Supremas a partir do julgamento de casos. Em outras palavras, não é necessária emenda constitucional para a adoção de um sistema de precedentes vinculantes no direito brasileiro. Rigorosamente, não seria nem mesmo necessário que o legislador brasileiro tivesse enfrentando o tema nos arts. 926 e 927, CPC/2015, para que tivéssemos precedentes vinculantes em nossa ordem jurídica.

7. Dever de Considerar, Dever de Interpretar e Dever de Aplicar. A regra do *stare decisis* implica dever de considerar, dever de interpretar e, em sendo o caso, dever de aplicar o precedente para a solução do caso concreto.⁵³ Esse é conteúdo normativo dos arts. 489, § 1.º, IV, V e VI, 926 e 927, CPC/2015.

As Cortes Supremas devem dar unidade ao direito e mantê-lo seguro. As Cortes de Justiça têm o dever de uniformizar a jurisprudência e assim conservá-la. Os tribunais e juízes observarão os precedentes e a jurisprudência vinculante, identificando-os, enfrentando-os e, em sendo o caso, aplicando-os para a solução do caso.

Obviamente que o dever de unidade e o dever de uniformização, acompanhados do dever de estabilização, só podem significar uma coisa: que as Cortes Supremas e as Cortes de Justiça têm o dever de não variar frivolamente os seus padrões decisórios. Em outras palavras, devem considerar os precedentes e a jurisprudência vinculante, existentes sobre o caso, devem identificar os seus significados normativos e devem aplicá-los, em sendo o caso, para a sua resolução. Vale dizer: estão vinculadas aos precedentes e à jurisprudência uniforme.

É à luz desse contexto normativo que deve ser lido o dever de observar constante do art. 927, CPC/2015: “observar” significa “dever de considerar”, isto é, levar em conta os precedentes e a jurisprudência vinculante existentes (arts. 1.º, 140, 489, § 1.º, IV, 926 e 927, CPC/2015), “dever de interpretar”, isto é, identificar o significado dos precedentes e da jurisprudência vinculante (arts. 489, § 1.º, V, 926 e 927, CPC/2015) e, chegando à conclusão que o precedente ou a jurisprudência vinculante se amolda ao caso, tem o “dever de aplicá-lo”, demonstrando a congruência existente (arts. 489, § 1.º, VI, 926 e 927, CPC/2015).

8. Íntegra e Coerente. O art. 926, CPC/2015, refere que a “jurisprudência” deve ser “íntegra e coerente”. Com isso, procurou caracterizar nesse dispositivo, o direito como integridade (“law as integrity”),⁵⁴ encampando uma conhecida e controvertida proposta existente a respeito na teoria do direito.⁵⁵ A fim de que se possa compreender o seu significado e avaliar o respectivo impacto no sistema do Código de 2015, cumpre entender o papel que o conceito de integridade desempenha dentro dessa peculiar proposta teórica, indagar se existem outros elementos normativos capazes de apontar diferentes soluções e perceber o real impacto que semelhante tomada de posição textual do legislador pode ter em termos normativos.

Na segunda metade dos Novecentos é publicada a obra *The Concept of Law*, de Herbert Hart, em que se procura dialogar – sem extrapolar as fronteiras do positivismo jurídico⁵⁶ – com o

pensamento de John Austin, Jeremy Bentham e, mais remotamente, de Thomas Hobbes.⁵⁷ No que agora interessa, partindo da percepção da “open texture of Law”, Hart separa duas grandes categorias de casos: os casos previstos por normas e aqueles não previstos. A necessidade de distinção entre as categorias é justificada pela circunstância de, nos primeiros, existir uma resposta clara e correta provida pelo Direito, ao passo que nos segundos, não. Nessa linha, nos casos não previstos, isto é, fora da rotina, os juízes teriam maior discricionariedade para solucioná-los. Vale dizer: inexistiria uma resposta correta previamente dada.⁵⁸

Contra essa tese, Ronald Dworkin escreve alguns ensaios que posteriormente foram compilados nos livros *Taking Rights Seriously* e *A Matter of Principle*, sustentando a necessidade de se fechar os espaços de discricionariedade judicial – deixados em aberto por Herbert Hart – com o uso dos princípios morais e das diretrizes políticas existentes em uma dada comunidade política a fim de que se chegue a uma resposta correta (one right answer) também para os casos difíceis (hard cases).⁵⁹ Na verdade, as ideias expostas por Dworkin nesses trabalhos procuram se colocar em um contexto mais amplo de questionamento do positivismo jurídico como um todo.⁶⁰

Visando à viabilização de uma resposta correta para os problemas jurídicos, Dworkin propõe, logo em seguida em *Law's Empire*, uma metodologia interpretativa que seria capaz na sua avaliação de guiar o intérprete para a obtenção da resposta correta para todos os problemas jurídicos. É justamente no centro dessa metodologia que se encontra alocado o conceito de integridade – o qual serviria, desde que devidamente manejado por um juiz Hércules, para assegurar a correção do resultado interpretativo.⁶¹

O método proposto conta com três fases – pré-interpretativa, interpretativa e pós-interpretativa. Na primeira, o intérprete teria que identificar e recolher as normas (“rules and standards”) existentes sobre o caso. Na segunda, teria que identificar as possíveis justificações dessas normas – pelo menos a fim de que se possa percebê-las como já existentes e não como criadas pelo próprio intérprete. Nessa fase, as justificações devem ser confrontadas argumentativamente a fim de que se possa chegar à conclusão de qual é efetivamente o sentido normativo do material recolhido na fase pré-interpretativa.⁶² Trata-se de empreendimento que deve ser conduzido justamente mediante os conceitos de coerência e integridade.⁶³ Por fim, na terceira, teria que revisar a justificação encontrada para as normas visando a aferição da sua efetiva correção.⁶⁴

Todavia, ao lado do conceito de integridade, mencionado no art. 926, o Código de 2015 também adota os conceitos de proporcionalidade, razoabilidade (art. 8.º, CPC/2015) e de ponderação (art. 489, § 2.º, CPC/2015) como critérios – ou, mais propriamente, postulados – interpretativos e aplicativos. Como é sabido, também a ponderação (*Abwägung*) constitui um critério notoriamente ligado a uma proposta teórica igualmente bastante conhecida no âmbito da teoria do direito.⁶⁵ Mais ainda: o próprio conceito de coerência presente no art. 926, CPC/2015, também é normalmente trabalhado pela doutrina despregado do conceito de integridade.⁶⁶

Isso significa que o fato de o legislador ter aludido em determinada passagem ao conceito de integridade, não assegura por si só que a reconstrução sistemática do Código deva em torno dele girar.⁶⁷ Como é sabido, tanto a norma como o sistema são resultados interpretativos.⁶⁸

A integridade constitui um meio para a obtenção de uma resposta correta para os problemas jurídicos – com o que obviamente pressupõe a existência de uma única resposta correta como o objetivo da interpretação judicial. Ocorre que a natureza duplamente indeterminada do direito⁶⁹ e o seu papel de instância reguladora, voltada para a necessidade de assegurar um ambiente de tolerância em relação aos desacordos sociais, a partir de critérios capazes de identificar o que é o Direito e que marcam as democracias constitucionais contemporâneas,⁷⁰ sugerem justamente a inexistência de uma resposta que possa ser qualificada como unívoca para os problemas jurídicos. Em outras palavras, o fim visado pelo meio não é obtível – pelo menos não dentro da justiça dos homens. Daí surge naturalmente a pergunta pela sua efetiva utilidade.⁷¹

Nessa perspectiva, o art. 926, CPC/2015, lido sistematicamente, impõe que as Cortes Supremas

persigam não uma “jurisprudência” que possa ser qualificada como “íntegra e coerente”, mas sim a “unidade do direito”. Uma ordem jurídica pautada pela unidade é uma ordem que se vale da segurança jurídica para a promoção da liberdade e a proteção da igualdade de todos perante o Direito (arts. 1.º e 5.º, CF/1988, e 1.º, 8.º e 926, CPC/2015). Uma ordem jurídica que busca a sua unidade é uma ordem que procura estabelecer os devidos vínculos de hierarquização e de coerência entre as fontes ao longo de um processo interpretativo guiado pela racionalidade⁷² (arts. 489, § 1.º, e 926, CPC/2015). Por fim, uma ordem jurídica voltada para a unidade é uma ordem que universaliza os resultados interpretativos, isto é, que os torna replicáveis para a solução de casos futuros (arts. 926 e 927, CPC/2015).

A obtenção da unidade do direito tem a ver, portanto, com a hierarquia, com a coerência e com a universalidade do direito.

A hierarquia tem por objeto as relações resultantes da estrutura escalonada da ordem jurídica (a intuitiva “Stufenbau” kelseniana),⁷³ resolvendo-se no plano da validade normativa. Ainda, funciona a partir de uma sistematização linear (“a norma superior constitui o fundamento da norma inferior”), simples (“baseada numa relação de hierarquia linear entre as normas”) e não gradual (“as normas estão, ou não, sistematizadas enquanto hierarquicamente postas”).⁷⁴

A coerência exige que a interpretação judicial possa ser capaz de ser reconduzida a “um conjunto, internamente consistente, formal e materialmente, de princípios e regras” amalgamadas por “princípios fundamentais” comuns.⁷⁵ Ao contrário da hierarquia, a coerência tem por objeto as conexões de sentido entre as diferentes normas que compõem a ordem jurídica, resolvendo-se no plano da eficácia. Ainda, pode ser obtida a partir de uma sistematização circular (“as normas superiores condicionam as inferiores, e as inferiores contribuem para determinar os elementos das superiores”), complexa (“não há apenas uma relação vertical de hierarquia, mas várias relações horizontais, verticais e entrelaçadas entre as normas”) e gradual (“a sistematização será tanto mais perfeita quanto maior for a intensidade da observância dos seus vários critérios”).⁷⁶

A coerência é uma conexão de sentidos que se estabelece entre as normas que pode ser formal ou substancial. A coerência formal existe quando há uma relação normativa consistente (em que inexiste contradição) e completa (em que há inteireza e coesão). A ausência de quaisquer desses elementos leva à ausência de coerência. A coerência substancial existe quanto maior for a dependência recíproca e afinidade entre as normas. Ao contrário do aspecto formal da coerência, o seu aspecto substancial permite graduação. Vale dizer: enquanto a coerência formal existe ou não, a coerência material pode existir em maior ou menor medida.⁷⁷

A unidade do Direito exige ainda que o resultado da interpretação tenha condições de ser universalizado.⁷⁸ Em outras palavras, a interpretação tem que ter condições de ser replicável para os casos futuros idênticos ou semelhantes. Sem replicabilidade (“replicability”), não há objetividade e imparcialidade na interpretação.⁷⁹

Em resumo, de acordo com o art. 926, CPC/2015, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de outorgar unidade ao Direito. Esse dever é composto de outros três deveres: o de respeito à hierarquia normativa, de promoção da coerência normativa e de universalização das suas interpretações.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – os enunciados de súmula vinculante;

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1.º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1.º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2.º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3.º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4.º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

§ 5.º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

1. Juízes e Tribunais Observarão. Assim como os Tribunais devem observar os próprios precedentes (*stare decisis* horizontal – art. 926, CPC/2015), juízes e Tribunais a eles vinculados devem também observá-los (*stare decisis* vertical, art. 927, CPC/2015). Vale o mesmo para a jurisprudência vinculante (art. 927, CPC/2015).

O art. 927, CPC/2015, refere que juízes e tribunais observarão os precedentes e a jurisprudência vinculante. O significado do termo “observarão” é triplo: dever de considerar, dever de interpretar e, em sendo o caso, dever de aplicar o precedente ou a jurisprudência vinculante atinente ao caso. Isso quer dizer que existe no direito brasileiro um forte efeito vinculante dos precedentes (“strong-binding-force”).⁸⁰

Ser fiel ao precedente significa respeitar as razões necessárias e suficientes empregadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para solução de determinada questão de um caso.⁸¹ Significa, portanto, respeito à *ratio decidendi*, isto é, às razões necessárias e suficientes constantes da justificação judicial ofertadas pelas Cortes Supremas para solução de determinada questão de um caso.⁸² Tendo como matéria-prima a decisão, o precedente trabalha essencialmente sobre fatos jurídicos relevantes que compõem o caso examinado e que determinaram a prolação da decisão da maneira como foi prolatada. Nessa perspectiva, operam inevitavelmente dentro da moldura dos casos dos quais decorrem, sendo por essa razão, necessariamente contextuais. O mesmo vale para a jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça.

A compreensão da norma como resultado da interpretação judicial do Direito retira o foco exclusivamente da lei e coloca-o também nas razões invocadas para a solução de casos pelo Poder Judiciário, de modo que a liberdade e a igualdade, a partir daí, devem ser pensadas também diante do produto da interpretação e a segurança jurídica diante de um quadro que englobe tanto a atividade interpretativa como o seu resultado. Dessa forma, o precedente, sendo fruto da reconstrução do sentido da legislação, passa a ser o derradeiro garante da liberdade, da igualdade e da segurança jurídica no Estado Constitucional. Nessa linha, o precedente judicial constitui fonte primária do Direito,⁸³ cuja eficácia vinculante não decorre nem do costume judicial e da doutrina,⁸⁴ nem da bondade e da congruência social das razões invocadas⁸⁵ e nem de uma norma constitucional ou legal que assim o determine,⁸⁶ mas da força institucionalizante da interpretação jurisdicional,⁸⁷ isto é, da força institucional da jurisdição como função básica do Estado. O mesmo vale para a jurisprudência vinculante.

Essa é a razão pela qual o precedente e a jurisprudência vinculante têm força normativa entre nós. Essa é a razão pela qual juízes e Tribunais têm o dever de observar os precedentes e a

jurisprudência vinculante.

Sendo parte integrante do ordenamento jurídico, o precedente deve ser levado em consideração como parâmetro necessário para aferição da igualdade de todos perante a ordem jurídica, para conformação do espaço de liberdade de cada um e para a densificação da segurança jurídica. Isso implica que casos iguais sejam tratados de forma igual por todos os órgãos jurisdicionais a partir do conteúdo dos precedentes e que a exigência de cognoscibilidade inerente à segurança jurídica leve em consideração o processo de interpretação judicial do Direito e o seu resultado.⁸⁸

Isso quer dizer que a recusa à aplicação de precedente judicial constitui recusa de vinculação ao Direito. É preciso que isso seja dito claramente. Em uma perspectiva lógico-argumentativa – e, no fundo, em toda e qualquer perspectiva teórica que reconheça a diferença entre texto e norma – é imprescindível a vigência da regra do *stare decisis* como condição *sine qua non* do Estado Constitucional.⁸⁹ Como observa a doutrina, “there is a peculiar relationship between the idea of following precedents and the idea that there are rules of law that are established by judicial decisions”.⁹⁰ Essa relação peculiar é muito clara: se o Direito não é apenas revelado pela decisão judicial, se o texto legal não é portador de um único sentido intrínseco que é apenas declarado pelo Poder Judiciário, mas é de algum modo afirmado (“established”) pelas decisões judiciais, então a fidelidade ao precedente é o meio pelo qual a ordem jurídica ganha unidade, tornando-se um ambiente seguro, livre e isonômico,⁹¹ predados sem os quais nenhuma ordem jurídica pode ser reconhecida como legítima. Essas são as razões pelas quais os precedentes são vinculantes na nossa ordem jurídica.

Há, no entanto, quem negue a possibilidade de aludir-se propriamente a precedentes vinculantes, preferindo falar a respeito em “forza del precedente per indicare il grado, o l’intensità con cui esso riesce ad influire sulle decisioni successive”.⁹² Nessa linha, refere criticamente a doutrina que “da un lato, non è appropriato dire che il precedente di common law è vincolante, nel senso che ne derivi un vero e proprio obbligo del secondo giudice di attenersi al precedente. È noto che anche nel sistema inglese, che pare essere quello in cui il precedente è dotato di maggiore efficacia, i giudici usano numerose e sofisticate tecniche argomentative, tra cui il *distinguishing* e l’*overruling*, al fine di non considerarsi vincolati dal precedente che non intendono seguire. Rimane dunque vero che in quell’ordinamento il precedente è dotato di notevole forza, in quanto ci si aspetta che in linea di massima il giudice successivo lo segua – come in fatti solitamente accade –, ma questa forza è sempre *defeasible*, poichè il secondo giudice può disattendere il precedente quando ritenga opportuno farlo al fine di formulare una soluzione più giusta del caso che deve decidere”.⁹³

Todavia, é preciso ter presente, de um lado, que *distinguishing* e *overruling* são técnicas que justamente pressupõem a força vinculante do precedente. A distinção serve justamente para mostrar que não há analogia possível entre os casos, de modo que o caso está fora do âmbito do precedente.⁹⁴ O *overruling* é a superação total do precedente e constitui um poder dado apenas aos órgãos que foram encarregados da sua formulação mediante um complexo encargo argumentativo, que envolve a demonstração do desgaste do precedente no que tange à sua congruência social e consistência sistêmica.⁹⁵ A distinção e a superação, portanto, são técnicas que, longe de infirmarem a vinculação ao precedente, a pressupõem. De outro, em uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação, a *defeasibility* está longe de ser uma característica apenas do precedente judicial. Como observa a doutrina, a superabilidade constante das normas é uma característica do Direito como um todo,⁹⁶ de modo que semelhante argumento também não serve para infirmar a força vinculante do precedente.

Em outras palavras: uma vez identificado um precedente ou a existência de jurisprudência vinculante, juízes e Tribunais têm o dever de aplicá-lo para a solução do caso concreto. Fora daí, há recusa de vinculação ao Direito.

2. Precedente e Jurisprudência. A força vinculante do precedente judicial oriundo das Cortes Supremas não depende de uma manifestação específica do direito positivo. É consequência de

uma determinada concepção a respeito do que é o Direito e do valor que deve ser reconhecido à interpretação. A vinculação ao precedente resulta, pois, da consideração do ordenamento jurídico como um todo e, especialmente, do valor que deve ser dado à liberdade, à igualdade e à segurança jurídica.

Assente semelhante premissa, é preciso identificar uma série de equívocos presentes no art. 927, CPC/2015. Em primeiro lugar, existe uma confusão entre precedente constitucional e controle de constitucionalidade (art. 927, I, CPC/2015). Em segundo lugar, existe uma indevida assimilação entre decisão e precedente (art. 927, I, III e V, CPC/2015). Em terceiro lugar, uma indevida assimilação dos precedentes a julgamentos de casos repetitivos (art. 927, III, CPC/2015). Em quarto lugar, uma equivocada compreensão do significado das súmulas no nosso sistema jurídico (art. 927, II e IV, CPC/2015). Em quinto lugar, por fim, uma indevida limitação do campo dos precedentes a determinadas formas de julgamento (art. 927, III e V, CPC/2015). Todos esses equívocos devem ser desfeitos a fim de que se possa bem entender o papel do precedente e da jurisprudência no direito brasileiro.

2.1. Precedente Constitucional e Controle de Constitucionalidade. O art. 927, I, CPC/2015, refere que os juízes e Tribunais observarão “as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. O controle abstrato de constitucionalidade está disciplinado entre nós pelas Leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999.

O dispositivo acaba incidindo em uma confusão entre precedente constitucional e controle de constitucionalidade ou, em outras palavras, entre razões constantes da fundamentação e dispositivo da decisão. No controle abstrato de constitucionalidade (ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental) o que há é formação de coisa julgada erga omnes em torno do dispositivo que aplica a Constituição para a solução da dúvida constitucional (arts. 28, parágrafo único, Lei 9.868, de 1999 e 10, § 3.º, Lei 9.882, de 1999). Daí o efeito vinculante, o qual decorre do dispositivo e não das razões propriamente ditas. As razões servem para iluminar o alcance do dispositivo.

Quando juízes e Tribunais seguem decisões do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, aplicando ou deixando de aplicar o dispositivo objeto da controvérsia constitucional, eles se submetem à coisa julgada erga omnes e ao efeito vinculante daí oriundo. O que há é uma resolução da questão constitucional com o dispositivo da decisão formada no processo de controle de constitucionalidade. Aí não há vinculação ao precedente constitucional: há pura e simples vinculação à coisa julgada formada em torno do dispositivo da decisão.

É claro, porém, que é possível ler o dispositivo – e essa é a sua leitura apropriada – de modo a entender que o legislador esclareceu que não só o dispositivo da decisão de constitucionalidade vincula (arts. 28, parágrafo único, Lei 9.868, de 1999, e 10, § 3.º, Lei 9.882, de 1999), mas que também as razões constantes do julgado podem servir como precedente para a solução de questões análogas, isto é, para a solução de dúvidas constitucionais semelhantes. Vale dizer: o art. 927, I, CPC/2015, esclarece que a ratio decidendi emergente das decisões tomadas em controle abstrato de constitucionalidade vinculam juízes e tribunais.⁹⁷

2.2. Precedentes. Os precedentes emanam exclusivamente das Cortes Supremas e são sempre obrigatórios – isto é, vinculantes.⁹⁸ Do contrário, poderiam ser confundidos com simples exemplos.⁹⁹ Embora o Código de 2015 tenha introduzido legislativamente o conceito de precedente entre nós, a autoridade do precedente obviamente dele não decorre. Na verdade, a autoridade do precedente decorre do fato desse encarnar o significado que é adscrito ao direito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer: a autoridade do precedente é a própria autoridade do direito interpretado e a autoridade de quem o interpreta.

Dois equívocos podem ser percebidos no art. 927, III, CPC/2015.

O primeiro diz respeito à confusão entre decisão e precedente. O dispositivo refere que os juízes e tribunais observarão a “acórdãos” de “julgamentos” (art. 927, III, CPC/2015), quando na verdade deveria, no mínimo, ter feito referência às razões constantes da fundamentação dos

acórdãos. Porém, ainda que tivesse corretamente aludido às razões, faltaria substância ao dispositivo, porque nada diz a respeito da qualidade das razões – nem todas as razões devem ser seguidas, mas apenas as necessárias e suficientes para definição da questão – e da forma de julgamento necessária para que as Cortes Supremas bem possam desempenhar as suas funções de outorga de unidade ao direito: decisão colegiada – e não plural – e com fundamentação unânime ou majoritária – e não com fundamentação concorrente.¹⁰⁰

O segundo diz respeito à assimilação indevida entre precedente e casos repetitivos. Isso porque o art. 927, CPC/2015, deixa de arrolar hipóteses em que pode haver a formação de precedentes ainda que não se trate de casos repetitivos. Isso quer dizer que o art. 927, CPC/2015, deve ser visto como meramente exemplificativo.

O art. 927, CPC/2015, é meramente exemplificativo, tendo em conta que deixa de mencionar que a partir do julgamento de recursos extraordinários e de recursos especiais não repetitivos julgados pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e a partir do julgamento de embargos de divergência é possível formar precedentes. A uma, se o recurso extraordinário e o recurso especial por si só visam a viabilizar a outorga de unidade ao direito, então é óbvio que não é necessário ligar necessariamente a formação de precedentes mediante esses recursos ao incidente de assunção de competência (art. 947, CPC/2015) ou à forma repetitiva (arts. 1.036 a 1.041, CPC/2015) – como, nada obstante, sugere o art. 927, III, CPC/2015. A duas, o recurso de embargos de divergência visa justamente a viabilizar a composição de eventuais dissensos entre decisões no âmbito das Cortes Supremas, de modo que a sua função só pode estar evidentemente atada à superação do dissenso e à busca pela unidade do direito. Em outras palavras: à formação de precedentes. Como é evidente, num e noutro caso pode simplesmente não ser necessária a pronúncia da Seção, da Corte Especial ou do Pleno para o julgamento da questão a fim de que se obtenha a formação de um precedente.

Resumindo, precedentes constitucionais e precedentes federais podem ser formados não só a partir de julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, mas também a partir das decisões de recursos extraordinários e especiais não repetitivos e de embargos de divergência. Isso decorre do fato de o conceito de precedente ser um conceito qualitativo, material e funcional em nossa ordem jurídica.

2.3. Jurisprudência Vinculante. Se o conceito de precedente pode ser visto a partir de um prisma unitário na ordem jurídica brasileira, o mesmo não se passa com o conceito de jurisprudência, na medida em que é preciso distinguir entre a jurisprudência e a jurisprudência vinculante. Em comum, ambas têm apenas o fato de resultarem da interpretação formulada pelas Cortes de Justiça, isto é, pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais de Justiça.

Ao contrário da jurisprudência, a jurisprudência vinculante não constitui um conjunto de julgamentos de casos em um dado sentido. Como deixam claro os arts. 927, III e V, 947 e 976 a 987, CPC/2015, a jurisprudência vinculante depende mais da forma com que o julgamento é realizado – mediante incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de controle de constitucionalidade – do que propriamente da reiteração de vários julgados.

Isso quer dizer que é possível distinguir a jurisprudência vinculante da jurisprudência a partir de três dados distintos: a jurisprudência vinculante é formal (sua formação depende de uma forma específica), independe da reiteração de julgamentos (basta um único julgamento) e é obrigatória. Em contraste, a jurisprudência não depende de uma forma específica, depende da reiteração de julgamentos e não é obrigatória. É um equívoco, portanto, tratar do conceito de jurisprudência no Código de 2015 sem levar em consideração essas distinções.

Dito isso, é necessário repetir quanto à jurisprudência vinculante aquilo que já se disse quanto aos precedentes. O art. 927, III, CPC/2015, é também aqui, qualitativa e funcionalmente incompleto, porque alude a “acórdãos” de “julgamentos” de incidente de assunção de competência e de incidente de resolução de demandas repetitivas, quando na verdade deveria no mínimo ter feito referência às razões constantes da fundamentação dos acórdãos. No entanto, ainda que tivesse

corretamente aludido às razões, faltaria substância ao dispositivo, porque nada diz a respeito da qualidade das razões – nem todas as razões devem ser seguidas, mas apenas as necessárias e suficientes para definição da questão – e da forma de julgamento necessária para que as Cortes de Justiça possam bem desempenhar as suas funções de exploração de significados normativos e de uniformização da jurisprudência. Como é necessário também aqui individualizar razões, importa que essas Cortes atuem nesses incidentes com decisões colegiadas – e não plurais – e com fundamentações unânimes ou majoritárias – e não com fundamentações concorrentes.

Identificadas as razões determinantes da jurisprudência vinculante, as Cortes de Justiça e os juízes a elas vinculados estão obrigados a segui-la. Não se trata igualmente de simples exemplo, conselho ou recomendação. A jurisprudência vinculante constitui norma jurídica e deve ser considerada, interpretada e, em sendo o caso, aplicada para a solução dos casos submetidos à jurisdição.

Naturalmente, porém, uma vez formado precedente das Cortes Supremas em sentido contrário à jurisprudência vinculante, essa fica ultrapassada e perde a sua eficácia normativa. Em outras palavras, a partir daí os juízes e Tribunais possam a dever respeito ao precedente formado em sentido contrário, sob pena de invertida a lógica que preside a função de cada um dos Tribunais que compõem o sistema encarregado de administrar a Justiça Civil em nosso país.

2.4. Súmulas. O art. 927, II e IV, CPC/2015, refere que os juízes e Tribunais observarão “os enunciados de súmula vinculante” e os “enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”. O art. 926, § 2.º, CPC/2015, prescreve que “ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.

Daí que é possível concluir duas coisas: em primeiro lugar, não são propriamente as súmulas que vinculam. O que vinculam são os precedentes subjacentes às súmulas. Em segundo lugar, as súmulas devem ser interpretadas e aplicadas à luz dos precedentes a partir dos quais enunciadas. O que o art. 927, II e IV, CPC/2015, prescreve é a vinculação aos precedentes devidamente retratados nas súmulas.

3. Adequação do Procedimento por Força de Precedente ou Jurisprudência Vinculante. Como o Código de 2015 indevidamente procura vincular a força dos precedentes das Cortes Supremas a determinadas formas de julgamento (art. 927, III e V, CPC/2015), marcadamente a julgamentos de recursos repetitivos, determinados institutos processuais que servem para adequação do procedimento à luz da existência de precedentes devem ser redimensionados. Isso porque se trata de adequação erigida não apenas no interesse da eficiência do sistema judiciário, mas, sobretudo no interesse da promoção da unidade do direito.

Visto o precedente como um conceito qualitativo, material e funcional, é preciso redimensionar a tutela da evidência, a improcedência liminar, os poderes do relator, os poderes do presidente ou do vice-presidente das Cortes de Justiça para admissão de recursos extraordinários e especiais, a disciplina do recurso extraordinário e do recurso especial e o cabimento da ação de reclamação. Em todas essas passagens o equívoco do legislador deixou seu dolorido rastro.

O art. 311, II, CPC/2015, refere que o juiz pode prestar tutela da evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Isso quer dizer que nessa hipótese o juiz poderá proferir uma decisão provisória dotada de eficácia imediata, fundada em cognição sumária, visando a equacionar o ônus do tempo do processo de acordo com a maior probabilidade apresentada pela posição jurídica do autor. Essa decisão permitirá ao autor fruir desde logo do bem da vida que veio buscar no processo, fazendo pesar sobre o réu o ônus do tempo necessário para a obtenção da tutela definitiva.

No entanto, é preciso ter presente que o que demonstra a inconsistência da defesa do réu – hipótese geral em que se insere a hipótese particular concernente aos precedentes e à jurisprudência vinculante – e autoriza a tutela da evidência não é o fato de a tese do autor

encontrar-se fundamentada em “julgamento de casos repetitivos” (isto é, incidente de resolução de demandas repetitivas e recurso especial e extraordinário repetitivos, art. 928, CPC/2015) ou em “súmula vinculante” (art. 927, II, CPC/2015). É o fato de o pedido formulado encontrar-se fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência vinculante dos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de recursos repetitivos, assim como a jurisprudência vinculante pode ou não ser oriunda de incidente de resolução de demandas repetitivas (nada obsta, por exemplo, que seja oriunda de incidente de assunção de competência).

O art. 332, CPC/2015, autoriza, nas causas que dispensem a fase instrutória, o julgamento de improcedência liminar, quando o pedido formulado contrariar: “I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local”. O julgamento de improcedência liminar determina a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC/2015).

Todavia, não são só os precedentes retratados em súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ou oriundos do julgamento de recursos repetitivos que geram a possibilidade de improcedência liminar do pedido. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, retratados ou não em súmulas, decorrentes ou não de julgamento de casos repetitivos, autorizam a improcedência liminar do pedido. Se a improcedência liminar constitui forma de abreviação procedimental ligada à necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º, CPC/2015) e fundada na percepção de que é inútil prosseguir com o processo, dada a imediata percepção judicial de ausência de razão pelo autor, então não há por que limitá-la a precedentes sumulados ou a casos repetidos. Também diante dos demais precedentes – não sumulados e não oriundos de casos repetidos – é apropriado pensar-se em abreviar o procedimento a fim de que se promova a tempestividade da tutela jurisdicional.

O art. 932, IV e V, CPC, autoriza o relator a negar liminarmente provimento ao recurso ou, depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento ao recurso contrário a: “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. Nesses casos, o relator não precisará levar ao colegiado o recurso, podendo desde logo julgá-lo monocraticamente.

Exatamente os mesmos problemas presentes no art. 332, CPC/2015, reaparecem no art. 932, IV e V, CPC/2015. Se a outorga de poderes ao relator dos recursos constitui forma de abreviação procedimental ligada à necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º, CPC/2015) e fundada na percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente, então não há por que limitar o exercício desses poderes a precedentes sumulados ou a casos repetidos. Também diante dos demais precedentes – não sumulados e não oriundos de casos repetidos – é apropriado pensar-se em abreviar o procedimento a fim de que se promova a tempestividade da tutela jurisdicional. Assim, não são só os precedentes retratados em súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ou oriundos do julgamento de recursos repetitivos que geram a possibilidade de julgamentos monocráticos. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, retratados ou não em súmulas, decorrentes ou não de julgamento de casos repetitivos, igualmente autorizam a invocação de semelhantes poderes.

O art. 1.030, I, b, CPC/2015, refere que é competência do presidente ou do vice-presidente da Corte de Justiça, em que proferida a decisão recorrida, realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial, tendo que “a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”. O que autoriza, porém, o não conhecimento do recurso especial é o fato de o recorrente interpor o recurso sem a alegação de qualquer distinção ou sem a alegação da necessidade de superação por fundamento não considerado anteriormente diante de qualquer precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na decisão recorrida. Em outras palavras, é indevida a restrição dos poderes do presidente ou do vice-presidente da Corte de Justiça que prolatou a decisão recorrida aos precedentes oriundos dos recursos especiais repetitivos.

Ainda, a ligação indevida realizada pelo legislador entre unidade do direito, força vinculante e casos repetitivos pode ser sentida na disciplina do recurso extraordinário e do recurso especial. É claro que não há qualquer sentido em obrigar o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça a julgar inúmeras e inúmeras vezes a mesma questão, sendo essa a razão pela qual está em perfeita sintonia com a compreensão dessas cortes como cortes de interpretação e de precedentes a sistemática de julgamento em bloco prevista nos arts. 1.036 a 1.041, CPC/2015.¹⁰¹

Nada obstante, isso não quer dizer que apenas os casos repetitivos demandem certas particularidades procedimentais que se encontram presentes textualmente apenas na disciplina do julgamento dos recursos repetitivos. Como o legislador imaginou que os precedentes são na sua imensa maioria oriundos somente dos julgamentos dos recursos repetitivos (art. 927, III, CPC/2015), apenas em relação a esses, previu a necessidade de identificação “com precisão” da questão a ser submetida a julgamento (art. 1.037, I, CPC/2015), de “solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno” e de “fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento” (art. 1.038, I e II, CPC/2015). Porém, é necessário que todo e qualquer recurso extraordinário ou recurso especial tenha identificada com precisão a questão que será debatida e submetida a julgamento. Além disso, sendo conveniente, nada obsta que o relator promova uma abertura para o debate com a sociedade civil e com experts na questão submetida a julgamento, independentemente da sua natureza repetitiva. O que exige ou viabiliza semelhantes providências não é obviamente a repetitividade, mas o valor de precedente que é possível extrair do julgamento da questão.

Os precedentes não se encontram umbilicalmente ligados aos casos repetitivos e nem mesmo a jurisprudência vinculante apresenta semelhante correlação. Para os precedentes o que interessa é a qualitatividade, a materialidade e a funcionalidade. Para a jurisprudência vinculante, a qualitatividade, a materialidade e a formalidade. Com essas coordenadas é possível conceituar analiticamente precedente, jurisprudência vinculante e jurisprudência no Código de 2015.

Violado precedente ou jurisprudência vinculante, por fim, o meio adequado para fazer valer as razões para a solução do caso concreto é o recurso cabível da decisão que o violou. As vias recursais são as vias adequadas para a tutela do precedente ou da jurisprudência vinculante. O art. 988, CPC/2015, porém, permite a propositura de ação de reclamação para garantir a observância do conteúdo de precedente, enunciado em súmula vinculante e do conteúdo de decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (inc. III), a observância do conteúdo da jurisprudência vinculante formada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente de assunção de competência (inc. IV) e a observância de precedente de repercussão geral ou de recurso especial em questão repetitiva, desde que esgotadas as instâncias recursais ordinárias (art. 988, § 5.º, II, a contrario sensu, CPC/2015).

Em termos de política legislativa, trata-se de previsão em si mesma equivocada. A ação de reclamação tem a ver com a tutela da autoridade da decisão do caso concreto, isto é, tem a ver com desrespeito ao dispositivo de determinada decisão. Pertence, portanto, ao discurso do caso concreto. Não diz respeito ao discurso da unidade da ordem jurídica. Como o legislador, no entanto, resolveu fazer da ação de reclamação também um instrumento para a tutela do precedente, então é preciso que o faça de forma coerente: não só os precedentes formados a partir da sistemática do julgamento dos recursos repetitivos autorizam o uso da reclamação nos termos do art. 988, § 5.º, II, CPC/2015, mas todos os precedentes constitucionais ou federais oriundos do

4. Precedentes e Razões. Os precedentes são razões generalizáveis necessárias e suficientes para a solução de determinada questão oriundas da justificação das decisões judiciais das Cortes Supremas. Nas decisões, portanto, convivem razões necessárias e suficientes capazes de se tornarem precedentes e razões outras, que não possuem a mesma aptidão: as primeiras constituem a chamada *ratio decidendi*; as segundas, *obiter dictum*.

4.1. Ratio Decidendi. O núcleo duro do conceito de precedente pode ser identificado com o conceito de *ratio decidendi* – ou *holding*, como é mais comumente chamada na doutrina estadunidense – de determinado caso ou questão. É, sem dúvida, de grande colaboração para a sua compreensão no direito brasileiro o manancial teórico existente a respeito do tema no *Common Law*.

4.1.1. Ratio Decidendi no Common Law. Não há sinal de acordo no *common law* acerca de uma definição de *ratio decidendi* ou mesmo de um método capaz de permitir sua identificação.¹⁰² De qualquer forma, dada a sua notoriedade, devem ser referidos o denominado teste de Wambaugh¹⁰³ e o método de Goodhart.¹⁰⁴

Para Wambaugh, *ratio decidendi* é uma regra geral em cuja ausência o caso seria decidido de outra forma. O jurista descreve o modo como o teste deve ser feito. Antes de tudo há de ser cuidadosamente formulada a suposta proposição de direito. Após, deve inserir-se na proposição uma palavra que inverta o seu significado. Então, é necessário perguntar se, caso o tribunal houvesse admitido a nova proposição e a tivesse tomado em conta no seu raciocínio, a decisão teria sido a mesma. Sendo a resposta afirmativa, o caso não é um precedente para a proposição; em hipótese negativa, o caso tem autoridade para a proposição original. Wambaugh resume o seu teste dizendo que a proposição ou doutrina do caso, a razão da decisão, a *ratio decidendi*, deve ser uma regra geral sem a qual o caso deveria ter sido decidido de outra maneira.¹⁰⁵

Diante do teste de Wambaugh, invertendo-se o sentido da proposição tomada em conta pelo tribunal, a sua decisão não pode ser a mesma para que a proposição constitua *ratio decidendi*. A proposição com sentido invertido – portanto, outra proposição – faria com que o caso fosse decidido de outra maneira. Se a nova proposição gera igual decisão, a proposição original, em vez de constituir *ratio decidendi*, representa *obiter dictum*.

O teste de Wambaugh – bastante próximo ao de Vaughan C. J., formulado no século XVII – é apontado como falho pela doutrina contemporânea do *common law*. A principal razão para tanto, advém da situação de que a Corte baseia a sua decisão em dois fundamentos que, separadamente, podem levar à mesma solução. Quando o significado de um dos fundamentos é invertido, o outro fundamento é suficiente para preservar a decisão ou para impedir a alteração da conclusão. Assim, o teste de Wambaugh, no sentido de que a inversão da proposição faria com que o caso fosse decidido de outra forma, não vale quando o caso se baseia em dois fundamentos que, isoladamente, podem conduzir à mesma solução. Na verdade, nessa situação, o teste de Wambaugh faria com que as proposições sempre fossem *obiter dicta*, já que nenhum dos fundamentos seria necessário para a decisão.¹⁰⁶

O método de Goodhart dá maior ênfase aos fatos do que o teste de Wambaugh. Propõe que a *ratio decidendi* seja determinada mediante a verificação dos fatos tratados como fundamentais ou materiais pelo juiz. Goodhart apresentou o seu método em ensaio que apareceu publicado, pela primeira vez, no *Yale Law Journal*, em dezembro de 1930.¹⁰⁷ Este ensaio, intitulado “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, tornou-se a base de todas as investigações posteriores acerca do tema, no *common law*.¹⁰⁸

De acordo com Goodhart, a *ratio decidendi*, a que se refere constantemente como “principle of a case”, não é encontrada nas razões ou na *rule of law* apresentadas ou estabelecida na *opinion*. Também não é necessariamente encontrada mediante a consideração de todos os fatos averiguáveis do caso e na decisão judicial. Para Goodhart, a *ratio* é identificada mediante a consideração dos fatos tratados pelo juiz como materiais ou fundamentais e da sua decisão neles

baseada.¹⁰⁹

Melhor explicando: para Goodhart é necessário determinar todos os fatos do caso como vistos pelo juiz e, após, identificar quais destes fatos o juiz admitiu como materiais ou fundamentais para decidir.¹¹⁰ Mas, para a ratio, além dos fatos que o juiz considerou materiais, também seria importante a decisão que neles se fundou.

Na verdade, é necessário descobrir quais fatos foram tratados como materiais e quais foram tratados como imateriais. Muitas vezes é difícil determinar os fatos que foram considerados imateriais. Isso porque a determinação dos fatos imateriais pode não estar implícita no raciocínio judicial, nem ter sido expressamente realizada pelo juiz. A dificuldade, nesses casos, é saber se o tribunal considerou, ou não, o fato como imaterial. É o que ocorre quando a Corte, depois de ter definido todos os fatos do caso, identifica um pequeno número de fatos para fundamentar a sua decisão. Os fatos omitidos presumivelmente são imateriais. Goodhart explica através de exemplo, servindo-se do caso *Rylands v. Fletcher*.

Fletcher contratou um empreiteiro para construir um reservatório em sua propriedade. O empreiteiro atuou com negligência e a água do reservatório invadiu as terras do vizinho, causando prejuízos. Goodhart, ao analisar a situação, admitiu como “fatos do caso”: i) B tinha um reservatório em sua propriedade; ii) o empreiteiro, contratado por B para edificá-lo, agiu com negligência; iii) a água escoou do reservatório e prejudicou A. Foram considerados “fatos materiais”: i) B tinha um reservatório construído em sua propriedade; ii) a água escoou e prejudicou A. Anota Goodhart que a Corte ignorou o fato relacionado à negligência do empreiteiro, que foi implicitamente considerada como fato imaterial. Se a Corte não considerou a negligência do empreiteiro, não houve responsabilização de B pela negligência do seu contratado, mas instituição da doutrina da “absolute liability” (responsabilidade objetiva).¹¹¹

O juiz deve, expressa ou implicitamente, tratar os fatos como materiais ou imateriais. Frequentemente, o juiz expressamente indica os fatos que considera materiais ou imateriais. Como isso nem sempre ocorre, Goodhart sugere vários testes para determinar quais fatos devem ser admitidos como tendo sido tratados como materiais ou imateriais pelo juiz. Assim, os relacionados à pessoa, tempo, lugar, gênero e quantidade são presumivelmente imateriais, a menos que declarados como materiais. Os argumentos e razões da Corte, assim como a declaração da regra de direito que está sendo seguida, igualmente têm importância para a identificação dos fatos que foram considerados materiais e imateriais.¹¹²

Por fim, Goodhart alerta que a conclusão baseada em um fato hipotético, ou seja, em um fato cuja existência não foi determinada pela Corte, não constitui ratio decidendi, mas obiter dictum.¹¹³

Frise-se que a doutrina de Goodhart dá importância ao princípio de que casos iguais devem ser tratados da mesma forma (*treat like cases alike*). Qualquer Corte que se considerar vinculada pelo precedente deve chegar à mesma conclusão a que chegou no caso anterior, a menos que o caso sob julgamento tenha outros fatos que possam ser tratados como materiais, ou que fatos considerados materiais no caso anterior agora estejam ausentes.¹¹⁴

Deixando-se de lado o teste de Wambaugh e o método de Goodhart, que não poderiam ser esquecidos em virtude da sua notoriedade no common law, importa deixar claro que a identificação da ratio decidendi sempre foi buscada em dois pontos, um especialmente preocupado com a identificação dos fatos do caso, já que a ratio seria a decisão a respeito deles, e outro com as razões que embasam a conclusão, ou seja, com as razões que anunciam a regra que dá solução ao caso.

Não há dúvida que o método fático é restritivo quando comparado ao normativo. Isso não apenas porque fatos não se repetem e, portanto, nunca são os mesmos, mas também porque as circunstâncias fáticas variam de acordo com as particularidades dos casos – que, em abstrato, podem ser identificados em uma mesma espécie ou classe. Porém, quando são consideradas as razões para a decisão, torna-se possível ver que fatos similares devem ser enquadrados em uma mesma categoria, e, assim, não somente merecem, mas na verdade exigem, uma mesma solução

para que violado não seja o princípio da igualdade, mais claramente o princípio de que casos iguais devem ser tratados da mesma forma.

As razões para o encontro da solução do caso são imprescindíveis para a compreensão racional do precedente e do caso sob julgamento. O método fático importa como auxiliar, capaz de propiciar a racionalização do enquadramento do caso sob julgamento (instant case) no caso tratado no precedente (precedent case), e isso apenas quando há dúvida sobre a inserção fática do caso dentro da moldura do precedente. Lembre-se, com efeito, que a distinção entre situações concretas apenas tem razão de ser quando representam hipóteses que, numa perspectiva valorativa e jurídica, efetivamente reclamam tratamento diferenciado.¹¹⁵

Destaque-se de forma breve, ainda, o problema relativo a se saber quem define a ratio decidendi,¹¹⁶ se o órgão que institui o precedente ou se aquele que está a analisar se o precedente há de ser aplicado ao caso que está em suas mãos para julgamento. Não há dúvida que, mesmo que a ratio decidendi seja instituída pelo órgão que elaborou o precedente, isso não isentará os juizes de, no futuro, compreendê-la diante dos novos casos sob julgamento.

Note-se que, ao se supor que a Corte subsequente cria o precedente, estabelece-se um efeito retroativo, não desejável e admissível quando se têm em conta a segurança e a previsibilidade. O novo caso dá à Corte posterior apenas a possibilidade de compreender o precedente, que existe desde quando instituído pela primitiva Corte. Portanto, ainda que se admitisse que o juiz do novo caso elabora a ratio decidendi, ter-se-ia necessariamente duas ratio decidendi, uma elaborada pelo juiz do caso originário e outra pelo juiz do novo caso. Lembre-se que é nesta dimensão que Julius Stone falou em ratio decidendi descritiva e em ratio decidendi prescritiva, também atribuindo a esta última a qualificação de obrigatória, já que reveladora das razões que uma Corte posterior está obrigada a seguir.¹¹⁷

Além disso, é relevante a definição proposta por Rupert Cross, em seu conhecido *Precedent in English Law*, no sentido de que “a ratio decidendi de um caso é qualquer regra de direito expressa ou implicitamente tratada pelo juiz como passo necessário para alcançar a sua conclusão, tendo em vista a linha de raciocínio por ele adotada, ou uma parte de sua instrução para o júri”.¹¹⁸

MacCormick, porém, entende-a muito abrangente: “em qualquer caso em que uma lei está sendo interpretada ou aplicada, a lei em si, ou um artigo dela, corresponderá a uma regra sem a qual a mesma conclusão não poderia ser alcançada (pelo menos se quisermos dizer por ‘conclusão’ uma conclusão de, por exemplo, responsabilização pela aplicação daquela lei específica). Ninguém supõe, entretanto, que a lei seja a ratio. Na verdade, a ratio será o que a Corte afirma como interpretação correta da lei. Por essa abordagem, é claramente preferível descrever ou definir a ratio pelo fato de ser uma solução do juiz, em vez de ser qualquer regra da qual sua conclusão dependa”.¹¹⁹

Essa crítica à doutrina de Cross foi recentemente reafirmada por Duxbury. De acordo com o professor da London School of Economics, quando o juiz interpreta a lei para chegar à decisão, a ratio é o que o juiz acredita ser a melhor interpretação da lei – “the judges ruling, in other words, rather than the legal rule”.¹²⁰

Outra parte da definição de Cross que interessou a MacCormick diz que a regra de direito – vista pelo último como “solução do juiz” – deve ser tratada como “passo necessário” ao alcance da conclusão. Adverte MacCormick, todavia, que a “preocupação sobre as implicações do que é necessário foi levantada primeiro por Brian Simpson em seu artigo no *Oxford Essays in Jurisprudence*. Ali, ele mostrou que, nos termos de Cross, e talvez em certas formulações judiciais, o termo necessidade compreende muitos significados. Dessa maneira, Simpson propôs substituir a ideia do que é necessário por uma decisão pela ideia do que é suficiente para a decisão”.¹²¹

Não obstante, para MacCormick a formulação de Simpson compreende quase tanto conteúdo quanto a “necessidade” de Cross. Assim, o teórico escocês acaba por refutar tanto a doutrina de Cross quanto a de Simpson, propondo outra leitura da ideia de suficiência, apresentada pelo último. Admite que uma resolução, para configurar ratio, precisa ser suficiente para a resolução

da questão, mas que a questão jurídica deve exigir uma solução em particular para justificar a decisão do caso.¹²²

O real problema, sem dúvida, está no significado que se pretende atribuir aos vocábulos “necessário” e “suficiente”. Se o passo é necessário, ele é imprescindível, obrigatório. Suficiente, porém, é o que é bastante. Ora, há diferença entre caminho obrigatório e caminho bastante. Se o caminho é obrigatório, não há como chegar onde se quer sem passar por ele. Contudo, se o caminho é suficiente, chega-se ao lugar que se procura passando-se por ele, que é apto para conduzir ao local desejado. Suficiente, apto ou idôneo não se confunde com necessário ou obrigatório.

Cross, ao tratar das questões independentes e dependentes,¹²³ lembra do caso – *Perry v. Kendrick’s Transport* – em que não se considerou como *ratio decidendi*, a análise de questão que, julgada favoravelmente ao recorrido, não impediu que a Corte, julgando a segunda questão em favor do recorrente, provesse o recurso. A primeira questão não seria *ratio decidendi* por não ser necessária ao provimento do recurso. Como é óbvio, essa questão também não seria suficiente para se prover o recurso. Entretanto, caso houvesse outra questão, invocada pelo recorrente, capaz de permitir o provimento do recurso, haveria duas questões suficientes. Nesta hipótese, caso o tribunal pudesse analisar apenas uma das questões, essa obviamente seria *ratio decidendi*, não havendo falar em *obiter dictum*. Advirta-se desde logo, porém, que, quando o tribunal aprecia duas questões suficientes ao provimento do recurso, há grande debate na doutrina sobre a natureza da análise de cada uma delas.¹²⁴

É importante frisar, contudo, que neste caso a primeira questão foi julgada em favor do recorrido e, a segunda, em favor do recorrente. É que, diante disso, é possível perguntar se a ideia de suficiência se relaciona com o resultado do recurso ou com o resultado dado à questão posta pela parte. Ou melhor, o passo deve ser suficiente para o tribunal julgar a questão afirmada pela parte (recorrente ou recorrido) ou para dar solução ao recurso? O ponto é deveras importante, já que, caso a suficiência se ligue à solução da questão posta pela parte, não haverá entrave para se considerar *ratio decidendi* a decisão de questão em favor do recorrido, em caso de provimento do recurso. Note-se que, ao ser assim, não será propriamente a análise da questão que será suficiente para a decisão recursal – a razão ou o fundamento é que deverá ser suficiente à solução da questão.

No caso *The Minister of Health v. The King*, ex parte Yaffé,¹²⁵ a House of Lords refutou questão invocada pelo Ministro da Saúde e, ao julgar a segunda questão, decidiu por quatro votos contra um, em seu favor. A primeira questão disse respeito à competência da Corte para julgar a validade da ordem do Ministro e, a segunda, à sua validade propriamente dita, ou seja, à circunstância de estar a ordem autorizada pelo Housing Act, 1925.

Considerou-se que a decisão acerca da competência da Corte era *ratio decidendi*, ao argumento de que tal decisão seria necessária para se resolver o recurso. Nessa situação, nem mesmo seria possível falar em suficiente, uma vez que a decisão sobre competência jamais seria suficiente para a resolução sobre a questão de fundo do recurso. Realmente, a decisão apenas poderia ser considerada necessária para se chegar ao exame do mérito recursal. Não obstante, caso considerada a ligação das razões com a solução da questão, deixando-se de lado a ideia de se relacionar a análise da questão com a solução do caso, seria possível pensar que a fundamentação da House of Lords foi suficiente – e não somente necessária – para a decisão a respeito da competência.

Quando há duas questões e uma é resolvida em favor do recorrido e outra para dar provimento ao recurso, a decisão em favor do recorrido nunca será suficiente para a solução em prol do recorrente, podendo, no máximo, ser considerada necessária, como aconteceu quando se tomou em conta a análise da questão da competência como necessária à resolução do mérito. Entretanto, quando se destaca o raciocínio judicial para a análise das questões postas pelas partes, colocando-se à luz a solução dessas questões e não a solução do recurso ou do caso, torna-se viável pensar em suficiência de dada razão para a solução da questão, ficando claro que não apenas a decisão do caso, mas também as decisões relativas aos argumentos das partes devem constituir *ratio*

decidendi.

Como se vê, nem sempre é fácil definir os contornos da ratio decidendi. Um exemplo que costuma ser lembrado na doutrina inglesa é aquele que o caso *Barwick v. The English Joint Stock Bank* mereceu em *Lloyd v. Grace, Smith & Co.*¹²⁶

Em *Barwick v. The English Joint Stock Bank*, discutiu-se a respeito da questão da responsabilidade do empregador pelos atos praticados pelo seu empregado durante o serviço. Mais precisamente, sobre a responsabilidade do banco por ato fraudulento do seu gerente, que prejudicou alguém que obteve uma garantia inútil ou insuficiente. Na Corte, após a decisão do juiz de primeiro grau em favor do empregador, Willes J. declarou: “Mas, em relação à questão de se o empregador é responsável pelos atos do seu empregado no curso do serviço, e em benefício do empregador, nenhuma distinção sensível pode ser feita entre o caso de fraude e o caso de qualquer outra falta. A regra geral é a de que o empregador é responsável por toda falta do empregado ou agente praticado no curso do serviço e para o benefício do empregador, embora não seja provado comando ou ordem expressa do empregador”.¹²⁷

No caso, não houve dúvida de que o ato fraudulento praticado pelo gerente beneficiou o banco. Porém, problematizou-se, em julgamento posterior, *Lloyd v. Grace, Smith & Co.*, sobre a exata extensão da ratio decidendi do caso *Barwick*. Considerando-se as palavras de Willes J., proferidas em *Barwick v. The English Joint Stock Bank*, verifica-se a alusão de que a fraude ocorreu em benefício do empregador. Pois bem, o problema, em *Lloyd v. Grace, Smith & Co.*, era justamente o de saber se a ratio decidendi, do caso *Barwick*, se limitava a declarar a responsabilidade do empregador pelos atos de fraude praticados pelo empregado, mas em seu benefício, ou se, de forma mais abrangente, declarava a responsabilidade do empregador pelos atos de fraude praticados pelo empregado no curso do serviço.¹²⁸

Note-se que a adequada interpretação do precedente era fundamental para se saber o exato alcance da responsabilidade então declarada. Definição restritiva da ratio decidendi tornaria o precedente do caso *Barwick* favorável ao empregador em *Lloyd v. Grace, Smith & Co.* Isso porque, no caso *Lloyd*, o empregador se defendeu alegando que o ato fraudulento, praticado pelo seu empregado, não lhe trouxe nenhum benefício.

No caso *Lloyd*, o juiz de primeiro grau decidiu contra o empregador, a Corte de Apelação reformou a decisão recorrida, mas a House of Lords acolheu o appeal da vítima, declarando que o empregador é responsável pelas fraudes praticadas pelo seu empregado, durante o emprego.

Para prover o appeal, a House of Lords foi obrigada a interpretar o precedente do caso *Barwick v. The English Joint Stock Bank*, especialmente as palavras de Willes J., descritas acima. Lembre-se que Willes J. aludiu ao fato de que o ato fraudulento, em *Barwick*, beneficiou o banco. Não obstante, a House entendeu que essa alusão foi meramente accidental diante dos fatos que estavam à vista de Willes J., não constituindo parte da ratio decidendi. A House chegou a essa conclusão depois de atenta análise do precedente do caso *Barwick*, visto em sua globalidade. Além disso, a House interpretou a linguagem de Willes J. considerando o que foi dito, em julgamentos posteriores, por outros membros da Corte que julgou *Barwick*.¹²⁹

Tudo isso demonstra que a Corte subsequente, para aplicar um precedente, necessita definir o que realmente a obriga; vale dizer, precisa ter delineada a ratio decidendi do caso já resolvido. Para tanto, deve atentar não só para a linguagem do precedente, para a questão de direito discutida e para os fatos que nele estiveram presentes, mas também para os julgados anteriores e, principalmente, posteriores ao precedente, que possam explicar o significado de declarações contidas no precedente sob interpretação.

Assim, o caso *Barwick*, além de essencial para a compreensão da importância da definição exata da ratio decidendi, permite que se tenha em vista a relevância dos casos posteriores para a identificação do significado das declarações contidas nos precedentes. Veja-se até mesmo que, após a decisão em *Lloyd v. Grace, Smith & Co.*, ficou bastante claro o significado da ratio do caso *Barwick v. The English Joint Stock Bank*. Assim, em outras palavras, é preciso atentar para o fato

de que é importante para a interpretação da ratio decidendi, os julgados posteriores, na medida em que esses podem servir como instrumentos para o seu esclarecimento.

Algo diferente ocorre quando, em razão do enfrentamento de outra questão, um julgamento ou julgamentos posteriores agregam conteúdo a ratio decidendi, dando-lhe outra conformação. Nesse caso não há interpretação da antiga ratio, mas formação paulatina da ratio, que vai ganhando corpo à medida que os julgamentos vão sendo proferidos.¹³⁰

A dessemelhança pode ser mais bem compreendida a partir da distinção entre o ato do fotógrafo e a atividade do pintor. Embora o fotógrafo possa retratar e dar significado peculiar à paisagem, atribuindo-lhe interpretação, é certo que a fotografia congela a interpretação do passado, enquanto que o pintor vai, com o passar dos dias, dando forma e significado a sua pintura, que, no início do seu trabalho, muitas vezes nem mesmo ele sabe que resultado ou significado terá.

Porém, caso se parta da premissa de que a interpretação sempre gera uma nova ratio, tornando a ratio interpretada sem autoridade, reduz-se a importância da distinção feita acima. Mas será verdade que a interpretação da ratio, em um novo caso, destitui o significado do caso pretérito e a autoridade da sua ratio?

É certo que a interpretação, mais do que dizer o significado, pode ampliar ou reduzir um pretendido significado. Como ampliar e reduzir são atos que convivem com uma porção de significado que existia e que, mesmo com a ampliação ou com a redução, se mantém, não há como concluir que a ratio, depois de interpretada, deixa de ter qualquer autoridade e que o caso de que provém perde significado.

De qualquer forma, pretende-se falar aqui da necessidade de novos significados e não da necessidade de esclarecimento, mediante o qual pode haver redução ou ampliação do significado. Suponha-se, por exemplo, que em um caso, em que foi expressa de forma clara e precisa a ratio, não tenha sido enfrentada determinada questão de direito, que, se acolhida, pode reduzir ou ampliar a ratio primitiva.

Nessa situação, embora também se mantenha porção da primeira ratio, a sua alteração provém não da necessidade de esclarecimento, mas da imprescindibilidade de enfrentamento de uma nova questão. Não há acréscimo ou redução em virtude da necessidade de esclarecer, mas da imperiosidade de complementar. E não se pense que a complementação exclui a redução, podendo se dar somente pela ampliação. Na verdade, quando a completa solução do caso exige o enfrentamento de outra questão, o verbo reduzir não é incompatível com a ideia de complementar. Note-se, ademais, que isso não se confunde com uma revogação ou overruling, já que a ratio é alterada, mas não perde a sua autoridade.

4.1.2. Interpretação da Ratio no Common Law. A identificação da ratio decidendi do caso na doutrina do Common Law exige a consideração das questões de direito tratadas nos casos, dos fatos do caso e dos fatos considerados no caso precedente.

Para identificar o ponto de direito que faz parte da ratio decidendi, ou seja, que tem força obrigatória, é preciso analisar, em primeiro lugar, a apresentação do caso pela Corte. Para tanto, importa verificar o que a Corte disse acerca das alegações das partes, em relação aos fatos que dão composição ao litígio, a respeito das provas e, enfim, sobre os pontos de direito envolvidos.

Na fundamentação da Corte, será necessário investigar a maneira como os pontos de direito foram relacionados com as alegações das partes e com os fatos. Os pontos de direito que realmente importam são aqueles que, não apenas lembrados pela Corte, são relacionados com os fatos, de forma a se constituírem na base para a solução do caso.

É nesse sentido que se diz que o ponto de direito tem de ser necessário ou suficiente para a solução do caso. Sublinhe-se que o ponto de direito tem de ser suficiente para a específica solução dada ao caso, e não suficiente para uma qualquer solução do caso.

É por esse motivo que não constitui ratio decidendi, no Common Law, o fundamento que, embora detidamente analisado, é suficiente para decisão que pronuncia a competência da Corte, mas não soluciona o caso. Ainda por exemplo, é pelo mesmo motivo que as razões que rejeitam argumento elaborado pela parte, que, com base em outro fundamento, obteve solução favorável, não constituem ratio decidendi.

De qualquer forma, identificar o ponto de direito não é o mesmo que estar de posse de metodologia que permita saber se o ponto de direito contido na ratio decidendi do precedente se aplica a um novo caso sob julgamento. Isso se dá fundamentalmente porque, qualquer que seja essa metodologia, ela nunca se eximirá da comparação entre os fatos que dão composição aos dois casos.

Se o sistema de precedentes, e, portanto, a ratio decidendi e a sua força obrigatória, objetiva que casos similares sejam decididos de igual modo, quanto mais se aproximam os fatos de dois casos, maior é a probabilidade de que a decisão dada ao primeiro caso seja aplicável à solução do segundo.

Essa ideia tem presente a obviedade de que os fatos nunca se repetem e nunca podem ser ditos absolutamente iguais.¹³¹ É por isso que se fala em “probabilidade” de aplicação do precedente e em “maior aproximação” dos fatos. Portanto, para a conclusão acerca da adoção de um precedente, é imprescindível tratar da proximidade dos fatos que dão composição aos casos em cotejo.

Há diferença entre os fatos do caso e os fatos tomados como fundamentais pela decisão. É possível ver, na fundamentação, os fatos que foram considerados fundamentais para se chegar à decisão. Porém, nem sempre é fácil qualificar os fatos que, fazendo parte do caso, foram omitidos pela decisão. Estes, por presunção, são considerados não fundamentais.

Lembre-se de *Rylands v. Fletcher*, tratado por Goodhart. No caso em que um empreiteiro foi contratado para construir um reservatório de água que, mais tarde, vazou sobre a área do vizinho do proprietário-contratante; os fatos do caso ainda incluíam o fato de que o empreiteiro agira com negligência. Porém, a Corte se omitiu a respeito deste fato, tendo considerado apenas i) a propriedade do reservatório de água e ii) que este vazou sobre as terras do vizinho, causando-lhe danos. Se a Corte não se referiu expressamente ao fato da negligência do empreiteiro, seria possível dizer que o tribunal, implicitamente, o considerou fundamental. Nesse caso, a ratio decidendi teria o teor de que o proprietário é responsável pelas construções que, edificadas em sua propriedade pelo empreiteiro com negligência, causarem danos aos vizinhos. Entretanto, Goodhart, certamente a partir da visualização da decisão em sua globalidade, advertiu que a Corte ignorou o fato relacionado à negligência do empreiteiro, considerando-o implicitamente não fundamental. Por isso, a ratio decidendi teria aclamado a doutrina da “absolute liability”.¹³²

Deixando-se de lado a questão dos fatos fundamentais e não fundamentais, torna-se indispensável perceber que os fatos do precedente sempre podem ser enquadrados em determinada categoria – mais restrita ou mais ampla –, em conformidade com as razões que serviram de base à decisão.

Para se proceder a tal enquadramento, é necessário tomar em conta especialmente a linguagem, os conceitos jurídicos, a cultura e os valores que podem identificar as categorias em que os fatos se inserem. É possível identificar o produtor de suco de laranja como produtor de sucos ou como produtor de bebidas ou ainda de gêneros alimentícios. Alguém pode ser visto como consumidor, como membro de certa religião, como intelectual, como honesto etc., dependendo da situação pragmática em que está inserido.

Acontece que o enquadramento de um fato em determinada categoria, para o efeito de se dar ao primeiro a consequência outorgada à segunda, depende da análise cuidadosa das razões contidas na decisão, pois são estas que não só podem justificar o enquadramento do fato do precedente em determinada categoria, como também a inserção do fato do novo caso na categoria de que faz parte o fato do precedente.¹³³

Ao se olhar para as razões da decisão é preciso identificar a cultura e o modo de viver da época e do lugar do caso que deu origem ao precedente. Isso porque, como é sabido, a linguagem, os conceitos jurídicos, a cultura e os valores podem variar conforme as épocas e os lugares.

Contudo, como este enquadramento, ainda que dependente das razões do precedente, requer racionalidade jurídica, aquele sempre dependerá, em maior ou menor medida, da justificativa apresentada na decisão que aplicou o precedente. Na decisão do novo caso há que se justificar os critérios que levaram à assimilação dos fatos ou ao enquadramento destes em uma mesma categoria. Em outras palavras, deve haver razão para assimilar fatos, procedendo-se ao seu enquadramento em uma mesma categoria.¹³⁴ Deixe-se claro, porém, que os fatos somente devem ser distanciados, quando a princípio ou aparentemente pertencentes a uma mesma categoria, se as razões do precedente fizerem ver que se está diante de contextos diversos.

Assinale-se, por fim, que a força de um precedente, ou a extensão que ele pode atingir, depende do tamanho ou da latitude da categoria em que os seus fatos fundamentais se inserem. Sem dúvida, quanto mais larga for a categoria a que pertencem os fatos do precedente, mais ampla será a área de sua aplicação.

4.1.3. Ratio Decidendi no Direito Brasileiro. Os precedentes no direito brasileiro têm particularidades. Embora as decisões proferidas em recurso especial e recurso extraordinário sejam tomadas em casos concretos, esses recursos são restritos à valoração de “questões de direito”. Vale dizer: o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça devem valorar o direito tomando sem questionar o cenário fático delineado pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais de Justiça nos acórdãos recorridos. Tanto as decisões proferidas em recurso especial como aquelas tomadas em recurso extraordinário visam a interpretar questões relativas à lei federal e à Constituição Federal.

Não há dúvida que esses precedentes, embora definidores de teses jurídicas, são instituídos em casos dotados de particularidades fáticas, que, por isso, terão de ser considerados ao se analisar a aplicação do precedente a casos subsequentes. Isso significa que, embora a função das Cortes Supremas seja interpretativa, o sentido atribuído à lei ou à Constituição só pode ser compreendido a partir da moldura fática do caso em que se insere a questão de direito resolvida.

Já foi demonstrado que a ratio decidendi, no âmbito do common law, é vista como passo necessário à específica solução dada ao caso. No direito brasileiro, contudo, a conformação da ratio decidendi não necessita e não deve sofrer igual restrição.

O que se espera de um precedente, ou seja, a sua capacidade de outorgar unidade ao direito promovendo a segurança jurídica, a liberdade e a igualdade diante do significado das questões jurídicas, não pode constituir privilégio das soluções definitivas dadas a cada um dos casos. Nada obsta que, a princípio, todas as questões, envolvidas e presentes de uma ou outra maneira nos vários processos jurisdicionais, devem contar com os benefícios da teoria dos precedentes.

As questões preliminares, necessárias para se chegar à análise do mérito ou do próprio caso, dão origem a decisões que obviamente têm plenas condições de oferecer uma ratio decidendi, caracterizando-se como precedentes a serem observados no futuro, como, por exemplo, a decisão acerca da competência da Corte para decidir determinada matéria, a decisão sobre hipótese de admissibilidade de recurso ou a decisão a respeito de pressuposto para o manejo da ação rescisória, para não se falar de inúmeras outras situações, todas elas carentes de definição e estabilização por meio de precedentes.

Também não há motivo racional para excluir, da classe dos precedentes, as decisões que tratam de questões resolvidas em favor da parte que, ao final, restou vencida. Suponha-se, por exemplo, que a Corte admita parcialmente o recurso e, no mérito, lhe dê provimento, ou que a Corte negue a decadência da ação rescisória e, após, a julgue improcedente. Nada impede que, em tese, as decisões respeitantes a essas situações se comportem como importantes precedentes. Pensar de modo diverso significa confundir o dispositivo da decisão com a ratio decidendi emergente da sua fundamentação.

No caso de pedidos cumulados,¹³⁵ é possível ter tantos precedentes quantos sejam os pedidos, considerando-se, evidentemente, a espécie de cumulação. Quando a cumulação é simples, em que os pedidos podem ser julgados autonomamente, independentemente do resultado atribuído a cada um, haverá sempre a chance de se formarem tantos precedentes quantos sejam os pedidos, não importando se todos forem julgados procedentes, todos forem julgados improcedentes, ou um ou alguns forem julgados procedentes e outros não. Na hipótese de cumulação sucessiva, quando o segundo pedido, para ser apreciado, depende da procedência do primeiro, poderão se formar dois precedentes – não importando o resultado do segundo – ou um precedente – no caso em que o primeiro pedido for julgado improcedente. Se a cumulação for alternativa, situação em que o segundo pedido é realizado para a eventualidade de o primeiro não poder ser acolhido, abrir-se-á ensejo a apenas um precedente, isto é, ou o resultante da procedência do primeiro pedido ou daquele alternativo ou o que se estabelecer com a improcedência do pedido.

Tratando-se de pedido ancorado em várias causas de pedir, a formação dos precedentes dependerá do número de causas de pedir apreciadas. Assim, por exemplo, no caso de ação rescisória, podem ser analisadas várias causas de pedir até que se julgue procedente o pedido com base em uma delas, ou podem ser enfrentadas várias causas de pedir até que se acabe por julgar improcedente o pedido.

O Tribunal pode, por exemplo, rejeitar duas causas de pedir da ação rescisória por três votos contra dois e acolher uma das causas de pedir pela mesma votação. Não importa se todos os juízes votaram – consideradas as duas causas de pedir – pela improcedência do pedido, ou seja, se os juízes A, B e C rejeitaram a primeira causa de pedir e os juízes D, E e novamente o juiz A votaram pelo não acolhimento da segunda causa de pedir. O que interessa, para determinar a procedência, é se no mínimo três juízes, sejam eles quais forem, acolheram a terceira causa de pedir.

É interessante lembrar – uma vez que intimamente ligado ao tema da individualização da *ratio decidendi* – que são frequentes os equívocos cometidos em sede de ação rescisória quando da tomada dos votos proferidos pelos membros do órgão colegiado. A proclamação do resultado do julgamento deve considerar o número de causas de pedir sustentadas pelo autor. Se a ação rescisória se funda, por exemplo, em erro de fato e na violação literal das normas X e Y, inexistente resultado de procedência se, dos cinco juízes, dois julgam a ação rescisória improcedente, um declara ter ocorrido erro de fato, outro afirma ter sido violada a norma X e o último a norma Y. Neste caso, existem três ações rescisórias cumuladas, tendo se chegado ao resultado de 4 x 1 em favor da improcedência em cada uma delas.

Frise-se, por oportuno, que no julgamento de recurso especial ou extraordinário só há *ratio decidendi* quando a maioria do colegiado sustenta um mesmo fundamento ou uma mesma solução para a questão de direito. Não basta prover o recurso por três votos a dois para se ter precedente. Há *ratio* apenas quando o fundamento que determina o provimento ou desprovimento do recurso é acolhido por maioria de votos. Isso porque a *ratio decidendi* não se relaciona com o resultado do recurso, mas com o fundamento que foi adotado para se chegar à solução do caso.

Outra particularidade concernente à identificação da *ratio decidendi* no direito brasileiro pode ser encontrada na relação entre o precedente e a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC/2015). E mais uma vez aqui é imprescindível ter presente que a decisão judicial dá azo a um duplo discurso: um ligado à solução do caso concreto (ao qual pertence, por exemplo, o instituto da coisa julgada e da sua eficácia preclusiva) e outro ligado à unidade do direito (ao qual pertence a teoria dos precedentes). A intersecção entre esses dois discursos exige algumas observações.

Elemento integrante da ação e requisito necessário da petição inicial, a causa de pedir é constituída pelas alegações de fato e pelas razões jurídicas que justificam o pedido de tutela jurisdicional do direito. Em outros termos, trata-se de apresentar um fato e de demonstrar o seu nexo com o efeito jurídico pretendido (art. 319, III, CPC/2015).

Se é certo que o juiz não pode decidir fora da causa de pedir (art. 141, CPC/2015), o problema é saber o que está dentro da causa de pedir. A pergunta a respeito do que está inserido na causa de pedir, em determinada perspectiva, tem íntima relação com o chamado princípio do deduzido e do

dedutível ou com a eficácia preclusiva da coisa julgada. Isso porque se reputa dedutível o que está inserido na causa de pedir. O que faz parte da causa de pedir, tenha ou não sido expressamente deduzido pelo autor, presume-se deduzido.

De acordo com o art. 508 do CPC/2015, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Assim, todas as alegações deduzidas, bem como as dedutíveis – porque mantêm relação direta com o material da demanda, ainda que não tenham sido postas em juízo ou analisadas pelo juiz – presumem-se apresentadas pela parte e conhecidas pelo juiz.

O problema está em saber quais são as “alegações e as defesas que a parte poderia opor”. Assim, por exemplo, tratando-se de ação de despejo fundada em uso inadequado do imóvel, poderá o locador, em caso de improcedência, propor outra ação sob a alegação de não pagamento dos aluguéis? Proposta ação de ressarcimento sob a alegação de que o réu, ao colidir com o veículo do autor, desrespeitou o sinal vermelho, poderá o autor, tendo sido vencido na demanda, voltar a juízo alegando que o réu estava dirigindo embriagado? E se o autor descobrir que o réu agiu com dolo, tendo lhe causado prejuízo com intenção deliberada? Afinal, o que define as alegações que se tornam preclusas com o trânsito em julgado da sentença? Tais alegações seriam aquelas que dizem respeito à norma jurídica contemplada como fundamento para o pedido? Seriam apenas as circunstâncias acessórias, que acompanham o fato principal que compõe a causa de pedir?

É fácil perceber que, no exemplo da ação de despejo, a segunda ação é totalmente viável, já que baseada em outra causa de pedir. Na hipótese da ação de ressarcimento, não há como admitir a alegação posterior de que o réu estava embriagado, mas é possível nova ação fundada em dolo. Isso porque o estado de embriagado faz parte da causa de pedir consistente no fato de ter o réu agido com culpa, mas a intenção deliberada de trazer prejuízo não faz parte da primitiva causa de pedir, abrindo ensejo a ação sob a alegação de que o réu atuou com dolo. Uma vez que, na elaboração da petição inicial, devem estar presentes, a título de causa de pedir, somente os elementos relacionados ao específico fundamento – fatos jurídicos necessários e suficientes para ensejar certo efeito jurídico –, apenas os fatos relacionados a esta causa de pedir deverão ser deduzidos. Outros fatos, ainda que possam subsidiar outra causa de pedir, são totalmente impertinentes, e, assim, não podem figurar na narrativa apresentada na petição inicial e ser apreciados no julgamento da causa. Por conseguinte, sendo alegações alheias à causa de pedir, e assim não estando sujeitas à decisão judicial, não podem vir a ser consideradas preclusas diante do trânsito em julgado da sentença de mérito.

De modo que a preclusão, capaz de operar em razão do art. 508 do CPC/2015, diz respeito apenas às alegações concernentes à mesma causa de pedir. Somente as alegações internas à causa de pedir, relativas à ação proposta – e, portanto, referentes às mesmas partes, pedido e causa de pedir –, serão apanhadas por tal efeito preclusivo, de forma a torná-las não dedutíveis em ação posterior. Nenhuma questão não pertencente àquela específica ação, ainda que relacionada indiretamente a ela – porque correspondente a outra causa de pedir passível de gerar o mesmo pedido, ou porque concernente à pretensão de outra parte sobre o mesmo objeto etc. –, pode ficar sujeita à eficácia preclusiva. Por outro lado, o juiz, ao instruir o processo, não pode tomar em conta alegação não pertencente à causa de pedir. Assim, não cabe ao juiz, na decisão que visa à organização do processo (art. 357, II, CPC/2015), fixar como controvertido um fato que não se relaciona com o fato principal ou com a causa de pedir.

Mas é chegado o momento de esclarecer a relação entre a delimitação dos fatos pela causa de pedir com o tema dos precedentes. Na verdade, o que se pretende saber, quando são frisadas as ideias i) de que as alegações contidas na causa de pedir reputam-se deduzidas e ii) de que as alegações nela não presentes não podem ser julgadas, é i) se a *ratio decidendi*, derivada de caso em que não se fez determinada alegação, aplica-se a caso posterior, em que esta alegação esteja sendo feita, e ii) se o juiz pode considerar fato não invocado na ação, mas considerado no precedente.

No common law faz-se raciocínio inverso. Importa verificar os limites da *ratio decidendi*, bem como a assimilação entre os fatos, para saber se essa incide sobre o caso sob julgamento. Recorde-

se do caso *Rylands v. Fletcher*. Fletcher contratou empreiteiro para construir reservatório em sua propriedade, cuja água vazou e atingiu as terras do vizinho. Foi admitido, como fato do caso, além da propriedade do reservatório e da vazão da água em prejuízo da propriedade do vizinho, o fato de que o empreiteiro, contratado para construir o reservatório, atuara com negligência. Em casos posteriores, discutiu-se sobre o perfil da *ratio decidendi* formada neste caso, especialmente se a *ratio* firmou a doutrina da responsabilidade absoluta (*absolute liability*) ou se, para declarar a responsabilidade do proprietário, considerou a negligência do empreiteiro. Note-se que se a Corte, para declarar a responsabilidade, considerou a negligência do empreiteiro, ela não afirmou a responsabilidade do proprietário pelos danos decorrentes de atos gerados a partir da sua propriedade. Ela teria declarado a responsabilidade do proprietário por atos negligentes praticados pelo contratado em sua propriedade.

Goodhart, ao analisar *Rylands v. Fletcher*, entendeu que o fato de o empreiteiro ter atuado com negligência, não constituiu fato material ou fundamental para a Corte decidir. A Corte, na verdade, teria ignorado a questão da negligência do empreiteiro, e, portanto, não responsabilizado o proprietário pela negligência do seu contratado, mas instituído a doutrina da responsabilidade absoluta (*absolute liability*).¹³⁶

Assim, a questão da negligência, por não ser fato material, não importaria para a delimitação da *ratio decidendi*. Mas fato material não se confunde com fato essencial ou que dá base à causa de pedir. Fato material é um fato da causa, considerado a partir do raciocínio e das razões do juiz como fundamental à solução do caso. O fato material importa para delimitação da *ratio* e para a investigação a respeito da sua aplicação a caso subsequente. Mas não tem relevância para a identificação da coisa julgada e para a análise sobre a possibilidade da sua alegação em ação posterior.

Se o lesado, ao formular a ação de ressarcimento, alega que o proprietário é responsável porque o seu contratado agiu com negligência, o juiz não pode condená-lo se não ficar evidenciada e considerada a negligência como fator determinante do dano. Se a ação é proposta sob o fundamento de que o proprietário é responsável pelos atos derivados da sua propriedade, sem que se faça a alegação respeitante à negligência do contratado, o juiz não poderá condenar o proprietário em virtude da negligência. Há, nesta situação, duas causas de pedir distintas. A negligência do contrato não é simples fato que se insere na outra causa de pedir. De modo que, se o lesado não alegar negligência na primeira ação e receber sentença de improcedência, poderá propor outra ação de ressarcimento com base na negligência do empreiteiro contratado, o mesmo valendo para a hipótese de exclusiva alegação de negligência na primeira ação. Não há incidência do princípio do deduzido e do dedutível.

Note-se que a espécie técnico-jurídica fato material ou fundamental tem a ver com a necessidade ou suficiência para se chegar à conclusão. Portanto, um fato pode ter sido alegado, e constituir causa de pedir autônoma e não ser considerado como necessário ou suficiente, já que outro fato ou outra causa de pedir teria sido necessária ou suficiente para a decisão. Aliás, foi o que ocorreu em *Rylands v. Fletcher*, pois se ignorou a negligência ao se supor que bastaria, para a responsabilização, o fato de o dano advir do reservatório construído na propriedade de Fletcher.

Na verdade, a distinção entre a qualidade atribuída aos fatos (material e incluído na causa de pedir) repousa nas diferentes intenções em que estão envolvidos. Quando se indaga se um fato é material, deseja-se esclarecer os limites da *ratio decidendi* ou se o fato contido em caso posterior foi considerado no precedente. Se o réu se defende alegando que o seu empregado ou contratado não foi negligente, obviamente interessa ao autor que, na compreensão da *ratio*, a Corte que possui o caso nas mãos – a *instant court*, nos termos do *common law* – entenda que a primitiva Corte não tomou em consideração a negligência para julgar. Enquanto isso, quando se pergunta se um fato integra causa de pedir, quer-se apenas esclarecer se tal fato está acobertado pela coisa julgada, ou melhor, pela eficácia preclusiva da coisa julgada, com a qual o princípio do deduzido e do dedutível tem estreita ligação e similitude. Se o réu alega as duas questões para responsabilizar o réu e recebe decisão final de improcedência, não lhe é possível propor ação com base em qualquer dos fatos. Mas se o autor alega causa de pedir – por exemplo, a culpa do réu – e deixa de alegar fato que nela está integrado, a improcedência o impede de propor nova ação, alegando o

fato que poderia ter sido deduzido para evidenciar a culpa, aplicando-se o princípio do deduzido e do dedutível e incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Diante do que acaba de ser dito, a pergunta de se a *ratio decidendi*, derivada de caso em que não se fez determinada alegação, aplica-se a caso posterior, em que esta alegação esteja sendo feita, torna-se mais simples. Nesta situação não se fala de princípio do deduzido e do dedutível e de eficácia preclusiva da coisa julgada. Assim, pouco importa se a alegação que deixou de ser feita está ou não contida na causa de pedir da ação que deu origem ao precedente. Ora, não se está pretendendo fazer valer a coisa julgada, mas apenas aplicar a *ratio decidendi*. O fato que a Corte não considerou ao desenhar o precedente, tenha ou não sido alegado pela parte, constitui fato imaterial ou não fundamental, de modo que a *ratio decidendi* não lhe diz respeito. Quando esta alegação for feita em caso posterior envolvendo outras partes – exatamente por não estar obstaculizada pela eficácia preclusiva da coisa julgada ou pelo princípio do deduzido e do dedutível – caberá realizar uma tarefa de distinção dos casos, demonstrando-se que a nova alegação, feita no caso sob julgamento, não foi considerada como fato material no primitivo caso, que deu origem ao precedente.

Com a distinção (art. 489, § 1.º, V e VI, e 927, § 1.º, CPC/2015), a solução respeitante à aplicação da *ratio* pode variar. Caso a questão que se formou em razão da nova alegação possa ser vista de maneira autônoma, sem prejudicar a análise daquela já enfrentada no precedente, existirão duas questões, devendo o precedente ser aplicado para permitir ao juiz dar à questão, idêntica ou semelhante à já definida, a mesma solução. No entanto, se a nova alegação não formar questão autônoma, mas estiver presa ao fundamento apreciado no caso que deu origem ao precedente, não haverá como aplicá-lo. Na última hipótese, a nova alegação, ao exigir o *distinguished*, não deixa espaço para que qualquer questão seja solucionada mediante a aplicação do precedente. Aqui, impõe-se o exame da mesma questão, mas a partir de outra perspectiva. Há um novo fato material ou fundamental, pouco importando se este fato estava ou não integrado na causa de pedir do caso primitivo. Isso simplesmente porque o princípio do deduzido e do dedutível apenas serve para se delimitar a coisa julgada material, que diz respeito à segurança jurídica entre as partes de um mesmo litígio, nada tendo a ver com a *ratio decidendi*, que releva ao assegurar a todo e qualquer jurisdicionado igualdade de tratamento perante o juiz.

Portanto, é sempre possível fazer nova alegação, respeitante à mesma causa de pedir, para se tentar obter solução diversa daquela a que se chegou no precedente. E a *ratio decidendi*, assim, não se aplica a caso posterior em que se esteja fazendo nova alegação.

De outra parte, a indagação de, se o juiz pode considerar fato (fundamento) não invocado na ação, mas considerado no precedente, exige a verificação de, se tal fato está embutido na causa de pedir da ação sob julgamento. Se o fundamento ou fato está presente na causa de pedir, embora não expressamente alegado pela parte, ele pode ser considerado pelo juiz, desde que submetido ao contraditório (arts. 9.º e 10, CPC/2015). Tratando-se de fato que deve ser esclarecido mediante prova, o juiz pode fixá-lo como controvertido de ofício, determinando a produção de prova para esclarecê-lo. Não obstante, se o fundamento considerado no precedente constitui causa de pedir distinta da apresentada pela parte na ação em desenvolvimento, o juiz obviamente não pode tomá-lo em conta para decidir.

A mesma lógica governa as alegações do réu. Passada em julgado a sentença contrária ao réu, tudo o que por ele foi deduzido, ou poderia ter sido deduzido, reputa-se repellido, não mais podendo ser alegado para o efeito de se tentar subverter a decisão (eficácia preclusiva da coisa julgada). Frise-se que o art. 508 do CPC/2015 é expresso no sentido de que, ocorrido o trânsito em julgado, reputa-se deduzido e repellido não só o que o autor poderia invocar para o acolhimento do pedido, mas também o que o réu poderia opor à sua rejeição.

Assim, como incumbe ao réu apresentar todas as defesas para a rejeição do pedido, não poderá o juiz tomar em conta argumento ou fato que não faça parte da defesa, ainda que tenha sido expressamente considerada pelo tribunal quando da elaboração do precedente. Por igual razão, o não acolhimento das alegações do réu, em determinado precedente, não impede que parte distinta alegue outro fundamento para convencer o tribunal de que a *ratio decidendi*, então elaborada, não

pode ser aplicada ao caso sob julgamento. Novamente incumbirá à parte, realizar a distinção dos casos, demonstrando que a nova alegação, feita no caso sob julgamento, não foi considerada como fato material no primitivo caso.

Outro ponto interessante se relaciona com a pergunta a respeito da diferença entre alegar novo fundamento para ver o precedente não aplicado e invocar fato que torna os casos diferentes, seja porque no primeiro está presente fato que não se encontra no caso sob julgamento, seja porque fato que aparece no novo caso não fez parte daquele em que o precedente foi elaborado. Essa diferença apenas poderia ser sentida quando se estivesse diante da alegação de novo fundamento de direito. Na situação em que se alega novo fato para que o precedente não seja aplicado, demonstra-se que o novo caso não é igual àquele em que o precedente foi instituído, e, na hipótese em que se alega que, no primeiro caso, estava presente fato que não está no caso sob julgamento, também se está evidenciando a disparidade entre os casos. Não obstante, nem mesmo a alegação de novo fundamento de direito torna relevante a distinção entre alegar novo fundamento e diferenciar os casos. Isso porque a aproximação dos casos, especialmente quando se pensa em aplicação de precedentes, não depende apenas dos fatos alegados, mas também das razões jurídicas invocadas pela parte e consideradas pelo juiz.

De qualquer forma, é inegável que existem situações em que a parte simplesmente diz que no caso sob julgamento não está presente – ou está presente – fato ou fundamento considerado – ou não considerado – no caso que deu origem ao precedente. Nesta última dimensão é interessante pensar no caso *Barwick v. The English Joint Stock Bank*, em que se discutiu sobre a responsabilidade do banco por ato fraudulento de seu gerente. Como a Corte, no julgamento deste caso, aludira ao fato de que a fraude teria beneficiado o banco, questionou-se em caso posterior, *Lloyd v. Grace, Smith & Co.*, se a responsabilização do empregador exige que o ato fraudulento – praticado pelo empregado – lhe traga benefício, e, assim, sobre a exata extensão da *ratio decidendi* do caso *Barwick*. Sem dúvida, a adequada interpretação do precedente era fundamental para se saber o exato alcance da responsabilidade que fora declarada. Definição restritiva da *ratio decidendi*, no sentido de que do ato teria de advir benefício ao empregador, tornaria o precedente do caso *Barwick* favorável ao empregador em *Lloyd v. Grace, Smith & Co.*, uma vez que, no último caso, o empregador se defendeu alegando que o ato fraudulento, praticado pelo seu empregado, não lhe trouxe qualquer benefício. Ao julgar o caso *Lloyd*, a House of Lords entendeu que a alusão a benefício foi meramente acidental diante dos fatos que estavam à vista da Corte em *Barwick v. The English Joint Stock Bank*, não constituindo parte da *ratio decidendi*, e, assim, deu ganho de causa a *Lloyd*, declarando a responsabilidade do empregador por ato praticado por seu empregado durante o serviço, independentemente de outro fator.¹³⁷

Considerando-se a doutrina de Goodhart, o benefício ao empregador não é um fato material ou fundamental. Como no caso *Barwick* a Corte não considerou, para decidir pela responsabilidade, a questão do benefício advindo ao empregador em virtude do ato praticado pelo seu empregado, a defesa no sentido de que o empregador não fora beneficiado pelo ato do seu empregado não teve relevância no caso *Lloyd*. Nesse caso, entendeu-se que, no caso *Barwick*, a Corte decidiu que a responsabilidade prescinde de cogitação acerca do impacto do ato – se benéfico ou não – sobre o empregador.

Contudo, isso não quer dizer, obviamente, que o réu não poderia deduzir a defesa de que não fora beneficiado pelo ato fraudulento para tentar evitar a aplicação do precedente firmado em *Barwick*. O réu suscitou defesa que, em sua argumentação, inverteria o resultado a que se chegou em tal caso. Em *Lloyd*, a falta de benefício, na argumentação da própria defesa, não teria constituído passo necessário para a Corte, em *Barwick*, alcançar a condenação; ao contrário, a decisão, neste caso, teria admitido que, para responsabilizar o empregador, a fraude teria de beneficiá-lo. É exatamente esta falta de benefício que, em *Lloyd*, militaria em favor do réu, distinguindo os casos.

4.1.4. Em Especial: a Ratio Decidendi no Controle Abstrato de Constitucionalidade. Da Coisa Julgada Erga Omnes aos Motivos Determinantes. Na hipótese de pedidos incidentes sobre objetos materiais distintos, mas com idêntico fundamento, já discutido e definido em face de caso anterior, obviamente pouco importa a diferença substancial entre os pedidos para a aplicação do

precedente. Não obstante, discute-se no direito brasileiro sobre a possibilidade de se aplicarem os fundamentos adotados na decisão de inconstitucionalidade em caso posterior, em que se peça a declaração de inconstitucionalidade de norma semelhante com base nos mesmos fundamentos.

Pergunta-se, assim, se os fundamentos da decisão de inconstitucionalidade têm efeito vinculante, capaz de incidir sobre a produção de outras normas, similares à já declarada inconstitucional, ou se seria o caso de simplesmente aplicar os princípios clássicos do civil law, como o da congruência entre o pedido e a sentença, para exigir que, a cada norma similar, seja necessária específica ação de inconstitucionalidade.

Ao se falar em eficácia vinculante da fundamentação, se está generalizando, de modo atécnico, a eficácia vinculante ou obrigatória atribuída, no common law, a toda e qualquer ratio decidendi. É compreensível. Tendo sido constatado, em meio à névoa da doutrina processual clássica do civil law, a obviedade de que o tribunal não revela o seu entendimento apenas no dispositivo, é preciso desenvolver uma teoria jurídica que não só explique a razão para se atribuir eficácia obrigatória ao que está na fundamentação, mas que também se desenvolvam critérios capazes de permitir a identificação daquilo que, na fundamentação, efetivamente expressa o pensamento do tribunal acerca da questão constitucional levada ao seu conhecimento.

Cabe ao Ministro Gilmar Mendes o grande mérito de ter desenvolvido o assunto a partir do direito alemão. Aludindo à ideia de “eficácia transcendente da motivação”, o Ministro fez ver que esta eficácia está umbilicalmente ligada à própria natureza da função desempenhada pelos tribunais constitucionais, além de ser absolutamente necessária à tutela da força normativa da Constituição.

Com a expressão “eficácia transcendente da motivação” pretende-se passar o significado de eficácia que, advinda da fundamentação, recai sobre situações que, embora especificamente distintas, têm grande semelhança com a já decidida e, por isso, reclamam as mesmas razões que foram apresentadas pelo tribunal ao decidir. Assim, se a norma constitucional X foi considerada inconstitucional em virtude das razões Y, a norma constitucional Z, porém substancialmente idêntica a X, exige a aplicação das razões Y.

A expressão “motivos determinantes da decisão”, a princípio tomada como sinônima da enunciada por “eficácia transcendente da motivação”, contém detalhe que permite a aproximação do seu significado ao de ratio decidendi. Isso porque há nessa expressão uma qualificação da motivação ou da fundamentação, a apontar para aspecto que estabelece claro link entre os motivos e a decisão. Os motivos têm de ser determinantes para a decisão. Assim, não é todo e qualquer motivo que tem eficácia vinculante ou transcendente – apenas os motivos que são determinantes para a decisão adquirem essa eficácia. E os motivos que determinam a decisão nada mais são do que as razões de decidir, isto é, a ratio decidendi.

Feitas essas considerações, torna-se oportuno problematizar a extensão dos efeitos vinculantes na decisão que pronuncia a inconstitucionalidade. Para tanto é indispensável recorrer ao pensamento do Supremo Tribunal Federal, considerando-se, em particular, a Reclamação 1.987, o leading case sobre o tema da eficácia transcendente da fundamentação.¹³⁸

Nessa reclamação afirmou-se que a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10.^a Região, ao determinar o sequestro de verba do Distrito Federal para o pagamento de precatório, desrespeitou decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn n. 1.662. Essa ADIn, proposta pelo Governador do Estado de São Paulo, teve como objeto a IN 11/1997, do Tribunal Superior do Trabalho, que cuidou da uniformização dos “procedimentos para a expedição de precatórios e ofícios requisitórios referentes às condenações decorrentes de decisões trânsitas em julgado, contra a União Federal (administração direta), autarquias e fundações”. A IN 11/1997-TST, em seus itens III e XII, equiparara à hipótese de preterição do direito de preferência a situação de não inclusão do débito no orçamento do ente devedor, assim como a de pagamento a menor, ou realizado fora do prazo, permitindo, nestas hipóteses, o sequestro de verba pública para o pagamento de dívidas judiciais trabalhistas. A ADIn voltou-se exatamente contra esta autorização, asseverando-a inconstitucional. No curso da ADIn, foi promulgada a EC n. 30/2000, que alterou

determinadas regras relativas aos precatórios, mas nada modificou quanto ao tema então em discussão. Ao julgar o mérito da ADIn, o Supremo Tribunal Federal advertiu que a EC n. 30 não trouxe qualquer alteração à disciplina do sequestro no âmbito dos precatórios trabalhistas, decidindo que este somente estaria autorizado pela Constituição Federal no caso de preterição do direito de preferência, sendo inadmissível em qualquer outra situação.

Porém, a decisão da Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10.^a Região não se ancorou na IN 11/1997-TST, mas se fundou na EC 30. Nesta situação, como é óbvio, a reclamação não poderia ser julgada procedente com base no fundamento de que a decisão do TRT-10.^a Região teria desrespeitado a parte dispositiva da decisão proferida na ADIn. A procedência da reclamação apenas poderia se apoiar em desrespeito aos fundamentos ou às razões que o Supremo Tribunal Federal adotou para pronunciar a inconstitucionalidade. Portanto, na reclamação restou em jogo decidir se os motivos determinantes da decisão de inconstitucionalidade ou a sua *ratio decidendi* teriam força obrigatória de modo a evidenciar que a decisão do TRT-10.^a Região teria desrespeitado a decisão proferida na ADIn.

A reclamação, após grande discussão entre os ministros, foi julgada procedente por maioria de votos. Na parte que interessa, a ementa do acórdão tem a seguinte redação: “Ausente a existência de preterição, que autorize o sequestro, revela-se evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na mencionada ação direta, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional”.¹³⁹

O relator da reclamação, Ministro Maurício Correa, afirmou que “a questão fundamental é que o ato impugnado não apenas contrastou a decisão definitiva proferida na ADIn 1.662, como, essencialmente, está em confronto com os seus motivos determinantes”.¹⁴⁰ Em termos mais claros, quis dizer o ministro relator que a decisão contra a qual se reclamou contrastou com os motivos determinantes da decisão proferida na ADIn.

Acompanharam o ministro relator, admitindo a tese da eficácia vinculante dos motivos determinantes, os Ministros Celso Mello, Cezar Peluzo, Gilmar Mendes e Nelson Jobim. Divergiram, não admitindo que os fundamentos pudessem ter efeitos vinculantes, os Ministros Carlos Ayres Britto, Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Carlos Mário Velloso, sendo que este último, ao que parece contraditoriamente, admitiu a reclamação.¹⁴¹

O Ministro Carlos Velloso negou a abrangência da eficácia vinculante aos fundamentos e, por isso, não poderia ter admitido que a decisão do TRT da 10.^a Região, baseada na EC 30, desconsiderou a eficácia vinculante da decisão proferida na ADIn 1.662, que declarou a inconstitucionalidade de ato normativo do TST. Eis o que disse o ministro: “Não me oponho, Sr. Presidente, a esse efeito vinculante, que considero inerente à natureza da decisão proferida na ação direta. Quando esse efeito vinculante ficou expresso, na Constituição, com a EC 03/1993 – CF, art. 103, 2.º –, relativamente à ADC, afirmei que a EC 03/1993 apenas explicitou algo já existente, implicitamente. Esse entendimento, mais recentemente, veio a predominar nesta Corte. Deve ficar claro, entretanto, que o efeito vinculante está sujeito a uma limitação objetiva: o ato normativo objeto da ação, o dispositivo da decisão vinculante, não os seus fundamentos”.¹⁴² O Ministro Velloso, embora tenha afirmado que o efeito vinculante é “inerente à natureza da decisão proferida na ação direta”, evidencia que, na sua concepção, esse efeito incide sobre o dispositivo da decisão e não sobre os seus fundamentos.

O Ministro Carlos Britto, ao proferir o seu voto, disse que acompanharia o voto do relator, mas “observando o limite objetivo da reclamação”.¹⁴³ O Ministro Pertence, mostrando-se incomodado com a atribuição de eficácia vinculante aos fundamentos da decisão, ponderou em tom de alerta: “O que parece é que realmente esta é uma decisão do maior relevo. Transformamos em súmula vinculante qualquer premissa de uma decisão...”.¹⁴⁴ O Ministro Marco Aurélio argumentou que a

atribuição de efeito vinculante à fundamentação equivaleria à admissão de coisa julgada em relação aos fundamentos da decisão, o que – prosseguiu – não seria admitido nem mesmo no campo civil.¹⁴⁵

Reconhecidamente favorável à tese da eficácia transcendente da fundamentação, o Ministro Gilmar Mendes lembrou a literatura alemã, advertindo que, embora na Alemanha exista discussão acerca dos limites objetivos dos efeitos vinculantes – se abrangentes da fundamentação ou apenas do dispositivo –, a razão de ser do § 31 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Alemão,¹⁴⁶ teria sido a de dotar as suas decisões de uma eficácia transcendente, que, caso fosse limitada ao dispositivo da decisão, não teria muito a acrescentar à função desempenhada pela coisa julgada material, além de diminuir significativamente a contribuição que o Tribunal Constitucional pode dar à preservação e ao desenvolvimento da ordem constitucional.¹⁴⁷

Merece destaque a lembrança do Ministro Gilmar Mendes à doutrina de Klaus Vogel, que, embora aludindo à coisa julgada, disse que a sua extensão iria além do dispositivo para abranger o que designou de “norma decisória concreta”. Essa seria a “ideia jurídica subjacente à formulação contida na parte dispositiva, que, concebida de forma geral, permite não só a decisão do caso concreto, mas também a decisão de casos semelhantes”.¹⁴⁸ Na verdade, Vogel está misturando coisa julgada com eficácia vinculante ou obrigatória, ou melhor, está rotulando a força obrigatória das decisões, peculiar ao common law, de coisa julgada, ou, ainda mais precisamente, está conferindo à fundamentação o que o common law atribui à ratio decidendi.

A coisa julgada nada tem a ver com a intenção de se permitir igual solução a casos semelhantes. O conceito de Vogel deve a sua originalidade à concepção de ratio decidendi. Note-se que, assim como a ratio decidendi, a “norma decisória concreta” está à distância do dispositivo e dos fundamentos. Para permitir a decisão de casos semelhantes, tanto a ratio decidendi quanto a norma decisória concreta devem constituir uma espécie de “extrato significativo da fundamentação”.

Porém, não obstante à equivocada assimilação entre eficácia vinculante e coisa julgada, o conceito de Vogel, quando bem visto, contém um plus significativo em relação à ideia de eficácia vinculante ou transcendente da fundamentação. É que a ideia de norma decisória concreta diz respeito à porção da fundamentação em que se identifica o motivo pelo qual se decidiu e, portanto, com o isolamento de uma parte significativa da fundamentação, deixando de lado aquelas que não importam como razões de decidir, que, assim, são obiter dicta.

Como se vê, o conceito de Vogel se aproxima do de “motivos determinantes da decisão”, visto que o qualificativo “determinante” supõe o motivo como imprescindível e essencial, e, desse modo, como não supérfluo, restando em uma só dimensão, guardadas as suas particularidades, as ideias de ratio decidendi, norma decisória concreta e motivos determinantes (tragende Gründe) da decisão.¹⁴⁹

Ao se colocarem os conceitos de norma decisória concreta e de motivos determinantes da decisão na mesma dimensão do de ratio decidendi, deseja-se apenas evidenciar a importância de se extrair da fundamentação o que realmente levou o tribunal a decidir, bem como sublinhar que a não identificação desta porção da fundamentação gera incerteza, colocando em sério risco a segurança jurídica e a própria missão que se quer atribuir aos tribunais com a extensão dos efeitos vinculantes.

Os conceitos de coisa julgada e de coisa julgada erga omnes não são relevantes quando se pretende dar soluções iguais a casos semelhantes. Nem mesmo a eficácia vinculante, caso limitada à parte dispositiva, aí teria alguma importância. De outra parte, falar em coisa julgada erga omnes dos fundamentos da decisão seria baralhar os institutos, já que os objetivos perseguidos com a coisa julgada e com a obrigatoriedade de respeito aos fundamentos não só não se confundem, como exigem conceitos operacionais e metodologias diversas.

Nessa dimensão, de qualquer forma, não há por que não admitir a adoção de ratio decidendi ou da eficácia vinculante dos motivos determinantes de decisão de inconstitucionalidade em caso em

que se impugne norma de conteúdo similar. Aliás, embora o art. 102, § 2.º, da Constituição afirme que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, têm eficácia vinculante “relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário”, e, portanto, não sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, parece inquestionável que as *rationes decidendi* das decisões de constitucionalidade e inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – seja em controle concentrado, seja em controle difuso – não podem deixar de ser por ele observadas. Entendimento contrário daria ao Tribunal a que incumbe a tarefa de interpretar a Constituição, zelando pela sua força normativa, a possibilidade de negar a sua importante missão para a estabilização da ordem jurídica constitucional.

Como é óbvio, não se quer dizer com isso que o Supremo Tribunal Federal não possa, diante da alteração da realidade social, da evolução da tecnologia e da própria transformação da compreensão do direito (o que não se confunde com o mero repensar o direito), entender que os fundamentos das suas decisões perderam consistência, e que, assim, os seus precedentes podem ser revogados. Isso é plenamente viável até mesmo no common law. Aliás, isso sempre foi praticado nos Estados Unidos.

No common law, os precedentes são revogados fundamentalmente mediante o que se denomina de *overruling*. Não há dúvida que o Supremo Tribunal Federal pode revogar os seus precedentes. Pode revogar, note-se bem, as *rationes decidendi* das suas decisões.¹⁵⁰ Para tanto, contudo, tem de se desincumbir de pesado ônus argumentativo, demonstrando que as razões que levaram à elaboração do precedente que se quer revogar não são mais sustentáveis em virtude de motivos novos, que devem ser mostrados presentes. Tais “motivos novos”, é evidente, estão muito longe de novos entendimentos pessoais acerca da questão já debatida.

Para dar concretude ao princípio de que casos semelhantes devem ser decididos da mesma maneira, é necessário atribuir eficácia vinculante aos motivos determinantes da decisão, isolando-se, em outras palavras, a sua *ratio decidendi*. Da coisa julgada à eficácia vinculante da fundamentação, eis a realidade que se impõe diante da imprescindibilidade de preservar e proteger a igualdade diante da jurisdição e a força normativa da Constituição.

4.1.5. Interpretação da Ratio no Direito Brasileiro. A interpretação da *ratio* no direito brasileiro obedece aos mesmos padrões da sua interpretação no Common Law. É fundamental que se comparem as soluções dadas às questões de direito à luz dos fatos subjacentes, além dos precedentes posteriores que procuraram utilizá-la para a solução de outros casos. Sem que exista similitude fático-jurídica, o precedente é inaplicável.

4.2. Obiter Dictum. As decisões judiciais contêm razões determinantes e razões outras. Essas últimas compõem o campo do *obiter dictum*, despido de eficácia vinculante – nada obstante, como veremos, o tema possa ser teorizado com diversas nuances. Também para o seu delineamento no direito brasileiro, o seu exame no Common Law revela-se de grande interesse.

4.2.1. Obiter Dictum no Common Law. A discussão acerca do significado de *obiter dictum* é tão antiga, intensa e difícil quanto a travada sobre o significado de *ratio decidendi*.¹⁵¹ Isso porque o conceito de *obiter dictum* é absolutamente atrelado ao de *ratio decidendi*.¹⁵²

Nos Setecentos – época em que já se discutia sobre a distinção entre *ratio decidendi* e *obiter dictum* – entendia-se que a última não era *judicial opinion*, tendo a ideia prevalecida até meados dos Oitocentos. Supunha-se que a *obiter dictum*, apesar de pronunciada por uma Corte, era um argumento de caráter extrajudicial.¹⁵³

Não é difícil perceber a razão pela qual o common law sempre se preocupou em distinguir *ratio decidendi* de *obiter dictum*. Tal distinção se deve à valorização dos fundamentos da decisão, peculiar ao common law. Como nesse sistema importa verificar a porção do julgado que tem efeito obrigatório, há motivo para se investigar com cuidado a fundamentação, separando-se o que realmente dá significado à decisão daquilo que não lhe diz respeito ou não lhe é essencial.

No civil law, ao contrário, cabendo aos tribunais apenas aplicar a lei, pouca importância se

teria de dar à fundamentação, já que essa faria apenas a ligação entre os fatos e a norma legal voltada a regular a situação litigiosa. A fundamentação, assim, seria necessariamente breve e sucinta. Uma vez que a decisão deveria apenas dar atuação à lei, não haveria motivo para buscar na fundamentação o significado da decisão. A decisão que se limita a aplicar a lei não tem nada que possa interessar a outros que não sejam os litigantes. É por esse motivo que, no civil law, o que sempre preocupou em termos de segurança jurídica foi o dispositivo da sentença, que aplica a regra de direito, dando-lhe concretude, e que é apto a ser revestido pela coisa julgada. Não é por outra razão que, quando se pensa em segurança dos atos jurisdicionais, alude-se somente à coisa julgada e, especialmente, à sua função de tornar imutável e indiscutível a parte dispositiva da sentença.¹⁵⁴

Ao tratar da *obiter dictum*, Rupert Cross e J. W. Harris perguntam se nela é possível ver mais do que uma proposição de direito que não forma parte da *ratio decidendi*. Cross e Harris admitem que, a princípio, a resposta à questão é negativa, embora devam ser considerados os diversos graus de autoridade e as várias espécies de *obiter dictum*.

Para se compreender o significado de *obiter dictum*, ainda que na dimensão do common law, torna-se necessário sublinhar que a *ratio decidendi* seria um passo necessário ao alcance da decisão. Isso fundamentalmente porque, quando se olha para uma questão perguntando-se se ela constitui *ratio decidendi* ou *obiter dictum*, indaga-se sobre a necessidade ou não de seu enfrentamento a fim de se chegar à decisão.¹⁵⁵

Algumas questões são indiscutivelmente desnecessárias ao alcance da decisão e, assim, enquadram-se certamente dentro do campo dos *obiter dicta*. Como esclarece Neil Duxbury, as passagens que são *obiter dicta* se apresentam de diversas formas, como as que não são necessárias ao resultado, as que não são conectadas com os fatos do caso ou as que são dirigidas a um ponto que nenhuma das partes buscou arguir.¹⁵⁶ De outro lado, informa Robert Summers, em trabalho voltado a explicar o funcionamento dos precedentes em seu país, que as espécies de *dicta* mais comuns nos Estados Unidos consistem em declarações da Corte sobre questões que ela não está realmente decidindo ou foi chamada a decidir.¹⁵⁷

Porém, há questões que nada têm a ver com o caso que está sendo julgado e questões que, embora não necessitem ser apreciadas para se chegar à decisão, têm íntima relação com o caso sub judice. De outra parte, algumas questões podem ter sido enfrentadas de forma aprofundada pela Corte e, além disso, acolhidas à unanimidade pelos juízes.

É claro que as questões relacionadas ao caso, bem como as que foram detidamente tratadas pela Corte e acolhidas por parte representativa dos seus membros, têm mais autoridade do que as que não dizem respeito ao caso sob julgamento e são apenas levemente enfrentadas.

Não obstante, o que parece mais preocupar os doutrinadores é algo que, bem vistas as coisas, guarda particularidade com o fato de no common law o sistema de precedentes se pautar na resolução dos casos.

Cross e Harris, por exemplo, aludem a questões independentes e questões dependentes para justificar a qualificação de uma dada questão como *obiter dictum*. Quando existem duas questões, mas o acolhimento de uma delas basta para dar ganho de causa à parte e, além disso, a abordagem da segunda questão não depende da aceitação da primeira, há questões independentes. Na hipótese em que a segunda questão apenas pode ser apreciada se acolhida a primeira, há questões dependentes.¹⁵⁸

Em *Perry v. Kendrick's Transport* havia duas questões perante a Corte de Apelação. Uma dizia respeito à impossibilidade de se obter indenização, por injúrias pessoais, com base em *Rylands v. Fletcher*. A outra era relativa à viabilidade de o réu invocar, em sua defesa e no seu recurso, que o dano foi causado pelo ato de um estranho. A decisão, fundando-se em um ou outro ponto, seria favorável ao réu-apelante. A Corte decidiu o primeiro ponto em favor do autor-apelado, concluindo que os danos por injúrias pessoais poderiam ser cobrados com base em *Rylands v. Fletcher*. Mas decidiu a segunda questão em favor do réu-apelante, que, assim, saiu vitorioso na

apelação.

Havia questões independentes em *Perry v. Kendrick's Transport*. Uma foi decidida em favor do apelado e outra em favor do apelante. Ou seja, a segunda pode ser decidida em favor do apelante ainda que a decisão da primeira tenha dado razão ao apelado. Porém, e aí é que surge a abordagem que realmente interessa, Cross e Harris afirmam que a decisão a respeito da primeira questão não constitui *ratio decidendi*, mas *obiter dictum*. *Ratio decidendi* seria apenas a declaração sobre a segunda questão.

O raciocínio segue a própria lógica de Cross, Harris, Wambaugh e Goodhart. De acordo com Cross e Harris, as alegações acerca da questão das injúrias pessoais eram *obiter* porque a Corte não poderia tê-las considerado como necessárias para a decisão em favor do réu, isto é, para o provimento da apelação. Elas também seriam *obiter* à luz do teste de Wambaugh, porque a apelação poderia ser decidida da mesma maneira ainda que a Corte houvesse decidido que os danos por injúria pessoal não poderiam ser cobrados com base em *Rylands v. Fletcher*. Se submetidas ao método de determinação da *ratio decidendi* de Goodhart, as alegações relativas à primeira questão ainda seriam *obiter*, já que a Corte deve ter considerado o fato de que as injúrias sofridas pelo autor eram pessoais, como imaterial ou não fundamental, e concluído que a defesa de que os danos foram praticados por um terceiro era cabível.

Não obstante entender que a abordagem da primeira questão seria *obiter*, Cross e Harris deixam claro que é difícil acreditar que um órgão de primeiro grau se sentiria livre para decidir que os danos por injúrias pessoais não podem ser cobrados com base em *Rylands v. Fletcher*, embora essa declaração seja apenas *dictum* perante a House of Lords.¹⁵⁹ Cross e Harris estão aludindo ao efeito persuasivo da *obiter dictum*, que, em casos como o referido, pode ter intensidade tão forte quanto a do efeito obrigatório, particular à *ratio decidendi*.

Em um outro caso submetido à House of Lords, *The Minister of Health v. The King*, ex parte Yaffé, também estavam presentes duas questões. Nesse caso, em que se buscava anular uma ordem do Ministro da Saúde, foram apresentadas duas defesas: uma afirmando que a Corte não tinha competência para examinar a validade da ordem e outra no sentido de que a ordem era válida, pois autorizada pelo Housing Act, 1925. A House of Lords, por votação unânime de seus membros, julgou contra o Ministro no primeiro ponto, mas, por quatro votos contra um, decidiu a segunda questão em seu favor. O resultado da segunda questão era certamente *ratio decidendi*, mas houve dúvida sobre o significado da resolução do primeiro ponto.¹⁶⁰

Seria possível dizer que, como a segunda questão dava ganho de causa ao Ministro, não era necessário analisar a primeira questão, que, por este motivo, seria *obiter dictum*. Porém, além de esta questão ter sido analisada em primeiro lugar, ela constituía um antecedente lógico no raciocínio dos juízes, ou seja, um ponto que, por lógica, necessariamente deveria ser analisado para que a Corte pudesse adentrar na análise do segundo ponto.

A diferença de natureza entre as questões analisadas em *Perry v. Kendrick's Transport* e em *The Minister of Health v. The King*, ex parte Yaffé, foi detectada por Rupert Cross, que salientou que, no último caso, as questões não eram independentes, mas interdependentes.¹⁶¹ Se a primeira questão é um antecedente necessário ao julgamento da segunda, a ausência de necessidade, apontada em *Perry v. Kendrick's Transport*, não poderia ser invocada para se negar à resolução da primeira questão a qualidade de *ratio decidendi*.

Contudo, no caso de questões independentes, a questão cuja análise não é necessária à resolução – que, assim, é *obiter dictum* – é intimamente ligada ao caso sob julgamento e abordada de forma aprofundada pelo tribunal, assumindo perfil e textura muito próximos ao da *ratio decidendi*. Portanto, esse *obiter dictum* representa uma espécie que merece ser diferenciada da comum das *obiter dicta*.

Lembre-se que o tribunal, em alguns casos, trata de pontos irrelevantes, cuja análise sequer precisaria ser feita e que, portanto, acaba representando um excesso de argumentação. Este tipo de *obiter dictum* certamente não tem o mesmo significado da *obiter dictum* que trata de maneira

aprofundada de ponto de direito relacionado ao caso.¹⁶²

O obiter dictum que se aproxima da ratio decidendi, embora não tenha efeito obrigatório, tem efeito persuasivo bastante forte. Recorde-se que, ao analisar *Perry v. Kendrick's Transport*, Cross e Harris chegam a dizer que é difícil acreditar que um juiz de primeiro grau possa se sentir livre para negar o que a Corte decidiu em favor do apelado, embora essa, reconhecendo o argumento do réu-apelante, tenha lhe dado ganho de causa no appeal.¹⁶³

Diante da diferença entre esses obiter dicta, a doutrina fala em judicial dictum e em gratis dictum. Atribui-se tais denominações ao obiter dictum com grande efeito persuasivo, reservando-se o tradicional título obiter dictum às proposições que tratam de questões não relevantes e periféricas.¹⁶⁴

4.2.2. Obiter Dictum no Direito Brasileiro. No direito brasileiro, não basta simplesmente constatar que os fundamentos não efetivamente discutidos constituem obiter dicta. Nem mesmo há como pensar que obiter dicta são apenas os fundamentos não adequadamente discutidos. É preciso verificar, antes de tudo, se o fundamento podia ser discutido e se a decisão tomada exigia a sua discussão.¹⁶⁵ Desse modo, torna-se inclusive mais claro e objetivo o raciocínio que se deve percorrer para a determinação da ratio decidendi e do obiter dictum.

Os pronunciamentos que dizem respeito a pedido não formulado e à causa de pedir não invocada são inegavelmente obiter dicta. O mesmo se passa em relação aos fundamentos que, embora façam parte da causa de pedir, não foram alegados e discutidos pelas partes e, assim, estariam sendo tratados no processo pela primeira vez. Os pronunciamentos relativos a esses pontos são, em regra, não aprofundados e não decorrem de discussão entre todos os membros do colegiado, sendo feitos de passagem ou lateralmente ao enfrentamento de outra questão.¹⁶⁶

Todavia, como os frutos dessas discussões podem se sedimentar, dando origem à procedência do pedido ou mesmo ao provimento do recurso, aquilo que, em tese e à primeira vista, é obiter dictum pode se transformar em ratio decidendi. O pedido, a causa de pedir ou o fundamento que não poderiam ser apreciados, embora gerem sentenças passíveis de rescisão – seja por violação ao princípio da adstrição ao pedido e à causa de pedir ou ao direito ao contraditório, especialmente no que tange à vedação, as chamadas “decisões-surpresa” (art. 10, CPC/2015) –, podem dar origem a decisões transitadas em julgado e, inclusive, a decisões soberanamente transitadas em julgado, passados dois anos sem a propositura de ação rescisória. Assim, é possível pensar nas razões que especificamente conduziram a tais decisões, isolando-se as suas rationes decidendi, embora essas possam merecer menos crédito. E isso, é claro, quando as questões tiverem sido efetivamente discutidas por todos os integrantes do órgão colegiado, pressuposto sem o qual, aliás, nenhum pronunciamento, ainda que relativo a pedido e causa de pedir invocados e discutidos pelas partes, pode vir a constituir ratio decidendi.

Mais difícil, sem dúvida, é isolar o fundamento que, independentemente de ter sido alegado e discutido pelos juízes, era desnecessário à tomada da decisão. É certo que, quando um fundamento é desnecessário para se chegar à solução de dada questão, em regra ele não é tomado a sério e efetivamente discutido pelos juízes, caracterizando-se facilmente, dessa forma, como obiter dictum. Entretanto, em tese isso nem sempre pode ser assim. Daí a importância de se analisar a conhecida definição de Rupert Cross e J. W. Harris, celebrizada no common law, de que “a ratio decidendi de um caso é qualquer regra de direito expressa ou implicitamente tratada pelo juiz como passo necessário para alcançar a sua conclusão, tendo em vista a linha de raciocínio por ele adotada, ou uma parte de sua instrução para o júri”.¹⁶⁷

É preciso esclarecer em que termos se deve ter a decisão para a qual a ratio decidendi constitui passo necessário. Importa perceber que o passo necessário, ou a premissa ou as razões no curso do raciocínio decisório, não diz respeito à “decisão do caso” vista em abstrato, como sua mera resolução ou algo que, em tese, deve ocorrer para que o processo chegue ao fim. O passo necessário não se refere a uma decisão qualquer, mas à específica decisão tomada pelo juiz ou pela Corte em determinado caso.

De modo que para individualizar o passo necessário não basta relacioná-lo, por exemplo, com a solução do recurso, mas com a decisão que deu ou negou provimento ao recurso e, mais do que isso, com o raciocínio decisório empreendido pela Corte para lhe dar ou lhe negar provimento. Assim, se a Corte, ao dar provimento ao recurso do réu, decide pela decadência do direito do autor, obviamente não importam as alegações de que, interpretando-se de determinada maneira a norma x ou considerando-se a tese y, o réu não poderia ser condenado. Tais alegações não constituem passo necessário à decisão de decadência.

Porém, se o tribunal, para dar provimento ao recurso e condenar o réu a pagar, pode interpretar a norma x de determinada forma ou admitir a tese y, seria possível dizer que as razões relacionadas à admissão da tese y não importam porque o recurso foi provido com base na interpretação da norma x. Em verdade, é possível dizer que a admissão da tese y, neste caso, não é um passo necessário.

Contudo, deixando-se de lado a ideia de necessidade pela de suficiência, é possível concluir que a admissão da tese y, embora não necessária, seria suficiente para a condenação do réu. Note-se que, no caso do exemplo anterior, em que o tribunal reconheceu a decadência do direito do autor, as demais alegações do réu não seriam suficientes para a pronúncia de decadência. Perceba-se, assim, que a ideia de provimento do recurso, vista como solução do caso, necessita ter uma cor – precisa, por exemplo, apontar para um resultado no plano do direito substancial.

Quando um dos fundamentos, entre os vários alegados no recurso, for suficiente para provê-lo, os outros certamente não poderão ser considerados como necessários ao provimento. Porém, é comum, na prática forense, ter em conta dois fundamentos para julgar procedente o pedido, assim como dois fundamentos para dar provimento ao recurso. É claro que o juiz ou o Tribunal, nestas hipóteses, não precisa examinar todos os fundamentos, bastando analisar um deles. Contudo, tanto o juiz quanto o tribunal não estão proibidos de julgar procedente o pedido ou dar provimento à apelação com base em dois fundamentos, ainda que cada um deles seja suficiente a tanto.

Entretanto, o fato de um fundamento (por exemplo, a admissão da tese y) ser suficiente ao provimento do recurso, não garante que as razões que o apreciaram possam dar origem a uma *ratio decidendi*. No caso em que existem duas razões suficientes, é preciso que ambas, para poderem ser reconhecidas, tenham sido adequadamente discutidas pelos membros do colegiado.

Há um julgado do Superior Tribunal de Justiça que, por sua repercussão no meio forense, oferece interessante exemplo de *obiter dicta*. Trata-se de julgado que tratou da interpretação do art. 475-J do CPC do Código de 1973, mais precisamente a respeito da necessidade de intimação do condenado para a incidência da multa de 10% diante do não pagamento no prazo de quinze dias. No REsp 954.859, decidiu-se que a multa incidiria independentemente de intimação pessoal do condenado.¹⁶⁸ O relator, Ministro Humberto Gomes de Barros, assim argumentou: “Alguns doutrinadores enxergam a exigência de intimação pessoal. Louvam-se no argumento de que não se pode presumir que a sentença publicada no Diário tenha chegado ao conhecimento da parte que deverá cumpri-la, pois quem acompanha as publicações é o advogado. O argumento não convence. Primeiro, porque não há previsão legal para tal intimação, o que já deveria bastar. Os arts. 236 e 237 do CPC [1973] são suficientemente claros neste sentido. Depois, porque o advogado não é, obviamente, um estranho a quem o constituiu. Cabe a ele comunicar seu cliente de que houve a condenação. Em verdade, o bom patrono deve adiantar-se à intimação formal, prevenindo seu constituinte para que se prepare e fique em condições de cumprir a condenação. Se o causídico, por desleixo, omite-se em informar seu constituinte e o expõe à multa, ele deve responder por tal prejuízo”.¹⁶⁹ Note-se que o Tribunal não estava julgando a responsabilidade do advogado, mas somente analisando a necessidade de intimação pessoal do condenado para a incidência da multa.¹⁷⁰ De modo que a observação do relator, no sentido de que o advogado se torna responsável pela multa ao não informar seu constituinte sobre a condenação – certa ou não –, é verdadeiro *obiter dictum*, configurando-se como mero argumento lateral, à margem da questão que estava sendo discutida, de solução desnecessária para se chegar à decisão do recurso. Consequentemente, esta observação, de que o advogado é responsável pela multa do art. 475-J do CPC de 1973, jamais poderá ser invocada como precedente ou *ratio decidendi*.

O Supremo Tribunal Federal, no AgRg na Rcl 2.475, também discutiu questão de grande relevância quando se discute a respeito de obiter dictum. Mediante esta reclamação, afirmou-se que a 2.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg em REsp 429.610/MG, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 1/DF, em que se entendeu que a LC 70/1991 – que concedeu isenção para as sociedades civis prestadoras de serviços profissionais – é materialmente ordinária e apenas formalmente complementar. A 2.^a Turma do STJ concluiu que a revogação da isenção da Cofins não poderia ocorrer por lei ordinária, sob pena de lesão ao princípio da hierarquia das leis. Argumentou a reclamante que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 1/DF, “considerou que a Constituição da República não exige lei complementar para disciplinar a Cofins, motivo pelo qual se deve ter a LC 70/1991, que a instituiu, como uma lei apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária. A consequência desse fundamento é o de admitir que lei ordinária venha a alterar os dispositivos da referida lei complementar, justamente o que fez o art. 56 da Lei 9.430/1996, que revogou a isenção da Cofins concedida no inc. II do art. 6.^o da LC 70/1991 para as sociedades civis de prestação de serviços profissionais”.¹⁷¹

A liminar requerida na reclamação foi negada, quando se disse que a decisão proferida na ADC 1/DF “não assentou ser a LC 70/1991 lei complementar simplesmente formal. É verdade que no voto do Ministro relator isso foi dito (RTJ 156/745). Trata-se, entretanto, de um obiter dictum. Também no meu voto expressei obiter dictum igual (RTJ 156/745). Assim, pelo menos ao primeiro exame, não vejo configurado o fumus boni juris que autoriza o deferimento da liminar”¹⁷² (decisão objeto do agravo regimental, da lavra do Ministro Carlos Velloso).

A reclamante, no agravo regimental interposto contra esta decisão, sustentou que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou, para considerar a Cofins constitucional, que se estava diante de uma lei apenas formalmente complementar, ele expôs um motivo determinante e não um obiter dictum.

O relator originário do agravo regimental, Ministro Carlos Velloso, disse que, “por não ter sido pedido que o Tribunal declarasse que a LC 70/1991 seria materialmente lei ordinária, não poderia o Tribunal isso decidir, sob pena de decidir extra petita. É verdade que, no voto do Ministro relator, foi dito que a contribuição poderia ser instituída por lei ordinária e que ‘essa lei, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída – que não são objeto dessa ação – é materialmente ordinária’ (RTJ 156/745). Também no meu voto isso afirmei (RTJ 156/752). Tais afirmativas, entretanto, constituem fundamento dos votos, ou seus motivos. No que me concerne, obiter dictum. De um modo ou de outro – fundamento ou obiter dictum – não integram o dispositivo da decisão”.¹⁷³

O Ministro Marco Aurélio, seguindo o voto do relator, observou: “Não se fez em jogo, quando julgamos a ADIn 1, a natureza da lei que teria disciplinado o Cofins. Como salientado pelo relator, consideramos a anterioridade, o princípio da não cumulatividade e não adentramos nessa seara. O relator da ADIn 1 aludiu ao fato de que não haveria sequer necessidade de lei complementar para a criação do tributo, da contribuição. Evidentemente, todavia, se inexistiu celeuma em torno dessa matéria, não chegamos a decisão a respeito. Por isso acompanho o relator”.¹⁷⁴

O Ministro Sepúlveda Pertence deixou claro que, no seu entender, não há como buscar fazer valer a autoridade de decisão proferida em ação direta de constitucionalidade, via reclamação, arguindo-se desrespeito aos seus fundamentos: “Quero deixar claro que, em princípio, não estendo o efeito vinculante das decisões nas ações de controle abstrato de normas à sua fundamentação; isso me basta. Para mim, só desrespeitaria a nossa decisão na ADC 1 se se tivesse julgado inconstitucional dispositivo da LC 70, então questionada, e então afirmados constitucionais”.¹⁷⁵

O voto do Ministro Gilmar Mendes, ao contrário dos votos dos Ministros Carlos Velloso (relator), Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence – que o antecederam – não se preocupou em saber se a questão relativa à natureza da norma estava abrangida pela parte dispositiva da decisão tomada na ação direta de constitucionalidade. Isso porque, no seu entender, a eficácia vinculante cobre os motivos determinantes da decisão. Assim, o que importaria saber era apenas se os pronunciamentos da Corte acerca desta questão constituíam obiter dicta ou motivos

determinantes da decisão.

O voto do Ministro Gilmar foi dirigido à demonstração de que a questão respeitante à natureza jurídica da LC 70/1991 fora tratada no acórdão da ADC 1/DF. Consta do voto: “Atenta leitura do acórdão na ADC 1/DF permite afirmar que a questão da natureza jurídica da LC 70/1991 foi expressamente tratada nos votos dos Ministros Moreira Alves (relator), Ministro Carlos Velloso (fls. 140-141) e Ministro Sydney Sanches (fl. 149). Os demais ministros não enfrentaram expressamente a questão, silenciando-se a seu respeito, mas, genericamente, acompanharam o voto do relator. Dessa forma, não se pode deixar de admitir que a decisão proferida na ADC 1/DF foi enfática ao reconhecer, como um de seus fundamentos determinantes, que não se exige lei complementar para a disciplina dos elementos próprios à hipótese de incidência das contribuições desde logo previstas no texto constitucional, de forma que, por razões lógicas, a LC 70/1991 é, materialmente, uma lei ordinária, muito embora seja, à evidência, lei formalmente complementar. E não prevalece o argumento de que tal assertiva não constitui fundamento determinante, mas apenas complementação (ou obiter dictum) ao fundamento principal (que, segundo se alega, seria a existência de previsões constitucionais distintas para a Cofins e o PIS), pois resta claro do voto do Ministro Moreira Alves que esta é premissa essencial, a qual conduziu à conclusão pela constitucionalidade dos dispositivos em discussão (...). Assim sendo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, na decisão do AgRg no REsp 429.610/MG, não observou fundamento determinante de decisão desta Corte Suprema proferida na ADC 1/DF, de modo que o pedido da presente reclamação, ao que parece, deve ser julgado improcedente”.¹⁷⁶

A questão relativa à possibilidade de estender a eficácia vinculante aos motivos determinantes da decisão de inconstitucionalidade deve ser vista de forma separada em face da respeitante à identificação das porções que, na fundamentação, constituem ratio decidendi e obiter dictum. Melhor explicando: inadmitindo-se que os motivos da decisão possam ter eficácia vinculante, não há sequer por que questionar, em sede de reclamação, se determinado pronunciamento da Corte, por ocasião do julgamento de ADC, constitui motivo determinante ou obiter dictum. Ora, se a fundamentação não pode ser abarcada pela eficácia vinculante, e, destarte, não pode ser alegada como base de reclamação contra desrespeito a decisão prolatada em ADC, pouco importa a determinação da ratio decidendi.

O Ministro Carlos Velloso reconheceu que, na ADC 1, tanto o seu voto quanto o do relator afirmaram que a LC 70/1991 é materialmente ordinária, e, logo depois, concluiu que “tais afirmativas (...) constituem fundamento dos votos, ou seus motivos. No que me concerne, obiter dictum. De um modo ou de outro – fundamento ou obiter dictum – não integram o dispositivo da decisão”. Portanto, ao negar provimento ao agravo regimental, o Ministro Velloso firmou o entendimento de que “tais afirmativas (...) não integram o dispositivo da decisão”. Do seu voto, resta claro que não importou se “tais afirmativas” constituíam motivos determinantes ou obiter dicta, mas se integravam ou não o “dispositivo da decisão”. Ou seja, como para o Ministro Velloso, os fundamentos não são tocados pela eficácia vinculante, bastaria constatar que as referidas “afirmativas” não estão inseridas na parte dispositiva da decisão. Tanto é que, antes, o Ministro Velloso disse que o Tribunal não poderia sequer declarar que a LC 70/1991 é materialmente lei ordinária, por isso “não ter sido pedido”. Caso isso tivesse sido declarado, estaria o Supremo Tribunal Federal a “decidir extra petita”.¹⁷⁷

O voto do Ministro Sepúlveda Pertence também não deu qualquer importância à distinção entre ratio decidendi (ou motivos determinantes) e obiter dicta. Foi incisivo ao dizer que não estende “o efeito vinculante das decisões nas ações de controle abstrato de normas à sua fundamentação”.¹⁷⁸

O Ministro Marco Aurélio disse que o Tribunal não teria enfrentado a questão; alegou que “inexistiu celeuma em torno dessa matéria”. Porém, concluiu que, diante dessa falta de discussão, o Tribunal não chegou “à decisão a respeito”.¹⁷⁹ Assim, embora o Ministro Marco Aurélio, em princípio, aluda a argumento capaz de demonstrar que pronunciamento inserido na fundamentação é obiter dictum – por não ter sido discutido –, torna-se claro que essa alusão é feita para permitir a conclusão de que a Corte não proferiu decisão a respeito. Mais uma vez, portanto,

importou a circunstância de que o pronunciamento sobre a natureza jurídica da lei não constituiu uma decisão, ou melhor, não foi abarcado pela parte dispositiva da decisão.

Contudo, o voto do Ministro Gilmar, sem dúvida, preocupou-se em demonstrar que as afirmativas ou os pronunciamentos acerca da questão constituíram motivos determinantes da decisão de constitucionalidade, não podendo ser vistos como *obiter dicta*. Nesta perspectiva – de análise da natureza dos pronunciamentos inseridos na fundamentação – importava apenas saber se a questão realmente havia sido discutida pelos Ministros. O argumento do Ministro Carlos Velloso, de que, “por não ter sido pedido que o Tribunal declarasse que a LC 70/1991 seria materialmente lei ordinária, não poderia o Tribunal isso decidir, sob pena de decidir *extra petita*”,¹⁸⁰ não tem procedência. Sabe-se que a petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade deve indicar o dispositivo questionado, demonstrar a existência de controvérsia judicial relevante acerca da sua aplicação e apresentar o pedido de declaração de constitucionalidade deste dispositivo. Ademais, deve conter os fundamentos jurídicos do pedido (art. 14, I, II e III, Lei 9.868/1999). Mas o Tribunal está adstrito apenas ao pedido ou aos dispositivos apontados como constitucionais, e não aos fundamentos jurídicos. Vale aqui o entendimento adotado em relação à ação direta de inconstitucionalidade, de que o Tribunal pode declarar a inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos apresentados na petição inicial.¹⁸¹ Sendo o caso de declarar a constitucionalidade, o Tribunal pode cogitar de qualquer fundamento bastante para evidenciá-la, ainda que não alegado na inicial.

Assim, enquanto o pedido evidentemente não era – nem poderia ser – de declaração de que a lei “seria materialmente lei ordinária”,¹⁸² não importa se esta questão foi alegada na petição inicial. O que interessa, para aceitar que a questão constitui *ratio decidendi* no acórdão proferido na ADC 1/DF, é que a discussão de a LC 70/1991 ser, materialmente, uma lei ordinária “conduziu à conclusão pela constitucionalidade dos dispositivos em discussão”.¹⁸³

De qualquer forma, apenas o voto do Ministro Gilmar Mendes atentou para a individualização da natureza de “tais afirmativas” ou pronunciamentos no interior da fundamentação. Torna-se estranha, nesta dimensão, a própria ementa do acórdão proferido na reclamação, salientar que “no julgamento da ADC 1/DF, o Colegiado não dirimiu controvérsia sobre a natureza da LC 70/1991, consubstanciando a abordagem, no voto do relator, simples entendimento pessoal”.¹⁸⁴

5. Distinções (Distinguishing). O Código de 2015 fala na necessidade de o juiz identificar os “fundamentos determinantes” dos julgados a fim de demonstrar que “o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos” (art. 489, § 1.º, inciso V). Ainda, fala na necessidade de o juiz, para deixar de seguir um precedente ou jurisprudência vinculante, “demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento” (art. 489, § 1.º, inciso VI). Daí a oportunidade de se enfrentar o conceito de distinções (*distinguishing* – na terminologia do *Common Law*) como técnica processual da mais alta importância para a operação prática do Código de 2015. Como se trata de instituto cuja inspiração na tradição anglo-saxã é evidente, é oportuno primeiro investigá-lo nas suas origens para depois pensá-lo a partir do nosso Direito.

5.1. Distinguishing no Common Law. Para se compreender o precedente é indispensável delimitar a sua *ratio decidendi*, separando-se dela o *obiter dictum*. Como o precedente tem como objetivo regular o futuro, uma das questões centrais de qualquer teoria dos precedentes está na aplicação da *ratio decidendi* aos novos casos.

É intuitivo que para aplicar a *ratio decidendi* a um caso, é necessário comparar o caso de que provém a *ratio decidendi* com o caso sob julgamento, analisando-se as suas circunstâncias fáticas. Isso significa uma assimilação para fins de aplicação do precedente ou uma diferenciação ou distinção de casos a fim de afastá-la. Nesse contexto, essa busca entre semelhanças e diferenças entre os casos assume a forma de técnica jurídica voltada a permitir a aplicação dos precedentes. Nesse sentido fala-se no *common law* em *distinguishing*.

Surge, então, a primeira função que é acometida ao *distinguishing* no *Common Law* – permitir a realização de distinções entre casos a fim de que determinado precedente não seja aplicado de forma indevida.

O distinguishing expressa a distinção realizada entre casos a fim de afastar a aplicação de um precedente a determinado caso.¹⁸⁵ Daí que a necessidade de comparação entre os casos exige, como antecedente lógico, a identificação da ratio decidendi do precedente. Como a ratio espelha o precedente que deriva do caso, trata-se de opor o caso sob julgamento à ratio do caso decorrente do primeiro julgamento.

Assim, é necessário antes de qualquer coisa delimitar a ratio decidendi considerando-se os fatos materiais do primeiro caso, ou seja, os fatos que foram tomados em consideração no raciocínio judicial como relevantes ao encontro da decisão. De modo que o distinguishing revela a demonstração entre as diferenças fáticas entre os casos ou a demonstração de que a ratio do precedente não se amolda ao caso sob julgamento, uma vez que os fatos de um e outro são diversos.

Ao realizar o distinguishing, o juiz deve atuar com prudência e a partir de critérios. Como é óbvio, poder para fazer o distinguishing está longe de significar sinal aberto para o juiz desobedecer precedentes que não lhe convêm. Ademais, reconhece-se na cultura do common law que o juiz é facilmente desmascarado quando tenta distinguir casos com base em fatos materialmente irrelevantes.¹⁸⁶

Diferenças fáticas entre casos, portanto, nem sempre são suficientes para se concluir pela inaplicabilidade do precedente. Fatos não fundamentais ou irrelevantes não tornam casos desiguais. Para realizar o distinguishing não basta ao juiz apontar fatos diferentes, cabendo-lhe argumentar para demonstrar que a distinção é material (isto é, fundamental, apta a ensejar conclusão diversa daquela adotada no precedente) e que, portanto, há justificativa para não se aplicar o precedente. Ou seja, não é qualquer distinção que justifica o distinguishing. A distinção fática deve revelar uma justificativa convincente, capaz de permitir o isolamento do caso sob julgamento em face do precedente.

Note-se que exatamente pela circunstância de que o distinguishing depende de justificativa, há que se ter uma pauta racional uniforme na identificação dos seus critérios. Ou melhor, há que se uniformizar a aplicação dos próprios critérios para a realização do distinguishing, criando-se aí também uma obrigação de se respeitarem as decisões passadas.

A não adoção do precedente em virtude do distinguishing não quer dizer que o precedente está equivocado ou deve ser revogado. Não significa que o precedente constitui bad law, mas somente inapplicable law.¹⁸⁷ Porém, a declaração de que o precedente é inaplicável não elimina a dúvida a respeito da sua higidez. Isso porque a constatação da inaplicabilidade do precedente não tem relação com o seu conteúdo e força. Todavia, a não aplicação de precedente, especialmente quando rotineira, pode revelar que o seu conteúdo não está sendo aceito na comunidade jurídica e nos tribunais. O precedente perde naturalmente a sua autoridade e credibilidade quando se torna very distinguished. Quer dizer que a distinção, por si só, não revela a fragilidade do precedente, embora o excesso de distinções possa ser sinal de enfraquecimento da sua autoridade.¹⁸⁸

Diante da teoria do direito do common law, há interesse em indagar se o distinguishing declara um direito novo ou cria o direito ou mesmo se a intenção dos juízes é uma dessas duas. Antes de supor que o juiz está em busca da declaração de um direito novo, é necessário constatar que ele atua para dar solução ao caso. O juiz realiza o distinguishing por entender que, seguindo o precedente, estará proferindo decisão inadequada e não por possuir uma law-making, agenda.¹⁸⁹

Numa primeira visão, o distinguishing é apenas a declaração de que o direito evidenciado no precedente não deve regular o caso sob julgamento. Portanto, é uma declaração negativa, jamais podendo chegar perto da declaração de um direito novo ou da sua constituição. Isso pode ocorrer apenas após a declaração de inaplicabilidade do precedente e, ainda assim, não necessariamente, já que se pode adotar outro precedente. Porém, a decisão que estende a aplicação do precedente a outra hipótese dá origem ao seu incremento – quando se torna possível pensar em mudança do direito.

Explique-se: na última hipótese são consideradas outras circunstâncias que não estiveram no

caso que fora solucionado mediante o primitivo precedente. Assim, a ideia de extensão ou de incremento do precedente exige a consciência de que se aplica o direito impresso no precedente a caso constituído por elementos fáticos que se agregam aos tomados em consideração no caso anterior.

A propósito, lembra Neil Duxbury, que a mais interessante e sutil forma de distinguishing é aquela em que a Corte deixa de lado um precedente para, em razão da presença de um maior número de fatos materiais, editar uma regra particular. Assim, se a Corte decide, em *Black v. Black*, que *x* é o resultado diante dos fatos *a*, *b* e *c*, o mesmo se deve esperar em *White v. White* se os fatos operativos também são *a*, *b* e *c*. Suponha-se, no entanto, que em *Grey v. Grey*, a Corte diferencia *Black v. Black* e decide que *x* deve ser o resultado quando está presente *e*, além de *a*, *b* e *c*. Em *Grey v. Grey*, a Corte, para decidir por *x*, além de *a*, *b* e *c*, considera *e*, isto é, outro fato material. A Corte, dessa forma, entende que outra condição é necessária para se ter *x*, o que revela uma nova *ratio decidendi* ou, mais precisamente, uma *ratio decidendi* limitada em relação àquela formulada em *Black v. Black*. Por exigir outros fatos materiais, a nova *ratio decidendi* é aplicável a um número reduzido de casos.¹⁹⁰

Esse exemplo mostra que o distinguished acaba permitindo a alteração do precedente – ou melhor, o alcance da *ratio decidendi* do precedente. Há, em verdade, um redimensionamento da *ratio decidendi* ou a sua acomodação a um caso que, além de caracterizado pelas circunstâncias fáticas (ainda que não todas) que marcaram aquele que deu origem ao precedente, é constituído por outros fatos materiais e, assim, depende de outras exigências. Note-se que o caso obviamente não pode ser integralmente diverso. Ele deve conter os fatos presentes no caso que abriu ensejo ao precedente, aos quais se somam novas circunstâncias fáticas.

Diante disso, indaga-se quando se permite esta modalidade de distinguishing, em que se corrige o precedente para se abarcar um caso constituído por fato antes não previsto. O distinguishing apenas é viável quando o novo fato não é incompatível com o resultado a que se chegou no precedente. Esse fato, combinado com aqueles presentes no caso anterior, deve justificar o ajuste do precedente ao caso sob julgamento. Assim, se o fato antes ignorado, ao ser considerado, exige resultado contrário ao firmado no precedente, a *ratio decidendi* não estará sendo adequadamente ajustada. Nessa hipótese, o precedente não poderá ser legitimamente aplicado mediante a técnica do distinguishing.¹⁹¹

Entretanto, resta situação inversa, ou seja, aquela em que se limita o âmbito de incidência do precedente para não aplicá-lo ao caso em julgamento. Isso apenas será possível, a princípio, quando se tomar em conta situação não tratada no precedente e entendimento posterior, capaz de justificar a não aplicação do precedente à hipótese, que, precisamente, dá configuração a caso distinto.

Porém, nessa última espécie de distinguishing, não há compatibilidade entre os resultados do precedente e da nova decisão. Ora, esta decisão afirma que o resultado do precedente é inaplicável ao caso diferenciado. Note-se, porém, que essa incompatibilidade tem a ver apenas com os resultados do precedente e da distinção, enquanto, quando se considera as razões e a racionalidade de ambas as decisões, a compatibilidade deve se apresentar. A distinção, apesar de levar a resultado inverso, deve ser justificável à luz das razões do precedente e da distinção.

Quando se passa a raciocinar com o distinguishing nessa perspectiva, fica claro que ele passa a incorporar igualmente uma segunda função – passa a ser um meio de desenvolvimento do Direito mediante a extensão e a limitação dos precedentes.

Corte, ao instituir um precedente, pode deixar de considerar alguma questão relacionada com o entendimento firmado. Ademais, em virtude de os casos variarem naturalmente, conforme as particularidades que lhe dão configuração, é sempre possível o surgimento de novas situações, não tratadas no precedente. Assim, ainda que, a princípio, se possa pensar que se está tratando da mesma tese e de situação fática semelhante, haverá a possibilidade de se argumentar que o novo caso requer o enfrentamento de outra questão ou que o caso sob julgamento tem particularidade fática que o diferencia daquele envolvido no precedente. Além disso, como o precedente é incapaz

de contemplar a riqueza das situações conflitivas, um novo caso pode não se subsumir perfeitamente no precedente, ainda que esse caso, dadas as suas particularidades, mereça igual solução quando consideradas as razões do precedente.

Essas questões estão relacionadas com o alcance do precedente, ou melhor, com a circunstância de que um precedente pode ter sido concebido com conteúdo restrito ou limitado e um outro com conteúdo amplo ou mais extenso. Na verdade, como o alcance do precedente apenas pode ser analisado de forma crítica à luz dos novos casos, dado o seu caráter relacional, não há como afirmar – apenas diante do precedente – se aquele é amplo ou limitado. Ou seja, o alcance do precedente apenas pode ser visto como limitado ou amplo quando confrontado com novos casos. É nessa oportunidade que o tribunal se depara com a questão de saber se deve estender ou restringir o precedente.

Essa questão exige a ponderação entre os fundamentos do precedente em jogo (substantive reasons) e os princípios que justificam o sistema de precedentes, vale dizer, a unidade da ordem jurídica, a segurança, a liberdade e a igualdade (authority reasons). Quer dizer que a extensão do precedente prioriza as suas próprias razões, pois tende a permitir que ele regule novos casos, enquanto a tendência à sua limitação objetiva preserva as razões de segurança, na medida em que não possibilita que se dê a mesma solução jurídica a outros casos, vistos como distintos.¹⁹²

Porém, a limitação do precedente, bem vistas as coisas, não significa ênfase à estabilidade. Esse valor é preservado, em realidade, mediante a contenção do precedente, evitando-se não só o seu inchamento, mas também a sua limitação. Isso porque a limitação do precedente pode derivar do intuito de não se tratar do mesmo modo de caso que, a princípio – ou seja, sem a limitação –, seria semelhante, merecendo igual solução.

De qualquer forma, é certo que a extensão ou a limitação do alcance dos precedentes constitui forma de relacioná-los com novos casos, tornando-os adequados à solução de distintas realidades. Dessa forma há o desenvolvimento do significado e da força dos precedentes, que passam a se adaptar, sem rupturas, às situações que vão surgindo à medida que o tempo passa.¹⁹³

Embora o precedente possa ter o seu conteúdo restrito ou ampliado, é preciso ver que a aplicação do precedente deve ser compatível com a sua finalidade. Não há como admitir a adoção de um precedente quando essa é incompatível com a sua finalidade ou com as razões que justificaram a sua instituição – faltaria aí razoabilidade na aplicação do precedente.¹⁹⁴ Todavia, tal incompatibilidade também pode se dar diante de razões que estão à base de uma situação nova, não tratada no precedente, que impõem a limitação do alcance do precedente e, assim, em termos concretos, a sua não aplicação ao caso sob julgamento.

Considerada a sua finalidade, o precedente deve ser aplicado até os seus limites, regulando todos os casos aí cabíveis. É tal potencialidade, inerente ao precedente, que torna possível a sua adoção para a solução de casos particularizados por outras circunstâncias ou situações inicialmente não tratadas. Por idênticos motivos, se o fim do precedente deixa de estar presente diante de nova situação, não há como aplicá-lo. Em suma, se há outra situação, singularizada por razões compatíveis ou incompatíveis com as do precedente, justifica-se respectivamente a extensão ou a limitação do alcance do precedente.

É interessante perceber que o sistema de precedentes, quando visto a partir da técnica da distinção, sem perder a sua função de preservação da estabilidade, torna-se maleável e capaz de permitir o desenvolvimento do direito, dando conta das novas realidades e das situações que, embora antigas, não foram anteriormente tratadas, sem que com isso seja preciso o rompimento do sistema ou a revogação do precedente que ainda é necessário e suficiente para tratar das situações que contemplou desde a sua origem. Portanto, realizar distinção para aplicar ou deixar de aplicar um precedente é algo que milita, a um só tempo, para a estabilidade e para o desenvolvimento do direito.

Não obstante, é fundamental não deixar escapar outro ponto: a técnica da distinção é sempre utilizada nas perspectivas das partes e do Poder Judiciário. A primeira perspectiva faz ver o

próprio impulso prático para a distinção, uma vez que, partindo-se da premissa de que um precedente sempre beneficia dada posição ou pode beneficiá-la, a restrição da sua aplicabilidade é sempre favorável a uma parte e prejudicial à outra. O que significa dizer que no processo são desenvolvidos argumentos a favor e contra a adoção do precedente. Nesse sentido, há verdadeira tensão no interior do sistema, quase a constituir uma luta entre a contenção e a extensão do precedente.

Na outra perspectiva do Poder Judiciário, são contrapostos os valores do sistema, ou seja, unidade do direito, segurança, liberdade e igualdade, com as razões substanciais do precedente. A limitação e a extensão do precedente sempre configuram correção ou acomodação de sua ratio decidendi. Essa acomodação, não obstante, prioriza as razões do próprio precedente, já que tanto a sua extensão, quanto a sua limitação apenas são possíveis quando com elas compatíveis.

Sublinhe-se, para finalizar, que, ao contrário do que pensam alguns menos avisados, um sistema pautado pelos precedentes nada tem de estático ou insuscetível de alteração ou adaptação às novas realidades e diferentes situações. Basta recordar as palavras do Justice Cardozo, em sua breve e empolgante obra *The Nature of Judicial Process*: “Em meus primeiros anos como juiz, a minha perturbação de espírito foi muito grande ao perceber que não havia portos seguros no oceano em que me lançara. Eu queria a certeza. Fiquei deprimido e desanimado quando descobri que essa busca era vã. Estava tentando alcançar a terra, a terra firme das normas fixas e estabelecidas, o paraíso de uma justiça que se revelasse mais clara e dominante do que seus pálidos e tênues reflexos em minha mente e consciência vacilantes. Descobri, ‘com os viajantes em Paracelso, de Browning, que o verdadeiro paraíso sempre esteve mais além’. Com o passar dos anos, e à medida que refletia mais e mais sobre a natureza do processo judicial, eu me reconciliei com a incerteza, porque cresci para vê-la como inevitável. Cresci para ver que o processo em sua mais alta extensão não é descoberta, mas criação; que as dúvidas e apreensões, as esperanças e os temores fazem parte do trabalho do intelecto, das dores da morte e do nascimento, em que princípios que serviram a uma época se vão e novos princípios nascem”.¹⁹⁵

Em suma, o distinguishing tem basicamente duas funções em uma teoria dos precedentes. Em primeiro lugar, visa a permitir a distinção entre casos a fim de que determinado precedente não seja aplicado de forma indevida. Em segundo lugar, visa a viabilizar o desenvolvimento do Direito mediante a extensão e a limitação dos precedentes.

5.2. Distinções no Direito Brasileiro. Seria um desperdício de experiência não contar com o rico manancial produzido no Common Law a respeito da necessidade de elaboração de distinções entre casos no direito brasileiro. É por essa razão que os arts. 489, § 1.º, incisos V e VI, e 927, § 1.º, CPC, devem ser lidos, quando aludem à necessidade de distinções, a partir do duplo escopo que pode ser assimilado a essa técnica processual: evitar uma inadequada aplicação de precedentes e permitir o desenvolvimento do Direito mediante a extensão e a limitação das suas razões.¹⁹⁶

Nessa linha, o distinguishing constitui uma técnica processual que deve ser usada na argumentação para solução de casos em todas as instâncias do Poder Judiciário e por todos os atores que intervêm no debate processual. Se é certo que os juízes têm o dever de distinguir em suas argumentações (arts. 485, § 1.º, incisos V e VI, e 927, § 1.º, CPC), é igualmente certo que as partes têm o ônus de fazê-lo em suas manifestações. Não o fazendo, pode o juiz instá-las, tanto mediante o seu dever de esclarecimento inerente à estrutura cooperativa do processo civil (arts. 6.º e 139, CPC).

A distinção constitui uma técnica processual que deve ser empregada em todas as instâncias do Poder Judiciário. Nada obstante, pelo seu valor paradigmático, cumpre trabalhar a título de ilustração o distinguishing diante do Supremo Tribunal Federal.

5.2.1. Distinções perante o Supremo Tribunal Federal. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tratou da questão do distinguishing no HC 85.185 de relatoria do Ministro Cezar Peluso.¹⁹⁷ Examinou-se nesse caso o alcance da Súmula 691 do STF, cuja redação é a seguinte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”.

O habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. No Supremo Tribunal Federal, o impetrante afirmou não ser o caso de observar a Súmula 691 porque, embora a impetração fosse dirigida contra decisão que negara liminar em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, haveria flagrante ilegalidade.

Logo depois do relatório, o Ministro Sepúlveda Pertence propôs questão de ordem nos seguintes termos: “O único recurso de hermenêutica da súmula é consultar os seus precedentes. E ninguém tem dúvida de que os precedentes não faziam distinção alguma. Agora, o Tribunal tem, para questões excepcionais de afirmação da sua autoridade, um outro instrumento constitucional, hoje, que é a súmula vinculante. Esta, sim, permite per saltum, mediante reclamação, que se corrija ou que se imponha a jurisprudência que o Tribunal entenda de qualificar como vinculante, imediatamente. Estamos, decidida e declaradamente, a propor uma restrição à súmula; na verdade um cancelamento, porque, na medida em que admitirmos, sendo flagrante a ilegalidade, caber o habeas corpus contra o indeferimento da liminar, teremos de examinar todas as impetrações em que essa ilegalidade flagrante seja alegada. Homenageio os advogados do meu País: nenhum deles deixará de falar que a sua ilegalidade é flagrante. E vamos tornar inócua a EC 22. Ora, restringir o alcance de uma súmula, vale por cancelá-la: a competência é do Pleno. Vimos, da tribuna, o ilustre advogado analisar os fundamentos da súmula. Na primeira vez, falou-se que o Tribunal lhe estaria a dar uma interpretação bitolada. O Mestre Victor Nunes costumava dizer que, quando se discute se determinada súmula merece interpretação ampliativa ou restritiva, ela já não cumpre o seu papel, que é o de encerrar discussões que o Tribunal tem por ociosas, à vista dos precedentes e na extensão deles extraída. A própria liminar do eminente Ministro Cezar Peluso, em outra decisão de Sua Excelência, mostra, efetivamente, que Sua Excelência, na verdade, não concorda com os precedentes que alicerçam a Súmula 691. No caso, não há prisão. Não há urgência qualificada. Creio que a matéria deva ser submetida ao Plenário. Não estou antecipando nenhum julgamento quanto ao verbete; o que defendo é a instituição da súmula. Se, em cada Turma, pudermos dizer que este caso é peculiar, então a súmula perde a sua razão de ser. De tal modo que proponho, efetivamente, que levemos o problema à discussão do Plenário”.¹⁹⁸

O Ministro Cezar Peluso – relator do habeas corpus –, depois do pronunciamento do Ministro Pertence, apresentou fundamentos demonstrando que o habeas corpus deveria ser admitido e, diante disto, concluiu que a súmula deveria ser cancelada. Na sequência, o Ministro Carlos Britto disse que não seria o caso de cassar a súmula, “mas de ponderá-la em alguns casos”, o que levou o Ministro Pertence a retrucar: “Não, Ministro. Súmula: ou se observa de acordo com os precedentes que a embasaram, ou se cancela (...). Não se dá temperamento à súmula; cancela-se esta e, se for o caso, emita-se outra depois. Mas esta está fundada nos precedentes, a partir do referido pelo Ministro Cezar Peluso, da lavra do eminente Ministro Moreira Alves. Então, não é possível estabelecer temperamentos que não estão nos precedentes. A súmula é uma pura declaração solene do Tribunal de que considera determinada questão pacificada e, conseqüentemente, dispensa novas discussões, citações de precedentes, longas e eruditas fundamentações. É apenas um ‘método de trabalho do Tribunal’, na expressão do Victor Nunes. Quando se discute que a súmula não devia dizer o que os precedentes disseram, ela já não presta como súmula. Então, o caso é de cancelar. Assim, não há meia medida: ou se cancela, ou se aplica a súmula. Não se admitindo sequer interpretação, porque o verbete já é o resultado de interpretações reiteradas do Tribunal”.¹⁹⁹

Após outras considerações envolvendo fundamentos relativos ao conteúdo da súmula – quando se deixou de lado, momentaneamente, a questão da possibilidade de se conhecer do habeas corpus sem se cancelar a súmula –, argumentou o Ministro Gilmar Mendes: “Neste caso, não há nenhuma dúvida de que se trata – para usar uma expressão do Ministro Sepúlveda Pertence – de uma chapada violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É um caso de manifesta ilegalidade, quer dizer, não há nenhuma dúvida que tanto o Tribunal, ao negar a liminar, quanto o Superior Tribunal de Justiça, ao negar a liminar, arrostando a claríssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, construída, inclusive, no voto de Vossa Excelência. Por isso que, neste caso, não me parece que haja nenhuma dúvida. Eu não gostaria, sei das lições claras, da doutrina do Supremo Tribunal Federal, e das lições magníficas do eminente Victor Nunes Leal, que estão positivadas aqui no nosso Regimento Interno, quanto ao modelo sumular, especialmente quanto à

possibilidade de que não se faz a interpretação da súmula ou de que, talvez – para usar a expressão americana –, não se devesse fazer um distinguishing, mas sabemos que, a partir da ideia mesmo do stare decisis, há duas formas de arrostar o entendimento, um problema como este: ou vamos para a posição radical que os americanos chamam de overruling, ou fazemos o distinguishing”.²⁰⁰

O Ministro Cezar Peluso, definindo-se pelo conhecimento do pedido, advertiu que, embora o pedido de habeas corpus contra indeferimento de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça seja obstaculizado, a princípio, pela Súmula 691, os sucessivos indeferimentos de liminares sufragaram tese que colide com este entendimento, como decidiu o Tribunal HC 84.014-AgRg, relator o Ministro Marco Aurélio, em que se decidiu que a Súmula 691 cede quando se cuida de “flagrante constrangimento ilegal, que é o caso que se vê nos autos”.²⁰¹

A partir daí, passou-se a discutir se a decisão do Ministro Peluso teria adotado a técnica do distinguishing. Sem a devida fundamentação, disse o Ministro Pertence que a solução do Ministro Peluso seria mais ortodoxa que o distinguishing, “a não ser que os eminentes colegas que propuseram a teoria do distinguishing se proponham gentilmente a ser o filtro do conhecimento de qualquer habeas corpus: verificam, primeiro, se é manifesta a ilegalidade e depois se discute”.²⁰² O Ministro Pertence referiu-se claramente à proposta do Ministro Gilmar Mendes, que respondeu dizendo não haver qualquer diferença substancial entre a solução apontada no voto do Ministro Peluso e a que decorreria da adoção da técnica do distinguishing. Lembrou o Ministro Gilmar que o distinguishing é prática costumeira no Supremo Tribunal Federal, como mostram vários casos em que se tratou da aplicação das Súmulas 506 e 634. Recordou que, em alguns casos, tendo em vista razões de proteção judicial efetiva, tem-se admitido distinguishing em relação à Súmula 634. “Isso é algo comum. O Ministro Eros Grau, recentemente, em um caso do TSE – objeto de discussão, sobre o qual o Ministro Carlos Velloso, de quando em vez, tem suscitado dúvida quanto ao cabimento neste caso específico do efeito suspensivo – concedeu o efeito suspensivo antes da admissibilidade do recurso extraordinário. Poderíamos citar muitos outros exemplos nesse sentido. Aqui, parece-me ser evidente a possibilidade. A concessão do habeas corpus de ofício, antes confirma do que nega, exatamente, a tese que estou a defender. Em caso de chapada incompatibilidade, portanto, de manifesta ilegalidade em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aceita-se o habeas corpus. Está se dando até muito mais do que o pretendido. Na verdade, na solução do Ministro Cezar Peluso, vejo confirmada a minha tese: a possibilidade de concessão do habeas corpus em nome da proteção judicial efetiva, um princípio que não pode ser afastado. (...). De modo que acompanho o voto do eminente Ministro Cezar Peluso na concessão do habeas corpus de ofício, mas ressaltando que estamos, aqui, a colocar uma ressalva na súmula objeto de discussão. Certamente os advogados, sempre hábeis nesta discussão, saberão que poderão pedir, e, se Vossa Excelência entender, que faça a concessão do habeas corpus de ofício. Essa discussão acaba sendo, neste caso, meramente semântica. Mantenho a minha posição e acompanho o eminente Ministro-Relator”.²⁰³

Pois bem, esse caso abre oportunidade a algumas considerações. Como a súmula contém a definição do entendimento do Tribunal acerca de determinada questão, ela nada mais é do que o delineamento da tese ou da solução dada pelo Tribunal a uma questão jurídica ou a um caso. Sendo assim, como é absolutamente natural, o tempo – e com ele a evolução dos valores sociais, da tecnologia e da própria concepção geral do direito – pode impor ao Tribunal a conclusão de que a súmula não mais responde às necessidades para as quais foi criada, estando distante dos anseios de justiça da própria Corte. Isso ocorrendo, deve – e não pode – haver o cancelamento da súmula, aplicando-se, porque plenamente adequada, a técnica do overruling, utilizada no âmbito do common law.

Porém, o surgimento de uma nova situação, não tratada nos precedentes que deram origem à Súmula, pode não impor o overruling, mas o distinguishing. No common law, quando uma nova circunstância fática torna o caso diverso daquele de onde se originou o precedente, há um caso que, a princípio, não se amolda ao precedente. Não obstante, se esse novo fato, embora delineando novo caso, é compatível com as proposições sociais que justificaram o precedente, não há razão para overruling, devendo ser feito distinguishing. Basta que o novo fato, combinado com os fatos

presentes no caso primitivo, justifique o ajuste da ratio decidendi ao caso sob julgamento.

A Súmula 691 foi editada para obstaculizar o conhecimento de pedidos de habeas corpus contra decisões de Ministros de Tribunais Superiores que, em caráter liminar, indeferem habeas corpus. Porém, após a edição dessa súmula foram proferidas várias decisões, no Supremo Tribunal Federal, colidindo com o seu alcance literal. Decidiu-se, como reconheceu o Ministro Peluso, que a Súmula 691 não se opõe ao conhecimento de habeas corpus quando se cuida de flagrante constrangimento ilegal.

É indiscutível que o Supremo Tribunal Federal, após a edição da Súmula 691, passou a considerar circunstância capaz de justificar o conhecimento de habeas corpus, ainda que, a princípio, esse não seja admissível contra decisão que indefere liminar em habeas corpus dirigido a Tribunal Superior. Ou seja, o habeas corpus, diante de uma decisão não marcada por flagrante ilegalidade, é obstaculizado pela Súmula 691. Havendo flagrante constrangimento ilegal, conhece-se do pedido em face do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva ou em nome do princípio da proteção judicial efetiva.

Essa situação, de flagrante ilegalidade, impõe a correção da ratio decidendi ou do conteúdo da súmula em virtude de novo entendimento, que frisa o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Embora o conteúdo da súmula seja ampliado – por considerar nova circunstância – o seu alcance é restringido, passando a abarcar menor número de casos, exatamente aqueles em que não há flagrante ilegalidade.

A manutenção da súmula deriva da circunstância de que se deve negar, como princípio, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão de Ministro de Tribunal Superior que, em sede liminar, indeferiu habeas corpus. Mas a situação de flagrante ilegalidade justifica, a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional e do princípio da proteção judicial efetiva, a não aplicação da súmula para obstaculizar o conhecimento do habeas corpus.

Há, portanto, fundamento de natureza constitucional a justificar a restrição do alcance da súmula. Esse fundamento foi explicitado e justificado no voto do Ministro Gilmar Mendes. Contudo, o princípio da proteção judicial efetiva, no caso, não deve ser visto apenas como o fundamento que justificou o *distinguishing*. Ele constitui o “critério” que a Corte utilizou para pautar o *distinguishing* e, nessa dimensão, passa a ter força obrigatória sobre as futuras decisões da Corte. Em outras palavras: o direito fundamental à tutela efetiva passa a constituir critério capaz de justificar a limitação ou a ampliação – conforme o caso – do alcance do precedente ou da súmula, devendo incidir, obviamente, em casos similares.

O fato de o fundamento para a não aplicação da súmula, no voto do Ministro Peluso, estar na própria garantia constitucional do habeas corpus, certamente não torna a metodologia adotada nesse voto, diversa da que foi utilizada no voto do Ministro Gilmar Mendes. Embora o Ministro Peluso tenha insistido, inicialmente, no cancelamento da súmula, o seu voto terminou por afirmar que a orientação da Súmula 691 cede quando se cuida de flagrante constrangimento ilegal.

A circunstância de a súmula ter de ceder em face de determinada situação não significa o seu cancelamento implícito, como supôs o Ministro Pertence. Na verdade, o *distinguishing* apenas não foi utilizado de modo mais claro ou natural porque não se compreendeu que as súmulas, atualmente, necessitam das técnicas de operacionalização do uso de precedentes, desenvolvidas, sobretudo, no direito estadunidense. Essa é a razão pela qual o Código de 2015, aliás, conta com os arts. 489, § 1.º, incisos V e VI, 926 e 927, § 1.º, CPC.

Lembre-se que o Ministro Pertence disse que “restringir o alcance de uma súmula vale por cancelá-la: a competência é do Pleno (...). O Mestre Victor Nunes costumava dizer que, quando se discute se determinada súmula merece interpretação ampliativa ou restritiva, ela já não cumpre o seu papel, que é o de encerrar discussões que o Tribunal tem por ociosas à vista dos precedentes e na extensão deles extraída (...). Quando se discute que a súmula não devia dizer o que os precedentes disseram, ela já não presta como súmula. Então, o caso é de cancelar. Assim, não há

meia medida: ou se cancela, ou se aplica a súmula. Não se admitindo sequer interpretação, porque o verbete já é o resultado de interpretações reiteradas do Tribunal”.²⁰⁴

Não há qualquer dúvida que o Ministro Pertence não admitia a diferenciação de caso para se aplicar ou deixar de aplicar a súmula ou mesmo a manutenção da súmula, sem se impor o seu resultado ao caso sob julgamento, então considerado distinto. É certo que o Ministro Pertence, quando afirma que súmula não pode ser interpretada, não está dizendo obviamente que o texto da súmula não deve ser compreendido pelo magistrado, mas sim que essa compreensão é limitada pelos precedentes da súmula. Porém, restringir a interpretação da súmula aos seus precedentes, nada mais é do que não admitir a insuficiência dos precedentes da súmula diante de um novo caso ou situação fática. Portanto, entender que a súmula apenas pode ser interpretada com base em seus precedentes é simplesmente desconsiderar os fatores que, na história do common law, sempre demonstraram a necessidade de prudência na aplicação dos precedentes. Ora, adota-se a técnica do distinguishing exatamente porque se sabe que, no momento da prolação do precedente, determinado fato ou circunstância pode deixar de ser considerado e, na ocasião do seu posterior enfrentamento, ser capaz de permitir a justificação de nova solução independentemente da realização de overruling. De modo que admitir que a súmula apenas pode ser aplicada ou cancelada é o mesmo que supor que nenhuma circunstância pode escapar quando da sua elaboração. Não é preciso dizer que isso nega a estrutura marcadamente temporal do próprio direito.

Assim, a antiga concepção de operacionalização das súmulas, reafirmada pelo Ministro Pertence, embora adequada à época em que o sistema de súmulas foi pensado (época em que o Supremo Tribunal Federal atuava como simples corte de controle e de jurisprudência), não se adapta às necessidades contemporâneas (em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça constituem cortes de interpretação e de precedentes). A questão da aplicação dos precedentes certamente não pode ser “reduzida a um método de trabalho do tribunal”, como um delineamento do “horizonte da jurisprudência”, já que indissociável da necessidade de preservação da unidade da ordem jurídica, assim como do respeito à liberdade, à igualdade diante das decisões judiciais e da necessidade de segurança jurídica no tráfego social, sem as quais será impossível outorgar dignidade à função do Supremo Tribunal Federal.

Atualmente, em verdade, é impossível raciocinar sobre a aplicação das súmulas e dos precedentes sem se ter consciência das suas naturezas eminentemente temporais e fragmentárias, bem como do aprofundamento dos critérios para a utilização das técnicas que giram ao redor do distinguishing e do overruling.

De outra parte, a preocupação do Ministro Joaquim Barbosa, de que se estaria propondo a revogação de súmula recém-editada, em visível afronta à estabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,²⁰⁵ é eliminada quando se percebe que a súmula, em vez de revogada, é simplesmente corrigida para se atender a uma situação não prevista.

Note-se que o distinguishing atinge uma finalidade distinta daquela que é pretendida com o overruling. O primeiro não nega a necessidade do precedente, mas requer a sua acomodação diante de nova circunstância. O overruling, ao contrário, em vista da transformação dos valores, da evolução da tecnologia ou da própria concepção geral do direito, parte da premissa certa de que o precedente não tem como ser mantido, sendo impossível a sua correção ou emenda para atender a uma nova situação. É indiscutível, diante disso, que o overruling exige boa dose de tempo para ocorrer, ao passo que o distinguishing se relaciona ao tempo necessário para a percepção de circunstância inicialmente não prevista. Dessa forma, embora o distinguishing não seja algo que faça parte da rotina do tribunal, ele não tem requisitos tão rígidos quanto os do overruling.

Por ocasião do julgamento que acaba de se expor, em que se realizou distinguishing para não se aplicar a Súmula 691, aludiu-se à Súmula 634, tentando-se com isso demonstrar que essa súmula se submeteu a procedimento semelhante.

Diz a Súmula 634 que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de

admissibilidade na origem”. Essa súmula tem entre os seus precedentes o acórdão proferido no AgRg em Pet. 1.189, de relatoria do Ministro Moreira Alves. Nessa ocasião, a 1.^a Turma, à unanimidade, tratou de medida cautelar em que se pediu efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não tinha sido objeto de juízo de admissibilidade no tribunal de origem. A ementa do acórdão é suficiente para se aferir os fundamentos pelos quais a Turma entendeu não ser admissível o pedido de medida cautelar: “Agravio regimental – Medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto do juízo de admissibilidade na Corte de origem. O disposto no parágrafo único do art. 800 do CPC [art. 299, parágrafo único, do CPC/2015], na redação que lhe deu a Lei 8.592/1994, não se aplica a recurso extraordinário ainda não admitido, pela singela razão de que sua aplicação implicaria pré-julgamento da admissão do recurso extraordinário pelo relator da petição de medida cautelar, que se torna preventivo para julgar o agravo contra o despacho da não admissão desse recurso, em detrimento da livre apreciação do Presidente do Tribunal a quo no âmbito da competência originária que a legislação lhe outorga para esse juízo de admissibilidade, porquanto, se se considera relevante o fundamento jurídico do recurso extraordinário para o efeito de conceder-lhe o efeito suspensivo que a legislação não lhe outorga, é evidente que ele deverá ser admitido ainda que para melhor exame. Ademais, se, não obstante isso, o Presidente do Tribunal a quo não admitir o recurso extraordinário a que foi dado efeito suspensivo em medida cautelar requerida perante esta Corte, ter-se-á a esdrúxula situação de um recurso extraordinário não admitido por quem é competente para tanto continuar a ter efeito suspensivo antes de reformada a decisão de não admissibilidade, uma vez que o despacho de não admissão na Corte de origem não tem força para reformar a concessão de cautelar dada pelo Tribunal ad quem que lhe é hierarquicamente superior. Agravo a que se nega provimento”.²⁰⁶

Fica claro, nas razões do acórdão da 1.^a Turma, que não haveria como admitir medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário não apenas quando esse ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade, mas também quando esse não foi admitido na Corte de origem e, em virtude disso, foi interposto agravo de instrumento. Ora, se a cautelar não poderia ser concedida por implicar pré-julgamento da admissão do recurso extraordinário, maior obstáculo existiria para admitir a cautelar contra o juízo de inadmissibilidade e em face do agravo de instrumento pendente de julgamento.

Porém, quando do julgamento da AC 1.549, a 2.^a Turma, relator o Ministro Celso de Mello,²⁰⁷ assim decidiu: “Recurso extraordinário que ainda não sofreu juízo de admissibilidade – Acórdão do tribunal recorrido que versa matéria idêntica à veiculada em causas já preparadas para serem julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal – Retardamento, pela Presidência do tribunal recorrido, da formulação do juízo (positivo ou negativo) de admissibilidade do apelo extremo – Potencialidade danosa resultante dessa omissão processual, agravada pela inércia no exame do pedido de tutela de urgência – Caracterização de dano potencial apto a comprometer, de modo grave, a situação jurídica da empresa contribuinte – Possibilidade, ainda, de frustração dos fins inerentes ao processo cautelar – Hipótese excepcional que justifica, no caso, o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, do poder geral de cautela – Situação extraordinária que autoriza a não incidência das Súmulas 634 e 635 do STF – Função jurídica da tutela cautelar – Instrumentalidade do processo cautelar (binômio necessidade/utilidade) – Relação de complementaridade entre o instituto da tutela cautelar e o princípio da efetividade do processo – Doutrina – Situação que enseja a outorga excepcional do provimento cautelar, considerada a singularidade do caso – Suspensão da eficácia do acórdão objeto do apelo extremo – Medida cautelar deferida pelo relator – Decisão referendada”.²⁰⁸

Em caso um pouco diferente, a 2.^a Turma, na AC 1.550, relator o Ministro Gilmar Mendes,²⁰⁹ concedeu medida cautelar quando a decisão do tribunal de origem, impugnada mediante agravo de instrumento, não havia admitido o recurso extraordinário.²¹⁰ Concluiu-se, nesse momento, que “em situações excepcionais, em que estão patentes a plausibilidade jurídica do pedido – decorrente do fato de a decisão recorrida contrariar jurisprudência ou súmula do Supremo Tribunal Federal – e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser consubstanciado pela execução do acórdão recorrido, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar ainda que o recurso extraordinário tenha sido objeto de juízo negativo de admissibilidade perante o Tribunal de

origem e o agravo de instrumento contra essa decisão ainda esteja pendente de julgamento”.²¹¹

É importante lembrar que o voto do Ministro Gilmar Mendes afirmou que a admissibilidade da cautelar, no caso, não constituiria exceção à aplicação das Súmulas 634 e 635. Argumentou que essas “súmulas prescrevem que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, apenas é instaurada após o exercício do juízo de admissibilidade do recurso pelo Tribunal de origem. Exercido tal juízo, porém de forma negativa, nada obsta a que o STF, em situações excepcionais, conheça do pedido de medida cautelar para verificar se, no caso concreto, a decisão recorrida está em patente contrariedade com sua jurisprudência consolidada ou súmula e se está presente a urgência da pretensão cautelar, hipótese em que poderá conceder o efeito suspensivo pleiteado”.²¹²

Enquanto o acórdão relatado pelo Ministro Celso de Mello disse haver “situação extraordinária” que autorizaria “a não incidência das Súmulas 634 e 635”,²¹³ o acórdão relatado pelo Ministro Gilmar Mendes concordou que a tutela cautelar, “em situações excepcionais”, pode ser deferida, mas que a sua concessão, uma vez inadmitido o recurso extraordinário, “não constituiria exceção à aplicação” das referidas Súmulas.²¹⁴

De modo que as duas decisões concordam em que – em situações extraordinárias ou excepcionais, qualificadas pelo fundado receio de dano – é possível conceder tutela cautelar para suspender os efeitos de decisão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade no tribunal de origem ou que já foi inadmitido neste juízo. Note-se que o acórdão relatado pelo Ministro Celso de Mello falou em “caracterização de dano potencial apto a comprometer, de modo grave, a situação jurídica” da recorrente,²¹⁵ ao passo que o acórdão de que foi relator o Ministro Gilmar Mendes fez referência à “plausibilidade jurídica do pedido” e a “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser consubstanciado pela execução do acórdão recorrido”.²¹⁶

Não há dúvida que tais requisitos, vistos como excepcionais, revelam situação não discutida quando da elaboração dos precedentes que deram origem à súmula que enunciou a impossibilidade de se admitir tutela cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não submetido ao juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Nesse sentido, a Súmula 634, ao considerar nova condição – e, assim, ter o seu significado alargado – teve seu alcance limitado, pois, diante desta circunstância, passou a não obstaculizar a tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão objeto do extraordinário, ainda que este não tenha sido admitido, ou já tenha sido inadmitido, na origem.

A distinção entre as duas decisões está em que a relatada pelo Ministro Celso de Mello afastou a aplicação da súmula e a de que foi relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu que a admissão da cautelar, no caso, “não constituiria exceção” à sua aplicação. Ou seja, embora os dois acórdãos tenham feito *distinguishing*, o segundo disse que a súmula faz referência expressa apenas a casos em que o extraordinário não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem, ao passo que, no caso em julgamento, o juízo de admissibilidade no tribunal de origem, ainda que negativo, já fora feito. Recorde-se que o Ministro Gilmar Mendes disse que as Súmulas 634 e 635 “prescrevem que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, apenas é instaurada após o exercício do juízo de admissibilidade do recurso pelo tribunal de origem”.

Entretanto, tais hipóteses de *distinguishing* tocam em ponto mais delicado. É que o *distinguishing* que declarou que o caso sob julgamento, por ser diferente, não se submetia à súmula tomou em conta apenas o seu enunciado, enquanto, se qualquer um dos acórdãos houvesse considerado as razões dos precedentes que deram origem à súmula, chegar-se-ia à conclusão de que a *ratio decidendi* desses precedentes inibiria a admissão da cautelar em toda e qualquer hipótese de extraordinário ainda não analisado na origem ou não admitido.

Para a Corte revogar ou deixar de aplicar, mediante *distinguishing*, uma súmula, ela tem de analisar as razões que lhe deram origem. Essas razões estão nos fundamentos dos precedentes que justificaram a sua edição. Trata-se, em outras palavras, de buscar a *ratio decidendi* da súmula, que não se confunde com o seu enunciado.

Lembre-se que o Ministro Moreira Alves, no AgRg em Pet. 1.189, argumentou que não há como conhecer de medida cautelar em recurso extraordinário ainda não admitido, “pela singela razão” de que sua aceitação “implicaria pré-julgamento da admissão do recurso extraordinário pelo relator da petição de medida cautelar”, e que a admissão da cautelar, em caso de posterior não admissão do extraordinário na origem, criaria a “esdrúxula situação de um recurso extraordinário não admitido por quem é competente para tanto continuar a ter efeito suspensivo antes de reformada a decisão de não admissibilidade”. Ora, se a admissão da cautelar, em caso de não realização do juízo de admissibilidade na origem, implica pré-julgamento, a admissão da cautelar, antes da apreciação do agravo de instrumento contra a decisão de não admissibilidade, evidenciaria pré-julgamento de forma ainda mais forte. Do mesmo modo, se se entende esdrúxula a suspensão dos efeitos da decisão objeto do extraordinário “antes de reformada a decisão de não admissibilidade”, mais esdrúxulo seria dar efeito suspensivo após a decisão de não admissibilidade e enquanto se espera o processamento do agravo de instrumento.

Quando se olha para a *ratio decidendi* dos precedentes que originaram a súmula, não há como entender que o caso em que o extraordinário não foi admitido não se submete à súmula. Nessa perspectiva, o caso se submeteria à súmula, mas a existência de uma nova condição – isto é, o receio de dano grave e de difícil reparação – afastaria a sua aplicação, autorizando o *distinguishing* mediante a correção implícita do enunciado sumular.

A situação de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, justifica, a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional e do princípio da proteção judicial efetiva, a não aplicação da súmula para permitir o conhecimento do pedido de tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão recorrida. Este o fundamento exato do *distinguishing*.

Em outro caso, o Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática acerca de pedido de liminar em mandado de segurança, realizou *distinguishing* ao se deparar com a Súmula 266 – que diz não ser cabível mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese. Neste mandado de segurança, o impetrante, promotor público que, no momento, exercia a função de Secretário de Estado no Amapá, pediu a declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade dos arts. 2.º, parágrafo único, e 5.º da Resolução 05/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público e que lhe fosse garantido o exercício do cargo de Secretário de Estado. Com base no art. 5.º da referida resolução, o Procurador Geral de Justiça do Estado havia requisitado ao Governador do Amapá o retorno do impetrante às suas funções no Ministério Público. Ao decidir, indagou o Ministro se seria o caso de se manter a restrição constante da Súmula 266, ao menos em relação àquelas leis das quais decorrem efeitos diretos e imediatos para posições jurídicas. Entendeu o Ministro que se deve admitir o mandado de segurança para impugnar leis dotadas de eficácia imediata e capazes de afetar direito subjetivo e que, por isso, seria razoável a superação da súmula, ou, ao menos, um *distinguishing* para se decidir que as leis que afetam posições jurídicas de forma imediata poderão ser impugnadas mediante mandado de segurança. Advertiu que seria supérfluo o aguardo de novo ato administrativo para que a impugnação se viabilizasse, uma vez que a resolução teria força suficiente para impor ao impetrante as vedações nela contidas. Assim, conheceu do mandado de segurança, embora não tenha concedido a liminar pleiteada por entender faltar plausibilidade jurídica suficiente a justificá-la.²¹⁷

Na hipótese, está claro que se considerou uma nova condição. No caso sob julgamento estavam presentes as condições que levaram à edição da súmula aliada a uma nova circunstância, que justificava a admissão do mandado de segurança. A nova condição, que justificou a não aplicação da súmula, foi a de que a resolução tinha força suficiente para afetar a posição jurídica do impetrante. O *distinguishing* não nega as razões que fundaram a súmula, porém faz com que ela não abarque situação em que se afeta a posição jurídica da parte e, assim, não lhe subtrai o direito constitucional ao uso do procedimento do mandado de segurança.

A decisão que não admite a aplicação da súmula nesta hipótese, alarga o significado e restringe o alcance da primitiva *ratio decidendi*, pois, ao mesmo tempo que exige a consideração de nova condição, restringe o alcance da súmula quando esta se encontra presente. Vale dizer: a súmula passa a ter o significado de que o mandado de segurança é inadmissível contra lei ou ato normativo em tese, desde que não afete posição jurídica de forma imediata, e, por isso, tem o seu

alcance limitado.

Note-se que este distinguishing – assim como aqueles que foram realizados em face das Súmulas 691 e 634 – não teve o intuito de estender o alcance da súmula a novo caso, mas o de deixar de submeter o caso sob julgamento à súmula. Mas o novo conteúdo da ratio decidendi da súmula, a partir daí, certamente trará outra orientação às futuras decisões.

O Supremo Tribunal Federal obviamente também faz distinções em face de decisões tomadas em controle direto e difuso.

Lembre-se, em primeiro lugar, das várias reclamações que foram apresentadas para fazer valer a decisão que concedeu liminar na ADC 4, que, ainda que provisoriamente, afirmou a constitucionalidade do art. 1.º da Lei 9.494, de 10.09.1997, com a seguinte redação: “Art. 1.º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5.º e seu parágrafo único e 7.º da Lei 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1.º e seu § 4.º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1.º, 3.º e 4.º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992”.

Entendeu o acórdão que concedeu a liminar haver “plausibilidade jurídica na arguição de constitucionalidade, constante da inicial (fumus boni iuris)”, e estar “igualmente atendido o requisito do periculum in mora, em face da alta conveniência da Administração Pública, pressionada por liminares que, apesar do disposto na norma impugnada, determinam a incorporação imediata de acréscimos de vencimentos, na folha de pagamento de grande número de servidores e até o pagamento imediato de diferenças atrasadas. E tudo sem o precatório exigido pelo art. 100 da CF, e, ainda, sob as ameaças noticiadas na inicial e demonstradas com os documentos que a instruíram. Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos, para se suspender, ex nunc, e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei 9.494, de 10.09.1997, sustando-se, igualmente ex nunc, os efeitos futuros das decisões já proferidas, nesse sentido”.²¹⁸

Tais reclamações, ao exigirem a análise da relação das decisões tomadas pelos tribunais inferiores com a decisão que concedeu a liminar na ação declaratória de constitucionalidade, deram ao Supremo Tribunal Federal a nítida oportunidade de enxergar as decisões impugnadas como distinções e, por consequência, para eventualmente estabelecer o seu distinguishing diante da sua própria decisão.

Assim, por exemplo, no AgRg na Rcl 5.174, o Tribunal negou provimento ao recurso, confirmando a decisão de improcedência, sob o argumento de que “não ofende a decisão liminar proferida na ADC 4 a antecipação de tutela que implica ordem de pagamento de verba de caráter indenizatório”.²¹⁹

Em outro agravo regimental, manteve-se a decisão de improcedência da reclamação sob o fundamento de que “não ofende a decisão liminar proferida na ADC 4 a antecipação de tutela que garante a inscrição de candidato em concurso público, ainda que da aprovação lhe resultem vantagens financeiras”.²²⁰

Decidiu-se, no AgRg na Rcl 4.628, que “não ofende a autoridade da liminar deferida na ADC 4 a decisão em que o objeto da antecipação de tutela corresponda a prestação exigível nos termos da jurisprudência do Supremo”.²²¹

No AgRg na Rcl 5.163, também de relatoria do Ministro Cezar Peluso, a Corte voltou a decidir pela inexistência de ofensa à autoridade da decisão tomada na ADC 4 sob a alegação de que “não se admite reclamação contra decisão que está em consonância com assentada jurisprudência da Corte”.²²²

Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, diante de certas circunstâncias, não se aplica à decisão que reconheceu – ainda que provisoriamente – a constitucionalidade da norma que proibiu a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública.

Os fundamentos do acórdão que concedeu a liminar na ação direta de constitucionalidade, se concentraram na questão da admissibilidade de liminar nesta ação, sem que relevantes razões tenham sido apresentadas em relação ao *fumus boni iuris*, ou seja, à constitucionalidade da proibição de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. O tema da constitucionalidade acabou restando mais claro quando da abordagem do *periculum in mora*, quando foi dito que, apesar da vedação contida na norma, liminares estariam determinando a incorporação imediata de acréscimos de vencimentos, na folha de pagamento de grande número de servidores, e até o pagamento imediato de diferenças atrasadas, e tudo sem o precatório exigido pelo art. 100 da CF.

Apenas o fundamento relacionado ao *periculum in mora* permite inferir a *ratio decidendi* do acórdão. Admitiu-se constitucional a norma que proíbe tutela antecipada contra a Fazenda Pública ao se entender não ser prudente, sob o signo da provisoriedade da cognição judicial, permitir a incorporação de vencimentos em folha de pagamento ou o pagamento de diferenças atrasadas, especialmente sem precatório.

No entanto, como a *ratio decidendi* perquirida diz respeito à decisão de constitucionalidade, pensar em estender os seus fundamentos a outros casos seria vincular os demais juízes a afirmarem constitucional norma similar, igualmente proibitiva da tutela estatal. Assim, bastou reclamar da não observância do dispositivo do acórdão, sem qualquer necessidade de se aludir aos seus fundamentos.

Se, nas reclamações mencionadas, o que importava era a vinculação dos tribunais ordinários ao dispositivo da decisão, as distinções efetuadas por estes tribunais e admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, não precisariam guardar consistência com a *ratio decidendi* ou com os fundamentos da decisão, porém apenas observar o dispositivo da decisão, ou seja, a norma declarada constitucional.

Assim, com a afirmação de que o pagamento de verba indenizatória não está vedado pelo precedente, por exemplo, não se está dizendo que os fundamentos do precedente autorizam tal pagamento ou que a sua *ratio decidendi* apenas entende constitucional a proibição de pagamento imediato de verba salarial – e não de verba indenizatória. O pagamento de verba indenizatória não está vedado porque a norma declarada constitucional não o proíbe.

Portanto, as distinções feitas diante da ADC 4, não limitaram ou estenderam o alcance de precedente, mas apenas demonstraram que determinadas hipóteses não estavam incluídas no caso ou na hipótese solucionada pelo precedente. Ora, tal hipótese era exatamente a da constitucionalidade do art. 1.º da Lei 9.494, de 10.09.1997. Assim, o *distinguishing* feito nestes casos pode ser chamado, por assim dizer, de *pure distinguishing*.

De outro lado, na Rcl 1.987 discutiu-se clara e abertamente a respeito de se os fundamentos da decisão proferida na ADIn 1.662, poderiam vincular os demais tribunais. Esta ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Governador do Estado de São Paulo, teve como objeto a IN 11/1997, do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região, não se ancorou em tal instrução normativa, tendo se fundado na EC 30. Assim, a reclamação jamais poderia ser julgada procedente pelo fato de a decisão do tribunal ordinário ter desrespeitado a parte dispositiva da decisão de inconstitucionalidade.

Nesse caso, entretanto, o Supremo Tribunal Federal deu grande e importante passo, demonstrando que não apenas a parte dispositiva, mas também os fundamentos ou a *ratio decidendi* obrigam os demais tribunais, impedindo-os de negá-los. Afirmou-se que, na decisão do Tribunal do Trabalho da 10.ª Região, revela-se evidente a “violação ao conteúdo essencial do acórdão (...). A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional”.²²³

A extensão do alcance do dispositivo da decisão é óbvio e não se discute. O que importa saber é se houve extensão dos limites dos fundamentos determinantes da decisão. Para tanto é necessário investigar os fundamentos do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade.

Lembre-se que esta ação teve por objeto a IN 11/1997-TST, que equiparou à hipótese de preterição do direito de preferência, a situação de não inclusão do débito no orçamento do ente devedor, assim como a de pagamento à menor, ou realizado fora do prazo, permitindo, nestas hipóteses, o sequestro de verba pública para o pagamento de dívidas judiciais trabalhistas. No curso da ação direta de inconstitucionalidade foi promulgada a EC 30/2000, que, embora tenha alterado regras relativas aos precatórios, nada modificou quanto à questão que então se discutia. E isso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito da ADIn, afirmou expressamente não ter a EC 30 realizado qualquer alteração na disciplina do sequestro no âmbito dos precatórios trabalhistas, decidindo que este somente estaria autorizado pela Constituição Federal no caso de preterição do direito de preferência, sendo inadmissível em qualquer outra situação.

Reconheceu-se, ainda, a inconstitucionalidade da instrução normativa por ter autorizado o sequestro de verbas públicas com base em pressuposto não previsto na Constituição. Ou melhor, por ter criado fundamento para o pedido de sequestro de verbas públicas não encampadas pela Constituição.

A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10.^a Região determinou o sequestro de verba do Distrito Federal para o pagamento de precatório, em hipótese em que não houve violação do direito de preferência. Fundou-se na EC 30, que, de acordo com os fundamentos da decisão tomada na ADIn, só admite o sequestro, no caso de precatório trabalhista, na hipótese de preterição do direito de preferência.

Afirmou-se, assim, para se chegar na decisão de inconstitucionalidade, que a instrução normativa estaria criando fundamento para o sequestro de verbas públicas, não previsto na Constituição, e que a Constituição não permite o sequestro de verbas públicas, tratando-se de precatório trabalhista ou de natureza alimentar, fora do caso de violação do direito de preferência.

Clara e límpida, a razão da decisão que declarou a inconstitucionalidade da instrução normativa do TST, torna-se fácil constatar que, na reclamação, simplesmente aplicou-se a ratio decidendi da decisão de inconstitucionalidade. Não houve extensão nem limitação do precedente, obviamente que entendido como ratio decidendi – como, aliás, deve ser compreendido. O caso era absolutamente similar ao tratado na ação de inconstitucionalidade.

Em outro caso, igualmente de reclamação, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, deparou-se com a decisão proferida na ADIn 1.622, mas agora para contrastá-la com decisão originária de ação de desapropriação e de ordem de sequestro fundamentada no art. 78, § 4.º, do ADCT.

Concluiu-se que esta decisão, por referir-se à precatório decorrente de indenização expropriatória, não estaria em contradição com a decisão da ADIn 1.662. Argumentou-se que a decisão proferida na ação direta “versou sobre a satisfação de precatórios e ofícios requisitórios decorrentes de créditos de natureza alimentar, nos termos do art. 100, § 2.º, da CF,²²⁴ enquanto a decisão reclamada teria origem “em ação de desapropriação e ordem de sequestro fundamentada no art. 78, § 4.º, do ADCT”, o que demonstraria “ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.²²⁵

É certo que a decisão não poderia ser objeto de reclamação caso se considerasse apenas o dispositivo da decisão proferida na ADIn 1.662. Assim, considerando-se os fundamentos determinantes desta decisão, é preciso verificar se eles contradizem a decisão que entendeu ser viável o sequestro, em caso de desapropriação, com base no art. 78, § 4.º, do ADCT.

Pois bem. Diz esta norma que “o Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do

credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação”. Não há dúvida que esta norma não foi objeto de discussão na ADIn 1.622, assim como não se tratou, nesta ação, acerca de precatório oriundo de ação de desapropriação. Contudo, o que realmente importa, pensando-se em fundamentos determinantes, é saber se estes, na referida ação direta, atingem os precatórios oriundos de desapropriação e impedem o sequestro com base no art. 78, § 4.º, do ADCT.

Mais do que a natureza do precatório, o que distingue a decisão de inconstitucionalidade da decisão que foi reclamada é a circunstância de a decisão proferida na ADIn 1.622 não ter tratado da previsão constante do art. 78, § 4.º, do ADCT. Isso, aliás, já fora dito na Rcl 3.293, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, in verbis: “Reclamação – Sequestro – Parcelamento de débito – Atraso – Art. 78 do ADCT – Matéria estranha ao que decidido na ADIn 1.662-7/SP. No julgamento da ADIn 1.662-7/SP, não houve emissão de entendimento quanto à legitimidade do § 4.º do art. 78 do ADCT, decorrente da EC 30/2000, ficando afastada a adequação de medida reclamatória formalizada a pretexto de se ter respeitada a autoridade do acórdão proferido”.²²⁶

Nesse caso, portanto, também não houve limitação ou extensão do precedente. O limite de extensão do precedente não permitia alcançar o caso, pois este foi integrado, essencialmente, por questão não contemplada nas razões do precedente.

5.2.2. Distinção perante o Superior Tribunal de Justiça. As mesmas razões que levam à necessidade de distinção perante o Supremo Tribunal Federal, também conduzem ao mesmo resultado perante o Superior Tribunal de Justiça. Tem o Superior Tribunal de Justiça de distinguir os casos para bem aplicar o direito ou desenvolvê-lo mediante ampliação ou redução do raio de alcance do precedente.

6. Superação (Overruling). Além do distinguishing, outra ferramenta básica para o sistema de precedentes é a superação (overruling). Se as distinções permitem uma adequada aplicação do precedente e um apropriado desenvolvimento do Direito mediante ampliação ou redução do alcance do precedente, a sua superação permite uma alteração – total ou parcial – no entendimento judicial a respeito de determinada questão, impedindo com isso o engessamento do Direito.

O Código de 2015 fala em seu art. 489, § 1.º, inciso VI, que o juiz tem o dever de enfrentar na fundamentação da decisão e, em sendo o caso, tem o dever de seguir “enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte”, salvo se demonstrar distinção entre os casos ou a necessidade de “superação do entendimento”. Mais além, refere que a “alteração de tese jurídica” poderá ser precedida de debate em audiências públicas e com pessoas, órgãos ou entidades capazes de contribuir para a discussão do tema (art. 927, § 2.º). Ainda, refere que essa “modificação” depende de “fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia” (art. 927, § 4.º) e que semelhante “alteração” pode se dar apenas para a frente – isto é, “pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica” (art. 927, § 3.º, CPC).

Essas disposições tornam oportuno o exame do tema à luz do Common Law, uma vez que essa tradição o conhece e o pratica já há algum tempo. Assim como com as distinções, também aqui o desenvolvimento desses conceitos no Common Law poderá colaborar com a respectiva compreensão no direito brasileiro.

6.1. Overruling no Common Law. A doutrina do Common Law costuma referir que a superação do precedente pode ser total (overruling) ou parcial (overturning). A superação parcial do precedente pode ocorrer por força de uma reescrita (overriding) ou transformação (transformation).

6.1.1. Overruling. Fala-se, na Inglaterra, que os precedentes têm uma eficácia horizontal particular diante da House of Lords (a partir de 1.º de outubro de 2009, da Supreme Court of the United Kingdom), em virtude de esses serem formalmente vinculantes, porém sujeitos ao overruling. Nas últimas décadas, a House of Lords não revogou mais de um precedente ao ano,

embora tenha exercido o poder de overruling em casos muito importantes, tanto no âmbito do direito privado quanto nos domínios do direito público.²²⁷

Essa ideia de uma “qualified doctrine of horizontal bindingness”²²⁸ decorre da circunstância de não se ter claro que a eficácia vinculante não é incompatível com o overruling. Não é pela razão de ter poder para revogar os seus próprios precedentes que a Corte pode revogá-los à distância de circunstâncias especiais, como se a todo instante pudesse rever a mesma questão jurídica. Não há qualquer sentido em ter poder para elaborar precedente e não ter dever de respeitá-lo. Lembre-se que a Suprema Corte estadunidense, embora venha exercendo o seu poder de overruling de modo bem mais intenso, é sempre cobrada quando revoga precedentes sem critérios razoáveis.

Portanto, se é certo que o sistema de precedentes que não admite o overruling não ter mais lugar, uma vez que impede o desenvolvimento do direito,²²⁹ também não há como pensar que a possibilidade de revogar precedentes é excludente da eficácia horizontal dos precedentes, isto é, da obrigatoriedade de respeito às próprias decisões. Não há sistema de precedentes quando as Cortes Supremas não se submetem a critérios especiais para revogar os seus precedentes. E é exatamente essa submissão a critérios que caracteriza a eficácia horizontal dos precedentes no direito contemporâneo – a propósito, veremos adiante que é essa a razão pela qual a “modificação” de precedente no direito brasileiro demanda em qualquer caso “fundamentação adequada e específica” e consideração dos “princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia” (art. 927, § 4.º, CPC).

É possível concluir, a partir daí, portanto, que o problema da eficácia horizontal ou da revogação dos precedentes é na verdade o problema dos critérios que orientam os Tribunais para tanto.

Diante do direito estadunidense, afirma Melvin Eisenberg que um precedente está em condições de ser revogado quando deixa de corresponder aos padrões de congruência social e consistência sistêmica e, ao mesmo tempo, quando os valores que sustentam a estabilidade – basicamente os da isonomia, da confiança justificada e da vedação da surpresa injusta²³⁰ – mais fundamentam a sua revogação do que a sua preservação.²³¹

Um precedente deixa de corresponder aos padrões de congruência social quando passa a negar proposições morais, políticas e de experiência. Essas proposições aparecem no raciocínio do Common Law exatamente quando se mostram relevantes para a elaboração, para a aplicação ou para a mudança de um precedente. Segundo Eisenberg, as proposições morais determinam uma conduta como certa ou errada, a partir do consenso moral geral da comunidade; as proposições políticas caracterizam uma situação como boa ou má em face do bem-estar geral e as proposições de experiência dizem respeito ao modo como o mundo funciona, sendo que a maior classe dessas últimas proposições descreve as tendências de condutas seguidas por subgrupos sociais.²³²

A Corte deve utilizar proposições morais ancoradas nas aspirações da sociedade como um todo, assim como empregar proposições de conteúdo político que reflitam uma situação como boa para a generalidade da sociedade. Essas proposições, dentro de uma adequada metodologia, devem poder ser vistas como substancialmente fundadas na comunidade, derivar de normas morais ou políticas que têm essa base ou aparecer como se tivessem tal fundamento. Do mesmo modo, as proposições de experiência, assim como as de moralidade e política, devem ter ancoragem social. Porém, ao contrário das duas últimas, não necessitam ter base na generalidade da comunidade. É que as proposições de experiência podem dizer respeito a assuntos técnicos, de interesse e conhecimento de poucos, devendo assim encontrar fundamento em outro lugar, como em pareceres ou em opiniões de especialistas²³³ (a propósito, como veremos adiante, essa é a razão pela qual o art. 927, § 2.º, CPC, fala em audiências públicas e na participação de pessoas, órgãos ou entidades capazes de contribuir para a rediscussão do tema).

De outra parte, o precedente não tem consistência sistêmica quando deixa de guardar coerência com outras decisões. Isso ocorre quando a Corte decide, mediante distinções inconsistentes, chegando a resultados compatíveis com o do precedente, mas fundados em proposições sociais incongruentes e quando a Corte, apesar de tratar de situação diversa, decide

com base em proposições sociais incompatíveis com as que fundamentaram o precedente.

Importa salientar que, tanto a ausência de congruência social, quanto a falta de consistência sistêmica costumam ser demonstradas pela doutrina, cuja vigorosa e pontual crítica possui importância insuspeita para quem não está familiarizado aos precedentes obrigatórios. A crítica doutrinária permite não apenas a individualização dos precedentes que se revestem de algum ou de ambos os defeitos, como também apresenta os argumentos que os evidenciam, deixando a classe dos advogados adequadamente informada acerca da atual força de determinado precedente. A informação dos advogados é um dos elementos de grande importância para descaracterizar os fundamentos para a preservação do precedente, pois elimina as alegações de confiança justificada e de vedação de surpresa injusta.

A revogação de um precedente depende da adequada confrontação entre os requisitos básicos para o overruling – ou seja, a perda de congruência social e o surgimento de inconsistência sistêmica – e os critérios que ditam as razões para a estabilidade ou para a preservação do precedente – basicamente a confiança justificada e a prevenção contra a surpresa injusta. Eisenberg procura trabalhar essa relação na dimensão do que chama de jagged doctrines – isto é, entendimentos ou precedentes controversos. Os precedentes controversos preenchem a primeira condição para o overruling, pois são socialmente incongruentes e, em virtude disso, acabam se sujeitando a exceções inconsistentes, bem como se tornando inconsistentes com outros precedentes. Ou seja, os precedentes controversos são socialmente incongruentes e por isso se tornam sistematicamente inconsistentes, seja em razão da sua inconsistência com as exceções, seja em virtude da sua inconsistência com outros precedentes.²³⁴

Ademais, tratando-se de precedente controverso, os valores da estabilidade melhor justificam a sua revogação do que a sua preservação.²³⁵ Se a preservação de precedente controverso pode levar a tratamento igualitário dos casos de hoje e de ontem – o que é discutível, pois a alteração das proposições sociais aplicáveis pode exigir a mudança de resultado exatamente para permitir igualdade de tratamento – a preservação de precedente controverso resultará na inconsistência de resultados entre os casos presentes. Na hipótese de exceções inconsistentes, é certo que os resultados darão tratamento desigual às partes de casos em que o precedente se aplicar e às partes de casos em que ocorrerem as distinções inconsistentes.²³⁶

Para melhor demonstrar essa complexa relação entre os princípios básicos – ou, melhor dizendo, primários e não suficientes – do overruling e os valores da estabilidade, Eisenberg faz referência à história do precedente da isenção de responsabilidade das instituições de caridade, conhecida no direito estadunidense como “charitable-immunity doctrine”. Antes dos anos 40 do século passado, havia uma regra que afirmava a imunidade das instituições de caridade diante da responsabilidade por danos. Argumentava-se: (i) a concessão de indenização fora do fundo de caridade poderia violar o propósito da fundação (geralmente referida como “the trust-fund theory”); ii) o princípio da responsabilidade indireta era aplicável somente às instituições com fins lucrativos; iii) os beneficiários da caridade desistiriam do serviço ou assumiriam o risco do dano; e iv) a imposição de responsabilidade à instituição de caridade dissiparia os seus fundos e privaria as pessoas que dela se favorecem e o público em geral dos benefícios da caridade, além do que desencorajaria contribuições. Essas razões embutiam vários motivos implícitos, decorrentes da moral, da política e da experiência que prevaleciam à época em que foi estabelecido o precedente da imunidade das instituições de caridade. Entendia-se fundamentalmente que as instituições de caridade, por serem economicamente frágeis, não podiam fazer frente a pretensões indenizatórias, além de serem fundamentais para a sociedade em uma época em que os programas governamentais de bem-estar social eram escassos.²³⁷

Por volta dos anos 50 do século XX, com a perda de força das razões que justificaram o precedente, esse passou a ser amplamente criticado na doutrina. Dos principais argumentos podem ser sintetizados os seguintes: i) os doadores não tinham ou não manifestavam intenção de que os fundos não fossem utilizados para indenizar os danos causados pelas instituições de caridade e não havia qualquer razoabilidade em sustentar que o princípio da responsabilidade por atos de prepostos fosse aplicável apenas às instituições com fins lucrativos; ii) o

desenvolvimento dos seguros de responsabilidade eliminara o temor de que o pagamento de indenizações pudesse dissipar os fundos de caridade e privar as pessoas e os beneficiários dos seus serviços, bem como desencorajar contribuições. O mais importante, porém, é que as instituições de caridade deixaram de ser organizações pequenas e sem poder econômico, tornando-se empresas economicamente fortes e bem administradas. Restou claro, diante disso, que a circunstância de responderem por seus danos, longe de poder esgotar a sua capacidade econômica ou prejudicar os seus beneficiários, seria indispensável para não deixar ao desamparo os prejudicados pelos seus atos. Do pequeno hospital, presente na comunidade pobre, o paradigma passou a ser o complexo médico urbano, com orçamento na casa das dezenas ou centenas de milhões de dólares, administrado por profissionais competentes, sendo difícil distingui-lo, em termos organizacionais, de uma empresa de negócios.²³⁸

A falência da congruência social do precedente, além de explicitada pela doutrina, passou a gerar exceções inconsistentes. Assim, por exemplo, a Corte de Nova Iorque decidiu que a instituição de caridade não tinha responsabilidade no caso em que fora administrada uma bolsa de água quente de forma inapropriada, mas entendeu ser ela responsável no caso em que a bolsa de água quente ficara por tempo superior ao devido em aplicação sobre o paciente. Também disse haver distinção entre transfusão de sangue para o paciente errado e transfusão de sangue errado ao paciente certo; entre o caso em que se utilizou agulha mal esterilizada para uma injeção e aquele em que se deu uma injeção de maneira inapropriada; e entre deixar de colocar os aparadores em uma cama hospitalar e o médico deixar de determinar o uso desses aparadores. Tentou-se distinguir atos de responsabilidade da administração do hospital e atos de responsabilidade do médico, sempre para se decidir que a imunidade da instituição de caridade abarcaria apenas os atos de responsabilidade médica. A Corte de Ohio decidiu que um membro de uma Igreja que, após o culto, sofrera uma queda ao se dirigir ao local em que eram vendidos artigos religiosos não tinha direito à indenização, mas questionou-se se a imunidade seria aplicável diante de uma ação ajuizada por um membro da Igreja que participou de um jantar pago enquanto atendia a um bazar para arrecadação de fundos para a Igreja. A Corte do Missouri definiu que a imunidade impedia a ação por danos em relação a um prédio adquirido e mantido pela caridade, do qual ocupava uma parte e alugava outra, mas a imunidade não foi aplicada diante de um prédio que a caridade adquiriu e mantinha, mas não ocupava, embora os seus rendimentos fossem gastos unicamente na sede da instituição de caridade para idosos.²³⁹

A inconsistência não ficou clara apenas em face dessas exceções, mas também diante de casos em que se discutia a responsabilidade por danos provocados por instituições com fins lucrativos. Tornou-se inconsistente responsabilizar um hospital privado pela ação do seu médico e negar que a mesma conduta do cirurgião de um hospital sem fins lucrativos pudesse gerar igual responsabilidade. A inconsistência se explicava em razão de que as proposições sociais que, anteriormente, isentavam o hospital sem fins lucrativos de responsabilidade não mais se aplicavam, devendo ambos os hospitais se submeter à igual responsabilidade.²⁴⁰

A partir dos anos 40, portanto, o precedente da imunidade das instituições de caridade se tornou controverso (*jagged doctrine*), pois incompatível com as novas proposições sociais, e inconsistente, interna e externamente, com outros entendimentos – distinções inconsistentes e precedentes calcados nas novas proposições.²⁴¹

Diante da perda da congruência social e da consistência sistêmica do precedente, os fundamentos da estabilidade não puderam lhe garantir preservação. Isso porque a preservação sustentaria a consistência entre os resultados presentes e os passados, mas deixaria evidente a inconsistência entre os resultados presentes e aqueles obtidos diante de distinções inconsistentes (casos tratando da imunidade de instituições de caridade) e de novos casos semelhantes (casos envolvendo responsabilidade de instituições com fins lucrativos). De modo que a igualdade não só não fundamentava a preservação do precedente, como impunha a sua imediata revogação.

Nessa dimensão, lembra Eisenberg que a proteção da confiança justificada e a prevenção contra a surpresa injusta também normalmente não servem melhor à preservação de um precedente controverso do que à sua revogação. Sabe-se que uma importante espécie de confiança

geral consiste na probabilidade de um número significativo de pessoas ter pautado as suas condutas com base num precedente. Porém, a confiança injustificada, frágil ou destituída de fundamentação jurídica, certamente não constitui argumento capaz de permitir a preservação de um precedente incongruente e inconsistente. Confiança justificada num precedente controverso – socialmente incongruente e inconsistente – é muito improvável.²⁴²

Ao tomar em consideração a hipótese de uma classe de pessoas que poderia ter confiado num precedente controverso, Eisenberg faz considerações que merecem ser reproduzidas.

Admita-se, em primeiro lugar, que alguns membros dessa classe não consultaram um advogado antes de se envolverem em importante negociação. Certamente, as pessoas não podem reclamar por ter confiado em um precedente socialmente incongruente, se elas não tinham sequer ideia da sua existência. No common law é muito difícil atribuir confiança a partir de leigos e não há razão para proteger palpiteiros.

Suponha-se, em segundo lugar, que alguns membros dessa classe consultaram advogados, mas obtiveram conselhos equivocados sobre o conteúdo jurídico da questão ou acerca do estado da arte (the state of the law). Aqui, novamente a confiança não deve constituir preocupação. Não há como atribuir relevância, no momento da decisão, à circunstância de que algumas pessoas confiaram num mau conselho. Ora, ao se pensar sobre se a confiança milita contra a revogação, pouco importa o conselho que algumas pessoas eventualmente receberam, mas sim o posicionamento que teria um jurista respeitado e bem informado.

Suponha-se, por fim, que alguns membros da classe consultaram advogados bem informados, os quais efetivamente prestaram uma dessas opiniões: a) há um precedente que se aplica, de plano, ao negócio. Entretanto, as condições para a revogação desse precedente estão preenchidas e, em minha opinião, ele não constitui mais direito; b) há um precedente aplicável, de plano, ao negócio, porém o precedente está sujeito a exceções inconsistentes e, apesar do meu posicionamento, continua prevalecendo e governando o negócio. Assim, mantenho minha opinião com um grau de certeza relativamente baixo.²⁴³

Analisando a última hipótese, em que houve consulta a advogado bem informado, conclui, Eisenberg, que as pessoas cujos advogados informaram que as condições para a revogação do precedente estavam preenchidas, não poderão reclamar de que confiaram no precedente. Aqueles que consultaram advogados que emitiram o parecer de que o precedente, embora exposto a exceções inconsistentes, continuava prevalecendo, não poderão sustentar confiança justificada. Não há confiança robusta e juridicamente bem fundamentada quando um precedente está sujeito a exceções inconsistentes – especialmente exceções que não poderiam ser vistas como coerentes – e a sua preservação é fonte para dúvidas substanciais. Aliás, ainda que a confiança possa, de alguma forma, ser vista como robusta e juridicamente bem fundamentada, ela não é justificada quando o precedente deixou de ter congruência com as proposições sociais aplicáveis. Isso porque as pessoas não podem planejar suas condutas com base em um precedente que sabem ser inconsistente com proposições que têm suporte social substancial, pois nesta situação a confiança não será moralmente justificada. Porém, mesmo as pessoas que não conhecem o direito podem ter determinada confiança ou desconfiança em relação à certa conduta. A partir da percepção do que é socialmente errado e certo, as pessoas podem firmar confiança de que determinadas condutas serão sancionadas e outras não. Nessa perspectiva, a preservação do precedente que deixou de ter sustentáculo nas proposições morais milita contra a proteção da confiança justificada, sendo possível dizer que mesmo os leigos esperam a sua revogação.²⁴⁴

A prevenção contra a surpresa injusta, vista como o valor reflexo (mirror image value) da proteção da confiança justificada, também não fundamenta a preservação do precedente quando se está diante das circunstâncias antes expostas. Quando o precedente deixa de ter congruência social, daí advindo distinções inconsistentes e críticas doutrinárias, o overruling fica muito longe de poder constituir uma surpresa injusta. Nesses casos, a manutenção do precedente incongruente e inconsistente estaria mais perto de uma surpresa injusta do que o seu oposto, já que os que desconheciam a perda de autoridade do precedente, de um lado, estariam apostando contra as proposições com suporte social, e, de outro, teriam negadas as suas expectativas razoáveis,

baseadas na percepção do que é socialmente errado e certo.

No caso da imunidade das instituições de caridade, a confiança justificada e a prevenção contra a surpresa injusta, não constituíam obstáculos à revogação do precedente. Não havia confiança, amparada no direito, que sustentasse a autoridade do precedente. Ao contrário, as várias distinções inconsistentes – relacionadas às instituições de caridade – assim como a inconsistência do precedente diante de outros precedentes – fundados nas proposições sociais aplicáveis – demonstravam que o precedente estava à beira de ser revogado. Isso para não falar nas críticas doutrinárias, precisas em apontar a sua perda de congruência social e de consistência sistêmica.

Nem mesmo quando a confiança é relacionada ao seguro por danos, a situação se altera. Se era possível argumentar que as instituições de caridade poderiam deixar de fazer seguros por confiarem em sua imunidade, é certamente improvável que elas não tivessem consciência de que o precedente que as socorria havia perdido sustentação social, até mesmo porque isso estava refletido na crítica acadêmica e nas decisões judiciais. Da mesma forma, ainda que, em tese, fosse possível às seguradoras elaborarem o valor dos prêmios confiando na imunidade das instituições de caridade, não há como esquecer que a própria necessidade de seguro teria decorrido da perda da autoridade do precedente da imunidade. Na verdade, como as seguradoras também trabalham em razão da própria possibilidade de alteração dos precedentes, não há qualquer racionalidade em supor que as seguradoras, ao contratarem os prêmios, pudessem estar alheias ao que se passava com o precedente.²⁴⁵

Pelas mesmas razões, a revogação do precedente da imunidade das instituições de caridade não afetaria a prevenção contra a surpresa injusta. Não há como pensar em surpresa injusta quando a doutrina e os tribunais estão a demonstrar a perda de congruência social e a falta de consistência sistêmica do precedente.²⁴⁶

Teme-se que a revogação de precedente possa gerar insegurança ou perda de confiança em outros precedentes. No entanto, quando os precedentes são revogados com base em critérios que também são reafirmados e respeitados, torna-se possível vislumbrar quando um precedente está em vias de ser revogado. E isso ocorre exatamente quando o precedente deixa de ter sustentáculo nas proposições sociais e se torna inconsistente, e, além disso, não há justificativa para a sua preservação em face dos fundamentos da estabilidade. Um precedente controverso costuma ser retratado nos trabalhos doutrinários e as distinções inconsistentes evidenciam a sua fragilidade. Tanto a crítica doutrinária, quanto a judicial, são critérios de identificação dos precedentes que devem ser revogados, de modo que o overruling, nessas condições, certamente não elimina a confiança nos precedentes judiciais.

Deixou-se claro que, apesar de presentes as razões justificadoras da revogação do precedente, esse pode ser preservado em virtude dos fundamentos da estabilidade, particularmente da proteção da confiança justificada e da prevenção contra a surpresa injusta.²⁴⁷ Porém, afigura-se prudente melhor tratar dos critérios básicos para o overruling, ou melhor, dos critérios que justificam a revogação do precedente ainda que esse possa, em virtude dos fundamentos da estabilidade, ser preservado.

Foi dito que proposições morais, políticas e de experiência, devidamente ancoradas no seio social, assim com a falta de consistência do precedente com exceções ou com outros precedentes, constituem critérios básicos para o overruling. É preciso esclarecer, porém, que a revogação não requer a concomitância de ambos os requisitos, uma vez que pode se justificar unicamente a partir das proposições sociais, ou melhor, da perda de congruência social do precedente. Assim, se, em regra, a falta de congruência social gera inconsistência sistêmica, não é verdade que a ausência de congruência social não seja bastante à revogação. De outra parte, contudo, não há como pensar em decisões inconsistentes quando as proposições sociais que estão por detrás do precedente são reafirmadas nas novas decisões.

A transformação da concepção moral, política e de experiência é determinante de uma nova configuração do precedente. A alteração da concepção geral moral, assim como as novas proposições políticas, pertinentes à evolução do Estado, certamente podem abrir margem à

revogação de precedentes. Do mesmo modo, incluída entre as proposições de experiência, as proposições relacionadas à evolução da tecnologia, facilmente podem fazer ver a necessidade de overruling.

Não obstante, não há como deixar de admitir que uma nova concepção geral do direito igualmente pode impor a revogação. Não se trata de inconsistência sistêmica do precedente, ou seja, de uma concepção interior aos tribunais acerca da superação das proposições que o justificam, expressa em exceções inconsistentes, mas de uma nova concepção geral em termos de teoria ou dogmática jurídica, a evidenciar que aquilo que se pensava acerca de uma questão ou instituto jurídico se alterou. Porém, para que essa nova concepção acerca do direito possa justificar a revogação de um precedente, ela tem de estar presente nos círculos acadêmicos, isto é, nas universidades e nos trabalhos doutrinários, assim como nos tribunais, em face de outros casos ou até mesmo de distinções inconsistentes produzidas em virtude da modificação na compreensão do direito.²⁴⁸

Evidentemente não basta, para alterar um precedente, uma nova compreensão pessoal e individualizada da questão de direito. A posição de um único doutrinador ou de apenas um juiz não importa quando se pensa em preservar ou não um precedente. Na verdade, a vontade da minoria, ou melhor, aquilo que não configura a expressão geral da comunidade jurídica, é absolutamente incapaz de interferir sobre a estabilidade dos precedentes. Bem por isso não é possível revogar um precedente em razão da alteração na composição do órgão julgador ou do tribunal, como se o direito pudesse variar ao sabor do acaso.

Ademais, o chamado “erro” ou “equivoco”,²⁴⁹ hábil a justificar a revogação de um precedente no direito estadunidense, também deve ser evidenciado no ambiente acadêmico e, muito comumente, nos tribunais. O erro que justifica o overruling deve ser claro, evidente, de modo a dar à Corte, a nítida ideia de que a perpetuação do precedente constituirá uma “injustiça”. Assim, esse “erro” obviamente não tem o mesmo significado daquele que, num sistema estranho aos precedentes obrigatórios, permite um julgamento em sentido contrário, nem constitui a mera revelação do que pensa um juiz ou grupo de juízes da Corte acerca de certa questão jurídica.²⁵⁰

Não só a alteração na concepção geral do direito e o “erro” ou o “equivoco”, mas também a modificação das proposições sociais costuma ser retratada nos trabalhos acadêmicos e nas críticas doutrinárias dirigidas aos precedentes. Nessa dimensão, o trabalho dos juristas é extremamente importante para individualizar os precedentes à margem de revogação, constituindo veículo para a informação das classes profissionais e, assim, para evitar a violação da confiança justificada e da garantia contra a surpresa injusta.

É claro que essas situações também podem ser evidenciadas pelos tribunais mediante distinções inconsistentes. Essas distinções, especialmente quando fundadas em proposições sociais inconsistentes com as que embasam o precedente, constituem evidências de que esse será revogado em breve.

6.1.2. Overturning. Overriding e Transformation. Pode ocorrer de não ser o caso de superação total do precedente, mas algo semelhante a uma revogação parcial (overturning). Nesse caso costuma-se falar, principalmente diante do direito estadunidense, em overriding (reescrita) e transformation (transformação) do precedente.

O overriding não se confunde com o overruling. Também nada tem a ver com a sinalização e com a transformation. Basicamente pela razão de que, mediante o seu uso, não se revoga o precedente (overruling), não se anuncia a sua iminente revogação (sinalização) nem se faz a reconstrução do precedente, isto é, não se consideram como fatos relevantes ou materiais aqueles que, no precedente, foram considerados de passagem, atribuindo-se, diante disso, nova configuração (transformation).

O overriding apenas limita ou restringe a incidência do precedente, sendo algo muito próximo de uma revogação parcial²⁵¹. Mas no overriding não há propriamente revogação nem mesmo parcial do precedente, embora o resultado da decisão com ele tomada não seja compatível com a

totalidade do precedente. Mediante esse expediente, a Corte deixa de adotar precedente a princípio aplicável, liberando-se da sua incidência.

O overriding se baseia na necessidade de compatibilização do precedente com um entendimento posteriormente formado. A distinção que se faz para se deixar de aplicar o precedente em virtude do novo entendimento, é consistente com as razões que estiveram à base da decisão que deu origem ao precedente. Como explica Eisenberg, teoricamente o overriding poderia ser visto apenas como um caso especial de desvinculação (hiving off) mediante distinções consistentes, quando a Corte lida com um tipo de situação que não estava envolvida nos precedentes que deram origem ao entendimento anterior e conclui que, dadas as proposições sociais que fundamentam aquele entendimento anterior, a situação em questão deveria ser desvinculada para ser tratada de acordo com o entendimento mais recente.²⁵²

Portanto, há nova situação e novo entendimento no plano dos tribunais ou da academia, capaz de não permitir que caso substancialmente idêntico seja tratado da mesma forma. A distinção feita no overriding supõe que o litígio anterior, caso fosse visto na perspectiva da nova situação e do novo entendimento, teria tido outra solução. É por isso que, embora o overriding não signifique revogação, o seu resultado, do mesmo modo que aquele a que se chegou com o overruling, é incompatível com o precedente.

É importante sublinhar que, mediante o overriding, realiza-se uma distinção consistente com as razões que inspiraram o precedente. Consistente porque, dadas as razões do precedente, a consideração da nova situação e do novo entendimento justifica o tratamento diferenciado. De modo que a distinção é consistente com as velhas razões. É essa consistência que justifica a não revogação do precedente. As mesmas razões dão fundamento ao precedente e ao tratamento diferenciado em virtude da nova situação e do novo entendimento.

Apresenta-se conveniente melhor explicar o overriding mediante os exemplos fornecidos pela doutrina estadunidense. Destaquem-se, assim, as seguintes situações lembradas pela doutrina.

Antes dos anos 30 do século passado, havia entendimento firmado no sentido de que promessas de doação eram inexecutáveis. Em 1932, o Primeiro Restatement²⁵³ of Contracts adotou, em sua famosa Seção 90, o princípio de que as promessas de doação seriam executáveis quando confiáveis (if relied upon). Depois disso, as Cortes revogaram parcialmente (overroded) o entendimento anterior e aplicaram esse princípio para limitar o âmbito de incidência do entendimento antigo às promessas de doação não confiáveis.

Durante os anos 40, havia entendimento no sentido de que uma oferta acompanhada da promessa de se manter aberta por determinado período de tempo – considerada, assim, uma firm offer – era revogável apesar da promessa, a menos que essa tivesse sido paga separadamente. No começo dos anos 50, os tribunais revogaram parcialmente (overroded) esse entendimento, aplicando o princípio da confiança às ofertas firmes para limitar o âmbito do velho entendimento às ofertas consideradas não confiáveis.

Ao longo dos anos 50, estabeleceu-se o entendimento de que os acordos não poderiam ser revisados com fundamento em critérios de justiça, mas, no início dos anos 60, as Cortes revogaram parcialmente (overroded) aquele entendimento – aplicando o princípio da unconscionability²⁵⁴ – para admitir a revisão de acordos diante de certas espécies de injustiças.²⁵⁵

Sem dúvida, há nessas situações um entendimento posterior. Porém, como confessa o próprio Eisenberg, na prática, quando um tribunal revoga parcialmente (overrides) um entendimento estabelecido, geralmente lida com as mesmas espécies de situações tratadas nos precedentes. Assim, antes de ser adotada a Seção 90, o entendimento de que uma promessa de doação era inexecutável já vinha sendo aplicado a casos nos quais o promissário claramente confiava na promessa. Também, antes de a exceção da confiança se firmar, algumas Cortes já explicitamente defendiam que a confiança não tornava uma oferta firme irrevogável. Por fim, antes do princípio da unconscionability, alguns tribunais executaram acordos que agora sucumbiriam diante desse princípio.²⁵⁶

Mesmo que signifique uma revogação parcial não expressamente anunciada, por constituir resultado incompatível com o do precedente, o overriding é admitido nos Estados Unidos. Note-se que, ainda que o overriding trate da mesma situação envolvida no precedente, embora à luz de novo entendimento, ele não anuncia a sua revogação. Aliás, não obstante o overruling frequentemente conduza a uma revogação apenas parcial, em alguns casos ele pode ter a capacidade de silenciar, em sua totalidade, o entendimento anterior, gerando, assim, a implícita revogação do precedente em sua totalidade, chamada de implied overruling ou revogação implícita.²⁵⁷

Mediante a transformation, a Corte nega o conteúdo do precedente, mas deixa de expressar isso formalmente através do overruling. Ou seja, no overruling a Corte expressamente anuncia a revogação do precedente, enquanto na transformation isso não acontece.²⁵⁸

O resultado obtido na decisão que fez o overruling, não é compatível com o resultado do precedente revogado. Na transformation, porém, tenta-se muitas vezes compatibilizar o resultado do precedente transformado com o resultado alcançado no caso sob julgamento. Isso poderia ser visto como distinção substancial entre o overruling e a transformation. Acontece que essa compatibilidade é frequentemente artificial. A compatibilidade entre os resultados obtidos no caso transformado e no caso em que se fez a transformation é obtida somente quando se realiza a individualização de pontos do precedente que a antiga Corte não considerou fundamentais ou materiais. Adverte Eisenberg que, no célebre caso *MacPherson v. Buick Motor Co.*, Cardozo apontou para a aparente consistência entre a decisão que tomou e as decisões proferidas em casos precedentes – que se negaram a admitir a responsabilidade do fabricante – mas não viu esses casos da maneira como as Cortes que os julgaram, os conceberam. Em outros termos: Cardozo, ao apontar para a consistência entre as decisões, teria enxergado o caso anterior de forma distinta da Corte que o julgou e que definiu o precedente.²⁵⁹

De qualquer forma, ainda que frisando pontos que não foram considerados pelas Cortes anteriores, mediante a desconstrução de precedentes e casos já julgados, a transformation evidencia ainda que, em parte, a superação da *ratio decidendi* do precedente, no curso da história.

Contudo, se a distinção entre overruling e transformation é mais formal do que substancial, surge ao menos a curiosidade de indagar o motivo pelo qual a Corte pode preferir a transformation em relação ao overruling. Eisenberg alude à doutrina de Peter Westen para demonstrar que tanto a transformation quanto o overruling admitem equívoco no raciocínio ou na fundamentação das decisões anteriores, mas apenas o overruling aceita ter havido um erro de julgamento. A transformation admite equívoco na tese então sustentada, mas não aceita que a Corte tenha cometido impropriedade ao julgar o caso anterior. O overruling constitui confissão de que não apenas a tese está equivocada, mas também de que a Corte errou ao decidir em favor de uma das partes e não da outra. A transformation, por sua vez, não aceita a ideia de que a decisão deveria ter sido favorável ao autor e não ao réu ou vice-versa. Por exemplo, a Corte de Massachusetts, ao realizar o overruling no caso *Whitinsville*, além de reconhecer o equívoco na tese sustentada, admitiu o erro dos julgamentos anteriores. Porém, em *MacPherson v. Buick Motor Co.*, a Corte de Nova York não admitiu que as Cortes anteriores tivessem proferido decisões erradas, dando ganho de causa a uma parte, em vez da outra.²⁶⁰

A outra “vantagem” da transformation sobre o overruling estaria na não perturbação dos precedentes, enfatizando-se a segurança proporcionada pela sua estabilidade. Com isso surgiria a ideia, ainda que artificial, de que o respeito aos precedentes estaria sendo preservado, mesmo que as verdadeiras razões neles embutidas não fossem mais aceitas.²⁶¹

Adverte Eisenberg que as desvantagens da transformation constituem o lado obscuro das suas vantagens. A principal delas está na dificuldade de as Cortes inferiores compreenderem o real significado da decisão em que se fez a transformation. Isso é ocasionado exatamente pela sua artificialidade, expressa na tentativa de o julgador “esconder” o que está implícito em seu raciocínio.²⁶²

Parece que a grande desvantagem da transformation está na circunstância de que as Cortes

inferiores muitas vezes têm dificuldade para compreender o seu exato conteúdo, não sendo raras as hipóteses em que os tribunais vinculados continuam aplicando o precedente transformado, ou melhor, o entendimento antes estabelecido, como se nada houvesse acontecido. Foi o que ocorreu, por exemplo, após *MacPherson v. Buick Motor Co.*, já que muitos trial-court judges do Estado de Nova York prosseguiram aplicando a tese da responsabilidade civil do fabricante, deixada de lado no julgamento de tal caso, por não terem compreendido o que realmente Cardozo fez ao decidilo.²⁶³

Ademais, como a transformation não revoga o precedente, nada impede que esse passe por várias “transformações”, cada uma delas constituindo uma nova decisão, a ser considerada pelas Cortes inferiores. É claro que a pluralidade de decisões acerca de um mesmo tema gera maior dificuldade aos juízes, o que não se dá quando se está diante do overruling, devido a sua forma objetiva de demonstrar a revogação do precedente e o estabelecimento de nova regra.

Paradoxalmente, a grande vantagem da transformation parece decorrer exatamente do fato de que com ela as Cortes prosseguem decidindo a respeito da mesma questão jurídica. Isso, é certo, a princípio milita contra a própria razão de ser do sistema de precedentes, já que dessa forma não se obtém a cristalização do entendimento que deve orientar os advogados e jurisdicionados.

É preciso perceber, porém, que a transformation apenas se sustenta, enquanto a Corte ainda supõe que é necessária maior discussão a respeito do tema jurídico. Se a questão está madura para ser definida, achando-se a Corte em condições de definir a nova regra e revogar o precedente, impõe-se o overruling. Assim, não parece que a transformation possa encontrar base unicamente na preservação da estabilidade dos precedentes, até porque, como restará demonstrado mais tarde neste livro, o overruling não contradiz a estabilidade do sistema, mas, ao contrário, a garante.

Deixe-se claro que o overruling é ideal quando se tem motivo para abandonar entendimento antes fixado. As razões que justificaram a transformation em épocas passadas, como a tutela da estabilidade do sistema de precedentes e a preservação da confiança nos julgamentos, não têm motivo para prevalecer quando se tem a clareza de que o overruling é necessário para preservar a confiança no sistema. Não fosse por isso, como adverte de seu lado Eisenberg, a clareza do overruling tem maior probabilidade de levar a um coerente desenvolvimento dos precedentes, do que a deliberadamente opaca natureza da transformation.²⁶⁴

6.1.3. Overruling e Signaling. No direito estadunidense, a fim de prevenir a surpresa injusta diante da revogação inesperada de um precedente, fala-se na necessidade de sinalização (signaling) do seu enfraquecimento.²⁶⁵ Com essa técnica, o tribunal não ignora que o conteúdo do precedente está equivocado ou não mais deve subsistir, mas, em virtude da segurança jurídica, deixa de revogá-lo, preferindo apontar para a sua perda de consistência e sinalizar para a sua futura revogação.

Nessa situação, o tribunal tem consciência de que o distinguishing não é possível, pois a solução que se pretende dar à questão, é logicamente incompatível com a ratio decidendi do precedente. A exceção que derivaria do distinguishing, não guardaria lógica com a manutenção do precedente.

Não obstante, também sabe a Corte que a revogação do precedente, diante das particularidades da situação, estará colocando em risco a segurança jurídica por conta da negação da previsibilidade então outorgada à comunidade. Mantém-se o precedente unicamente em virtude da segurança jurídica, isto é, da previsibilidade dada aos jurisdicionados e da confiança que o Estado deve tutelar, ainda que não se duvide que a sua manutenção está em desacordo com o ideal de direito prevalente à época.²⁶⁶

Como a sinalização, portanto, objetiva-se comunicar que o precedente, que até então orientava a atividade dos jurisdicionados e a estratégia dos advogados, será revogado, evitando-se, com isso, que alguém atue em sua conformidade e, ainda assim ou por isso mesmo, seja prejudicado em seus negócios ou afazeres, isto é, em sua esfera jurídica. Frise-se que os litigantes, no caso concreto em que se faz a sinalização, não são pegos de surpresa, já que a decisão é orientada pela ratio decidendi em vias de revogação, tudo em respeito à confiança na autoridade dos precedentes

judiciais.

Nesse caso, verifica-se uma clara tensão entre o benefício outorgado pela revogação do precedente e a segurança jurídica. Como é óbvio, a mera existência de precedente e a eventual e pouco provável criação de expectativa aos usuários do Poder Judiciário, certamente não bastam para fazer prevalecer a segurança sobre o overruling. É preciso, nesse instante, estar atento ao significado da autoridade e da força dos precedentes perante a sociedade e o sistema de distribuição de justiça. Assim, convém deixar de pensar o precedente em abstrato e tomar em consideração algo que faz parte da sua natureza transitória. A autoridade e a força do precedente podem variar no tempo, culminando, em certos casos, com a sua incompatibilidade diante da sociedade e do sistema jurídico. Não obstante, a superação de um precedente nem sempre é clara ou visível aos olhos dos jurisdicionados e dos advogados.

Nos Estados Unidos, quando não há manifestações doutrinárias e decisões judiciais que permitam ver que o precedente perdeu força, entende-se por consequência que o jurisdicionado, que nele se pautou ou que os negócios jurídicos que nele se basearam, devem ser protegidos. O Estado deve tutelar a legítima confiança depositada no precedente e, se esse não foi desacreditado pela academia e pelos tribunais, inexistem critérios objetivos para justificar a sua inaplicabilidade. Em outras palavras, quando o precedente não é abalado de modo sério e objetivo, não há como desamparar o jurisdicionado que lhe devotou confiança.

Aliás, é possível que um precedente deva ser mantido, ainda que já tenha sido objeto de sérias críticas em nível doutrinário. Isso ocorre nas áreas em que existe sério planejamento calcado em precedentes e, assim, atividade estritamente pautada na confiança depositada nas decisões judiciais. A tutela da justificada confiança é particularmente realçada nas hipóteses em que terceiros se orientam por precedentes para considerar determinadas situações.²⁶⁷

Nesses casos, se aplica por excelência, a técnica da sinalização, mediante a qual, nas palavras de Melvin Eisenberg, a Corte pavimenta o caminho para o overruling do precedente que acredita que deva ser preservado em virtude da justificada confiança.²⁶⁸ Para explicar a technique of signaling, Eisenberg alude a uma série de casos que ficaram conhecidos como Massachusetts cases, nos quais se controverteu acerca de direito de propriedade, especificamente sobre pactos de restrição relativos a parcelas de propriedade, em que se falava de parcela dominante e subordinada.

Uma espécie comum de pacto restritivo proibia qualquer uso da parcela de propriedade subordinada que pudesse concorrer com o uso da parcela dominante. Em Massachusetts, contudo, surgiu um precedente em sentido contrário em *Norcross v. James*, decidido em 1855 pelo Justice Holmes. Em *Norcross*, decidiu-se que, se no contrato entre arrendante e arrendatário, não restou estabelecido o privilégio da área dominante em detrimento da subordinada, o arrendante pode dispor da parcela subordinada do modo que melhor lhe convier, mesmo que com isso a parcela dominante possa ser prejudicada.²⁶⁹

O precedente firmado em *Norcross* foi criticado pelos juristas e comentadores e conflitou com decisões proferidas em outros Estados. Em 1927, a Suprema Corte de Massachusetts seguiu o precedente em *Shade v. M. O'Keefe, Inc.* A questão voltou a ser discutida na década de 60 do século passado em *Shell Oil Co. v. Henry Ouellette & Sons Co.* Ouellette, proprietária de cem acres de terra, que transmitiu vinte para certas companhias em 1962, prometendo por si e por seus sucessores que os restantes oitenta acres não seriam usados de forma tal que pudesse concorrer com o uso contemporâneo feito nos vinte acres. Em 1963, as empresas venderam parte dos vinte acres para a Shell, que construiu um posto de gasolina na área. Em 1965, a Ouellette concedeu opção a Mobil para a aquisição de parte dos restantes oitenta acres para a construção de posto de gasolina que iria concorrer com o da Shell. A Shell, então, propôs ação judicial contra a Ouellette e a Mobil para obrigar ao cumprimento da restrição. A Suprema Corte de Massachusetts advertiu que o pleito da Shell estava de acordo com as críticas endereçadas ao precedente firmado em *Norcross*, mas se negou a revogá-lo ou a realizar o overruling sob os argumentos de que se deve dar peso à confiança no passado, especialmente quando se tem em jogo um precedente relativo à propriedade, e de que, no caso sob julgamento, assim como provavelmente em diversas outras

transações passadas, as partes devem ter depositado confiança em Norcross e em Shade.²⁷⁰

A questão voltou a ser discutida em 1974, em *Gulf Oil Corp. v. Fall River Housing Authority*, quando a Corte de Massachusetts livrou-se da força do precedente firmado em Norcross mediante uma distinção inconsistente (*drawing an inconsistent distinction*). A Corte distinguiu Norcross, Shade e Ouellette, fixando um pacto de não concorrência sob o fundamento de que a razão para o pacto, em *Gulf Oil*, fora o de assegurar o disciplinado e mutuamente vantajoso desenvolvimento da área em sua totalidade.²⁷¹

Em 1979, a Suprema Corte de Massachusetts mais uma vez tratou do assunto em *Whitinsville Plaza, Inc. v. Kotseas*, momento em que finalmente revogou o precedente firmado em Norcross. A Corte considerou a história do precedente, as reflexões da crítica acadêmica e a rejeição do precedente em vários outros Estados, apontando para distinções inadequadas que já estabelecera e confessando que a distinção formulada em *Gulf Oil* era insustentável. Mas observou que o *overruling* tinha sido adequadamente sinalizado em Ouellette e *Gulf Oil*, concluindo, diante disso, que o novo precedente deveria ter efeitos retroativos à data em que a sua revogação fora prevista em Ouellette. Disse a Corte: “Acreditamos que partes que, depois da data da decisão em Ouellette, estabeleceram pactos restritivos da espécie envolvida nesse caso poderiam racionalmente ter confiado na expectativa de que, na próxima ocasião adequada, essa Corte iria revogar as decisões tomadas em Shade e em Norcross. Acreditamos, além disso, que aqueles que fixaram tais pactos depois de Ouellette, não poderiam racionalmente ter a expectativa de que estes iriam continuar a ser inexigíveis com base nos precedentes de Shade e Norcross. Decidimos, portanto, que o *overruling* da regra formulada nas decisões de Shade e Norcross deve se aplicar a todos os pactos estabelecidos depois da decisão proferida em Ouellette”.²⁷²

Nesses casos, decididos pela Suprema Corte de Massachusetts, tinha-se consciência, desde Ouellette, que a decisão proferida em Norcross não estava de acordo com os princípios. A Corte se recusou a revogar Norcross em Ouellette e *Gulf Oil* e, nestes casos, também não fez um adequado *distinguishing*. Em Ouellette, a Corte simplesmente não julgou em favor daquele que pedia uma decisão em contrariedade a Norcross, alegando a confiança que ele gerara e que não apenas as partes do caso sob julgamento, como também aquelas envolvidas em diversas outras transações no passado teriam tido motivos racionais para agir de acordo com Norcross. Em *Gulf Oil*, a Corte solucionou o caso mediante a elaboração de uma distinção inconsistente.

No entanto, é importante deixar clara a razão pela qual a Corte se recusou a revogar Norcross, ainda que consciente do seu equívoco. Isso ocorreu, como já dito, em virtude de a Corte ter preservado a confiança depositada em Norcross, e não apenas a confiança da parte que litigava no caso em julgamento, como também a confiança de todos aqueles que teriam se comportado de acordo com o precedente. Frise-se que a Corte, em *Whitinsville Plaza, Inc. v. Kotseas*, afirmou que já havia sinalizado para a revogação de Norcross em Ouellette, e, com base nisso, outorgou efeitos retroativos ao *overruling*, declarando que deveriam ser apanhados todos os negócios realizados após Ouellette. Note-se: efeitos retroativos em relação às transações e não no que diz respeito às ações judiciais (que eventualmente poderiam estar em trânsito) fundadas em fatos anteriores a Ouellette.

Porém, se a técnica da sinalização tem o objetivo de tutelar a justificada confiança depositada no precedente, não há como deixar de ver a ligação desta técnica com a questão dos efeitos do *overruling*. Lembre-se que o *overruling* ditado em *Whitinsville Plaza* retroagiu até a decisão proferida em Ouellette porque a Corte entendeu que, a partir desta data, poder-se-ia racionalmente confiar na expectativa de que, na próxima ocasião adequada, a Corte iria revogar as decisões tomadas em Shade e em Norcross.

Se a postergação do *overruling* e, por consequência, o uso da sinalização objetivam tutelar as situações jurídicas que se formaram com base no precedente, é possível indagar se o mesmo não poderia ser obtido com um *overruling* dotado de efeitos plenamente prospectivos, que não atingisse as situações passadas e o próprio caso em julgamento. Ou seja, alguém poderia dizer que, se o desejo é evitar efeitos retroativos, basta dar efeitos plenamente prospectivos ao *overruling*, ou que não há motivo para se deixar de fazer o *overruling* quando basta modular os seus efeitos para

o futuro, sem sequer atingir o caso em discussão.²⁷³

Se a sinalização dá ciência aos advogados de que o precedente deverá ser revogado e, assim, não deve mais sustentar o comportamento dos jurisdicionados, o overruling anuncia de forma definitiva que ninguém mais deverá depositar confiança no precedente. Neste sentido, o overruling é mais eficaz que a sinalização. Assim, se o overruling não atinge o passado nem o caso sob julgamento, seria possível concluir que ele, além de mais eficaz – por não deixar “no ar” um precedente que, embora sem força, ainda não foi revogado – igualmente tutela a justificada confiança, já que não pega de surpresa aqueles que se pautaram no precedente revogado.

Ao se atribuírem efeitos plenamente prospectivos ao overruling são abrangidas apenas as situações que se formaram após esta decisão, com o que se pode resolver o problema que se objetiva eliminar com a própria sinalização. E, em certo sentido, de forma mais eficaz, já que se tem uma decisão revogatória “definitiva” e não apenas uma decisão que afirma que a revogação provavelmente ocorrerá ou está por vir.

No entanto, procurando-se um benefício adicional na técnica da sinalização, encontra-se a possibilidade de os efeitos do overruling serem modulados de acordo com o impacto da sinalização na realidade social. Melhor explicando: se, considerada a área em que o precedente incide, o impacto da sinalização foi retardado ou esmorecido ou não atingiu determinada faixa de negócios, os efeitos do overruling podem ser modulados de forma a não abarcar, de maneira absoluta, todas as situações posteriores à decisão em que se fez a sinalização.

Perceba-se que a técnica da sinalização tem a finalidade imediata de comunicar aos jurisdicionados e, sobretudo, aos advogados que o precedente está em vias de ser revogado. O que efetivamente assegura o passado são os efeitos atribuídos ao overruling, que não podem anteceder a decisão em que se fez a sinalização, mas que, em tese, podem ser postergados a esta data.

Nada impede, é certo, que se deem efeitos retroativos mais limitados ao overruling, fazendo-o incidir, por exemplo, apenas após determinada data posterior à sinalização. Acontece que, se os efeitos retroativos podem ser modulados, o mesmo ocorre com os efeitos prospectivos. Nada obsta que os efeitos do overruling tenham efeitos prospectivos apenas a partir de certa data ou evento futuro – posteriores à data em que se fez o overruling. Diante disso, novamente estariam equiparados os benefícios outorgados pela sinalização e pelo overruling com efeitos prospectivos.

Assim, torna-se visível que o real problema não está em saber se a sinalização e o overruling com efeitos prospectivos podem ser equiparados, mas sim em analisar, diante do caso concreto, quando um é mais adequado que outro. Em outros termos, não é possível comparar tais institutos em abstrato, cabendo verificar a maior idoneidade de um ou outro em face das circunstâncias que rodeiam a área sobre a qual o precedente incide.

Quando é difícil saber, diante das particularidades das relações que se basearam no precedente, se o imediato overruling com efeitos prospectivos é suficiente para garantir a justificada confiança, torna-se prudente apenas sinalizar para a revogação futura, dando aos advogados tempo para preparar os seus clientes no sentido de que não mais poderão se pautar no precedente. Afirmando-se, na sinalização, esta circunstância, os efeitos retroativos do futuro overruling não terão como deixar de considerá-la, restando limitados a um instante posterior àquele em que ocorreu a sinalização. Observe-se, porém, que neste caso os efeitos retroativos do overruling não têm o mesmo limite temporal (o da sinalização) daquele fixado em *Whitinsville*.

Importa frisar, por fim, que a decisão que adota a técnica da sinalização não revoga o precedente, embora reconheça o equívoco da sua *ratio decidendi*. Essa aparente contradição é desfeita pelos motivos que fazem a Corte ver que, em alguns casos, é melhor manter o precedente do que revogá-lo: quando a segurança jurídica e a previsibilidade justificam a manutenção do precedente até que os jurisdicionados tenham plena consciência de que não mais devem considerá-lo para pautar as suas atividades, é adequado sinalizar para a circunstância de que o precedente não tem mais autoridade e que, portanto, o overruling deverá ocorrer em breve.²⁷⁴

6.1.4. Prospective Overruling no Common Law. Em regra, a revogação de um precedente tem efeitos retroativos no common law em geral e nos Estados Unidos em particular. Como a revogação do precedente significa a admissão de que a tese nele enunciada – vigente até o momento da decisão revogadora – estava equivocada ou se tornou incompatível com os novos valores ou com o próprio direito, aceita-se naturalmente a ideia de que a decisão deve retroagir para apanhar as situações que lhe são anteriores, tenham dado origem ou não a litígios cujos processos devem estar em curso.

Ou seja, as decisões do common law são normalmente retroativas, no sentido de que a nova regra, estabelecida para o caso sob julgamento, é aplicável às situações que ocorreram antes da decisão que as fixou, bem como a todas aquelas que lhes são similares e, assim, estão expostas à mesma *ratio decidendi*.

Porém, a prática judicial estadunidense tem evidenciado em tempos recentes hipóteses em que é necessário impedir a retroatividade da nova regra firmada na decisão que revogou o precedente.²⁷⁵ Nessas situações, as Cortes mostram-se particularmente preocupadas em tutelar o princípio da segurança – especialmente nas suas feições de garante da previsibilidade e da confiança depositada pelos jurisdicionados nos atos do Poder Público.²⁷⁶

Eisenberg enfatiza que “the major justification for prospective overruling is the protection of justifiable reliance”.²⁷⁷ Há aí, antes de tudo, plena consciência de que a retroatividade de uma decisão que substitui precedente que, por certo período de tempo, pautou e orientou a conduta dos jurisdicionados é tão injusta quanto a perpetuação do precedente judicialmente declarado injusto. Mas, para que a não retroatividade se justifique, exige-se que a credibilidade do precedente não tenha sido abalada, de modo a não tornar previsível a sua revogação. Caso a doutrina e os tribunais já tenham advertido para o equívoco do precedente ou apontado para a sua conveniente ou provável revogação, não há confiança justificável, isto é, confiança capaz de fazer acreditar que os jurisdicionados tenham legitimamente traçado os seus comportamentos e atividades de acordo com o precedente. De modo que, para que o overruling não tenha efeitos retroativos, as situações e relações antes estabelecidas devem ter se fundado em uma confiança qualificada, que pode ser dita uma “confiança justificável”.

Há casos em que o precedente pode deixar de corresponder aos valores que o inspiraram ou se tornar inconsistente e, ainda assim, não se mostrar razoável que a sua revogação atinja situações passadas, em virtude de a confiança justificável, então caracterizada, sobrepor-se à ideia de fazer a revogação valer para trás. Não obstante, embora com a irretroatividade dos efeitos do overruling ou com o overruling com efeitos prospectivos se garanta o princípio da segurança e proteja-se a confiança nos atos do Poder Público, daí também podem advir custos ou prejuízos. O prospective overruling pode gerar resultados ou decisões inconsistentes, especialmente quando se está diante do overruling cujos efeitos apenas podem ser produzidos a partir de certa data ou do overruling cujos efeitos retroativos incidem apenas sobre determinado caso.²⁷⁸

Note-se que, na primeira hipótese, como o overruling tem efeitos somente a partir de certa data, as situações e relações que se formam depois da decisão são tratadas de modo diverso, conforme tenham se estabelecido antes ou depois da data prevista na decisão, ainda que essa tenha declarado a ilegitimidade do precedente. De outro lado, a admissão da retroatividade em relação a apenas um caso ou somente ao caso sob julgamento faz com que todos os outros casos passados sejam tratados à luz do precedente, embora se declare que esse não mais tem autoridade. Tais situações acabam acarretando o surgimento de resultados inconsistentes.

A primeira hipótese acima referida é exemplificada mediante *Spaniel v. Mounds View School District* n. 621, em que a Corte de Minnesota revogou o precedente que conferia imunidade às unidades municipais, como cidades e distritos estudantis, recusando-se a aplicar a nova regra ao caso sob julgamento e declarando que os seus efeitos deveriam ficar contidos até o final da próxima legislatura de Minnesota.²⁷⁹

A segunda hipótese é exemplificada através do caso *Molitor v. Kaneland Community*. Trata-se de caso em que a Corte de Illinois revogou o precedente da “imunidade municipal”,

responsabilizando o município pelos danos sofridos por Thomas Molitor em acidente de ônibus escolar. Nessa hipótese, decidiu-se que a nova regra não seria aplicada a casos anteriores, exceto o de Thomas – o caso sob julgamento. Contudo, mais tarde a Corte percebeu que teria de aplicar a nova regra a outras sete crianças – três delas irmãos de Thomas – que também estavam no ônibus que se acidentara, em virtude de ter reconhecido que todas as crianças que viajavam no ônibus deveriam ser tratadas de igual forma.²⁸⁰

Quando se posterga a produção de efeitos da nova regra, fala-se em prospective overruling. Ademais, como esclarece Eisenberg, alude-se a pure prospective overruling para demonstrar o que ocorre quando a Corte não aceita que a nova regra regule o próprio caso sob julgamento, restando a terminologia prospective overruling para anunciar a mera irretroatividade da nova regra às situações anteriores à data da decisão.²⁸¹

Há outras situações intermediárias. Assim, em *Li v. Yellow Cab Co.*, a Suprema Corte da Califórnia revogou o precedente da contributory negligence pela regra da comparative negligence, deixando claro que a nova regra não seria aplicável aos casos com julgamento em curso. Em *Whitinsville Plaza*, relacionou-se a técnica do overruling prospectivo com a técnica da sinalização.²⁸² Ou seja, decidiu-se que a nova regra teria efeitos retroativos até a data da decisão em que houvesse ocorrido a sinalização.²⁸³ Se mediante a técnica da sinalização, conquanto se deixe de revogar o precedente, adverte-se para a sua provável e próxima revogação, pouca diferença existiria em substituir tal técnica pela revogação imediata do precedente com efeitos prospectivos a partir de certa data futura. Portanto, quando se revoga o precedente, e sinalização anterior foi feita, é coerente admitir a retroatividade da nova regra até a data da decisão sinalizadora ou até data em que se supõe que o sinal foi absorvido na comunidade jurídica.

Há um caso, sublinhado por Eisenberg, em que o prospective overruling possui grande importância para a consistência de resultados. Trata-se da hipótese em que a Corte possui motivos para acreditar que o overruling será revertido pelo Legislativo, que dará melhor regulação à situação. Como a regra judicial criada com o overruling, a princípio, governa as relações que lhe são pretéritas, a menos que a decisão revogadora declare que os seus efeitos dirão respeito apenas ao futuro, nessa última hipótese o overruling poderá atingir as situações intermediárias entre o overruling e a regra legislativa ou ter os seus efeitos contidos até a data em que se presume que o Legislativo terá criado a regra. Ao se declarar que a revogação vai produzir efeitos após a possível criação legislativa da regra, os efeitos do overruling somente serão produzidos caso o Legislativo não atue. Foi o que aconteceu em *Massachusetts v. Whitney v. City of Worcester*, em que a Corte, utilizando a técnica da sinalização como substituto funcional do prospective overruling, afirmou a sua intenção de ab-rogar o precedente da imunidade municipal no primeiro caso por ela decidido após a conclusão daquela que seria a próxima sessão do Legislativo, caso este não houvesse atuado de modo a revogar o precedente.²⁸⁴

Nesse caso, é certo, não houve propriamente overruling com efeitos prospectivos, mas manutenção do precedente, mediante a técnica da sinalização, anunciando-se a intenção de se proceder à revogação em caso de não atuação do Legislativo. Note-se, porém, que existe maior efetividade em revogar desde logo o precedente, contendo-se os seus efeitos, pois nesta hipótese não haverá sequer como temer que o precedente continue a produzir efeitos, diante de uma eventual inação da Corte em imediatamente decidir como prometera ao fazer a sinalização.

De outra parte, o prospective overruling pode ainda trazer outros problemas, especialmente em suas feições de pure prospective overruling e de prospective overruling.²⁸⁵ Se a nova regra não vale ao caso sob julgamento, a energia despendida pela parte não lhe traz qualquer vantagem concreta, ou melhor, não lhe outorga o benefício almejado por todo litigante que busca a tutela jurisdicional. Isso quer dizer que o uso do prospective overruling pode desestimular a propositura de ações judiciais contra determinados precedentes.²⁸⁶

Ademais, o uso indiscriminado do pure prospective overruling e do prospective overruling elimina a necessidade de os advogados analisarem como os precedentes estão sendo vistos pela doutrina e de que forma os tribunais vêm tratando de pontos correlatos com aqueles definidos na

ratio decidendi do precedente. Quando se atribui efeito prospectivo à nova regra, impedindo-se a sua incidência em relação ao caso sob julgamento, resta eliminada qualquer possibilidade de a parte ser surpreendida pela decisão judicial, ainda que o precedente já tenha sido desautorizado pela doutrina e por decisões que, embora obviamente não tenham enfrentado de forma direta a questão resolvida no precedente, afirmam soluções com ele inconsistentes. Desse modo, a investigação e análise do advogado não seriam sequer necessárias, já que ao jurisdicionado bastaria a mera existência do precedente, pouco importando o grau da sua autoridade ou força e, assim, a possibilidade ou a probabilidade da sua revogação. Assim, o uso inadequado do prospective overruling, de um lado, torna desnecessária a análise de se a tutela da segurança jurídica e da confiança fundamenta a não retroatividade dos efeitos do overruling e, de outro, constitui obstáculo ao desenvolvimento do direito. Na verdade, dessa forma o direito deixaria de ser visto como algo em permanente construção, negando-se o fundamento que deve estar à base de uma teoria dos precedentes.

Deixe-se claro, por fim, que a doutrina de common law frisa que, em regra, a revogação deve ter efeitos retroativos. Apenas excepcionalmente, em especial quando há confiança justificada no precedente, é que se admite dar efeitos prospectivos ao overruling. E isso sem se enfatizar que as Cortes não devem supor razão para a tutela da confiança sem consideração meticulosa, analisando se a questão enfrentada é uma daquelas em que os jurisdicionados costumam se pautar nos precedentes, assim como se os tribunais já sinalizaram para a revogação do precedente ou se a doutrina já demonstrou a sua fragilidade.²⁸⁷

6.2. Superação no Direito Brasileiro. A Alteração da Tese Jurídica. Para se referir ao instituto designado no Common Law como overruling o legislador brasileiro fala ora em “superação do entendimento” (art. 489, § 1.º, inciso VI), ora em “alteração de tese jurídica” (art. 927, § 2.º), ora em “alteração de jurisprudência dominante” (art. 927, § 3.º), ora finalmente em “modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada” (art. 927, § 4.º). Os termos empregados pelo legislador suscitam desde logo algumas observações.

O mais apropriado seria falar em superação do precedente ou da jurisprudência vinculante – ou mais sinteticamente superação das razões. Vale dizer: superação das razões que determinaram a interpretação da questão constitucional ou da questão federal de um dado caso à luz de um determinado contexto. Não se trata apenas de superação de uma “tese”, embora também disso se trate: o que se supera são as razões que levaram à adoção de uma tese a partir de um dado caso devidamente delimitado na sua unidade fático-jurídica.

Além disso, também a ordem com que a matéria foi disciplinada no art. 927, CPC, merece igualmente uma observação: o ideal seria que o atual § 4.º figurasse como § 2.º, o atual § 2.º como § 3.º e o atual § 3.º como § 4.º. Isso porque parece mais adequado primeiro falar das condições para a superação em geral (o que hoje está no § 4.º), recomendando na sequência eventuais audiências públicas e participações de pessoas aptas a colaborar para demonstração da necessidade de superação (o que hoje está no § 2.º) e aí sim falar nas condições da superação para a frente (o que hoje está no § 3.º). Em outras palavras, é preciso primeiro saber se é o caso de superação, firmando-se um convencimento a respeito quiçá com amplo debate social, para somente depois indagar-se a respeito dos efeitos com que essa superação deve ocorrer.

6.2.1. Requisitos para a Superação. As Cortes Supremas – isto é, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho – têm o dever de promover a unidade da ordem jurídica (art. 926, CPC). O dever de promoção da unidade da ordem jurídica envolve velar pelos vínculos de hierarquia e de coerência entre as fontes em um processo interpretativo pautado pela racionalidade e pela universalização de seus resultados (comentários ao art. 926, item 8). Trata-se de dever que tem de ser desempenhado sem descuidar da necessidade de prover um adequado nível de segurança jurídica capaz de promover os princípios da liberdade e da igualdade (art. 927, § 4.º, CPC).

É exatamente dentro desse quadro normativo que devem ser buscados os requisitos que autorizam a superação dos precedentes. Nessa perspectiva, os precedentes no direito brasileiro podem ser superados quando se verificam determinados requisitos materiais e processuais.

Do ponto de vista material, a superação do precedente está autorizada quando os princípios da segurança, da liberdade e da igualdade (arts. 926 e 927, § 4.º, CPC) – que dão sustentação à regra do *stare decisis* – deixam de autorizar a replicabilidade do precedente, além da sua solução ter perdido sua coerência (conceito talvez mais apropriado diante do art. 926, CPC, do que aquele de consistência sistêmica trabalhado por Eisenberg), enfraquecendo a unidade da ordem jurídica, e a sua congruência social (art. 927, § 2.º, CPC). Do ponto de vista processual, a demonstração da perda de sustentação do precedente, de sua coerência e de sua congruência social demanda contraditório e fundamentação adequada e específica (art. 927, §§ 1.º e 4.º, CPC).

O dever de promover um estado de coisas seguro – ou, como prefere o legislador, o dever de estabilidade – das Cortes Supremas tem uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. Na sua dimensão positiva, exige-se a adoção de determinadas medidas que tornem a alteração o mais suave possível. Na sua dimensão negativa, veda-se a alteração arbitrária do precedente.

No seu aspecto positivo, exige-se que o precedente tenha sido desgastado por sinalizações de que a Corte irá alterar o seu entendimento. Essas sinalizações devem ser veiculadas a título de *obiter dictum*, constante da justificação das decisões. Em outras palavras, a Corte deve informar à comunidade jurídica que pretende rever o seu posicionamento a respeito de determinada questão. Com isso, a alteração do precedente torna-se mais previsível e o sistema jurídico mais estável.

No seu aspecto negativo, veda-se a alteração por determinados motivos que jogam contra a estabilidade do sistema jurídico como um todo. Assim, não é qualquer razão que se presta a justificar a superação de um precedente. A simples alteração de um membro do órgão julgador, por exemplo, não autoriza a superação de um precedente. O mesmo vale para a simples mudança de opinião a respeito de dada questão jurídica por um determinado julgador ou mesmo pelo colegiado.

O dever de promover a unidade do direito das Cortes Supremas implica dever de velar pela hierarquia, coerência e universalização na ordem jurídica. Daí que se determinado precedente deixa de promover a unidade do direito por ausência de adequada hierarquização das fontes ou por ausência de coerência, cessa o dever de replicabilidade, o que deve ser reconhecido pelas Cortes a fim de que se forme um novo precedente sobre o tema.

A hierarquia tem por objeto as relações resultantes da estrutura escalonada da ordem jurídica, funcionando a partir de uma sistematização linear (“a norma superior constitui o fundamento da norma inferior”), simples (“baseada numa relação de hierarquia linear entre as normas”) e não gradual (“as normas estão, ou não, sistematizadas enquanto hierarquicamente postas”).²⁸⁸ Se é verificada uma quebra de hierarquia, o sistema vê enfraquecida a sua unidade e está autorizada a superação que denota semelhante violação.

A coerência exige que a interpretação judicial possa ser capaz de ser reconduzida a “um conjunto, internamente consistente, formal e materialmente, de princípios e regras” amalgamadas por “princípios fundamentais” comuns.²⁸⁹ Pode ser obtida a partir de uma sistematização circular (“as normas superiores condicionam as inferiores, e as inferiores contribuem para determinar os elementos das superiores”), complexa (“não há apenas uma relação vertical de hierarquia, mas várias relações horizontais, verticais e entrelaçadas entre as normas”) e gradual (“a sistematização será tanto mais perfeita quanto maior for a intensidade da observância dos seus vários critérios”).²⁹⁰

Ainda, a coerência é uma conexão de sentidos que se estabelece entre as normas que pode ser formal ou substancial. A coerência formal existe quando há uma relação normativa consistente (em que inexiste contradição) e completa (em que há inteireza e coesão). A ausência de quaisquer desses elementos leva à ausência de coerência. A coerência substancial existe quanto maior for a dependência recíproca e afinidade entre as normas. Ao contrário do aspecto formal da coerência, o seu aspecto substancial permite graduação. Vale dizer: enquanto a coerência formal existe ou não, a coerência material pode existir em maior ou menor medida.²⁹¹

Se é verificada uma quebra de coerência formal, autoriza-se a superação do precedente.

Enfraquecida a coerência substancial, a sua maior ou menor graduação determinará o grau de autorização para a alteração do entendimento.

O desgaste da unidade da ordem jurídica por força de determinado precedente pode ser verificado a partir da crítica da comunidade jurídica, notadamente a partir de trabalhos doutrinários e da própria crítica judicial ao precedente – exposta em decisões que, apesar de aplicarem o precedente, criticam-no como contendo uma solução inadequada para o caso. Além disso, tanto as audiências públicas como a participação de pessoas, órgãos ou entidades podem ter por objeto a aferição da coerência do precedente (art. 927, § 2.º, CPC). Vale dizer: a contribuição para a rediscussão da tese abarca a capacidade de contribuição para a aferição da coerência do precedente.

Ademais, o dever de promover a unidade da ordem jurídica implica dever de aferir a congruência social dos precedentes – não fosse assim seria dispensável a participação social na discussão referente à revogação do precedente (art. 927, § 2.º, CPC). E também aqui o esquema proposto pela doutrina estadunidense pode colaborar para a compreensão dos precedentes no nosso direito.

Lembre-se que Eisenberg refere que a congruência social de um precedente pode ser aferida a partir da sua referibilidade a proposições morais, políticas e técnicas encontradas no seio social.²⁹² O que há de comum em todas essas proposições é a sua ancoragem social. Nada obstante, enquanto as proposições morais e políticas exigem uma configuração social geral (ou, pelo menos, majoritária, respeitado em todos os casos o regime jurídico diferenciado dos direitos fundamentais), as proposições técnicas dependem apenas de uma configuração social particular, isto é, restrita à opinião de especialistas na matéria debatida – isso porque o seu objeto é justamente a experiência técnico-científica. Essa é razão pela qual é altamente recomendável que a alteração de precedente ou jurisprudência vinculante seja efetivamente precedida de um amplo diálogo com a sociedade civil (art. 927, § 2.º, CPC). A participação social que visa a colaborar no debate a respeito do precedente pode ocorrer mediante audiências públicas e/ou por escrito de pessoas, órgãos ou entidades. O juízo pode acolher o pedido de manifestação do interessado ou exortá-la mediante comunicação para intervenção.

O desgaste do precedente – pela perda de sustentação e de unidade (coerência e congruência) – deve ser objeto de contraditório adequado e específico. Pela simetria entre esses dois direitos fundamentais, segue-se à necessidade de contraditório adequado e específico, a imprescindibilidade de fundamentação adequada e específica (arts. 9.º, 10, 11, 489, § 1.º, inciso VI, e 927, §§ 1.º e 4.º, CPC).

Isso quer dizer que, do ponto de vista processual, deve haver indicação judicial prévia a respeito da possibilidade de alteração do precedente. Em outras palavras, o órgão judicial tem o dever de viabilizar o contraditório das partes a respeito dos argumentos que serão futuramente utilizados no debate ligado à superação. Além disso, deve estar necessária, expressa e especificamente justificada na decisão, a dupla perda que autoriza a revogação do precedente: ausência de suporte e de unidade, sendo imprescindível que eventual perda de hierarquia, coerência ou congruência que caracterizam a perda de unidade, sejam detalhadamente expostas na fundamentação. Fora daí, há violação do dever de debate adequado e específico imposto pelos arts. 927, §§ 1.º e 4.º, CPC.

6.2.2. Superação para Frente. Modulação dos Efeitos. O direito brasileiro reconheceu textualmente a possibilidade de superação apenas para frente do precedente, referindo que “pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica” (art. 927, § 3.º, CPC). Trata-se de debate que não é novo entre nós – o qual, porém, era equivocadamente assimilado àquele referente à modulação dos efeitos no controle de constitucionalidade (art. 27, Lei 9.868, de 1999).²⁹³ Aliás, a terminologia empregada pelo legislador – “modulação de efeitos” – e a alusão a “interesse social” como requisito para superação, deixam transparecer essa indevida ligação. A fim de que se possa adotar uma chave de leitura apropriada, cumpre examinar o tema à luz de alguns casos examinados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em primeiro lugar, é necessário distinguir a necessidade de modulação de efeitos no controle de constitucionalidade (art. 27, Lei 9.868, de 1999) da necessidade de outorgar efeitos prospectivos aos precedentes em geral (art. 927, § 3.º, CPC).

O Supremo Tribunal Federal, na ADIn 2.240, em que se questionou a inconstitucionalidade da lei que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães, ao deparar-se com o problema da eficácia da decisão de inconstitucionalidade, chegou a uma solução muito interessante a quem está interessado na questão relativa à proteção da segurança jurídica mediante a técnica dos efeitos prospectivos.²⁹⁴

Nesse caso, a Corte não tinha qualquer dúvida sobre a inconstitucionalidade da lei, mas temia que, ao pronunciá-la, pudesse irremediavelmente atingir todas as situações que se formaram após a sua edição. Receava-se que a declaração de inconstitucionalidade não pudesse permitir a preservação das situações estabelecidas antes da decisão de inconstitucionalidade.

Não é preciso dizer que, no caso, partia-se da teoria da nulidade do ato inconstitucional, de modo que a preservação do que aconteceu após a edição da lei inconstitucional, teria de ter sustentáculo em algo que pudesse se contrapor ao princípio da nulidade.

Esclareça-se que o relator, inicialmente, embora reconhecendo a inconstitucionalidade, julgou improcedente a ação. E isso para preservar as situações consolidadas, em nome do princípio da segurança jurídica.²⁹⁵ Após o voto do relator, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. Em seu voto, contudo, argumentou que não seria razoável deixar de julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade para não se atingir o passado, advertindo que a preservação das situações anteriores poderia se dar ainda que a ação fosse julgada procedente, com a declaração da inconstitucionalidade da norma.

Consta do voto do Ministro Gilmar: “Impressionou-me a conclusão a que chegou o Ministro Eros Grau – votou pela improcedência da ação – após tecer percuciente análise sobre a realidade fática fundada na lei impugnada e o peso que possui, no caso, o princípio da segurança jurídica. De fato, há toda uma situação consolidada que não pode ser ignorada pelo Tribunal. Com o surgimento, no plano das normas, de uma nova entidade federativa, emergiu, no plano dos fatos, uma gama de situações decorrentes da prática de atos próprios do exercício da autonomia municipal. A realidade concreta que se vincula à lei estadual impugnada já foi objeto de extensa descrição analítica no voto proferido pelo Ministro relator, e não pretendo aqui retomá-la. Creio que o Tribunal já se encontra plenamente inteirado das graves repercussões de ordem política, econômica e social de uma eventual decisão de inconstitucionalidade”.²⁹⁶

Após ter deixado claro que o Ministro relator esteve preocupado em proteger as situações consolidadas, argumentou o Ministro Gilmar que a solução do problema “não pode advir da simples decisão de improcedência da ação. Seria como se o Tribunal, focando toda sua atenção na necessidade de se assegurar realidades concretas que não podem mais serem desfeitas e, portanto, reconhecendo plena aplicabilidade ao princípio da segurança jurídica, deixasse de contemplar, na devida medida, o princípio da nulidade da lei inconstitucional”.²⁹⁷ Depois disso, advertiu que, embora não se possa negar a relevância do princípio da segurança jurídica no caso, é possível primar pela otimização de ambos os princípios – ou seja, dos princípios da segurança jurídica e da nulidade da lei inconstitucional – “tentando aplicá-los, na maior medida possível, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas que o caso concreto pode nos apresentar”.²⁹⁸

Mais tarde, sublinhou que “a falta de um instituto que permita estabelecer limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, acaba por obrigar os Tribunais, muitas vezes, a se abster de emitir um juízo de censura, declarando a constitucionalidade de leis manifestamente inconstitucionais”.²⁹⁹ E que o “perigo de uma tal atitude desmesurada de self restraint (ou greater restraint) pelas Cortes Constitucionais ocorre justamente nos casos em que, como o presente, a nulidade da lei inconstitucional pode causar uma verdadeira catástrofe – para utilizar a expressão de Otto Bachof – do ponto de vista político, econômico e social”.³⁰⁰ Diante disso, consignou o Ministro Gilmar: “Não há dúvida, portanto – e todos os Ministros que aqui se encontram parecem ter plena consciência disso – de que o Tribunal deve adotar uma fórmula que, reconhecendo a

inconstitucionalidade da lei impugnada – diante da vasta e consolidada jurisprudência sobre o tema – resguarde na maior medida possível os efeitos por ela produzidos”.³⁰¹

Nessa linha, o Ministro Gilmar Mendes, que acabou sendo acompanhado pelos demais Ministros – inclusive pelo Ministro relator, que retificou o seu voto – com exceção do Ministro Marco Aurélio – que, embora julgando procedente a ação de inconstitucionalidade, pronunciava a nulidade da lei³⁰² – votou no “sentido de, aplicando o art. 27 da Lei 9.868/1999, declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade da lei impugnada, mantendo sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lapso temporal razoável dentro do qual poderá o legislador estadual reapreciar o tema, tendo como base os parâmetros que deverão ser fixados na lei complementar federal, conforme decisão desta Corte na ADIn 3.682”.³⁰³

Note-se que se afirmou estar sendo declarada a inconstitucionalidade, mas sem a pronúncia da nulidade da lei impugnada, mantendo-se sua vigência pelo prazo de vinte e quatro meses.³⁰⁴ O método utilizado, embora similar, não se confunde com a técnica do prospective overruling, empregada no direito estadunidense.³⁰⁵

A similaridade decorre do fato de se ter mantido a vigência da lei pelo prazo de vinte e quatro meses, o que aproximaria essa decisão daquela cujos efeitos operam somente a partir de determinada data no futuro. Nessa perspectiva, não há dúvida que ambas as decisões protegem a segurança jurídica.

Porém, a técnica do prospective overruling tem a ver com a revogação de precedentes e não com a declaração de inconstitucionalidade. É isso precisamente que baralha a situação. Quando nada indica provável revogação de um precedente e, assim, os jurisdicionados nele depositam confiança justificada para pautar suas condutas, entende-se que, em nome da segurança jurídica, notadamente na sua face relacionada à proteção da confiança, é possível revogar o precedente com efeitos puramente prospectivos (a partir do trânsito em julgado) ou mesmo com efeitos prospectivos a partir de certa data ou evento. Isso ocorre para que as situações que se formaram com base no precedente não sejam atingidas pela nova regra. Porém, na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn do município de Luis Eduardo Magalhães, não há falar em proteção da confiança fundada nos precedentes, até porque a Corte deixou bem claro que os seus próprios precedentes eram no sentido da inconstitucionalidade. Aliás, caso se tivesse pensado nos efeitos dos fundamentos determinantes das decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos similares, estar-se-ia muito longe de se poder imaginar uma decisão que não fosse de inconstitucionalidade. Daí a necessidade de se distinguir o art. 27, Lei 9.868, de 1999, do art. 927, § 3.º, CPC de 2015.

Quando não se outorga efeito retroativo à decisão de inconstitucionalidade, objetiva-se preservar as situações que se consolidaram com base na lei inconstitucional. É somente nessa situação, como é óbvio, que entra em jogo a teoria da nulidade dos atos inconstitucionais e passa a ser possível questionar, por consequência, a relação entre os princípios da nulidade da lei inconstitucional e da segurança jurídica. Em outras palavras, quando se atribuem efeitos prospectivos, a decisão que não é de inconstitucionalidade, importa apenas saber se há confiança justificada no precedente.

Lembre-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos de suas decisões também em sede de controle difuso.³⁰⁶ Nessa dimensão, é possível perceber com maior facilidade a distinção entre atribuir efeitos prospectivos à decisão que, em tese, pode fulminar a lei e a decisão que simplesmente pode revogar um precedente.

Não há dúvida que as decisões proferidas em recurso extraordinário produzem eficácia vinculante em relação aos seus motivos determinantes, assim como as decisões prolatadas em controle concentrado produzem coisa julgada erga omnes (art. 927, CPC). Como é óbvio, para se admitir a eficácia vinculante no controle difuso, não é preciso argumentar que a eficácia vinculante é viável no controle concentrado. Da mesma forma, a circunstância de ser possível atribuir efeito prospectivo à decisão de procedência na ação direta de inconstitucionalidade nada tem a ver com a viabilidade de se atribuírem efeitos prospectivos à decisão proferida em sede de

recurso extraordinário. Ou melhor, a modulação dos efeitos das decisões proferidas em recurso extraordinário não é consequência lógica da possibilidade de se atribuírem efeitos prospectivos às decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade.

Atribuir eficácia vinculante aos fundamentos determinantes da decisão é o mesmo que conferir autoridade aos fundamentos da decisão em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Esses ficam vinculados ou obrigados em face dos fundamentos da decisão, ou seja, diante da *ratio decidendi* do precedente. De modo que a técnica da obrigatoriedade do respeito aos fundamentos determinantes é utilizada para atribuir força ou autoridade aos precedentes judiciais – e não, obviamente, para simplesmente reafirmar a teoria da nulidade do ato inconstitucional.

Da mesma forma, a modulação dos efeitos das decisões proferidas em recurso extraordinário não é tributária da possibilidade de se modular os efeitos das decisões de inconstitucionalidade no controle concentrado. Ou seja, o poder de modular os efeitos das decisões em sede de controle difuso, deriva exclusivamente do princípio da segurança jurídica, notadamente da sua face ligada à proteção da confiança justificada, e não da necessidade de harmonizar a aplicação dos princípios da nulidade do ato inconstitucional e da segurança jurídica.

A declaração de inconstitucionalidade, proferida em recurso extraordinário, embora possa ter eficácia vinculante, obrigando os demais órgãos do Poder Judiciário, não elimina a norma do ordenamento jurídico, que resta, por assim dizer, em estado latente. É certamente possível que a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade de determinada norma, um dia seja contrariada pelas mesmas razões que autorizam a revogação de precedente constitucional ou dão ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de declarar inconstitucional, norma que já afirmou constitucional. Trata-se do mesmo “processo” em que, nos Estados Unidos, a Suprema Corte “ressuscita” a lei que era vista como *dead law*, tendo em conta já ter sido declarada inconstitucional.

Na verdade, em sede de controle difuso o Supremo Tribunal Federal sempre tem a possibilidade de – a partir de critérios rígidos – negar os fundamentos determinantes das suas decisões, sejam elas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Porém, como a revogação de um precedente institui nova regra, a ser observada pelos demais órgãos judiciais, é pouco mais do que evidente a possibilidade de se violentarem a segurança jurídica e daí a confiança depositada no próprio tribunal. Quando não há indicações de que o precedente será revogado e, assim, há confiança justificada, não há razão para tomar de surpresa o jurisdicionado, sendo o caso de atribuir efeitos prospectivos à decisão, seja ela de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade.

Embora a viabilidade de outorgar efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade, esteja expressa no art. 27 da Lei 9.868, de 1999, é indiscutível que essa possibilidade advém do princípio da segurança jurídica, o que significa que, ainda que se entendesse que tal norma se aplica apenas ao controle concentrado, não haveria como negar a possibilidade de se modular os efeitos da decisão proferida em recurso extraordinário.³⁰⁷ Essa é a razão pela qual, acertadamente, o art. 927, § 3.º, CPC, faz referência ao princípio da segurança jurídica como fundamento para a outorga de efeitos prospectivos aos precedentes.

Frise-se, porém, que a necessidade de modulação em controle difuso decorre da preocupação em não atingir as situações que se formaram com base no precedente e não da imprescindibilidade em proteger as situações que se consolidaram com base na lei inconstitucional. Contudo, no Brasil, até o Código de 2015, a técnica dos efeitos prospectivos foi pensada a partir da teoria da nulidade dos atos inconstitucionais. Vale dizer, para tutelar a segurança jurídica, mas em virtude do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Daí não se ter percebido, com maior nitidez, a imprescindibilidade da adoção dessa técnica em sede de controle difuso.

O mais importante, entretanto, é que certamente não se pensa em confiança justificada para se dar efeitos prospectivos na hipótese de decisão de inconstitucionalidade. Só há razão para investigar se a confiança é justificada em se tratando de revogação de precedente. É apenas aí que

importa verificar se havia, na academia e nos tribunais, manifestações que evidenciavam o enfraquecimento do precedente ou apontavam para a probabilidade da sua revogação, a eliminar a confiança justificada. De modo que, nesta situação, tutela-se o passado em nome da confiança que se depositou nas decisões judiciais, enquanto, no caso de decisão de inconstitucionalidade, tutelam-se excepcionalmente as situações que se formaram na vigência da lei declarada inconstitucional. Em verdade, os fundamentos para se dar efeitos prospectivos, em cada um dos casos, são diferentes. Os fundamentos bastantes para se dar efeitos prospectivos, na hipótese de revogação de precedente, estão longe das “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”, aptas a justificar efeitos prospectivos em caso de decisão de inconstitucionalidade.

Em segundo lugar, é preciso perceber como se estabeleceu o debate nas Cortes Supremas sobre a necessidade de outorga de efeitos prospectivos à alteração de precedentes antes da entrada em vigor do Código de 2015. A indevida assimilação do tema àquele da modulação dos efeitos e a ausência de percepção da sua estatura constitucional, ligada ao princípio da segurança jurídica, levaram a equívocos na sua compreensão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de enfrentar um caso cujo debate é emblemático. Nos autos dos EDiv no REsp 738.689, julgados pela 1.^a Seção,³⁰⁸ discutiu-se a possibilidade de aplicação do art. 27 da Lei 9.868, de 1999, para superação apenas para frente do precedente.

Buscava-se, na ação que deu origem ao recurso especial e aos embargos de divergência, o reconhecimento do direito ao aproveitamento do crédito-prêmio do IPI, instituído pelo art. 1.^o do Decreto-Lei 491, de 1969. Ao enfrentar o recurso especial, a Turma reafirmou a improcedência do pedido, daí tendo sido interpostos embargos de divergência à 1.^a Seção. Durante o julgamento dos embargos de divergência – que restaram improvidos – o Ministro Hermann Benjamin pediu vista e propôs a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868, de 1999.

Frise-se que, até agosto de 2004, o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça era pela subsistência do benefício. Inicialmente, observou o Ministro Hermann que, ao tentar se familiarizar com os debates sobre a vigência do crédito-prêmio – dos quais não participou, pois ocorridos antes do seu ingresso na Corte – chamou a sua atenção “a profunda mudança de orientação jurisprudencial sobre o tema, fato que é insistentemente repisado pelos contribuintes, no contexto da segurança jurídica”.³⁰⁹

Alegou que, “em face da jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça até agosto de 2004, persistiu em favor dos contribuintes uma certa ‘sombra de juridicidade’”.³¹⁰ Assim, para proteger a segurança jurídica e em especial a confiança, entendeu o Ministro Hermann Benjamin que seria o caso de se proceder à modulação dos efeitos da decisão, limitando-se a sua retroatividade. Para fundamentar a sua proposta, fez as seguintes ponderações: “Tenho para mim que, também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, as decisões que alterem jurisprudência reiterada, abalando forte e inesperadamente expectativas dos jurisdicionados, devem ter sopesados os limites de seus efeitos no tempo, buscando a integridade do sistema e a valorização da segurança jurídica. É que o reconhecimento da ‘sombra de juridicidade’, decorrente da atividade jurisdicional do Estado, revela indiscutível a necessidade de resguardarem-se os atos praticados pelos contribuintes sob a expectativa de que aquela era a melhor interpretação do Direito, já que consubstanciada em uma jurisprudência reiterada, em sentido favorável às suas pretensões, pela Corte que tem a competência constitucional para dar a última palavra no assunto. Essa necessidade de privilegiar-se a segurança jurídica e, por consequência, os atos praticados pelos contribuintes sob a ‘sombra de juridicidade’ exige do Superior Tribunal de Justiça o manejo do termo a quo dos efeitos de seu novo entendimento jurisprudencial. Repito que não se trata de, simplesmente, aplicar-se as normas veiculadas pelas Leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999, por analogia, mas sim de adotar como válidos e inafastáveis os pressupostos valorativos e principiológicos que fundamentam essas normas e que, independentemente da produção legislativa ordinária, haveriam de ser observados tanto pelo E. Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso dos Vereadores [em que o Supremo Tribunal Federal limitou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade], parece evidente que eventual

inexistência de lei federal prevendo expressamente a modulação temporal dos efeitos da decisão judicial não impediria o E. Supremo Tribunal Federal de sopesar os efeitos de seu acórdão, por conta do imperativo da segurança jurídica. Da mesma forma, a inexistência de norma ordinária expressa que regule o assunto, não tem o condão de impedir os Tribunais Superiores de adequarem sua atividade, ou o produto da ação jurisdicional, aos ditames da segurança jurídica. “O E. Supremo Tribunal Federal adota esse entendimento, ao modular temporalmente os efeitos de suas decisões, mesmo em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, não abarcado expressamente pelo regime das Leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999”.³¹¹

Após sustentar a possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça modular os efeitos das suas decisões, para o que – na sua argumentação – não seria sequer preciso norma infraconstitucional, o Ministro Hermann Benjamin passou a traçar critérios para justificar a limitação dos efeitos da nova regra do Superior Tribunal de Justiça. Ao observar a necessidade de se preservar a segurança jurídica, refletida na expectativa dos jurisdicionados quanto à aplicação, aos seus próprios casos, do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, advertiu o Ministro que “esse entendimento exige sejam fixados a) o limite temporal a partir do qual se afasta a ‘sombra de juridicidade’ e b) os tipos de atos e negócios jurídicos realizados pelos contribuintes que devem ser resguardados da mudança jurisprudencial. O limite temporal é de fácil visualização. A ‘sombra de juridicidade’ – e, a partir daí, também a necessidade de modulação temporal da eficácia da decisão – deixa de existir quando do julgamento, pela 1.^a Turma, do REsp 591.708/RS, em 08.06.2004, acórdão relatado pelo e. Ministro Teori Zavascki e publicado no DJ de 09.08.2004 (conforme registrado pelo E. Min. João Otávio de Noronha em seu voto-vista no REsp 541.239/DF). Até esse momento, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, dando a interpretação última à legislação federal, era pela subsistência do benefício, nos termos de detalhado registro efetuado pelo E. Min. José Delgado, por ocasião de seu voto-vencido no REsp 591.708/RS. Fixo, portanto, a data de publicação desse acórdão (REsp 591.708/RS) em 09.08.2004, como o momento em que se exaure a ‘sombra de juridicidade’ que garantiria a subsistência do benefício, não cabendo, a partir de então, falar-se em expectativa, boa-fé ou confiança legítima dos contribuintes. É essa data (09.08.2004) que serve como marco inicial para a irradiação dos efeitos da novel jurisprudência desta Corte, no sentido da extinção do crédito-prêmio do IPI, seja em 1983, seja em 1990. Quanto aos atos e negócios jurídicos praticados pelos contribuintes, a serem resguardados da mudança jurisprudencial, há que se ter em mente o objetivo da modulação temporal dos efeitos da decisão judicial, qual seja privilegiar a segurança jurídica, refletida na expectativa dos contribuintes na manutenção do entendimento que, até então, lhes era favorável. Pois bem, em face da incontestável e incansável resistência do fisco ao aproveitamento do “crédito-prêmio”, restava aos interessados o caminho do Judiciário. Por isso, não se descuida que, dados os efeitos inter partes dos precedentes desta Corte, os contribuintes haveriam de buscar provimento jurisdicional a garantir-lhes o direito que, em sua visão, era certo. Consequentemente, somente cabe falar em expectativa ao provimento judicial favorável, por óbvio, em favor daqueles que se socorreram da via pretoriana. Na seara contábil, essa busca do provimento judicial é exigência do princípio do conservadorismo. Havendo resistência do Fisco ao aproveitamento de um direito pela empresa, há que se buscar um provimento administrativo ou judicial para legitimar a escrituração. A propósito, registro o Alerta ao Mercado, exarado pela Comissão de Valores Mobiliários em 30.03.2005, que, de maneira ainda mais severa e referindo-se a atos normativos e pareceres anteriores, veda expressamente a contabilização do direito ao ‘crédito-prêmio’ pelas companhias abertas antes de eventual trânsito em julgado da sentença favorável. Entendo, portanto, que a expectativa a ser protegida contra a mudança jurisprudencial refere-se exclusivamente àquelas empresas que buscaram provimento judicial e efetivamente aproveitaram o ‘crédito-prêmio’ até 09.08.2004. As pretensões de empresas não deduzidas em juízo não podem ser resguardadas. A estas, não socorre o argumento da expectativa de provimento judicial favorável e, portanto, o imperativo da segurança jurídica que me leva a decidir pela modulação temporal dos efeitos da decisão. Os contribuintes que demandaram judicialmente, e somente eles, tinham a expectativa de um provimento judicial favorável. Utilizaram-se do ‘crédito-prêmio’ num momento em que o Superior Tribunal de Justiça mantinha um posicionamento sólido a seu favor. Este aproveitamento do benefício implicou redução dos custos e preços praticados por essas empresas, em valor correspondente ao montante do IPI mitigado, levando-as a orientar seus planos e atividades com base nessa realidade. São estes atos dos contribuintes, de apropriação e aproveitamento do ‘crédito-prêmio’ antes da guinada

jurisprudencial, que se aperfeiçoaram sob a ‘sombra de juridicidade’ e, agora, merecem ser preservados. Afasta-se também, portanto, a hipótese de empresas que, apesar de demandarem judicialmente, não realizaram, por qualquer razão, o efetivo aproveitamento do ‘crédito-prêmio’ até 09.08.2004. Não tiveram elas reduzidos seus custos, nem deixaram, por consequência, de repassar o ônus tributário integral (sem a dedução do crédito-prêmio) aos seus clientes. Com relação a esses contribuintes, não há ofensa relevante à segurança jurídica que justifique a modulação temporal dos efeitos da decisão. Tampouco aproveita a mitigação dos efeitos da decisão declaratória a outros que não o titular original do ‘crédito-prêmio’, já que a ‘sombra de juridicidade’ refere-se ao entendimento pacificado por esta Corte, que não abrange a possibilidade de aproveitamento, por terceiros, do benefício fiscal. Sem dúvida, a controvérsia acerca da possibilidade desse aproveitamento por terceiros e a interpretação a ser dada à legislação federal que trata do assunto nunca gozaram, neste Tribunal, da pacificação jurisprudencial advinda de profundo debate e reiterados precedentes. Não há, em favor desses cessionários do crédito-prêmio, ‘sombra de juridicidade’ a socorrer-lhes. Numa palavra, a modulação temporal dos efeitos da decisão favorece somente os créditos aproveitados pelos titulares originários do benefício. Diante de todo o exposto, posiciono-me pela extinção do crédito-prêmio em 1983 e, superada esta tese, pelo término do benefício em 1990, nos termos do art. 41, § 1.º, do ADCT, acompanhando o E. relator, Ministro Teori Albino Zavascki, para negar provimento aos embargos de divergência, resguardando, dos efeitos desta decisão, eventual aproveitamento do crédito-prêmio pelo titular originário, desde que realizado até 09.08.2004”.³¹²

Em voto-vista, o Ministro Teori Albino Zavascki se opôs à proposta do Ministro Hermann Benjamin, argumentando “que a modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal, quando autorizada, é apenas a que diz respeito a normas declaradas inconstitucionais e limita-se aos efeitos de natureza exclusivamente temporal. Aqui, ao contrário, pretende-se modular os efeitos de decisões judiciais, não sobre a inconstitucionalidade de norma, mas sobre a sua revogação, e não apenas em seus aspectos temporais (= eficácia prospectiva às normas revogadas), mas também em seus aspectos subjetivos (= para beneficiar alguns contribuintes, não todos) e em seus aspectos materiais (= para abranger apenas alguns atos e negócios, e não todos)”.³¹³

A maioria dos membros da 1.ª Seção aderiu à posição do Ministro Teori, tendo restado consignado na ementa do acórdão o seguinte: “Salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 27 da Lei 9.868/1999, é incabível ao Judiciário, sob pena de usurpação da atividade legislativa, promover a ‘modulação temporal’ das suas decisões, para o efeito de dar eficácia prospectiva a preceitos normativos reconhecidamente revogados”.³¹⁴

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento referido, perdeu grande oportunidade para adotar técnica imprescindível a um Tribunal incumbido de dar unidade ao direito federal. Pouco importa que o art. 27 da Lei 9.868, de 1999 faça referência expressa apenas às decisões de inconstitucionalidade. Isso porque, como já observado, a limitação dos efeitos retroativos das decisões não é mera decorrência da necessidade de compatibilizar a segurança jurídica com a teoria da nulidade da lei inconstitucional. Trata-se, ao contrário, de algo imprescindível para não se surpreender aqueles que depositaram confiança justificada nos precedentes judiciais. Os atos, alicerçados em precedentes dotados de autoridade em determinado momento histórico – e, assim, irradiadores de confiança justificada – não podem ser desconsiderados pela decisão que revoga o precedente, sob pena de violação à segurança jurídica e à confiança nos atos do Poder Público. Ou seja, a modulação dos efeitos ou a limitação dos efeitos retroativos das decisões, certamente não pode servir apenas às decisões de inconstitucionalidade. Na verdade, a limitação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade é apenas um dos aspectos que se insere na questão mais ampla relativa à tutela da segurança diante das decisões judiciais.

Aliás, mesmo que o art. 27 da Lei 9.868, de 1999, não existisse, o Supremo Tribunal Federal poderia e deveria limitar, quando necessário, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, bastando argumentar com base na Constituição Federal. Uma norma, afirmando a possibilidade da limitação dos efeitos retroativos das decisões revogadoras de precedentes – ou, caso se queira em outros termos, de jurisprudência consolidada e pacífica – no Superior Tribunal de Justiça, jamais poderia ser vista como resultado de “livre opção” do legislador infraconstitucional. Essa norma é

imprescindível para o legislador cumprir com o seu dever de tutela da confiança justificada nos atos do Poder Público. O que significa dizer que a inexistência de normas dessa ordem àquele tempo configurava “falta de lei”, com o que autorizava a sua colmatação no caso concreto pelo Poder Judiciário diante dos casos concretos. Como o Judiciário não pode prestar adequada tutela jurisdicional sem limitar os efeitos da decisão que revoga precedente – deixa de lado jurisprudência pacífica ou, o que é o mesmo, inaugura nova compreensão de dada situação jurídica – não há como subordinar a sua decisão, de limitação dos efeitos retroativos, à existência de lei. Na realidade, a possibilidade de limitar os efeitos retroativos das decisões é inerente ao exercício do poder de julgar conferido às Cortes Supremas.³¹⁵

De outro lado, excetuar alguns atos e sujeitos dos efeitos retroativos de uma decisão, não significa dar efeitos prospectivos à lei revogada, ainda que tal decisão tenha reconhecido que, na época da prática dos atos, a lei não deveria produzir efeitos. Ora, se, no momento em que os atos foram praticados, o Poder Judiciário afirmava que a lei estava em vigor, inegavelmente existia “norma jurídica” para orientar os jurisdicionados. Se essa norma é revogada por norma posteriormente emanada do próprio Poder Judiciário, a nova norma não pode retroagir para apanhar as situações que se consolidaram à época em que era justificada a confiança na norma judicial revogada. De modo que, limitar os efeitos de decisão, para preservar atos praticados com base em lei declarada revogada, não é usurpar o poder do legislador, mas proteger a confiança justificada no Poder Judiciário. Trata-se, em verdade, de um ato de autotutela do próprio Judiciário.

Também não é correto supor que, para a proteção da confiança, basta apenas limitar os efeitos retroativos da decisão, sem dissociar os atos que foram e não foram praticados com base em confiança justificada. Portanto, pouco importa que a lei tenha se referido apenas à limitação dos efeitos retroativos, sem dizer que os atos praticados no passado podem ser diferenciados: é da essência da limitação de efeitos em nome da proteção da confiança, a discriminação de atos que não foram praticados com base em confiança justificada e que, assim, não devem ser ressalvados dos efeitos retroativos da decisão.

Frise-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir posteriormente pela irretroatividade de decisão revogadora de precedente. Há caso exemplar que pode ser lembrado a respeito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 83.255/SP, alterou a regra judicial a respeito do prazo recursal para o Ministério Público, que desde então passou a ser contado a partir da data da entrada do processo nas dependências da instituição. O Superior Tribunal de Justiça acompanhou a nova orientação do Supremo Tribunal Federal.

Naturalmente, porém, surgiu o problema relacionado com os recursos que haviam sido interpostos à época em que prevalecia o entendimento anterior. Nos recursos especiais que se basearam na alteração do entendimento acerca da contagem do prazo recursal, o Superior Tribunal de Justiça preservou a tempestividade dos recursos que se fundaram na regra judicial – ou no entendimento jurisprudencial – que ainda prevalecia quando da interposição, não admitindo a retroatividade do novo entendimento para descaracterizar a tempestividade recursal. Veja-se, neste sentido, julgado da 5.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça: “Habeas corpus – Processual penal – Tempestividade do recurso ministerial – Mudança do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores – Aplicação aos casos futuros. 1. De fato, o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento plenário do HC 83.255/SP (Informativo 328), decidiu que o prazo recursal para o Ministério Público conta-se a partir da entrada do processo nas dependências da Instituição. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, aderiu à nova orientação da Suprema Corte. 2. Não se pode olvidar, todavia, que o entendimento jurisprudencial, até então, há muito sedimentado no STF e no STJ, era justamente no sentido inverso, ou seja, entendia-se que a intimação pessoal do Ministério Público se dava com o ‘ciente’ lançado nos autos, quando efetivamente entregues ao órgão ministerial. 3. Dessa maneira, constata-se que o Procurador de Justiça, nos idos anos de 2000, tendo em conta a então sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores, valendo-se dela, interpôs o recurso dentro do prazo legal. 4. Não se poderia, agora, exigir que o órgão ministerial recorrente se pautasse de modo diverso, como se pudesse antever a mudança do entendimento jurisprudencial. Essa exigência seria inaceitável, na medida em que se estaria criando obstáculo insuperável. Vale dizer: depois de a parte ter realizado o ato processual,

segundo a orientação pretoriana prevalente à época, seria apenada com o não conhecimento do recurso, quando não mais pudesse reagir à mudança. Isso se traduziria, simplesmente, em usurpação sumária do direito de recorrer, o que não pode existir em um Estado Democrático de Direito, mormente se a parte recorrente representa e defende o interesse público. 5. Ordem denegada”.³¹⁶

Essa decisão merece um único reparo. Pouco importa se a parte recorrente representa e defende o interesse público. Não é possível retroagir entendimento novo para o efeito de prejudicar quem quer que tenha praticado ato em confiança em precedente ou em jurisprudência pacífica.

A sua importância, entretanto, transcende esse ponto, pois demonstra que um Tribunal cuja missão é a de atribuir unidade ao direito federal deve estar consciente de que a revogação de um precedente – ou de um entendimento jurisprudencial – tem significado muito mais amplo ao de uma simples decisão judicial.³¹⁷ Em outras palavras: a decisão judicial de uma Corte Suprema – como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho – apresenta razões que servem não tanto para a solução do caso concreto, mas mais agudamente para a outorga de significado ao direito. Daí que a revogação de precedente, ao alterar o entendimento da Corte a respeito da interpretação da lei federal, tem grande impacto sobre as situações levadas a efeito sob o império do precedente revogado.

Delimitado esse contexto em que o tema aparece no direito brasileiro, é possível traçar algumas diretrizes para a adequada interpretação do art. 927, § 3.º, CPC. Em primeiro lugar, o dispositivo parece querer limitar o seu campo de aplicação apenas aos casos em que há “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”. Em segundo lugar, refere que é possível a superação para frente do precedente “no interesse social e no da segurança jurídica”.

Quanto à primeira questão, é preciso perceber que em qualquer alteração de precedente das Cortes Supremas – independentemente do modo com que foi formado, isto é, independentemente de observado o procedimento dos recursos repetitivos – pode haver superação apenas para frente. Sendo o precedente digno de confiança, a alteração do seu conteúdo exige apenas superação para frente.

Quanto à segunda questão, importa desde logo ter presente que a alteração do precedente nada tem a ver com a tutela do “interesse social” – que aí só pode ser entendido como interesse de que a confiança depositada pela sociedade no precedente seja preservada e como interesse social de afirmação da igualdade de todos perante o Direito. O que realmente interessa para a superação para frente do precedente é a tutela da confiança legítima da parte que atuou com base no precedente – o que o legislador chama no art. 927, § 3.º, CPC, de tutela da “segurança jurídica” – e a necessidade de preservação da igualdade de todos perante o Direito em um dado momento histórico.

Assim, a proteção da confiança legítima diante da superação do precedente – e, portanto, a sua alteração apenas com eficácia prospectiva – demanda a ocorrência de alteração retroativa e surpreendente do precedente. Isso quer dizer que a superação do precedente com eficácia prospectiva requer a existência de precedente, sua alteração com vocação retroativa e a existência de confiança legítima no conteúdo do precedente.³¹⁸ Esses são os requisitos que autorizam a aplicação do art. 927, § 3.º, CPC.

Em primeiro lugar, a alteração do precedente pressupõe a existência de duas soluções jurídicas diacronicamente distintas para o mesmo caso. É preciso que as soluções tenham o mesmo objeto e sejam contrárias entre si. Não é necessário que a decisão de que oriundo o primeiro precedente tenha transitado em julgado para inspirar confiança.³¹⁹ O que determina a capacidade de orientação do precedente é a publicação da decisão a partir do qual pode ser retirado. A partir daí a decisão é eficaz, isto é, mostra-se capaz de produzir efeitos. Submeter a eficácia do precedente à formação da coisa julgada é confundir um instituto que pertence ao discurso voltado à tutela dos direitos em uma dimensão geral (o precedente) com um instituto que concerne ao discurso voltado

à tutela do direito em uma dimensão particular (a coisa julgada), além de confundir a eficácia da decisão, aí incluída aquela que é oriunda da simples publicação das suas razões, com a qualidade da coisa julgada.

Em segundo lugar, a alteração do precedente deve ter vocação retroativa, isto é, o novo precedente tem de ter a pretensão de regular casos para os quais se aplicava o precedente anterior. Isso porque é justamente para evitar a aplicação de uma norma inexistente e, portanto, desconhecida no momento da conduta de determinada pessoa que a superação prospectiva do precedente encontra justificação. Como observa a doutrina, “o problema da retroatividade envolve, por definição, a inexistência e o desconhecimento da norma no momento da ação. Justamente porque a norma não existia no momento da ação, o indivíduo não tinha como se orientar por aquela, e, portanto, não tinha como determinar sua linha de ação levando em consideração o seu conteúdo. A liberdade é exercida sem a eficácia da norma modificadora, porém é valorada, posteriormente, por ela”.³²⁰

Em terceiro lugar, a alteração do precedente tem de ser surpreendente, isto é, capaz de frustrar a confiança legitimamente nele depositada. Daí que para configuração da alteração surpreendente pressupõe a existência de confiança no precedente. A confiança legítima no precedente tem de ser protegida diante da sua superação quando há base de confiança, exercício da confiança e sua frustração. A base de confiança concerne à existência efetiva de uma decisão da qual se possa retirar um precedente constitucional ou um precedente federal. Isso quer dizer que é preciso, conforme o caso, um pronunciamento apropriado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão controvertida. Na aferição da maior ou menor aptidão do precedente para gerar uma base idônea de confiança, tem-se que levar em consideração a maior ou menor densidade das normas aplicadas para resolução da questão e a maior ou menor abertura semântica dos textos empregados pelo legislador. Quanto menor a densidade normativa (por exemplo, princípio), maior a confiança na sua concretização judicial. Quanto maior a abertura semântica (por exemplo, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados), maior a confiança na sua concretização judicial. Ainda no que tange à configuração da base de confiança, não é necessário para sua configuração prova do conhecimento concreto do precedente. Como inexistente norma sem interpretação, então o precedente judicial conta com a mesma ficção que existe a propósito do conhecimento da lei – todos o conhecem, já que ninguém pode se escusar de observar o Direito alegando o seu desconhecimento. O exercício da confiança existe quando há a prática de atos concretos em razão do precedente superado. Quanto mais dispendiosos, duradouros e de difícil reversão os atos praticados, maior a proteção que deve ser dispensada. Há frustração da confiança, finalmente, quando a aplicação do novo precedente é capaz de causar um resultado diverso e mais gravoso do que aquele esperado de acordo com o precedente superado.

Nesses casos, em que configurada a alteração retroativa e surpreendente do precedente, a estabilidade e a confiabilidade da ordem jurídica dependem da outorga de eficácia prospectiva à mudança do precedente, protegendo-se a parte contra a sua superação inesperada, bem como todas aquelas pessoas que se encontram em situação idêntica ou semelhante e que, até o momento da sua publicação, tenham atuado judicialmente para defesa de seus direitos com base no precedente superado. Em sendo o caso, podem essas Cortes inclusive marcarem um termo futuro a partir do qual o precedente começará a entornar a sua eficácia. Atuando dessa forma, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça confluem na vocação das Cortes Supremas para atuação proativa e com atenção para o futuro, salvaguardando-se a confiança no passado sem que essa seja capaz de impedir, contudo, o adequado desenvolvimento do Direito.

6.2.3. O Despropósito da Tese da Retroatividade do Precedente sobre a Coisa Julgada. Ao lado da proteção subjetiva proporcionada pela confiança legítima diante da alteração do precedente mediante o instituto da superação para frente (art. 927, § 3.º, CPC), nossa ordem constitucional igualmente protege objetivamente a segurança jurídica por força do instituto da coisa julgada diante da alteração de precedentes (art. 5.º, inciso XXXVI, CF). Vale dizer: impede a retroatividade de precedentes sobre a coisa julgada.³²¹

O debate a respeito do tema não é recente e é muito significativo.

Como o direito é duplamente indeterminado, os Tribunais podem ter diferentes posicionamentos a respeito da mesma questão jurídica até que se forme um determinado precedente em uma Corte Suprema. Nessa situação, todas as situações jurídicas consolidadas – vale dizer, todas as decisões sobre as quais eventualmente se formou a coisa julgada – até a formação do precedente são regidas pela coisa julgada. O precedente formado valerá para o caso julgado e para os casos futuros. Não valerá para outros casos anteriores já transitados em julgado. Nessa situação, a decisão do caso tem efeito *ex tunc*, mas o precedente tem apenas efeito *ex nunc*. Para resguardar eventuais coisas julgadas que se formaram no período em que o precedente estava sendo formado aplica-se a Súmula 343, STF.

Isso quer dizer que no que tange ao momento de formação de um determinado precedente, pode ocorrer que existam sincronicamente múltiplas interpretações judiciais nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais sobre o significado de determinado enunciado constitucional ou legal. Pode inclusive ocorrer de conviver no mesmo momento interpretações judiciais diferentes dentro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sem que os órgãos responsáveis pela uniformização da interpretação dentro de cada uma dessas cortes (o Plenário do Supremo Tribunal Federal ou a Corte Especial ou as Seções do Superior Tribunal de Justiça) tenham apreciado a questão adequadamente. Qualquer uma dessas interpretações pode inclusive transitar em julgado, adquirindo cada qual a proteção inerente à coisa julgada (artigo 5.º, inciso XXXVI, CF).

Uma solução orientada por uma perspectiva teórica que separa texto e norma e que pressupõe a potencial equivocidade dos enunciados legais, prestigia no momento de desacordo interpretativo que marca naturalmente o período de formação do precedente a segurança jurídica pela consolidação das situações individuais. Vale dizer: protege as interpretações jurisdicionais possíveis e, portanto, igualmente legítimas consolidadas no momento anterior à formação do precedente. É que, em um quadro teórico que rejeita univocidade normativa do texto e uma função puramente declaratório-descritiva da jurisdição, não é possível pressupor que a norma sempre existiu e que, dessa forma, a consolidação da interpretação judicial vencedora no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça deve ser imposta a todos os casos indistintamente. O precedente deve ser obviamente aplicado para o futuro – e todas as decisões transitadas em julgado em momento posterior à sua existência que o violam devem ser reformadas ou rescindidas pelas vias adequadas. Não deve, contudo, ser aplicado de forma retroativa, cuja aplicação pressupõe equivocadamente a existência de um sentido intrínseco e unívoco da legislação e acarreta evidente violação à segurança jurídica.

Duas razões, portanto, devem ser consideradas para solução do problema. A primeira delas é que semelhante solução nega o caráter polissêmico da linguagem jurídica e daí a autonomia da jurisdição na sua interpretação e aplicação. A segunda é que semelhante solução nega força à coisa julgada, fazendo a sua proteção depender sempre de um evento futuro e incerto: a confirmação do seu conteúdo por um precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Daí que em um momento de instabilidade da ordem jurídica em termos gerais, pela ausência de precedente que delimite com maior precisão o significado dos enunciados legislativos e o contexto fático-jurídico em que aplicável, deve-se prestigiar a segurança jurídica em termos individuais, cuja proteção é garantida pela coisa julgada. Trata-se de proteção objetiva, que depende tão somente da formação da coisa julgada em momento anterior à pacificação da interpretação judicial pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.³²² A igualdade realiza-se aí pelo tratamento isonômico deferido a todos que se encontram na mesma situação: aqueles que contam com a proteção da coisa julgada, têm suas esferas jurídicas protegidas contra o precedente superveniente; aqueles que não contam com a proteção da coisa julgada, ficam sujeitos à força do precedente.

Durante muito tempo o Supremo Tribunal Federal orientou-se corretamente nesse sentido, na medida em que prestigiava o entendimento segundo o qual “não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (Súmula 343, STF).³²³ O Superior Tribunal de Justiça igualmente observava semelhante orientação nos seus julgados.³²⁴ A orientação, todavia, foi

paulatinamente superada pelo Supremo Tribunal Federal, que chegou a deixar de aplicá-la em matéria constitucional.³²⁵ Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender igualmente que a Súmula 343, STF, não se aplicava em matéria constitucional³²⁶ e, na sequência, chegou igualmente a deixar de aplicá-la em matéria infraconstitucional federal.³²⁷ Hoje, porém, o Supremo Tribunal Federal inclina-se pela aplicação da Súmula 343, STF, em matéria constitucional,³²⁸ bem como o Superior Tribunal de Justiça em matéria constitucional e infraconstitucional.³²⁹

No julgamento do RE 89.108/GO, o Supremo Tribunal Federal deixou de aplicar, pela primeira vez, a Súmula 343, STF. Em suma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Súmula 343 não se aplica em matéria constitucional, tendo em conta que o seu conteúdo se refere exclusivamente à interpretação da legislação ordinária e que a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei tem eficácia *ex tunc*.

No voto do Ministro Soares Muñoz consta que “na espécie, o texto legal controvertido não é de lei ordinária, mas da própria Constituição. Entendo, por isso, que não é aplicável a Súmula 343. A inconstitucionalidade é o maior vício que uma lei pode conter. O efeito da declaração de inconstitucionalidade é *ex tunc*”.³³⁰ Na mesma linha, o voto do Ministro Moreira Alves refere que “não há que invocar-se, no caso, o disposto na Súmula 343 (‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’), uma vez que ela deflui de julgados que dizem respeito, apenas, a lei ordinárias. E, por se tratar de súmula, está ela vinculada ao âmbito dos julgados de que é síntese, não podendo – como poderia se se tratasse de preceito legal – extravasar dele, por via de interpretação extensiva. Aliás, ainda quando fosse isso possível, não me animaria a essa extensão, pois entendo que a Súmula 343 nada mais é do que a repercussão, na esfera da ação rescisória, da Súmula 400 – que não se aplica a texto constitucional – no âmbito do recurso extraordinário. Como se infere do art. 119, III, ‘a’ da Emenda Constitucional 1/69, o correspondente, no plano constitucional, à negativa de vigência de lei é a contrariedade à Constituição; e, em assim sendo, se a legislação ordinária (no caso, o Código de Processo Civil) se limita a aludir como pressuposto da rescisória a violação literal de disposição de lei, impõe-se que se distinga a lei ordinária (para a qual é necessária a negativa de vigência) e a lei constitucional (para a qual basta a contrariedade)”.³³¹ Por fim, na mesma linha, consta do voto do Ministro Thompson Flores que a Súmula 343, STF, “não tem aplicação, como não tem o verbete 400, quando se trata de fazer aplicação de texto constitucional”.³³²

Embora não conste expressamente do acórdão do RE 89.108/GO, uma razão de suma importância para compreensão da solução dada ao problema da não aplicação da Súmula 343 em matéria constitucional pelo Supremo Tribunal Federal consta do julgamento do RE 81.429/SP, em que o Ministro Moreira Alves afirma que “em se tratando de dispositivo constitucional, é cabível o recurso extraordinário para examinar, se correto, ou não, a interpretação que as instâncias ordinárias lhe deram. Não fora assim, e deixaria o Supremo Tribunal Federal de ser o sumo intérprete da Constituição, e, conseqüentemente, o guardião de sua observância”.³³³ Vale dizer: segundo o Supremo Tribunal Federal, a interpretação da Constituição não pode ser simplesmente razoável, mas deve ser correta.

Seguindo o mesmo entendimento, no julgamento do RE 101.114/SP, o Supremo Tribunal Federal deixou igualmente de aplicar a Súmula 343. Consta do voto do Ministro Rafael Mayer que “descabe invocar-se a Súmula 343 em obséquio às divergências de entendimento ocorrentes na instância estadual. O verbete, na verdade, se reporta à interpretação controvertida da lei, e a matéria aqui é constitucional que, pela supremacia jurídica, não pode ficar sujeita à perplexidade, não se aplicando, portanto, a máxima jurisprudencial”.³³⁴ O Supremo Tribunal Federal entendeu, pois, que a “supremacia” da Constituição impede a aplicação da Súmula 343 em matéria constitucional.

Na mesma esteira, no julgamento do Agravo Regimental no RE 235.794/SC, o Supremo Tribunal Federal tornou ainda mais clara a razão pela qual deixou de aplicar a Súmula 343 em matéria constitucional. Consta do voto do Ministro Gilmar Mendes que “se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação do

texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, em decorrência do efeito definitivo absoluto outorgado à sua decisão. Não se pode diminuir a eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal, com a manutenção de decisões divergentes. Assim, se somente por meio do controle difuso de constitucionalidade, portanto, anos após as questões terem sido decididas pelos Tribunais inferiores, é que o Supremo Tribunal Federal veio a apreciá-la, é a ação rescisória, com fundamento em violação de literal disposição de lei, instrumento adequado para a superação de decisão divergente. Contrariamente, a manutenção de soluções divergentes, em instâncias inferiores, sobre o mesmo tema, provocaria, além da desconsideração do próprio conteúdo da decisão desta Corte, última intérprete do texto constitucional, a fragilização da força normativa da Constituição”.³³⁵ E para arrematar: “a aplicação da Súmula 343 em matéria constitucional revela-se afrontosa não só à força normativa da Constituição, mas também ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Admitir a aplicação da orientação contida no aludido verbete em matéria de interpretação constitucional significa fortalecer as decisões das instâncias ordinárias em detrimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Tal prática afigura-se tanto mais grave se se considerar que no nosso sistema geral de controle de constitucionalidade a voz do STF somente será ouvida após anos de tramitação das questões em duas instâncias. Privilegiar a interpretação controvertida, para a manutenção de julgado desenvolvido contra a orientação desta Corte, significa afrontar a efetividade da Constituição”.³³⁶ Em suma, como consta bem retratado na ementa do julgado, o Supremo Tribunal Federal entendeu nessa oportunidade que a não aplicação da Súmula 343 em matéria constitucional deve-se ao fato de que “a manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação constitucional revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional”.³³⁷

No julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 687.903/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal e deixou de aplicar a Súmula 343, STF, em matéria constitucional. Consta do voto do Ministro Ari Pargendler que “a compreensão de que o nosso direito positivo assegura tutela qualificada ao texto constitucional, seja quanto à abrangência, seja quanto ao rigor dessa tutela, exige do juiz que atribua à Constituição o máximo de efetividade. A tutela da Constituição é abrangente. O Supremo Tribunal Federal julga, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição (CF, art. 102, III, a). Já o Superior Tribunal de Justiça só julga, em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. Quer dizer, julgamento contrário à Constituição sempre pode ser atacado perante o Supremo Tribunal Federal, enquanto julgamento contrário à lei só pode ser contrastado no Superior Tribunal de Justiça quando realizado no âmbito de um tribunal. A tutela da Constituição é rigorosa. A lei pode ter mais de uma interpretação, bastando que seja razoável (CPC, art. 485, V, que só autoriza a ação rescisória se literal a violação da lei). Mas o recurso extraordinário não é tolhido pelo óbice da interpretação razoável, se estiver em causa norma constitucional. ‘Em se tratando de dispositivo constitucional’ – disse o Min. Moreira Alves no julgamento do RE 81.429, SP – ‘é cabível o recurso extraordinário para examinar, se correta, ou não, a interpretação que as instâncias ordinárias lhe deram. Não fora assim, e deixaria o Supremo Tribunal Federal de ser o sumo intérprete da Constituição, e, conseqüentemente, o guardião de sua observância’ (RTJ 89, p. 878). E, no RE n. 89.108, GO, tratando da ação rescisória de julgado proferido ao arrepio da Constituição, o mesmo Ministro afirmou: ‘entendo que a Súmula 343, nada mais é do que a repercussão, na esfera da ação rescisória, da Súmula 400 – que não se aplica a texto constitucional – no âmbito do recurso extraordinário’ (RTJ 101, p. 214). Há razões para esse tratamento especial. Um juízo acerca da conformidade, ou não, da lei com a Constituição é um juízo sobre a validade da lei; uma decisão contra a lei ou que lhe negue vigência supõe lei válida. A lei pode ter uma ou mais interpretações, mas ela não pode ser válida e inválida, dependendo de quem seja o encarregado de aplicá-la. Por isso, se a lei é conforme à Constituição e o acórdão deixa de aplicá-la à guisa de inconstitucionalidade, o julgado se sujeita à ação rescisória ainda que na época os tribunais divergissem a respeito, e vice-versa”.³³⁸

A decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça seguiu orientação oriunda da 1.^a

Seção constante nos autos dos Embargos de Divergência no REsp n. 608.122/RJ, que igualmente acolheu o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. A ementa do julgado é claríssima e reflete rigorosamente o conteúdo do julgado. Consta da ementa redigida pelo Ministro Teori Zavascki: “1. Na interpretação do art. 485, V, do Código de Processo Civil, que prevê a rescisão de sentença que ‘violar literal disposição de lei’, a jurisprudência do STJ e do STF sempre foi no sentido de que não é toda e qualquer violação à lei que pode comprometer a coisa julgada, dando ensejo à ação rescisória, mas apenas aquela especialmente qualificada. 2. Na esteira desse entendimento, editou-se a Súmula 343/STF, segundo a qual ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 3. Ocorre, porém, que a lei constitucional não é uma lei qualquer, mas a lei fundamental do sistema, na qual todas as demais assentam suas bases de validade e de legitimidade, e cuja guarda é a missão primeira do órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). 4. Por essa razão, a jurisprudência do STF emprega tratamento diferenciado à violação da lei comum em relação à da norma constitucional, deixando de aplicar, relativamente a esta, o enunciado de sua Súmula 343, à consideração de que, em matéria constitucional, não há que se cogitar de interpretação apenas razoável, mas sim de interpretação juridicamente correta. 5. Essa, portanto, a orientação a ser seguida nos casos de ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC: em se tratando de norma infraconstitucional, não se considera existente ‘violação a literal disposição de lei’, e, portanto, não se admite ação rescisória, quando ‘a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’ (Súmula 343). Todavia, esse enunciado não se aplica quando se trata de ‘texto’ constitucional. 6. A orientação revela duas preocupações fundamentais da Corte Suprema: a primeira, a de preservar, em qualquer circunstância, a supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme a todos os destinatários; a segunda, a de preservar a sua autoridade de guardião da Constituição. Esses os valores dos quais deve se lançar mão para solucionar problemas atinentes à rescisão de julgados em matéria constitucional. 7. Assim sendo, concorre decisivamente para um tratamento diferenciado do que seja ‘literal violação’ a existência de precedente do STF, guardião da Constituição. Ele é que justifica, nas ações rescisórias, a substituição do parâmetro negativo da Súmula 343 por um parâmetro positivo, segundo o qual há violação à Constituição na sentença que, em matéria constitucional, é contrária a pronunciamento do STF”.³³⁹

No julgamento do REsp 1.026.234/DF, a 1.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Súmula 343, STF, não deve mais ser aplicada inclusive no que toca à interpretação da legislação infraconstitucional federal. O julgado, igualmente relatado pelo Ministro Teori Zavascki, conta com ementa muito esclarecedora e que retrata muito fielmente as razões constantes do acórdão: “1. A Súmula 343/STF, editada antes da Constituição de 1988, tem origem na doutrina (largamente adotada à época, inspiradora também da Súmula 400/STF) da legitimidade da interpretação razoável da norma, ainda que não a melhor, permitindo assim que a respeito de um mesmo preceito normativo possa existir mais de uma interpretação e, portanto, mais de um modo de aplicação. 2. Ao criar o STJ e lhe dar a função essencial de guardião e intérprete oficial da legislação federal, a Constituição impôs ao Tribunal o dever de manter a integridade do sistema normativo, a uniformidade de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação. O exercício dessa função se mostra particularmente necessário quando a norma federal enseja divergência interpretativa. Mesmo que sejam razoáveis as interpretações divergentes atribuídas por outros tribunais, cumpre ao STJ intervir no sentido de dirimir a divergência, fazendo prevalecer a sua própria interpretação. Admitir interpretação razoável, mas contrária à sua própria, significaria, por parte do Tribunal, renúncia à condição de intérprete institucional da lei federal e de guardião da sua observância. 3. Por outro lado, a força normativa do princípio constitucional da isonomia impõe ao Judiciário, e ao STJ particularmente, o dever de dar tratamento jurisdicional igual para situações iguais. Embora possa não atingir a dimensão da gravidade que teria se decorresse da aplicação anti-isonômica da norma constitucional, é certo que o descaso à isonomia em face da lei federal não deixa de ser um fenômeno também muito grave e igualmente ofensivo à Constituição. Os efeitos da ofensa ao princípio da igualdade se manifestam de modo especialmente nocivos em sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado: considerada a eficácia prospectiva inerente a essas sentenças, em lugar da igualdade, é a desigualdade que, em casos tais, assume caráter de estabilidade e de continuidade, criando situações discriminatórias permanentes, absolutamente

intoleráveis inclusive sob o aspecto social e econômico. Ora, a Súmula 343 e a doutrina da tolerância da interpretação razoável nela consagrada têm como resultado necessário a convivência simultânea de duas (ou até mais) interpretações diferentes para o mesmo preceito normativo e, portanto, a cristalização de tratamento diferente para situações iguais. Ela impõe que o Judiciário abra mão, em nome do princípio da segurança, do princípio constitucional da isonomia, bem como que o STJ, em nome daquele princípio, também abra mão de sua função nomofilática e uniformizadora e permita que, objetivamente, fique comprometido o princípio constitucional da igualdade. 4. É relevante considerar também que a doutrina da tolerância da interpretação razoável, mas contrária à orientação do STJ, está na contramão do movimento evolutivo do direito brasileiro, que caminha no sentido de realçar cada vez mais a força vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores. 5. Por todas essas razões e a exemplo do que ocorreu no STF em matéria constitucional, justifica-se a mudança de orientação em relação à súmula 343/STF, para o efeito de considerar como ofensiva a literal disposição de lei federal, em ação rescisória, qualquer interpretação contrária à que lhe atribui o STJ, seu intérprete institucional. A existência de interpretações divergentes da norma federal, antes de inibir a intervenção do STJ (como recomenda a súmula), deve, na verdade, ser o móvel propulsor para o exercício do seu papel de uniformização. Se a divergência interpretativa é no âmbito de tribunais locais, não pode o STJ se furtar à oportunidade, propiciada pela ação rescisória, de dirimi-la, dando à norma a interpretação adequada e firmando o precedente a ser observado; se a divergência for no âmbito do próprio STJ, a ação rescisória será o oportuno instrumento para uniformização interna; e se a divergência for entre tribunal local e o STJ, o afastamento da Súmula 343 será a via para fazer prevalecer a interpretação assentada nos precedentes da Corte Superior, reafirmando, desse modo, a sua função constitucional de guardião da lei federal”.³⁴⁰

É absolutamente certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são os intérpretes institucionais da Constituição e da legislação infraconstitucional federal e que os seus precedentes devem ser observados por todo o Poder Judiciário, sem o que a igualdade de todos perante a ordem jurídica prometida pela Constituição não passa de uma afirmação fantasiosa. É igualmente preciso ter presente, contudo, que não é possível seguir um precedente inexistente. Nenhuma corte pode violar uma orientação que ainda não existe. É uma questão lógica. É claro que, existindo precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, qualquer decisão posterior contrária transitada em julgado pode e deve ser rescindida mediante ação rescisória (art. 966, inciso V, CPC) ou declarada inexecutável mediante impugnação (arts. 525, inciso III, §§ 12 a 14, e 535, inciso III, §§ 5.º a 7.º, CPC).

A mesma solução não se aplica, porém, aos casos em que inexistente precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e a coisa julgada forma-se no sentido contrário àquele que posteriormente será acolhido pelo precedente constitucional ou federal. Nessa linha, é preciso ter desde logo presente que os arts. 525, inciso III, § 15, e 535, inciso III, § 8.º, CPC, são flagrantemente inconstitucionais por ofenderem o núcleo duro do direito fundamental à segurança jurídica e à igualdade.

Precisamente nesse ponto duas questões devem ser lembradas: a primeira, de que existe um lapso temporal destinado à formação do precedente em que duas ou mais soluções para o mesmo problema jurídico são inevitáveis, tendo em conta a indeterminação da linguagem jurídica. Como os enunciados constitucionais e legais – e nesse particular inexistente qualquer diferença entre ambos – dependem de interpretação para ganhar sentido, isto é, o texto só se converte em norma mediante interpretação, e a tarefa da jurisdição não se esgota em declarar um sentido prévio e unívoco da Constituição e da legislação, a existência de interpretações divergentes no momento anterior à formação do precedente é uma condição inerente ao Direito, compreendido como prática lógico-argumentativa. É apenas com o precedente que o sentido institucional da norma é delimitado à luz do caso em que o texto é interpretado e a norma é aplicada. Como é evidente, somente a partir do exato instante em que formado o precedente, é que se pode exigir o seu respeito – só é possível orientar uma conduta futura, não é possível orientar o passado. Daí porque o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, como Cortes de Precedentes, são cortes cuja atuação é destinada ao futuro.

A propósito, existe uma assimilação indevida na argumentação desenvolvida pelo Supremo

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para superação da Súmula 343, que está exatamente na suposição de que essa súmula é apenas uma repercussão no âmbito da ação rescisória da Súmula 400, STF, concernente ao recurso extraordinário (“decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra ‘a’ do art. 101, III, da Constituição Federal”).³⁴¹ Dizer que não cabe recurso extraordinário quando a interpretação dada pelas instâncias ordinárias é razoável, não é o mesmo que dizer que a existência de controvérsia na interpretação ao tempo da formação da coisa julgada não autoriza sua rescisão. Isso porque o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça existem como instituições justamente para definir qual é a melhor interpretação da Constituição e da legislação infraconstitucional federal.

Como inexiste uma única e intrínseca resposta correta a problemas interpretativos, o problema da formação do precedente está justamente em saber qual é a interpretação que encontra maior suporte justificativo no sistema jurídico – se quisermos usar essa palavra, saber qual dentre as possíveis é a mais razoável do ponto de vista racional.³⁴² E quem deve afirmar qual é essa interpretação é exatamente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Daí que a solução constante da Súmula 400 carrega em si um equívoco evidente e a sua superação foi altamente positiva para o sistema. A Súmula 343, no entanto, apenas reconhece a possibilidade de um determinado enunciado linguístico contar com duas ou mais interpretações possíveis e que, inexistindo precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça definindo qual é a interpretação que deve ser observada ao tempo da formação da coisa julgada, a proteção a essa deve prevalecer.

Vale dizer: enquanto a ratio subjacente à Súmula 343 opera no âmbito da proteção que deve ser dada à segurança jurídica em face da indeterminação inerente ao Direito pela ausência de precedente, a ratio subjacente à Súmula 400 impede a definição do sentido que deve ser dado aos enunciados linguísticos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Embora ambas reconheçam a indeterminação do Direito, uma atua para proteção da estabilidade normativa exigida pela segurança jurídica, enquanto a outra impede a definição do sentido normativo que deve ser reconhecida aos textos da Constituição e da legislação infraconstitucional federal – com o que atua contra a cognoscibilidade normativa também exigida pela segurança jurídica. É evidente, portanto, que uma conta com uma solução acertada e a outra com uma solução equivocada. A superação de uma, portanto, não implica superação da outra.

A segunda, de que inexiste respeito à Constituição sem respeito à segurança jurídica. Com a violação da coisa julgada pela retroação de julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (como pretendem os arts. 525, inciso III, § 15, e 535, inciso III, § 8.º, CPC), a pretexto de outorgar a máxima efetividade à determinada norma constitucional, viola-se a segurança jurídica, que sustenta toda a estrutura do Estado Constitucional. Vale dizer: promove-se a parte em detrimento do todo. A retroação da orientação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, apanhando indistintamente tanto situações protegidas pela coisa julgada formada em momento anterior à existência de precedente como situações ainda não apreciadas definitivamente pelo Poder Judiciário, constitui manifesta violação do núcleo duro da segurança jurídica e da própria ideia de igualdade, na medida em que ignora a existência da coisa julgada como critério que legitima a distinção entre casos.

7. Publicidade. O art. 927, § 5.º, CPC, refere que “os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores”. Há aí a previsão do dever de publicidade dos precedentes judiciais.

Em primeiro lugar, o direito brasileiro reserva aos tribunais o dever de divulgar – aí obviamente implícito o dever de identificar e selecionar – os precedentes judiciais. Trata-se de solução diferente, por exemplo, daquela adotada no direito inglês. Como se sabe, os repertórios ingleses atuais são editados pelo Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales, criado em 1865 com a finalidade específica de “imprimir maior certeza e genuinidade aos precedentes judiciais”.³⁴³ Nesse conselho tem assento não só magistrados, mas membros de diferentes setores da prática jurídica.

Em segundo lugar, é preciso evitar qualquer interpretação do art. 927, § 5.º, CPC, no sentido de que seja possível que os precedentes tenham divulgação semelhante à das súmulas. Dever de organização por questão jurídica decidida significa apenas dever de indexação: não isenta, portanto, os tribunais de identificarem devidamente o caso – ou os casos – do qual oriundo o precedente. Assim como nos law reports do Common Law, é imprescindível que a questão jurídica decidida venda, devidamente contextualizada a partir de seus aspectos fáticos, sem os quais não é possível identificar o precedente e operá-lo de forma apropriada.

Art. 928. Para fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I – incidente de resolução de demandas repetitivas;

II – recursos especial e extraordinário repetitivos.

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.

1. Julgamento de Casos Repetitivos. Com o intuito de tornar mais eficiente a Justiça Civil (arts. 37, caput, CF, e 8.º, CPC), o Código de 2015 procura criar um procedimento adequado aos casos repetitivos. É por essa razão que em outras passagens – como na tutela da evidência (art. 311, CPC), na improcedência liminar (art. 332, CPC), nos poderes do relator (art. 927, CPC), nos poderes do presidente ou do vice-presidente das Cortes de Justiça para admissão de recursos extraordinários e especiais (art. 1.030, CPC), na disciplina do recurso extraordinário e do recurso especial (arts. 1.029 e seguintes, CPC) e no cabimento da ação de reclamação (art. 988, CPC) – procura-se diferenciar casos repetitivos de outros casos não repetitivos.

Existe, porém, um equívoco no Código que salta logo aos olhos no próprio art. 928, CPC. É que o Código mistura o julgamento de casos com o julgamento de questões – o que fica claro com o seu parágrafo único. Trata-se de equívoco que deriva mais fundamente da indistinção em que o Código incorreu a respeito do papel das Cortes Supremas e das Cortes de Justiça, do precedente e da jurisprudência, do julgamento de casos e do julgamento de questões.

Rigorosamente, o julgamento de toda e qualquer questão poderia ser tido como repetitivo, pelo simples fato de as questões poderem se repetir – ainda que em casos distintos. Daí que o incidente de resolução de demandas repetitivas não pode ter o mesmo objeto dos recursos repetitivos: enquanto que o incidente visa a resolver casos repetitivos, o recurso especial visa a formar precedentes. São projeções das diferentes funções que cada uma das cortes, encarregadas de seus julgamentos, levam a efeito.

Essa é a razão pela qual é preciso redimensionar os escopos de cada um dos institutos mencionados pelo art. 928, CPC. O incidente de resolução de demandas repetitivas visa a resolver casos marcados por direitos individuais homogêneos. Os recursos repetitivos – como, aliás, qualquer recurso extraordinário ou especial – visam resolver questões para a formação de precedentes. Nessa perspectiva, todo e qualquer precedente oriundo de Corte Suprema – derivado ou não da forma repetitiva (art. 928, inciso II, CPC) – autoriza a utilização de todos os institutos que o legislador, a princípio, reservou ao julgamento de casos repetitivos.

2. Questão de Direito Material ou Processual. Os casos repetitivos – isto é, massificados – naturalmente serão resolvidos em todos os seus aspectos pelas Cortes de Justiça. Envolvem, portanto, questões de direito material ou processual. O objetivo do art. 928, parágrafo único, CPC, portanto, está em esclarecer que os precedentes oriundos das Cortes Supremas podem ter, por objeto, questões de direito material ou de direito processual.

1

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios* (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016; Idem, *O STJ enquanto Corte de Precedentes* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Idem, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016; Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 868-972; Idem, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 606-613, vol. II.

2

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011, p. 39 e ss.

3

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011, p. 40-44.

4

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011, p. 46-52; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007, p. 144-145.

5

Oliver Wendell Holmes Jr. (1841 – 1935), *The Common Law* (1881). Cambridge: Harvard University Press, 1963, p. 5. Para uma adequada contextualização dessa célebre afirmação, Giovanni Tarello (1934 – 1987), *Il Realismo Giuridico Americano*. Milano: Giuffrè, 1962, p. 39-40: “la distinzione tra mere sopravvivenze e diritto che ha una funzione sociale si muove parallelamente ad un'altra distinzione holmesiana: la distinzione tra ‘forma’ e ‘sostanza’ del diritto. All'inizio di *The Common Law* Holmes afferma che ‘la sostanza del Diritto in ogni época corrisponde abbastanza a ciò che in quella stessa época è considerato utile (convenient); ma la sua forma ed il suo macchinismo (machinery), e la misura in cui esso è capace di conseguire i risultati voluti dipendono invece in larga parte dal suo passato’. Appare chiaro ad un esame degli scritti di Holmes che la forma del Diritto altro non è che quanto sopravvive di epoche passate, ed è sprovvisto di rapporti con ciò che attualmente è ‘convenient’. Sulla base di queste distinzioni è sufficientemente chiaro cosa Holmes intendesse con le affermazioni – troppe volte citate fuori dal contesto – secondo cui ‘la vita del diritto non è logica ma esperienza’. Egli intendeva semplicemente dire che, di fatto, i processi attraverso i quali si evolvono gli ordinamenti giuridici, cioè per Holmes i processi di decisione giudiziaria che portano alla formulazione di regole, sono condizionati non tanto da sviluppi sillogistici di regole precedentemente formulate quanto da una serie di fattori in senso lato social che vanno dalla struttura degli interessi in gioco sino alle teorie politiche dominante ed ai pregiudizi dei singoli giudici. Cosichè, mentre la veste esteriore delle decisioni, cioè la loro ‘forma’ è secondo Holmes ‘logica’, la loro ‘sostanza’ è ‘legislativa’: ove è palese una assimilazione tra le sopravvivenze del passato che hanno perso una funzione, la forma ed il macchinismo (le tecniche) del diritto, e l'aspetto che Holmes forse poco propriamente chiama ‘logico’ del diritto”.

6

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011, p. 52-53.

7

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011, p. 54.

8

Rupert Cross (1912 – 1980) e J. W. Harris, *Precedent in English Law* (1961), 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 3.

9

Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 250-256.

10

Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 250.

11

Reinhold Zippelius, *Rechtsphilosophie* (1982), 6. ed. München: C. H. Beck, 2011, p. 132.

12

Arthur Kaufmann (1923 – 2001), *Rechtsphilosophie* (1994), 2. ed. München: C. H. Beck, 1997, p. 192; Helmut Coing (1912 – 2000), *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1950), 5. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1993, p. 145-146.

13

Reinhold Zippelius, *Rechtsphilosophie* (1982), 6. ed. München: C. H. Beck, 2011, p. 132.

14

Helmut Coing, *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1950), 5. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1993, p. 145.

15

Hermes Zaneti Júnior, in Cabral e Cramer (coords.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.305.

16

A literatura existente sobre o assunto é imensa. Um bom panorama bibliográfico pode ser encontrado em

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, e Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014. Ainda, Frédérique Ferrand, “La Juridiction Judiciaire Suprême en Droit Comparé: Missions, Filtrage, Intensité du Contrôle”, in Drago, Fauvarque, Cosson e Goré (coords.), *L’Accès au Juge de Cassation*. Paris: LGDJ, 2015, p. 147–218; Christoph Kern, “The Role of the Supreme Court”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 228; “La Función de las Cortes Supremas en la América Latina – Historia, Paradigmas, Modelos, Contradicciones y Perspectivas” in *Reforma Procesal Civil*. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores, 2010, p. 669-721; Julio Guilherme Müller, “O Papel Fundamental do Superior Tribunal de Justiça no Contexto do Estado Democrático de Direito: Reflexões a Partir do Interesse Público de Uniformização da Interpretação da Legislação Infraconstitucional”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 238; Márcio Carvalho Faria, “As Funções das Cortes Superiores, os Recursos Excepcionais e a Necessária Revisão dos Parâmetros Interpretativos em Relação à Lealdade Processual (Parte Um)”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 247; Idem, “As Funções das Cortes Superiores, os Recursos Excepcionais e a Necessária Revisão dos Parâmetros Interpretativos em Relação à Lealdade Processual (Parte Dois)”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 248.

17

Michele Taruffo, “Linee per una Riforma della Cassazione Civile”, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*. Bologna: Il Mulino, 1991, p. 173.

18

Melvin Eisenberg, *The Nature of the Common Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 4. Aliás, como refere J. A. Jolowicz (1926 – 2012), “The Role of the Supreme Court at the National and International Level”. In: Yessiou-Faltsi, Pelayia (coord.), *The Role of the Supreme Courts at the National and International Level – Reports for the Thessaloniki International Colloquium*. Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 1998, p. 39, “the observation that the decisions of Supreme Courts contribute to the law in one way or another by interpretation, the clarification and, sometimes, the development of the law, whether the doctrine of stare decisis is formally recognised or not, is by now banal”.

19

Michele Taruffo, “Il Controllo del Diritto e del Fatto in Cassazione”, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*. Bologna: Il Mulino, 1991, p. 123; Vittoria Barsotti, *L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti*. Torino: Giappichelli, 1999, p. 292; André Tunc (1917 – 1999), “La Cour Suprême Idéale”, in Bellet e Tunc (coords.), *La Cour Judiciaire Suprême – Une Enquête Comparative*. Paris: Economica, 1978, p. 437. Semelhante fórmula, a propósito, foi expressamente adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin (“Caso Lula”).

20

Jerzy Wróblewski (1926 – 1990), *The Judicial Application of Law*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 255.

21

Michele Taruffo, “Le Funzioni delle Corti Supreme. Cenni Generali”, *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 14.

22

António Castanheira Neves, *O Instituto dos “Assentos” e a Função Jurídica dos Supremos Tribunais*. Coimbra: Coimbra Editora, 1983, p. 657-658.

23

J. A. Jolowicz, “The Role of the Supreme Court at the National and International Level”. In: Yessiou-Faltsi, Pelayia (coord.), *The Role of the Supreme Courts at the National and International Level – Reports for the Thessaloniki International Colloquium*. Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 1998, p. 39.

24

Michele Taruffo, “La Corte di Cassazione e la Legge”, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*. Bologna: Il Mulino, 1991, p. 65-66.

25

Michele Taruffo, “La Corte di Cassazione e la Legge”, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*. Bologna: Il Mulino, 1991, p. 89-90. Como observa igualmente André Tunc, “le litige dont une cour suprême est saisie n’est pour elle que l’occasion de remplir sa mission principale. Elle statue dans l’intérêt du droit – donc de tous les citoyens – plus que dans celui des plaideurs. (...) La cour suprême doit avant tout guider les autres juridictions, presider à l’élaboration du droit judiciaire. Elle a, pourrait-on dire, une fonction pastorale” (“La Cour Suprême Idéale”, in Bellet e Tunc (coords.), *La Cour Judiciaire Suprême – Une Enquête Comparative*. Paris: Economica, 1978, p. 437).

26

Embora tenha nascido como um meio extraordinário de viabilizar o acesso à Supreme Court, atualmente o writ of certiorari consiste, na prática, na sua única via de acesso. Sobre o assunto, amplamente, Vittoria Barsotti, *L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti*. Torino: Giappichelli, 1999, p. 61-131.

27

Neil MacCormick (1941 – 2009), *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 91. Por essa razão, o problema da vinculação ao precedente não é um problema de direito positivo, mas um problema ligado à teoria do Direito, ao significado da interpretação jurídica e à metodologia jurídica a ela subjacente.

28

STF, Pleno, RE 655.265/RS, rel. Min. Luiz Fux, rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 13.04.2016, *DJE*

05.08.2016. Na mesma linha, STF, RE 994.607/MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 23.08.2017, *DJE* 28.08.2017.

29

STJ, AREsp 634.051/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 01.08.2017, *DJE* 07.08.2017.

30

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios* (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016; Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016; Hermes Zaneti Júnior, *O Valor Vinculante dos Precedentes*. Salvador: JusPodium, 2014. Como observa Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios* (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 156-157: “seria possível pensar que toda decisão judicial é um precedente. Contudo, ambos não se confundem, só havendo sentido falar de precedente quando se tem uma decisão dotada de determinadas características, basicamente a potencialidade de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados. De modo que, se todo precedente ressaia de uma decisão, nem toda decisão constitui precedente. Note-se que o precedente constitui decisão acerca da matéria de direito – ou, nos termos do common law, de um point of law – e não de matéria de fato. Quando são enfrentados pontos de direito, as decisões muitas vezes se limitam a anunciar o que está escrito na lei, não revelando propriamente uma solução judicial acerca da questão de direito, no sentido de solução que ao menos dê uma interpretação da norma legal. De qualquer forma, a decisão que interpreta a lei, mas segue julgado que a consolidou, apenas por isso não constitui precedente. Contudo, para constituir precedente, não basta que a decisão seja a primeira a interpretar a norma. É preciso que a decisão enfrente todos os principais argumentos relacionados à questão de direito posta na moldura do caso concreto. Até porque os contornos de um precedente podem surgir a partir da análise de vários casos, ou melhor, mediante uma construção da solução judicial da questão de direito que passa por diversos casos”.

31

Aleksander Peczenik (1937 – 2005), *On Law and Reason* (1989), 2. ed. Dordrecht: Springer, 2009, p. 272.

32

Frederick Schauer, *Thinking like a Lawyer*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009, p. 40. Sobre a evolução do precedente no direito inglês, notadamente a partir das suas funções de ilustração, persuasão e vinculação, Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

33

A expressão *ratio decidendi* é tradicional do direito inglês, ao passo que a expressão *holding* é mais usual no direito estadunidense (P. S. Atiyah e Robert Summers, *Form and Substance in Anglo-American Law*. Oxford: Oxford University Press, 1987, p. 124).

34

Se a *ratio decidendi* pode ser conceituada como uma razão para a decisão (Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 67), o *obiter dictum* pode ser como tudo aquilo que não integra o rol das razões necessárias e suficientes para tanto. *Obiter dictum*, portanto, é tudo aquilo que é dito de passagem, dito pelo caminho, mas que não integra propriamente a razão para a decisão (Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 68). Não integrando a *ratio*, o *obiter dictum* não tem força vinculante.

35

Michele Taruffo, “Precedente e Giurisprudenza”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2007, p. 711-712; Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 611, vol. II. Nessa mesma linha crítica, Carlos Alberto Salles, “Precedentes e Jurisprudência no Novo CPC: Novas Técnicas Decisórias?”, *O Novo Código de Processo Civil – Questões Controvertidas*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 78; Camilo Zufelato, “Precedentes Judiciais Vinculantes à Brasileira no Novo CPC: Aspectos Gerais”. *O Novo Código de Processo Civil – Questões Controvertidas*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 106-109.

36

O tema das relações entre fato e direito é complexo e a literatura a seu respeito extensa (sobre o assunto, Júlio Lanes, *Fato e Direito no Processo Civil Cooperativo*. São Paulo: Ed. RT, 2014). Um inventário do tema está fora do escopo do presente trabalho. No entanto, é preciso ter presente que existe uma incindibilidade ontológica entre fato e direito, nada obstante exista uma cindibilidade funcional. Existe uma incindibilidade ontológica, porque toda narrativa de fato já ingressa no processo a partir de uma determinada moldura normativa (vale dizer, a norma aí funciona como “esquema de interpretação” dos fatos – “Norm als Deutungsschema”, Hans Kelsen (1881 – 1973), *Reine Rechtslehre* (1. ed., 2. ed., 1960), 2. ed. Wien: Österreich, 2000, p. 3). No entanto, é possível dissociar fato e direito no processo – depois de estabelecida a causa em todos os seus contornos fático-jurídicos – para determinadas funções (por exemplo, para individualização do objeto da prova e para comparação entre casos em seus aspectos fáticos). Daí a razão pela qual se pode nesses limites afirmar a possibilidade de cindibilidade funcional da causa.

37

Por essa razão, Rupert Cross e J. W. Harris, *Precedent in English Law* (1961), 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 43, são enfáticos: “judgments must be read in the light of the facts of the case in which they are delivered”. Na mesma linha, Michele Taruffo, “Precedente e Giurisprudenza”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2007, p. 712.

38

Luiz Guilherme Marinoni, *Julgamento nas Cortes Supremas*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 33 e ss. Nessas passagens chama-se a atenção para a circunstância de um sistema de precedentes depender não só de uma adequada identificação da questão que deve ser interpretada (como, aliás, é possível construir como regra geral no sistema brasileiro a partir do art. 1.037, I, CPC/2015), mas também de um adequado sistema de julgamento nas Cortes Supremas. Nessa linha, é oportuno distinguir entre decisão colegiada (em que há fundamentos compartilhados) e decisão plural (em que não há fundamentos compartilhados), entre

fundamentos majoritários (mesmos fundamentos e mesmas conclusões) e fundamentos concorrentes (fundamentos diferentes e mesmas conclusões) e entre voto divergente (em que não há preocupação em oposição à ratio decidendi) e voto dissidente (em que há preocupação em oposição à ratio decidendi) como conceitos úteis para a compreensão do tema. Em um sistema de julgamento adequado a um sistema de precedentes o ideal é que as decisões sejam colegiadas (e não plurais), os fundamentos sejam unânicos ou majoritários (e não concorrentes) e a contrariedade seja expressa em termos de votos dissidentes (e não simples votos divergentes). O assunto será enfrentado oportunamente diante dos comentários ao art. 941, CPC/2015.

39

Nada obstante, quanto à utilização do termo jurisprudência, há quem sustente a sua colocação como gênero no qual se inserem todas as manifestações do direito reconstruído pelos juízes, incluindo aí os precedentes das Cortes Supremas (é nesse sentido que Teresa Arruda Alvim Wambier fala em “direito jurisprudencial”, *Direito Jurisprudencial*. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 5-6, vol. II), e há quem pugne pela eliminação do conceito da terminologia jurídica brasileira para significar formas de vinculação a casos decididos com força vinculante (é nessa linha a lição de Hermes Zaneti Júnior, in Cabral e Cramer (coords.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.310-1.311).

40

Nada obstante, em sentido contrário, Hermes Zaneti Júnior, *O Valor Vinculante dos Precedentes*. Salvador: JusPodium, 2015, p. 341 e ss.

41

Gino Gorla, “La Giurisprudenza” (1970), *Diritto Comparato e Diritto Comune Europeo*. Milano: Giuffrè, 1981, p. 265.

42

Caracterizando a teoria geral como uma teoria transsetorial, Riccardo Guastini, *Teoria del Diritto – Approccio Metodologico*. Modena: Mucchi Editore, 2002, p. 31.

43

Victor Nunes Leal (1914 – 1985), “Passado e Futuro da Súmula do STF”, *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1981, p. 1 e ss, n. 145.

44

Miguel Reale (1910 – 2006), *Lições Preliminares de Direito* (1973), 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 175.

45

Hermes Zaneti Júnior, in Cabral e Cramer (coords.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.322; Alexandre Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo:

46

Brian Bix, *A Dictionary of Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 204-205.

47

Frederick Schauer, *Thinking like a Lawyer*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009, p. 36--37 e 41-43.

48

Frederick Schauer, *Thinking like a Lawyer*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009, p. 42.

49

Idem, p. 41.

50

Idem, p. 36.

51

Como observa com razão Benjamin Cardozo (1870 – 1938), *The Nature of Judicial Process*. New Haven: Yale University Press, 1921, p. 127, “statutes do not cease to be law because the power to fix their meaning in case of doubt or ambiguity has been confided to the courts”. Aliás, essa contingência mostra que outorgar força ao precedente judicial, vendo-o como fruto de uma reconstrução racional da ordem jurídica, em nada apaga a heteronomia que normalmente é reconhecida como característica das normas jurídicas (Norberto Bobbio (1909 – 2004), *Teoria Generale del Diritto* (1957 – 1958). Torino: Giappichelli, 1993, p. 63-66; Miguel Reale, *Lições Preliminares de Direito* (1973), 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 48-49).

52

Contra, postulando a inexistência de vinculação, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1.836-1.837; Cássio Scarpinella Bueno, *Código de Processo Civil Anotado*. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 568.

53

A decomposição analítica do conteúdo da regra do stare decisis é devida a Pierluigi Chiassoni (sobre o assunto, “I Precedenti Civili sono Vinculanti? Considerazioni sull’art. 360-bis CPC”, *Diritti Umani, Sentenze Elusive, Clausole Ineffabili – Scritti di Realismo Militante*. Roma: Aracne, 2011, p. 131-139; “The Philosophy of Precedent: Conceptual Analysis and Rational Reconstruction”, *On the Philosophy of Precedent*. Stuttgart: Franz Steiner, 2012, p. 29-33), que trabalha o tema a partir das distinções verbais indicadas no

texto para conceber diferentes modelos de sistemas de precedentes. Trata-se de uma proposta de sistematização crítica e alternativa àquela apresentada pelo conhecido Bielefelder Kreis (MacCormick e Summers, *Interpreting Precedents – A Comparative Study*. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997).

54

Trata-se da conhecida proposta de Ronald Dworkin (1931 – 2013), que pode ser conferida nesse particular especialmente no seu *Law's Empire*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1986, especialmente p. 176-275. Cuida-se de uma tentativa de apresentar um conceito interpretativo do direito (“law is an interpretative concept”, p. 87) capaz de responder adequadamente aos problemas do positivismo jurídico (“legal positivism”, p. 33-35, “conventionalism”, p. 114 e ss), do jusnaturalismo (“natural law”, p. 35-36) e do pragmatismo (aí incluído o “legal realism”, p. 151 e seguintes) – propostas identificadas por Dworkin, com uma enorme dose de simplificação em determinados aspectos, como “semânticas” e “descritivistas” do direito (daí porque sofreriam do chamado “semantic sting”, isto é, do “agulhão semântico”, p. 45 e seguintes). No que agora interessa, o núcleo do pensamento de Dworkin pode ser conferido a partir dos seus *Taking Rights Seriously*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1977, *A Matter of Principle*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1985, e *Law's Empire*, já citado. Para ulterior desenvolvimento das suas ideias, seus críticos também apontam importantes aportes em *Justice for Hedgehogs*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2011.

55

A literatura crítica sobre o pensamento de Ronaldo Dworkin é enorme. Para limitarmo-nos à doutrina brasileira, Juliano Maranhão, *Positivismo Jurídico Lógico-Inclusivo*. São Paulo: Marcial Pons, 2012; Ronaldo Porto Macedo Júnior, *Do Xadrez à Cortesia – Dworkin e a Teoria do Direito Contemporânea*. São Paulo: Saraiva, 2013; Cláudio Mello, “Verdade Moral e Método Jurídico na Teoria Constitucional de Ronald Dworkin”, in Lisboa-Storck, *Normatividade & Argumentação – Ensaios de Filosofia Política e do Direito*. Porto Alegre: Linus Editores, 2013; Arthur Maria Ferreira Neto, *Metaética e a Fundamentação do Direito*. Porto Alegre: Elegancia Juris, 2015.

56

Sobre o positivismo jurídico oitocentista, Norberto Bobbio, *Il Positivismo Giuridico (1960-1961)* (1979), 2. ed. Torino: Giappichelli, 1996 (porém, sobre a necessidade de desconstrução da tese do positivismo jurídico como um movimento unitário, tal como apresentado por Bobbio, Pierluigi Chiassoni, *Positivismo Giuridico – Una Investigazione Analitica*. Modena: Mucchi Editore, 2013); sobre o positivismo jurídico novecentista, Vittorio Villa, *Il Positivismo Giuridico: Metodi, Teorie e Giudizi di Valore*. Torino: Giappichelli, 2004, p. 45-83; Luís Fernando Barzotto, *O Positivismo Jurídico Contemporâneo – uma Introdução a Kelsen, Ross e Hart* (1999), 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; Cláudio Michelon Júnior, *Aceitação e Objetividade – Uma Comparação entre as teses de Hart e do Positivismo Jurídico Precedente sobre a Linguagem e o Conhecimento do Direito*. São Paulo: Ed. RT, 2004; sobre o desenvolvimento posterior do positivismo jurídico a partir de Hart, especialmente sobre o debate entre o positivismo jurídico inclusivista e o positivismo jurídico exclusivista, Juliano Maranhão, *Positivismo Jurídico Lógico-Inclusivo*. São Paulo: Marcial Pons, 2012.

57

58

Herbert Hart (1907 – 1992), *The Concept of Law* (1961), 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 124 e ss.

59

Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (1977). Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1977, p. 14 e ss, 46 e ss e 81 e ss; *A Matter of Principle* (1985). Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1985, p. 119 e ss.

60

Não é momento adequado para tratarmos de semelhante assunto. É possível referir, porém, que diante das críticas endereçadas por Ronald Dworkin ao positivismo jurídico esse reagiu dividindo-se em positivismo jurídico inclusivista e positivismo jurídico exclusivista. É esclarecedora a síntese de Juliano Maranhão, *Positivismo Jurídico Lógico-Inclusivo*. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 63-65: “a evidência da qual parte Dworkin é aceita pelos positivistas: princípios morais ou de políticas públicas são empregados na fundamentação de decisões. Essa constatação também se dá em ambiente do fenômeno jurídico particularmente relevante para os positivistas: é na atividade dos juízes onde se constitui a convenção sobre as fontes dotadas de autoridade. Daqui segue seu argumento. Como os princípios são razões vinculantes para os juízes, mas não podem satisfazer uma convenção sobre as fontes, a única fonte de sua validade deve ser o mérito moral de seu conteúdo. Em cada ato de adjudicação estão envolvidas concepções distintas sobre o propósito moral ou político das decisões políticas prévias e de nosso dever em segui-las. Os princípios morais ou de políticas públicas presentes nas decisões cristalizam essas concepções e informam a reconstrução da história político-jurídica como atos justificados dentro de determinada perspectiva moral. Isso significa que princípios de moralidade política estão necessariamente incorporados ao direito. Essa explicação, além de implodir a tese da separação, afeta, pelo caráter controverso atribuído aos fundamentos do direito, a própria tese das fontes e, assim, todo o edifício positivista. Como então explicar a força vinculante atribuída pelos tribunais a princípios morais e de políticas públicas empregados na interpretação do direito e justificação de suas decisões? A resposta dada pelos inclusivista (também chamados de incorporacionistas ou positivistas soft-core), consiste em admitir a possibilidade da regra de reconhecimento conter critérios morais, além da indicação de instituições dotadas de autoridade para criar regras. Com essa especificação na tese das fontes, torna a relação entre princípios morais e o direito apenas contingente. Esses critérios de moralidade, eventualmente incorporados na regra de reconhecimento, podem ser condições positivas que geram standards de conduta ou apenas estabelecem limites (negativos) ao uso da autoridade pelas instituições (e. g., ‘é direito tudo o que autoridade determinar a não ser que se viole a igualdade entre cidadãos’). Em última análise, seria a convenção social um fato contingente a determinar a presença ou não de critérios morais na regra de reconhecimento, quebrando-se assim a premissa de Dworkin de que haveria necessariamente razões jurídicas sem pedigree, cujo fundamento de validade seria seu mérito moral. Para os inclusivista, portanto, princípios são vinculantes se e porque em conformidade com os critérios morais da regra de reconhecimento. (...). A resposta dada pelos exclusivistas (também chamados de positivistas hard-core) aceita que a força vinculante dos princípios esteja fundamentada em seu mérito moral, porém

rejeita que esses façam parte do direito ou constituam razões jurídicas. A existência de razões morais empregadas pelos tribunais que não satisfaçam a regra última de reconhecimento apenas prova, para os exclusivistas, a tese ad discricionarietà. Aliás, afirmam que razões de fundamento moral necessariamente não fazem parte do direito e consideram a tese da incorporação de critérios morais de validade inconsistente com a tese das fontes. (...). Assim, a distinção entre interpretativistas (e jusnaturalistas contemporâneos), inclusivista e exclusivistas está, respectivamente, na necessidade, contingência e impossibilidade da incorporação de parâmetros morais na identificação das normas válidas. Enquanto os inclusivista cedem espaço à moralidade e sua incorporação pelos critérios de validade, os exclusivistas reafirmam as teses do positivismo clássico e as desenvolvem para fechar a possibilidade de incorporação, que, conforme o próprio Hart, não estava excluída em *The Concept of Law*".

61

Ronald Dworkin, *Law's Empire* (1986). Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1986, p. 65 e ss, 176 e seguintes. Para uma pormenorizada análise das etapas interpretativas em Dworkin, Cláudio Mello, "Verdade Moral e Método Jurídico na Teoria Constitucional de Ronald Dworkin", in Lisboa-Storck, *Normatividade & Argumentação – Ensaio de Filosofia Política e do Direito*. Porto Alegre: Linus Editores, 2013, p. 300-311.

62

Como sintetiza Arthur Maria Ferreira Neto, essa segunda etapa seria "promovida com o intuito de argumentar e justificar a função e a razão de ser da prática social que deveria ou não ser realizada em determinado contexto de ação. Assim, o aplicador do direito deve buscar construir uma interpretação sistemática que possa ser justificada como sendo a mais coerente dentre as variadas alternativas que poderiam ser elaboradas a partir dos textos jurídicos relevantes. Para tanto, deve o intérprete desenvolver e apresentar as teorias morais e políticas capazes de fornecer o critério para essa 'melhor interpretação', a qual, dentro da metodologia hermenêutica proposta por Dworkin, dependeria de uma análise que passaria por duas dimensões, quais sejam a dimensão da compatibilidade (fit) e a da moralidade política (political morality). A primeira, segundo Dworkin, indicaria que a teoria política a ser utilizada na explicação do direito seria aquela que fosse capaz de melhor justificar a maior quantidade de material jurídico que veio a ser efetivamente positivado. Nesta dimensão, portanto, podemos afirmar que teríamos um critério quantitativo. Já a segunda forneceria o critério qualitativo, por meio do qual seria possível promover-se o desempate moral entre duas teorias políticas que fossem capazes de justificar, em condições de igualdade, a compatibilidade do material jurídico em vigor. A teoria a ser escolhida seria aquela capaz de melhor justificar em termos políticos e morais os direitos que poderiam ser extraídos do material jurídico em vigor. E é, precisamente, nesse ponto, que surge a relevância da ideia de integridade, a qual representa o critério final para a resolução de conflitos jurídicos considerados difíceis e que dá fechamento a toda concepção dworkiniana da teoria interpretativa do direito" (*Metaética e a Fundamentação do Direito*. Porto Alegre: Elegancia Juris, 2015, p. 266-267).

63

Ronald Dworkin, *Law's Empire* (1986). Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1986, p. 217 e 225 e seguintes. A análise empreendida por Arthur Maria Ferreira Neto é novamente útil aqui: "o resgate da melhor interpretação possível, para Dworkin, seria definido por meio de um critério, qual seja o da

integridade na interpretação do significado de um objeto (e. g., uma obra de arte ou um texto jurídico). Por sua vez, o critério da integridade no que se refere à efetiva significação do objeto de interpretação é definido pela coerência com que se consegue justificar o maior número de proposições que formam aquilo que está sendo interpretado. Com efeito, pode-se dizer que a ideia mais ampla que perfaz o pensamento de Dworkin, ao caracterizar o direito como sendo um fenômeno social interpretativo, é a da integridade, a qual se manifesta por meio de dois princípios políticos, um regulador da atividade legislativa e outro regulador da atividade jurisdicional. O primeiro princípio exige que o legislador formule um sistema total de leis que seja moralmente coerente, enquanto que o segundo princípio exige que o juiz aplique tais leis de modo a garantir o máximo possível de coerência entre as suas proposições jurídicas, visando a identificar os padrões morais que estão implícitos em tais princípios. O ideal da integridade, portanto, não é outra coisa senão a busca por uma coerência no que diz respeito à formulação e a aplicação de proposições jurídicas, tendo em vista um conjunto de princípios morais que está, implicitamente, em vigor em uma comunidade política. A integridade, nessa esteira, é compreendida como sendo a maior virtude que uma prática social pode manifestar, mesmo que outros valores também devam ser combinados na resolução de conflitos jurídicos, sendo os mais relevantes a justiça, a igualdade e o devido processo legal. (...). A noção de integridade como coerência é sabidamente um ideal a ser perseguido e não um projeto concreto que poderia ser ambicionado em uma realidade social específica, na medida em que não se poderia pretender alcançar uma integral coerência entre todas as regras positivas que estão, efetivamente, em vigor. É exatamente por isso que a metodologia que Dworkin fornece ao seu leitor, como forma de permitir visualizar como se poderia concretizar o ideal de integridade como coerência por ele proposto, exige ainda mais um nível de idealização, i. é, pressupõe imaginarmos o processo hermenêutico antes descrito sendo realizado por um julgador perfeito, dotado de poderes intelectuais super-humanos, o qual se submeteria a analisar casos difíceis em condições também idealizadas. Esse juiz super-humano seria, para Dworkin, o chamado juiz Hércules. Seria, portanto, de acordo com a perspectiva desse magistrado idealizado que o processo narrativo de interpretação do direito deveria ser pensado, o que permitiria traçar o paradigma de coerência (também ideal) que poderia ser buscado, concretamente, pelos reais operadores do direito” (Metaética e Fundamentação do Direito. Porto Alegre: Elegancia Juris, 2015, p. 269-271).

64

Ronaldo Dworkin, *Law's Empire* (1986). Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1986, p. 65-66.

65

Cuida-se da proposta de Robert Alexy, *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

66

Por exemplo, Aleksander Peczenik, *On Law and Reason* (1989), 2. ed. Dordrecht: Springer, 2009; Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

67

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 611-612, vol. II; Idem, *Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 871-872. Nessa mesma linha, Hermes Zaneti Júnior, in Cabral e Cramer, *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense,

2015, p. 1.316-1.318; Didier Júnior, Braga e Oliveira, Curso de Direito Processual Civil (2007), 10. ed. Salvador: JusPodium, 2015, p. 476-486, vol. II.

68

Riccardo Guastini, Interpretare e Argomentare. Milano: Giuffrè, 2011, p. 63-65; Riccardo Guastini, Teoria e Dogmatica delle Fonti. Milano: Giuffrè, 1998, p. 136-146.

69

Riccardo Guastini, Interpretare e Argomentare. Milano: Giuffrè, 2011, p. 39 e seguintes.

70

Juliano Maranhão, Positivismo Jurídico Lógico-Inclusivo. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 41.

71

Arthur Maria Ferreira Neto, Metaética e a Fundamentação do Direito. Porto Alegre: Elegancia Juris, 2015, p. 299.

72

Humberto Ávila, Teoria dos Princípios (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 166 e ss.

73

Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (1. ed., 2. ed., 1960), 2. ed. Wien: Österreich, 2000, p. 228 e seguintes.

74

Humberto Ávila, Teoria dos Princípios (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 166 e seguintes.

75

Cláudio Michelon, “Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica”, in Macedo Júnior-Barbieri (coords.), Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 267.

76

Humberto Ávila, Teoria dos Princípios (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 166 e seguintes.

77

Humberto Ávila, Teoria dos Princípios (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 169-171.

78

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 97. Amplamente, Paula Pessoa, *Legitimidade dos Precedentes – Universabilidade das Decisões do STJ*. São Paulo: Ed. RT, 2014.

79

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 91; Melvin Eisenberg, *The Nature of the Common Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 8-12.

80

Pierluigi Chiassoni, “The Philosophy of Precedent: Conceptual Analysis and Rational Reconstruction”, *On the Philosophy of Precedent*. Stuttgart: Franz Steiner, 2012, p. 32. Vale dizer: os juízes têm o dever de mencionar e analisar os precedentes existentes sobre o caso (isto é, dever de considerar, arts. 10 e 489, § 1.º, V e VI, CPC/2015), têm o dever de interpretá-los (arts. 489, § 1.º, V e VI, e 927, § 1.º, CPC/2015) e, em sendo o caso, o dever de segui-los, ainda que não concordem com as suas razões (arts. 926 e 927, CPC/2015), e só podem se afastar dos precedentes para superá-los – obviamente, se tiverem competência para tanto. Como é evidente, se os juízes simplesmente distinguem as questões não há que se falar em precedente e, portanto, na sua violação.

81

Amplamente, Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios* (2010), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 224-228.

82

Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (1978). Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 215; Neil MacCormick, “Why Cases Have Rationes and What These Are”, *Precedent in Law*. Oxford: Oxford University Press, 1987, p. 170.

83

Giuseppe Zaccaria, *La Giurisprudenza come Fonte di Diritto – Un’Evoluzione Storica e Teorica*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007, p. 7-21. Sobre o problema do precedente judicial como fonte do Direito, amplamente, José Rogério Cruz e Tucci, *Precedente Judicial como Fonte do Direito*. São Paulo: Ed. RT, 2004.

84

Como estimava Carl Friedrich von Savigny (1779 – 1861), *System des heutigen römischen Rechts*. Berlin: Veit und Comp., 1840, p. 34-38 (*Gewohnheitsrecht* – costume jurídico) e p. 45-49 (*Wissenschaftliches Recht* – direito científico ou simplesmente doutrina), tomo I.

85

Como propôs Josef Esser (1910 – 1999), “*Richterrecht, Gerichtsgebrauch und Gewohnheitsrecht*”, in Esser-

Thieme (coords.), Festschrift für Fritz von Hippel zum 70 Geburtstag. Tübingen, Mohr Siebeck, 1967, p. 95-130.

86

Como entendem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1.836-1.837; Cássio Scarpinella Bueno, Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 568.

87

Martin Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation. Berlin: Duncker & Humblot, 1967, p. 243 e seguintes; Gino Gorla (1906 – 1992), “L’Uniforme Interpretazione della Legge e i Tribunali Supremi” (1976), Diritto Comparato e Diritto Comune Europeu. Milano: Giuffrè, 1981, p. 511-540; Giuseppe Zaccaria, La Giurisprudenza come Fonte di Diritto – Un’Evoluzione Storica e Teorica. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007, p. 21.

88

STF, Pleno, RE n. 733.433-MG, em especial o voto do Min. Edson Fachin; STJ, 6.^a Turma, HC 274.806/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.02.2014; STJ, 6.^a Turma, HC 276.152/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31.03.2014.

89

Como observa Estefânia Maria de Queiroz Barboza, Precedentes Judiciais e Segurança Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 237, “a segurança jurídica não se realiza quando os Tribunais inferiores decidem diversamente dos Tribunais Superiores, quando turmas ou câmaras de um mesmo Tribunal decidem de modo divergente entre si. Do mesmo modo, é violado o princípio da segurança jurídica quando o Tribunal Superior desrespeita sua própria prática e seus próprios precedentes”.

90

Theodore Benditt, “The Rule of Precedent”, in Goldstein (coord.), Precedent in Law. Oxford: Oxford University Press, 1987, p. 94.

91

Idem, p. 89-91.

92

Michele Taruffo, “Precedente e Giurisprudenza”, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile Milano: Giuffrè, 2007, p. 716, com apoio em Aleksander Peczenik, The Binding Force of Precedent, in McCormick e Summers (coords.), Interpreting Precedents – A Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997, p. 461-479, nada obstante esse último observe, com razão, que “no doubt, formal bindingness may be regarded as a non-graded concept, like ‘pregnant’: a precedent is formally binding or not, and it cannot be

binding to a degree” (The Binding Force of Precedent, Interpreting Precedents – A Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997, p. 478).

93

Michele Taruffo, “Precedente e Giurisprudenza”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2007, p. 716.

94

Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 113.

95

Melvin Eisenberg, *The Nature of the Common Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 104-105.

96

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 237-253.

97

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios* (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 285; Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 107-108.

98

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*. São Paulo: Ed. RT, 2010; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014. Adotando um conceito mais amplo de precedente, de modo a englobar também a jurisprudência das Cortes de Justiça a que o Código emprestou efeito vinculante, Guilherme Rizzo Amaral, *Comentários às Alterações do Novo CPC*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 945-949. Embora corretamente reconheça a necessidade de tratar do precedente sempre nos domínios da vinculação, Hermes Zaneti Júnior, *O Valor Vinculante dos Precedentes*. Salvador: JusPodium, 2015, p. 341 e seguintes, procura classificá-los a partir da equivocada premissa de que a força do precedente deve estar legalmente prevista. Sustentando a possibilidade de falar-se em precedentes obrigatórios e precedentes persuasivos, Didier Júnior, Braga e Oliveira, *Curso de Direito Processual Civil* (2007), 10. ed. Salvador: JusPodium, 2015, p. 454-457, vol. II; Lucas Buril de Macêdo, *Precedentes Judiciais e o Direito Processual Civil*. Salvador: JusPodium, 2015, p. 99 e seguintes; em precedentes vinculantes e não vinculantes, Alexandre Freiras Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 433. Sustentando a possibilidade de se falar em diferentes graus de vincutatividade dos precedentes de acordo com fatores institucionais e extrainstitucionais, Thomas da Rosa de Bustamante, *Teoria do Precedente Judicial – A Justificação e a Aplicação de Regras Jurisprudenciais*. São Paulo: Noeses, 2012, p. 302 e seguintes, e Francisco Rosito, *Teoria dos Precedentes Judiciais*. Curitiba: Juruá, 2012, p. 115 e seguintes. Sustentando a necessidade de se pensar no precedente a partir das suas boas razões (e, portanto, pensá-lo apenas com caráter persuasivo), Fábio Machado, “Por que Realmente os Precedentes Importam?”, *Jurisdição, Direito Material e Processo*.

99

Frederick Schauer, *Thinking like a Lawyer*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009, p. 38.

100

Luiz Guilherme Marinoni, *Julgamento nas Cortes Supremas*. São Paulo: Ed. RT, 2015. A questão concernente à forma de julgamento nas Cortes Supremas e nas Cortes de Justiça será abordada nos comentários ao art. 941, CPC/2015.

101

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 226 e seguintes; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 101-102.

102

Neil MacCormick, “Why Cases Have Rationes and What These Are”, in Goldstein (coord.), *Precedent in Law*. Oxford: Oxford University Press, 1987, p. 157.

103

Eugene Wambaugh (1856 – 1940), *The Study of Cases* (1892), 2. ed. Boston: Little, Brown & Co., 1894, p. 17 e ss.

104

Arthur Goodhart (1891 – 1978), “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, *Essays in Jurisprudence and the Common Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1931, p. 1 e seguintes.

105

Eugene Wambaugh, *Op. cit.*, p. 18.

106

Neil Duxbury, *Op. cit.*, p. 77.

107

Antes disso, precisamente em 1928, Goodhart publicou importante artigo no *Cambridge Law Journal*, intitulado de “Three Cases on Possession”, em que a sua concepção de ratio decidendi mostrou-se bastante diferente. Neste artigo, ao invés de buscar a ratio decidendi nos fatos – na identificação dos fatos que o

juiz considerou materiais e imateriais –, Goodhart procurou-a nos fundamentos ou nas reasons for the decision (razões para a decisão). Vide Arthur Goodhart, “Three Cases on Possession”, *The Cambridge Law Journal*, n. 3, 1928, p. 195-208.

108

Neil Duxbury, *Op. cit.*, p. 83.

109

Sublinhe-se que o trabalho “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, quando comparado ao que Goodhart escreveu anteriormente – “Three Cases on Possession” –, revela a influência que recebeu de Joseph Francis, um dos mais importantes realistas da história do common law, ao lado de Oliphant. Francis escreveu artigo para polemizar com Goodhart, publicado na *St. Louis Law Review* também em 1928, sob o título de “Three Cases on Possession – Some Further Observations”, *St. Louis Law Review*, n. 14, 1928, p. 11-16.

110

Arthur Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, *cit.*, p. 15.

111

“Em *Rylands v. Fletcher*, o réu contratou um empreiteiro independente para fazer um reservatório em sua propriedade. Devido à negligência do empreiteiro em não encher algumas minas d’água em desuso, a água escoou e inundou a mina do autor. O réu foi considerado responsável. Seria o princípio do caso que um homem que constrói um reservatório em sua propriedade seja considerado responsável pela negligência de um empreiteiro independente? Por que, então, este caso é sempre mencionado como aquele que fixou a doutrina mais ampla da ‘responsabilidade objetiva’? A resposta é encontrada nas opiniões. Após determinarem os fatos como acima descritos, os juízes então ignoraram o fato da negligência do empreiteiro, e fundamentaram suas conclusões no fato de que um reservatório artificial havia sido construído. A negligência do empreiteiro foi, assim, implicitamente considerada com um fato imaterial. O caso pode ser analisado como segue: Fato I – O réu teve um reservatório construído em sua propriedade. Fato II – O empreiteiro que o construiu foi negligente. Fato III – A água escoou e prejudicou o autor. Conclusão – O réu é responsável perante o autor. Fatos materiais como vislumbrados pela Corte: Fato I – O réu teve um reservatório construído em sua propriedade. Fato III – A água escoou e prejudicou o autor. Conclusão – O réu é responsável perante o autor. Em razão da omissão do Fato II, a doutrina da ‘responsabilidade objetiva’ foi estabelecida” (Arthur Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, *cit.*, p. 17-18).

112

Como esclarece Rupert Cross e J. W. Harris, tratando do método de Goodhart, “sua justificativa pode ser incorreta e sua afirmativa sobre o direito ampla demais, mas elas nos indicarão sobre quais fatos ele alcançou sua conclusão” (Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 71).

113

“Uma conclusão fundamentada em um fato hipotético é um dictum. Por fato hipotético quer-se dizer de qualquer fato cuja existência não foi determinada ou aceita pelo juiz” (Arthur Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, cit., p. 26).

114

Neil Duxbury, Op. cit., p. 83.

115

“O poder do precedente depende de alguma assimilação entre o evento em comento e algum outro evento. (...) A tarefa de uma teoria de precedente é explicar, em um mundo em que um único evento pode ser enquadrado em várias categorias diferentes, como e por que algumas assimilações são plausíveis e outras não” (Frederick Schauer, “Precedent”, Stanford Law Review, vol. 39, n. 3, 1987, p. 577).

116

Não se olvidando, contudo, a opinião cética de Joseph Francis, que, em artigo escrito em 1929, em resposta ao “Three Cases on Possession”, de Arthur L. Goodhart, escreveu: “Se for verdade que o caminho para o progresso humano é coberto de princípios e conceitos mortos, então me atrevo a sugerir que o empenho em se encontrar a ratio decidendi de um caso em breve será visto sob o mesmo enfoque que aquele de um médico tentando localizar a ‘alma’” (Joseph Francis, “Three Cases on Possession – Some Further Observations”, St. Louis Law Review, vol. 11, 1928). Ainda, vide Robert Scofield, “Goodhart’s Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century”, King’s College Law Journal, vol. 16, 2005, p. 311-328.

117

Julius Stone (1907 – 1985), “The Ratio of the Ratio Decidendi”, The Modern Law Review, vol. 22, 1959, p. 597.

118

Rupert Cross e J. W. Harris, Op. cit., p. 77.

119

Neil MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law, cit., p. 209. Neil Duxbury comunga da mesma crítica de MacCormick: “A suposição de Cross – de que a ratio é a ‘regra de direito’ que o juiz trata como necessária para uma decisão – não parece exatamente correta. Quando, por exemplo, um juiz interpreta uma lei no processo de proferir uma decisão, a ratio é o que o juiz crê ser a melhor interpretação da lei – a decisão do juiz, em outras palavras, em vez da regra legal” (Neil Duxbury, Op. cit., p. 77).

120

Neil Duxbury, Op. cit., p. 78.

121

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, cit., p. 209.

122

Idem, p. 210.

123

Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 81 e ss.

124

Neil Duxbury, *Op. cit.*, p. 75; Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 38.

125

Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 83.

126

Idem, p. 42.

127

Idem, *ibidem*.

128

Idem, p. 43.

129

Idem, *ibidem*.

130

É por essa razão que Ronald Dworkin compara, adequadamente, o delineamento da *ratio decidendi* com um romance que vai sendo escrito em capítulos (“*Law as Interpretation*”, *Texas Law Review*, vol. 60, p. 527-550).

131

“Não há dois eventos exatamente iguais. Para que uma decisão seja precedente para outra decisão, não há necessidade de que os fatos dos casos anteriores e posteriores sejam absolutamente idênticos. Caso isso

fosse exigido, nada seria precedente para nenhum outro caso” (Frederick Schauer, “Precedent”, cit., p. 575).

132

Arthur Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, cit., p. 17-18.

133

“... é cristalino que a relevância de um precedente anterior depende de como caracterizamos os fatos presentes no caso anterior” (Frederick Schauer, “Precedent”, cit., p. 575).

134

De acordo com Frederick Schauer, “a tarefa de uma teoria de precedente é explicar, em um mundo em que um único evento pode ser enquadrado em várias categorias diferentes, como e por que algumas assimilações são plausíveis e outras não” (idem, p. 577).

135

A cumulação de pedidos pode ser simples ou eventual. A cumulação simples é caracterizada pela autonomia entre os pedidos (art. 327, CPC/2015), ao passo que a cumulação eventual é caracterizada pela dependência – o pedido formulado de maneira sucessiva ou alternativa só será examinada se o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado de forma principal ou prioritária (Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 161-163, vol. II).

136

Arthur Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, cit., p. 17-18.

137

Rupert Cross e J. W. Harris, Op. cit., p. 43.

138

Patrícia Perrone Campos Mello, Precedentes, cit., p. 148 e ss.

139

STF, Rcl 1.987, Pleno, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.05.2004.

140

Idem.

141

Outra reclamação voltou a tratar do assunto. Na Rcl 4.219 existiam nove votos tratando da questão quando, em virtude do falecimento do reclamante, julgou-se prejudicado o pedido. Tinham votado pela admissibilidade da reclamação os Ministros Eros Grau, Cezar Peluzo, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Em sentido contrário, votaram os Ministros Joaquim Barbosa (relator), Sepúlveda Pertence, Ricardo Lewandowski, Carlos Brito e Cármen Lúcia. Restavam os votos dos Ministros Ellen Gracie e Marco Aurélio.

142

STF, Rcl 1.987, voto do Ministro Carlos Velloso.

143

Idem, voto do Ministro Carlos Britto.

144

Idem, manifestação do Ministro Sepúlveda Pertence.

145

“Mas, Senhor Presidente, há mais na hipótese: verificamos que o fator cronológico é contrário à admissibilidade, como já ressaltado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, desta reclamação. Por que? Porque na ADIn 1.662 – se não me falha a memória –, cujo acórdão se diz descumprido, fulminamos um ato de 1997, e a base da decisão proferida pela louvável Justiça do Trabalho é um diploma posterior, é a EC 30, de 2000. Mas parte-se para o princípio da transcendência – e, aí vislumbra-se a coisa julgada quanto aos fundamentos da decisão da Corte. Nem mesmo no campo civil temos coisa julgada de fundamentos. A coisa julgada diz respeito, de início – como está no art. 469 do CPC – à parte dispositiva do julgado” (STF, Rcl 1.987, voto do Ministro Marco Aurélio). Nota: a alusão ao art. 469 concerne ao CPC de 1973.

146

“As decisões do Tribunal Constitucional alemão têm eficácia vinculante (Bindungswirkung) por disposição legal, conforme o § 31, 1, da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional”.

147

STF, Rcl 1.987, voto do Ministro Gilmar Mendes.

148

Idem, cf. voto do Ministro Gilmar Mendes.

149

Esse é um ponto de congruência entre os sistemas americano e alemão. Tanto num quanto noutro só irradiam efeitos vinculantes os motivos determinantes da decisão, isto é, a própria ratio decidendi.

Questões ditas de passagem (*obiter dicta*) não têm força vinculante, como de resto também reconhece o nosso Supremo Tribunal Federal (STF, Informativo 335).

150

Outra situação diz respeito a se saber se a coisa julgada, relativa a decisão de constitucionalidade, impede que o Supremo Tribunal Federal, mais tarde, chegue à conclusão de que a norma, então declarada constitucional, é inconstitucional. Neste caso, o problema toca no tema da coisa julgada material e não na questão da *ratio decidendi* ou da eficácia vinculante dos motivos determinantes da decisão de inconstitucionalidade.

151

Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 37.

152

Neil Duxbury, *Op. cit.*, p. 67.

153

Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 37.

154

“A busca pela *ratio decidendi* é primariamente uma peculiaridade do processo judicial da Inglaterra, Escócia, e daqueles países cujo sistema legal deriva do nosso. Na Cour de Cassation da França, as razões para uma decisão são ditas bastante sucintamente e tudo que diz respeito à natureza de um discurso geral é proibido, ao menos naquilo que diz respeito a todas as Cortes civis francesas. O resultado é que discussões continentais sobre o assunto das decisões judiciais não compartilham da preocupação dos escritores que discutem a jurisprudência anglo-americana no que tange ao método de distinção entre *ratio decidendi* e *obiter dictum*” (Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 47).

155

“Algumas partes de uma opinião não são formalmente vinculantes como precedente. Isso é verdade acerca das compreensões ou opiniões de uma Corte que não sejam necessárias à solução da questão específica apresentada à Corte. Essa terminologia é chamada *dicta* e é geralmente não vinculante. Como mencionado, *dicta* são normalmente definidas simplesmente como declarações presentes na opinião ‘não necessárias’ à decisão da Corte sobre a questão ou as questões” (Robert Summers, *Op. cit.*, p. 384).

156

Neil Duxbury, *Op. cit.*, p. 68.

157

Robert Summers, Op. cit., p. 385.

158

Rupert Cross e J. W. Harris, Op. cit., p. 81 e ss.

159

Idem, p. 82-83.

160

Rupert Cross e J. W. Harris, Op. cit., p. 83.

161

Idem.

162

Thomas W. Merrill, “Judicial Opinions as Binding Law and as Explanations for Judgments”, *Cardozo Law Review*, New York, vol. 15, out. 1993.

163

Rupert Cross e J. W. Harris, Op. cit., p. 82.

164

“Juristas e juízes do direito jurisprudencial têm, em algumas oportunidades, tentado acumular distinções sobre a distinção básica entre ratio-obiter – argumentando que um caso pode conter um holding que seja mais impositivo que uma ratio decidendi, e que pode haver judicial dicta que seja menos impositiva que as rationes decidendi, porém mais impositivas que qualquer outro obiter dictum. No entanto, é a distinção básica que tem perdurado” (Neil Duxbury, Op. cit., p. 68).

165

O Superior Tribunal de Justiça, ao realizar juízo de admissibilidade de recurso especial, já aludiu à distinção entre obiter dictum e ratio decidendi. Veja-se acórdão de relatoria da Ministra Denise Arruda: “Processual civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso especial. Administrativo. Energia elétrica. Interrupção do serviço. 1. O Tribunal local, embora reconhecendo que é indevida a manutenção do serviço em comento quando inadimplente o usuário, com base nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que o ‘direito à saúde merece maior destaque em relação às demais situações’, fazendo referência expressa ao art. 196 da CF/88. A eliminação de tal premissa importa necessariamente a conclusão de que seria viável a interrupção do serviço. 2. Desse modo, a premissa referida não constitui mero obiter dictum, como argumenta a agravante, mas ratio decidendi, que deveria necessariamente ser impugnada pela via adequada (recurso extraordinário). Tal descuido obsta o exame do recurso especial

(Súmula 126/STJ). 3. Agravo regimental desprovido” (STJ, 1.^a T., AgRg no Ag 739.535, rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.2006).

166

Contudo, sendo a aplicação do brocardo iura novit curia precedido do devido diálogo com as partes, em face do direito ao contraditório, nada obsta a que os fundamentos da decisão venham a ser considerados para efeitos de formação da ratio decidendi. V. Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil* (2009), 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 87-90.

167

Rupert Cross e J. W. Harris, *Op. cit.*, p. 77.

168

STJ, 3.^a T., REsp 954.859, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 27.08.2007.

169

Idem.

170

“Lei 11.232/2005 – Art. 475-J, CPC [1973] – Cumprimento da sentença – Multa – Termo inicial – Intimação da parte vencida – Desnecessidade. 1. A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia certa consoma-se mediante publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la. 3. Cabe ao vencido cumprir espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob pena de ver sua dívida automaticamente acrescida de 10%” (STJ, 3.^a T., REsp 954.859, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 27.08.2007).

171

Acórdão proferido no AgRG na Rcl 2.475, STF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 02.08.2007.

172

Idem.

173

Idem.

174

Idem.

175

Idem.

176

Idem.

177

Idem.

178

Idem.

179

Idem.

180

Voto do Min. Carlos Velloso no AgRg na Rcl 2.475, STF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.02.2008.

181

Ver STF, ADInMC 2.396-MS, rel. Min. Ellen Gracie, DJU 26.09.2001.

182

Voto do Min. Carlos Velloso no AgRg na Rcl 2.475, STF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.02.2008.

183

Voto do Min. Gilmar Mendes no AgRg na Rcl 2.475, STF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.02.2008.

184

Acórdão proferido no AgRg na Rcl 2.475, STF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.02.2008.

185

Neil Duxbury, Op. cit., p. 113.

186

“O juiz que tenta ‘distinguir’ casos com base em fatos materialmente irrelevantes está propenso a ser facilmente descoberto. Advogados e outros juízes que têm razões para controlar sua atividade, provavelmente não terão dificuldade em evidenciar a sua atitude como de alguém descuidado ou desonesto, e, então, sua reputação será desgastada e a sua decisão questionada. O fato de os juízes terem o poder de ‘distinguir’ não significa que eles podem negar os precedentes quando lhes for conveniente” (idem, p. 114).

187

Idem, ibidem.

188

Idem, p. 115.

189

Idem, ibidem.

190

Idem, ibidem.

191

Idem, p. 116.

192

Patrícia Perrone Campos Mello, Op. cit., p. 201 e ss.

193

Frederick Schauer, *Thinking like a Lawyer*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009, especialmente itens 5, 8 e 9.

194

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios* (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 194 e ss.

195

Benjamin Cardozo (1870 – 1938), *The Nature of Judicial Process*. New Haven: Yale University Press, 1921, p. 166-167.

196

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios* (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016; Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016; Hermes Zaneti Júnior, *O Valor Vinculante dos Precedentes* (2015), 2. ed. Salvador: JusPodium, 2016; Marco Félix Jobim, “A Técnica do Distinguishing a Partir da Análise do Julgamento do Caso Escola vs. Coca-Cola Bottling Co.”, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 237.

197

STF, Pleno, HC 85.185/1, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01.09.2006.

198

Idem.

199

Idem.

200

Idem.

201

Idem.

202

Idem.

203

Idem.

204

Idem.

205

Idem.

206

1.^a T., Pet. 1189 AgRg, rel. Min. Moreira Alves, DJ 29.10.1996. No mesmo sentido, STF, 1.^a T., Pet. 1189

AgRgEDcl, rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.03.1997; 2.^a T., Pet. 1327 AgRg, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.03.1998; 2.^a T., Pet. 1334 AgRg, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.03.1998; 2.^a T., Pet. 1336 AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 06.03.1998; 2.^a T., Pet. 1341 AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 06.03.1998; 1.^a T., Pet. 1962 AgRg, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 23.06.2000.

207

STF, 2.^a T., AC 1.549, rel. Min. Celso de Mello, DJU 31.10.2007. Ver RTJ 174/437, 191-123, 191-483.

208

O fato de a decisão poder produzir efeitos imediatos, ainda que não escoado o prazo recursal, gera a possibilidade de a decisão provocar danos já nos primeiros momentos de sua existência. Ou melhor, a decisão pode causar dano grave enquanto o recurso especial ou o recurso extraordinário é preparado para interposição, ou mesmo durante o seu processamento no tribunal de origem. Como a decisão pode provocar dano mesmo que o recurso especial ou o recurso extraordinário não tenha sido ainda interposto, é lógico que aí é cabível cautelar, a qual evidentemente não terá a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Na realidade, embora se fale, por facilidade de linguagem, em cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso, o correto é pensar em suspender os efeitos da decisão (objeto do recurso). Não se trata apenas de precisão conceitual, mas, sobretudo, da necessidade de evidenciar que é a decisão que pode trazer dano grave, pouco importando o fato de o recurso já ter sido interposto. Portanto, presentes o *fumus boni iuris* e a probabilidade de dano, cabe cautelar para suspender os efeitos da decisão, mesmo que ainda não tenha sido interposto recurso especial ou recurso extraordinário, e, com muito mais razão, nos casos em que o recurso foi interposto e é esperado o juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Porém, na hipótese em que o recurso ainda não foi interposto, o autor da cautelar deverá anunciar sua interposição, até porque a tutela cautelar é vinculada a esse recurso, ou melhor, só tem razão de ser quando interposto o recurso. De outra parte, alguém poderia supor que, enquanto não proferido juízo de admissibilidade no tribunal de origem, a competência para o julgamento da cautelar é desse tribunal, e não do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Isso sob o argumento de que o *fumus boni iuris* teria íntima relação com a decisão a respeito da admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário. Em outras palavras: não seria possível apreciar o *fumus boni iuris* da cautelar, que tem relação com a probabilidade de êxito do recurso, antes de o tribunal de origem analisar sua admissibilidade, sob pena de restar alterada a “ordem das coisas”. O raciocínio tem lógica em um primeiro instante, mas não sobrevive à constatação de que o que se deve proibir, na verdade, é a possibilidade de o tribunal de origem adentrar na apreciação do mérito do recurso. Dando-se ao tribunal local competência para julgar a cautelar, confere-se a ele o poder de apreciar, ainda que com base em probabilidade, o mérito do recurso. Se ao tribunal de origem for dada competência para a cautelar, esse tribunal poderá inibir os efeitos da sua decisão em razão de um recurso que não lhe cabe julgar, mas apenas admitir ou não. Lembre-se, por outro lado, que o juízo de inadmissibilidade do recurso pode ser reelaborado pelo STJ ou pelo STF em razão de agravo de instrumento. Neste caso, aliás, mostra-se ainda mais relevante a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, já que a execução provisória que se faz na pendência do exame deste agravo de instrumento, na atual sistemática do Código de Processo Civil, dispensa até a caução para a prática de atos que importem o levantamento de dinheiro (ressalvadas hipóteses de haver dano grave, de difícil ou incerta reparação). Se a necessidade de cautelar tivesse relação apenas com o juízo de admissibilidade no tribunal de origem, bastaria a decisão de inadmissibilidade para lhe retirar a razão de ser. Acontece que a decisão de inadmissibilidade pode ser atacada através de agravo de instrumento, quando, obviamente, o agravante poderá estar frente a

fundado receio de dano e, assim, ter necessidade de requerer ao STJ ou ao STF tutela capaz de suspender os efeitos da decisão recorrida. Como se vê, o ponto chave para a solução da questão está em que o direito de suspender os efeitos da decisão recorrida se liga ao julgamento do STJ ou do STF e não à decisão do tribunal de origem. No caso em que o perigo de dano é reconhecido – e esse é um dos requisitos da cautelar –, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal ficam investidos da competência de imediatamente apreciar a probabilidade de êxito do recurso. Aliás, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos recursos especial e extraordinário (respectivamente), podem fazer juízo de admissibilidade diverso daquele realizado pelo tribunal de origem.

209

STF, 2.^a T., AC 1.550, rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 18.05.2007.

210

Não é pelo fato de que o recurso extremo não foi admitido que a decisão não poderá causar dano ao recorrente. Se foi interposto agravo de instrumento contra a decisão de inadmissibilidade do recurso, é lógico que, durante o tempo para a definição da sorte dos recursos, poderá ser ocasionado dano grave. Na realidade, o pressuposto da probabilidade do dano não se modifica, quando se passa a pensar no agravo em substituição ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. O que merecerá maior atenção é a questão do *fumus boni iuris*, pois, se restou decidido não estarem presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, será possível concluir estar ausente o pressuposto da probabilidade de seu êxito. Nesta hipótese o perigo de dano sobressai, na medida em que a lei autoriza a dispensa de caução quando da execução provisória de decisão objeto de recurso não admitido por decisão atacada mediante agravo de instrumento. Supor que a cautelar não é admissível no caso de juízo negativo de admissibilidade, e que assim a cautelar não pode ser usada quando interposto agravo de instrumento, é o mesmo que concluir que o juízo de inadmissibilidade não pode ser modificado em sede de cautelar, ou que o *fumus boni iuris* da cautelar não pode ser objeto de juízo diverso ao daquele feito quando se decidiu pela inadmissibilidade do recurso. Entretanto, assim como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal podem, dando provimento ao agravo de instrumento, modificar a decisão de inadmissibilidade, eles podem entender estar presente o *fumus boni iuris*.

211

“Ação cautelar – Efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido pelo tribunal de origem – Agravo de instrumento pendente de julgamento – Medida cautelar concedida para suspender os efeitos do acórdão recorrido. 2. Em situações excepcionais, em que estão patentes a plausibilidade jurídica do pedido – decorrente do fato de a decisão recorrida contrariar jurisprudência ou súmula do Supremo Tribunal Federal – e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser consubstanciado pela execução do acórdão recorrido, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar ainda que o recurso extraordinário tenha sido objeto de juízo negativo de admissibilidade perante o Tribunal de origem e o agravo de instrumento contra essa decisão ainda esteja pendente de julgamento. 3. Hipótese que não constitui exceção à aplicação das Súmulas 634 e 635 do STF. 4. Suspensão dos efeitos do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, até que o agravo de instrumento seja julgado. 5. Ação cautelar deferida (STF, 2.^a T., AC 1.550, rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 18.05.2007). Ver STF, 2.^a T., AC 1772, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 09.11.2007; RTJ 192/778, 192-411, 95-139, 191-123, 174-437.

212

STF, 2.^a T., AC 1.550, rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 18.05.2007.

213

STF, 2.^a T., AC 1.549, rel. Min. Celso de Mello, DJU 31.10.2007.

214

STF, 2.^a T., AC 1.550, rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 18.05.2007.

215

STF, 2.^a T., AC 1.549, rel. Min. Celso de Mello, DJU 31.10.2007.

216

STF, 2.^a T., AC 1.550, rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 18.05.2007.

217

STF, MC no MS 26.325, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01.02.2007.

218

STF, Plenário, MC na ADC 4, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 21.05.1999.

219

STF, Plenário, AgRg na Rcl 5.174, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.02.2009.

220

STF, Plenário, AgRg na Rcl 5.042, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.02.2009.

221

STF, Plenário, AgRg na Rcl 4.628, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.02.2009.

222

STF, Plenário, AgRg na Rcl 5.163, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.02.2009.

223

“Reclamação – Cabimento – Afronta à decisão proferida na ADIn 1662-SP – Sequestro de verbas públicas – Precatório – Vencimento do prazo para pagamento – EC 30/2000 – § 2.º do art. 100 da CF. 1. Preliminar. Cabimento. Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato, administrativo ou judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa se dê de forma oblíqua. 2. Ordem de sequestro deferida em razão do vencimento do prazo para pagamento de precatório alimentar, com base nas modificações introduzidas pela EC 30/2000. Decisão tida por violada – ADIn 1.662-SP, Maurício Corrêa, DJ 19.09.2003: Prejudicialidade da ação rejeitada, tendo em vista que a superveniência da EC 30/2000 não provocou alteração substancial na regra prevista no § 2.º do art. 100 da CF. 3. Entendimento de que a única situação suficiente para motivar o sequestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas judiciais alimentares é a relacionada à ocorrência de preterição da ordem de precedência, a essa não se equiparando o vencimento do prazo de pagamento ou a não inclusão orçamentária. 4. Ausente a existência de preterição, que autorize o sequestro, revela-se evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na mencionada ação direta, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional. 5. Mérito. Vencimento do prazo para pagamento de precatório. Circunstância insuficiente para legitimar a determinação de sequestro. Contrariedade à autoridade da decisão proferida na ADIn 1.662. Reclamação admitida e julgada procedente” (STF, Pleno, Rcl 1.987, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.05.2004). Observação: O § 2.º do art. 100 da CF indicado no texto desse julgado é atualmente o § 1.º do mesmo artigo, por alteração efetuada pela EC 62/2009.

224

Observação: O § 2.º do art. 100 da CF indicado no texto é atualmente o § 1.º do mesmo artigo, por alteração efetuada pela EC 62/2009.

225

“Reclamação – Precatório decorrente de indenização expropriatória – Não pagamento – Sequestro de verbas públicas – Alegado descumprimento ao que decidido na ADIn 1.662-DF – Descumprimento não configurado – Reclamação julgada improcedente. 1. A decisão proferida na ADIn 1.662-DF versou sobre a satisfação de precatórios e ofícios requisitórios decorrentes de créditos de natureza alimentar, nos termos do art. 100, § 2.º, da CF. 2. Decisão reclamada que tem origem em ação de desapropriação e ordem de sequestro fundamentada no art. 78, § 4.º, do ADCT. 3. Ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação-paradigma. 4. Reclamação julgada improcedente, cassada a liminar deferida e prejudicado o exame do agravo regimental” (STF, Pleno, Rcl 5.928, rel. Min. Carmen Lúcia, DJE 11.09.2009). Observação: O § 2.º do art. 100 da CF indicado no texto desse julgado é atualmente o § 1.º do mesmo artigo, por alteração efetuada pela EC 62/2009.

226

STF, Pleno, Rcl 3.293, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.04.2007.

227

Zenon Bankowski, Neil MacCormick e Geoffrey Marshall, “Precedent in the United Kingdom”, in *Interpreting Precedents*, cit., p. 329.

228

Idem, *ibidem*.

229

Nos Estados Unidos, há muito são enfatizadas “as possibilidades de mudança e desenvolvimento no direito que são oferecidas pela revogação de precedentes em situações apropriadas. Nas palavras do Justice Field: ‘É mais importante que a Corte esteja certa sobre considerações posteriores e mais elaboradas sobre os casos do que coerente com declarações anteriores’. O Justice Cardozo observou que ‘todo o tema da jurisprudência é mais plástico, mais maleável, as formas menos definidas, os limites entre o certo e o errado menos previsíveis e constantes do que a maior parte de nós... está acostumada a crer’” (Margaret Kniffin, “Overruling Supreme Courts Precedents: Anticipatory Action by United States Courts of Appeals”, *Fordham Law Review*, 1982, p. 55).

230

Deixe-se claro, não obstante, que Eisenberg, ao aludir aos valores da estabilidade, também se refere aos valores da replicability e do support. De acordo com Eisenberg, um precedente deve ser revogado (overruled) se (i) falhou substancialmente em satisfazer os padrões de congruência social e consistência sistêmica e (ii) os valores que sustentam o padrão de estabilidade jurisprudencial e o princípio do stare decisis – valores de isonomia, proteção da confiança justificada, prevenção da surpresa injusta, “repetitividade” e “fundamentação” – não serviriam melhor à preservação do precedente do que à sua revogação (Eisenberg, *Op. cit.*, p. 104).

231

Idem, p. 104 e ss.

232

Idem, p. 14, 26 e 37.

233

Idem, p. 14, 28 e 39.

234

“Os entendimentos controversos preenchem a primeira condição do princípio básico do overruling. Eles são socialmente incongruentes; é por isso que passam a se sujeitar a exceções inconsistentes. São sistemicamente inconsistentes, em parte por causa da inconsistência entre o entendimento e as exceções, e em parte porque, em razão de sua incongruência social, são inconsistentes com outros entendimentos”

(idem, p. 105).

235

Howard Yale Lederman, “Judicial overruling” Michigan Bar Journal, vol. 83, 2004.

236

Melvin Eisenberg, Op. cit., p. 106.

237

Idem, ibidem.

238

Idem, p. 107-108.

239

Idem, p. 108-109.

240

“Tendo em vista que o entendimento da imunidade das instituições de caridade falhou substancialmente ao satisfazer o padrão de congruência social, este se tornou não apenas internamente, mas também externamente inconsistente – isto é, o entendimento era inconsistente não somente com suas exceções, mas também com outros entendimentos. (...) Quando as proposições sociais aplicáveis deixaram de sustentar a proposição de que os atos danosos dos dois tipos de instituições eram diferentes no que se refere à responsabilidade, tornou-se inconsistente manter uma instituição responsável por seus atos prejudiciais e a outra não” (idem, p. 109).

241

Idem, ibidem.

242

Idem, p. 110.

243

Idem, p. 110-111.

244

Idem, p. 111.

245

Idem, p. 114.

246

“O que foi dito sobre a confiança justificada também se aplica à surpresa injusta. (...). À imunidade faltava congruência com as normas e políticas socialmente aplicáveis. Revogar a imunidade não mudaria uma regra de conduta primária socialmente aceita. Finalmente, a revogação era prevista por uma série de distinções inconsistentes, que explicitavam a crítica ao precedente realizada na doutrina, e nas decisões de outros Estados. Pelas mesmas razões, as seguradoras não seriam surpreendidas negativamente, e, se atuassem de forma racional, levariam em conta os riscos do overruling ao fixar seus prêmios” (idem, p. 115).

247

Stephen Markman, “Precedent: Tension between Continuity in the Law and the Perpetuation of Wrong Decisions”, Texas Review of Law and Politics, 2004.

248

Caleb Nelson, “Stare Decisis and Demonstrably Erroneous Precedents”, Virginia Law Review, 2001, n. 87.

249

Michael Gerhardt, The Power of Precedent. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 18-19.

250

Mark Alan Thurmon, “When the Court Divides: Reconsidering the Precedential Value of Supreme Court Plurality Decisions”, Duke Law Journal, 1992, vol. 42; Evan H. Caminker, “Sincere and Strategic Voting Norms on Multimember Courts”, Michigan Law Review, 1999, vol. 67; Sarah K. Delaney, “Stare decisis v. The ‘New Majority’: the Michigan Supreme Court’s Practice of Overruling Precedent, 1998-2002”. Albany Law Review, 2003, vol. 66.

251

A técnica do *overriding* já foi expressamente utilizada pelo Pleno do STF no RE n. 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 19.10.2016, DJE 31.03.2017.

252

Eisenberg, Op. cit., p. 135.

253

Espécie de compêndio, produzido pelo American Law Institute e elaborado por juristas e experts, que seleciona doutrinas das principais áreas do direito (como contratos, responsabilidade civil e propriedade), as quais são amplamente aplicadas pelos tribunais, embora não tenham força obrigatória.

254

Princípio do direito contratual estadunidense que expressa que os contratos portadores de obrigações abusivas, também conhecidos como “acordos inescrupulosos”, não são exigíveis judicialmente.

255

Melvin Eisenberg, Op. cit., p. 135.

256

Idem, p. 136.

257

Idem, ibidem.

258

“Uma vez que, tanto a transformation quanto o overruling envolvem a completa revogação de um precedente, a distinção entre os dois modelos é frequentemente mais formal do que substantiva” (Melvin Eisenberg, Op. cit., p. 133).

259

Idem, ibidem.

260

Idem, p. 134.

261

Idem, ibidem.

262

Idem, ibidem.

263

R. Davis, “A Re-examination of the Doctrine of MacPherson v. Buick and its Application and Extension in the State of New York”, Fordham Law Review, 1955.

264

Eisenberg, Op. cit., p. 134.

265

Eisenberg, Op. Cit., p. 121 e ss.

266

Idem, p. 122.

267

Idem, p. 121-122.

268

Idem, p. 122.

269

Idem, ibidem.

270

“A Corte, portanto, recusou-se a revogar Norcross, na medida em que ‘a confiança depositada pelos advogados no passado (...) deve pesar quando uma regra que afeta a propriedade imobiliária está envolvida’, e que, ‘neste caso, como provavelmente em muitas outras transações passadas, deve ter havido uma confiança razoável’ em Norcross e Shade” (idem, p. 123).

271

Idem, p. 122.

272

Idem, ibidem.

273

Anote-se que, em regra, o overruling tem efeitos retroativos. Apenas recentemente o overruling tem sido adotado com efeitos prospectivos (prospective overruling) nos Estados Unidos. Nestes casos, quando o

overruling não se aplica nem mesmo ao caso sob julgamento, fala-se em pure prospective overruling, e, quando o overruling se aplica apenas às situações ocorridas após determinada data, alude-se a prospective overruling. Vide Melvin Eisenberg, Op. cit., p. 127-128.

274

Maira Portes, “Instrumentos para Revogação de Precedentes no Sistema de Common Law”, Marinoni (coord.), A Força dos Precedentes – Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito Processual Civil da UFPR. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 103 e ss.

275

Howard Federman, “Judicial Overruling. Time for a New General Rule”. Michigan Bar Journal, 2004, p. 21 e ss.

276

Como refere Robert Summers que “a aplicação retroativa de uma decisão revogadora de precedente pode contrariar relevante confiança no precedente revogado e tratar partes em posições similares de modo muito diferente” (Robert Summers, Op. cit., p. 397-398).

277

Melvin Eisenberg, Op. cit., p. 131.

278

Bradley Scott Shannon, “The Retroactive and Prospective Application of Judicial Decisions”, Harvard Journal of Law & Public Policy, Cambridge, 2003, vol. 26.

279

Idem, p. 128.

280

Melvin Eisenberg, Op. cit., p. 128-129.

281

Idem, p. 127-128.

282

Idem, p. 128.

283

Em *Whitinsville Plaza, Inc. v. Kotseas*, a Corte afirmou que já havia sinalizado para a revogação do precedente firmado em *Norcross* no caso *Ouellette*, e, com base nisso, outorgou efeitos retroativos ao overruling, declarando que deveriam ser apanhados todos os negócios realizados após *Ouellette*. O overruling ditado em *Whitinsville* retroagiu até a decisão proferida em *Ouellette* porque a Corte entendeu que, a partir desta data, poder-se-ia racionalmente confiar na expectativa de que, na próxima ocasião adequada, a Corte iria revogar as decisões tomadas em *Shade* e em *Norcross*. Verifica-se aí nítida aproximação entre a técnica da sinalização e a do overruling com efeitos prospectivos.

284

Melvin Eisenberg, *Op. cit.*, p. 131.

285

Roger J. Traynor, “Quo Vadis, Prospective Overruling: a Question of Judicial Responsibility”, *Hastings Law Journal*, 1999, vol. 50.

286

Melvin Eisenberg, *Op. cit.*, p. 131.

287

Idem, p. 132.

288

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios* (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 166 e ss.

289

Cláudio Michelon, “Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica”, Macedo Júnior-Barbieri (coords.), *Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições*. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 267.

290

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios* (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 166 e ss.

291

Idem, p. 169-171.

292

Melvin Eisenberg, *Op. Cit.*, p. 14, 26 e 37.

Sobre o assunto, Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios* (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016; Idem, *O STJ enquanto Corte de Precedentes* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente* (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Idem, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016; Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*. São Paulo: Malheiros, 2011.

“Ação direta de inconstitucionalidade – Lei 7.619/2000, do Estado da Bahia, que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães – Inconstitucionalidade de lei estadual posterior à EC 15/1996 – Ausência de lei complementar federal prevista no texto constitucional – Afronta ao disposto no art. 18, § 4.º, da CF – Omissão do Poder Legislativo – Existência de fato – Situação consolidada – Princípio da segurança jurídica – Situação de exceção, estado de exceção – A exceção não se subtrai à norma, mas esta, suspendendo-se, dá lugar à exceção – Apenas assim ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção. 1. O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de fato, há mais de seis anos, como ente federativo. 2. Existência de fato do Município, decorrente da decisão política que importou na sua instalação como ente federativo dotado de autonomia. Situação excepcional consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia reconhecimento e acolhimento da força normativa dos fatos. 3. Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero exercício de subsunção. A situação de exceção, situação consolidada – embora ainda não jurídica – não pode ser desconsiderada. 4. A exceção resulta de omissão do Poder Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, desde a promulgação da EC 15, em 12 de setembro de 1996, deve-se à ausência de lei complementar federal. 5. Omissão do Congresso Nacional que inviabiliza o que a Constituição autoriza: a criação de Município. A não edição da lei complementar dentro de um prazo razoável consubstancia autêntica violação da ordem constitucional. 6. A criação do Município de Luís Eduardo Magalhães importa, tal como se deu, uma situação excepcional não prevista pelo direito positivo. 7. O estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é a exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá lugar à exceção – apenas desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção. 8. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção. 9. Cumpre verificar o que menos compromete a força normativa futura da Constituição e sua função de estabilização. No aparente conflito de inconstitucionalidades impor-se-ia o reconhecimento da existência válida do Município, a fim de que se afaste a agressão à federação. 10. O princípio da segurança jurídica prospera em benefício da preservação do Município. 11. Princípio da continuidade do Estado. 12. Julgamento no qual foi considerada a decisão desta Corte no MI 725, quando determinado que o Congresso Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei complementar federal referida no § 4.º do art. 18 da CF, considere, reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de Luís Eduardo Magalhães. Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de sua nulidade 13. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, mas não pronunciar a nulidade pelo prazo de 24 meses, da Lei 7.619, de 30 de março de 2000, do Estado da Bahia” (STF, Pleno, ADIn 2.240, rel. Min. Eros Grau, DJe 03.08.2007).

Parte final do voto do Min. relator, Eros Grau: “Permito-me observar ainda que no caso está em pauta o

princípio da continuidade do Estado, não o princípio da continuidade do serviço público. Os serviços públicos prestados pelo Município de Luís Eduardo Magalhães passariam a ser imediatamente prestados, se declarada a inconstitucionalidade da lei de sua criação, pelo Município de Barreiras, de cuja área foi destacado. Mas não é disso que aqui se cuida, senão da necessária, imprescindível afirmação, por esta Corte, do sentido normativo veiculado pelo art. 1.º da CF: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. É o princípio da continuidade do Estado que está em pauta na presente ADIn, incumbindo-nos recusar o fiat justitia, pereat mundus. Por certo que a afirmação da improcedência da ADIn não servirá de estímulo à criação de novos municípios, indiscriminadamente. Antes, pelo contrário, há de expressar como que um apelo ao Poder Legislativo, no sentido de que supra a omissão constitucional que vem sendo reiteradamente consumada. Concluído, retornarei à observação de Konrad Hesse: também cumpre a esta Corte fazer tudo aquilo que seja necessário para impedir o nascimento de realidades inconstitucionais, mas indispensável há de ser, quando isso seja possível, que esta mesma Corte tudo faça para pô-la, essa realidade, novamente em concordância com a Constituição. As circunstâncias da realidade concreta do município de Luis Eduardo Magalhães impõem seja julgada improcedente a ADIn” (STF, Pleno, ADIn 2.240, rel. Min. Eros Grau, DJe 03.08.2007).

296

Idem.

297

Idem.

298

Idem.

299

Idem.

300

Idem.

301

Idem.

302

Voto do Ministro Marco Aurélio: “Presidente, peço vênica para cingir-me à concepção que tenho sobre as normas de regência da matéria, ao alcance que dou ao art. 18, § 4.º, da CF e ao art. 27 da Lei 9.868/1999, não estabelecendo solução prática, pouco importando o Município, fora desses mesmos parâmetros. Hoje, há autorização – e sob esse preceito foi criado o Município – que não se torna efetiva ante a inexistência

de atividade legiferante do Congresso quanto à lei complementar que fixaria as balizas temporais, afastando, quem sabe, o ano das eleições – segundo memorial recebido, esse Município foi criado em ano de eleições – e, também, os requisitos a serem atendidos. Portanto, julgo procedente o pedido formulado” (idem).

303

Idem.

304

Na ADIn 3.615, tratando de caso semelhante, a Corte julgou procedente a ação direta, atribuindo à decisão de inconstitucionalidade efeitos ex nunc: “Ação direta de inconstitucionalidade – Art. 51 do ADCT do Estado da Paraíba – Redefinição dos limites territoriais do Município do Conde – Desmembramento de parte de município e incorporação da área separada ao território da municipalidade limítrofe, tudo sem a prévia consulta, mediante plebiscito, das populações de ambas as localidades – Ofensa ao art. 18, § 4.º, da CF. 1. Para a averiguação da violação apontada pelo requerente, qual seja o desrespeito, pelo legislador constituinte paraibano, das exigências de consulta prévia e de edição de lei estadual para o desmembramento de município, não foi a norma contida no art. 18, § 4.º, da CF substancialmente alterada, uma vez que tais requisitos, já existentes no seu texto primitivo, permaneceram inalterados após a edição da EC 15/1996. Precedentes: ADIn 458, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 11.09.1998, e ADIn 2.391, rel. Min. Ellen Gracie, Informativo STF 316. 2. Afastada a alegação de que a norma impugnada, sendo fruto da atividade do legislador constituinte estadual, gozaria de uma inaugural presunção de constitucionalidade, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, o exercício do poder constituinte deferido aos Estados-membros está subordinado aos princípios adotados e proclamados pela Constituição Federal. Precedente: ADIn 192, rel. Min. Moreira Alves, DJ 06.09.2001. 3. Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias, favoráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de município, não são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pelo § 4.º do art. 18 da CF. Precedente: ADIn 2.994, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 04.06.2004. A esse rol de instrumentos ineficazes que buscam driblar a exigência de plebiscito expressa no art. 18, § 4.º, da CF soma-se, agora, este de emenda popular ao projeto de Constituição Estadual. 4. Ação direta cujo pedido se julga procedente, com a aplicação de efeitos ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99” (STF, Pleno, ADIn 3.615, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 09.03.2007). É importante registrar parte do voto da Ministra relatora, Ellen Gracie: “Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado na presente ação direta e declaro a inconstitucionalidade do art. 51 do ADCT do Estado da Paraíba. Nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, proponho, porém, a aplicação ex nunc dos efeitos dessa decisão. Justifico. Nas mais recentes ações diretas que trataram desse tema, normalmente propostas logo após a edição da lei impugnada, se tem aplicado o rito célere do art. 12 da Lei 9.868/1999. Assim, o tempo necessário para o surgimento da decisão pela inconstitucionalidade do diploma dificilmente é desarrazoado, possibilitando a regular aplicação dos efeitos ex tunc. Nas ações diretas mais antigas, por sua vez, era praxe do Tribunal a quase imediata suspensão cautelar do ato normativo atacado. Assim, mesmo que o julgamento definitivo demorasse a acontecer, a aplicação dos efeitos ex tunc não gerava maiores problemas, pois a norma permanecera durante todo o tempo com sua vigência suspensa. Aqui, a situação é diferente. Contesta-se, em novembro de 2005, norma promulgada em outubro de 1989. Durante esses dezesseis anos, foram consolidadas diversas situações jurídicas, principalmente no campo financeiro, tributário e administrativo, que não podem, sob pena de ofensa à segurança jurídica, ser desconstituídas desde a sua origem. Por essa razão, considero presente legítima hipótese de aplicação de efeitos ex nunc da declaração de

inconstitucionalidade” (STF, Pleno, ADIn 3.615, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 09.03.2007).

305

William Michael Treanor, “Prospective Overruling and the Revival of Unconstitutional Statutes”, Columbia Law Review, New York, 1993, vol. 93.

306

Em decisão de 06.06.2002, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE 197.917-8, tratar-se de “situação excepcional em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex tunc, resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente”. Assim, proclamou: “Prevalência do interesse público para assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro futuro à declaração incidental de inconstitucionalidade” (STF, Plenário, RE 197.917, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 07.05.2004).

307

Ana Paula Ávila, A Modulação de Efeitos Temporais pelo STF no Controle de Constitucionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

308

STJ, 1.^a Seção, EDiv no REsp 738.689, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 22.10.2007.

309

Idem.

310

Idem.

311

Idem.

312

Idem. O Ministro João Otávio de Noronha, acrescentando que “o efeito prospectivo e a modulação do julgamento têm o condão, exatamente, de permitir a uma Corte Superior transcender o interesse individual e fazer prevalecer a própria credibilidade do Poder Judiciário”, acompanhou o voto do Ministro Hermann Benjamin.

313

Idem.

314

Idem.

315

Luiz Guilherme Marinoni, O STJ enquanto Corte de Precedentes (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

316

STJ, 5.^a T., HC 28.598/MG, rel. Min. Laurita Vaz, DJ 01.08.2005.

317

A própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de declarar que este Tribunal “foi concebido para um escopo especial: orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se assim ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para se manter firme e coerente. Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal Federal, de quem o STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o Poder Judiciário mantém sagrado compromisso com a justiça e a segurança” (STJ, Corte Especial, AgRg nos EResp 228432, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 18.03.2002).

318

Humberto Ávila, Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 465-490.

319

Como estimou equivocadamente o STF, Pleno, RE 212.484-RS, rel. Min. Ilmar Galvão, rel. para acórdão Min. Nelson Jobim, j. em 05.03.1998, DJ 27.11.1998, p. 22.

320

Humberto Ávila, Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 479.

321

Luiz Guilherme Marinoni, A Intangibilidade da Coisa Julgada diante da Decisão de Inconstitucionalidade (2008), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016; Idem, Precedentes Obrigatórios (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016; Idem, O STJ enquanto Corte de Precedentes (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Idem, Precedentes – da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Ed. RT, 2016; Humberto Ávila, Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011.

322

Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 352-355; Luiz Guilherme Marinoni, *Coisa Julgada Inconstitucional*. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 93-135.

323

Para uma ampla análise do tema, Teori Zavascki, *Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional* (2001), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012; Teresa Arruda Alvim Wambier, *Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória* (2001), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 521-543.

324

Por todos, STJ, 1.^a Seção, AR 170-GO, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 12.12.1989, DJ 19.02.1990, p. 1.028.

325

STF, Pleno, RE n. 89.108/GO, rel. Min. Cunha Peixoto, j. em 28.08.1980, DJ 19.12.1980; STF, 1.^a Turma, RE n. 101.114/SP, rel. Min. Rafael Mayer, j. em 12.12.1983, DJ 10.02.1984; STF, 2.^a Turma, AgRg no RE n. 235.794/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 22.10.2002, DJ 14.11.2002.

326

STJ, Corte Especial, EREsp 687.903/RS, rel. Min. Ari Pargendler, j. em 04.11.2009, DJe 19.11.2009; STJ, 1.^a Seção, EREsp 608.122/RJ, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 09.05.2007, DJe 28.05.2007.

327

STJ, 1.^a Turma, REsp 1.063.310/BA, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 07.08.2008, DJe 20.08.2008; contra, aplicando a Súmula 343, STF, em matéria infraconstitucional federal, por todos, STJ, 2.^a Turma, AgRg no REsp 1.301.531/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 14.08.2012, DJe 27.08.2012.

328

STF, Pleno, RE 590.809/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 22.10.2014.

329

STJ, 1.^a Turma, REsp 1.458.607/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 23.10.2014.

330

STF, Pleno, RE 89.108/GO, rel. Min. Cunha Peixoto, j. em 28.08.1980, DJ 19.12.1980, voto do Ministro Soares Muñoz, p. 963.

331

STF, Pleno, RE 89.108/GO, rel. Min. Cunha Peixoto, j. em 28.08.1980, DJ 19.12.1980, voto do Ministro Moreira Alves, p. 969-970.

332

STF, Pleno, RE 89.108/GO, rel. Min. Cunha Peixoto, j. em 28.08.1980, DJ 19.12.1980, voto do Ministro Thompson Flores, p. 997.

333

STF, Pleno, RE 81.429/SP, rel. Min. Cunha Peixoto, j. em 15.06.1977, DJ 31.10.1977, p. 7.586, voto do Ministro Moreira Alves, p. 418.

334

STF, 1.^a Turma, RE 101.114/SP, rel. Min. Rafael Mayer, j. em 12.12.1983, DJ 10.02.1984, voto do Ministro Rafael Mayer, p. 580.

335

STF, 2.^a Turma, AgRg no RE 235.794/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 22.10.2002, DJ 14.11.2002, voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 572.

336

Idem, p. 573.

337

STF, 2.^a Turma, AgRg no RE 235.794/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 22.10.2002, DJ 14.11.2002, ementa do julgado, p. 568.

338

STJ, Corte Especial, EREsp 687.903/RS, rel. Min. Ari Pargendler, j. em 04.11.2009, DJe 19.11.2009, voto do Ministro Ari Pargendler.

339

STJ, 1.^a Seção, EREsp n. 608.122/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 09.05.2007, DJe 28.05.2007, ementa do julgado.

340

STJ, 1.^a Turma, REsp 1.026.234/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27.05.2008, DJe 11.06.2008, ementa do julgado.

341

STF, Pleno, RE 89.108/GO, Rel. Min. Cunha Peixoto, j. em 28.08.1980, *DJ* 19.12.1980, voto do Ministro Moreira Alves, p. 969-970.

342

Aulis Aarnio, *The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987, p. 77.

343

José Rogério Cruz e Tucci, *Precedente Judicial como Fonte do Direito*. São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 162.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO II. DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL

Capítulo II. Da Ordem dos Processos no Tribunal

1. Processos nos Tribunais

Os arts. 929 a 946, CPC/2015, cuidam do modo pelo qual os órgãos judiciais nas Cortes de Justiça e nas Cortes Supremas devem conduzir os feitos. Isso quer dizer duas coisas: em primeiro lugar, que dentro da expressão “tribunal” cabem todos os tribunais que compõem o Poder Judiciário em nosso país (art. 92, CF/1988); em segundo, que dentro da expressão “processos” ingressam tanto os incidentes, como as ações originárias e os recursos.¹

Mais precisamente, esses dispositivos tratam do registro e da distribuição dos casos (arts. 929 e 930, CPC/2015), das atribuições do relator (arts. 931 a 933, CPC/2015), do presidente (art. 934, CPC/2015), do prazo de espera necessário para o julgamento (art. 935, CPC/2015), da ordem preferencial (art. 936, CPC/2015), da dinâmica (arts. 937 a 942 e 946, CPC/2015) e do registro e publicação do julgamento (arts. 943 e 944, CPC/2015). A análise desses dispositivos revela que o procedimento perante os Tribunais orbita basicamente em torno de dois grandes polos: relator e presidente do colegiado concentram em grande parte as posições jurídicas que marcam o encadeamento do procedimento perante os tribunais.² Ao relator compete praticar todos os atos tendentes a viabilizar o julgamento do caso – preferencialmente, o seu julgamento de mérito (arts. 6.º e 932, parágrafo único, CPC/2015);³ ao presidente compete dirigir o colegiado a fim de que o julgamento seja realizado de forma adequada, inclusive no que tange à forma pela qual as deliberações devem ocorrer (arts. 938 a 941, CPC/2015), bem como apropriadamente proclamado e documentado.

2. Regimentos Internos

Os dispositivos que tratam da ordem dos processos nos tribunais podem ainda ser complementados por outros existentes nos regimentos internos dos respectivos tribunais (art. 96, I, a, CF/1988). A Constituição refere que os tribunais poderão elaborar os respectivos regimentos internos dispendo sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos.

Os regimentos internos dos tribunais constituem atos normativos infralegais. São, portanto, semelhantes aos regulamentos administrativos, cuja principal nota está na sua subordinação à legislação e na consequente vedação à inovação legislativa no que tange à criação de direitos e deveres autônomos. Vale dizer: os regimentos internos têm por função organizar internamente os tribunais, distribuindo internamente a competência já estabelecida pela Constituição e pela legislação, seja no que tange ao funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais, seja no que concerne ao funcionamento dos seus órgãos administrativos.

Nesse particular, porém, merece uma observação a situação do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na medida em que esse foi recebido com força de lei pela Constituição de 1988. Isso se deve ao fato de a Constituição de 1967, depois de alterada pela Emenda de 1969, ter outorgado competência legislativa ao Supremo Tribunal Federal. Daí que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, naquilo que é recepcionado pela Constituição de 1988, só pode ser alterado por força de lei. Nada obstante, tudo que não conflite com semelhantes disposições pode

ser alterado pelo próprio Supremo Tribunal Federal.⁴

Art. 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição.

Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante delegação a órgãos de justiça de primeiro grau.

1. Protocolo

Protocolar significa registrar oficialmente. Daí que o protocolo constitui um documento – físico ou eletrônico – que assinala o registro oficial das causas que ingressam no tribunal.

A principal função do protocolo é assinalar o momento a partir do qual determinada ação, incidente ou recurso ingressou no tribunal. A partir daí podem os interessados requerer certidões na forma legal (art. 189, CPC/2015). Também é a partir do protocolo que as partes adquirem o direito ao recibo da entrega de petições e requerimentos (art. 201, CPC/2015).⁵

Os serviços de protocolo podem ser descentralizados, mediante delegação, aos órgãos de justiça de primeiro grau. É claro que semelhante disposição pressupõe a existência de processos físicos.⁶ Havendo delegação, a responsabilidade pela qualidade do serviço delegado é do órgão jurisdicional de primeiro grau. Em outras palavras, não pode a parte ser responsabilizada pela ausência de registro ou distribuição por defeito na prestação do serviço. O mesmo vale para a completude e a integridade dos documentos que eventualmente acompanhem as manifestações das partes, desde que devidamente indicadas pelos respectivos advogados em seus arrazoados.

2. Registro e Distribuição

Registrar significa anotar a existência de algo – no contexto, significa anotar a existência de ação, incidente ou recurso. Além de servir à memória, o registro destina-se à publicidade dos atos processuais (arts. 93, IX, CF/1988, 11 e 189, CPC/2015). Todas as causas estão sujeitas a registro (arts. 284 e 929, CPC/2015).

Depois de registradas as causas no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, os autos devem ser ordenados pela secretaria e distribuídos imediatamente (art. 929, CPC/2015). A distribuição obedecerá aos critérios legais (arts. 285 e 930, CPC/2015) a fim de concretizar o direito fundamental ao juiz natural (art. 5.º, XXXVII e LIII, CF/1988).⁷

O art. 929, CPC/2015, refere que a distribuição será imediata. Trata-se de regra que concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º, CPC/2015). Isso quer dizer que os regimentos internos dos tribunais não poderão dispor de forma contrária: uma vez ordenados os autos, impõe-se a imediata distribuição ao órgão competente. A alusão do art. 930, CPC/2015, ao regimento interno diz respeito à maneira como se articula a competência do tribunal para fins de distribuição, mas de modo nenhum apaga a necessidade de sua imediata realização. É vedada a “represa” de distribuição.⁸

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

1. Distribuição

Distribuir uma causa – incidente, ação ou recurso – significa atribuí-la a determinado julgador. Havendo mais de um órgão jurisdicional competente para o seu julgamento, distribui-se o feito levando-se em consideração a competência concorrente. Naturalmente, dentro do colegiado haverá distribuição entre os magistrados que o compõem. Nada obstante, ainda que exista apenas um órgão jurisdicional competente dentro do tribunal, ainda assim há que se observar a regra da

distribuição: nesse caso, distribui-se apenas entre os membros do órgão colegiado.

O juiz natural da causa no tribunal é o órgão fracionário. Não é, portanto, um dos magistrados que o compõe. Daí que a causa é em primeiro lugar atribuída, de acordo com a competência, ao colegiado; dentro do colegiado é que se procede à atribuição entre os seus componentes. Isso quer dizer que não é propriamente o primeiro destinatário da distribuição o magistrado; o primeiro endereço da distribuição é o órgão colegiado.⁹ É somente a partir de estabelecida a competência do órgão fracionário que se cogita da distribuição entre seus diferentes integrantes. Isso tanto é assim que, alterada a composição do órgão colegiado, não se altera a competência já firmada.

A fim de que a distribuição obste qualquer possibilidade de escolha do juízo, o que significaria evidente afronta ao direito fundamental ao juiz natural (arts. 5.º, XXXVII e LIII, CF/1988), o Código determina que seja realizada de forma alternada e por meio de sorteio. É igualmente o que afirma o art. 285, CPC/2015, quando afirma a necessidade de distribuição “alternada e aleatória”. Distribuição alternada é aquela que se sucede cada qual por sua vez – com espaços regulares repetidos. Distribuição aleatória é aquela que não obedece à prévia ordem. Distribuição alternada e aleatória, nada obstante, deve resultar também perante os tribunais em rigorosa igualdade de repartição de trabalho (analogicamente, art. 285, CPC/2015).

Haja vista a necessidade de se assegurar a aleatoriedade do juízo, veda-se a formação de litisconsórcio facultativo ulterior com o único objetivo de escolha do juízo após a distribuição do feito: pouco importa, aliás, se essa tentativa é realizada perante o juízo de primeiro grau ou perante os tribunais.¹⁰ É preciso fazer a ressalva ligada ao objetivo da distribuição por dependência, na medida em que o próprio Código admite como hipótese de distribuição a juízo prevento aquela em que há conexão entre as causas (arts. 286, I, e 930, parágrafo único, CPC/2015) – que, como é sabido, pode inclusive dar origem a um litisconsórcio facultativo, art. 113, II, CPC/2015.

Além de alternada e aleatória, a distribuição deve ser realizada mediante a devida publicidade. Como é sabido, a publicidade é essencial ao Estado de Direito¹¹ e constitui um dos traços mais marcantes de uma democrática administração da Justiça Civil (arts. 93, IX, CF/1988, e 11, CPC/2015).¹² A exigência de publicidade da distribuição prende-se, portanto, à transparência da administração judiciária, cujo mote está em viabilizar a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Judiciário.

Embora o ato de distribuição seja um ato administrativo do tribunal, o equívoco na sua realização pode dar azo à configuração de um vício capaz de violar o direito ao juiz natural – na sua dimensão de juiz constitucionalmente competente – sempre que a distribuição importar em julgamento por juiz absolutamente incompetente. Embora se possa a qualquer tempo, enquanto pendente o processo, remeter os autos ao juízo competente (art. 64, CPC/2015),¹³ não se pode excluir a possibilidade de ação rescisória por incompetência absoluta do juízo (art. 966, II, CPC/2015). É claro que a causa de rescindibilidade aí não é propriamente o ato de distribuição, mas o julgamento proferido pelo juízo absolutamente incompetente oriundo da distribuição equivocada.

2. Prevenção

Juízo prevento é aquele que primeiro conheceu determinada questão relativamente à causa. Tanto no primeiro grau de jurisdição (arts. 43 e 59, CPC/2015) como perante os tribunais (art. 930, parágrafo único, CPC/2015), o que determina a prevenção é a atribuição da causa ao julgador.

Note-se que os arts. 43 e 59, CPC/2015, falam em “registro” ou “distribuição”, ao passo que o art. 930, parágrafo único, CPC/2015, alude ao primeiro “recurso protocolado” no tribunal como elemento de definição de competência. Duas observações: em primeiro lugar, o ideal seria falar em “causa” e não “recurso”, porque a regra alcança também os incidentes e as ações originárias; em segundo lugar, o ideal seria falar em “distribuição” da causa, porque mesmo quando inexistente competência concorrente entre diferentes órgãos colegiados é necessário distribuir a um dos componentes do órgão colegiado a causa. Tudo somado, isso quer dizer que a regra de prevenção é

a mesma tanto no primeiro grau como nos tribunais: a atribuição da causa ao julgador torna prevento o juízo para os demais recursos, incidentes ou mesmo ações subsequentes no mesmo processo ou em processo conexo.

A supressão do órgão fracionário ou a alteração da sua competência absoluta determina a redistribuição da causa. A simples alteração de um dos componentes do colegiado, porém, não altera a competência e nem determina a redistribuição do feito. Segue-se aí a regra da perpetuação da competência (analogamente, art. 43, CPC/2015).

Art. 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de elaborar o voto, restitui-los-á, com relatório, à secretaria.

1. Elaboração do Voto

O relator tem por incumbência estudar a causa a fim de apresentá-la ao colegiado, acaso não seja hipótese de julgamento monocrático (art. 932, CPC/2015). A apresentação da causa deve ser a mais completa possível, expondo-se os principais acontecimentos do processo e os fundamentos que amparam as posições das partes. Nada obsta que o relator, tendo dúvida a respeito de como se posicionam as partes – ou uma das partes – diante de determinado ponto ou questão, determine o seu esclarecimento (art. 6.º, CPC/2015). Trata-se de providência que visa permitir uma melhor compreensão da controvérsia e, assim, uma melhor defesa das próprias posições jurídicas pelas partes.

Embora o voto seja redigido antes do julgamento, o que vai para os autos é apenas o relatório do caso. Trata-se de providência que objetiva evitar que as partes tomem contato com o posicionamento do relator a respeito da controvérsia antes do momento oportuno.

2. Nova Visão Jurídica da Causa e Necessidade de Vista às Partes

Ao analisar o caso, pode o relator concluir que esse – ou determinada questão sua – deve receber tratamento jurídico distinto daquele que encontrou até então pelo debate das partes. Não há dúvida de que o juiz pode qualificar juridicamente de modo diverso os fatos da causa, na medida em que ao juiz incumbe aplicar o direito (*Iura Novit Curia – Da Mihi Factum, Dado Tibo Ius*).¹⁴ Porém, é igualmente fora de dúvida que só poderá fazê-lo depois de ouvir as partes a respeito da nova visão jurídica que pretende imprimir à questão ou à causa, sob pena de violar o direito ao contraditório como direito de influência e prolatar uma decisão-surpresa, o que é sabidamente vedado em nossa ordem jurídica (arts. 5.º, LV, CF/1988, e 10, CPC/2015). Aliás, essa é a mesma lógica que preside o art. 933, CPC/2015.

O momento oportuno para que o relator abra vista às partes é justamente aquele cogitado pelo art. 931, CPC/2015. A diferença está em que, percebendo a possibilidade de enquadrar juridicamente os fatos de maneira diferente, ao invés de restituir os autos à secretaria a fim de que essa os alcance ao presidente do colegiado (art. 934, CPC/2015), o relator determinará a intimação das partes para que falem a respeito da possível solução da causa à luz do novo enquadramento proposto.

Longe de ser uma indevida antecipação do juízo, trata-se de saudável exercício de diálogo que visa tornar a decisão mais amadurecida e não surpreendente para as partes, portanto, tendencialmente melhor do ponto de vista do conteúdo e confiável do ponto de vista de sua produção. Assim, semelhante exigência encontra de um lado evidente respaldo no interesse público de chegar-se a uma solução bem amadurecida para o caso levado a juízo, não podendo ser identificada de modo nenhum como uma providência erigida no interesse exclusivo das partes.¹⁵ Consoante observa a doutrina, o debate judicial amplia necessariamente o quadro de análise, constrange ao cotejo de argumentos diversos, atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a formação de uma decisão mais aberta e ponderada.¹⁶ Funciona, pois, como um evidente instrumento de “democratização do processo”.¹⁷ De outro, conspira para reforçar a confiança do cidadão no Poder Judiciário, que espera legitimamente que a decisão judicial leve em consideração apenas proposições sobre as quais pode exercer o seu direito de conformar o juízo.¹⁸ Trata-se de

uma decorrência direta do direito ao contraditório como direito de influência e dever de debate (arts. 5.º, LV, e 93, IX, CF/1988, e 10 e 489, § 1.º, IV, CPC/2015). Vale dizer: trata-se de uma decorrência da transformação que o direito ao contraditório experimentou na cultura jurídica contemporânea.

A propósito, é preciso recordar que, em geral, do ponto de vista do seu conteúdo, o direito ao contraditório era identificado com a simples bilateralidade da instância, dirigindo-se tão somente às partes. Nesse contexto, o contraditório realizava-se apenas com a observância do binômio conhecimento-reação. Isto é, uma parte tinha o direito de conhecer as alegações feitas no processo pela outra e tinha o direito de, querendo, contrariá-las. Semelhante faculdade estendia-se igualmente à produção da prova. Trata-se de feição do contraditório própria à cultura do Estado Legislativo,¹⁹ confinando as partes, no fundo, no terreno das alegações de fato e da respectiva prova.

Nessa linha, o órgão jurisdicional nada teria que ver com a realização do direito ao contraditório, na medida em que apenas os litigantes seriam os seus destinatários. Partindo desse pressuposto, o Supremo Tribunal Federal já chegou a decidir que “a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tem como destinatários os litigantes em processo judicial ou administrativo e não o magistrado que no exercício de sua função jurisdicional, à vista das alegações das partes e das provas colhidas e impugnadas, decide fundamentadamente a lide”.²⁰

Atualmente, porém, a doutrina tem identificado no direito ao contraditório muito mais do que simples bilateralidade da instância. Ao binômio conhecimento-reação tem-se acrescentado a ideia de cabal participação como núcleo-duro do direito ao contraditório. É lógico que o contraditório, no processo civil do Estado Constitucional, tem significado completamente diverso daquele que lhe era atribuído à época do direito liberal. Contraditório significa hoje conhecer e reagir, mas não só. Significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência.²¹ Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou a gravar igualmente o juiz. Daí a razão pela qual eloquentemente se observa que o juiz tem o dever não só de velar pelo contraditório entre as partes, mas fundamentalmente a ele também se submeter. O juiz encontra-se igualmente sujeito ao contraditório.

Consequência dessa nova dimensão da matéria é que a dinâmica do processo é alterada significativamente. Por força dessa nova conformação da ideia de contraditório, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes (art. 10, CPC/2015). Em outras palavras, veda-se o juízo de terza via.²² Há proibição de decisões-surpresa (Verbot der Überraschungsentscheidungen).²³ O direito ao contraditório promove a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão nos atos jurisdicionais do Estado.

A razão pela qual o direito ao contraditório, inicialmente confinado às alegações de fato e ao terreno da prova, acabou avançando também para o âmbito das alegações jurídicas é muito clara: ao tempo em que se entendia que a jurisdição apenas interpretava uma norma preexistente e que para cada caso havia apenas uma norma aplicável (cognitivismo interpretativo), a legitimidade democrática da solução jurídica do caso advinha do fato de o caso ser resolvido por uma norma legitimada pela atuação do Poder Legislativo (democracia representativa). Quando se passou a entender que a jurisdição, ao interpretar, outorga um sentido possível ao texto, dentre vários aceitáveis (adscritivismo interpretativo), e que nem sempre é aplicável ao caso apenas uma única norma, a legitimidade democrática passou a depender não só da vinculação do juiz aos dispositivos da Constituição e da legislação aplicáveis, mas também da prévia oportunidade de participação das partes na decisão (democracia participativa). Portanto, é na teoria da interpretação que reside o elemento que justifica os novos contornos do direito ao contraditório no processo civil.²⁴

Essa nova ideia de contraditório, como facilmente se percebe, acaba alterando a maneira como o juiz e as partes se comportam diante da ordem jurídica. Nessa nova visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir

de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício²⁵ (art. 10, CPC/2015). Trata-se de exigência que se aplica em todos os graus de jurisdição – daí porque há oportunidade de sublinhá-la também na dinâmica dos julgamentos perante os tribunais.

Exigir-se que o pronunciamento jurisdicional tenha apoio tão somente em elementos sobre os quais as partes tenham tido a oportunidade de manifestarem-se significa evitar a decisão-surpresa no processo.²⁶ Nesse sentido, têm as partes de se pronunciar previamente à tomada de decisão também no que atine à eventual visão jurídica do órgão jurisdicional diversa daquela aportada por essas ao processo.²⁷ É por essa razão que o brocardo *Iura Novit Curia* só autoriza a variação da visão jurídica dos fatos alegados no processo acaso as partes tenham tido a oportunidade de se pronunciar previamente à tomada de decisão (art. 10, CPC/2015). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório.

3. Prazo Impróprio

O relator tem o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o caso e redigir o relatório e o seu voto. Como se trata de um dever, o prazo para o seu cumprimento é impróprio, vale dizer, não gera preclusão temporal acaso desatendido.

Art. 932. Incumbe ao relator:

I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI – decidir o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;

VII – determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII – exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível.

1. Poderes do Relator

O relator tem poderes para dirigir o processo (arts. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC/2015), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC/2015) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV e V, CPC/2015). Como parte do officium judicis, o relator tem o dever de exercer seus poderes independentemente de requerimento das partes.

Quando exerce sua competência para o julgamento de recursos, a outorga de poder ao relator visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC/2015, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator.²⁸

O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC/2015) e patrocinando sensível economia processual, promovendo por essa via um processo com duração razoável (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º, CPC/2015). Como observa a doutrina, não há aí um simples espaço de poder livre – o que há é um “dever-poder”.²⁹ Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC/2015, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária³⁰ e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária.³¹

2. Direção do Processo

Dentro do órgão fracionário competente, o relator é responsável pela direção do processo. Daí a razão pela qual tem poderes para determinar prova, homologar autocomposição das partes, determinar a intimação do Ministério Público e exercer outras atribuições que o Código refere e que eventualmente constem do regimento interno do respectivo tribunal.

Não há dúvida de que, nas instâncias ordinárias, isto é, nas Cortes de Justiça – Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais – é possível produzir prova, seja a requerimento da parte, seja por determinação do relator (arts. 370 e 932, I, CPC/2015). Isso porque, em primeiro lugar, juízes de primeiro grau e Cortes de Justiça têm o dever de dar tutela aos direitos em sua dimensão particular, o que impõe decidir o mérito do caso de forma justa e efetiva (art. 6.º, CPC/2015) – decisão justa que implica, de seu turno, adequada apuração da verdade das alegações de fato no processo.³² Em segundo lugar, porque sempre que for possível alegar fato novo perante o tribunal, deverá igualmente ser possível prová-lo (arts. 342, 493 e 1.014, CPC/2015). Cuida-se de desdobramento evidente do direito de ação e do direito de defesa, porque de nada adianta ser possível alegar, se não for possível provar. Em terceiro lugar, porque a previsão de possibilidade de produção de prova documental a qualquer tempo constante do art. 435, CPC/2015, observadas as exigências legais, e de inspeção judicial, art. 481, CPC/2015, levam à necessidade de se admitir a produção de todo e qualquer meio de prova perante as Cortes de Justiça, sob pena de distinção arbitrária na admissão da prova.³³

Além do art. 932, CPC/2015, o relator deve dirigir o processo observando no que couber igualmente o art. 139, CPC/2015. Em outras palavras: deve, dentre outras coisas, dirigi-lo de forma cooperativa (art. 6.º, CPC/2015), zelando pelo efetivo contraditório (arts. 7.º e 139, I, CPC/2015). Não por acaso o legislador particularizou o seu dever de prevenção no art. 932, parágrafo único, CPC/2015, e o seu dever de diálogo no art. 933, CPC/2015. Em outro dispositivo, refere o Código que, havendo a participação de amicus curiae no processo, compete ao relator delimitar os poderes que lhe serão reconhecidos (art. 138, § 2.º, CPC/2015).

3. Questões Incidentais

O relator é competente para decidir todas as questões incidentais que tenham lugar antes do julgamento colegiado. Decidir o pedido de tutela provisória e o pedido de desconsideração de personalidade jurídica são exemplos expressamente arrolados no art. 932, CPC/2015.

Uma questão incidental que pode surgir é aquela concernente à admissão de coisa julgada sobre questão prejudicial (art. 503, § 1.º, CPC/2015). Nada obsta que a questão concernente à possibilidade ou não de sua formação seja suscitada perante um tribunal. Nesse caso, o juízo de admissibilidade sobre a possibilidade de formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial compete ao relator. Outros exemplos: questões sobre a competência (aí incluída a questão a respeito, por exemplo, da prevenção do relator), sobre eventuais meios de prova admitidos originariamente pelo tribunal (por exemplo, a nomeação de um perito) e sobre a validade de determinada convenção processual apresentada originariamente perante o tribunal.³⁴

Em quaisquer dos casos, da decisão do relator caberá agravo interno (art. 1.021, CPC/2015).

4. Não Conhecimento

O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade no art. 932, III, CPC/2015. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal).

Antes de conhecer qualquer recurso, porém, tem o relator o dever de viabilizar ao recorrente a sanção do vício ou a complementação da documentação faltante (art. 932, parágrafo único, CPC/2015). Trata-se de dever de prevenção, decorrente da estrutura cooperativa do processo civil brasileiro (art. 6.º, CPC/2015).³⁵ O relator deve indicar especificamente qual o vício deve ser sanado ou qual é a documentação faltante (dever de esclarecimento).

Nesse particular, duas observações são importantes.

Em primeiro lugar, cumpre observar que o art. 932, parágrafo único, CPC/2015, alcança *toda e qualquer vício* capaz de inviabilizar o conhecimento – isto é, a admissibilidade – do recurso. Ressalvada a tempestividade recursal (analogicamente, art. 1.029, § 3.º, CPC/2015), todos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal são passíveis de correção. Se é verdade que constitui um dos objetivos do processo civil a viabilização de uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.º, CPC/2015), com o que há primazia do mérito no julgamento da causa, então é evidente que o art. 932, parágrafo único, CPC/2015, deve ser lido à luz dessa norma fundamental.

Em segundo lugar, é preciso distinguir a aplicação do art. 932, parágrafo único, CPC/2015, nas Cortes de Justiça e nas Cortes Supremas. Embora em todos os tribunais o dispositivo tenha o mesmo alcance, aplicando-se indistintamente a todo e qualquer vício capaz de inviabilizar o exame do mérito do recurso, nas Cortes Supremas a aplicação dos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3.º, CPC/2015, está subordinada à demonstração de que, a partir do julgamento do caso, poderá a Corte Suprema outorgar unidade ao direito.³⁶ Em outras palavras, não basta o intuito de viabilizar uma decisão de mérito justa e efetiva, na medida em que essas Cortes sabidamente não têm essa função. O que interessa para a sanção do vício é a possibilidade de, a partir do caso concreto, outorgar-se unidade ao direito brasileiro.

Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021, CPC/2015).

5. Provimento e Desprovimento

O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente quando esse for contrário aos precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC/2015). Pode igualmente provê-lo, mas aí se exige o contraditório (art. 932, V, CPC/2015).

Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC/2015, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento ao recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC/2015) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC/2015). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.

O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC/2015). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incs. IV e V do art. 932, CPC/2015, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.

Inconformada com a decisão do relator, pode a parte provocar a análise do colegiado competente para conhecer do recurso mediante a interposição de agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 2.º, CPC/2015). Observe-se que rigorosamente esse agravo apenas desobstrui a via normal do recurso originariamente interposto, permitindo o desembargo adequado da irresignação. Essa a sua função. Em outras palavras: o recurso originariamente interposto não vai suplantado pelo agravo interno, cuja única finalidade é permitir a análise pelo colegiado do recurso julgado monocraticamente. A análise que o colegiado realiza provendo o agravo é a do recurso originariamente interposto.

A jurisprudência é pacífica em exigir a interposição do agravo interno para o colegiado a fim de que se esgote a instância, viabilizando-se, assim, a interposição dos demais recursos eventualmente cabíveis (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência). Consoante a jurisprudência, o recurso especial, por exemplo, interposto diretamente da decisão monocrática do relator, não deve ser conhecido, porque não configura decisão de última instância.³⁷

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1.º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

§ 2.º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

1. Dever de diálogo

O fato e o direito supervenientes são atendíveis no julgamento das Cortes de Justiça (arts. 342, I, 493 e 933, CPC/2015) e, quando determinantes da perda do objeto recursal, também pelas Cortes Supremas. Conjuntamente com as questões apreciáveis de ofício ainda não debatidas, agregam-se ao objeto do recurso. Devidamente integrados ao objeto recursal nos limites assinalados, fato e direito superveniente e questões apreciáveis de ofício integram a cognição dos tribunais (arts. 933

e 1.034, parágrafo único, CPC/2015).³⁸

Todavia, como não é possível que exista julgamento definitivo válido sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercer o direito ao contraditório, aí entendido como direito de influência (arts. 9.º e 10, CPC/2015), que implica dever de diálogo (art. 489, § 1.º, IV, CPC/2015), a validade da utilização de material novo e ainda não debatido na decisão está condicionada justamente ao prévio debate com as partes. Vale dizer: o relator tem o dever de abrir a oportunidade para as partes falarem a respeito do fato e do direito supervenientes e das questões apreciáveis de ofício ainda não debatidas (art. 933, CPC/2015).

2. Momento

Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, o julgamento será imediatamente suspenso (art. 933, § 1.º, CPC/2015). Porém, estando as partes devidamente representadas na sessão – e concordando a respeito (analogamente, art. 190, CPC/2015) – poderão se manifestar específica e oralmente sobre a questão nova, sem suspensão do julgamento. Se a constatação ocorrer por lembrança de outro juiz, desembargador ou ministro que compõe o colegiado, esse deve encaminhar a questão ao relator a fim de que sejam tomadas as providências pertinentes (art. 933, § 2.º, CPC/2015).

Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

1. Publicidade

Em condições os autos, toca ao presidente do órgão fracionário designar data para julgamento, mandando publicar a pauta no órgão oficial. Todos os recursos, incidentes e ações originárias devem entrar em pauta, o que obviamente inclui o agravo interno e os embargos declaratórios, tendo em conta a necessidade de se assegurar o direito ao contraditório, na sua mais básica acepção de direito de informação (arts. 5.º, LV, CF, e 7.º, 9.º e 10, CPC/2015), e o direito à publicidade dos atos processuais (arts. 5.º, LX, e 93, IX, CF, e 11 e 189, CPC/2015), não só no que tange à observância do direito à informação pública, mas também a respeito do direito de se fazer presente na sessão de julgamento. Na publicação da pauta em que esteja designado o dia do julgamento, devem constar todos os elementos que servem à informação dos envolvidos no caso. Assim é que deve constar o nome das partes – e de todos os eventuais litisconsortes – e de seus respectivos advogados.

A ausência de publicação em pauta do dia do julgamento, bem como a omissão de uma das partes ou do respectivo advogado, gera a ineficácia do julgamento. Não se trata de requisito de existência³⁹ ou de validade.⁴⁰ A publicidade condiciona o julgamento: não diz respeito aos elementos para a sua existência ou validade. Em sendo omitida a parte vencedora, pode essa ter interesse em comparecer aos autos simplesmente para manifestar sua concordância com o julgamento, suprindo-se a condição de eficácia do ato. O comparecimento espontâneo das partes e de seus advogados à sessão de julgamento igualmente supre essa condição.

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

§ 1.º Às partes será permitida vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento.

§ 2.º Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento.

1. Pauta

Entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento mediará, pelo menos, o espaço de

5 (cinco) dias (art. 935, CPC/2015). Trata-se de prazo de espera, cujo objetivo está em possibilitar que as partes e os seus advogados, querendo, participem da sessão de julgamento. “A inobservância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes, acarreta nulidade” (Súmula 117, STJ). A súmula 117, STJ, continua sendo aplicável, observando-se, contudo, o prazo previsto no art. 934, CPC/2015. Rigorosamente, no entanto, a inobservância do prazo legal de espera acarreta a ineficácia do julgamento e não a sua nulidade. A solução aí está em refazê-lo. A pauta de julgamento deve ser afixada na entrada da sala em que ocorrerá a sessão de julgamento.

2. Nova Pauta

Os processos não julgados devem ser objeto de nova pauta, salvo se expressamente colocados na pauta da sessão subsequente por indicação do presidente do órgão julgador.

3. Vista dos Autos

As partes têm direito de acesso aos autos depois de publicada a pauta de julgamento. O direito é à vista dos autos na secretaria do órgão julgador, vedando-se implicitamente a retirada em carga.

Art. 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem:

- I – aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos;
- II – os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento;
- III – aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior; e
- IV – os demais casos.

1. Ordem

O art. 936, CPC/2015, apresenta a ordem em que os processos serão julgados na sessão. A sua não observância, acaso não gere prejuízo, não acarreta nulidade. Trata-se de simples irregularidade. A ressalva constante no início do dispositivo indica que semelhante ordem pode, ainda, ser objeto de modificação pelos regimentos internos dos tribunais.

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

- I – no recurso de apelação;
- II – no recurso ordinário;
- III – no recurso especial;
- IV – no recurso extraordinário;
- V – nos embargos de divergência;
- VI – na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;
- VII – vetado;

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

- IX – em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1.º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2.º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3.º Nos processos de competência originária previstos no inc. VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

§ 4.º É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.

1. Etapas do Julgamento.

O julgamento da causa constitui um “procedimento complexo, que se desdobra em várias etapas”.⁴¹ A uma, o presidente do órgão colegiado anuncia o início do julgamento e logo em seguida concede a palavra ao relator a fim de que esse exponha a causa. A duas, nos casos previstos em lei (art. 937, CPC/2015), a palavra é dada aos procuradores das partes para a sustentação oral das suas razões, seguindo-se daí, nos casos em que cabível a sua intervenção (arts. 127, caput, CF/1988, e 178, CPC/2015), a manifestação do Ministério Público. A três, vencidos os debates, devem ser tomados os votos de cada um dos membros do colegiado (art. 941, CPC/2015), tendo o presidente logo em seguida de proclamar o resultado do julgamento. Esse é o procedimento padrão.

Nada obstante, ao longo da sessão podem ocorrer outras situações que demandem a adaptação do procedimento: pode um dos membros do colegiado pedir vista para exame mais detido da causa (art. 940, CPC/2015), pode ser suscitado incidente de assunção de competência (art. 947, CPC/2015), de arguição de inconstitucionalidade (art. 948, CPC/2015), de conflito de competência (arts. 951 e 958, CPC/2015) e de resolução de demandas repetitivas (art. 976, CPC/2015). Também é possível que o julgamento seja ampliado subjetivamente por força da ausência de unanimidade nas hipóteses legais (art. 942, CPC/2015), seja convertido em diligência para determinar a prova de determinada alegação cuja necessidade se aferiu no momento do julgamento (art. 932, inc. I, CPC/2015) ou seja convertido em diligência para sanar eventuais vícios verificados também ao longo da sessão (arts. 932, parágrafo único, e 938, § 1.º, CPC/2015).

2. Sustentação Oral

Depois de feita a exposição da causa pelo relator, o presidente possibilitará a sustentação oral das razões recursais pelas partes, concedendo a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um. Se o Ministério Público tiver que intervir no feito como fiscal da ordem jurídica, então falará depois das partes. No entanto, se estiver participando do processo na qualidade de parte (arts. 177 e 996, CPC/2015), falará na ordem legal: se recorrente, em primeiro lugar; se recorrido, em segundo.

As partes não podem inovar na fundamentação oral das suas razões. Vale dizer: apenas a matéria trazida no recurso e nas contrarrazões é que poderá ser objeto de sustentação oral. Podem, no entanto, suscitar questões que o colegiado deve conhecer de ofício, ainda que não tratadas no recurso. Nesse caso, tem a parte contrária o direito de pedir a conversão do julgamento em diligência a fim de que se promova efetivo contraditório (arts. 7.º, 10 e 937, CPC/2015).

A sustentação oral pode ser feita por videoconferência ou qualquer outro recurso tecnológico que permita transmissão de som e imagem em tempo real – nesse caso, porém, é preciso requerê-la no dia anterior.

3. Feitos que Admitem

Os feitos que admitem sustentação oral são aqueles expressamente mencionados pelo legislador no art. 937, CPC/2015: o denominador comum entre as hipóteses arroladas pelo legislador é a pressuposição de que nesses recursos haverá oportunidade para se tratar do mérito da causa – daquilo que os litigantes vieram buscar em juízo. É por essa razão que no agravo de instrumento que trata da tutela de urgência e da tutela de evidência há direito à sustentação oral (art. 937, VIII, CPC/2015). Por essa razão, igualmente, as partes têm direito de realizar sustentação oral em reexame necessário.⁴²

Rigorosamente, a fim de que o Código alcançasse maior coerência, também os demais casos em que o mérito da causa é tratado no recurso deveria ser objeto de sustentação oral: assim é que não só nas hipóteses em que o agravo interno leva ao colegiado quaisquer dos recursos mencionados nos incs. I, II, III, IV e VIII do art. 937, CPC/2015, indevidamente vetadas, mas também naquelas em que o agravo de instrumento se volta contra decisões interlocutórias de mérito deveria caber sustentação oral (como, por exemplo, a decisão que julga parcialmente o mérito, art. 356, CPC/2015, a liquidação e a impugnação em cumprimento de sentença por questões ligadas ao mérito, art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015).

4. Não Surpresa

Se, de um lado, não podem as partes inovar na fundamentação recursal na sustentação oral, de outro, não pode o órgão jurisdicional surpreender as partes com uma visão jurídica da causa por elas não debatida. A tanto impede a regra da colaboração – e o dever de diálogo judicial que daí ressaí. Decisão judicial que se apoia em ponto de vista não debatido é nula por afronta ao direito fundamental ao contraditório (arts. 5.º, LV, CF, e 9.º e 10, CPC/2015), matriz constitucional da regra da colaboração no processo civil. Surpreendidas por decisão de terceira via – que decide a controvérsia fora do debatido – têm as partes direito a suscitar questão de ordem na sessão de julgamento e pedir a palavra para nova sustentação oral, limitada, contudo, ao ponto em que se deu a inovação judicial (analogamente, art. 933, CPC/2015).

Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

§ 1.º Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes.

§ 2.º Cumprida a diligência de que trata o § 1.º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso.

§ 3.º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.

§ 4.º Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos §§ 1.º e 3.º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso.

1. Questões Preliminares

As questões preliminares têm prioridade no julgamento da causa. As questões preliminares podem ser materiais (de mérito – por exemplo, a prescrição ou a decadência) ou processuais (por exemplo, pressupostos processuais). O art. 938, CPC/2015, refere-se a ambas, nada obstante a sua imperfeita redação sugira o contrário.⁴³

Ao lado das questões prejudiciais, as questões preliminares entram no gênero questões prévias.⁴⁴ Tendo em conta que comungam o fato de terem prioridade no julgamento, essas questões também são conhecidas como questões prioritárias.⁴⁵

As questões preliminares são aquelas que impossibilitam ou tornam desnecessária a análise das questões posteriores. Vale dizer: as questões preliminares dizem respeito à colocação ou não

das questões posteriores ao conhecimento do órgão jurisdicional. Assim, por exemplo, o acolhimento da preliminar de litispendência dispensa o órgão jurisdicional de examinar as demais questões que compõem o objeto do processo – notadamente, as questões de mérito. O mesmo vale para a prescrição: o acolhimento da exceção de prescrição dispensa o juiz de examinar se a prestação exigida é devida ou não, na medida em que encoberta a sua exigibilidade.

As questões prejudiciais são aquelas que condicionam o conteúdo das questões subordinadas.⁴⁶ Uma questão prejudicial, portanto, embora seja uma questão cronologicamente anterior, não pode ser simplesmente conceituada por esse critério: é imprescindível que se conjugue para tanto a influência que a sua solução pode ter sobre o conteúdo da questão subordinada.⁴⁷ Assim, por exemplo, constitui questão prejudicial à condenação em alimentos o reconhecimento da filiação. O mesmo vale para a condenação em aluguéis: a existência de contrato de locação constitui a essa questão prejudicial. O art. 938, CPC/2015, não se refere às questões prejudiciais.

2. Preliminares do Recurso e Preliminares da Causa

Existindo questões preliminares a serem analisadas no recurso, tem o órgão jurisdicional de julgá-las prioritariamente, não conhecendo das questões posteriores se a solução dada às questões preliminares for com elas incompatível, salvo se puder julgar a questão posterior no mérito de maneira favorável a quem aproveitaria o acolhimento da questão preliminar (art. 488, CPC/2015). Nesse particular, porém, é preciso distinguir entre as questões preliminares concernentes à causa e as questões preliminares atinentes ao recurso.

Como observa a doutrina,⁴⁸ as preliminares do recurso não se confundem com as preliminares ao julgamento do mérito e com as preliminares de mérito. As preliminares do recurso são aquelas que dizem respeito ao seu juízo de admissibilidade: em sendo possível, antes de acolher qualquer preliminar que impeça o julgamento do mérito do recurso (isto é, seu provimento ou desprovimento), tem o relator de viabilizar a sua sanção (arts. 932, parágrafo único, e 938, § 1.º, CPC/2015). As preliminares ao julgamento do mérito são preliminares da causa que condicionam o seu exame: assim, por exemplo, os pressupostos processuais, a legitimidade para a causa e o interesse recursal – espécies que entram no gênero requisitos para a concessão da tutela jurisdicional do direito. Nesse caso, o exame das preliminares ao julgamento do mérito da causa já pressupõe um juízo positivo a respeito da admissibilidade recursal. Note-se que a preliminar pode ser processual (por exemplo, a existência de coisa julgada, art. 485, V, CPC/2015), mas seu exame se oferecer como uma questão ligada ao mérito do recurso. Por fim, existem as preliminares de mérito, isto é, aquelas que dizem respeito àquilo que é efetivamente debatido entre as partes desde o ponto de vista do direito material, cujos exemplos notórios são a prescrição e a decadência.

No sistema do Código de 1973, ensinava a doutrina que não era lícito ao órgão jurisdicional indagar a respeito do mérito da causa sem que antes as preliminares processuais estivessem devidamente enfrentadas e afastadas.⁴⁹ Já na vigência do Código anterior, porém, parecia-nos necessário rever o dogma da absoluta prioridade das preliminares processuais sobre o mérito da causa.⁵⁰ O Código de 2015 tem regra expressa nesse sentido: o art. 488, CPC/2015, permite ao órgão jurisdicional julgar o mérito a favor de quem o acolhimento de determinada preliminar favoreceria. Trata-se de uma evidente manifestação da colaboração e da primazia do exame do mérito a essa inerente (art. 6.º, CPC/2015).⁵¹

Assim, por exemplo, se o juiz pode julgar o mérito a favor do demandado, não há razão para extinguir o processo por ausência de legitimidade do demandante.⁵² Se o juiz pode julgar procedente o pedido do demandante, não tem razão para extinguir o processo pela sua ausência de capacidade para ser parte.⁵³

Seja como for, ainda que o julgamento das questões preliminares não tenha precedido o julgamento das questões posteriores, não se decreta a nulidade da decisão por afronta ao art. 938, CPC/2015, se a quebra da ordem de apreciação da matéria não tiver causado efetivo prejuízo aos fins de justiça do processo.⁵⁴ Não há nulidade sem prejuízo (arts. 277 e 282, § 1.º, CPC/2015).

3. Vício Sanável

Versando a preliminar sobre vício sanável, tem o tribunal o dever de converter o julgamento em diligência e baixar os autos para sanção do vício. O art. 938, § 1.º, CPC/2015, aplica-se a todas as espécies sujeitas ao conhecimento dos tribunais: recursos, sucedâneos recursais, incidentes e ações originárias. Reconhecida necessidade de produção de prova não ordenada anteriormente, pode o tribunal determinar a sua realização (art. 370, CPC/2015). Instruído o feito, os autos devem retornar para o julgamento. Se o relator não determinar as providências concernentes ao art. 938, CPC/2015, qualquer membro do colegiado pode suscitar a questão. Também as partes, a propósito, podem fazê-lo, inclusive durante a sessão de julgamento.

Art. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.

1. Julgamento Principal

Rejeitada a preliminar ou sendo compatível o seu acolhimento com o restante do julgamento, cumpre ao órgão jurisdicional continuar no exame da causa, decidindo a controvérsia em toda a sua extensão. Acolhida, cumpre encerrar aí a cognição do litígio, salvo se for possível decidir no mérito a favor de quem o acolhimento da questão preliminar aproveitaria (arts. 488 e 938, CPC/2015).

2. Juízes Vencidos

Se, na discussão a respeito do acolhimento ou não de determinada questão preliminar restar vencido algum ou alguns dos julgadores, cumpre a esses pronunciarem-se a respeito do restante do litígio (art. 939, CPC/2015). A omissão de pronúncia dos juízes vencidos no que se refere ao restante da controvérsia desafia embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC/2015) e constitui erro de forma passível de anulação em recurso especial por violação do art. 939, CPC/2015.

Art. 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução.

§ 1.º Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo mais 10 (dez) dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído.

§ 2.º Quando requisitar os autos na forma do § 1.º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal.

1. Vista

Não se sentindo habilitado a julgar imediatamente a controvérsia, qualquer juiz que componha o órgão fracionário encarregado de julgar o recurso poderá pedir vista dos autos. O art. 940, CPC/2015, disciplina a espécie. Vencido o prazo de vista e ausente pedido de prorrogação de prazo, o presidente do órgão fracionário requisitará os autos do processo e reabrirá o julgamento na sessão ordinária subsequente, sempre com publicação em pauta. Se aquele que pediu vista ainda não se sentir habilitado para o julgamento, o presidente convocará substituto para proferir voto na forma regimental. Nessa situação, a parte interessada tem legitimidade para requerer ao presidente do órgão fracionário que requisiute os autos e coloque o feito em pauta.

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1.º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

§ 2.º No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.

§ 3.º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento.

1. Julgamento

O art. 941, caput, CPC/2015, fala que o julgamento será realizado pela tomada de votos de cada um dos julgadores que compõem o órgão fracionário, sendo logo em seguida tarefa do presidente anunciar o resultado. Nada fala, porém, a respeito de como as questões devem ser individualizadas e debatidas ao longo do julgamento.

Daí que é necessário ler o art. 941, CPC/2015, à luz de outros dispositivos do Código: no incidente de assunção de competência, o art. 947, CPC/2015, alude à necessidade de existir uma “relevante questão de direito” devidamente demonstrada, o art. 984, CPC/2015, refere a necessidade de o relator expor no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas o “objeto do incidente” e o art. 1.037, I, CPC/2015, determina a identificação “com precisão” da questão a ser submetida a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos. Em realidade, o que se exige em todos esses casos é um determinado modo com que o julgamento deve ocorrer. Na verdade, é preciso examinar a razão pela qual essa exigência está prevista no Código, inclusive para que se possa saber se essa deve ter lugar também em outras situações que não as previstas pela legislação e como devem ocorrer os demais julgamentos nos tribunais.

2. Decisão Colegiada e Decisão Plural

O método pelo qual determinado julgamento tem de ocorrer deve refletir, em primeiro lugar, aquilo que se espera da Corte encarregada de realizá-lo. Se o julgamento deve ter lugar em uma Corte Suprema (entre nós, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho), é claro que se espera, a partir do julgamento do caso, uma adequada interpretação da Constituição ou do direito federal. Em outras palavras, sendo a Corte Suprema uma corte de interpretação e de precedentes, é necessário que exista um método de julgamento compatível com o atingimento de semelhantes finalidades.⁵⁵

O mesmo vale para as Cortes de Justiça. Sendo essas cortes de controle e de jurisprudência, é preciso que se pense em um método de julgamento apropriado capaz de refletir o que se espera do trabalho dessas cortes. E, tendo em conta o fato de o direito brasileiro ter outorgado caráter vinculante à jurisprudência formada por determinada forma nas Cortes de Justiça, notadamente mediante os incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas (art. 927, III, CPC/2015), também nesses casos especiais as Cortes de Justiça devem ter um método de trabalho compatível com as finalidades que são normativamente esperadas.

Todo e qualquer julgamento – e não só o julgamento em incidente de assunção de competência, em incidente de resolução de demandas repetitivas e em recursos repetitivos – depende de uma adequada individualização da questão – ou das questões – que está sendo debatida e que será objeto da decisão. Isso porque só haverá efetivo julgamento do caso se esse – e os seus pontos e as suas questões – estiver precisamente delineado. Todos os membros do colegiado, portanto, devem enfrentar as questões que foram devidamente delineadas pelo relator: isso quer dizer que tanto as questões preliminares recursais como as questões que envolvem o mérito do recurso (digam ou não respeito ao mérito da causa) devem ser julgadas por todos os membros do órgão julgador (arts. 489, § 1.º, IV, e 939, CPC/2015).

O que varia, portanto, não é o dever de precisar as questões e de enfrentá-las, presente em todo e qualquer julgamento (arts. 489, § 1.º, IV, e 939, CPC/2015). O que muda de uma Corte Suprema para uma Corte de Justiça é a necessidade de se privilegiar nas primeiras decisões colegiadas, enquanto nas segundas é possível se trabalhar, em regra, com decisões plurais.

As decisões colegiadas são aquelas que permitem ver o colegiado como um todo único, na

medida em que contêm fundamentos compartilhados, ainda que existam no acórdão votos dissidentes. As decisões colegiadas apresentam um debate que envolve os mesmos fundamentos sobre as mesmas questões – é a partir dessa comunidade no debate que se pode aferir com maior facilidade a ratio decidendi do julgado. O resultado é que a questão é examinada sempre à luz de um mesmo fundamento que é enfrentado por todos os membros do colegiado: se todos concordam com a sua adoção, há fundamentos compartilhados; se apenas parte do colegiado concorda, há fundamento majoritário. Em outras palavras, as decisões colegiadas exigem a precisa identificação da questão e o voto em separado de cada uma das questões à luz dos diferentes fundamentos a partir dos quais essas podem eventualmente ser decididas. Vale dizer: há necessidade de identificação da questão, de identificação dos fundamentos que podem servir à solução da questão e de voto em separado de cada um desses fundamentos. Nas decisões colegiadas, ademais, mesmo o dissenso é polarizado pela necessidade de atenção aos fundamentos em torno dos quais as questões giram: quando um dos juízes que compõem o colegiado dissente, espera-se que o faça enfrentando os mesmos fundamentos enfrentados pela maioria, isto é, espera-se que profira um verdadeiro voto dissidente, que se preocupe em mostrar porque a ratio decidendi compartilhada não pode prevalecer.

As decisões plurais – também conhecidas como decisões fragmentadas ou decisões por agregação – são aquelas em que a ausência de necessidade de enfrentamento dos pontos e das questões da causa à luz dos mesmos fundamentos gera a impressão de que o colegiado constitui a simples soma de três posições individuais sobre determinado ponto ou questão. Por essa razão, as decisões plurais tendem a ter fundamentos concorrentes ao invés de fundamentos compartilhados, isto é, diferentes fundamentos que servem à solução da mesma questão. O que interessa é o acordo quanto ao dispositivo, sendo uma questão menor o acordo concernente aos fundamentos utilizados para obtê-lo. Como a atenção da decisão colegiada está centrada sobre a solução do caso e na busca pelo dispositivo, é natural que a preocupação com a formação da ratio decidendi fique em segundo plano. Em outras palavras, a decisão plural, embora exija precisa identificação da questão e de identificação dos fundamentos, não exige voto em separado de cada um dos fundamentos. Ademais, a mesma fragmentação que ocorre em relação aos fundamentos concorrentes também se verifica no momento em que há divergência entre os juízes que compõem o colegiado: o voto divergente normalmente é dado sem qualquer preocupação com o enfrentamento dos fundamentos já sustentados pelos demais membros do colegiado. Há aí também simples agregação de mais um fundamento no acórdão.

Assim, é fácil concluir que toda vez que os fundamentos de uma determinada decisão importarem a título de ratio decidendi, interessa que o órgão fracionário decida de forma colegiada, com precisa identificação da questão, identificação dos fundamentos e voto em separado de cada um deles. Quando, porém, não houver a necessidade de formação de uma ratio a partir da decisão, basta que o órgão julgador decida de forma plural, isto é, com precisa identificação da questão e dos fundamentos, mas sem necessidade de voto em separado de cada um deles.

Diante disso, é possível concluir que as Cortes Supremas devem sempre deliberar mediante decisões colegiadas, na medida em que voltadas para adequada interpretação do direito e para a formação de precedentes. Trata-se de necessidade vinculada à formação de precedentes e que, portanto, não se faz presente apenas nos recursos repetitivos e no incidente de assunção de competência. Já as Cortes de Justiça podem julgar mediante decisões plurais, porque voltadas para a solução dos casos concretos, salvo quando a ordem jurídica acopla eficácia vinculante ao produto de seus julgamentos – como é o caso dos julgamentos dos incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Nesses casos, devem as Cortes de Justiça decidir mediante decisões colegiadas.

Isso não quer dizer, porém, que a formação da ratio decidendi esteja sempre vinculada à decisão colegiada. Pode ocorrer de, mesmo diante de decisões plurais, a Corte conseguir chegar a fundamentos majoritários – isto é, comungados pela maioria dos seus membros. Nesse caso, mesmo sem a utilização do método próprio, há formação de precedente. O que interessa, portanto, é a viabilização de um consenso sobre os fundamentos: se esse consenso é obtido por meio de decisões colegiadas – método mais apropriado – ou mediante decisões plurais – método, a

princípio, menos idôneo – é uma questão meramente instrumental, isto é, ligada mais ao meio do que ao fim visado pela atuação da Corte.

3. Alteração do Voto

Até o momento em que o resultado não é proclamado pelo presidente do órgão fracionário é possível a qualquer dos seus membros discutir o caso. Em outras palavras, o encerramento do julgamento só se dá com a proclamação de seu resultado.

O julgamento colegiado tem por endereço viabilizar ampla discussão da causa em determinado espaço de tempo. Pressupõe, portanto, o diálogo entre os seus participantes – o que pressupõe suficiente abertura de espírito para consideração das razões trazidas não só pelos advogados das partes, mas também pelo Ministério Público e pelos demais juízes que compõem o órgão fracionário. Em outras palavras, é da essência da discussão colegiada a possibilidade de revisão de entendimento de quaisquer de seus membros enquanto pendente o julgamento: a decisão colegiada não é uma soma de decisões individuais, mas o resultado de um debate o mais aberto possível da causa.

Isso quer dizer que a solução encampada pelo art. 941, caput, in fine, CPC/2015, não é mais feliz, na medida em que incompatível com o ideal dialogal inerente ao julgamento colegiado. O ideal é que o juiz que ocupa o lugar do juiz afastado ou substituído pudesse participar efetivamente do debate da causa.

Seja como for, juiz afastado ou substituído, no art. 941, CPC/2015, pressupõe afastamento ou substituição por motivos que não infirmem a imparcialidade do julgador: se o afastamento ou a substituição ocorreu por motivos capazes de ofender a imparcialidade judicial, então obviamente o novo julgador não está atado ao voto proferido pelo juiz suspeito de parcialidade.

4. Voto Vencido

O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento (art. 941, § 3.º, CPC/2015). Superada a súmula 320, STJ (“a questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento”).

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1.º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2.º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3.º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I – ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II – agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4.º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I – do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II – da remessa necessária;

III – não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.

1. Ampliação do Debate

O novo Código extinguiu o recurso de embargos infringentes. No entanto, sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate. Em outras palavras: o julgamento não unânime terá prosseguimento com a ampliação do quórum de julgadores.

Não se trata de novo recurso, nem de incidente, nem tecnicamente de novo julgamento.⁵⁶ o art. 942, CPC/2015, constitui apenas um meio de provocar a ampliação do debate. A ampliação do debate não depende de requerimento de quaisquer das partes – o prosseguimento do julgamento deve se dar de ofício.

O fato de o legislador ter, por assim dizer, substituído o recurso de embargos infringentes pela técnica de ampliação do debate diante da não unanimidade não autoriza, todavia, a leitura do art. 942, CPC/2015, como se fosse um simples sucedâneo – apenas dotado de um novo nome – do recurso de embargos infringentes. É preciso evitar semelhante interpretação. Como se trata de prosseguimento de julgamento, é claro que as questões recursais continuam sendo as mesmas do recurso que deu lugar à não unanimidade. Em outras palavras, não é o caso principalmente de ver-se na ampliação do debate qualquer espécie de devolutividade restrita à questão objeto de divergência.

2. Não Unânime

O art. 942, CPC/2015, não circunscreve a ampliação do julgamento apenas às questões de mérito. Qualquer julgamento não unânime – quer verse questões de direito material, quer verse questões de direito processual – pode ser subjetivamente ampliado.

Como se trata de simples prosseguimento, sem que tenha havido a proclamação do resultado, incide a regra que permite a todo e qualquer componente do órgão fracionário mudar a sua opinião enquanto não encerrado o julgamento (art. 941, CPC/2015).⁵⁷ Diante da ausência de unanimidade, ainda, é preciso ter presente que a mudança de opinião de quaisquer dos julgadores não está cifrada apenas à matéria que foi objeto de divergência: toda e qualquer questão é suscetível de novo julgamento, inclusive questões acessórias, como aquelas concernentes às despesas processuais, em especial em relação aos honorários advocatícios. Vale dizer: o novo juiz natural, a partir da ausência de unanimidade, é o colegiado ampliado.

3. Decisões Finais

Cabe ampliação do julgamento não unânime na apelação, na ação rescisória julgada procedente e no agravo de instrumento que reforma decisão que antecipa parcialmente o mérito. Analogicamente ao art. 942, § 3.º, II, CPC/2015, deve caber semelhante ampliação no julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que reforma o julgamento de improcedência liminar parcial, a liquidação de sentença e contra a decisão que reforma o não acolhimento da impugnação. O elemento que permite a analogia é o caráter final de todas essas decisões – nada obstante impugnáveis por agravo de instrumento.⁵⁸ A extensão da técnica de ampliação do debate nessas hipóteses decorre da necessidade de unidade da ordem jurídica, especialmente de promover-se a sua coerência sistemática (art. 926, CPC/2015).

4. Não se Aplica

A técnica de ampliação do julgamento não se aplica à decisão do incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, da remessa necessária e à decisão não unânime proferida pelo plenário ou pelo órgão especial dos tribunais. O art. 942, CPC/2015, é uma técnica que visa ao julgamento do caso concreto: por essa razão, não tem sentido empregá-la no

julgamento dos incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, cujo objetivo comum é o de formar jurisprudência vinculante no âmbito das Cortes de Justiça. A técnica também não se aplica aos julgamentos proferidos pelo plenário ou órgão especial, porque aí o julgamento já é formado a partir de significativa pluralidade no debate.

5. Prosseguimento

O prosseguimento pode ocorrer na mesma sessão, acaso já existam julgadores em número suficiente para reversão do resultado do julgamento presentes (art. 942, § 1.º, CPC/2015), ou em qualquer outra, hipótese em que é imprescindível a colocação em pauta (art. 935, CPC/2015). Acaso os novos julgadores não tenham acompanhado as sustentações orais, as partes têm direito de renová-las, bem como os terceiros que eventualmente participem do processo (art. 942, CPC/2015). Como a sessão de julgamento constitui um prolongamento do julgamento originário, quaisquer dos julgadores que já votaram podem livremente alterar o voto, ressalvada a incidência do art. 941, § 1.º, *in fine*, CPC/2015.

Se for o caso de novo julgamento, é necessária a colocação em pauta com um cuidado adicional: é preciso que se indique quem são os julgadores convocados para o prosseguimento. É que somente a partir dessa informação será possível que as partes tenham condições de exercer plenamente o contraditório, direcionando seus esforços também para convencer os membros ocasionais do julgamento.

6. Embargos Declaratórios

Com a ampliação do julgamento, o juiz natural para o caso desloca-se do órgão originário e concentra-se no órgão ampliado. Isso quer dizer que os embargos declaratórios eventualmente opostos das decisões do colegiado ampliado devem ser apreciados pelo próprio órgão ampliado. Nada obsta, em sendo o caso (art. 932, CPC), que o relator do recurso o decida monocraticamente: fá-lo-á, contudo, em nome do colegiado ampliado – e não do colegiado originário.

Essa observação é importante sobretudo por duas razões: em primeiro lugar, porque, em regra, os embargos declaratórios também terão de ser examinados pelo colegiado ampliado. Em segundo lugar, porque eventuais razões divergentes apresentadas no colegiado ampliado podem evidenciar questões constitucionais ou questões federais passíveis de recurso para as Cortes Supremas.

Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico.

§ 1.º Todo acórdão conterá ementa.

§ 2.º Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias.

1. Suporte

Os votos, acórdãos e demais atos processuais podem constar de arquivo eletrônico inviolável e assinado eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando esse não for eletrônico.

2. Ementa

A ementa constitui um resumo da matéria tratada no acórdão. Todo acórdão conterá ementa (art. 943, CPC/2015). A contradição entre a ementa e o corpo do acórdão desafia embargos de declaração⁵⁹ (art. 1.022, I, CPC/2015). A divergência entre a ementa e o corpo do acórdão, consoante já se decidiu, deve ser resolvida em favor daquilo que consta do conteúdo da decisão.⁶⁰

A finalidade da ementa é permitir de forma mais rápida possível o conteúdo do julgamento. Em um sistema de precedentes, importa que a ementa anuncie não apenas as questões jurídicas resolvidas, mas também os fatos que deram origem ao caso tratado em juízo. Embora o legislador

refira que todo acórdão conterá ementa, a sua ausência não provoca nulidade: a ementa é apenas uma versão minimalista – por assim dizer – do julgado. A sua ausência em nada prejudica a sua compreensão, nada obstante impeça a mais rápida identificação do conteúdo da decisão. Como não há prejuízo pela ausência de ementa, não há que se falar em nulidade.⁶¹

3. Publicação

Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias. Não publicado, incide no art. 944, CPC/2015.

Art. 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão.

Parágrafo único. No caso do caput, o presidente do tribunal lavrará, de imediato, as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão.

1. Notas

A fim de acelerar a publicação dos acórdãos e promover a duração razoável do processo (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º, CPC/2015), não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado do primeiro dia útil subsequente à sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. Nesse caso, o presidente do tribunal lavrará de imediato o acórdão, redigindo as conclusões e a ementa, mandando publicá-lo.

Art. 945. (Revogado pela Lei 13.256, de 04.02.2016)

1. Julgamento Eletrônico. Dispositivo Revogado

O art. 945, CPC/2015, ora revogado, possibilitava o julgamento eletrônico de feitos que não admitissem sustentação oral. Como as partes têm direito à publicidade imediata, isto é, de estarem presentes no momento da prática dos atos processuais, qualquer das partes poderia, no prazo de 5 (cinco) dias da cientificação do julgamento eletrônico, apresentar discordância com a forma de julgamento. Tratava-se de direito potestativo da parte, que inclusive independia de motivação (art. 945, §§ 2.º e 3.º, CPC/2015). No mesmo prazo as partes poderiam apresentar memoriais ao julgamento da causa. O legislador, porém, achou por bem vetar o dispositivo antes da entrada em vigor do Código.

Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo.

Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.

1. Ordem de Julgamento

Porque o agravo de instrumento leva ao conhecimento do tribunal, normalmente, uma questão prévia ao julgamento da apelação, prevê o art. 946, CPC/2015, que essa não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo. Calhando de ambos os recursos terem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. A razão é simples – eventual provimento do agravo de instrumento pode esvaziar o recurso de apelação. A inversão na ordem de julgamento, se causar prejuízo aos fins de justiça do processo, pode dar lugar à decretação da nulidade da decisão sobre a apelação,⁶² retomando-se a partir daí o julgamento na ordem estabelecida pelo art. 946, CPC/2015.

1

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil (1975), 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 197-198, t. VIII; José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil (1974), 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 646, vol. V.

2

Manoel Caetano Ferreira Filho, Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 364, vol. VII; Didier Júnior e Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil (2006), 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 33, vol. III.

3

Tendo em conta que uma das normas fundamentais do processo civil brasileiro é a que impõe a colaboração como meio para viabilização de uma decisão de mérito (art. 6.º, CPC). Em outras palavras: tendo em conta que a “primazia da decisão de mérito” (como refere Fredie Didier Júnior, Curso de Direito Processual Civil (2003), 18. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 137, vol. I) é o fim perseguido pela colaboração (Daniel Mitidiero, Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos (2009), 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 105).

4

Essa discussão ganhou notoriamente importância no julgamento da AP 470, rel. Ministro Joaquim Barbosa (“Caso Mensalão”), tendo em conta a necessidade de se decidir pela subsistência ou não do recurso de embargos infringentes em ação penal de competência originária do STF. Sobre o assunto, Didier Júnior e Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil (2006), 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 34, vol. III.

5

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil (1975), 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 200, t. VIII; José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil (1974), 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 649, vol. V.

6

Hemes Zaneti Júnior. In: Cabral e Cramer (coords.), Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.339.

7

Sobre o direito fundamental ao juiz natural, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de Direito Constitucional (2012), 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 764-766, em coautoria com Ingo Sarlet. Amplamente, Leonardo Carneiro da Cunha, Jurisdição e Competência (2008), 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013. Para uma visão histórica e comparada do tema, Ulrike Müßig, El Juez Legal – Una Comparación

Histórica, desde el Derecho Canónico hasta la Convención Europea de los Derechos Humanos, con Especial Énfasis en el Desarrollo del Derecho en Alemania, Inglaterra y Francia (2003), tradução de Anne Cullmann, Ignacio Czeguhn e Antonio Sánchez Aranda, Madrid: Dykinson, 2014.

8

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil (1974), 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 651, vol. V.

9

Em sentido contrário, Araken de Assis, Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 265-266.

10

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de Direito Constitucional (2012), 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 766, em coautoria com Ingo Sarlet.

11

Karl Heinz Schwab (1920 – 2008) e Peter Gottwald, Verfassung und Zivilprozeß. Bielefeld: Giesecking, 1984, p. 13-14.

12

Vittorio Denti (1919 – 2001), La Giustizia Civile (1989), 2. ed., Bologna: Il Mulino, 2004, p. 104; Michele Taruffo, La Motivazione della Sentenza Civile, Padova: Cedam, 1975, p. 407; Eduardo Couture, Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil (1948), Estudios de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires: Ediar, 1948, p. 20-21, t. I.

13

Entendendo que o equívoco na distribuição constitui “nulidade não cominada” e, portanto, “sanável”, Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil (1975), 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 202, t. VIII.

14

Extensamente sobre o Iura Novit Curia, com amplas indicações bibliográficas, Otávio Domit, Iura Novit Curia e Causa de Pedir – O Juiz e a Qualificação Jurídica dos Fatos no Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Ed. RT, 2016.

15

Alvaro de Oliveira, A Garantia do Contraditório, Do Formalismo no Processo Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 237.

16

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 645.

17

Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 168.

18

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 669.

19

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, 4. ed., Napoli: Jovene, 2002 p. 202-203.

20

STF, 2ª Turma, AgRg no RE 222.206/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 30.03.1998.

21

Antônio do Passo Cabral, *Il Principio del Contraddittorio come Diritto d’Influenza e Dovere di Dibattito*, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 2005; Alvaro de Oliveira, *O Juiz e o Princípio do Contraditório*, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, 1993, n. 71; Vanessa Chincoli, *O Direito Fundamental ao Contraditório no Processo Civil. Conceito e Possíveis Aplicações*. In: Mitidiero (coord.), *O Processo Civil no Estado Constitucional*, Salvador: JusPodivm, 2012; André Pagani de Souza, *Vedação das Decisões-Surpresa no Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2014.

22

Luigi Paolo Comoglio, *Le Garanzie Fondamentali del “Giusto Processo”, Etica e Tecnica del “Giusto Processo”*, Torino: Giappichelli, 2004, p. 71-74.

23

Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C. H. Beck, 2010, p. 432; Frédérique Ferrand. In: Guinchard, Serge (coord.), *Droit Processuel – Droit Commum et Droit Comparé du Procès Équitable*, p. 894-904.

24

Sobre os conceitos de cognitivismo e adscritivismo interpretativo e as respectivas influências no conceito de jurisdição, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, vol. I.

25

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 657.

26

Luigi Paolo Comoglio, *La Garanzia Costituzionale dell’Azione ed il Processo Civile*, Padova: Cedam, 1970, p. 145-6; Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 659.

27

Luigi Paolo Comoglio, *La Garanzia Costituzionale dell’Azione ed il Processo Civile*, Padova: Cedam, 1970, p. 145-6.

28

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil* (1974), 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 683, vol. V.

29

Hermes Zaneti Júnior. In: Cabral e Cramer (coords.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.341.

30

Súmula 253, STJ: o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

31

Contra, entendendo que os poderes do relator para o julgamento limitam-se apenas aos “recursos, na acepção técnica da palavra”, José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil* (1974), 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 684, vol. V.

32

Michele Taruffo, *Idee per una Teoria della Giusta Decisione, Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*, Bologna: Il Mulino, 2002.

33

Nessa linha, Didier Júnior e Carneiro da Cunha, *Curso de Direito Processual Civil* (2006), 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 46-48, vol. III.

34

Os dois primeiros exemplos são de Cadiet, Normand e Mekki, *Théorie Générale du Procès*, Paris: PUF, 2010, p. 371.

35

Nesse sentido, com as devidas indicações bibliográficas, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015.

36

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ como Corte de Precedentes*. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 185-90; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente*. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 67-71 e p. 94-102.

37

STJ, REsp 738.586/PR, 1ª Turma rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007, DJ 15.10.2007, p. 228.

38

Rodrigo da Cunha Lima Freire. In: Wambier, Didier Júnior, Talamini e Dantas (coords.), *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 2.091. Amplamente sobre a influência do fato superveniente no processo civil, Leonardo Carneiro da Cunha, *A Atendibilidade dos Fatos Supervenientes no Processo Civil – Uma Análise Comparativa entre o Sistema Português e o Brasileiro*. Coimbra: Almedina, 2012.

39

Como sustenta Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 208, t. VIII.

40

Como sustenta José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 661, vol. V.

41

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 665, vol. V.

42

STJ, REsp 493.862/MG, 2ª Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, rel. para acórdão Min. Franciulli Netto,

j. 05.02.2004, DJ 12.04.2004, p. 192.

43

STJ, REsp 277.843/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.08.2001, DJ 22.10.2001, p. 327.

44

Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 73, vol. I; Adroaldo Furtado Fabrício, A Ação Declaratória Incidental, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 44.

45

José Carlos Barbosa Moreira, Questões Prejudiciais e Questões Preliminares, Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 76.

46

Por todos, Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 73, vol. I.

47

Francesco Menestrina, La Pregiudiciale nel Processo Civile, Milano: Giuffrè, 1963, p. 97.

48

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 702-704, vol. V.

49

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 704, vol. V.

50

Marinoni e Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 257-259.

51

Daniel Mitidiero, Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015; Didier Júnior e Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 50, vol. III.

52

Didier Júnior, Sarno e Oliveira, Curso de Direito Processual Civil, 11. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 328, vol. II.

53

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 567-9; Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 548-55, vol. I. Nessa mesma linha, José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, São Paulo: Malheiros, 2006; Fredie Didier Júnior, Pressupostos Processuais e Condições da Ação, São Paulo: Saraiva, 2005; Miguel Teixeira de Sousa, Sobre o Sentido e a Função dos Pressupostos Processuais, Revista de Processo, São Paulo: Ed. RT, 1991, n. 63; Bruno Rimmelspacher, Materiellrechtlicher Anspruch und Streitgegenstandsprobleme im Zivilprozess, München: Beck, 1970.

54

STJ, REsp 807.579/RJ, 2ª Turma, rel. Min. Castro Meira, j. Em 21.08.2007, DJ 31.08.2007, p. 224.

55

Sobre o assunto, com ampla indicação bibliográfica, Luiz Guilherme Marinoni, Julgamento nas Cortes Supremas – Precedente e Decisão do Recurso diante do Novo CPC, São Paulo: Ed. RT, 2015.

56

Hermes Zaneti Júnior. In: Cabral e Cramer (coords.), Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.356.

57

Júlio Lanes. In: Wambier, Didier Júnior, Talamini e Dantas (coords.), Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 2.106.

58

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1.005. Nessa linha, Hermes Zaneti Júnior. In: Cabral e Cramer (coords.), Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.356-1.357.

59

STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102.

60

STJ, EDcl no RMS 7.526/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 09.06.1997, DJ 30.06.1997, p. 31.085.

61

Didier Júnior e Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 42, vol. III.

62

STJ, REsp 220.110/AP, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.03.2003, DJ 04.08.2003, p. 305.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO III. DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capítulo III. Do Incidente de Assunção de Competência

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1.º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2.º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3.º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4.º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

• 1. Questão de direito com grande repercussão social envolvida no caso e questão de direito prejudicial à resolução de demandas repetitivas: Distinção e principais consequências.

O art. 947 afirma que é admissível a assunção de competência quando “o julgamento” – de recurso etc. – “envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos”. O art. 976, por sua vez, diz que o incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser instaurado quando há “repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”.

De lado o fato de que o incidente de assunção de competência cabe para o julgamento do caso que contém a questão e o incidente de resolução para o julgamento da questão contida nos processos, o que realmente distingue os dois incidentes é que no primeiro há de haver uma questão com grande repercussão social, e no segundo, apenas, uma mesma questão de direito.

Esta diferença está implícita na razão de ser dos dois incidentes: um destina-se a permitir que determinado órgão do tribunal assuma a competência para julgar caso que contém questão relevante, ou melhor, questão de grande repercussão social; o outro confere a determinado órgão do tribunal a competência para definir uma questão de direito, que está sendo discutida em múltiplos processos que se repetem. O primeiro incidente requer apenas a grande repercussão social da questão contida no caso; o segundo exige que a mesma questão esteja sendo discutida em demandas repetitivas. Portanto, num incidente importa uma qualidade da questão de direito; e no outro, apenas a sua unidade. Em um o caso tem que conter questão de grande repercussão social; e no outro, basta que exista uma única questão replicada em diversas demandas.

Os diferentes pressupostos para a instauração do incidente têm importante consequências. No

incidente de resolução decide-se questão prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas. O incidente, portanto, discute e define questão que afeta, diretamente, a sorte da tutela de direitos individuais múltiplos. Para que não seja violado o *due process*, exige-se que os litigantes excluídos sejam representados adequadamente, é imprescindível a participação dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos, nos termos dos arts. 5.º da Lei da Ação Civil Pública e 82 do CDC. A resolução de uma questão prejudicial à tutela de direitos de sujeitos que não podem discuti-la diretamente, mas apenas mediante representante adequado, tem o significado de coisa julgada sobre questão com eficácia erga omnes.¹

Porém, a questão de grande repercussão social não tem qualquer relação com pessoas, classes ou grupos determinados. Julga-se um caso específico que detém a questão de grande repercussão social. Mas não há solução de caso, nem de questão de terceiros. Por isso, não há motivo para reclamar a participação dos representantes adequados das partes que foram excluídas – como ocorre no incidente de resolução de demandas. Uma vez que a questão deve ser resolvida por determinado órgão colegiado competente apenas por ter significativa importância para a sociedade, há apenas deslocamento da decisão da questão para outro órgão judicial, sem que se possa pensar em exclusão de participação de partes que, sendo titulares de pretensões à tutela de direitos, têm o direito de discuti-la e de influenciar a Corte. A decisão proferida no incidente de assunção de competência, por não julgar questão de terceiros, não produz coisa julgada erga omnes. A decisão do incidente de assunção, ao julgar o caso, produz coisa julgada inter partes. A decisão da questão envolvida no caso atinge terceiros em virtude da sua eficácia vinculante, conforme o § 3.º do art. 947.

2. Significado de questão de direito com grande repercussão social.

Questão de direito com grande repercussão social é aquela que, além de não ter relevo apenas para a solução do caso sob julgamento, tem valor para a sociedade. Na verdade, quando se fala em questão com grande repercussão social, não se quer apontar para algo que diz respeito à sua relevância técnico-processual, que atingiria outros casos repetitivos ou casos respeitantes a direitos coletivos ou difusos. Alude-se a uma questão de direito com grande repercussão social para evidenciar o seu excepcional relevo em face da vida social nas perspectivas política, religiosa, cultural e econômica.

É preciso perceber, no entanto, que se trata antes de tudo de questão de direito com impacto relevante na vida social, e não, simplesmente, de questão com impacto na sociedade, inclusive na dimensão jurídica. Deve se pensar, assim, numa questão jurídica que tem relevante impacto sobre uma ou mais das várias facetas da vida em sociedade. Porém, não basta que a questão de direito apenas diga respeito à política, à religião, à cultura ou à economia de uma região. É preciso que a resolução afete diretamente, e com relevante impacto, tais aspectos da vida social para que possa ser considerada de “grande repercussão social”.

3. Assunção de competência para o julgamento do caso (recurso, remessa necessária e ação de competência originária) e não apenas da questão de direito: A necessidade de discussão, decisão e justificação em torno da questão de direito.

Vale a pena frisar que, no incidente de assunção de competência, há julgamento do recurso, remessa necessária ou mesmo da ação originária que contém a questão de direito. Assim, transmite-se, e assume-se, o julgamento do caso – recurso, reexame necessário ou ação originária – e não apenas de uma questão de direito que diz respeito ao caso. Desloca-se a competência para o julgamento do caso de um para outro órgão do tribunal. Como já dito, há aí algo bem distinto do que ocorre no incidente de resolução, quando se transfere para o tribunal apenas o julgamento da questão de direito prejudicial ao julgamento das demandas repetitivas.

O interessante é que, embora no incidente de assunção se transfira o julgamento do caso, isso ocorre em virtude da questão de direito “com grande repercussão social” que o “envolve”. De modo que, ao julgar o caso, o colegiado competente, em face do incidente de assunção, deve discutir e decidir, de forma individualizada, a questão de direito.

Ora, se a razão da assunção da competência está na relevância da questão de direito, mais importante que o julgamento do caso é o julgamento da questão. No entanto, como a assunção de competência é admissível quando o julgamento de recurso (por exemplo) envolve uma questão de direito – termos do caput do art. 947 –, o julgamento deslocado não terá como objeto a questão. Essa será apenas um fundamento do recurso a ser julgado pelo órgão que assumiu a competência.

Mas os fundamentos de um recurso, como se sabe, nunca são decididos em separado e, raramente, são discutidos de forma individualizada. Bem por isso, na generalidade dos casos os fundamentos não são justificados de forma particularizada, sendo quase sempre impossível saber o fundamento que contou com a maioria dos votos dos membros do colegiado.

Este modelo de julgamento não só é inadequado, mas incompatível à assunção de competência. A assunção de competência requer não só a discussão individualizada da questão de direito que a justifica, mas a sua decisão, que só pode ser particularizada. Ou seja, todos os membros do colegiado devem votar não apenas para dar ou negar provimento ao recurso, mas também para decidir a questão de direito envolvida no recurso. Significa que a questão de direito relevante pode ser decidida em favor do recorrido e o recurso ser provido, em virtude de outros fundamentos que podem ser acolhidos pelos membros do colegiado que decidiram a questão de direito em favor do recorrido. Saliente-se que o recurso pode ser provido com base em vários fundamentos, enquanto a questão de direito, no caso de assunção de competência, constitui fundamento para o provimento do recurso. Mesmo que exista um único fundamento, ou apenas a questão de direito dotada de grande repercussão social envolvida no recurso a ser julgado, isso não é garantia de que a questão de direito será discutida, e decidida, por todos os membros do colegiado.

Lembre-se, por exemplo, do caso *Metabel v. União Federal*, recentemente julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.² A questão posta no recurso extraordinário foi a de se decisão do STF, posterior à decisão de tribunal acobertada por coisa julgada material, poderia fundar ação rescisória fundada no antigo art. 485, V, do CPC/1973 – violação a “literal disposição de lei”.

O recurso extraordinário foi provido por sete votos a dois, conforme a proclamação de resultado, firmando-se o precedente de que manifestação do Supremo Tribunal Federal, ulterior ao trânsito em julgado da decisão, não é fundamento para a sua desconstituição mediante ação rescisória. O recurso, embora provido por sete votos, contou com três fundamentos distintos: os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello, Luiz Fux, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski adotaram o fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, posterior à decisão rescindenda, não pode constituir base para a sua desconstituição por meio de ação rescisória. O Ministro Toffoli reconheceu a decadência da ação rescisória, e não se manifestou sobre a questão da possibilidade da desconstituição de decisão com base em precedente ulterior do STF. A Ministra Cármen Lúcia rejeitou a decadência e o fundamento sustentado pelos cinco Ministros, provendo o recurso depois de admitir a ação rescisória e analisar a questão do creditamento de IPI devido à aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. O Ministro Teori não conheceu da questão da decadência, não abordou o fundamento sustentado pela Ministra Cármen e dissentiu da maioria. O Ministro Gilmar acompanhou o Ministro Teori para dissentir da maioria, sem também considerar a questão da decadência e o fundamento firmado pela Ministra Cármen.

O exemplo tem importância apenas para demonstrar que a questão de fundo pode não ser discutida, ou mesmo decidida, por algum membro do colegiado. O Ministro Toffoli tratou apenas da questão da decadência. Não discutiu ou decidiu a questão de se a decisão do Supremo Tribunal Federal, ulterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, pode constituir sustentáculo para ação rescisória. Isso mostra que, caso não bem delineada, a necessidade de discussão e decisão da questão de direito; essa poderá ser discutida, e decidida, apenas por alguns membros do colegiado, deixando-se de encontrar a voz ou o verdadeiro entendimento do colegiado definido como competente para resolvê-la.

Por identidade de motivos, a discussão e a decisão da questão de direito devem ser justificadas de modo claro, sem mistura ou confusão com fundamentos que não lhe dizem respeito. Lembre-se que a assunção de competência só existe em virtude da relevância da questão e, portanto, para se saber o que determinado colegiado pensa a seu respeito.

4. Legitimidade para requerer a assunção de competência e a sua admissibilidade pelo órgão originariamente competente e pelo órgão competente para julgar os casos derivados de incidente de assunção de competência.

De acordo com o § 1.º do art. 947, “ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar”.

A legitimidade para requerer o deslocamento da competência, portanto, é de qualquer das partes do caso sob julgamento (recurso etc.), do Ministério Público e da Defensoria Pública – quando estes, obviamente, já estiverem funcionando no processo – e do relator, de ofício.

Isso não quer dizer que, uma vez requerido o deslocamento de competência, esse não tenha que ser aprovado pelo colegiado originariamente competente para o caso. O relator não está vinculado ao requerimento das partes, do Ministério Público e da Defensoria Pública nem pode decidi-lo sozinho. Só o colegiado originariamente competente – o “juiz natural” – tem legitimidade para aprovar pedido de deslocamento de competência. Por isso, o relator, quando age de ofício, apenas submete a ideia de deslocamento de competência para os demais membros do colegiado. Jamais poderá decidir para imediatamente encaminhar os autos ao outro órgão colegiado.

Porém, quando o requerimento é feito pelo relator, parte do processo, Ministério Público ou Defensoria Pública, a decisão do colegiado não pode ocorrer antes de se dar a todos a oportunidade de falar para convencer sobre a incorreção, ou correção, do deslocamento da competência. Afinal, o requerente da assunção da competência deverá, adequadamente, demonstrar os motivos que evidenciam que a solução da questão de direito terá “grande repercussão social”.

Aprovado o deslocamento da competência, o órgão competente – definido pelo regimento interno do tribunal (art. 497, § 1.º, in fine) – para o julgamento dos casos derivados de assunção de competência poderá admiti-la ou não. O órgão colegiado para o qual foi deslocado o caso não fica vinculado à decisão do órgão originariamente competente.

Contudo, não há como dar poder ao órgão definido como competente para revogar a decisão que não admitiu a assunção, proferida pelo órgão originariamente competente. Isso porque só o juiz natural pode decidir sobre a oportunidade de deslocamento da competência. Como é óbvio, nenhum outro órgão do tribunal pode se sobrepor ao juiz natural. De modo que haveria usurpação de competência – no caso de decisão tomada pelo órgão que assume a competência – ou deslocamento inconstitucional da competência – no caso de outro órgão do tribunal definir que a competência é daquele instituído para os casos de assunção de competência.

Significa que os regimentos internos dos tribunais, embora possam definir o órgão colegiado competente para os casos de assunção de competência, não podem prever recurso de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do órgão originariamente competente.

5. Interesse público na assunção de competência.

O órgão colegiado para o qual foi deslocada a competência julgará o caso apenas “se reconhecer interesse público na assunção de competência”, conforme o § 2.º do art. 947.

A princípio, seria possível pensar que o legislador desejou impor um novo requisito para a admissibilidade da assunção de competência. Note-se, contudo, que a previsão de interesse público surge apenas quando se fala na admissão do julgamento do caso. Para o deslocamento da competência para o julgamento do caso alude-se, apenas, a questão de direito “com grande repercussão social”.

Mas o “deslocamento” e a “admissão do julgamento” constituem fases de uma mesma situação jurídica. O que realmente importa é saber se a assunção de competência é cabível, pois o

deslocamento, e a admissão do julgamento, são apenas consequências do seu cabimento. Ora, não é possível supor que, para duas decisões que aferem a mesma circunstância, é possível exigir requisitos diferentes. Os dois requisitos teriam que ser necessários tanto para o deslocamento, quanto para a admissão do julgamento.

Porém, além de o art. 947 ter aludido a “interesse público” ao tratar de uma fase específica, das duas locuções insertas no artigo – “grande repercussão social” e “interesse público” – pode-se retirar previsões absolutamente similares, de modo que não se pretendeu criar dois requisitos diferentes para a admissão da assunção de competência. Objetivou-se, isto sim, frisar que tanto o órgão originariamente competente, quanto o órgão para o qual a competência foi deslocada, têm poder para aferir razões para a assunção da competência com base tanto em uma quanto em outra locução. Na verdade, pretendeu-se evidenciar que o órgão competente para a assunção deve, após ter sido decidido o deslocamento pelo órgão de competência originária, afirmar ou não razão suficiente para a assunção da competência.

Sublinhe-se que o órgão para o qual foi deslocada a competência só pode decidir pela assunção da competência depois de o órgão originário ter reconhecido que a questão de direito tem “grande relevância social”. Ora, se não pode haver dúvida que resolução de questão de direito de “grande relevância social” é indicativo bastante de existência de interesse público; o mesmo, obviamente, jamais poderia servir para o órgão colegiado da segunda fase negar a existência de “grande repercussão social”, mas, a princípio, apenas para o colegiado afirmar i) que há grande repercussão social e, por consequência, interesse público, ii) que há interesse público além de grande repercussão social ou iii) que há apenas motivo de interesse público, e não de grande impacto social. Essas duas últimas hipóteses, porém, são inaplicáveis. Em primeiro lugar porque não haveria sentido em exigir um requisito para abrir mão da competência e dois requisitos para assumir a competência, quando, como visto, trata-se apenas de saber se há razão para a “assunção de competência”. Além disso, a grande repercussão social é o critério para o órgão originariamente competente abrir mão da sua competência em favor da assunção, de modo que não há qualquer sentido em supor que o colegiado, que assume a competência, pode negar a existência de grande repercussão social em favor de outro critério, que estaria encartado no interesse público. Sem dúvida, o legislador equiparou grande repercussão social a interesse público para efeito de assunção de competência.

Tudo isso significa que a locução “interesse público”, posta no § 2.º do art. 947, gera ao colegiado, para o qual o caso foi deslocado, a necessidade de reafirmar que a questão tem grande repercussão social e, por consequência, de declarar que há interesse público no julgamento do caso. Isso ocorre exatamente porque o colegiado ao qual a competência é deslocada tem que concordar em assumir a competência, não bastando a decisão do órgão originariamente competente.

De qualquer forma, para evitar qualquer tentação e possibilidade de arbitrariedade, importa deixar claro que não se pode pensar que um órgão judicial pode assumir uma competência que, constitucionalmente, não é sua a partir de um motivo que não diga respeito à vida em sociedade, mas aos interesses da Fazenda Pública e, pior ainda, do governo.

6. Perigo de violação do direito ao juiz constitucionalmente competente diante do apelo relativo à repercussão social da questão de direito.

Ainda que o deslocamento da competência dependa da concordância do órgão originariamente competente, é claro que isto não basta quando se pensa em garantia do juiz natural. Essa garantia, como é óbvio, não é do órgão originariamente competente ou do Poder Judiciário, mas dos jurisdicionados. Trata-se de uma garantia do cidadão de que os seus casos não serão julgados por pessoas que – a partir de uma regra delineada a partir da Constituição: “juiz constitucionalmente competente” –, não estejam objetiva, e imparcialmente, predefinidas para o julgamento dos casos conflitivos.

No entanto, o enunciado “grande repercussão social”, revestido de textura altamente aberta, a princípio, permite ao intérprete extrair os mais diversos critérios para justificar quando uma

questão de direito pode justificar o deslocamento da competência atribuída ao juiz natural. Considerando-se que a compreensão do enunciado incide sobre um dos mais relevantes direitos fundamentais processuais – a garantia do juiz natural –, não há como deixar de chamar a atenção para o perigo envolvido na interpretação desta cláusula dotada de significado a ser determinado.

O problema aqui não mais é o de tentar explicar o significado de “grande repercussão social”, mas o de analisar o problema do texto propositadamente escrito pelo legislador para ser determinado pelo juiz. O problema seria resolvido, apenas, mediante a resposta de que este texto parte da premissa de que o legislador tem consciência de que a sua norma deve ser completada pelo juiz conforme as particularidades dos casos que lhe chegam às mãos? Parece que não.

É certo que a percepção de que determinadas “conclusões” dependem das circunstâncias específicas das situações concretas e dos momentos históricos fez o legislador compreender que, nessas hipóteses, deveria editar normas dotadas de conceitos vagos ou indeterminados ou dar ao juiz o poder de expressamente completar o texto legislativo, escolhendo uma opção adequada à justiça do caso concreto.³

A técnica das cláusulas gerais tem como premissa a ideia de que a lei é insuficiente e, nesse sentido, constitui elemento que requer complementação pelo juiz. Em virtude da cláusula geral, o juiz tem poder para elaborar a norma adequada à regulação do caso. A cláusula constitui texto legislativo que, conscientemente, lhe dá espaço para participar do processo de frutificação do Direito.

Se a técnica das cláusulas abertas deu ao juiz um espaço que não tinha, é necessário cuidado para que estas não sejam utilizadas de forma inadequada, ou de modo a permitir-lhe fazer valer as suas valorações pessoais ou as suas tendências moralizantes.⁴ Com certeza, as cláusulas gerais não pretendem dar a cada juiz a possibilidade de editar a sua própria norma. É interessante lembrar que Merryman, em estudo de direito comparado acerca da tradição do civil law, adverte que não se exige muito esforço para perceber que cláusulas como a da boa-fé dão ao juiz de civil law grande porção de poder equitativo indefinido, deixando-o quase sem responsabilidade diante da formulação legislativa, e distante do modelo de juiz concebido pela sua tradição.⁵

A saída, portanto, além de estar na racionalidade da argumentação que deve presidir a justificativa das decisões fundadas em cláusulas gerais, concentra-se na necessidade dessa justificativa advir da Corte Suprema incumbida de definir o modo como uma cláusula geral deve ser aplicada diante de determinada circunstância específica, que se repete em casos similares. Só o respeito aos precedentes da Corte Suprema pode deixar claro que a cláusula geral se destina a dar ao Judiciário poder de elaborar norma de aplicação geral, ainda que atenta a uma circunstância específica insuscetível de ser definida à época da edição do texto legal. A norma judicial derivada da técnica legislativa das cláusulas gerais, não obstante considere uma circunstância que surge no caso concreto, deve ter caráter universalizante a ser definido pelas Cortes Supremas, na medida em que não terá racionalidade caso não possa ser aplicada a casos futuros marcados pela mesma circunstância.⁶

Recorde-se que, no incidente de assunção de competência, caberá ao órgão originariamente competente, e ao órgão definido competente pelo regimento interno do tribunal para o julgamento dos casos, a tarefa de justificar a existência de questão de direito de grande repercussão social. O órgão que assume a competência, como visto, também tem a obrigação de reconhecer que há um caso revestido de questão de direito de grande repercussão social, não obstante o § 2.º do art. 947 fale em “interesse público” na assunção de competência.

Ambos os órgãos devem justificar as razões pelas quais entendem que a questão de direito envolvida no caso tem “grande repercussão social”. A racionalidade da justificativa é imprescindível para permitir o controle, e a legitimidade, da assunção de competência. Ademais, o próprio colegiado responsável pelo incidente de assunção de competência deve observar os critérios que já utilizou para determinar o significado de questão de direito com grande repercussão social. Não há razão para que as suas decisões tenham efeito vinculante (art. 947, § 3.º, CPC/2015) quanto à resolução da questão sobre os demais órgãos do tribunal e juízes –

§ 3.º, CPC/2015) quanto à resolução da questão sobre os demais órgãos do tribunal e juízes – eficácia vinculante vertical – mas não tenham em relação aos critérios para definir o que é uma questão de direito de grande repercussão social, e, portanto, sobre ele mesmo – eficácia vinculante horizontal. Na verdade, a decisão de tribunal que tem efeito vinculante vertical não pode deixar de ter eficácia vinculante horizontal. De modo que as decisões do colegiado sempre vincularão o próprio colegiado em relação à questão decidida – que só poderá ser revista em hipóteses excepcionais – e também em face dos pressupostos para o julgamento da questão de direito.

7. Relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

O § 4.º do art. 947 afirma que a fórmula processual prevista para a assunção da competência também se aplica quando “ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Trata-se também de uma transferência de competência para um colegiado definido pelo regimento interno do tribunal. A justificativa para a transferência do julgamento não é mais a existência de questão de direito com “grande repercussão social”. Basta uma relevante questão de direito e, especialmente, que a sua solução seja “conveniente” para prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. A transferência também é do julgamento do caso – recurso, remessa necessária ou ação originária – e não apenas da questão de direito.

Recorde-se que a dicção do art. 947, caput, é no sentido de que é admissível a assunção de competência quando “envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social”. No entanto, tal como descrito o pressuposto do caput, não há razão para supor que deve haver uma questão relevante e de grande repercussão social. É que a norma fala em relevante questão de direito, qualificando-a como de grande repercussão social após a vírgula, ou seja, não alude a relevante questão de direito e de grande repercussão social. A relevante questão de direito é, bem vistas as coisas, qualificada, ou definida, como de grande repercussão social, de modo que importa apenas saber se existe questão de “grande repercussão social”. No § 4.º, no entanto, fala-se apenas em relevante questão de direito, de forma que o “relevante” não busca ou tem qualificação, mas apenas considera a questão de direito. Nos termos do § 4.º a questão de direito tem que ser relevante; de acordo com o caput a questão de direito relevante é a de grande repercussão social.

Portanto, é certo que a relevante questão de direito do § 4.º nada tem a ver com a de grande repercussão social. Relevante questão de direito, para o efeito do § 4.º, é a questão de direito cuja solução é relevante para o esclarecimento da ordem jurídica. Assim, por exemplo, questão de direito controvertida, oriunda do novo CPC, cuja solução é importante para o adequado funcionamento do processo, certamente, é questão de direito relevante.

Contudo, para a assunção de competência do § 4.º, além de a questão de direito ter que ser relevante, a sua definição deve ser “conveniente” para a prevenção ou para a composição da divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

O caput do art. 947, ao aludir a questão de direito com grande repercussão social, obviamente, não quer dizer que a questão de direito com grande repercussão social não possa se repetir em algum processo; quer apenas esclarecer que a sua caracterização não depende de repetição em múltiplos processos. A questão de direito, que deve ser replicada em múltiplos processos para poder ser isoladamente julgada mediante incidente, é a que constitui questão prejudicial ao julgamento de demandas que se repetem. É a dita “questão idêntica” do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss.).

Se a razão de ser da transferência de competência prevista no § 4.º do art. 947 é a prevenção e a composição da divergência, há que existir uma questão que já se repetiu, e pode se repetir, em vários casos. A diferença é a de que, nessa hipótese, a questão de direito pode aparecer em diferentes demandas e, portanto, em recursos e ações originárias que não guardam qualquer semelhança, de lado, obviamente, a questão de direito. Bem por isso, a questão de direito não há que ser prejudicial ao julgamento de demandas; porém, apenas uma questão de direito envolvida

no caso. Basta que a questão de direito apareça como controvertida em vários recursos – ou reexames necessários ou ações originárias – e, assim, possa dar origem a divergência entre as câmaras ou turmas do tribunal. Lembre-se que, no incidente de resolução de demandas repetitivas, a repetição é das demandas que envolvem a mesma questão; aqui, basta a reiteração da questão em demandas distintas.

Assim, por exemplo, uma questão de direito de natureza eminentemente processual, embora posta em recursos que dizem respeito a casos que não guardam qualquer semelhança, pode dar origem a julgamento destinado a prevenir, ou a compor, a divergência. Da mesma forma, uma questão de direito que pergunta sobre prescrição, ao se colocar em vários recursos, pode suscitar uma única solução para o mesmo fim de evitar a divergência.

Todavia, a questão que assim pode se repetir deve ser tal que seja conveniente a sua definição para eliminar a divergência. Além de a questão dever ter uma natureza que faça presumir a sua constante aparição nos feitos futuros, a divergência que pode se formar diante dela, em vista do seu significado, deve ter um valor capaz de permitir ver que é conveniente a sua prevenção, ou composição, em nome dos valores da estabilidade e das posições jurídicas que, na situação concreta, dela dependem.

Reitere-se que, quando se pensa na assunção diante da divergência, fala-se em prevenção ou composição. Casos já julgados podem evidenciar a divergência, mas a existência de outros que devem ser julgados é que demonstra a necessidade de composição da divergência. Porém, quando há casos que estão para serem julgados, sem com que a divergência já tenha se manifestado entre câmaras ou turmas, pode haver razão para a prevenção da divergência.

Note-se que tanto a câmara ou a turma originariamente competente, quanto o colegiado que deve assumir o julgamento do caso, devem aferir, e justificar, os pressupostos para a assunção da competência. Vale dizer que, em primeiro lugar, a câmara ou a turma devem afirmar a existência de relevante questão de direito e a conveniência da prevenção ou composição da divergência. Mas, ao receber o caso, o órgão colegiado definido como competente pelo regimento interno do tribunal para os casos derivados de assunção de competência também deve reconhecer que a questão de direito é relevante, e que é conveniente a prevenção ou a composição da divergência.

Mais uma vez a justificativa torna-se relevante para a racionalização do significado de conceito jurídico determinável no caso concreto. É preciso que as decisões expliquem o significado de questão relevante e de conveniência da prevenção ou da composição de divergência para que haja efetivo controle, e legitimidade, da assunção de competência. Além disso, a devida justificativa é também importante para que possa haver coerência quando o tribunal voltar a decidir a mesma situação.

Se a decisão sobre a questão de direito tem efeito vinculante (art. 947, § 3.º, CPC/2015), o colegiado, ao decidir e fixar o significado dos conceitos jurídicos indeterminados, estará se autovinculando para os casos futuros. Realmente não há motivo para supor que as decisões sobre a questão de direito vinculam os demais órgãos do tribunal e juízes, mas as decisões a respeito dos pressupostos para se decidir a questão de direito não autovinculam o colegiado. Na verdade, as decisões do colegiado também vinculam a ele mesmo, seja no que toca à questão de direito – que só poderá ser revista em casos excepcionais, seja no que diz respeito aos pressupostos para julgá-la. O trabalho do próprio tribunal, mais uma vez, representará a melhor forma de controle e de racionalização das suas decisões.

8. Eficácia da decisão do incidente de assunção de competência em face das eficácias da decisão do incidente de resolução de demandas e dos precedentes das Cortes Supremas

8.1. Relação entre a decisão do incidente de assunção de competência, a decisão do incidente de resolução de demandas e os precedentes das Cortes Supremas.

As decisões proferidas nos dois casos – questão de “grande repercussão social” e “relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência

entre câmaras ou turmas do tribunal” – vinculam “todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese” (art. 947, § 3.º, CPC/2015).

Parte-se do pressuposto de que tais decisões, por definirem questão de grande relevância social e questão não só relevante como também cuja solução é conveniente para a prevenção ou à composição de divergência no tribunal, devem vincular os demais órgãos do tribunal e os juízes de primeiro grau.

É preciso frisar, contudo, que a circunstância destas decisões terem efeito vinculante não permite confundi-las com a decisão de questão idêntica, prejudicial à resolução de demandas repetitivas, nem com os precedentes das Cortes Supremas.

As decisões de questões idênticas, próprias ao incidente de resolução de demandas, resolvem questões que surgem, e ressurgem, em demandas que se repetem. Embora a questão seja sempre a mesma, ela diz respeito a demandas de sujeitos que, obviamente, têm o direito de discuti-la, ainda que seja por meio de um representante adequado (legitimado à tutela de direitos individuais homogêneos). A decisão da questão de direito, prejudicial ao julgamento das demandas repetitivas, produz coisa julgada erga omnes.

O incidente de assunção de competência diz respeito a uma questão de direito específica que, voltando à análise de órgão fracionário ou de juiz do tribunal que a julgou, não pode ser decidida de outra forma. A diferença é a de que, neste caso, a questão de direito é identificada por ser de grande repercussão social, ou por ser relevante e poder gerar divergência que, desde logo, deve ser obstada em nome dos valores da estabilidade, e não por constituir uma mesma questão replicada em múltiplas demandas repetitivas. No incidente de assunção, a identificação da questão para julgamento deriva da sua qualidade, e não da sua relação com demandas de massa. A qualidade da questão é que justifica a sua imediata decisão com eficácia vinculante para os casos que já existem ou estão por vir. Bem por isso, não sendo a questão influente sobre a tutela do direito de pessoas, ninguém pode ser dito privado da oportunidade de discuti-la, bem como não há que pensar em coisa julgada erga omnes.

Ademais, embora o incidente de assunção trate de questão de grande repercussão social, e de relevante questão a respeito da qual seja conveniente eliminar a divergência, a razão para a decisão destas questões é diferente daquela que inspira as Cortes Supremas.

Lembre-se que ao Judiciário podem ser reconhecidas duas funções básicas: a resolução de conflitos (resolution of disputes), e o desenvolvimento do direito ou enriquecimento das normas jurídicas (enrichment of the supply of legal rules). Cabe aos juízes e tribunais de apelação a primeira tarefa; e às Cortes Supremas, a segunda. Isso significa que, enquanto perante os tribunais importa especialmente o desejo do litigante de ver bem solucionado o caso, diante das Cortes Supremas espera-se a aderência das soluções jurídicas à realidade e à cultura sociais, ou seja, a emissão de decisões capazes de atribuir ao direito um sentido conforme às necessidades da vida das pessoas. Não é por outro motivo que as decisões, quando resolvem litígios, interessam às partes (res judicata) e, quando atribuem sentido ao direito, interessam à sociedade (ratio decidendi).⁷

Um tribunal de apelação não firma precedentes interpretativos por uma razão muito simples: não é função sua atribuir sentido ao direito e dar-lhe desenvolvimento, mas resolver os litígios. Os tribunais atuam de modo a revisar a “justiça” das sentenças de primeiro grau sem qualquer restrição. Há, assim, dois juízos repetitivos sobre o litígio, devendo o tribunal estar atento aos fatos litigiosos e à prova. Isso não quer dizer, como é óbvio, que os juízes e os tribunais não tenham que dedicar tempo e esforço para dar interpretação aos textos legais. Os juízes e tribunais têm aí a importante missão de colaborar para o amadurecimento da interpretação das leis e da solução das questões de direito. Se os juízes e tribunais não podem negar o sentido atribuído ao direito pelas Cortes Supremas, cabe-lhes dar início à atividade interpretativa do Poder Judiciário, fornecendo os primeiros exemplos de interpretação e de solução das questões de direito.

A função de resolver litígios deve dar aos tribunais a possibilidade de sedimentar os seus

entendimentos sobre o direito. Isso para que as Cortes Supremas possam resolver os impasses interpretativos a partir de interpretações delineadas, ou seja, com base no “direito vivo” ou na “jurisprudência uniforme” de cada um dos tribunais, e não a partir de decisões dispersas, e incapazes, de revelar os seus pensamentos. A jurisprudência uniforme do tribunal é formada a partir do resultado dos recursos, que devem espelhar uma determinada solução interpretativa, expressa na fundamentação e na ementa do acórdão. Vários julgados num mesmo sentido, ou seja, várias soluções interpretativas numa mesma direção, dão origem à “jurisprudência uniforme” do tribunal acerca de determinada questão.⁸

O incidente de assunção é uma técnica para a definição de questões de direito que tem clara relação com a “jurisprudência uniforme”. Isso porque o incidente de assunção objetiva alcançar uma única solução para questões de direito. A grande diferença em relação à jurisprudência uniforme é a de que, enquanto nessa última chega-se a uma interpretação única com o passar do tempo, e mediante debate oriundo da divergência formada a partir dos casos, nas hipóteses de assunção evita-se a divergência em nome de uma definição imediata da questão de direito.

Embora isso seja mais claro na hipótese do § 4.º do art. 947, a ideia de definição imediata da questão está implícita no motivo que abre oportunidade ao incidente de assunção em caso de questão de “grande repercussão social”. Na primeira hipótese, supõe-se conveniente prevenir ou compor a divergência; enquanto que, na segunda, a imediata “solução única” é uma consequência da grande repercussão social da questão de direito.

Contudo, o que realmente importa é que a solução imediata, e única, da questão nada tem a ver com função de desenvolvimento do direito, peculiar às Cortes Supremas. A razão destas decisões é simplesmente esclarecer a questão de direito para efeitos das demandas próprias à circunscrição do tribunal. O precedente que define o sentido do direito, emitido pelas Cortes Supremas, orienta a vida em sociedade e regula os casos futuros. Não é pensado para casos dotados de questões idênticas que estão para ser resolvidos ou ainda podem ser apresentados para julgamento.

Por isso mesmo, a eficácia das decisões do incidente de assunção e do incidente de resolução, assim como dos precedentes das Cortes Supremas, são distintas e peculiares.

8.2. Eficácia vinculante e coisa julgada erga omnes.

O CPC/2015 expandiu os limites objetivos da coisa julgada, que não é mais restrita ao dispositivo da decisão. Agora, a coisa julgada material também incide, nos termos do art. 503, § 1.º, do código sobre questão prejudicial, decidida expressa, e incidentemente, no processo, se: i) dessa resolução depender o julgamento do mérito; ii) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; iii) o juízo tiver competência em razão da matéria, e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

O incidente de resolução, a despeito do seu nomen juris, julga uma questão de direito prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas. Essa questão, como é óbvio, diz respeito aos litigantes das demandas repetitivas, que, por isso mesmo, não podem ser excluídos da sua discussão e, assim, participam do incidente por meio de representantes adequados – os legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos. Portanto, a decisão da questão de direito, no incidente de resolução, produz coisa julgada erga omnes, descabendo pensar em eficácia vinculante ou obrigatória.

Mas a eficácia vinculante das decisões tomadas no incidente de assunção de competência também não pode ser confundida com a eficácia natural aos precedentes obrigatórios das Cortes Supremas. Por várias razões.

Em primeiro lugar, a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas não precisa estar definida em lei. A Constituição Federal reserva ao STJ e ao STF uma função que, obviamente, não pode ser confundida com a dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. As Cortes Supremas, muito mais do que resolver casos conflitivos concretos, desses se valem para atribuir sentido ao direito, garantindo a sua unidade, bem como para desenvolvê-lo de acordo com os novos fatos e valores

sociais.

Não se quer dizer, obviamente, que as decisões das Cortes Supremas têm eficácia obrigatória por criarem o direito ou coisa que o valha. É certo que os textos que contêm normas jurídicas são, em maior ou menor medida, equívocos, e por isso mesmo impescindem de um significado que lhes é sempre atribuído pelo juiz. Porém, se todo e qualquer juiz, a princípio, atribui significado ao texto, a tarefa de frutificação do direito é do Judiciário e, portanto, não pode ser desenvolvida ao gosto de cada juiz. É exatamente por isso que os sistemas de distribuição de justiça contemporâneos têm cortes de vértice com a função de definir o sentido do direito e de dar-lhe desenvolvimento conforme a evolução da vida social.

A interpretação judicial agrega algo de novo à ordem jurídica sem invalidar, ou modificar, a legislação. Ao deixar a legislação intocada, dá conteúdo a uma ordem jurídica de maior amplitude, preenchida pela legislação, e pelos precedentes, das Cortes Supremas.

Isso quer dizer que um precedente de Corte Suprema fixa uma interpretação, ou solução, que deve orientar a sociedade e regular os casos futuros.⁹ Neste contexto, os precedentes das Cortes Supremas, obviamente, não se limitam aos litigantes envolvidos no caso, mas se estendem a toda coletividade com o caráter de direito. De modo que a eficácia obrigatória do precedente, circunscrita à sua *ratio decidendi*, nada mais é do que uma consequência da função da Corte Suprema de atribuir sentido ao Direito e desenvolvê-lo – ou, em outras palavras, de criar algo de novo na ordem jurídica vinculante.

Além do mais, a eficácia vinculante da decisão do incidente de assunção de competência diz respeito à solução da questão de direito, ou melhor, ao resultado do julgamento, que afirma a sua solução. Todos os demais órgãos do tribunal e juízes ficam vinculados à solução encontrada para a questão de direito. Esta decisão pode ser tomada a partir de vários fundamentos, não importando se algum deles foi compartilhado pela maioria do colegiado.

Nos recursos especial e extraordinário, ao contrário, como não se julga uma questão ou fundamento específico, mas um recurso que pode ser discutido a partir de várias questões ou fundamentos, o resultado do recurso não tem como obrigar os tribunais e juízes. O que pode obrigar é a *ratio decidendi*, ou seja, as razões que amparam o fundamento que determinou a solução do recurso. Essas razões, no entanto, devem ser compartilhadas pela maioria do colegiado. É que o entendimento da corte está nas razões que sustentam o fundamento majoritário, e não nas várias razões que apontam para o resultado do recurso. Um fundamento concorrente, apesar de apontar para o mesmo resultado, obviamente, não expressa o entendimento daqueles que firmam o fundamento majoritário. O problema ocorre, como se vê, quando nenhum dos fundamentos é compartilhado pela maioria. Nesse caso não há *ratio decidendi* e, portanto, precedente.

8.3. Rigidez da preclusão.

O fato de a eficácia vinculante, no caso de incidente de assunção de competência, ser restrita à solução da questão de direito, tem consequência sobre a preclusão inerente à decisão do tribunal. A preclusão das decisões do incidente de assunção de competência é mais rígida, na medida em que os litigantes e o juiz de caso posterior têm um espaço menor para cogitar de distinção (art. 489, § 1º, VI, CPC/2015).

Se o caso sob julgamento diz respeito à questão de direito já decidida em incidente de assunção, nem o litigante inconformado ou o juiz poderão argumentar para que a decisão seja ou não aplicada sob o fundamento de o caso ter particularidades específicas. Não será possível argumentar, nem para restringir ou para estender, a aplicação da decisão da questão de direito. A única distinção possível, na hipótese, deriva de a questão de direito ser outra.

É que a decisão do incidente de assunção não se destina a fixar um entendimento para a regulação dos casos futuros, mas apenas resolve uma questão de direito importante para a distribuição da justiça no âmbito da circunscrição do tribunal. A decisão não se propõe a orientar a sociedade e fixar critério para a regulação dos casos que estão por vir, mas apenas, e tão

somente, a evitar que os juízes dos casos futuros decidam a questão de direito de maneira diversa.

Os precedentes das Cortes Supremas conferem amplo espaço para os tribunais e juízes solucionarem casos similares. A lógica da aplicação dos precedentes não apenas permite dizer que o precedente não deve ser aplicado em razão de o caso sob julgamento ser distinto. Um precedente deve regular caso que, a princípio, deixou de ser abarcado, mas não tem qualquer razão jurídica para por ele não ser regulado, bem como não deve regular caso que, a princípio, foi contemplado, porém possui particularidades que o torna incompatível com a *ratio decidendi*. Nessas hipóteses, a extensão e a limitação do precedente não apenas é possível, como é necessária para a coerência do direito e para a tutela da igualdade perante a distribuição da justiça.

A distinção não é uma técnica de mera diferenciação; é, isto sim, uma técnica de desenvolvimento do direito mediante a aplicação de precedentes. A distinção permite não apenas a adequada aplicação do direito, mas também o seu apropriado desenvolvimento. Com a extensão, ou a limitação do alcance dos precedentes, esses se tornam adequados à regulação de outras e distintas realidades.¹⁰ O direito, tal como posto no precedente, adapta-se às situações que surgem na medida em que o tempo passa.¹¹ A técnica da distinção permite que o sistema de precedentes, sem perder a sua função de tutela dos valores da estabilidade, torne-se maleável e capaz de permitir o desenvolvimento do direito, dando conta das novas realidades sem que seja preciso a revogação do precedente que ainda é necessário, e suficiente, para tratar das situações que foram contempladas desde o seu nascimento.

Portanto, realizar distinção para aplicar ou deixar de aplicar um precedente é algo que milita, a um só tempo, para a estabilidade e para o desenvolvimento do direito, ao contrário da mera distinção realizada para dizer que uma questão de direito é igual ou não àquela que já foi decidida. Uma decisão proferida em incidente de assunção não tem autoridade para regular caso diverso, mas também não dá ao litigante de novo caso espaço para argumentar que este, apesar de a princípio contemplado, por ela não deve ser regulado. No caso de solução de questão de direito por Tribunal de Justiça ou Regional Federal, a decisão aplica-se ou não. Isso porque, como já dito, um tribunal não decide para orientar a sociedade e regular novos casos, mas para resolver conflitos e, quando necessário, resolver questões de direito importantes para a desempenho da sua prestação jurisdicional. Daí porque o novo litigante, diante da decisão proferida no incidente de assunção, não tem o mesmo espaço para procurar afastar a vinculação do juiz que está à frente do caso sob julgamento.

Aliás, a rigidez da preclusão é ainda maior quando se tem em conta a decisão de questão prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas. Nesse caso, há coisa julgada *erga omnes*, a afastar qualquer possibilidade de cogitação sobre a incidência da decisão da questão sobre a demanda repetitiva. Essa é julgada a partir da solução conferida à questão de direito no incidente de resolução, sendo despicando ao demandante argumentar que a questão de direito é a mesma. Nessa situação, basta invocar a coisa julgada.

8.4. Eficácia preclusiva e revisão da decisão.

O incidente de resolução, ao julgar a questão de direito prejudicial ao julgamento das demandas repetitivas, faz com que opere coisa julgada sobre a questão de direito com eficácia *erga omnes*. O fato de a decisão julgar questão prejudicial à tutela dos direitos dos litigantes excluídos de participação direta no incidente torna necessária a participação dos representantes adequados – legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos.

A coisa julgada *erga omnes* oriunda da decisão do incidente de resolução não é apenas a favor dos representados, como acontece na ação coletiva de tutela de direitos individuais homogêneos (art. 103, III, CDC), mas *pro et contra* – podendo beneficiar ou prejudicar. Os artigos 985 e 986 do CPC/2015 falam em “revisão” da decisão da questão jurídica em face dos casos futuros. Essa pretensão “revisão” somente pode ser a busca de uma outra decisão, que não se sobreponha à decisão acobertada pela coisa julgada. Diante de decisão que produziu coisa julgada, é possível ter, no máximo, pequena alteração do objeto litigioso para se ter outra decisão e outra coisa julgada; mantendo-se a decisão já proferida, e a coisa julgada que lhe reveste, intactas.

Como a decisão do incidente de resolução, proferida em face do representante adequado, pode produzir coisa julgada contra os representados, cabe perguntar se outro representante adequado ou mesmo os representados podem invocar fundamento não deduzido (mas dedutível) para rediscutir a questão decidida no incidente.

O art. 503 afirma que a coisa julgada sobre questão depende de “contraditório prévio e efetivo”, não ocorrendo “no caso de revelia” (art. 503, § 1.º, II, CPC/2015) nem quando “houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial” (art. 503, § 2.º, CPC/2015). Nos Estados Unidos a situação é semelhante. Os efeitos preclusivos da coisa julgada sobre a questão – collateral estoppel – são limitados ao efetivamente discutido com base na preocupação de não prejudicar o litigante que não a discutiu adequadamente.¹²

Ora, se a parte que não discute a questão de forma adequada não deve ficar obstada de voltar a discuti-la, o litigante excluído cujo representante não discutiu determinado fundamento, por motivo mais evidente, não pode ser proibido de invocá-lo para rediscutir a questão. O litigante excluído, obviamente, não pode ser prejudicado pela não dedução de fundamento pelo representante adequado. A não dedução de fundamento que permite rediscutir a questão é, por si só, evidência de déficit de representação, que deve poder ser remediado mediante a abertura à rediscussão da questão decidida.

Portanto, a regra do deduzido e do dedutível, prevista no art. 508 do CPC/2015, não se aplica à coisa julgada sobre questão decidida no incidente. Qualquer legitimado à tutela dos direitos individuais homogêneos, que não tenha participado do incidente, pode invocar fundamento não discutido e decidido para rediscutir a decisão em face dos casos futuros. Da mesma forma, os titulares de pretensão à tutela de direito, que dependem da resolução da mesma questão de direito, não ficam proibidos de invocar o fundamento não discutido, e decidido, em suas demandas individuais.

Isso significa que a eficácia preclusiva, em caso de decisão firmada em incidente de resolução, não abarca o dedutível. Na verdade, a eficácia preclusiva, diante da decisão de questão, fica restrita ao efetivamente discutido e decidido.

Quando se fala em revisão de decisão proferida em incidente de assunção de competência, ou mesmo em revogação de precedente de Corte Suprema, aponta-se para a possibilidade de qualquer litigante, mediante argumentação, demonstrar que a decisão e o precedente, respectivamente, estão a merecer revisão e revogação. Nestes casos, não importa a regra do deduzido e do dedutível. Importa, em verdade, determinar a partir de que perspectiva a decisão e o precedente podem ser questionados.

Um precedente pode ser revogado quando passa a negar proposições morais, políticas e de experiência ou quando deixa de guardar coerência com os fundamentos de outras decisões da própria Corte Suprema.¹³ O precedente também pode ser revogado quando há alteração da concepção geral sobre o direito – revelada em artigos etc. – ou quando, excepcionalmente, baseou-se num equívoco. Enfim, um precedente não pode ser colocado em discussão em razão da discordância de um litigante ou mesmo de um juiz, ainda que, teoricamente, sustentável.

Porém, o que diferencia a revisão da decisão proferida em incidente de assunção de competência da revogação de precedente de Corte Suprema é a circunstância de que, no primeiro caso, há uma decisão que esclarece questão jurídica importante para a prestação jurisdicional no âmbito do tribunal, enquanto que, no segundo, há uma ratio decidendi que, ao apontar o sentido do direito, orienta a sociedade e regula os casos futuros em todo o território nacional.

A tarefa de esclarecer questão de direito é muito mais modesta do que a de apontar o sentido do direito. Se todo tribunal deve esclarecer o direito para julgar os casos, apontar ou definir o sentido do direito é função reservada às Cortes Supremas. O impacto da revisão de uma decisão que esclareceu questão de direito é, obviamente, menor do que o da revogação de um precedente que atribui sentido ao direito. Pense-se nos valores da “confiança justificada” e da “vedação da

surpresa injusta”, que podem ser violados diante de uma revogação abrupta de um precedente. Uma decisão que revoga precedente, que orienta a sociedade, não pode retroagir de modo a atingir aqueles que tinham motivos para ter confiança no precedente que estava em vigor na época em que os fatos do caso aconteceram. Revogação sem critérios pode significar “surpresa injusta”. É exatamente por isso que se pode admitir, ainda que em casos excepcionais, a manutenção dos efeitos do precedente para não se prejudicar aqueles que nele se pautaram.

A decisão de tribunal, além de limitada ao âmbito da sua circunscrição, está relacionada ao esclarecimento da questão de direito. Ora, uma decisão de tribunal que esclarece o direito, certamente, não reclama a mesma estabilidade da decisão que atribui sentido ao direito para todo o país.

Nesse sentido, os critérios que abrem oportunidade para a revisão da decisão da questão decidida no tribunal são menos rígidos do que aqueles que oportunizam a revogação de precedente. Não há motivo para exigir incompatibilidade da decisão com novas proposições morais, políticas e de experiência ou mesmo alteração da concepção geral sobre o direito. Importa, para a revisão da decisão de tribunal, fundamentalmente, a inconsistência sistêmica da decisão, derivada da existência de decisões – do próprio tribunal – baseadas em razões incompatíveis com as que sustentam a decisão do incidente. O surgimento de razões de direito incompatíveis – diante de questões diversas – com as que estão à base da decisão, no âmbito dos órgãos fracionários do tribunal, não só favorecem os argumentos dos interessados na revisão da decisão, mas também impõem ao tribunal a sua reavaliação. Também são suficientes argumentos robustos, embora não necessariamente unânimes, da doutrina em sentido contrário ao da decisão. Esses podem abrir oportunidade para a revisão da decisão, conforme o caso. Note-se, aliás, que o § 3.º do art. 947 fala em revisão, e não em revogação. Numa perspectiva meramente lógica, motivos para pedir a revisão não precisam ser tão fortes quanto motivos para pedir a revogação. De qualquer forma, a opção linguística do legislador favorece a ideia de que os critérios para a revisão da decisão do tribunal em incidente de assunção são menos rígidos do que aqueles que permitem a revogação de precedente de Corte Suprema.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Ver Luiz Guilherme Marinoni, O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos, *Revista de Processo*, v. 249, p. 413.

2

STF, RE 590.809, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014.

3

Normas desse tipo, ditas cláusulas gerais, resultam de uma técnica legislativa que se contrapõe à técnica casuística. A técnica casuística é utilizada quando, para a estruturação da lei, são estabelecidos critérios para a qualificação dos fatos normados, ao passo que as cláusulas gerais são caracterizadas por vagueza ou imprecisão de conceitos, tendo o objetivo de permitir o tratamento de particularidades concretas e de novas situações, inexistentes e imprevisíveis à época da elaboração da regra. Ver Nicola Picardi, *La vocazione del nostro tempo per la giurisprudizione*. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2004, p. 46.

4

Franz Wieacker, em sua importante “História do Direito Privado Moderno”, ao analisar o processo de formação do Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemão) advertiu que “o reverso das cláusulas gerais foi de há muito notado. Se a disciplina dogmática do juiz se torna mais rigorosa, dá-se uma tentativa de ‘fuga para as cláusulas gerais’ (Hedemann), para uma jurisprudência voltada exclusivamente para a justiça e liberta da obediência aos princípios; em épocas de predomínio da injustiça, elas favorecem as pressões políticas e ideológicas sobre a jurisprudência e o oportunismo político. Mesmo abstraindo destas épocas de degenerescência, elas possibilitam ao juiz fazer valer a parcialidade, as valorações pessoais, o arrebatamento jusnaturalista ou tendências moralizantes do mesmo gênero contra a letra e contra o espírito da ordem jurídica. Por outro lado, o uso inadequado, hoje cada vez mais frequente, das cláusulas gerais pelo legislador atribui ao juiz uma responsabilidade social que não é a do seu ofício. Todas estas manifestações se baseiam no fato de a cláusula geral não permitir e, ao mesmo tempo, esvaziar de sentido qualquer atividade substantiva, desde que ela, por seu lado, não remeta para a situação bem definida de uma moral estabelecida e de uma técnica judicial firme. Enquanto a teoria do direito e a tradição judicial não desenvolverem uma técnica refletida do uso correto da cláusula geral, ela constitui um perigo crescente para as nossas ordens jurídicas” (Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung* (1967), 2. ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, p. 476-477).

5

“It is true that the legislature has acted and that its action is expressed as a substantive rule of law, but the terms are so broad (‘good faith’, which is not defined in the code, has an almost unlimited area of potential application) that the judge is hardly constrained by the legislative formulation. What that statute means depends on what judges do with it in concrete cases. What they do with it in concrete cases becomes the law in fact, although not in theory”. (John Henry Merryman, *The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin America*, Stanford: Stanford University Press, 2007, p. 53).

6

Na verdade, em uma perspectiva lógico-argumentativa, toda e qualquer decisão deve ser universalizável, sob pena de não ser justificada do ponto de vista do sistema jurídico. O caso das cláusulas gerais é um em que essa necessidade é ainda mais sensível. Sobre a universalização no direito, com ampla indicação bibliográfica, Paula Pessoa Pereira, *A Legitimidade dos Precedentes – Universalidade das Decisões do STJ*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

7

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., cit., Capítulo IV, item 2; Id., *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. Ed., cit.; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, 2. Ed., cit.; Id., *Precedentes*, cit.

8

É claro que a jurisprudência uniforme, nessa perspectiva, não mais está ligada à tutela da lei ou à correção das decisões a partir do sentido exato da lei. A jurisprudência uniforme é o resultado dos vários julgados

do tribunal acerca da interpretação da lei ou da devida solução de uma questão de direito, apresentando-se como dado que a um só tempo revela o entendimento do tribunal e o critério para a revisão das sentenças.

9

Como diz Wróblewski, o suposto da criatividade ocorre se, e somente se, uma decisão interpretativa influi de fato na aplicação do direito de maneira análoga às regras legais. Isso ocorre quando a decisão da Corte Suprema é considerada argumento nas atividades interpretativas futuras dos tribunais inferiores nos sistemas de civil law (Jerzy Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, Madrid: Civitas, 2001, p. 84).

10

A aplicação da técnica da distinção exige a ponderação entre os fundamentos ou as razões do precedente (substantive reasons) e os valores que justificam o sistema de precedentes obrigatórios, vale dizer, os valores da segurança, da igualdade e da coerência da ordem jurídica (authority reasons). Nesse sentido, a extensão do precedente prioriza as suas próprias razões, pois tende a permitir que ele regule novos casos, enquanto a limitação preserva as razões da estabilidade, na medida em que não possibilita que se dê a mesma solução jurídica a casos diversos. Porém, a limitação do precedente, bem vistas as coisas, nem sempre tutela a estabilidade. Esse valor é preservado, em realidade, mediante a contenção do precedente, evitando-se não só a sua extensão, mas também a sua limitação. Note-se que a limitação do precedente pode derivar do intuito de não se tratar do mesmo modo de caso que, em princípio – ou seja, sem a limitação –, seria semelhante, a merecer igual solução. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4a. ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, Capítulo III, item 4.2; Patrícia Perrone Campos Mello, *Precedentes*, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 201 e ss.

11

V. Frederick Schauer, *Thinking like a lawyer*. Cambridge: Harvard University Press, 2009. esp. itens 5, 8 e 9.

12

“(...) preclusion in second trial must not work an unfairness” (Otherson v. Department of Justice, I.N.S., United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, June 21, 1983, 711 F.2d 267, 228 U.S.App.D.C. 481).

13

Melvin Eisenberg, *The nature of the common law*, Cambridge: Harvard University Press, 1998, p. 14, 26 e 37.

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO IV. DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Capítulo IV. Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade

1. Compreensão do controle de constitucionalidade exercido na forma incidental ao julgamento do caso

1.1. Controle concreto. No controle concreto, a análise da constitucionalidade da norma – que é pressuposto à resolução da demanda – se apresenta conjugada à aferição de direito subjetivo ou interesse legítimo, cuja tutela jurisdicional dela depende. A constitucionalidade da norma, em outras palavras, não é o objeto ou mesmo o fim do processo. O processo não é instaurado em virtude de dúvida acerca da legitimidade da norma nem objetiva definir a sua constitucionalidade. O controle abstrato, ao contrário, considera a norma em si, desvinculada de direito subjetivo e de situação conflitiva concreta. Busca-se apenas analisar a validade constitucional da norma, independentemente de ser imprescindível, ou não, à tutela jurisdicional de um direito. O controle abstrato ocorre em processo voltado unicamente à análise da constitucionalidade da norma, fazendo surgir, neste sentido, um processo autônomo para o controle de constitucionalidade.

Lembre-se que a evolução do sistema austríaco de controle de constitucionalidade, caracterizada pela reforma constitucional de 1929, conferiu à Corte Suprema e à Corte Administrativa austríacas o poder de requerer à Corte Constitucional a análise de lei cuja validade fosse prejudicial à solução de caso que deveria resolver.¹ Os tribunais superiores austríacos, em caso de dúvida acerca da constitucionalidade de lei prejudicial ao julgamento de caso conflitivo, passaram a ser obrigados a requerer à Corte Constitucional a definição da sua constitucionalidade, vinculando-se ao seu pronunciamento. A Constituição italiana de 1948 e a Constituição alemã de 1949 instituíram modelos de controle de constitucionalidade similares ao austríaco, reservando-se o controle de constitucionalidade a uma Corte Constitucional. Assim como o sistema austríaco, os modelos alemão e italiano não apenas permitem que o controle da constitucionalidade seja requerido de forma direta, como também viabilizam o controle incidental aos casos concretos, permitindo que se peça à Corte Constitucional a análise de lei cuja constitucionalidade seja duvidosa. Porém, diversamente do austríaco, que dá este poder apenas às Cortes Suprema e Administrativa, os sistemas italiano e alemão dão a qualquer juiz o poder de invocar a Corte Constitucional. Ressalte-se que o juiz, obrigado a arguir a questão de legitimidade constitucional, não exerce controle de constitucionalidade, mas, ao menos, não é obrigado a aplicar lei reputada inconstitucional.²

A alusão a estes sistemas e, sobretudo, a estas formas associadas (incidental e concentrada) de controle de constitucionalidade, deve-se ao interesse em ressaltar que o controle de constitucionalidade, ainda que reservado a um único órgão (a Corte Constitucional), pode ser incidental ao julgamento de um litígio e, assim, ter natureza concreta. Note-se que, embora sejam separados dois juízos – um em que se faz apenas a análise da constitucionalidade e outro em que se aprecia o caso concreto a partir da definição acerca da questão constitucional –, o caso concreto, de que brotou a arguição da questão, exerce influência sobre o juízo da Corte Constitucional, que definirá a legitimidade constitucional da norma.

Ainda que o controle concreto derive, em regra, do controle de constitucionalidade feito pelo próprio juiz incumbido de julgar o litígio, ele pode decorrer do controle que se dá a partir da arguição do juiz de primeiro grau à Corte Constitucional. Há, nessa última hipótese, controle

concreto e incidental conjugado a controle concentrado, uma vez que, nos sistemas de Corte Constitucional, o controle de constitucionalidade é concentrado neste órgão. Isso permite dissociar o controle concreto e incidental do controle típico aos sistemas em que o poder de controlar a constitucionalidade é distribuído a todos os órgãos do Poder Judiciário.

Mas se o controle concreto pode assumir a forma de concentrado, é preciso verificar a sua dissociabilidade do controle incidental. Ou melhor, é preciso investigar a possibilidade de o controle concreto ocorrer no controle principal, que se dá por via de ação endereçada ao órgão incumbido de controlar a constitucionalidade.

O controle principal, que tem como contraposto o controle incidental, em regra constitui controle abstrato. Quando o controle de constitucionalidade se dá por intermédio de ação direta endereçada à Corte Constitucional ou à Corte Suprema, ou, no caso brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal, instaura-se processo autônomo para tanto, desvinculado de caso concreto a ser resolvido pelo Poder Judiciário. O controle por via de ação direta, dito controle direto, viabiliza o controle abstrato da norma impugnada. Porém, há casos excepcionais em que se permite, mediante ação direta à Corte Constitucional ou ao Supremo Tribunal Federal, alegação de inconstitucionalidade que leva em conta situação pessoal, de direito substancial, afetada pela norma reclamada. É o caso do recurso constitucional alemão (*Verfassungsbeschwerde*), que pode ser dirigido à Corte Constitucional por sujeito que se diz titular de direito fundamental – ou a ele assimilável – afetado por ato – que pode ser legislativo – ou omissão do Poder Público.

No direito brasileiro, o mandado de injunção exemplifica caso de ação, especialmente dirigida ao Supremo Tribunal, em que o controle de constitucionalidade é concreto. A Constituição Federal instituiu o mandado de injunção para a situação em que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5.º, LXXI), reservando-o, em relevantes casos, à competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, q). Trata-se, assim, de ação endereçada ao Supremo Tribunal Federal, cujo objetivo é, mediante a impugnação de inconstitucionalidade por omissão, tutelar direito constitucional relacionado à situação pessoal e concreta deduzida em juízo pelo demandante. Bem por isso, o controle não é abstrato.

1.2. Controle incidental. Há sistemas em que o controle da constitucionalidade pode ser feito diante de qualquer caso conflitivo, como prejudicial à solução do litígio. É o que ocorre, desde os primórdios, no sistema estadunidense, em que se fixou o entendimento de que o juiz, tendo poder para decidir, possui, por consequência, poder para analisar a validade constitucional da lei que é prejudicial à solução do caso que lhe é submetido.³ É o que também acontece no direito brasileiro, desde a Constituição de 1891.⁴ Quando, no curso de um processo “comum”, é arguida a inconstitucionalidade da lei que constitui pressuposto à tutela jurisdicional do direito, o juiz brasileiro está autorizado a tratar da questão constitucional como prejudicial ao julgamento da demanda. O objeto do processo é um litígio entre as partes, o qual não se confunde com a questão constitucional que, suscitada incidentalmente, configura-se como prejudicial à resolução do mérito. Nestes casos, há controle incidental de constitucionalidade.

O contraposto do controle incidental é o controle principal. No controle principal a questão constitucional não é suscitada incidentalmente nem constitui prejudicial ao julgamento do litígio que constitui objeto do processo. No controle principal, o objeto do processo é a própria questão constitucional.

O controle principal ocorre por meio de ação direta, dirigida à Corte Constitucional ou ao tribunal de cúpula do Judiciário. Se o controle incidental pode se dar quando o juiz, condutor do processo instaurado em virtude de litígio entre as partes, tem poder para controlar a constitucionalidade das leis, como ocorre no direito brasileiro e no direito estadunidense, nos sistemas em que o controle de constitucionalidade é reservado a uma Corte Constitucional, como no alemão, italiano e espanhol, o controle incidental ocorre em virtude de arguição do juiz ordinário à Corte Constitucional. O controle é derivado de arguição a respeito da constitucionalidade de norma que constitui prejudicial ao julgamento do mérito. Portanto, não há dúvida que o controle de constitucionalidade, neste caso, também é incidental.

O controle incidental é sempre de natureza concreta. O controle principal, em regra, é de natureza abstrata, mas pode, excepcionalmente, ter natureza concreta, como é exemplo o mandado de injunção. Controles principal e incidental constituem “modos” como a questão de constitucionalidade é levada à apreciação do Judiciário. Enquanto isso, os controles abstrato e concreto exprimem a maneira como a questão de constitucionalidade é apreciada e julgada pelo Judiciário. Quando a questão de constitucionalidade é relacionada com uma situação pessoal e concreta, há controle concreto. Na hipótese em que se examina a compatibilidade da norma com a Constituição, independentemente de qualquer situação concreta, há controle abstrato.

Por fim, apenas para evitar mal-entendido, é importante rechaçar a terminologia “controle por via de ação”, com significado de controle principal, e “controle por via defesa”, como sinônimo de controle incidental. O modo incidental não se perfaz apenas por defesa, podendo advir da própria ação, que pode afirmar, como causa de pedir, a inconstitucionalidade de lei. É o que ocorre no mandado de segurança em que o impetrante alega, por exemplo, que a lei em que se funda o imposto que a autoridade está a exigir é inconstitucional.

1.3. Controle difuso. O controle difuso tem íntima relação com o controle incidental, chegando, frequentemente, a ser com ele confundido. É que se afirma que, quando a constitucionalidade da lei pode ser examinada como prejudicial à solução de qualquer litígio, o controle é difuso. Mas a ideia carece de consistência. Quando o poder de controlar a constitucionalidade é distribuído aos órgãos do Poder Judiciário diante de todo e qualquer caso, este pode e deve ser feito por todos os órgãos judiciais nas formas incidental e concreta. Contudo, no mesmo sistema em que se outorga competência para o controle judicial da constitucionalidade em face de qualquer caso, é possível dar à Suprema Corte competência para realizá-lo na forma principal, mediante ações diretas.

Na verdade, se o controle de constitucionalidade é deferido aos juízes em face de todo e qualquer caso, inexistindo previsão de via direta, o controle é difuso, mas, note-se bem, incidental. De outra parte, se o controle é conservado nas mãos da Corte Constitucional, este é concentrado, mas, sublinhe-se, exercido na forma principal. Isso quer dizer que, nos sistemas em que os juízes exercem o controle de constitucionalidade diante de qualquer caso e, ao lado disso, este controle também é deferido à Suprema Corte mediante a via direta, há controle difuso decorrente das formas incidental e principal. Misturam-se, portanto, os modelos incidental e principal, não o controle difuso com o concentrado. Se existe sistema misto, esse é constituído pelo modelo incidental somado ao principal, os quais, por sua vez, permitem o controle concreto e o controle abstrato, ainda que a via principal possa, excepcionalmente, também levar ao controle concreto.

Na mesma perspectiva de encaminhamento do raciocínio, parece certo sustentar que o sistema austríaco pós-1929, com a introdução da possibilidade de arguição de inconstitucionalidade pelas Cortes Suprema e Administrativa à Corte Constitucional, não apenas não fez surgir sistema misto, como, na verdade, nem mesmo interferiu no modelo concentrado. Perceba-se que, ainda que se admitisse que as Cortes Suprema e Administrativa passaram a participar do controle de constitucionalidade, nesta hipótese não haveria atuação de juiz de primeiro grau de jurisdição, como, por exemplo, nos atuais sistemas italiano, alemão e espanhol. De qualquer forma, nem as Cortes Suprema e Administrativa, no sistema austríaco, nem o juiz, nos sistemas italiano, alemão e espanhol, exercem controle de constitucionalidade; estes, na verdade, têm o seu poder limitado à arguição da questão de constitucionalidade.⁵ Há aí, evidentemente, contribuição para a força normativa da Constituição, mas não controle de constitucionalidade. Em tais sistemas, o controle de constitucionalidade nunca deixou de ser concentrado na Corte Constitucional. A arguição de inconstitucionalidade permite pensar, no máximo, em difusão da legitimidade à arguição de inconstitucionalidade; nunca em difusão do controle da constitucionalidade.

Portanto, quando a Corte Constitucional, além de poder exercer o controle pela via principal, pode atuar a partir de arguição feita por juiz, não há sistema misto a conjugar controle concentrado e controle difuso. Há, igualmente neste caso, apenas mistura do controle incidental com o controle principal, conduzindo, ainda, aos controles concreto e abstrato.

Tudo isso significa que o sistema brasileiro não deve ser visto como um sistema resultante da

associação entre controle difuso e controle concentrado. No Brasil há sistema apenas difuso. A conjugação está no modo como se permite o controle – incidental e principal – e na dimensão em que o Judiciário pensa o controle – concreto e abstrato.

Note-se que o art. 948 do Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do art. 480 do Código de 1973, fala expressamente em “controle difuso” ao se referir ao “incidente de arguição de inconstitucionalidade”. Dizia o art. 480: “Arguida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público...”. Diz o art. 948: “Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público...”. Portanto, basta apenas perceber que no lugar de “controle difuso” não há como não ler “controle incidental”.⁶

2. Declaração incidental de inconstitucionalidade nos Tribunais Estaduais e Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça. Uma das notas que singularizam o sistema processual constitucional brasileiro diante dos seus congêneres está na conjugação da possibilidade de todos os juízes exercerem o controle de constitucionalidade em qualquer caso judicial ao controle mediante a via principal, reservado ao Supremo Tribunal Federal especialmente para o controle abstrato.

Todos os juízes de primeiro grau têm poder para, diante de qualquer demanda, não aplicar lei considerada inconstitucional. Porém, os órgãos fracionários dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça não podem assim proceder diante de recurso ou ação originária, situação que, quando comparada à possibilidade de o juiz singular realizar o controle de constitucionalidade, é estranhável. O art. 97 da Constituição Federal afirma que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. Dessa norma extrai-se o que se denominou de regra da reserva de plenário.

A circunstância de a norma só poder ser declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial não tinha como não levar ao fracionamento do julgamento dos recursos e das ações em que o órgão fracionário se depara com norma que reputa inconstitucional. Daí o incidente de arguição de inconstitucionalidade, tal como delineado entre os arts. 948 e 950.

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

1. Submissão da arguição de inconstitucionalidade ao órgão fracionário. Se uma das partes argumenta com a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, cabe ao relator, depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter a questão à turma ou à câmara (art. 948, CPC). Para o relator proceder dessa forma, não é preciso que uma das partes peça a instauração do incidente de inconstitucionalidade. Se um dos litigantes sustenta uma conclusão que, para ser atingida, necessariamente depende de se ter a norma como inconstitucional, o relator obviamente pode atuar de ofício, dispensando requerimento no sentido de que a lei seja reconhecida inconstitucional pela maioria absoluta do órgão competente do tribunal. Num caso como este, o relator deve convocar o Ministério Público e as partes para se manifestarem e, logo depois, submeter a questão ao órgão fracionário de que participa.

Quando o Ministério Público ou uma das partes requer a remessa da questão ao plenário ou órgão especial, o relator deve necessariamente considerar o tema em seu relatório, submetendo-o à análise dos seus pares. Não pode deixar de propor a discussão da arguição por ocasião do julgamento do caso, ainda que entenda não ser o caso de declaração de inconstitucionalidade.

No momento em que os membros do órgão fracionário se reúnem para o julgamento do caso, a arguição de inconstitucionalidade deve ser apresentada, discutida e decidida como preliminar. Os membros do órgão fracionário devem decidir se a norma em questão é inconstitucional, num juízo prévio necessário para o encaminhamento da questão ao plenário ou ao órgão especial.

Esclareça-se que a norma, que pode estar imbrincada com o mérito ou, por exemplo, ter natureza processual, pode ser impugnada em face da Constituição Federal ou de Constituição estadual.

2. Decisão sobre a suspensão do julgamento e envio da questão ao plenário ou ao órgão especial. Se a câmara ou turma não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, resta-lhe encaminhar a questão à decisão do plenário ou do órgão especial. Antes disso, porém, os membros da câmara ou turma devem decidir se a hipótese é realmente de suspensão do julgamento e encaminhamento da questão. Como é óbvio, não basta a arguição da inconstitucionalidade – por uma das partes, pelo Ministério Público ou pelo relator de ofício – para que o órgão fracionário fique obrigado a suspender o julgamento.

O art. 97 da Constituição Federal proíbe os órgãos fracionários apenas de declarar a inconstitucionalidade da norma. Não de analisar uma questão constitucional nem, muito menos, de declarar a norma constitucional. Isso quer dizer que a suspensão do julgamento só é necessária quando o órgão fracionário chega à conclusão de que a norma é incompatível com a Constituição. Nesse caso, ou a norma não pode ser aplicada por inconstitucionalidade, ou resta a declaração parcial de nulidade sem redução de texto ou a interpretação conforme, técnicas de controle de constitucionalidade que apenas podem ser aplicadas pelo plenário ou pelo órgão especial (ver, *infra*, n. 4).

Trata-se, obviamente, de um juízo de inconstitucionalidade que não configura a declaração de inconstitucionalidade proibida pelo art. 97 da Constituição Federal, mas de um juízo específico, próprio ao colegiado que só deve suspender o julgamento e remeter a questão à decisão do plenário ou do órgão especial exatamente por não poder declarar a inconstitucionalidade

3. A Súmula vinculante 10 e o escamoteamento da inconstitucionalidade. A Súmula Vinculante 10, aprovada na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal de 18.06.2008, afirma que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Esta súmula poderia ser vista como mera sobreposição à norma do art. 97 da Constituição Federal, que submete a declaração de inconstitucionalidade à reserva de plenário. Porém, na prática dos tribunais eram frequentes – antes da edição desta súmula – decisões que deixavam de aplicar norma, sem afirmar a sua inconstitucionalidade.

A Súmula Vinculante 10 evita o escamoteamento da declaração de inconstitucionalidade, ou melhor, o afastamento ou a mera não aplicação de lei sem a afirmação da sua inconstitucionalidade. Deseja-se impedir o órgão fracionário de julgar o recurso – sem sobrestá-lo e enviar a questão constitucional à decisão do plenário ou do órgão especial – como se a lei não existisse ou pudesse deixar de ser aplicada de forma silenciosa – sem a argumentação explícita de sua inconstitucionalidade. No AgRg no AgIn 472.897, de relatoria do Min. Celso de Mello, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que equivale à própria declaração de inconstitucionalidade a decisão de Tribunal que, sem proclamá-la, explícita e formalmente, deixa de aplicar, afastando-lhe a incidência, determinado ato estatal subjacente à controvérsia jurídica, para resolvê-la sob alegação de conflito com critérios resultantes do texto constitucional.⁷

Portanto, a Súmula 10, antes de meramente reafirmar a reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade, adverte para a necessidade de o órgão fracionário estar atento à sua falta de poder para deixar de aplicar uma lei.

4. A interpretação conforme e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto enquanto exclusividades do plenário ou do órgão especial. De outro lado, nos casos de interpretação conforme à Constituição e de declaração parcial de nulidade sem redução de texto, a necessidade de observar a cláusula de reserva de plenário não é tão clara. Existe semelhança entre tais técnicas. O Supremo Tribunal Federal chegou a equipará-las. De qualquer forma, a Lei 9.868/1999 (art. 28, parágrafo único) fez referência a ambas, sustentando a sua autonomia.

A interpretação conforme à Constituição não constitui método de interpretação, mas técnica de controle de constitucionalidade. Constitui técnica que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma mediante a afirmação de que esta tem um sentido – ou uma interpretação – conforme à Constituição.

Por outro lado, há casos em que uma norma pode ser utilizada em face de situações diversas: uma em que se apresenta inconstitucional e outras constitucional. Quando se impugna a aplicação da norma em determinada situação, o tribunal, ainda que reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação nesta situação, pode admitir a sua aplicação em outras. Nestes casos há declaração parcial de nulidade sem redução de texto.

No caso de interpretação conforme, reconhece-se a inconstitucionalidade da interpretação suscitada, mas se afirma que a norma pode ser interpretada de forma constitucional. Na declaração de nulidade parcial sem redução de texto não se cogita da interpretação da norma – reconhece-se a inconstitucionalidade da norma na situação alegada, admitindo-se a sua aplicabilidade em outras situações.

Assim, o que distancia tais técnicas de controle de constitucionalidade é a circunstância de que a interpretação conforme exclui a interpretação proposta e impõe outra, conforme à Constituição, enquanto a declaração parcial de nulidade revela a ilegitimidade da aplicação da norma na situação proposta, ressaltando a sua aplicabilidade em outras. Num caso discute-se o âmbito de interpretação e, no outro, o de aplicação.

Ao assim proceder, o tribunal atua de forma fundamentada e clara. Não se equipara ao órgão fracionário que reconhece implicitamente a inconstitucionalidade da lei e deixa de afirmá-la inconstitucional. Mas, exatamente por isso, a competência para tanto só pode ser do plenário ou do órgão especial.

5. Quando o órgão fracionário não deve encaminhar a arguição de inconstitucionalidade à decisão do plenário ou do órgão especial. O órgão fracionário só deve remeter a questão ao plenário ou ao órgão especial quando houver necessidade de controle de constitucionalidade. Assim, se para a solução do recurso não é necessária a declaração de inconstitucionalidade nem a interpretação conforme ou a declaração parcial de nulidade sem redução de texto, descabe o incidente de inconstitucionalidade.

Sublinhe-se que a interpretação conforme e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto, embora não declarem a inconstitucionalidade da lei, constituem técnicas de controle de constitucionalidade. Portanto, os mesmos motivos que excluem a possibilidade de o órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade de lei o impedem de empregar tais técnicas de controle de constitucionalidade. A interpretação conforme e a declaração parcial de nulidade estão reservadas ao plenário ou ao órgão especial.

Art. 949. Se a arguição for:

I – rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II – acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

1. Rejeição ou acolhimento pela câmara ou turma. A decisão do órgão fracionário a respeito da arguição de inconstitucionalidade da parte, Ministério Público ou do próprio relator tem consequências diversas, conforme seja de rejeição ou de acolhimento. No caso de rejeição, o julgamento prosseguirá, definindo-se o recurso ou a demanda. A decisão de rejeição não abre oportunidade para recurso antes de finalizado o julgamento. O acórdão relativo ao julgamento final, no entanto, não só deverá justificar a rejeição da arguição, como poderá ser objeto de

recurso nesta parte específica pelo litigante que entender, por exemplo, que a câmara escamoteou a inconstitucionalidade ou deixou de aplicar a norma que só poderia ser desconsiderada caso houvesse sido declarada inconstitucional.

Na outra hipótese, concluindo o órgão fracionário que a norma não pode ser aplicada por incompatibilidade constitucional, lavra-se acórdão específico para esta decisão, submetendo-se a questão ao plenário ou ao órgão especial. Com a decisão de envio, resta o julgamento suspenso. A decisão que admite o incidente de inconstitucionalidade é irrecorrível. Nessa hipótese, recorrível será apenas o acórdão do julgamento final do órgão fracionário, realizado depois de resolvida a questão de constitucionalidade pelo plenário ou órgão especial.

2. Questão constitucional já decidida pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Essa regra, reafirmando o que já estava contido no art. 481 do Código de 1973 (nos termos da Lei 9.756/1998), deixa clara a eficácia obrigatória dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal.

É preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido a questão, não importando se em ação direta ou em recurso extraordinário. Como é óbvio, não é preciso que a decisão seja de inconstitucionalidade ou tenha aplicado as técnicas da interpretação conforme ou da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Mesmo a decisão de constitucionalidade obriga os tribunais e, portanto, não apenas dispensa o órgão fracionário de enviar a questão ao plenário ou ao órgão especial, mas na verdade o impede de decidir a questão constitucional de modo diverso. O parágrafo único do art. 949 não é uma norma que dispensa o órgão fracionário de encaminhar a questão, mas uma norma que deixa clara o efeito obrigatório dos precedentes constitucionais sobre os tribunais.

O grande problema é que as questões constitucionais julgadas em recurso extraordinário nem sempre são justificadas de modo individualizado. Quando existem várias questões constitucionais num recurso extraordinário, muitas vezes é difícil saber como algumas delas foram pensadas pelo colegiado. Ou melhor, nem sempre é fácil identificar o entendimento dos Ministros a respeito de uma questão constitucional específica. Portanto, como um precedente depende do entendimento da maioria do colegiado sobre a questão constitucional, e não apenas de uma maioria em favor do provimento ou desprovimento do recurso, é preciso analisar o acórdão com atenção para encontrar o pensamento dos Ministros a respeito da questão constitucional. Só quando um entendimento for sustentado pela maioria do plenário haverá precedente capaz de obrigar os tribunais e, portanto, de dispensar o envio da questão ao plenário ou ao órgão especial.

3. Questão constitucional já decidida pelo plenário ou pelo órgão especial. O parágrafo único do art. 949 é expresso no sentido de que os órgãos fracionários não ficam obrigados apenas diante de precedente do Supremo Tribunal Federal, mas também de decisão já tomada pelo plenário ou pelo órgão especial em incidente de inconstitucionalidade. Não é apenas o órgão fracionário que submeteu a questão de constitucionalidade que fica vinculado à decisão. Todas as câmaras ou turmas ficam obrigadas perante a decisão tomada pelo plenário ou pelo órgão especial.

Uma vez decidida a questão em incidente de inconstitucionalidade, as câmaras ou turmas a princípio não têm mais motivo para submeter a arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial. Terão razão para tanto caso a modificação dos fatos e valores sociais conduza à alteração da compreensão da norma à luz da Constituição. E isso obviamente quando o Supremo Tribunal Federal já não tiver decidido a questão, uma vez que, a partir daí, esta resta entregue aos seus cuidados, já que cabe apenas à Corte Suprema revogar os seus precedentes.

A eficácia vinculante da decisão proferida no incidente de inconstitucionalidade é consequência da norma constitucional que afirma que uma lei só pode ser declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu órgão especial (art. 97,

CF). Se apenas o plenário ou o órgão especial pode declarar a inconstitucionalidade, não apenas a decisão que reconhece a inconstitucionalidade, mas também a que admite a constitucionalidade, obstaculizam os órgãos fracionários de voltar a encaminhar a questão para decisão. Afinal, a questão já foi decidida.

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1.º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.

§ 2.º A parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.

§ 3.º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

1. Procedimento no plenário ou órgão especial. Decidindo-se pelo encaminhamento da questão, obviamente será designado novo relator entre os membros do plenário ou órgão especial. Remetida cópia do acórdão da câmara ou turma a todos os desembargadores componentes do colegiado, o presidente do tribunal designará sessão para o julgamento.

As partes litigantes no órgão fracionário têm direito de manifestação na fase de julgamento da questão de constitucionalidade, inclusive de sustentação oral. Não obstante, por se tratar da discussão sobre a constitucionalidade de norma cuja decisão tem eficácia vinculante sobre os órgãos do tribunal (art. 949, parágrafo único, CPC), podem participar a pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado, o Ministério Público, os legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, e, considerada a relevância da matéria, todos os órgãos ou entidades representativos de setores sociais potencialmente atingidos pela decisão a ser tomada (*amici curiae*).

O debate é obviamente restrito à questão da constitucionalidade da norma. Isso não quer dizer, é claro, que o julgamento da questão de constitucionalidade não constitua controle de constitucionalidade influenciado pelas particularidades do caso concreto a ser posteriormente decidido. Ocorre o mesmo que sucede em outros sistemas, como o italiano, em que a Corte Constitucional aprecia a questão de constitucionalidade a partir de arguição feita pelo juiz em cujas mãos está o caso concreto debatido pelas partes. Em sistemas como este, embora existam dois juízos autônomos, um que suscita a questão constitucional e outro que a analisa, o caso concreto certamente exerce influência sobre o julgamento da questão de constitucionalidade. Isso quer dizer que as partes podem trazer particularidades do caso para esclarecer a questão a ser decidida e influenciar os julgadores. O que não podem, nem precisam, é tratar de argumentos que dizem respeito exclusivamente a questões que não podem ser decididas no incidente de inconstitucionalidade.

A decisão proferida pelo plenário ou pelo órgão especial é irrecorrível, salvo por embargos de declaração.⁸ Após a decisão sobre a questão de constitucionalidade, retoma-se o julgamento que restou suspenso no órgão fracionário. O julgamento do caso, como é evidente, não pode fugir da decisão do plenário ou do órgão especial a respeito da constitucionalidade da norma.

2. O julgamento não encerra enquanto houver possibilidade de alcançar maioria absoluta dos votos dos membros do plenário ou do órgão especial. A decisão de inconstitucionalidade somente pode ser tomada pela maioria absoluta dos membros do plenário ou do órgão especial. Significa que não basta o voto da maioria dos magistrados presentes na sessão de julgamento. Entende-se que a questão de constitucionalidade não pode ser entregue às composições eventuais

do plenário ou do órgão especial. De modo que o julgamento não termina enquanto houver a possibilidade de ser alcançada a maioria absoluta mediante os votos dos membros ausentes.

Explique-se melhor: se, por exemplo, existem onze votos pela inconstitucionalidade e nove contrários ao final da sessão em que estão presentes vinte dos vinte e cinco desembargadores que dão composição ao órgão especial, o julgamento ainda não está finalizado e a decisão ainda não foi tomada. É necessário suspender o julgamento à espera dos votos dos ausentes. Assim, se, na próxima sessão, comparecerem os desembargadores que não votaram, bastarão apenas mais dois votos para se chegar a treze – maioria absoluta – e, dessa forma, a uma decisão de inconstitucionalidade. É claro que, se ao final da sessão treze desembargadores tivessem votado pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade, a decisão teria de ter sido proclamada. Exatamente nessa linha, o art. 199, § 3.º, do RISTJ preceitua que, “se não for alcançada a maioria absoluta necessária à declaração de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o quorum; não atingido, desta forma, o quorum, será convocado Ministro não integrante da Corte, observada a ordem de antiguidade (art. 162, § 3.º)”.

3. Declaração de inconstitucionalidade no Superior Tribunal de Justiça. Numa análise apegada à função do Superior Tribunal de Justiça, de tutelar a unidade do direito federal infraconstitucional, seria possível argumentar que esta Corte Suprema não deve controlar a constitucionalidade das leis. Porém, a circunstância de o recurso especial ser reservado ao tratamento de lei federal inconstitucional não quer dizer que o Superior Tribunal de Justiça não possa ter que aferir a constitucionalidade da lei em discussão. O recurso especial obviamente não elimina a possibilidade e a necessidade de o Superior Tribunal de Justiça controlar a constitucionalidade da norma federal questionada.

Quando o tribunal decide com base em fundamento constitucional e, ao mesmo tempo, com lastro em fundamento infraconstitucional que abre ensejo a recurso especial, a admissibilidade do último não dá ao Superior Tribunal de Justiça poder para analisar a questão constitucional. Num caso como este, o acórdão do tribunal de origem desafia recurso especial e recurso extraordinário, de modo que o interessado em discutir a questão constitucional deve, desde logo, interpor recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, por estarem presentes dois fundamentos, um de ordem infraconstitucional e outro de natureza constitucional, a parte vencida deve simultaneamente interpor recurso especial e recurso extraordinário. Se assim não o fizer, interpondo apenas recurso especial, a discussão da questão constitucional restará preclusa e o recurso especial não poderá ser admitido pela circunstância de o acórdão recorrido se apoiar em fundamento bastante para sustentá-lo. É que, diante do fundamento constitucional não impugnado, de nada adianta ter razão no recurso especial. Aplica-se a Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua ser “inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça não pode tratar de questão constitucional decidida por tribunal, já que isto é de incumbência do Supremo Tribunal Federal. Porém, ao deparar-se com questão constitucional até então não tratada, mas prejudicial à solução do recurso especial, deve analisá-la, cabendo à turma, preliminarmente, após acolher arguição de inconstitucionalidade, remeter os autos à definição da Corte Especial – já que igualmente no Superior Tribunal de Justiça, como acontece em outros tribunais, a decisão de inconstitucionalidade depende da maioria absoluta dos membros do órgão especial.⁹

Lembre-se que o sistema instituído na Constituição austríaca de 1920 é devido ao gênio de Hans Kelsen. A Constituição austríaca criou uma Corte Constitucional (o Verfassungsgerichtshof), habilitada a realizar o controle da constitucionalidade das leis. Embora a Corte Constitucional pudesse apreciar a constitucionalidade de lei relevante ao julgamento do mérito de processo instaurado diante dela, não era possível, no primitivo sistema austríaco, o questionamento da constitucionalidade de lei que constituía pressuposto à resolução de litígio em outros juízos ou tribunais. Porém, logo surgiu o sentimento de que a Corte Constitucional atuava num âmbito muito limitado, podendo deixar sem proteção direitos individuais que poderiam ser violados por normas inconstitucionais, uma vez que os governos federal e estaduais tinham apenas a faculdade de pedir a declaração de inconstitucionalidade. A reforma constitucional austríaca de 1929 conferiu à Corte Suprema e à Corte Administrativa o poder de requerer à Corte Constitucional o exame da constitucionalidade de lei cuja validade fosse prejudicial à solução de litígio levado ao seu julgamento. Objetivou-se, com isto, oferecer a possibilidade de controle de constitucionalidade de leis que, por alguma razão, não eram ou poderiam não ser questionadas pelos governos federal e estaduais. V. Hans Kelsen, *Jurisdição constitucional*, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 223-236; Tom Ginsburg, *Judicial review in new democracies: constitutional courts in Asian cases*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 9.

2

Georg Vanberg, *The politics of constitutional review in Germany*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 234-242; Dieter Grimm, *Human rights and judicial review in Germany*, In: *Human rights and judicial review*, London: Springer, 1994, p. 267-296; Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale*, Padova: Cedam, 2010, p. 126 e ss.

3

G. Stone, L. Seidman, C. Sunstein, M. Tushnet e P. Karlan *Constitutional law*, 5. ed., New York: Aspen, 2005, p. 29 e ss.

4

Hermes Zaneti Júnior, *A Constitucionalização do Processo*, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2014.

5

Lembre-se do art. 163 da Constituição espanhola: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”.

6

“O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é indubitavelmente um sistema difuso, e apenas difuso (...). Poder-se-ia conceber um sistema misto, isto é, simultaneamente difuso e concentrado, se, por exemplo, determinada categoria de atos legislativos ficasse submetida apenas ao controle de constitucionalidade exercido por um único tribunal, ao passo que os demais atos legislativos estariam sujeitos ao controle difuso. Não temos notícia, contudo, da existência, presente ou passada, de um sistema

de controle misto quanto ao aspecto sub examine” (Elival da Silva Ramos, Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 70).

7

AgRg no AgIn 472.897, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.10.2007. No AgR no RE 613.748, relator o Min. Ricardo Lewandowski, decidiu-se que o afastamento, pelo órgão fracionário do tribunal, da incidência de norma prevista em lei federal aplicável à hipótese concreta, viola a cláusula de reserva de plenário. (RE 613.748-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.10.2011).

8

De acordo com a Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal, “a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”.

9

Seria diferente se houvesse um sistema de envio da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal, deixando-se o Superior Tribunal de Justiça unicamente com a função de atribuir sentido ao direito federal infraconstitucional. No mais, diga-se que a opinião de que o Superior Tribunal de Justiça pode fazer controle de constitucionalidade é de Luiz Guilherme Marinoni, na medida em que Daniel Mitidiero reserva o controle de constitucionalidade nas cortes supremas tão somente ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO V. DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Capítulo V. Do Conflito de Competência

Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.

Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar.

1. Conflito de Competência. As hipóteses em que se configura o conflito de competência estão arroladas no art. 66, CPC. Com ligeiras explicitações, trata-se de dispositivo praticamente idêntico ao art. 115 do Código de 1973.

Sendo a competência um dos núcleos do conceito de juiz natural, é evidente que o seu respeito constitui uma questão prioritária na cognição do juiz. A condução do processo pelo juiz natural constitui uma das condições básicas para a justa estruturação do processo. Por essa razão, entende-se que uma das primeiras questões que o próprio juiz se coloca no que tange ao objeto do processo está justamente na sua própria competência para julgar o pedido – daí o surgimento da eloquente expressão *Kompetenz-Kompetenz*, cunhada pela doutrina alemã¹ e bem conhecida na nossa doutrina,² cujo significado está em reconhecer o juiz como o primeiro juiz da sua própria competência.

O conflito de competência pode ser positivo (art. 66, I, CPC) ou negativo (art. 66, II, CPC). Havendo controvérsia a respeito da reunião ou separação de processos, porém, não há propriamente conflito: a controvérsia é uma consequência de um conflito positivo ou negativo de competência a partir da aplicação das regras a respeito da modificação de competência pela conexão.³

2. Legitimidade. As partes, o Ministério Público e o juiz podem suscitar o conflito de competência. Admite-se que o assistente também o faça. Enquanto custos legis, o Ministério Público pode suscitar o conflito em face de incompetência absoluta ou relativa do órgão jurisdicional (art. 65, parágrafo único, CPC). Suscitando, terá a qualidade de parte. O órgão jurisdicional pode suscitar o conflito quer em função de incompetência relativa (desde que tenha havido a sua alegação por qualquer das partes, arts. 64 e 65, CPC), quer em função de incompetência absoluta.

3. Ministério Público. O Ministério Público tem de ser intimado para oitiva em todos os conflitos de competência em que subjacentes causas em que prevista a sua participação obrigatória (art. 178, CPC). Vale dizer: o simples fato de o conflito ter sido suscitado não determina por si só a sua intimação. Suscitado em primeiro grau pelo Ministério Público, todavia, basta a oitiva do órgão ministerial em segundo grau. Do contrário, suscitado por qualquer outro legitimado, o Ministério Público deve ser ouvido em ambos os graus de jurisdição.

Art. 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa.

Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu

suscite a incompetência.

1. Ilegitimidade. Não pode suscitar o conflito a parte que no processo já arguiu incompetência relativa. A parte que alegou, antes da instauração do conflito, a incompetência relativa, está proibida de novamente suscitar a questão mediante o conflito basicamente por duas razões: acaso já rejeitada a alegação, a parte estará simplesmente a reiterando; acaso já acolhida, estará incidindo em comportamento contraditório, o que é obviamente vedado pelo princípio da boa-fé (*nemo potest venire contra factum proprium*, art. 5.º, CPC). Já se decidiu, contudo, que em hipóteses excepcionais é possível mitigar o rigor da norma em comento, desde que não reste configurado com a suscitação do conflito manifesto propósito protelatório da parte.⁴

Nada obsta que seja suscitado o conflito pela parte contrária àquela que arguiu a incompetência relativa (art. 952, parágrafo único, CPC). A parte que alegou anteriormente incompetência absoluta do órgão jurisdicional não está impedida de suscitar o conflito.⁵

2. Incompetência. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte, que o não suscitou, suscite a incompetência. Já se decidiu que o conflito de competência pode ser suscitado antes do prazo para arguição da incompetência, isto é, inclusive antes do prazo para a contestação (art. 64, CPC).⁶

Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal:

I – pelo juiz, por ofício;

II – pela parte e pelo Ministério Público, por petição.

Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito.

1. Competência. A competência para decisão do conflito de competência está prevista na Constituição (arts. 102, I, o, 105, I, d, 108, I, e, 114, V), nas Constituições Estaduais (art. 125, § 1.º, CF) e em Lei Complementar (art. 121, CF). Já se decidiu que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a Tribunais Regionais do Trabalho diversos” (Súmula 236, STJ) e que cumpre “ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado, na respectiva Região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de jurisdição federal” (Súmula 03, STJ).

2. Forma de Instauração. O conflito deve ser instaurado pelo juiz por ofício dirigido ao presidente do tribunal que tem competência para decidi-lo. Se provocado pela parte ou pelo Ministério Público, deve ser instaurado por requerimento igualmente endereçado. Suscitado o conflito por qualquer das partes, tem de ser acostada aos autos a procuração outorgada ao advogado da parte suscitante.⁷ Não acostada, tem o órgão jurisdicional o dever de intimá-la para fazê-lo (art. 76, CPC), sendo-lhe vedado inadmitir desde logo o conflito.

3. Prova. As manifestações dos juízos conflitantes nos autos que evidenciam o conflito constituem documentos necessários à sua prova.⁸ Não sendo o conflito suscitado por qualquer das partes, as procurações outorgadas aos seus advogados não constituem documentos necessários ao julgamento do conflito.⁹

Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado.

Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações.

1. Oitiva. Registrado e distribuído o conflito, o relator mandará ouvir os juízes em conflito, ou apenas o suscitado, se um deles for o suscitante. As informações solicitadas pelo relator têm de vir aos autos no prazo por esse assinalado. Trata-se de prazo próprio, cuja inobservância gera preclusão temporal.

Estando o conflito desde logo bem instruído, pode-se dispensar a oitiva dos juízos conflitantes.¹⁰ Decorrido o prazo ou dispensada a oitiva, em sendo o caso, tem de se dar vista ao Ministério Público (arts. 951, parágrafo único, e 956, CPC).

Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em:

I – súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

II – tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

1. Suspensão. Se o conflito é negativo, então naturalmente o feito se encontra sobrestado, porquanto nenhum dos dois juízos se entende competente para processá-lo. Sendo positivo, pode o relator, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a suspensão do processo. Os atos processuais eventualmente praticados num ou noutro juízo são eficazes até que se decida o conflito. Se concedido determinado provimento liminar, esse será eficaz até que deslindado o conflito ou até que reapreciada a matéria pelo juízo designado pelo relator para decidir a respeito das medidas urgentes.

2. Urgência. Estando o processo paralisado pela existência de conflito de competência, cumpre ao relator designar um dos juízos para que decida a respeito de eventuais medidas urgentes. A competência para decisão no que concerne à tutela de urgência perdura até a solução do conflito.

A competência para a tutela de urgência abarca tanto a tutela satisfativa – dita antecipada – quanto a tutela cautelar de urgência (arts. 294 e 300, CPC). Em ambos os casos pode o juiz designado prestar jurisdição enquanto pendente o conflito. Note-se que aí não há propriamente a adoção da velha regra das Ordenações “quando est periculum in mora incompetentia non attenditur”.¹¹ O que há, rigorosamente, é a adoção da regra contrária: é preciso que a competência tenha sido designada para a prestação da tutela de urgência.

3. Decisão monocrática. Havendo precedente ou jurisprudência vinculante sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de plano o conflito, monocraticamente, racionalizando-se por aí a atividade judiciária. É preciso observar, porém, que o art. 955, parágrafo único, CPC, deve ser lido à luz dos arts. 926, 927 e 932, III, IV e V, CPC. Vale dizer: na verdade, não são apenas as razões constantes das decisões mencionadas nesses dispositivos que se mostram capazes de determinar o julgamento monocrático. Todo e qualquer precedente – aí entendido o termo em sentido próprio, tal como exposto nos comentários ao art. 927, CPC – pode a esse dar lugar. Da decisão monocrática cabe agravo interno para o órgão colegiado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, CPC).

Art. 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento.

1. Apresentação. Decorrido o prazo para apresentação de informações pelos juízos conflitantes, ou dispensadas as informações, tem o Ministério Público de ser ouvido no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo para manifestação do órgão ministerial, o relator apresentará o conflito em sessão de julgamento.

Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

1. Decisão. A decisão do conflito de competência tem de declarar o juízo competente e determinar a remessa dos autos ao mesmo para que tenha curso o procedimento. Nada obsta que o tribunal decida pela competência de um terceiro juízo, diverso dos juízos conflitantes – o ideal aí é que, sempre que possível, desde logo viabilize o contraditório deste novo juízo antes da decisão do conflito (art. 10, CPC). Uma vez declarada a competência, tem o órgão jurisdicional de submeter-se à decisão da instância que decidiu o conflito, sendo-lhe vedado suscitar novamente o incidente ou de qualquer modo resistir ao pronunciamento do órgão competente.¹²

2. Validade. Na mesma oportunidade em que decidir qual o juízo competente, tem o tribunal de se pronunciar sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Ainda que prolatado por juiz incompetente, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição (art. 240, § 1.º, CPC) e obsta a decadência (art. 240, § 4.º, CPC). Salvo decisão em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (art. 64, § 4.º, CPC). O ideal é que se aproveite o máximo de atos processuais possível (arts. 5.º, LXXVIII, CRFB, e 4.º, CPC).

3. Recorribilidade. Da decisão que julga o conflito de competência cabe o recurso de embargos declaratórios e, concorrendo os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial e o recurso extraordinário.

Art. 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal.

1. Conflito interno. Havendo conflito entre turmas, seções, câmaras, Conselho Superior da Magistratura, juízes de segundo grau e desembargadores do mesmo tribunal, há conflito interno de competência, devendo ser observado o regimento interno de cada tribunal para solução do conflito. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já se decidiu que a definição de competência de suas seções opera levando em conta a natureza da relação jurídica litigiosa, pouco importando o instrumento processual utilizado ou a fundamentação da decisão recorrida ou que consta do recurso.¹³

2. Reprodução obrigatória. O conflito interno de competência tem de observar o que dispõe o regimento interno do tribunal em que se originou. Seu conteúdo, contudo, não é livre, havendo normas do Código de Processo Civil de reprodução obrigatória no regimento, como aquelas referentes à legitimação e à intervenção obrigatória do Ministério Público.

Art. 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa.

1. Conflito de atribuições. O conflito de atribuições a que alude o art. 959, CPC, supõe divergência entre autoridade judiciária, no exercício de função administrativa, e autoridade administrativa a respeito da competência para prática de determinado ato administrativo.¹⁴ Não existe, no direito brasileiro, a possibilidade de conflito de atribuições entre autoridade administrativa e autoridade judiciária no exercício de função jurisdicional.

2. Competência. Ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar, originariamente, “os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União” (art. 105, I, g, CRFB). Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciais estaduais ou entre autoridades judiciais e autoridades administrativas municipais devem ser resolvidos na forma do regimento interno dos tribunais estaduais (art. 125, CRFB).

1

Rosenberg, Schwab e Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. ed., München: 2010, p. 55.

2

Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 445, vol. I.

3

Antônio Dall'agnol Júnior, Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 71, vol. II.

4

STJ, 2ª Seção, CC n. 45.891/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 23.11.2005, DJ 05.12.2005, p. 214.

5

STJ, 1ª Seção, CC n. 50.560/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 23.08.2006, DJ 11.09.2006, p. 215.

6

STJ, 2ª Seção, AgRg no CC n. 36.525/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 23.10.2002, DJ 17.02.2003, p. 216.

7

STJ, 2ª Seção, EDcl no AgRg no CC 33.346/GO, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 24.04.2002, DJ 26.08.2002, p. 156.

8

STJ, 1ª Seção, CC 44.107/RN, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 08.03.2006, DJ 17.04.2006, p. 162.

9

STJ, 2ª Seção, EDcl no AgRg no CC 40.451/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 12.05.2004, DJ 18.10.2004, p. 183.

10

STJ, 1ª Seção, CC 41.444/AM, rel. Min. Luiz Fux, j. 11.02.2004, DJ 16.02.2004, p. 200.

11

Galeno Lacerda, Comentários ao Código de Processo Civil, 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 199, vol.

12

STJ, 1ª Seção, CC 34.777/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.06.2002, DJ 09.09.2002, p. 156.

13

STJ, Corte Especial, CC 48.562/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.03.2006, DJ 27.03.2006, p. 134.

14

STJ, 2ª Seção, CAT n. 30/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 08.09.1993, DJ 27.09.1993, p. 19.771.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO VI. DA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA E DA CONCESSÃO DO EXEQUATUR À CARTA ROGATÓRIA

Capítulo VI. Da Homologação de Decisão Estrangeira e da Concessão do Exequatur à Carta Rogatória

Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado.

§ 1.º A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória.

§ 2.º A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 3.º A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste Capítulo.

1. Homologação. O processo de homologação de sentença estrangeira visa a aferir a possibilidade de decisões estrangeiras produzirem efeitos dentro da ordem jurídica nacional.¹ O órgão jurisdicional competente para examinar o pedido de homologação de sentença estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, i, CRFB). A homologação de sentença estrangeira obedecerá ao disposto nos arts. 960 a 965, CPC, e nos arts. 216-A a 216-X, do Regimento Interno do STJ (redação dada pela Emenda Regimental 18, de 2014).

Compete ao presidente homologar a decisão estrangeira e conceder o exequatur à carta rogatória (arts. 216-A e 216-O, Regimento Interno do STJ). Existindo, porém, contestação, o pedido de homologação de decisão estrangeira deverá (art. 216-K, Regimento Interno do STJ) e o pedido de concessão de exequatur poderá ser remetido para julgamento pela Corte Especial (art. 216-T, Regimento Interno do STJ).²

2. Direito à homologação. Homologar significa outorgar autoridade, possibilitando a emanção de eficácia. A homologação nada acresce de substancial ao ato que constitui o seu objeto – apenas formalmente o ato se torna outro. Observe-se que o direito à homologação constitui direito à modificação no status de determinado ato jurídico e, nesse sentido, o direito à homologação não se submete à prescrição (apenas direitos a prestações se submetem à prescrição). Trata-se de direito potestativo. Bem por isso, o direito à homologação só é suscetível de decadência, acaso exista previsão de prazo decadencial para a espécie. Como inexiste previsão dessa ordem no direito brasileiro, o direito à homologação de sentença estrangeira pode ser exercido a qualquer tempo.

A decisão interlocutória estrangeira poderá ser cumprida no Brasil mediante carta rogatória a que se concedeu o devido exequatur (arts. 960, § 2.º, e 961, CPC). O mesmo vale para a decisão arbitral estrangeira, a qual pode ser homologada obedecendo-se às normas internacionais e nacionais que regem a espécie (arts. 34 a 40, Lei 9.307, de 1996), aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil (art. 960, § 3.º, CPC).³

Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença

estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado.

§ 1.º É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional.

§ 2.º A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente.

§ 3.º A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira.

§ 4.º Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira.

§ 5.º A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.

§ 6.º Na hipótese do § 5.º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência.

1. Eficácia. A principal questão que interessa para que possa ser homologada no Brasil a decisão estrangeira é que essa tenha no país de origem a mesma força que se reconhece à sentença nacional transitada em julgado (arts. 961, § 1.º, CPC, e 216-A, § 1.º, Regimento Interno do STJ). Nesse sentido, interessa que tenha sido prolatada por órgão jurisdicional ou órgão administrativo com função judicante definitiva, dela não cabendo mais recurso (Súmula 420, STF: “não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado”; art. 216-D, III, Regimento Interno do STJ).

Salvo contadas exceções, devidamente articuladas em ato normativo próprio (por exemplo, Protocolo de Medidas Cautelares do Mercosul – Decreto 2.626, de 1998), nenhuma decisão estrangeira pode ser eficaz no país sem prévia homologação pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 216-B, Regimento Interno do STJ). As decisões estrangeiras que versem sobre o estado de pessoa também devem ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça para adquirirem eficácia no território nacional (revogado o art. 15, parágrafo único, LINDB), salvo se há dispensa no próprio ordenamento nacional a respeito (como, por exemplo, o divórcio consensual, art. 961, § 5.º, CPC).

2. Parcialmente. A decisão estrangeira – transitada ou não em julgado – pode ser homologada apenas parcialmente. A parcialidade da homologação pode tanto derivar da vontade da parte ou da impossibilidade de homologação total. Pouco importa o motivo. O que interessa é que o legislador permite a homologação parcial (arts. 961, § 2.º, CPC, e 216-A, § 2.º, Regimento Interno do STJ).

3. Urgência e execução provisória. Assim como ocorre no procedimento comum, é necessário que se distribua de maneira adequada o ônus do tempo no processo também a propósito das decisões estrangeiras. É por essa razão que o legislador permite – e não poderia deixar de permitir, dado o direito fundamental à tutela adequada, efetiva e tempestiva dos direitos (art. 5.º, XXXV e LXXVIII, CF) – a realização de atos urgentes e a prática de atos de execução enquanto pendente a discussão do direito à homologação (arts. 961, § 3.º, CPC, e 216-G, Regimento Interno do STJ). Tal como no procedimento comum, incidem, no que couber, as disposições nacionais pertinentes à tutela cautelar e à antecipação da tutela fundada na urgência e à execução provisória.

4. Execução fiscal. Para que se atenda ao crédito fiscal estrangeiro basta a promessa de reciprocidade. Trata-se de regra básica de direito internacional.

5. Divórcio consensual. Como o direito brasileiro permite o divórcio consensual independentemente de decisão judicial, também o divórcio consensual estrangeiro não jurisdicional tem eficácia no Brasil – daí a razão pela qual se dispensa a sua homologação. Admite-se o seu controle, porém, perante o Poder Judiciário brasileiro incidentalmente ou em ação própria

(art. 961, § 6.º, CPC).

Art. 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência.

§ 1.º A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória.

§ 2.º A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior.

§ 3.º O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira.

§ 4.º Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.

1. Medida de urgência. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. A execução no Brasil far-se-á por carta rogatória. Se concedida sem prévio contraditório no juízo estrangeiro, a possibilidade de cumprimento da decisão estrangeira perante o direito brasileiro depende de o direito estrangeiro viabilizar, em momento posterior, o contraditório para aprofundamento da cognição.

2. Probabilidade e urgência. Saber se a parte tem ou não direito à medida de urgência constitui assunto afeito apenas à autoridade judiciária estrangeira. Em outras palavras, não pode o juiz brasileiro reapreciar a existência de direito provável e da urgência em prover. O juízo concessivo do exequatur é um juízo que não pode sindicat o mérito da tutela de urgência.

3. Validade expressamente reconhecida. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 962, § 4.º, CPC). Vale dizer: o juízo brasileiro deve conhecer em primeiro lugar do fato de haver ou não dispensa de homologação para a sentença estrangeira perante a nossa ordem jurídica e em segundo lugar se a decisão provisória não ofende a ordem pública – especialmente, se o contraditório é devidamente assegurado perante a autoridade estrangeira da qual emanou a ordem.

4. Tutela de evidência. Como a ordem jurídica brasileira reconhece inequivocamente decisões provisórias fundadas na evidência do direito postulado em juízo com eficácia imediata (art. 311, CPC), é possível igualmente homologar decisão estrangeira provisória com eficácia imediata que, em cognição sumária, entende que o direito é evidente (pense-se, por exemplo, no caso clássico do référé-provision français). Trata-se de solução inspirada na necessidade de reciprocidade.

Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão:

I – ser proferida por autoridade competente;

II – ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia;

III – ser eficaz no país em que foi proferida;

IV – não ofender a coisa julgada brasileira;

V – estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado;

VI – não conter manifesta ofensa à ordem pública.

Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os

pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962, § 2.º.

1. Requisitos Indispensáveis à Homologação. São requisitos indispensáveis para homologação de sentença estrangeira constam dos arts. 963, CPC, 216-C e 216-D, Regimento Interno do STJ. A sentença estrangeira tem de ter sido proferida por autoridade competente, as partes têm de ter sido regularmente citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, a sentença estrangeira tem de ter transitado em julgado e estar autenticada pelo cônsul brasileiro, acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil.

Não será homologada sentença estrangeira que ofenda a ordem pública, aí obviamente incluída a ofensa à soberania e à dignidade da pessoa humana (arts. 963, VI, CPC, e 216-F, Regimento Interno do STJ).⁴ Daí que a defesa no processo de homologação encontra-se limitada ao não preenchimento dos requisitos indispensáveis à homologação (arts. 216-C e 216-D, Regimento Interno do STJ) e à existência de ofensa à soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou à ordem pública (art. 216-F, Regimento Interno do STJ).

Como a defesa é limitada, também a cognição o é – assim, ao Superior Tribunal de Justiça é vedado reexaminar o mérito da decisão homologanda – “o ato homologatório da sentença estrangeira limita-se à análise dos seus requisitos formais”.⁵ Atendidos os requisitos dos arts. 963, CPC, e 216-B, 216-C e 216-F, a contrario sensu, Regimento Interno do STJ, a homologação da decisão estrangeira impõe-se.⁶

2. Requisitos Indispensáveis ao Exequatur. Além dos requisitos constantes nos arts. 963, CPC, e 216-P, Regimento Interno do STJ (respeito à soberania nacional, à dignidade da pessoa humana e à ordem pública), a concessão de exequatur depende de o contraditório ser em qualquer caso garantido perante o juízo estrangeiro (art. 963, parágrafo único, CPC). Não é necessário que o contraditório seja prévio: interessa apenas que a parte tenha a oportunidade de discutir a questão, querendo, perante a jurisdição estrangeira. Vale dizer: tanto a possibilidade de contraditório diferido como de contraditório eventual atendem ao art. 962, § 2.º, CPC.

3. Procedimento. Os procedimentos dos processos de homologação de sentença estrangeira e de concessão do exequatur consta dos arts. 216-C, 216-E e 216-G a 216-N (homologação) e arts. 216-Q a 216-X (exequatur), Regimento Interno do STJ.

A homologação de sentença estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial conter as indicações constantes da lei processual (art. 319, CPC), e ser instruída com a certidão ou cópia autêntica do texto integral da sentença estrangeira e com outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos e autenticados (art. 216-C, Regimento Interno do STJ). Não preenchendo os requisitos, tem o órgão jurisdicional o dever de viabilizar a emenda (art. 216-E, Regimento Interno do STJ). A parte interessada será citada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido de homologação de sentença estrangeira (art. 216-H, Regimento Interno do STJ), sendo que a defesa só poderá versar sobre a “inteligência da decisão alienígena e a observância dos requisitos indicados nos arts. 216-C, 216-D e 216-F” (art. 216-H, parágrafo único, Regimento Interno do STJ). Havendo contestação à homologação de sentença estrangeira, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo, admitindo-se réplica e tréplica (arts. 216-J e 216-K, Regimento Interno do STJ). Revel ou incapaz o requerido, dar-se-lhe-á curador especial que será pessoalmente notificado (art. 216-I, Regimento Interno do STJ). O Ministério Público terá vista dos autos nas homologações de sentenças estrangeiras, pelo prazo de 10 (dez) dias, podendo impugná-las (art. 216-L, Regimento Interno do STJ). Das decisões do Presidente na homologação de sentença estrangeira cabe agravo (art. 216-M, Regimento Interno do STJ). Cumpre ao juízo federal competente, em sendo o caso, executá-la (art. 216-N, Regimento Interno do STJ).

A concessão do exequatur será requerida pela parte interessada ao presidente do Superior Tribunal de Justiça. Acaso seja formulado, a título de exequatur, pedido de cooperação jurídica internacional insuscetível de juízo de delibação do STJ, esse será devolvido ao Ministério da Justiça para as providências necessárias para o seu cumprimento como auxílio direto (arts. 28, CPC, e 216-O, Regimento Interno do STJ). A parte contrária será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,

impugnar o pedido (art. 216-Q, Regimento Interno do STJ). Nada obsta, porém, que o exequatur seja concedido inaudita altera parte, desde que o contraditório possa resultar em ineficiência da medida (art. 216-Q, § 1.º, Regimento Interno do STJ). A defesa só poderá versar sobre a “autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e a observância dos requisitos previstos neste Regimento” (art. 216-Q, § 2.º, Regimento Interno do STJ). Revel ou incapaz a parte requerida, dar-se-lhe-á curador especial (art. 216-R, Regimento Interno do STJ). Assim como ocorre no processo de homologação de decisão estrangeira, o Ministério Público Federal terá vista dos autos nas cartas rogatórias pelo prazo de 10 (dez) dias, podendo impugnar o pedido (art. 216-S, Regimento Interno do STJ). Havendo impugnação ao pedido, o presidente poderá determinar a sua distribuição à Corte Especial (art. 216-T, Regimento Interno do STJ). Das decisões do presidente ou do relator na concessão de exequatur à carta rogatória caberá agravo (art. 216-U, Regimento Interno do STJ). Devidamente internalizada, a carta rogatória será remetida para o juízo federal competente para o cumprimento (art. 216-V, Regimento Interno do STJ). No juízo federal será admitida defesa mediante embargos (art. 216-V, §§ 1.º e 2.º, Regimento Interno do STJ). Da decisão caberá agravo (art. 216-W, Regimento Interno do STJ). Cumprida a carta ou verificada a impossibilidade de seu cumprimento, essa será devolvida ao presidente do STJ, que a remeterá mediante o Ministério da Justiça ou o Ministério das Relações Exteriores à autoridade estrangeira de origem (art. 216-X, Regimento Interno do STJ).

Art. 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira.

Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória.

1. Jurisdição nacional e jurisdição estrangeira. As decisões estrangeiras passíveis de homologação são aquelas em que há competência concorrente entre a jurisdição nacional e a jurisdição estrangeira (arts. 21 e 22, CPC). Nesse caso, a tramitação paralela de duas ações idênticas não impõe a extinção de nenhum dos processos por litispendência (art. 24, CPC).

Se a competência é exclusiva da justiça brasileira (art. 23, CPC), o pedido de homologação de sentença estrangeira está fadado ao insucesso. O trânsito em julgado da decisão estrangeira ou mesmo o seu pedido de homologação não tem o condão de determinar a extinção do processo brasileiro pela ocorrência da coisa julgada. Apenas a homologação da sentença estrangeira impõe a extinção do processo brasileiro em face da coisa julgada estrangeira (art. 485, V, CPC). Se, entre o trânsito em julgado estrangeiro e a efetiva homologação no Brasil sobrevier o trânsito em julgado nacional, a decisão que deve ser atendida é a decisão brasileira, impondo-se a extinção do processo de homologação de sentença estrangeira por conta da coisa julgada brasileira (art. 485, V, CPC).

Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional.

Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso.

1. Sentença estrangeira dependente de cumprimento. A sentença estrangeira para prestar tutela ao direito pode ou não depender de cumprimento. Sendo declaratória ou constitutiva, a simples homologação é suficiente para outorgar tutela ao direito do demandante (a sentença declaratória e a sentença constitutiva são sentenças autossuficientes). Do contrário, tendo natureza condenatória, mandamental ou executiva não basta a mera homologação – a tutela do direito só será prestada ao demandante depois de cumprida a sentença (art. 513, CPC). A sentença, nesse caso, é não autossuficiente. Sendo o caso de sentença não autossuficiente, o cumprimento da sentença far-se-á perante a Justiça Federal (art. 109, X, CF). Se a sentença impõe um fazer ou não fazer, o cumprimento dar-se-á de acordo com o arts. 139, IV, 536 e 537, CPC; se reconhece direito à coisa ou direito à prestação de declaração de vontade, em conformidade com os arts. 139, IV, 501, 536 a 538, CPC; se condena ao pagamento de quantia certa, em consonância com o arts. 139, IV, 536, 537 e 523, CPC.

2. Procedimento. O cumprimento da sentença não autossuficiente far-se-á por cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur (arts. 965, parágrafo único, CPC, 216-N e 216-V, Regimento Interno do STJ). O procedimento que deve ser observado no juízo federal de primeiro grau para cumprimento é aquele constante do Código de Processo Civil para cumprimento da sentença nacional da mesma natureza (art. 965, CPC).

NOTAS DE RODAPÉ

1

Para uma resenha histórica e de direito comparado, consulte-se José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 50-62, vol. V.

2

Marcela Melo Perez, in Cabral e Cramer (coords.), Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.391.

3

Amplamente, André Abbud, Homologação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008.

4

Sobre o conceito de ordem pública no processo civil, com ampla indicação bibliográfica, Ricardo Aprigliano, Ordem Pública e Processo. São Paulo: Atlas, 2011.

5

STJ, Corte Especial, EDcl na SEC 507/EX, rel. Min. Gilson Dipp, j. 06.12.2006, DJ 05.02.2007, p. 173.

6

STJ, Corte Especial, SEC 573/EX, rel. Min. José Delgado, j. 01.08.2006, DJ 04.09.2006, p. 198.

Comentários ao CPC - v. XV - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO VII. DA AÇÃO RESCISÓRIA

Capítulo VII. Da Ação Rescisória

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;

V – violar manifestamente norma jurídica;

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1.º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2.º Nas hipóteses previstas nos incs. do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I – nova propositura da demanda; ou

II – admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3.º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4.º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5.º Cabe ação rescisória, com fundamento no inc. V do *caput* deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6.º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5.º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por

hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

1. Ação rescisória. Ação rescisória é uma ação que visa a desconstituir a coisa julgada.¹ Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica – substrato indelével do Estado Constitucional – a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).

A ação rescisória serve tanto para promover a rescisão da coisa julgada (*iudicium rescindens*) como para viabilizar, em sendo o caso, novo julgamento da causa (*iudicium rescissorium*) (art. 968, I, CPC). A ação rescisória é um instrumento para a tutela do direito ao processo justo e à decisão justa. Não constitui instrumento para tutela da ordem jurídica, mesmo quando fundada em ofensa à norma jurídica. Em outras palavras, a ação rescisória pertence ao campo da tutela dos direitos na sua dimensão particular – e não ao âmbito da tutela dos direitos na sua dimensão geral.

2. Ação rescisória, ação anulatória e querela nullitatis insanabilis. Ação rescisória visa a desconstituir decisão definitiva de mérito transitada em julgado ou a decisão que, nada obstante não tenha examinado o mérito, impede a sua discussão ou a sua rediscussão em outro processo (art. 966, § 2.º, CPC). Visa a desconstituir um ato judicial.

Isso quer dizer que não se confunde de modo nenhum com a ação anulatória de ato das partes praticado no processo, prevista no art. 966, § 4.º, CPC: a ação anulatória de ato processual tem por finalidade desconstituir atos processuais das partes. Não se confunde, ainda, com a ação de querela nullitatis insanabilis, em que se objetiva desconstituir determinado processo por ausência de citação ou por ausência de citação válida de um litisconsorte necessário,² porquanto essa última não está sujeita a qualquer espécie de prazo fatal para exercício e deve ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição.

3. Decisões rescindíveis. O caput do art. 966 afirma ser rescindível a “decisão de mérito”, eliminando a dúvida que existia perante o CPC/1973, cujo art. 485 falava apenas em “sentença de mérito”. Assim, não há mais dúvida de que a decisão interlocutória que trata do mérito é rescindível – ao lado da sentença, da decisão monocrática do relator e do acórdão. Há decisão interlocutória de mérito, por exemplo, quando é resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou julgado o pedido de exibição de documentos (art. 1.015, IV e VI, CPC). Aliás, o art. 1.015, II, afirma textualmente o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que “versar” sobre o “mérito do processo”. Caso de especial relevância é aquele em que o juiz decide parte do mérito quando um ou mais dos pedidos, ou parcela deles, mostra-se incontroverso ou está em condições de julgamento imediato no curso do processo, que deve caminhar adiante para a elucidação da outra parcela do mérito (art. 356, CPC). Trata-se de hipóteses de “cisão do julgamento do mérito”, há aproximadamente duas décadas sugeridas pela doutrina preocupada com a racionalização do processo e sua adequação ao direito fundamental à duração razoável.³

Cabe advertir que, no caso de julgamento de parcela do mérito no curso do processo, o prazo para a propositura da ação rescisória inicia a contar do trânsito em julgado da respectiva decisão. De modo que a ação rescisória poderá ser proposta no curso do processo que prossegue para a elucidação e julgamento da outra parcela do mérito. Não fosse assim, a parte estaria submetida à execução definitiva da decisão que resolveu parcela do mérito, e não poderia impugná-la mediante ação rescisória. O prazo que toma em consideração a “última decisão proferida no processo” (art. 975, CPC) importa apenas para não haver dúvida de que qualquer decisão rescindível só transita em julgado após esauridos todos os recursos que lhe dizem respeito. Assim, por exemplo, se uma decisão que julga um dos pedidos cumulados é objeto de recurso especial admitido, não há que se pensar que o prazo da rescisória possa ter se esgotado antes da última palavra do Superior Tribunal de Justiça, ainda que este venha a declarar que o recurso é intempestivo. Elimina-se, em outras palavras, qualquer pretensão de se fazer valer a tese de que o trânsito em julgado pode ocorrer apesar da interposição do recurso.

Ademais, decisões que não versam sobre o mérito também passam a ser rescindíveis. De acordo com o art. 966, § 2.º, “nas hipóteses previstas nos incs. do caput, será rescindível a decisão

transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente”. A compreensão do inc. I do § 2.º do art. 966 requer a consideração do art. 486, § 1.º, que reza que “no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incs. I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”.

Quando o processo é julgado extinto sem resolução do mérito com base em, por exemplo, litispendência, falta de pressuposto processual ou ausência de interesse processual ou de legitimidade, a propositura de nova (rectius: da mesma) ação depende da correção do vício que levou ao reconhecimento da litispendência, da falta de pressuposto processual ou da ausência de interesse ou legitimidade.

O problema é que a decisão, ao reconhecer tais “vícios”, pode estar marcada pelas causas que autorizam a sua rescindibilidade. Assim, por exemplo, o autor pode não ter como endereçar a sua pretensão em face de outro legitimado; legitimado pode ser aquele que, na decisão rescindível e, assim, enquadrável nos incs. do art. 966, foi declarado sem legitimidade para figurar no polo passivo. Do mesmo modo, o juiz pode reconhecer a litispendência em decisão gravada por um dos fundamentos de rescindibilidade previstos nos incs. do art. 966.

Além disso, prevê-se o cabimento da ação rescisória quando decisão transitada em julgado, ainda que não de mérito, impede a “admissibilidade do recurso correspondente”. O § 2.º do art. 966 refere-se à decisão de Tribunal ou Corte Suprema que não admite o recurso. É claro que, se a decisão objeto do recurso está viciada por uma das causas dos incs. do art. 966, a ação rescisória é cabível contra a decisão recorrida, a despeito de o recurso não ter sido admitido. Porém, apenas para reabrir a rediscussão do caso, o § 2.º afirma o cabimento da ação rescisória contra a decisão que “impeça a admissibilidade do recurso correspondente”. Isso é possível, como é óbvio, somente quando a decisão de inadmissibilidade incide em motivo de rescindibilidade.

4. Ação rescisória contra decisão de questão prejudicial

4.1. Primeiras considerações. O tema da coisa julgada sobre questão é absolutamente novo. Não apenas passou a ser discutido na doutrina de civil law recentemente,⁴ como, em termos normativos, apareceu no direito brasileiro somente com o Código de Processo Civil de 2015. De modo que, para a adequada compreensão das decisões rescindíveis, é imprescindível o aprofundamento da análise da coisa julgada sobre questão prejudicial.

A abordagem exige a consideração dos arts. 503 e 506 do código. Diz o art. 503: “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1.º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I – dessa resolução depender o julgamento do mérito; II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2.º A hipótese do § 1.º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”. Por sua vez, afirma o art. 506: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Como está claro, o art. 503 prevê expressamente a possibilidade de a coisa julgada estender-se à questão de que “depender o julgamento do mérito”, desde que presentes determinados pressupostos, como, por exemplo, ter “havido contraditório prévio e efetivo”. O art. 506, ao reafirmar que a coisa julgada diz respeito às partes, adverte que esta não pode prejudicar terceiros, podendo, consequentemente, beneficiar aqueles que não participaram do processo.

4.2. Fundamento. Para que se compreenda o raciocínio que será desenvolvido, não há como deixar de situá-lo no contexto das razões ou dos motivos para o sistema processual brasileiro – de um momento para o outro – não só abandonar um critério absolutamente tradicional em todo o civil law – a restrição da coisa julgada ao dispositivo e às partes –, como também inovar para se aproximar do common law.

Esclareça-se prontamente que a extensão da coisa julgada à questão de que depende a decisão, e também, eventualmente, para terceiros que não participaram do processo, nada tem a ver com o sistema de precedentes judiciais ou com o *stare decisis*. Tornar imutável e não passível de rediscussão o que se decidiu a respeito de uma questão que é pressuposto para a solução do mérito é uma exigência que se relaciona com a necessidade de estabilidade da própria decisão do litígio às partes, com a autoridade das decisões judiciais e com a eficiência da distribuição da justiça.

Não há sentido em fragilizar o que se decide a respeito de uma questão, retirando das partes a segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada, apenas pela circunstância de as partes, no processo em que resolvida a questão, estarem interessadas na solução de outra controvérsia. Considere-se, por exemplo, a ação de alimentos em que se alega que o demandado, por ser pai do autor, deve pagar-lhe alimentos. Controvertida a questão da paternidade, essa obviamente se torna um pressuposto a ser discutido e decidido para a solução do pedido de alimentos. Ora, se a questão é devidamente discutida pelas partes, sem qualquer restrição, não há qualquer razão para não se atribuir autoridade de coisa julgada à decisão pertinente à questão da paternidade. Deixá-la em aberto e livre para questionamentos futuros serve apenas para não definir às partes algo que é mais importante do que os próprios alimentos. É absurdo permitir que as partes voltem a discutir a questão de paternidade, já resolvida na ação de alimentos, apenas porque um dia alguém afirmou em sede doutrinária que a coisa julgada recai apenas sobre o objeto do processo ou sobre o pedido do autor.

Vale a pena lembrar que a ideia de restringir a coisa julgada ao pedido tem relação com o princípio dispositivo e, assim, com a liberdade das partes. Supunha-se que, como o juiz não pode decidir a não ser o que foi pedido pela parte, não seria possível tornar imutável e indiscutível algo que o próprio autor não pediu ao juiz. O Estado estaria ingressando numa esfera privada, que não é sua. O princípio dispositivo, ao limitar a atuação do juiz, também impediria a extensão da coisa julgada a uma questão que não foi posta pela parte enquanto pedido. Isso fica ainda mais claro quando se pensa na ação declaratória incidental: a decisão judicial só assume a condição de coisa julgada material quando a parte manifesta expressamente a sua vontade de ter a questão resolvida mediante tal condição.

Restringir a coisa julgada em virtude do princípio dispositivo ou da liberdade das partes obviamente não tem sentido. Afinal, são as próprias partes que controvertem a questão em juízo, tornando-a capaz de ser decidida com força de coisa julgada. Também são as partes que terão definitivamente resolvida uma questão importante para a acomodação do seu conflito social, bem como para a estabilidade das suas vidas.

Além disso, desafia a autoridade da prestação jurisdicional voltar a decidir questão já decidida, especialmente uma questão que já foi decidida entre as mesmas partes. Na verdade, permitir a rediscussão de questão já decidida para as partes, apenas por estarem a litigar num outro processo, significa reduzir a autoridade da prestação jurisdicional ao dispositivo, como se a solução da questão de que depende a resolução do mérito não representasse afirmação do poder estatal. Ora, não há motivo para fingir não ver que a possibilidade de voltar a discutir e decidir questão já decidida representa a admissão de que o juiz só exerce poder – ou realmente decide – quando julga o pedido. Isso obviamente não tem racionalidade.

Fora tudo isso, dar às partes oportunidade para relitigar questão já discutida e decidida certamente dobra o gasto de tempo e de dinheiro das partes e da administração da justiça, constituindo um atentando contra a racionalidade da prestação jurisdicional.

4.3. Questão de que depende o julgamento do mérito. O inc. I do art. 503 fala literalmente em resolução de questão de que “depende o julgamento do mérito”. Isso quer dizer que a questão prejudicial que importa para se saber se há coisa julgada não é apenas aquela que diz respeito ao que se chama – no direito italiano – de “fato-direito”.⁵ Constitui fato-direito, por exemplo, a qualidade de herdeiro na ação em que se controverte sobre crédito do de cujus. A qualidade de herdeiro não é apenas um simples fato de que pode decorrer um direito; ela é um fato que pode constituir objeto de uma ação autônoma.

Porém, todo fato que pode ser associado a um efeito jurídico – e não apenas os “fatos-direito” – é capaz de dar origem a uma questão prejudicial. Assim, por exemplo, o fato atribuído ao réu que pode ser associado ao efeito jurídico culpa. No caso em que se pede indenização por danos emergentes afirmando-se a culpa do demandado diante de acidente automobilístico, determinado fato – como a velocidade acima do limite permitido em lei – é associado à culpa, de modo que a culpa é um pressuposto de que depende a resolução do pedido de indenização. A culpa, portanto, é aí uma questão prejudicial sobre a qual pode recair coisa julgada.

Note-se que, uma vez decidida a questão da culpa com autoridade de coisa julgada, não será possível voltar a discutir e decidir a mesma questão em outra ação em que o mesmo autor peça indenização por lucros cessantes ou danos morais em face do mesmo réu e do mesmo fato antes qualificado como culposo. O juiz da primeira ação já decidiu sobre a existência de culpa, de modo que o juiz da segunda ação, em que se pede indenização por outro dano em virtude do mesmo fato antes admitido como culposo, não pode permitir que se volte a discutir a questão da culpa nem decidi-la. Está impedido a tanto pela coisa julgada formada sobre a questão.

O juiz da segunda ação não apenas não pode redecidir; não pode abrir oportunidade à discussão da questão. Deve, assim, indeferir a produção de prova destinada a provar que não houve culpa ou mesmo a prová-la. Aqui, o juiz, além de não poder decidir em sentido contrário, não pode decidir no mesmo sentido. As partes não podem relitigar a questão, o juiz não pode permitir a sua rediscussão e também não pode redecidi-la.

Assim, o autor que já obteve indenização pelos danos emergentes, pode pedir indenização por lucros cessantes ou danos morais invocando a autoridade de coisa julgada já estabelecida sobre a questão da culpa em virtude do acidente. Também poderá invocar a proibição de relitigação da questão se o réu tentar rediscuti-la ou requerer a produção de prova para resolvê-la. O que se poderá rediscutir e terá que ser decidido é, por exemplo, a existência de lucros cessantes ou o cabimento – no caso – da indenização por danos morais.

Frise-se que a questão só ficará revestida pela coisa julgada se dela depender o julgamento do mérito. Vale dizer: a questão ficará acobertada pela coisa julgada apenas se o julgamento do pedido exigir a sua resolução incidental. É possível que o juiz possa julgar o mérito a partir da solução de mais de uma questão, como, por exemplo, ocorre quando o autor afirma que o réu praticou condutas que configuram culpa e dolo. A culpa e o dolo dizem respeito a questões distintas, ainda quando relacionados ao mesmo e único fato. Saber se houve dolo ou se houve culpa é decidir uma questão de que o julgamento do pedido indenizatório depende.

4.4. A questão pode derivar de fato constitutivo ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. É verdade que os fatos, quando negados pela parte adversa, tornam-se controversos e exigem a produção de prova. Porém, nem sempre a questão prejudicial deriva de um fato constitutivo negado pelo demandado. Como é sabido, o réu pode não apenas negar os fatos constitutivos afirmados pelo autor, mas também alegar fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Assim, se o réu alega adimplemento – fato extintivo – ou, ainda, por exemplo, exceção de contrato não cumprido – fato impeditivo –, a negação do fato pelo autor torna-o controverso e, assim, faz surgir uma questão de que depende o julgamento do pedido de pagamento das prestações pecuniárias.

4.5. Questão discutida. O art. 503 deixa claro que a coisa julgada apenas recai sobre questão na hipótese em que não ocorrer revelia, o contraditório for efetivo e o procedimento não contiver restrição quanto à produção de prova e à discussão de determinados temas.

Tudo isso tem relação com a circunstância de que a questão será considerada indiscutível num processo futuro, em que uma das partes poderá ser prejudicada em virtude da decisão já tomada.⁶ Ora, é certo que uma decisão judicial apenas pode prejudicar aquele que teve ampla e completa oportunidade de influenciar o juiz, ou seja, de alegar, discutir, requerer prova, participar da sua produção e considerar sobre o seu resultado. Ninguém pode ser prejudicado por decisão tomada

em processo de que não pôde participar em adequado contraditório. Trata-se de princípio basilar e ancestral que legitima o exercício do poder estatal no processo. A legitimidade do exercício do poder pelo juiz depende da efetiva possibilidade de participação daqueles que serão afetados pela decisão judicial.⁷

O interessante é que, tratando-se de coisa julgada sobre questão, não basta a oportunização para o contraditório. Segundo o art. 503, § 1.º, II, é preciso que tenha “havido contraditório prévio e efetivo”. Isso é assim em razão de a decisão ficar na dependência de a questão se tornar controvertida, além de poder prejudicar a uma das partes em processo futuro.

Não pode haver coisa julgada sobre questão quando há revelia, simplesmente porque, nesse caso, a questão não se torna controvertida. Aliás, pelo mesmo motivo pode não haver coisa julgada em caso de não contestação, ou seja, quando há apresentação de contestação e o fato constitutivo – de que surgiria a questão prejudicial – não é contestado.

Porém, é preciso evitar enganos. A coisa julgada sobre questão não é excluída pelo simples fato de o procedimento restringir a prova ou a discussão de determinado tema. Antes de tudo, é preciso esclarecer que a restrição da prova pode resultar em duas técnicas de cognição: sumária e exauriente secundum eventum probationis. A técnica da cognição sumária é típica às hipóteses em que se dá ao juiz poder para decidir mediante juízo de probabilidade, que dispensa as provas cujo tempo de produção é incompatível com a urgência que caracteriza a necessidade de tutela do direito. Ao contrário, a cognição exauriente não permite a postecipação da produção da prova. Porém, a técnica da cognição exauriente secundum eventum probationis é a que diz respeito às hipóteses em que, ao mesmo tempo que se restringe a prova, não se permite ao juiz decidir o mérito quando a prova não é suficiente para elucidar o mérito. É a técnica de cognição aplicada aos casos em que a matéria de mérito não depende, para ser elucidada, de prova distinta da documental. Nesses casos, embora a prova seja restringida a determinada espécie – documental –, o juiz não se vê obrigado a decidir com base em probabilidade; o juiz tem a prova adequada para poder declarar a existência ou a inexistência do direito afirmado.

Tome-se em conta, por exemplo, o mandado de segurança. Nesse procedimento a afirmação de existência do direito deve ser provada desde logo, ou melhor, mediante prova documental anexa à petição inicial. Por sua vez, o réu também não pode produzir prova diversa da documental. Se o autor apenas pode se valer de documento e esse deve ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito, a única forma de o réu se opor à alegação fática é através da negação da idoneidade do documento. Fora daí apenas poderá discutir a matéria de direito. Quando o direito afirmado no mandado de segurança exige outra prova além da documental, fica ao juiz impossível o exame do mérito. No caso oposto, quando apresentada prova documental da alegação – ou o chamado “direito líquido e certo” –, o juiz julgará o mérito e a sentença produzirá coisa julgada material. Assim, o mandado de segurança constitui um procedimento que tem o exame do mérito condicionado à existência de prova documental.⁸

Portanto, é simplesmente impossível decidir questão prejudicial que dependa de prova diferente da documental no mandado de segurança. Mas isso está longe de significar que não se pode decidir questão prejudicial com força de coisa julgada no mandado de segurança. Basta que a questão prejudicial não exija qualquer prova ou dependa exclusivamente de prova documental. Nessa hipótese é obviamente possível decidir questão prejudicial sem qualquer restrição à adequada cognição judicial, ainda que o procedimento restrinja a produção probatória.

Contudo, ao se pensar – em tese – em tutela final baseada em cognição sumária – e não em juízo de cognição exauriente secundum eventum probationis –, obviamente não há como ter coisa julgada sobre questão caso essa igualmente exija – assim como acontece com o próprio pedido – provas que não estão no processo.

Algo diferente acontece quando se pensa em cognição parcial. Quando o procedimento limita a matéria de defesa, reservando determinados pontos litigiosos para outra demanda, há uma limitação do conflito de interesses (ou da lide, para quem identifica conflito de interesses com lide) e, assim, a construção de um procedimento de “lide parcial” (compreendida, por óbvio, no sentido

carne luttiano).⁹ O procedimento de lide parcial é um procedimento que limita a cognição do juiz sobre a “lide total”, podendo ser dito, assim, procedimento de cognição parcial. Perceba-se que nesses casos não há restrição à produção de prova: a cognição não é exauriente secundum eventum probationis nem sumária; é, isto sim, cognição exauriente (no sentido vertical) e parcial (no sentido horizontal).¹⁰

Se um procedimento pode restringir o direito de discutir determinada porção da “lide total” para dar efetividade à tutela do direito material, o direito não terá sido violado desde que a parte possa invocar a questão subtraída por meio de ação inversa posterior. Embora seja plenamente possível impedir a alegação em um procedimento diferenciado – de cognição parcial –, não é possível proibir a alegação e, conseqüentemente, a prova perante o Poder Judiciário.

Considere-se, por exemplo, o procedimento da desapropriação, precisamente a regra que afirma que “a contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta” (art. 20 do Dec.-lei 3.365/1941). Essa regra define os limites da defesa na ação de desapropriação, mas obviamente não exclui a possibilidade da discussão da questão restringida através de outra ação. Por isso mesmo, o art. 20, em sua parte final, apressa-se em esclarecer que o réu poderá discutir “qualquer outra questão” por meio de ação própria. O objetivo da regra é definir a defesa que pode ser apresentada na ação de desapropriação e não eliminar a possibilidade de o desapropriado discutir questões que poderiam impedir a desapropriação. De outro modo estaria sendo violado o princípio da inafastabilidade.

Como está claro, a lei, ao dar os contornos de um procedimento de cognição parcial, pode impedir a parte de alegar determinada questão, mas certamente não pode eliminar o seu direito de discuti-la em juízo. A simples restrição do direito à alegação não pode ser dita inconstitucional. A violação ao núcleo essencial do direito de ação ou do direito de defesa somente se dará se a lei impedir a parte de invocar a alegação excluída perante o Poder Judiciário.

Quando se fala em procedimento de cognição parcial, em que a discussão de determinada questão é proibida, o problema não é de restrição de prova ou ao contraditório, mas de deslocamento da discussão da questão para ação inversa e procedimento posterior. Assim, quando determinada alegação excluída da apreciação pela lei é invocada pela parte e considerada de passagem pelo juiz, sobre ela simplesmente não há como se formar coisa julgada. Não pelo fato de ela não ter sido discutida ou decidida; mas precisamente porque não podia ser objeto de discussão, cognição e decisão em virtude da lei que instituiu o procedimento.

Na verdade, a exclusão da coisa julgada em todas essas hipóteses quer dizer não só que a decisão resta na dependência de a questão ter sido controvertida, mas também que apenas uma discussão plena e adequada pode impedir a parte prejudicada de discuti-la em processo em que voltar a aparecer. De modo que o problema vai além.

Mesmo que um fato tenha sido contestado, isso não significa que a parte tenha discutido de modo pleno e adequado a questão. Aqui a lógica não é a mesma da formação da coisa julgada sobre o pedido. Não importa apenas saber se a parte teve oportunidade de adequadamente discutir. Caso a parte não tenha, por exemplo, requerido a produção de prova pericial capaz de alterar o resultado da decisão da questão, poderá pleiteá-la em processo futuro em que a questão novamente surgir.

Suponha-se a hipótese de ação de ressarcimento em que restou estabelecida a culpa do demandado pelo dano invocado, julgando-se procedente o pedido. Mais tarde, o mesmo autor pode propor ação contra o mesmo réu, afirmando exatamente o mesmo fato e a culpa já reconhecidos na ação anterior, mas invocando dano substancialmente maior para realizar pedido ressarcitório. Numa situação como essa, caso o demandado possa requerer a produção de prova que, não produzida anteriormente, pode absolvê-lo de culpa, não há como invocar coisa julgada sobre questão para obstar a sua rediscussão. Ao aceitar-se que a produção da prova pode alterar – em tese, obviamente – a decisão anterior, admite-se igualmente que a questão não foi adequadamente discutida no primeiro processo. Há também coisa julgada secundum eventum probationis. Não há

coisa julgada a impedir a rediscussão da questão com base em outra prova, quando esta prova – capaz de alterar a decisão – não foi considerada pelo juiz do processo anterior.

Perceba-se que a coisa julgada sobre questão, nesse aspecto, tem natureza semelhante à da coisa julgada erga omnes ou ultra partes das ações coletivas (art. 103, I e II, CDC), em que o pedido “julgado improcedente por insuficiência de provas” não impede que “qualquer legitimado” possa “intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”. A óbvia diferença é a de que, aqui, não se trata de ação com base em outra prova, mas de rediscussão da mesma questão com base em outra prova. Na realidade, quando o CDC fala em “outra” ação, está a se referir exatamente à mesma ação, porém a partir de nova ou outra prova.

Varia a razão pela qual se permite a rediscussão com base em outra prova, isto é, em prova que já poderia ter sido produzida, mas não foi. Tratando-se de tutela de direitos difusos e coletivos, isso ocorre em virtude de o legitimado à ação coletiva ser visto como alguém que pode não tutelar de forma adequada os direitos. No caso de decisão sobre questão, parte-se da premissa de que esta, por estar sempre relacionada a um pedido, pode levar a parte a vê-la de modo diverso conforme a importância e o significado do pedido. Portanto, uma mesma questão, diante de pedidos diferentes, pode despertar na parte receios, cuidados e atitudes diversos.

Quando o réu depara com afirmação da sua responsabilidade por dano ínfimo, é claro que a sua preocupação em face da declaração da sua culpa será compatível com o eventual prejuízo que poderá sofrer em virtude da procedência do pedido. No direito estadunidense, a limitação dos efeitos preclusivos do collateral estoppel tem relação direta com a possibilidade de a questão poder assumir configuração distinta em ação futura. Lembra-se claramente como hipótese a situação em que a demanda tem valor econômico destituído de significação, de modo que a parte poderia não ver razão para discutir intensamente a questão.¹¹ Deixa-se ver que a rigidez da preclusão da rediscussão da questão deve ser abrandada pela circunstância de que a parte sempre considera a questão diante do caso específico e nunca em face de casos futuros.¹²

Contudo, muito mais clara é a inexistência de coisa julgada quando o fato é discutido de passagem pelas partes, em meio a outras alegações e sem qualquer produção de provas. Isso, como é evidente, não se aplica às questões apenas de direito, ou melhor, às questões que não dependem do esclarecimento de fatos.

4.6. Questão de direito que independe de prova. No common law, a proibição de relitigar questão inicialmente ficou limitada às questões de fato. Porém, uma vez percebida a artificialidade da distinção entre questão de fato e questão de direito,¹³ as cortes, inclusive a Suprema Corte dos Estados Unidos, passaram a decidir que o collateral estoppel também se aplica às “issues of law”.¹⁴ E não apenas às questões de direito que envolvem fatos que necessitam ser provados, mas também às questões de direito que independem de prova.

Não há motivo para não admitir coisa julgada sobre questão de direito que independe de prova, nem mesmo sobre questão de constitucionalidade. Se uma questão de direito é discutida e decidida, não há motivo para que possa novamente ser discutida e decidida em processo entre as mesmas partes, tão somente em razão de a nova ação conter outro pedido ou causa de pedir mais abrangente. Não pode haver diferença, quando se pensa em coisa julgada sobre questão, entre questão que reclama produção de prova e questão que não a exige.

Lembre-se que, mesmo nessa última hipótese, a coisa julgada sobre questão ainda fica muito distante da eficácia obrigatória dos precedentes. No primeiro caso profere-se decisão entre as partes e para as partes, de modo que a questão não pode mais ser discutida e decidida para as mesmas partes, enquanto que o precedente vincula todos os juízes e afeta todos os jurisdicionados, não importando quem tenha participado do processo.

Do mesmo modo, a decisão sobre questão constitucional, ao dizer respeito apenas às partes que a discutiram, nem de longe contradiz o sistema de controle principal de constitucionalidade. Na verdade, se as partes discutiram questão constitucional e essa foi expressamente decidida pelo juiz, não há racionalidade em permitir que a mesma questão seja rediscutida pelas mesmas partes

apenas pelo fato de o pedido ser diferente.

4.7. Questão decidida. A proibição de relitigação da questão, além de depender de “contraditório prévio e efetivo”, exige que tenha sido “decidida expressa e incidentemente no processo” (art. 503, § 1.o, CPC). É interessante que essa previsão também possui claro parentesco com o Restatement (Second) of Judgments, que não apenas exige que a questão tenha sido “actually litigated”, como também requer que a questão tenha sido efetivamente decidida. A exigência de que a questão tenha sido “efetivamente decidida”, quando pensada em face do referido Restatement, recomenda lembrar que nos Estados Unidos as decisões de primeiro grau nem sempre são justificadas e as decisões das Cortes de Apelação federais e estaduais muitas vezes se limitam ao tradicional affirmed ou reversed, deixando de explicar as razões pelas quais a decisão impugnada é mantida ou reformada.¹⁵

Frise-se que a lógica da coisa julgada sobre questão está em negar a rediscussão de questão decidida, mas que foi efetivamente discutida.¹⁶ De nada adianta a questão ser decidida se não houve discussão efetiva das partes a seu respeito, seja em virtude do procedimento utilizado, seja em razão de a própria parte não ter requerido a produção de prova apta ao esclarecimento dos fatos.

Porém, o art. 503 também exige que a questão seja decidida de forma expressa e incidentemente no processo. É claro que a questão não precisa ser decidida mediante ato jurisdicional autônomo nem mesmo antes da sentença que julga o pedido. A questão pode ser decidida no curso da fundamentação da sentença que julga o pedido procedente ou improcedente.

Importa, porém, que a questão não seja apenas considerada de passagem pelo juiz; a questão tem que ser claramente solucionada em um sentido ou outro e, para tanto, deve contar com fundamentação capaz de explicar a opção judicial. Não se trata de uma exigência para a adequada fundamentação da sentença, mas de algo indispensável para que a questão possa ser dita decidida incidentemente no processo.

4.8. Competência absoluta. O art. 503, III, afirma que a decisão da questão prejudicial só produzirá coisa julgada quando “o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal”. Trata-se de competência absoluta, nos termos do art. 62, que diz ser inderrogável pelas partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função.

A previsão do inc. III do art. 503 não é mera consequência lógica da impossibilidade de o juiz absolutamente incompetente decidir o próprio pedido. É, isto sim, clara advertência de que o juízo competente para decidir o pedido pode não ter competência em razão da matéria – por exemplo – para decidir a questão. Se em ação de ressarcimento proposta por A perante a Justiça Federal em face de B e da União Federal surge uma questão prejudicial que diz respeito apenas à relação entre A e B, o juiz poderá decidi-la, mas a decisão da questão não terá aptidão para gerar coisa julgada. A situação é semelhante àquela que ocorria diante da ação declaratória incidental, à época do Código de Processo Civil de 1973. O juízo federal não podia decidir ação declaratória incidental que exsurgia a partir de questão prejudicial que dizia respeito a dois particulares. De igual modo, em processo acerca da posse de coisa que envolva herdeiros e alguém que se afirma herdeiro, eventual questão prejudicial que se forme sobre a qualidade de filho não abre oportunidade para decisão com autoridade de coisa julgada.

É importante perceber, no entanto, que a decisão de questão proferida por juízo absolutamente incompetente não precisa ser rescindida para deixar de ter autoridade capaz de obstar nova decisão em outro processo. O art. 503 afirma que há coisa julgada sobre questão se e quando o juízo tiver competência absoluta para decidir a questão prejudicial como principal. Significa dizer que, diante de processo em que a mesma questão apareça, a parte prejudicada poderá simplesmente alegar que a decisão foi proferida por juiz absolutamente incompetente para não sofrer a impossibilidade da sua rediscussão.

4.9. Coisa julgada em favor de terceiros: fundamento. Tendo em vista que a decisão de

questão pode se tornar indiscutível e imutável para as partes, é oportuno indagar se a resolução de questão pode afetar terceiros que não participaram do processo, mas cujos direitos dependem da solução da mesma questão.

Obviamente não se está a pensar na possibilidade de terceiro ser beneficiado por decisão relativa a uma questão similar ou que surge de uma situação concreta que não lhe diz respeito. Fala-se de questão idêntica, ou melhor, da solução da questão que diz respeito exatamente ao conflito concreto em que o terceiro está inserido. Portanto, está a se considerar a própria questão que o terceiro tem legitimidade para discutir em juízo para obter tutela do direito.

Muito mais do que as relações substanciais unitárias, importam aqui as hipóteses de múltiplos danos, inadimplementos ou violações, em que pessoas situadas numa mesma posição diante de um mesmo caso conflitivo concreto podem pedir tutela dos seus direitos ou litigar de forma individualizada em face de um único adversário.

Para exemplificar, é possível considerar o acidente de um ônibus com dezenas de passageiros. Tendo sido proposta ação por um grupo de três em face do proprietário do veículo que causou o acidente, o julgamento de procedência do pedido de indenização obviamente não pode beneficiar os demais acidentados ou mesmo as famílias de eventuais mortos. Contudo, a controvérsia que se formou a respeito da culpa, ao dar origem a uma questão adequadamente discutida e expressamente decidida, evidentemente é do interesse dos demais acidentados. Isso porque essa questão decidida nada mais é do que a questão de que depende a tutela dos direitos dos acidentados que não participaram do processo.

De modo que o problema que surge, bem vistas as coisas, é somente o de se é racional admitir a rediscussão de questão já decidida apenas por terem sido alteradas as partes do processo, ou melhor, apenas pelo vencido estar agora litigando com parte que, apesar de estar envolvida no conflito concreto, não participou do processo em que a questão prejudicial à tutela do seu direito foi resolvida.

Essa colocação, apesar de contradizer a tradição do direito processual de civil law, tem sustentação na lógica que deve presidir a prestação jurisdicional, na otimização do serviço judiciário, na autoridade das decisões judiciais, na coerência do direito, na segurança jurídica e nos direitos fundamentais processuais. Enfim, não há argumento razoável que possa a ela se opor.

Lembre-se que Bentham, nas primeiras décadas dos oitocentos, fez advertência similar ao dizer que, se há razão para dizer que um homem não deve perder a sua causa em consequência de uma decisão dada em anterior processo de que não foi parte, não há qualquer razão para dizer que ele não deve perder a sua causa em consequência de uma decisão proferida em um processo em que foi parte simplesmente porque o seu adversário não foi.¹⁷ A frase de Bentham é ainda hoje utilizada na Suprema Corte dos Estados Unidos em casos em que se discute a possibilidade de terceiro invocar a proibição da parte relitigar questão já decidida – non-mutual collateral estoppel. Em *Parklane v. Shore*, o Justice White lembrou Bentham e advertiu que a admissão da discussão da mesma questão, apenas em razão de o adversário ser outro, traz péssimas consequências em termos econômicos, seja para as partes envolvidas, seja para a administração da justiça.¹⁸

Da conjugação dos arts. 503 e 506 do CPC extrai-se que a coisa julgada sobre questão pode beneficiar terceiros. Perceba-se que o art. 506 do código atual afirma que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, enquanto que o art. 472 do CPC/1973 dizia que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. Ora, não se trata apenas de um silêncio do legislador, mas da clara exclusão da cláusula “não beneficiando”, ou seja, da prática de ato que evidência a intenção nítida e indiscutível do legislador de permitir que a coisa julgada beneficie terceiros.

4.10. A coisa julgada sobre questão pode beneficiar terceiro, mas jamais prejudicá-lo. Esclareça-se que a decisão a respeito de questão que também é de terceiro somente pode beneficiá-lo, nunca prejudicá-lo. Trata-se de obviedade quando considerado que ninguém pode ser prejudicado por decisão tomada em processo de que não pôde participar e que todos têm direito

fundamental de influenciar o convencimento do juiz.

Frise-se que o collateral estoppel foi inicialmente concebido enquanto proibição das partes do processo em que proferida a decisão voltarem a discuti-la em processo posterior. Só mais tarde é que se admitiu que terceiro poderia invocar a proibição de rediscussão de decisão proferida em processo alheio em seu benefício. Esse modo de ver o collateral estoppel foi qualificado de non-mutual collateral estoppel.

O caso Bernhard v. Bank of America National Trust and Savings Association deu origem à primeira decisão de uma Corte estadunidense admitindo o non-mutual collateral estoppel. ¹⁹ Ao julgar esse caso no início dos anos 40 do século passado, a Suprema Corte da Califórnia decidiu que o estranho ao processo em que decidida a questão também pode invocar proibição de relitigar questão já decidida contra aquele que já a discutiu.²⁰ A Suprema Corte dos Estados Unidos tratou pela primeira vez do tema em 1971, ao julgar Blonder-Tongue Laboratories Inc. v. University of Illinois Foundation. Nesse caso, a University of Illinois Foundation voltou a alegar violação da sua patente, que, entretanto, já havia sido declarada inválida em processo anterior. Depois de alertar para as consequências econômicas da abertura à relitigação da validade da patente, a Suprema Corte revogou parcialmente o precedente firmado em Triplett v. Lowell e declarou que a mutualidade do collateral estoppel estava “out of place”.²¹

Porém, em ambos os casos foram firmados claros requisitos para admissão da dispensa da mutualidade do collateral estoppel. Afirmou-se que o terceiro só poderia invocar a proibição de relitigação quando a questão fosse idêntica (the issue is identical), ocorresse julgamento final do mérito (a final judgments on the merits) e aquele a quem se pretende proibir a rediscussão tivesse não apenas sido parte no processo em que proferida a decisão, mas houvesse tido “full and fair opportunity” de participação.²²

A ideia de “full and fair opportunity” de participação tem relação com o pressuposto da adequada discussão da questão, posta no art. 503 do CPC. A parte que pode ser prejudicada em processo futuro, especialmente diante de terceiro que não participou do processo em que proferida a decisão, não pode ser proibida de relitigar quando deixou de discutir adequadamente a questão.

4.11. A questão deve ser a mesma e deve estar inserida no conflito entre as partes e os terceiros. É evidente que a coisa julgada só pode obstaculizar a discussão da mesma questão, isto é, da questão decidida no processo anterior. Além disso, a questão deve ser porção do conflito de interesses entre a parte vencida, de um lado, e a parte vencedora e os terceiros, de outro. Vale dizer, a questão decidida, para ser invocada por terceiro, deve ser uma questão de titularidade do terceiro, que, caso não houvesse sido decidida, teria que ser discutida em ação posterior enquanto prejudicial para a tutela do seu direito.

Quer isso dizer que a coisa julgada em benefício de terceiros não pode ser confundida com o efeito obrigatório dos precedentes das Cortes Supremas. Os precedentes obviamente não têm qualquer relação com terceiros nem com partes. Apenas orientam os jurisdicionados e vinculam os juízes dos casos futuros, sem que precisem ter sido discutidos pelas partes dos novos processos, mesmo quando as prejudicam.

Não é por outro motivo que quando um precedente é invocado a parte que pode ser prejudicada tem a possibilidade de argumentar mediante a técnica da distinção, demonstrando que o caso sob julgamento, em vista de suas particularidades, não tem motivo para ser resolvido mediante a aplicação do precedente. Quando se pensa em precedente, em outras palavras, sempre se supõe que a questão não é igual ou idêntica e, especialmente, que a questão não está inserida num conflito de interesses de que fazem parte os litigantes do primeiro e do segundo processos. A cogitação sobre precedente faz supor apenas uma questão similar, resolvida entre partes que nada têm a ver com as partes do caso sob julgamento, ao passo que a coisa julgada sobre questão exige questão idêntica à decidida, pertencente às partes do novo processo ou ao conflito de interesses em que estas estão inseridas.

4.12. Ato que provoca múltiplos danos ou prejuízos. Um dos casos em que a coisa julgada em favor de terceiros mostra-se mais relevante é aquele em que alguém pratica ato de que derivam múltiplos fatos danosos. Pense-se num acidente de grandes proporções, que gerou danos a inúmeras pessoas. Assim, por exemplo, no derrame de material químico em uma região litorânea, que ocasionou danos a centenas de pescadores e a dezenas de restaurantes e hotéis. Num caso como esse, em que são produzidos fatos danosos de diferentes proporções, o nexo causal constitui um árduo pressuposto a ser ultrapassado para a definição da responsabilidade pelo dano.

Suponha-se, assim, que foram julgadas improcedentes duas demandas propostas por dois grupos de pescadores. Na terceira demanda, demonstra-se que o demandado pratica atividade que certamente produz os detritos químicos encontrados no meio ambiente e o juiz, a partir da valoração da prova e de juízo sobre o direito, declara o nexo causal e a responsabilidade da empresa demandada, condenando-a ao pagamento de ressarcimento pelo dano causado.

Se a questão respeitante à responsabilidade do dano foi adequadamente discutida pela empresa, há coisa julgada sobre a questão da responsabilidade pelo dano. Assim, numa próxima ação, proposta por outro grupo de pescadores, estará proibida a rediscussão da questão da responsabilidade, devendo ser discutida e determinada apenas a extensão do dano e o seu valor pecuniário equivalente.

Note-se, contudo, que o eventual reconhecimento da falta de responsabilidade do demandado, enquanto solução da questão prejudicial a seu favor, jamais poderá obstaculizar a rediscussão da questão da responsabilidade em ação proposta por outro grupo de pescadores. É que estes não participaram do processo em que proferida a decisão em favor da empresa. Frise-se que a decisão da questão prejudicial só pode beneficiar terceiros, jamais prejudicá-los.

O mesmo ocorre no caso de ato contrário ao direito que exige tributo ou sua majoração. A afirmação de que um tributo está sendo inconstitucionalmente cobrado, ao ser negada, faz surgir questão prejudicial. A discussão e a decisão dessa questão em processo de um ou de um grupo produz coisa julgada, que, assim, pode ser invocada por terceiro em processo futuro. Nessa hipótese, ao contrário do que ocorre no caso dos danos múltiplos ocasionados pelo derrame de material químico, não há um único ato que atinge a todos, mas atos particulares balizados numa premissa comum, que nada mais é do que o ato que afirma a exigibilidade do tributo. Contudo, isso não quer dizer que a questão decidida no processo de um contribuinte não seja exatamente a mesma que importa a outro contribuinte para obter tutela do seu direito.

Similar a esta última é a situação dos danos acarretados a vários consumidores em virtude da venda de produtos com “defeito” – como, por exemplo, “defeito de concepção”.²³ De acordo com o art. 12 do CDC, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Fala-se nesses casos em danos oriundos de “acidentes de consumo”.²⁴

Numa situação como esta, não obstante as aquisições sejam individualizadas, os produtos contêm um mesmo defeito, que está na projeção do produto. Assim, se um consumidor propõe ação contra o produtor – por exemplo –, alegando defeito na concepção do produto e pedindo indenização pelo dano provocado quando da sua utilização, a negação do defeito e da consequente responsabilidade faz surgir questão prejudicial ao julgamento do pedido de indenização. A decisão da questão prejudicial no sentido de que há “defeito de concepção” e, por isso, responsabilidade pelo dano, produz coisa julgada que pode ser aproveitada pelos demais consumidores que sofreram danos em virtude da utilização do mesmo produto dotado de “defeito de concepção”.

4.13. Discussão do preenchimento dos requisitos formais para a formação da coisa julgada sobre questão. Na linha do direito estadunidense, o Código de Processo Civil delineou critérios que devem ser preenchidos para a configuração da coisa julgada sobre a questão prejudicial. Assim, nos termos do art. 503, cabe ao juiz do processo em que a coisa julgada for

invocada analisar: i) se a questão foi devidamente decidida, ii) se houve contraditório prévio e adequado, iii) se a questão precisava ser decidida para se chegar no julgamento do pedido e iv) se o juízo que decidiu tinha competência em razão da matéria e da pessoa para tratar da questão em via principal.

Embora a *indiscutibilidade* seja corolário da *autoridade* da coisa julgada, a indiscutibilidade da questão num segundo processo, diante do art. 503, fica na dependência do controle do juiz. Nesse sentido, a eficácia da coisa julgada sobre questão, numa outra ação, é subordinada à verificação da presença dos requisitos do art. 503.

Dentre esses requisitos, o mais problemático é o da oportunidade para a discussão da questão. Não é apenas a restrição (probatória ou à cognição) abstratamente delineada no procedimento que impede a adequada discussão da questão. Equívoco na inadmissibilidade do recurso ou de prova e o surgimento de nova técnica capaz de permitir a elucidação dos fatos revelam impossibilidade de discussão. A indevida inadmissibilidade do recurso, vista como *impossibilidade* de obtenção de reanálise da decisão, é suficiente para caracterizar violação à cláusula da “adequada discussão”. Do mesmo modo, a indevida inadmissibilidade da prova, a evidenciar *impossibilidade* de elucidação dos fatos imprescindíveis à resolução da questão, basta para demonstrar que não houve adequada oportunidade de discutir.

5. Ação rescisória e capítulo da decisão rescindenda. Conforme diz o art. 966, § 3.º, “a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão”. Como é sabido, a princípio os capítulos da sentença dizem respeito a resoluções de mérito relacionadas a pedidos cumulados ou a pedidos contrapostos ou reconventionais.²⁵ Assim, por exemplo, a rescisão contratual e a restituição da coisa ou, embora em outra perspectiva, o ressarcimento de dano material e o ressarcimento de dano moral. Os capítulos de mérito, segundo parcela da doutrina, também podem dizer respeito a pedidos quantificáveis, como o de pagamento de soma em dinheiro, caso em que a sentença pode ter um capítulo que condena ao pagamento de parcela do valor pedido e outro que declara indevido o valor restante.²⁶ Também são admitidos capítulos sentenciais pertinentes a questões processuais, ou melhor, a questões que podem impedir o julgamento do mérito, como as relativas às condições da ação e aos pressupostos processuais.²⁷

É certo que determinados fundamentos de rescindibilidade associam-se naturalmente à decisão na sua íntegra. Assim, por exemplo, são os casos de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz e os de juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente (art. 966, I e II, CPC). É, em outros, e não nesses casos, que importa relacionar o motivo rescindente com o capítulo da sentença, como no caso de haver ofensa à coisa julgada no capítulo da sentença que julgou o pedido de ressarcimento por dano material, e não no capítulo que julgou o pedido de ressarcimento por dano moral.

Nesse exemplo, em que os capítulos são independentes, a ação rescisória pode ser dirigida contra o capítulo da sentença que o autor entende conveniente impugnar com base em determinado fundamento rescindente. Porém, algo diferente sucede quando se tem em conta os capítulos decisórios que correspondem a pretensões relacionadas por prejudicialidade. Por exemplo, os pedidos de rescisão contratual e de restituição de coisa. Nesse caso, a ação rescisória deve se voltar contra os dois capítulos da decisão. Mas, caso seja pedida apenas a rescisão do primeiro capítulo, julgando-se este procedente, a consequência lógica é a procedência do segundo, de modo que se pode admitir a desconstituição dos dois capítulos sem que a ação rescisória tenha sido dirigida contra ambos. Distinta é a hipótese em que a ação rescisória pede a desconstituição do capítulo dependente – ou seja, do segundo – sem pedir a do subordinante. Nesse caso, a desconstituição do primeiro certamente não é consequência lógica do segundo. De modo que há de se dar oportunidade para o autor emendar a petição inicial, oportunizando-lhe a realização do pedido de desconstituição do primeiro capítulo.²⁸

Situação particular é a do capítulo dos honorários de advogado. Esse capítulo, ainda que possa ser considerado dependente do capítulo relativo ao pedido principal, deve ser discutido pelos advogados titulares do direito aos honorários, de sorte que, caso haja propositura de ação rescisória diante do capítulo que versou sobre o mérito e também do capítulo que condenou em honorários de advogado, coloca-se num só processo partes que não litigam sobre ambos os

capítulos.

Mais interessante e complexa é a questão dos capítulos sobre questões.²⁹ Quando a coisa julgada recai apenas sobre a parte dispositiva da decisão, negando-se importância às resoluções das questões – vistas como pressupostos lógicos, sem autonomia e capacidade para projetar efeitos sobre a vida das pessoas –, obviamente não há que se pensar em capítulos da decisão (sentença, acordo, decisão monocrática) relativos às questões. Bem por isso, não era possível cogitar de capítulo sobre questão no CPC/1973. Porém, isso agora é necessário em vista do art. 503, § 1.º, que expressamente admite que a coisa julgada pode recair sobre questão de que depende o julgamento do mérito. No código atual, a decisão sobre questão está muito longe de ser um mero pressuposto lógico. Tem absoluta autonomia e produz efeitos substanciais para fora do processo, revestindo-se de indiscutibilidade e imutabilidade em qualquer processo futuro envolvendo as mesmas partes. Também possui efeitos sobre terceiros, para beneficiá-los (art. 506, CPC), podendo ser invocada pelos titulares da questão resolvida que não participaram do processo.

No sistema em que a coisa julgada recai apenas sobre a parte dispositiva da decisão, a rescindibilidade está restrita aos capítulos decisórios, enquadrados no dispositivo. Aí obviamente não há interesse de agir na rescindibilidade de decisão de questão. Contudo, no sistema em que há coisa julgada sobre questão, pode haver interesse ou fundamento rescindível para a sua desconstituição. Quando há vício rescindível na decisão da questão, o autor em regra tem interesse em desconstituir a coisa julgada sobre a questão e a coisa julgada sobre a parte dispositiva, na medida em que a segunda se funda na primeira. Entretanto, pode haver causa para rescisão apenas em relação à decisão do pedido, abstraindo-se a decisão da questão. Suponha-se, por exemplo, pedido de ressarcimento de dano baseado na responsabilidade do demandado. Nesse caso, pode haver decisão que reconheça a responsabilidade civil (decisão sobre questão prejudicial) e decisão que reconheça o dano com base em erro de fato, admitindo-se um fato que não existiu para a configuração dos lucros cessantes e a concessão da tutela ressarcitória.

Há situações em que o vencido tem motivos concretos para temer que a coisa julgada que recaiu sobre a questão possa ser invocada em processo futuro. Assim, por exemplo, na hipótese em que houve decisão sobre a responsabilidade civil para a condenação do demandado a pagar danos emergentes. Admitindo-se que o autor não está impedido de propor outra ação de ressarcimento por lucros cessantes, a parte condenada no primeiro processo tem claro motivo para pretender rescindir a decisão a respeito da responsabilidade para poder voltar a discuti-la na ação de ressarcimento fundada em lucros cessantes. A mesma ou maior preocupação pode existir no caso de decisão que reconhece a responsabilidade em ação proposta por uma das vítimas de acidente em que estão envolvidas várias outras pessoas. Nesse caso, como a coisa julgada sobre a questão da responsabilidade pode ser invocada pelas demais vítimas em futuras ações de ressarcimento (art. 506, CPC), a existência de fundamento rescisório em relação à decisão da questão ganha especial dimensão.

É possível pensar, ainda, em capítulos de decisões distintas tomadas em um mesmo processo. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando a ação rescisória se volta contra a decisão que julgou parcialmente o mérito (art. 356, CPC) e a sentença, tomando em consideração seus respectivos capítulos.

6. Decisão proferida em virtude de prevaricação, concussão ou corrupção. O inc. I do art. 966 afirma ser rescindível a decisão quando “se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz”. O legislador utiliza nomes que qualificam crimes previstos no Código Penal. De modo que não é correto pensar que se possa buscar em outro lugar, que não nos respectivos artigos do Código Penal, elementos para configurar os seus respectivos conceitos. De acordo com o art. 319, do CP, há prevaricação quando o juiz, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou ainda pratica ato contra disposição expressa de lei. Dá-se a concussão quando o magistrado exige vantagem indevida em razão de suas funções (art. 316, CP). A corrupção que dá lugar à ação rescisória é a corrupção passiva, que importa na solicitação, ou recebimento, pelo magistrado, em razão de suas funções, de vantagem indevida, ou aceitação quanto à promessa de recebê-la (art. 317, CP).

O inc. alude expressamente a “juiz”. Entretanto, é óbvio que se refere a qualquer magistrado. Não há racionalidade em supor que a norma exclui membro de tribunal ou mesmo de Corte Suprema. Afinal, não deve importar em que tribunal ou Corte uma dessas hipóteses ocorre.

Também não procede pensar que, tratando-se de julgamento colegiado, a corrupção de um dos membros do colegiado não seja suficiente para determinar a rescisão da decisão. Num colegiado composto por cinco julgadores, a prova da corrupção de apenas um, mesmo no caso em que o julgamento é proferido à unanimidade, é suficiente para viciar a decisão. Aliás, não importa o teor do voto do julgador que incidiu em corrupção, prevaricação ou concussão. Mesmo se o voto for vencido, a decisão colegiada está irremediavelmente maculada e, assim, torna-se rescindível.³⁰

É que a decisão colegiada não pode ser cindida para o efeito de se expurgar a corrupção de um dos julgadores. A ideia de cindir a decisão, separando-se o voto do juiz corrupto, só tem cabimento quando a decisão colegiada é pensada como um mero ajuntamento de decisões individuais dos membros do colegiado, situação em que não se percebe que a vontade do juiz tem poder para influenciar o conteúdo dos votos vencedores. Bem por isso, é a participação no julgamento – e não o simples voto – de magistrado que incidiu em corrupção, concussão ou prevaricação que vicia a decisão colegiada, tornando-a rescindível.³¹

O inc. I fala que a rescisão deve se dar quando “se verificar que foi proferida...”. Significa, em primeiro lugar, que a rescisão da decisão não depende de processo penal nem muito menos de condenação penal transitada em julgado. É preciso apenas que se demonstre, no processo da rescisória, que a decisão foi proferida por juiz ou por colegiado composto de magistrado que incidiu em prevaricação, concussão ou corrupção.

Mas isso não quer dizer, como é óbvio, que não possa existir processo penal que possa ser relacionado com a ação rescisória. É realmente possível pensar em processo penal i) que transitou em julgado antes da propositura da ação rescisória, ii) que pendeu ao lado do processo da rescisória e iii) que iniciou depois do encerramento da ação rescisória.

É certo que se está a cogitar de processo penal que se relaciona com o julgamento que deu origem à decisão que se pretende rescindir. A condenação de um juiz em processo penal obviamente não torna todas as suas decisões rescindíveis.

Se o juiz ou membro do colegiado já foi condenado em processo penal, a rescisão da decisão civil não precisa mais do que a decisão transitada em julgado proferida no processo penal. Porém, se o juiz foi absolvido, isso não quer dizer que a ação rescisória não possa ser julgada procedente. Isso apenas não poderá ocorrer se a decisão penal houver declarado a inexistência material do fato ou que a sua autoria não pertence ao juiz.

Quando a ação rescisória é proposta quando pende o processo penal ou quando o processo penal é instaurado na pendência da ação rescisória, o juiz da ação rescisória pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal – mediante decisão transitada em julgado (art. 315, caput, CPC). Lembre-se, aliás, que o juiz também pode determinar a suspensão do processo quando ainda não proposta ação penal. Nessa última hipótese, caso a ação penal não seja proposta em três meses, contados da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz da rescisória examinar incidentemente a questão (art. 315, § 1.º, CPC). Uma vez proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano (art. 315, § 2.º, CPC).

O resultado da ação rescisória certamente não influencia a ação penal. Mas o resultado da ação penal, depois de encerrada a ação rescisória, também não é suficiente para a rescisão da decisão proferida na ação rescisória. Contudo, o que se passa no processo penal pode oportunizar a propositura de uma segunda ou inversa ação rescisória caso no processo penal i) seja evidenciada a falsidade da prova que serviu de base para a decisão proferida na ação rescisória (art. 966, VI, CPC) ou ii) seja produzida prova, cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, que evidencie a existência ou demonstre a inexistência de prevaricação, concussão ou corrupção (art. 966, VII, CPC).

7. Impedimento e incompetência absoluta. O impedimento também configura causa de rescindibilidade. Só a decisão proferida por juiz impedido é rescindível. É óbvio que a decisão proferida por juiz suspeito (art. 145, CPC) não é rescindível, uma vez que, desde o CPC/1973, não apenas se restringe a rescindibilidade ao impedimento como se diferencia claramente as hipóteses de impedimento e de suspeição.

Tendo em vista que a decisão proferida por juiz impedido é rescindível, não importa se o impedimento não foi alegado. A decisão só se torna livre do vício rescisório quando decorre o prazo (art. 975, CPC) para a propositura da ação rescisória.

O juiz impedido não pode aceitar a ação que lhe foi distribuída e, ao tornar-se impedido por circunstância ulterior à instauração do processo, deve imediatamente afastar-se. Significa que a decisão é rescindível quando, no momento em que proferida, o juiz era impedido.

No caso de julgamento colegiado, a presença de um julgador impedido é suficiente para contaminar a decisão, tornando-a rescindível. Se a decisão é de um colegiado, não há como eliminar o vício mediante a exclusão do voto de um dos julgadores, pouco importando se este não afeta o resultado do julgamento ou é vencido. Isso porque, conforme já dito quando se tratou da rescindibilidade com base em prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, uma decisão colegiada supõe a participação dos julgadores nas várias fases que conduzem à proclamação do resultado.

Ao lado do impedimento, o inc. II prevê como causa de rescindibilidade a incompetência absoluta. Sabe-se que a competência relativa se prorroga quando o réu não alega a incompetência em preliminar de contestação (art. 65, CPC), enquanto a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1.º, CPC). Porém, ainda que não tenha sido alegada ou discutida, a incompetência absoluta – e não a relativa –, conforme expressamente diz o inc II do art. 966, torna a decisão passível de rescisão.

Nos termos do art. 63, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Mas a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável pelas partes (art. 62, CPC). Caso a decisão seja proferida por juízo incompetente em razão da matéria, da pessoa ou da função, ou tenha sido tomada em um caso de incompetência pelo valor ou território excepcionalmente prevista como absoluta – por exemplo, art. 80 do Estatuto do Idoso –, ³² caberá ação rescisória sob o fundamento de que a decisão foi proferida “por juízo absolutamente incompetente”.

8. Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida e simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. A decisão é rescindível quando resulta de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. ³³ Não só a parte, mas todos aqueles que participam do processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé (arts. 5.º, 77 e 80, CPC). A parte age com dolo processual quando atua no processo mediante má-fé, ³⁴ seja para prejudicar a participação da parte adversária, seja para influenciar o convencimento do juiz.

Saber quando o comportamento da parte configura dolo processual depende do que dela se espera no processo. Quando não há preocupação com o interesse público na obtenção de uma decisão que corresponda à verdade, o problema da lealdade e da veracidade da parte assume outra dimensão no processo. Quando esses elementos deixam de constituir deveres e passam a representar critérios que interessam ao bom desenvolvimento do “jogo” entre os litigantes, a configuração dos atos e condutas que correspondem à sua infringência é feita a partir de outro ângulo visual.

Não há dúvida que subtrair documento dos autos constitui ato de má-fé, genuíno dolo processual. Há maior problema quando se pensa na possibilidade de a alegação falsa configurar dolo processual. No direito italiano entende-se que a alegação de fatos não verdadeiros não constitui causa para a rescindibilidade. ³⁵ A Corte de Cassação já decidiu que a alegação de fatos não verdadeiros assim como o silêncio sobre os fatos alegados não integram o dolo que pode fundamentar a revocazione. ³⁶ De acordo com a Cassação italiana, o dolo processual revocatório

pressupõe uma vontade especificamente dirigida ao dano ao adversário mediante o engano do juiz. O dolo processual, portanto, não pode ser concretizado mediante a simples afirmação de uma circunstância não verdadeira, mas não fraudulentamente preordenada.³⁷ Significa que a mera alegação falsa não constitui fundamento para a revocazione. A alegação falsa deve ser preordenada para fraudar ou enganar. Também dando ênfase à intenção de enganar, a Pretura de Roma já decidiu que o silêncio sobre fatos desfavoráveis incide na previsão do art. 395, 1, quando constitui artifício idôneo a paralisar ou a induzir em erro a defesa do adversário ou a obstar ao juiz o conhecimento e a declaração da verdade.³⁸

O ônus de contestar os fatos na forma específica é uma consequência do dever de veracidade. Ou melhor, o dever de contestar os fatos na forma específica é imprescindível para gravar o demandado com o dever de veracidade. Quando o demandado não tem ônus de contestar os fatos de modo específico, o seu dever de dizer a verdade pode ser facilmente encoberto pela legitimidade da sua omissão. Em outras palavras, quando não se admite o ônus de contestar na forma específica e, por consequência, não se vislumbra o conceito de “não contestação” – de que decorre a extração dos fatos não contestados como verdadeiros –, o demandado fica livre para não contestar os fatos que sabe verdadeiros.³⁹

Registre-se que no direito italiano há discussão sobre a existência de um princípio geral de não contestação.⁴⁰ Entre os que admitem este princípio, alguns afirmam que os fatos não contestados devem ser considerados provados⁴¹ e outros argumentam que, embora a não contestação não forneça ao juiz elementos de convencimento e, assim, não diga respeito ao campo probatório, ela impede que o juiz deva ou possa formar uma convicção autônoma a respeito dos fatos não contestados.⁴² Contudo, há também quem sustente que o ordenamento italiano não alberga um princípio de não contestação. Para estes, em caso de fato não contestado não se verifica uma automática relevatio ab onere probandi, embora o juiz possa retirar da não contestação argumentos de prova.⁴³ Invoca-se, em benefício desta posição, o art. 116, 2, do CPC italiano, que reza que o juiz pode extrair argumentos de prova das respostas das partes, da sua recusa injustificada em permitir as inspeções que lhe são ordenadas e, em geral, do comportamento das próprias partes no processo.

De lado o direito italiano, o § 138⁴⁴ da ZPO alemã afirma que as partes devem esclarecer as circunstâncias de fato da causa de modo completo e conforme a verdade. Diz, ainda, que cada parte deve se manifestar sobre os fatos afirmados pelo adversário e que aqueles que não forem expressamente contestados devem ser considerados admitidos se a intenção de querer contestar não resultar de outras declarações da parte.⁴⁵

No direito brasileiro, de acordo com o art. 77, I, do CPC, constitui dever “das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: i – expor os fatos em juízo conforme a verdade”. Ademais, incumbe “ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas” (art. 341, CPC).

Portanto, no direito brasileiro, à semelhança do que ocorre no direito alemão, estão presentes o dever de veracidade e o dever de o réu contestar especificamente os fatos alegados, sob pena de serem presumidos verdadeiros. No direito brasileiro, em outros termos, a alegação falsa viola o dever de veracidade (ar. 77, I, CPC) e a não contestação, por violar o dever de o réu “manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial”, faz com que as alegações não impugnadas sejam presumidas verdadeiras.

Como a não contestação de alegação de fato pode ser idoneamente sancionada no processo com a presunção de veracidade, não há como pensar que a não contestação possa configurar dolo processual para efeito de rescindibilidade da decisão. De outra parte, a alegação falsa não traz qualquer prejuízo, no processo em que é feita, à parte. É como se o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade” fosse uma simples proclamação retórica. No entanto, há também grande dificuldade em admitir que uma alegação falsa possa constituir dolo processual para efeito de ação rescisória.

Toda alegação de fato, quando posta em um processo, é uma alegação caracterizada pela dúvida. A não demonstração de uma afirmação fática obviamente não a torna uma alegação de má-fé. Porém, isso não quer dizer que a alegação falsa, para constituir dolo, tenha que ser previamente articulada para trazer específico engano ao juiz ou determinado prejuízo ao demandado. Basta que a parte saiba, antes de aportar sua alegação de fato no processo, que ela é não verdadeira. Ora, quem faz uma alegação que sabe ser falsa só pode estar tentando enganar o juiz, algo que afronta a legitimidade do processo.⁴⁶

Realizar uma afirmação que se sabia falsa, em regra, não é suficiente para uma sentença favorável, na medida em que esta, quando contestada, terá que ser provada. Mas, se a alegação falsa, ainda que a partir de prova, determinou a sentença, há razão para rescindi-la. Quando o autor faz alegação que sabia falsa e que não é negada na contestação, seria possível imaginar que a sentença se tornou legítima por ter se fundado em alegação incontroversa (art. 374, III, CPC). Sucede que a “não contestação” não pode ser vista como causa suficiente para excluir a má-fé. Quer dizer que a sentença que, com base em alegação falsa e não contestada, confere vantagem ao autor, é indiscutivelmente rescindível por dolo processual. Bem por isso, quando o autor faz alegação que sabia falsa e a sentença é proferida em face dos efeitos da revelia, também não há motivo para não admitir a ação rescisória.

Nessas hipóteses, será preciso ao autor da ação rescisória demonstrar que a decisão que se pretende rescindir está fundada em alegação falsa, compreendida como a alegação que não só pode ser demonstrada em contrário, mas também como a alegação que a parte sabia ser falsa ou que, em determinado espaço ou local em que inserida a parte, sabia-se publicamente que era falsa.

Se o réu de ação de ressarcimento alega que não é proprietário do automóvel que ocasionou os danos, daí decorrendo a improcedência do pedido, e mais tarde descobre-se que ele era o proprietário do veículo quando ocorreu o acidente, há dolo processual. Do mesmo modo, se alguém, sabendo ser pai, propõe ação de negação de paternidade e obtém sentença de procedência, ainda que mediante produção de prova, há também dolo processual e, assim, fundamento para a rescisão da decisão. Ainda que o art. 966 abra oportunidade para ação rescisória quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso (inc. VII, art. 966, CPC) e, ainda, na hipótese de a decisão ter se fundado em prova falsa (inc. VI, art. 966, CPC), isto não apenas não exclui a incidência do dolo processual como fundamento, como ainda deixa sem solução as hipóteses em que a prova foi indeferida (no primeiro caso) e em que a decisão não se fundou em prova falsa, mas em prova produzida mediante método científico equivocado (no segundo caso).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de julgar ação rescisória em que se alegou que decisão monocrática de Ministro da própria Corte estava viciada por dolo processual derivado de alegação falsa.⁴⁷ Tudo começou com decisão que declarou fraude à execução. Em agravo de instrumento, o recorrente alegou que tinha patrimônio suficiente para a garantia da execução, mas o Tribunal negou provimento ao agravo. Mediante recurso especial, voltou-se a afirmar que a alienação admitida como fraudulenta não caracterizou a insolvência e que havia imóvel com valor suficiente para garantir a execução. Não admitido o especial, foi interposto agravo que acabou sendo provido monocraticamente pelo Ministro Humberto Gomes de Barros sob o fundamento de que a alienação dita fraudulenta não tinha levado o executado à insolvência, uma vez que existia outro imóvel garantindo a execução.⁴⁸ A Segunda Seção, ao decidir a ação rescisória por votação unânime, argumentou: “Não prospera o argumento do ora requerido de que silenciar sobre o tamanho de sua dívida para com o Banco do Brasil S/A configura mera omissão relativa a uma circunstância que lhe era desfavorável, o que não configura dolo processual. É que a decisão rescindenda não decorreu de uma mera omissão de sua parte, mas sim de sua afirmação reiterada nos autos de que a alienação do bem não o reduzira à insolvência, posto que o imóvel remanescente seria suficiente para garantir o gravame que sobre ele pesava e o débito exequendo. Ao assim proceder, alterou, deliberadamente, a verdade dos fatos, conduta esta que encontra expressa reprimenda no inc. II, do art. 17, do CPC”.⁴⁹ Advertiu a Corte Suprema que “a lei exige que a parte não engane o juiz. Essa é a conduta que se espera daquele que postula em juízo, compatível com a dignidade do processo civil”.⁵⁰

Note-se que sequer foi necessário perguntar se o réu da ação rescisória sabia da falsidade da alegação. O conhecimento prévio da falsidade estava implícito na alegação de que havia patrimônio suficiente para descaracterizar a insolvência. A Segunda Seção, ao tratar da relação de causalidade entre o dolo e a decisão, observou que “a decisão rescindenda fundamentou-se, justa e exclusivamente, na ausência de insolvência do devedor decorrente da alienação impugnada, fato que, posteriormente, se comprovou falso, implicando a frustração da ação executiva”.⁵¹

Se as partes realizam acordo logo depois da citação, restando ao autor a obrigação de protocolar a petição em que se requer a extinção do processo, a omissão dolosa do autor e a prolação de sentença que lhe é favorável tornam-na rescindível. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu caso similar – em que o autor omitiu-se –, rescindindo sentença de procedência proferida em processo em que o réu não apresentou contestação e sofreu os efeitos da revelia, sob o exposto argumento de que o demandado “foi induzido a quedar-se inerte”.⁵² O exemplo demonstra que não apenas o ato comissivo, mas também o omissivo, pode configurar dolo processual capaz de viabilizar a propositura de ação rescisória.

Também é possível pensar na situação em que o autor escondeu a documentação sobre a qual a prova deveria ter sido produzida. Não é apenas a subtração de prova dos autos que constitui dolo. Esconder documentos sobre os quais a prova deveria e poderia ter sido produzida igualmente caracteriza dolo processual, não obstante também se possa aí pensar em prova de que não se “pôde fazer uso” e, assim, em ação rescisória baseada no inc. VII do art. 966.

É preciso que o prejuízo acarretado à parte diretamente repercuta sobre a decisão ou que a atuação de má-fé sobre o juiz a determine. Em outras palavras, deve haver nexo de causalidade entre o comportamento da parte e a decisão.⁵³ Quando o vencedor atua diretamente sobre o convencimento do juiz, por exemplo, mediante alegação falsa, torna-se fácil estabelecer ligação entre a conduta de má-fé e a sentença. Nesse caso, quando a sentença não depende da alegação falsa realizada pelo vencedor, não há relação entre a conduta dolosa e a decisão, de modo que não há razão para a sua rescisão.

Porém, quando a parte atua dolosamente de modo a prejudicar o seu adversário, como no caso em que esconde a base para a produção da prova ou em que, de má-fé, cria situação para provocar a omissão da parte contrária, nem sempre é possível estabelecer clara relação de causa e efeito entre o prejuízo à parte e a decisão. No exemplo em que o juiz julga procedente o pedido em razão dos efeitos da revelia, não há dúvida que a decisão decorre do prejuízo acarretado à parte. Porém, quando a parte esconde a documentação sobre a qual a prova deveria ter sido realizada, importa apenas saber se, caso a prova houvesse sido produzida, teria esclarecido fatos que poderiam permitir outra resolução ao litígio. O resultado e a valoração da prova não importam. Interessa somente se os fatos que deixaram de ser demonstrados – mediante a prova que não pôde ser produzida e valorada – poderiam ter proporcionado decisão diversa.⁵⁴

O dolo processual pode ser cometido por qualquer um dos litisconsortes vitoriosos, não importando a sua qualidade. Na verdade, basta que o comportamento de má-fé de um dos litisconsortes, ou mesmo de um terceiro, prejudique a parte adversa, causando-lhe decisão desfavorável, ou interfira sobre o convencimento do juiz, para que esteja configurado o dolo processual e, assim, abra-se oportunidade para ação rescisória.

Enquanto o CPC/1973 falava apenas em dolo (art. 485, III), o CPC/2015 alude a dolo ou coação da parte vencedora (art. 966, III). Nos termos do Código Civil, a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incute ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens (art. 151, CC). Contudo, a coação referida pelo inc. III é a coação processual, que interferiu sobre a vontade da parte adversária ou sobre a vontade do juiz.

Não há como elaborar a coação processual a partir dos conceitos de direito civil. No plano do direito material as partes constroem vínculos jurídicos com uma finalidade comum. O adimplemento, fim do processo obrigacional, domina toda a sua estruturação. Os interesses são convergentes. A princípio não há qualquer crise que afaste as partes da finalidade comum no plano do direito material. No processo ocorre o oposto. Enquanto no plano do direito material as

partes convergem para o mesmo fim, no processo há uma crise na realização do direito material, de modo que os interesses das partes, que antes eram convergentes, transformam-se em divergentes. Além disso, no processo, e especialmente quando se considera a decisão, sobreleva o interesse público, e não o interesse privado das partes. Quer dizer que a coação no processo deve ser visualizada a partir da dinâmica da divergência entre os interesses das partes em face do Estado-Juiz, especialmente do interesse público na distribuição de decisões acordes com o direito e com a verdade.

No plano do direito material, a sanção correspondente à coação da vontade de uma das partes não afeta a validade do negócio jurídico quando esta é produzida por terceiro sem o conhecimento da parte a que aproveita. Lembre-se que, nos termos do Código Civil, “vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveita, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos” (art. 154, CC), porém “subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveita dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto” (art. 155, CC).

Se no plano do direito material importa conservar o negócio jurídico e é possível separar as sanções dos atos praticados pela parte e pelo terceiro, no processo as coisas se passam de forma diferente. No plano do direito material a vontade viciada é da outra parte, ao passo que no processo a vontade está na decisão. Não há razão nem lógica para conservar uma decisão judicial derivada de coação processual, apenas por ter sido produzida por um terceiro, por exemplo o sublocatário que intervém na qualidade de assistente simples do locatário na ação de despejo. Esse terceiro pode ser visto como “vencedor” em face dos termos do inc III do art. 966.

Na dimensão do direito material, há motivo em preservar o negócio jurídico a partir da premissa de que seria do interesse das partes, sancionando-se o terceiro mediante perdas e danos; no processo, as partes sempre têm interesses em decisões com sinais invertidos, de modo que preservar uma decisão pelo fato de a coação ter sido produzida por assistente simples significa preservar a decisão que desde o início foi do interesse de apenas uma das partes, exatamente a que se beneficiou pela coação. Ou seja, preservar a decisão faz surgir resultado absurdo quando utilizada a lógica de direito material. Além de a decisão nunca ser do interesse de ambas as partes e, na verdade, favorecer a parte que desde o início a objetivou, deste modo se ignora totalmente o interesse público em ver eliminadas do mundo jurídico as decisões viciadas, violadoras dos valores que devem presidir o processo civil.

Aliás, não deveria ser necessário que a coação fosse praticada pela própria parte ou por um terceiro que participou do processo. Também deveria bastar a coação praticada por um estranho ao processo, com ou sem o consentimento da parte vencedora. Uma decisão proferida sob coação não deve valer, pouco importando quem produziu a ameaça. Assim, por exemplo, a coação praticada sobre um juiz por um terceiro também juiz obviamente faz surgir decisão que não deve prevalecer em detrimento do vencido.

Também não há que se medir a intensidade da coação processual nos termos em que ocorre no plano do direito material para se determinar a coação capaz de tornar o ato jurídico anulável. Sublinhe-se que, de acordo com o art. 151, caput, do CC, a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens. Adverte o art. 152 que, “no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela”.

Se não há racionalidade em admitir que o partícipe de um negócio jurídico alegue qualquer motivo ou um motivo frágil – sob as vestes de coação – para obter a sua anulação, quem sofre com decisão judicial proferida por juiz coagido está em situação diversa. Não é preciso demonstrar que o juiz sofreu ameaça com a conotação “X” para se pleitear a rescisão da sua decisão; basta que se demonstre que o juiz proferiu a decisão sob coação. A ação rescisória, além de tutelar a parte em vista de uma decisão estatal, tutela o interesse público na legitimidade e na autoridade das decisões judiciais. Deixar intactas decisões proferidas sob ameaça não só afeta a confiança no

poder estatal e gera o descrédito da população nos juízes, como mantém corrompido o sistema de distribuição de justiça. A rescisória também é um instrumento para resgatar a legitimidade do exercício do poder, pressuposto para que as decisões tenham autoridade e sejam respeitadas pela população e pelos próprios juízes.

Assim, basta que se demonstre que o juiz proferiu a decisão em razão de coação, não sendo necessário evidenciar que o juiz efetivamente tinha motivo para se sentir ameaçado. Quando não se alega coação no interesse da anulação de um negócio privado, mas para rescindir decisão, não há motivo para exigir ameaça com determinada intensidade para não se violar a liberdade da parte contrária.

Tendo o juiz proferido a decisão em razão da ameaça, isso é o bastante para tornar a decisão viciada e passível de rescisão. A qualidade da coação só interessa quando não se pode demonstrar que a decisão foi proferida em razão de ameaça, mas apenas que o juiz foi ameaçado e, portanto, deve ter proferido a sua decisão em virtude de pressão psicológica. Nesse caso, há de se demonstrar que o juiz estava sob uma ameaça séria e considerável, capaz de intimidar e pressionar qualquer juiz a proferir uma decisão viciada. A existência de prova de ameaça com tal qualidade para a tomada da específica decisão, ao lado da decisão favorável à parte que exerceu a coação, é suficiente para a rescisão da decisão.

Deixe-se claro que também é rescindível a decisão que resulta de coação produzida sobre a parte vencida. Note-se, aliás, que o inc. III fala em coação “em detrimento da parte vencida”. É óbvio que a coação exercida sobre o juiz para a prolação de decisão constitui coação “em detrimento da parte vencida”. Porém, é possível que a coação seja exercida sobre a própria parte, provocando, por exemplo, a não produção de uma prova. É claro que nessa hipótese a coação não tem relação direta com o conteúdo da decisão, mas apenas com a prova que poderia ter sido produzida. Como já dito quando se tratou do dolo processual, ao se obstaculizar a produção de prova interessa apenas saber se esta teria esclarecido fatos que poderiam alterar a decisão. Ou seja, não pode importar o resultado e a valoração da prova, mas somente constatar se os fatos que não puderam ser demonstrados poderiam ter acarretado outra decisão.

Afirma o art. 142 do CPC que, uma vez convencido “de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé”. O inc. III do art. 966, ao contrário do inc. III do art. 485, que aludia apenas à “colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei”,⁵⁵ fala de “simulação ou colusão entre as partes ...”.

Desejou-se acrescentar o processo simulado, ao lado do fraudulento, enquanto fundamento para a rescisão da decisão. A colusão entre as partes é essencial tanto no processo fraudulento quanto no simulado. A diferença não está entre colusão e simulação, mas entre processo fraudulento e processo simulado. Há simulação quando as partes vão a juízo e apresentam um litígio aparente, que não existe, a fim de conferir ou transmitir direitos simuladamente; age com fraude à lei quem frustra a aplicação da lei e, assim, afasta a sua incidência ou obtém aquilo que ela proíbe.

De modo que a outra novidade do inc. III do art. 966 – a simulação – constitui fundamento para a rescisão quando a sentença reconhece como existente situação simulada por ambas as partes para a obtenção de algo previamente acertado entre elas. As duas partes ajustam-se previamente e, então, simulam um litígio, dando origem e desenvolvimento a processo para que se declare existente situação que nunca existiu. O exemplo clássico é o da reclamação trabalhista em que se simula uma relação de trabalho para se obter a condenação do demandado a pagar alta soma em dinheiro, abrindo-se oportunidade para a satisfação do crédito mediante a expropriação dos bens do suposto “empregador” em fraude aos credores verdadeiros.

9. Ofensa à coisa julgada

9.1. Os limites objetivos da coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015. A coisa julgada material constitui projeção do princípio da segurança jurídica e, nessa linha, a tutela à

coisa julgada deve ser compreendida como uma decorrência do próprio princípio do Estado de Direito – Rechtsstaatsprinzip.⁵⁶ A ofensa à coisa julgada significa, em outras palavras, violação à segurança jurídica e à cláusula do Estado de Direito, representando negação da permanência, da previsibilidade e do império do Direito.

A definição da porção da decisão que se torna imutável e indiscutível é algo que pode variar, conforme a intenção do legislador. Se é certo que a coisa julgada é garantida pela Constituição (art. 5.º, XXXVI, CF), isso não significa que os limites da coisa julgada não devam ser definidos pela lei.⁵⁷

Embora o collateral estoppel – de que se aproxima a coisa julgada sobre questão – seja algo típico do common law, tendo surgido na Inglaterra a partir do estoppel by record⁵⁸ e depois se desenvolvido até atingir a forma de non-mutual collateral estoppel,⁵⁹ possibilitando a terceiro – beneficiado pela decisão – invocar a proibição da relitigação da questão já decidida,⁶⁰ não há como esquecer que no âmbito do civil law o problema da relação das questões prejudiciais com a coisa julgada também sempre constituiu uma questão teórica.

Sabe-se que os §§ 280⁶¹ e 322⁶² da ZPO alemã têm origem na doutrina e na jurisprudência francesa do século XIX. A dogmática alemã é o ponto de partida da doutrina italiana que influenciou a elaboração do art. 34 do Codice di Procedura Civile. Trata-se da doutrina marcada pelas obras geniais e consagradas de Menestrina⁶³ e de Chiovenda,⁶⁴ que em síntese deixaram claro que o ponto que constitui antecedente lógico e necessário da solução do litígio, quando controvertido pelas partes, não pode deixar de ser decidido pelo juiz, porém não tem razão para ficar revestido pela autoridade da coisa julgada. Desde logo, esta tradicional doutrina, nas águas dos §§ 280 e 322 da ZPO alemã, propôs que a lei e a parte poderiam obrigar o juiz a decidir a questão prejudicial como se estivesse diante de uma demanda autônoma.⁶⁵

Dá surge o art. 34 do código italiano de 1940, base do Código de Processo Civil de 1973. Segundo o art. 34 do Codice di Procedura Civile, se o juiz, em virtude de lei ou por explícito pedido de uma das partes, tem que decidir com eficácia de coisa julgada uma questão prejudicial que pertence em razão da matéria ou do valor à competência de um juiz superior, deve enviar toda a causa a este último, definindo às partes um termo peremptório para a readmissão da causa diante dele. O que importa, no art. 34, é que a coisa julgada sobre questão prejudicial depende de lei ou de explícito pedido de uma das partes. Isso demonstra que a decisão de questão prejudicial, fora as exceções referidas, não produz coisa julgada.

O Código de Processo Civil de 1973, para resolver o problema que estava à base do art. 287, parágrafo único, do código de 1939, que afirmava que “considerar-se-ão decididas todas as questões que constituam premissa necessária da conclusão”, valeu-se de duas normas claramente elaboradas nos moldes dos §§ 280 e 322 da ZPO alemã e do art. 34 do Codice di Procedura Civile. Disse em primeiro lugar o art. 469: “Não fazem coisa julgada: i – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; ii – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; iii – a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo. Depois o art. 470: “Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5.º e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide”. Significa claramente que a coisa julgada, de lado o exposto requerimento da parte em relação à questão prejudicial, restou restrita ao comando da decisão ou à sua parte dispositiva.

O regime da coisa julgada restrita ao dispositivo da decisão gerou inúmeros problemas não apenas no direito brasileiro. No direito italiano, por exemplo, doutrina do maior relevo foi obrigada a se servir do direito comparado, especialmente do direito inglês e do direito estadunidense, para admitir que a decisão de questão prejudicial, quando presentes determinados pressupostos, produz coisa julgada. Além dos importantes trabalhos de Denti,⁶⁶ Taruffo⁶⁷ e mais recentemente Volpino,⁶⁸ o consagrado verbete de Giovanni Pugliese, presente na Enciclopedia del Diritto, também reconheceu a necessidade de se buscar inspiração no common law para interpretar o art. 34 do Codice di Procedura Civile.⁶⁹

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 503, preferiu apostar na experiência estadunidense, definindo que a decisão de questão prejudicial faz coisa julgada desde que presentes determinados pressupostos, basicamente os mesmos que são reclamados pela doutrina e pelas cortes dos Estados Unidos para a admissão do collateral estoppel, figura que impede a parte de voltar a litigar uma questão que já foi plenamente discutida e expressamente decidida por um juiz competente.

Portanto, atualmente a coisa julgada não é mais restrita à parte dispositiva da decisão. Em razão do art. 503 do CPC, a coisa julgada, além de recair sobre a decisão do pedido, grava a decisão das questões prejudiciais, desde que não ausentes os requisitos para tanto – presentes nos §§ 1.º e 2.º do art. 503.

De modo que a grande novidade, em termos de ofensa à coisa julgada, está na extensão dos seus limites às questões prejudiciais. Porém, antes de se ingressar especificamente no estudo da ofensa à coisa julgada sobre questões, é importante tratar de graves problemas teóricos que também marcam a ofensa à coisa julgada que grava o comando da decisão.

9.2. Ofensa à coisa julgada mediante solução de questão de que depende o julgamento de demanda distinta. O juiz está impedido de rejulgar pedido baseado em mesma causa de pedir entre as mesmas partes. Estão aí presentes os três elementos que identificam a ação. A repetição desses elementos faz ver a repetição da mesma ação e, portanto, a óbvia proibição de as partes relitigarem e de o juiz voltar a decidir. Costuma-se dizer que, quando se repete a mesma ação, o efeito negativo da coisa julgada obsta que o juiz decida.

É claro que, quando em face das mesmas partes e da mesma causa de pedir há pedido menos extenso ou contido no pedido já julgado, a coisa julgada igualmente proíbe a rediscussão e o re julgamento do pedido. Assim, por exemplo, se o autor pede que o réu, em virtude de um contrato de compra e venda, seja condenado a pagar três prestações, a rejeição integral do pedido obviamente não permite que se peça posteriormente o pagamento de duas prestações, muito menos que o juiz decida a respeito.

Contudo, a verdade é que ofensa à coisa julgada em virtude da repetição da mesma ação é algo raro. Muito mais comum é decidir, em ação diferente, com ofensa à coisa julgada. Recorde-se que uma questão de direito que pode ser decidida incidentemente enquanto “questão prejudicial” também pode ser decidida, em alguns casos, como pedido em ação autônoma. Assim, por exemplo, quando se resolve o pedido na ação de investigação de paternidade. Porém, se a ação de investigação de paternidade é julgada improcedente, a ação de alimentos, em que o autor afirma ser filho do também réu da ação de investigação de paternidade, não permite que o juiz julgue procedente o pedido de alimentos com base na suposição de que o réu é filho. Se isso ocorrer haverá violação da coisa julgada derivada da ação de investigação de paternidade.

Na ação em que se postula a declaração da validade da alienação de bem social não pode ser proferida sentença de procedência se, em virtude de outra ação, já foi proferida sentença invalidando a autorização assemblear para a venda. Julgar procedente o pedido, admitindo-se a validade da autorização assemblear, constitui óbvia ofensa à coisa julgada.

Stefano Villata, após realizar ampla resenha do direito alemão em excelente monografia dedicada ao tema dos limites da coisa julgada nas ações de impugnação de deliberações assembleares, observa que a coisa julgada formada sobre a sentença de procedência contém um julgamento típico de uma situação jurídica capaz de projetar-se sobre a atividade posterior da sociedade e sobre eventuais juízos que sobre semelhante atividade sejam necessários.⁷⁰

Raffaele Tommasini afirma que o fenômeno deve ser trabalhado a partir da teoria da base do negócio jurídico. No seu raciocínio, se determinado negócio funda-se em autorização previamente dada, e essa autorização é declarada inválida, o que existe aí não é propriamente uma invalidade derivada, mas uma nulidade oriunda da ausência de base para o negócio – isto é, por força da ausência de um requisito intrínseco de validade do ato subsequente. De acordo com o civilista italiano, o ato de autorização representa um requisito de validade do ato autorizado: um vício no

primeiro torna inválido igualmente o segundo, mas não por derivação, e sim por ausência de um de seus requisitos intrínsecos.⁷¹

Significa que a invalidade decorre da coisa julgada na medida em que essa priva de base o negócio posterior. É fácil percebê-lo: sendo um negócio composto, a compra e venda de bem social depende da prévia existência de autorização assemblear válida. Como a coisa julgada refere que a autorização assemblear é nula, o negócio subsequente que nela se funda só pode ser igualmente nulo. É nesse sentido que se fala em eficácia expansiva da coisa julgada para as situações em que as deliberações sociais são ligadas de forma tão estreita com determinados atos posteriores que o provimento que declara a nulidade de uma leva à nulidade dos atos a ela condicionados. E isso sem que seja necessária qualquer declaração autônoma a respeito do ato posterior ou qualquer juízo autônomo de impugnação. Como esclarece Villata, existem deliberações tão estreitamente ligadas que a declaração de nulidade de uma delas comporta a nulidade da outra, sem necessidade de um julgamento autônomo ou de uma ação autônoma de impugnação. Assim ocorre diante da relação intercorrente entre a deliberação de aprovação de um balanço e a conexa deliberação de destinação e distribuição dos lucros: se a primeira é declarada nula por falsidade do balanço, a segunda torna-se privada de seu objeto.⁷²

É uma consequência simplesmente lógica da coisa julgada a falta de base do negócio posterior. Como parece intuitivo, seria muitíssimo estranho que se considerasse nula a assembleia que autorizou a venda de determinado bem e válida a venda realizada com base na autorização assemblear. Ou ambas são válidas ou ambas são inválidas. *Tertium non datur*. E isso porque um juízo posterior jamais poderia decidir pela validade da autorização sem ofensa direta e inequívoca à coisa julgada.

Porém, não importa, para efeito de ação rescisória, se a coisa julgada relativa à ação de invalidação de assembleia tem eficácia expansiva, de modo a invalidar a alienação praticada. O que realmente interessa é que o juiz da ação em que se pede a declaração da validade da alienação não pode julgar procedente o pedido, admitindo a autorização assemblear, se esta já foi invalidada mediante sentença transitada em julgado.

Lembre-se que no direito italiano a revocazione ordinaria, baseada no art. 395, 5⁷³ do Codice di Procedura Civile, é admitida de forma pacífica não apenas quando o objeto dos dois processos é o mesmo, mas também nas hipóteses da assim chamada “*efficacia riflessa del giudicato*”, quando o objeto do segundo processo é um direito juridicamente dependente do direito sobre o qual se formou a primeira coisa julgada.⁷⁴

Na verdade, é mais claro dizer que há ofensa à coisa julgada quando a decisão desconsidera a coisa julgada formada sobre um pressuposto de que dependia a afirmação ou a negação do direito na segunda ação, ou, em outras palavras, que há ofensa à coisa julgada quando o juiz nega a função positiva da coisa julgada.⁷⁵

Lembre-se, por fim, que a situação inversa, ou seja, a de decisão sobre a questão enquanto prejudicial, não vinculava a decisão sobre a mesma questão em outro processo perante o Código de Processo Civil de 1973. Antes do CPC/2015, como a decisão sobre questão prejudicial só fazia coisa julgada em caso de ação declaratória incidental, não existia coisa julgada sobre a questão prejudicial no comum dos casos. De modo que, se na ação de alimentos o juiz reconhecesse a paternidade para julgar procedente o pedido de alimentos, isso não afetaria a decisão que mais tarde tivesse que ser proferida em ação de investigação de paternidade nem a ação de cobrança em que, depois da morte do suposto pai, aquele que se diz filho ingressasse na qualidade de herdeiro contra terceiro.

No primeiro caso o juiz poderia voltar a decidir sobre a questão da paternidade, inclusive no sentido inverso, negando-a. No segundo, o terceiro simplesmente poderia alegar que o autor não é herdeiro do crédito e, na verdade, o autor nada poderia fazer para obter sentença de procedência.

No atual sistema, o reconhecimento da paternidade na ação de alimentos, desde que presentes os pressupostos formais do art. 503 do CPC, faz coisa julgada, impedindo nova decisão sobre a

questão já decidida. Do mesmo modo, a decisão de reconhecimento da paternidade na ação de alimentos, muito embora nada tenha a ver com coisa julgada diante de terceiro⁷⁶ – até porque não há coisa julgada em face de terceiro que não participou do processo, conforme se verá mais à frente –, poderia ser utilizada como base para o pedido de cobrança do crédito. Bem vistas as coisas, o juiz não poderia negar a qualidade de herdeiro do autor não apenas em virtude da coisa julgada emanada da decisão proferida na ação de alimentos, mas em razão desta decisão ter constituído a situação de filho para o autor.

9.3. Ofensa à coisa julgada por meio de violação ao princípio do deduzido e do dedutível. É importante relacionar o dispositivo e a decisão da questão prejudicial com os seus conteúdos. O dispositivo concede ou nega uma tutela de direito material, ao passo que a decisão de questão prejudicial resolve questões de direito relacionadas aos fatos constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo, que podem ou não ser objeto de ação autônoma.

Nessa perspectiva, a essência da coisa julgada que marca o dispositivo consiste basicamente em não admitir que um juiz, num processo posterior, possa desconhecer ou limitar a tutela jurisdicional do direito ou mesmo negar a tutela jurisdicional que declarou a inexistência do direito.

Isso significa que, num segundo processo, todas as alegações que foram feitas ou poderiam ter sido feitas no primeiro processo ficam obstadas quando capazes de permitir o desconhecimento ou a limitação da tutela do direito ou a negação da tutela jurisdicional que declarou a sua inexistência.⁷⁷

Trata-se, em outras palavras, de uma adaptação da célebre proposta chiovendiana de não permitir que alegações, que foram ou poderiam ter sido feitas no primeiro processo, possam ser invocadas em outro processo para se obter “il riconoscimento del bene negato o il disconoscimento del bene riconosciuto”.⁷⁸

A ideia de Chiovenda é tomada por Proto Pisani para lembrar que a coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível. Afirma Proto Pisani que o princípio do deduzido e do dedutível, quando corretamente compreendido, não influi de modo a restringir ou ampliar os limites objetivos da coisa julgada. Uma vez definidos estes limites, o princípio do deduzido e do dedutível se apresenta apenas para dizer que o resultado da primeira demanda não poderá ser novamente colocado em discussão, muito menos diminuído ou desconhecido mediante a dedução de questões relevantes para a decisão proferida no primeiro processo, e que nele foram ou poderiam ter sido propostas.⁷⁹

Porém, se a coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível relacionado com o resultado acerca da tutela jurisdicional pleiteada, mais difícil é saber em que termos o princípio se relaciona com a coisa julgada sobre questão. O art. 508 do CPC consagra o princípio do deduzido e do dedutível no direito brasileiro. De acordo com esse artigo, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A regra que faz precluir o dedutível não é indissociável da coisa julgada material. Essa tem autonomia diante da sua eficácia preclusiva. Aliás, só assim se poderia perguntar se a coisa julgada sobre questão abarca o deduzido e o dedutível.

O art. 503 do CPC, na linha do que ocorre no direito estadunidense, limitou os efeitos preclusivos da coisa julgada sobre questão. Não há coisa julgada sobre questão, de acordo com o art. 503, quando não “tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia” (art. 503, § 1.º, II, CPC) e quando a decisão tiver sido proferida em processo em que “houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial” (art. 503, § 2.º, CPC).

O collateral estoppel também depende de a questão ter sido adequadamente discutida.⁸⁰ A propósito, uma das distinções mais salientes entre res judicata e collateral estoppel nos Estados Unidos é a de que, diante da primeira, há preclusão de todas as alegações de fato e de direito que a parte poderia ter deduzido, enquanto que o segundo depende de a questão ter sido debatida e

decidida no processo.⁸¹

A limitação dos efeitos preclusivos do collateral estoppel encontra fundamento nas razões da imprevisibilidade da parte quando da discussão da questão. Advertem as Cortes, por exemplo, que a parte pode não discutir em toda a sua extensão determinada questão por considerar que a demanda tem valor econômico incompatível com o custo para tanto, o que não justificaria o seu sacrifício numa demanda futura dotada de relevância.⁸²

Bem, ainda que a coisa julgada sobre questão esteja limitada pela impossibilidade da sua adequada discussão (art. 503, § 1.º, II, e § 2.º, CPC), isso não quer dizer que, no direito brasileiro, as alegações que poderiam ter sido deduzidas em prol da solução da questão possam ser reavivadas para a sua rediscussão. Na verdade, isso só é possível quando se está diante de coisa julgada contra terceiro que, no incidente de resolução de demandas repetitivas, é representado por legitimado à tutela de direitos individuais homogêneos (ver, a respeito, os comentários ao art. 976 e ss.)

Frise-se que a coisa julgada erga omnes que marca a decisão do incidente de resolução de demandas repetitivas, ao contrário do que ocorre na ação coletiva do art. 103, III, do CDC, é pro et contra e, assim, pode beneficiar ou prejudicar os litigantes excluídos. No entanto, os arts. 985 e 986 do CPC admitem o que é designado de “revisão” da decisão do incidente para os casos futuros, ou seja, para os casos que não estavam pendentes. Tal “revisão” de decisão obviamente significa uma redecisão. Porém, certamente uma redecisão que não viole a coisa julgada material e, portanto, uma redecisão que não seja uma mera rediscussão. Ora, só um outro fundamento, não deduzido e não discutido no primeiro processo, pode deixar de levar a uma rediscussão da matéria que serve para a prolação da decisão. A discussão de fundamento que poderia ter sido discutido, em outras palavras, não obstante se choque com o princípio do dedutível, não viola a coisa julgada. Trata-se de uma opção legítima em face de uma decisão proferida em incidente que exclui a participação direta dos litigantes. Por consequência, a decisão tomada em virtude do novo fundamento conduz a outra decisão e a outra coisa julgada.

O princípio que cobre o dedutível realmente não se aplica à coisa julgada sobre questão contrária aos excluídos, resultante do incidente de resolução de demandas repetitivas. Se a parte que não discute a questão de forma adequada não fica sujeita à coisa julgada sobre questão, nos termos do art. 503, o litigante excluído cujo representante não discutiu determinado fundamento no incidente de resolução de demandas repetitivas não pode ser proibido de invocar outro fundamento para discutir a questão de direito. Note-se que, se no processo individual evita-se prejudicar quem não teve oportunidade de efetivamente discutir a questão, no incidente de resolução de demandas – em que se exclui os litigantes da participação direta – não há como supor que o representante adequado não quis discutir o fundamento e, assim, eliminar a possibilidade de rediscussão da questão com base em fundamento não deduzido. O que importa, em outras palavras, é que a ficção de que a parte abriu mão da discussão do fundamento ao não alegá-lo não vale no incidente. Afinal, a participação adequada do representante é indispensável para a preservação de direitos fundamentais processuais.

Nessas condições, qualquer legitimado à tutela dos direitos individuais homogêneos que não tenha participado do incidente de resolução pode invocar fundamento não discutido e não decidido para rediscutir a decisão em face dos casos futuros. Ademais, os titulares de pretensão à tutela de direito que depende da resolução da mesma questão de direito não ficam proibidos de invocar o fundamento não discutido e decidido ao proporem suas ações.

9.4. Prestações bilaterais e infringência da coisa julgada sobre o contrato. Um dos grandes problemas da coisa julgada material, de certa forma relacionado com a não atribuição de coisa julgada às questões, está presente diante das relações jurídicas complexas e da sua discussão fragmentada mediante ações autônomas. Nesses casos discute-se uma parte ou um efeito do todo ou de uma relação jurídica. A prejudicialidade entre a parte e o todo constitui uma prejudicialidade interna à relação jurídica, distinguindo-se daquela característica à hipótese em que dois direitos estão em relação de conexão por prejudicialidade.

Diante das várias situações concretas que poderiam ser lembradas, é interessante destacar, em virtude não só da sua importância prática, mas também da sua fácil assimilação teórica diante do problema ora enfrentado, o caso do contrato bilateral ou sinalagmático, em que estão previstas prestações para ambas as partes.

Tome-se em conta o exemplo do contrato de compra e venda. Uma vez julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento da prestação pecuniária devida ao vendedor, seria possível imaginar – não apenas no sistema em que não há coisa julgada sobre questão – que diante de posterior ação voltada à obtenção da coisa o juiz poderia julgar o pedido improcedente sob o argumento de que o contrato é inválido ou inexistente.

De modo que o problema é exatamente o de se saber se a coisa julgada se forma apenas sobre a prestação pedida ou alcança a base contratual sobre a qual a prestação se funda, ou, em outras palavras, se a coisa julgada abrange a relação jurídica em que situa a prestação exigida. Considerando o objeto do processo, as soluções aventadas pela doutrina foram as seguintes: i) por ser determinado apenas a partir da demanda do autor, o objeto do processo deve limitar-se ao pedido relativo à prestação exigida; ii) o objeto do processo estende-se à relação jurídica em que inserida a prestação exigida, independentemente da contestação do réu e, assim, de ter surgido controvérsia sobre o contrato em que a prestação se funda; e iii) o objeto do processo é determinado pela demanda e pela defesa, de modo que se o réu contestar a existência ou a validade do contrato em que se funda a exigência da prestação, o objeto do processo abarácará a relação jurídica em que baseado o pedido de adimplemento da prestação.⁸³ É interessante perceber que a solução i) tem base na doutrina chiovendiana; a solução ii) sempre foi aquela admitida pelos tribunais italianos e a solução iii) foi a sustentada por Mortara,⁸⁴ reconhecido como o primeiro doutrinador italiano a sustentar teoricamente o enquadramento do processo no âmbito do direito público.⁸⁵

Recentemente, reconhecendo a diversidade dos entendimentos doutrinários e, sobretudo, a gravidade do problema em termos práticos e sistemáticos, Proto Pisani concluiu que a tese de que a coisa julgada é limitada pelo pedido ao pagamento da prestação é “francamente inammissibile”, sob pena da “distruzione del valore del giudicato” e da “disarticolazione tramite il processo di una realtà sostanziale indissolubilmente unitaria”.⁸⁶

Note-se que a solução de Proto Pisani, ao contrário das demais soluções dadas ao problema teórico, enfatiza o problema de se ter, diante da limitação do objeto do processo e, por consequência, da restrição da coisa julgada aos efeitos ou a uma parte (à prestação) da relação jurídica, a quebra de uma realidade de direito material que não comporta fragmentação.⁸⁷ Esse ponto tem especial relevo, na medida em que agrega uma complicação acessória, a de que basta pensar em coisa julgada sobre questão para eliminar o problema da contradição entre coisas julgadas relativas a prestações fundadas em um contrato.

Diante do art. 503 do CPC, para se concluir pela coisa julgada sobre a relação jurídica em que se baseia o pedido de adimplemento da prestação é necessário admitir que a questão prejudicial de que depende o julgamento do mérito está longe de ser a questão prejudicial “clássica”, ou melhor, aquela em que dois direitos distintos estão em relação de conexão por prejudicialidade – por exemplo, herdeiro e credor, proprietário da coisa e responsável etc. A questão relativa ao contrato, embora possa não ser uma prejudicial em sentido técnico tradicional, certamente pode constituir uma questão prejudicial ao julgamento do pedido de adimplemento das prestações. Aliás, quando se pensa na razão de ser da coisa julgada sobre questão, não há razão para restringir o conceito de questão prejudicial nem sequer para limitá-lo – desde logo deixe-se claro – com base em razões dogmáticas de outras épocas ou mesmo relacionadas com a possibilidade de discussão da questão mediante ação declaratória incidental.

Contudo, não há como escapar da regra de que, quando uma questão não é adequadamente discutida e expressamente decidida (art. 503, § 1.º, II, CPC), não há como pensar em coisa julgada. Sucede que nem sempre a ação em que se pede o pagamento de prestação será contestada ou especificamente contestada em relação à existência ou à validade do contrato. Ora, uma vez proposta ação de adimplemento de prestação pecuniária derivada de contrato de compra e venda

– por exemplo –, pode haver revelia, proferindo-se sentença de condenação ao pagamento das prestações sem qualquer alusão ao contrato. Também pode acontecer de o réu contestar a demanda apenas para negar o inadimplemento da prestação, quando, reconhecendo-se ou não o inadimplemento, obviamente nada terá sido discutido e decidido a respeito do contrato. Nesse caso, em verdade, o réu admite a validade do contrato.

É certo que o sistema que admite coisa julgada sobre questão, na hipótese em que se forma controvérsia sobre o contrato e, assim, surge questão de que depende o julgamento do pedido de adimplemento de prestação, elimina o problema da contradição entre julgados e evita a negação do valor da coisa julgada material, na medida em que, diante da posterior ação proposta pelo comprador para a obtenção do bem, o juiz não poderá julgar o pedido sem considerar a coisa julgada – sobre o contrato – que se formou na ação em que o vendedor pediu o pagamento da prestação pecuniária.

Porém, não há como deixar de ver que, mesmos nos casos em que há revelia ou não contestação do contrato, há grave contradição em condenar ao pagamento da prestação devida pelo comprador e, posteriormente, obstar a realização da sua prestação. Esta contradição, se não pode ser eliminada aludindo-se a coisa julgada sobre questão, pode ser evitada mediante a compreensão de que o processo não pode distorcer ou tratar de modo disforme uma realidade de direito material, no caso uma relação jurídica complexa e unitária. É claro que aí não importa saber se o objeto do processo pode ser configurado com base apenas na demanda do autor ou também com suporte na defesa do demandado. Interessa apenas que à base do pedido do autor há uma relação jurídica – de que decorre prestações bilaterais, ao autor e ao réu – que não pode ser tratada de forma fragmentada ou partilhada, sob pena não somente de cisão da discussão e da decisão da relação jurídica, mas especialmente do seu tratamento descontraído e divorciado da sua realidade substancial unitária.

Assim, o pedido do vendedor ao pagamento da prestação pecuniária, por estar fundado no contrato de que também deriva prestação de titularidade do comprador, não é suficiente para dar configuração à coisa julgada. O contrato obviamente não pode ser visto de duas formas distintas, conforme a prestação exigida seja de uma ou de outra parte da relação substancial. Ou há contrato ou este válido ou não há contrato ou este é inválido, pouco importando quem esteja a exigir a prestação. É a unidade do contrato e a impossibilidade de conferir-lhe tratamento contraditório que impõe a extensão da coisa julgada à relação jurídica complexa e unitária que está à base do pedido de adimplemento de prestação.

Para que não se pense que esta é uma elaboração dogmática arbitrária, cabe lembrar que o próprio Chiovenda, cujo pensamento constitui a base moderna não só da elaboração teórica italiana, mas também das doutrinas dos países de civil law sobre a coisa julgada, advertiu expressamente para o problema das relações jurídicas complexas diante de ações relativas às suas porções. Para evitar a fragmentação das relações substanciais unitárias, Chiovenda disse que, quando se pede um “direito central” derivado de uma relação jurídica complexa, os limites da coisa julgada não devem ficar limitados ao direito que se pretende obter em juízo, mas devem alcançar a totalidade da relação jurídica.⁸⁸ Ao se ter em consideração que a coisa julgada assume tal configuração em razão da impossibilidade de se conferir tratamento contraditório à relação unitária base, obviamente não importa se há revelia ou não contestação do contrato.

Tudo isso quer dizer que, diante do Código de Processo Civil de 2015, pode haver ofensa à coisa julgada nas seguintes hipóteses: i) quando, diante de ação em que se pede prestação fundada em contrato, há discussão e decisão do contrato e, posteriormente, em ação em que se pede a prestação contrária baseada no mesmo contrato, julga-se improcedente o pedido sob o fundamento de que o contrato não existe ou é inválido; e ii) quando, em ação proposta por uma das partes, sem se discutir e decidir sobre o contrato, é reconhecido o direito à prestação que do contrato deriva e, posteriormente, nega-se a prestação pedida pela outra parte do contrato sob o fundamento de que este não existe ou não é válido.

Na hipótese i) há coisa julgada sobre o contrato em virtude deste ter sido discutido e decidido enquanto questão prejudicial à solução do pedido de adimplemento da prestação, nos termos do

art. 503 do CPC. De modo que a negação do contrato, na ação em que a outra parte pede o adimplemento da prestação que lhe corresponde, significa ofensa à coisa julgada sobre a questão.

Quando o contrato não é discutido e decidido, ou seja, na hipótese ii), ainda assim não há como negar o contrato na ação subsequente em que se pede o cumprimento de outra prestação. Isso porque, mesmo que o contrato não tenha sido decidido, é possível dizer que o contrato não pode ser negado, sob pena de se dar tratamento contraditório a uma relação substancial indissolavelmente unitária.

Seria possível dizer que não há motivo para falar em coisa julgada sobre questão quando o contrato constitui o objeto do processo e da própria coisa julgada relativa à ação de adimplemento. Mas aí, diante do Código de Processo Civil de 2015, o problema estaria sendo invertido. É preciso ter em conta que o contrato nunca deixa de ser fato constitutivo do direito à prestação. Ora, um fato constitutivo, quando se torna controverso e, assim, assume a condição de questão prejudicial de que depende a resolução do pedido, naturalmente produz coisa julgada material no sistema do novo código. Lembre-se que o problema surge quando há revelia ou não contestação do contrato, ou seja, exatamente quando a questão prejudicial não se configura. Nesse caso é que surge como necessário estender a coisa julgada – que a princípio estaria centrada no pedido de adimplemento da prestação – para o fato constitutivo que não foi controvertido. E isso apenas é feito – frise-se – em razão de estar em jogo uma realidade substancial indissolavelmente unitária. Ou melhor, para que o direito material não seja mutilado pelo processo.

Realmente, os próprios doutrinadores italianos que conseguiram visualizar a singularidade da questão teórica admitem que a extensão da coisa julgada ao contrato objetiva salvaguardar o direito substancial. Como reconhece Proto Pisani, a ideia de se colocar o contrato na esfera do objeto do processo não só constitui a consciência “della gravità degli inconvenienti pratici ora denunciati”, mas também um “corretivo” que foi utilizado por Chiovenda diante do problema da fragmentação das relações jurídicas complexas e unitárias.⁸⁹

9.5. Ofensa à coisa julgada mediante sua “relativização”. Há quem entenda que o juiz pode negar a coisa julgada sob o fundamento de que é incompatível com decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Não só isso. Que o juiz pode invocar a regra da proporcionalidade em sentido estrito para desconsiderar a coisa julgada quando essa nega direito que, diante da aplicação da regra, sobre ela deve prevalecer. Esse fenômeno restou conhecido no direito brasileiro como “relativização da coisa julgada”.

O que aqui interessa saber é se é possível desconsiderar a coisa julgada em virtude de posterior declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal e se é viável aplicar a regra da proporcionalidade para desconsiderá-la, bem como se a rescindibilidade inerente à ofensa da coisa julgada também sustenta ação rescisória diante de decisão que argumentou estar apenas a relativizando.

Não há como negar a coisa julgada sob a invocação de posterior declaração de inconstitucionalidade basicamente pelos seguintes motivos: i) a decisão que aplica lei posteriormente declarada inconstitucional é uma decisão legítima, na medida em que todo e qualquer juiz, no sistema brasileiro, tem poder para afirmar se uma lei é constitucional, ainda que a sua inconstitucionalidade seja arguida pelas partes; ii) sustentar a premissa de que lei inconstitucional não produz efeitos para desconsiderar a coisa julgada que sobre ela se formou é confundir um enunciado do discurso das fontes com um enunciado do discurso do intérprete, ou seja, não fazer distinção entre disposição (texto legal) e norma (resultado-interpretação);⁹⁰ iii) o resultado interpretativo ou a disciplina do direito mediante a decisão judicial, uma vez acobertados pela coisa julgada, separam-se ou destacam-se da disposição geral e abstrata;⁹¹ iv) de modo que proteger a coisa julgada que se forma sobre a decisão que aplicou lei posteriormente declarada inconstitucional obviamente não significa admitir efeitos a uma lei declarada inconstitucional, mas apenas ressaltar juízo anterior e legítimo sobre a questão constitucional;⁹² v) não fosse assim, estaria irremediavelmente nulado ou destruído o sistema de controle incidental de constitucionalidade, na medida em que de nada valeria a decisão do juiz ou do tribunal a respeito da questão constitucional; vi) ou a coisa julgada, operante sobre a decisão que

aplicou lei por entendê-la constitucional, teria o significado de uma inusitada e curiosa coisa julgada sob condição imprevisível e insuscetível de determinação no tempo – na medida em que a coisa julgada sempre estaria na espera de poder ser desconsiderada em virtude de eventual decisão de inconstitucionalidade da Corte Suprema; vii) não há decisão estatal legítima que possa ser desconsiderada pelo próprio Estado. A decisão em controle incidental de constitucionalidade é tão legítima quanto a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ambas provêm do Poder Judiciário e são legitimadas pela Constituição. O equívoco não expresso, porém, contido nos argumentos que admitem a desconsideração da coisa julgada, é realmente não perceber que ressaltar a coisa julgada não é o mesmo que admitir eficácia a uma lei declarada inconstitucional.

Isso é o que basta, neste momento, para evidenciar a impropriedade da tese da retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada. Essa questão será revisitada quando dos comentários ao inc. V do art. 966. Mas ainda cabe enfrentar o problema da possibilidade do uso do postulado da proporcionalidade para afastar ou desconsiderar a coisa julgada.

Argumenta-se que pode haver conflito entre a coisa julgada e outros direitos. Na verdade, afirma-se textualmente que o juiz pode deparar com conflito entre a coisa julgada e “outros princípios postos na Constituição” e, nesse caso, deve resolvê-lo mediante a aplicação do postulado da proporcionalidade.⁹³ Os casos exemplares que animam quem chega a essa conclusão são os de ação de investigação de paternidade julgada improcedente quando não era conhecido o exame de DNA e de ação de desapropriação que condena a Fazenda Pública a pagar indenização em valor muito superior ao que estaria de acordo com a “justa indenização”, prevista no art. 5.º, XXIV, da CF.

A tese que pretende solucionar as questões do DNA e da supervalorização da indenização na desapropriação mediante a contraposição de normas constitucionais com a coisa julgada aponta para o que chama de “superprincípio da proporcionalidade”, vendo-o como mecanismo capaz de dar ao juiz o poder de escolher entre a norma constitucional que se alega violada e a coisa julgada.

Lembre-se que o postulado da proporcionalidade se divide em três subpostulados: adequação, necessidade – que se desdobra nas regras do meio idôneo e da menor restrição possível – e proporcionalidade em sentido estrito. Esclareça-se, assim, que, ao aludir a “superprincípio da proporcionalidade”, o Ministro José Delgado está em realidade falando em proporcionalidade em sentido estrito. Realmente, a proporcionalidade, nos casos antes mencionados, não poderia ser pensada como “adequação” ou “necessidade”, mas apenas como proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, como regra que seria capaz de solucionar as situações de choque entre a manutenção da coisa julgada e a proteção de bem que torne indispensável a revisão do julgado.

Em outras palavras, não seria o caso de simples harmonização, mas de aplicar um método de ponderação dos bens, lembrando-se que ponderar é o mesmo que sopesar para definir o bem que deve prevalecer, enquanto harmonizar indica a necessidade de contemporizar para assegurar a aplicação coexistente dos princípios em conflito.⁹⁴

A ponderação não é um método de interpretação. Como explica Canotilho, a atividade interpretativa começa por uma reconstrução e qualificação dos interesses ou bens conflitantes, procurando, em seguida, atribuir um sentido aos textos normativos a aplicar, enquanto a ponderação visa elaborar critérios de ordenação para, em face dos dados normativos e factuais, obter a solução justa para o conflito de bens.⁹⁵

Por outro lado, a proporcionalidade em sentido estrito não é um princípio nem, muito menos, um superprincípio. É, isto sim, um postulado,⁹⁶ que apenas pode ser usado em casos excepcionais, de colisão de direitos de igual hierarquia, cuja solução não pode se dar mediante outro método que não a ponderação no caso concreto. O postulado da proporcionalidade em sentido estrito somente deve ser utilizado em situações extremas, em que não exista outra alternativa a não ser a ponderação dos direitos. A ponderação não só é um método complementar, mas talvez o menos recomendável e o mais criticado de todos os que existem.⁹⁷

Outro grande equívoco presente no raciocínio que tenta ponderar a coisa julgada com normas

constitucionais está em minimizar o peso da coisa julgada ou, pior do que isso, em colocar a coisa julgada no mesmo plano dos direitos à descoberta do verdadeiro pai e ao pagamento da justa indenização, por exemplo. Ora, obviamente não há como colocar no mesmo plano um direito que foi definido pela jurisdição e a coisa julgada material. Esta última, em uma “escala de valores”, possui valor superlativo, não podendo ser objeto do balanceamento pretendido.

A coisa julgada é uma condição para o discurso jurídico. Um discurso revisável não é um discurso jurídico, mas um discurso prático-geral.⁹⁸ A coisa julgada não integra o discurso propriamente dito, mas a parte formal da argumentação. Ela é uma regra indispensável à existência do discurso jurídico. Isso significa claramente que a coisa julgada não pode ser “relativizada” pela ponderação de princípios, pois só existe ponderação em discurso jurídico, para cuja existência é imprescindível o respeito a determinadas regras formais, aí incluída a coisa julgada. A coisa julgada não pode ser objeto de “ponderação” por não constituir um princípio cujo fundamento axiológico possa ser mensurado e comparado com os outros. Ela é uma regra formal do próprio discurso jurídico, cuja fundamentação é pragmático-transcendental.

Sem coisa julgada não há como falar em discurso jurídico e, por consequência, em Estado Democrático de Direito. A regra formal do discurso jurídico contida na coisa julgada é, sem dúvida, parte estruturante do Estado Democrático de Direito.⁹⁹ Aliás, o fato de determinados bens não poderem se submeter à proporcionalidade é conhecido na prática do direito constitucional, bastando lembrar decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão que deixou claro que os direitos subtraídos ao poder de revisão, nos termos do art. 79, § 3.º, e do art. 19, § 2.º, da Lei Fundamental alemã, têm valor supraconstitucional.¹⁰⁰

Não há cabimento em ponderar um direito que deve ser tutelado pela jurisdição e um atributo que objetiva garantir a própria decisão jurisdicional. A coisa julgada não pode ser colocada no mesmo plano do direito que constitui o objeto da decisão à qual adere. Ela é elemento integrante do conceito de decisão jurisdicional, ao passo que o direito é apenas o seu objeto. Não há dúvida de que os direitos podem, conforme o caso, ser contrapesados para fazer surgir a decisão jurisdicional adequada,¹⁰¹ mas a própria decisão não pode ser oposta a um direito, como se ao juiz pudesse ser conferido o poder de destruir a própria estabilidade do seu poder, a qual, antes de tudo, é uma garantia do cidadão.

Aliás, se a coisa julgada pudesse ser objeto de ponderação, não haveria como escapar da conclusão de que esta ponderação já teria sido feita pelo próprio legislador constitucional. O art. 5.º, XXXVI, ao garantir a coisa julgada material, mais do que afirmar a segurança jurídica, teria feito uma opção pelos princípios da segurança e da confiança diante do risco de eventuais injustiças. Nessa dimensão, a coisa julgada seria uma regra que impediria qualquer ponderação judicial. Isso porque, quando se está diante de bens ponderáveis, a ponderação legislativa exclui qualquer ponderação judicial sobre os bens já ponderados.¹⁰²

Assim, basta admitir que o art. 5.º, XXXVI, da CF tutela a coisa julgada, tornando estáveis as decisões e impedindo a sua rediscussão perante o Poder Judiciário, para se entender que a Constituição exclui qualquer possibilidade de ponderação judicial que tome em conta a coisa julgada.¹⁰³

Mas, além de incorrer nos equívocos antes referidos, a teoria da ponderação ou da relativização ainda padece do defeito congênito de ver a coisa julgada como mera decorrência de regra contida no Código de Processo Civil. Com efeito, enquanto o Ministro Delgado sustenta ter sido vontade do legislador constituinte apenas configurar o limite posto no art. 5.º, XXXVI, da CF, impedindo que a lei prejudique a coisa julgada,¹⁰⁴ Theodoro Jr. alega que a noção de intangibilidade da coisa julgada, no sistema jurídico brasileiro, não tem sede constitucional, mas resulta, antes, de norma contida no Código de Processo Civil, pelo que de modo algum pode estar imune ao princípio da constitucionalidade hierarquicamente superior.¹⁰⁵

Ora, a coisa julgada não apenas tem sustentáculo no art. 5.º, XXXVI, da CF, como constitui elemento estruturante do Estado de Direito. Lembre-se que na Alemanha, onde não há proteção constitucional expressa à coisa julgada, o seu fundamento constitucional está ancorado no

princípio do Estado de Direito. O Bundesverfassungsgericht foi o principal responsável por esta elaboração, frisando que o princípio do Estado de Direito tem como componente essencial a garantia da certeza do direito, que exige não apenas o desenvolvimento regular do processo, como também a estabilidade da sua conclusão.

O art. 5.º, XXXVI, da CF não quis apenas dizer que a lei não pode modificar a situação definida pela decisão que produziu coisa julgada, mas que a lei infraconstitucional, além de não poder negar a coisa julgada, deve protegê-la (dever de tutela normativa). Qualquer lei que diga que uma decisão, proferida em processo em que todos os argumentos e provas puderam ser apresentados, pode ser revista pelo Poder Judiciário, não acatada pelo Poder Executivo ou alterada ou modificada pelo Poder Legislativo, é uma lei inconstitucional.

Engana-se, assim, quem pensa que a proporcionalidade é uma saída para todos os males ou um “superprincípio” capaz de acomodar a coisa julgada diante de princípio constitucional. Na verdade, a proporcionalidade em sentido estrito não só é um método complementar, mas também perigoso, por dar ao juiz um poder de difícil racionalização.

A coisa julgada, por não fazer parte do conteúdo material do discurso jurídico, não pode ser objeto de balanceamento. Ela é regra formal do discurso jurídico ou regra imprescindível para a existência desse discurso ou do próprio processo. De modo que, e em vez de mera regra infraconstitucional de caráter processual, a coisa julgada é elemento estruturante do Estado Democrático de Direito. Tem, assim, base constitucional, e, em uma interpretação do art. 5.º, XXXVI, que considere o contexto, não pode deixar de ser vista como uma expressão de estabilidade e como uma garantia de segurança e de confiança. Portanto, mesmo que se considerasse a coisa julgada como elemento integrante do discurso, e assim passível de ponderação, essa ponderação já teria sido feita pelo legislador constituinte, que optou por ela diante do risco de eventuais injustiças.¹⁰⁶

Dessa forma, é preciso esclarecer que, além de a expressão superprincípio não ser adequada para definir a proporcionalidade em sentido estrito, se existe alguma coisa, na dimensão ora estudada, que pode ser qualificada de “super”, esta é a regra da coisa julgada. A coisa julgada, por não ser um elemento que integra o conteúdo material do discurso, mas uma condição imprescindível para a sua existência, coloca-se fora do local em que poderia ser vista como uma mera regra, constituindo então, ela sim, uma verdadeira “super-regra”.

O fato de não ser possível balancear a coisa julgada com outros direitos não significa que os problemas relacionados aos casos exemplares – investigação de paternidade e ação de desapropriação – não possam ser adequadamente tratados sem se violentar a coisa julgada. Isso ficará evidenciado logo mais, quando se abordar e comentar os incs. VI e VII do art. 966.

Por ora é importante frisar que toda decisão que “relativiza” a coisa julgada – com base em argumentos como o de posterior declaração de inconstitucionalidade e de aplicação da regra da proporcionalidade – ofende-a indesculpavelmente, sujeitando-se a ação rescisória com base no art. 966, IV, do CPC.

Seria absurdo supor que, em razão de o juiz ter fundamentado a desconsideração da coisa julgada em um ou outro fundamento, estaria a proferir decisão não rescindível. A decisão claramente ofende a coisa julgada e, portanto, não pode escapar da ação voltada à sua rescisão.

9.6. Coisas julgadas contraditórias em ações idênticas e o falso problema da superação do prazo para a propositura da ação rescisória. A questão teórica mais controvertida pela doutrina brasileira, em tema de ofensa à coisa julgada, certamente é a das chamadas coisas julgadas antagônicas ou contraditórias que sobrevivem ao prazo para a propositura da ação rescisória em face da segunda coisa julgada. Trata-se do problema que ocorre quando as partes voltam a discutir exatamente a mesma ação já decidida e outro juiz, ao rejulgar o mesmo pedido com base na mesma causa de pedir por descuido, profere decisão em sentido contraditório ou oposto.

A doutrina, quando depara com o problema teórico, gasta energia em torno de um esquema

lógico pautado entre o valor da coisa julgada e o significado da ação rescisória. Por um lado, afirma-se que a primeira coisa julgada deve prevalecer em razão de a segunda estar a ferir o valor da coisa julgada, assegurado na Constituição Federal. Não teria sentido admitir que uma coisa julgada que não pode se formar é capaz de superar a coisa julgada que se formou validamente e tem a proteção constitucional. De outro lado, alega-se que, se a ação rescisória é o meio previsto para desconstituir a coisa julgada que se formou com ofensa à coisa julgada, a sua não utilização só pode significar que a segunda coisa julgada se tornou incontestável. A não propositura da ação rescisória representaria a convalidação da coisa julgada formada em detrimento da primeira coisa julgada ou uma espécie de admissão tácita da validade da segunda coisa julgada.

Lembre-se, apenas como exemplo dessa segunda posição, o que diz Barbosa Moreira em seus Comentários ao Código de Processo Civil [1973]: “No direito romano, prevalecia sem dúvida a primeira, já que a segunda, proferida contra a res iudicata, se considerava inexistente e não chegava, como tal, a revestir-se, ela própria, da autoridade da coisa julgada. A concepção moderna, todavia, é bem diversa. A decisão que ofende a res iudicata nem é inexistente, nem sequer nula de pleno direito, mas apenas suscetível de desconstituição, por meio de recurso ou de ação impugnativa autônoma, conforme a opção de cada sistema jurídico. No ordenamento pátrio, v.g., semelhante decisão transita em julgado como qualquer outra e, enquanto não rescindida, produz todos os efeitos que produziria se nenhum vício contivesse. Seria evidente contrassenso recusar-se eficácia à segunda sentença, depois de consumada a decadência, quando nem sequer antes disso era recusável a eficácia. A passagem da sentença, da condição de rescindível à de irrevocabível, não pode, é claro, diminuir-lhe o valor. Aberraria dos princípios tratar como inexistente ou como nula uma decisão que nem rescindível é mais, atribuindo ao vício, agora, relevância maior do que a tinha durante o prazo decadencial. Daí se infere que não há como obstar, só com a invocação da ofensa à coisa julgada, à produção de quaisquer efeitos, inclusive executivos, da segunda sentença, quer antes, quer (a fortiori!) depois do termo final do prazo extintivo”.¹⁰⁷

É curioso que nesta discussão deixam de ser considerados alguns aspectos fundamentais: i) a maioria dos casos de ofensa à coisa julgada ocorre quando um juiz, ao decidir questão prejudicial ao julgamento da demanda, ofende a coisa julgada que se formou em ação com conteúdo diverso; ii) a ofensa a coisa julgada, em caso de repetição de demandas idênticas, não só é algo raro, como em regra constitui má-fé de uma das partes e desatenção da outra; iii) há importante diferença entre coisa julgada que ofende coisa julgada formada em ação idêntica e coisa julgada que ofende coisa julgada formada em ação distinta; iv) na primeira hipótese existem duas coisas julgadas que se excluem, não ocorrendo o mesmo quando uma coisa julgada, embora incompatível com a primeira, não a exclui; v) quando a ação rescisória não é proposta, em uma das referidas hipóteses sobrevivem coisas julgadas antagônicas e na outra passam a existir coisas julgadas que ocupam espaços próprios e diferentes; vi) não obstante a ofensa à coisa julgada possa se dar mediante re julgamento de demanda idêntica ou de desconsideração de julgamento de demanda distinta em ação distinta, nada indica que se deva conferir igual sanção para a negação das funções negativa e positiva da coisa julgada.¹⁰⁸

Não há dúvida de que coisas julgadas antagônicas, formadas mediante a repetição de ação idêntica, constituem o resultado de uma afronta ao Poder Judiciário. Uma verdadeira situação contrária ao direito. Apenas alguém de má-fé ou por injustificável falta de cuidado pode propor ação que já propôs ou propor ação inversa em face da parte com quem já litigou para obrigar outro juiz a redecidir o mesmo caso com o propósito de obter outra decisão. De outro lado, somente o advogado de grande corporação privada ou da Fazenda Pública, membro de extenso corpo de advogados a serviço de alguém que é litigante habitual, pode deixar de perceber que está atuando diante de uma ação ou de um caso em que a parte que representa já obteve sentença favorável transitada em julgado. Isso pode ocorrer nos casos de ações em massa, endereçadas contra uma empresa privada ou contra a Fazenda Pública, cujos advogados são muitos, de modo que um pode atuar em processo em que a parte venceu sem que outro advogado tenha ciência de que a mesma parte está diante da mesma ação. Isso para não falar que deve haver um deficiente controle das ações, em virtude de a parte estar envolvida num grande número de casos. Como é óbvio, não se quer dizer que esta desatenção seja justificável, mas apenas que isso pode acontecer em casos excepcionais.

Porém, se a repetição de ações iguais é uma patologia derivada da má-fé e da desatenção causada pelo excesso de litigiosidade, isso não isenta o Estado de sua parcela de culpa, na medida em que, além de a coisa julgada constituir matéria de ordem pública e, assim, dever ser tutelada de ofício pelo juiz, o processamento de duas ações idênticas e a prolação de duas decisões inversas para um mesmo caso significa um óbvio comportamento estatal desconforme ao direito.

Entretanto, isso só importa para evidenciar a racionalidade de sancionar de forma mais incisiva e forte a ofensa à coisa julgada por repetição de demanda (ainda que inversa) do que a ofensa à coisa julgada que constitui pressuposto ao julgamento de demanda distinta.

Não fosse isso, há outro ponto do mais alto relevo que sempre foi deixado na sombra. A passagem do prazo à propositura da ação rescisória tem implicações completamente diversas nos casos em que se ofende a coisa julgada em ação distinta e em que se ofende a coisa julgada em virtude da repetição da mesma ação. Só realmente há problema, diante da passagem do prazo para a propositura da ação rescisória, na hipótese de repetição de ações idênticas, de que surgem coisas julgadas contraditórias. Só nesse caso não há como racionalmente dar lugar às coisas julgadas. Note-se que, no caso em que se julga procedente a ação de alimentos não obstante ter sido julgada improcedente a ação de investigação de paternidade, a passagem do prazo para a rescisão da decisão proferida na ação de alimentos não faz surgir duas coisas julgadas contraditórias ou que ocupam um só lugar, mas duas coisas julgadas que ocupam lugares distintos: uma diz que A não é pai de B e outra diz que A deve pagar alimentos a B. Isso é bem diferente do que afirmar que A é pai de B e que A não é pai de B ou que B não é filho de A (numa ação inversa).

É difícil entender o motivo pelo qual a doutrina nunca percebeu a necessidade de se outorgar sanção processual correspondente a cada uma dessas diferentes situações. Não há qualquer motivo razoável para supor que a ofensa à coisa julgada derivada da repetição de ação idêntica deva ser convalidada pelo decurso do prazo para a propositura da ação rescisória. Na verdade, esquece-se aí de mais um ponto de grande importância para a dilucidação do problema teórico.

Nessa situação parece que não se percebe que o problema surge exatamente quando a ação rescisória não pode mais ser proposta, ao contrário do que acontece nas demais situações de ação rescisória. No caso de ofensa à coisa julgada em virtude de desrespeito à coisa julgada que era pressuposto para a decisão, a passagem do prazo da ação rescisória simplesmente convalida a coisa julgada. Com o decurso do prazo da rescisória não existem coisas julgadas que se excluem. Ao contrário, no caso de coisa julgada que ofende outra em virtude da repetição de ações idênticas, o decurso do prazo para a rescisória apenas potencializa a gritante e insolúvel contradição entre as coisas julgadas. Nesse caso, esquece-se de que, ao se admitir a validade da segunda coisa julgada por não ter sido atacada pela rescisória, há ainda a primeira. Ora, o decurso do prazo para a rescisória poderia ter o efeito de fazer cessar a possibilidade de rescisão da segunda coisa julgada, mas jamais a capacidade de eliminar a primeira coisa julgada do mundo jurídico. É equivocado o argumento de Pontes de Miranda, para quem “a segunda toma lugar da primeira, porque a lei a fez só rescindível no lapso bienal. Não prevalece, porque a primeira se desvaleça, e sim porque convalidando-se inteiramente, tornando-se inatacável, irrescindível, torna-se impossível o que lhe é contrário”.¹⁰⁹ Se a primeira coisa julgada não é desconstituída, é realmente arbitrária e destituída de base constitucional a conclusão de que “torna-se impossível” o que é contrário à segunda coisa julgada. Ora, impossível, de acordo com a Constituição, só pode ser o que é contrário à primeira coisa julgada.¹¹⁰

Aí está mais um ponto que sempre foi negligenciado. Nunca se percebeu que no caso de coisas julgadas antagônicas a superação do prazo da rescisória não tem que acertar contas apenas com o vício rescindível; na verdade, para ter o valor que a ele se pretendeu outorgar, o decurso do prazo da rescisória teria que não apenas fazer desaparecer a ameaça da rescindibilidade da segunda coisa julgada, mas igualmente consumir a coisa julgada que, em primeiro lugar, formou-se idoneamente sob a tutela da Constituição Federal.

Portanto, obviamente não há como tentar solucionar o impasse sob o argumento de que o decurso do prazo para a rescisória torna a segunda coisa julgada inatacável. É que essa conclusão omite ou não enxerga que apenas reproduz o problema que já existia quando a segunda coisa

julgada era rescindível. Tanto neste período, como no posterior à superação do prazo para a rescisória, existem duas coisas julgadas antagônicas. Antes a segunda coisa julgada estava sob ameaça de rescindibilidade; mas depois, a despeito de a segunda coisa julgada não mais estar sob ameaça, não há como dizer que a primeira deixou de existir. A verdade é que a superação do prazo da ação rescisória não tem o efeito de consumir a primeira coisa julgada, mas apenas o efeito de reavivar a colidência entre as coisas julgadas sob a mera diferença de que nem mais potencialmente é possível desfazer a segunda. Bem vistas as coisas, portanto, há um agravamento do problema.

Mas o que significa admitir que, após o decurso do prazo da rescisória, ainda existem duas coisas julgadas contraditórias? Ora, isso apenas permite retomar com maior clareza algo que sempre foi evidente: a primeira coisa julgada é legítima e a segunda uma simples violação da primeira. Daí decorre que a única e simples alternativa é solucionar os eventuais conflitos práticos entre as coisas julgadas de acordo com os variados casos concretos que podem surgir.

Quando se pensa em coisas julgadas oriundas de sentenças condenatórias e de improcedência, há possibilidade de execução se a sentença condenatória é anterior. Tratando-se de duas sentenças de procedência – condenatória e após declaratória –, a declaração certamente não terá qualquer utilidade ou possibilidade de impedir a execução ou de abrir oportunidade para a repetição do valor que já foi executado. Em caso inverso, a declaração revestida pela primeira coisa julgada obsta eventual intenção de execução da sentença condenatória proferida na ação posterior.

Note-se que, quando há condenação em face de declaração ou vice-versa, cabe pensar na possibilidade de obstar a produção de efeitos condenatórios. Isso apenas é possível quando a declaração é anterior à condenação.

Quando existem duas declarações opostas qualificadas pela coisa julgada, vale obviamente a primeira declaração. Na verdade, a coisa julgada que se forma sobre a segunda declaração produz uma eficácia que resta obstada por aquela que já se espraia desde a formação da primeira coisa julgada. A segunda declaração, por assim dizer, nasce com defeito congênito, ou melhor, destituída de capacidade de produzir efeitos.

No caso de sentença constitutiva e sentença de improcedência ou vice-versa, o problema se resolve da mesma maneira. Quando a constituição surge em primeiro lugar, a posterior declaração contida na sentença de improcedência obviamente não interfere nos efeitos constitutivos que estão sendo produzidos desde a primeira coisa julgada. Quando a sentença constitutiva é posterior, a produção de efeitos constitutivos encontra óbice na primeira coisa julgada. De modo que não há como pensar em efeitos constitutivos derivados de uma coisa julgada contraditória.

Tudo isso encontra sustentação no bom-senso que orienta ordenamentos jurídicos estrangeiros, como, por exemplo o português. O Código de Processo Civil português de 2013 possui duas disposições muito claras a respeito. Diz o seu art. 625, 1, sob a rubrica de “casos julgados contraditórios”, que “i) havendo duas decisões contraditórias sobre a mesma pretensão, cumpre-se a que passou em julgado em primeiro lugar”. Mais à frente, ao tratar dos “fundamentos de oposição à execução baseada em sentença”, afirma o art. 729, f), que, “fundando-se a execução em sentença, a oposição só pode ter algum dos fundamentos seguintes: (...) f) caso julgado anterior à sentença que se executa”.

O Código de Processo Civil português é claríssimo no sentido de que, quando há duas coisas julgadas contraditórias, “cumpre-se” a primeira, e de que a execução não pode negar coisa julgada anterior. Quer dizer, em outras palavras, que, além de a primeira coisa julgada sempre prevalecer, essa sempre constitui fundamento para obstar a execução fundada em coisa julgada que com ela colide.¹¹¹

Como demonstrado, a ofensa à coisa julgada derivada da reprodução de ações idênticas reclama maior reprovação do que a ofensa à coisa julgada que constitui pressuposto de ação distinta. Essa maior reprovação certamente tem relação com a sanção que o sistema processual deve reservar para cada uma dessas hipóteses. Recorde-se, por outro lado, que não há dúvida de

que o dado mais relevante para a condução da interpretação das regras processuais está na necessidade de permitir que o processo responda às necessidades de direito substancial, aos direitos fundamentais processuais e às demais normas constitucionais.

Quando aqui se fala em sanção da ofensa à coisa julgada se está a referir aos remédios processuais destinados a obstar a incidência da coisa julgada derivada da reprodução de ação idêntica. Lembre-se que, de acordo com o art. 337 do CPC, o réu deve alegar em contestação, antes de discutir o mérito, a “coisa julgada” (art. 337, VII, CPC). Nessa linha, o juiz fica impedido de resolver o mérito quando “reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (art. 485, V, CPC). Note-se que tal alegação de coisa julgada é restrita à coisa julgada decorrente da reprodução de ação idêntica. Como é evidente, não se obsta a resolução do mérito mediante alegação de que o juiz deve observar coisa julgada para decidi-lo. Não tem cabimento dizer que o réu deve alegar coisa julgada que constitui pressuposto ao julgamento do mérito “antes de discutir o mérito” e muito menos que o juiz não pode resolver o mérito quando reconhece coisa julgada que constitui pressuposto à sua resolução.

O art. 966, IV, por sua vez, dispõe que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “ofender a coisa julgada”. Certamente, a regra foi elaborada para atender aos casos mais frequentes, que são os que dizem respeito a decisões que dependem da observância da coisa julgada.

Embora seja possível lançar mão de ação rescisória no caso de coisa julgada derivada de reprodução de demanda idêntica, o certo é que a coisa julgada formada em ação idêntica não é simplesmente rescindível; ela não pode produzir efeitos. Essa segunda coisa julgada não é uma coisa julgada que, enquanto não rescindida, produz efeitos como outra qualquer. Assim, como não há como confundir rescindibilidade e ineficácia, certamente há legitimidade concomitante para a rescisória e para a declaração de não produção de efeitos da segunda coisa julgada, especialmente dos efeitos que contradizem a primeira coisa julgada. Ou também há legitimidade, por assim dizer, para a deseficacização da segunda coisa julgada. Não é preciso sublinhar que a possibilidade de declaração de não produção de efeitos obviamente nada tem a ver com o prazo decadencial da ação rescisória. Mais ainda pela razão de que as duas coisas julgadas prosseguem em contradição após a decadência, conforme antes explicado.

A superação do prazo da rescisória só pode importar para a situação em que a decadência colabora para a pacificação social. Perceba-se que isso ocorre no caso de decisão que violou coisa julgada que era seu pressuposto, ou seja, quando se tem, após a passagem do prazo da rescisória, decisão que, por exemplo, declara que A não é proprietário da coisa que deu origem ao dano e decisão que condena o mesmo A na qualidade de responsável pelo dano provocado pela coisa. Porém, isso não se verifica no caso de coisa julgada que ofende outra oriunda de ação idêntica. Nesse caso, a passagem do prazo da rescisória – como já demonstrado – apenas potencializa o problema das coisas julgadas antagônicas, de modo que é óbvio que este conflito ainda está a reclamar solução.

Na verdade, o simples e incontestável fato de a superação do prazo da rescisória não eliminar a sobrevivência das coisas julgadas contraditórias é sinal de que a segunda coisa julgada, diante do surgimento de conflito prático em face da primeira coisa julgada, é sempre impugnável, seja mediante ação declaratória de ineficácia, seja por meio de impugnação à execução.¹¹²

Embora o art. 525, § 1.º, do Código, não tenha previsto expressamente a possibilidade de o executado alegar em impugnação coisa julgada anterior à sentença, é evidente que a coisa julgada anterior obsta a exigibilidade do direito reconhecido na sentença. Basta constatar que a invocação de coisa julgada anterior adverte que o juiz possui diante de si uma decisão proferida contra jus. Não uma decisão que julgou de modo disforme ao direito ou com base num vício que já era alegável, mas uma decisão (em abstrato) proibida pelo direito. Bem por isso, o executado pode deduzir coisa julgada anterior sob o fundamento de “inexigibilidade da obrigação”, nos termos do art. 525, § 1.º, III, do CPC. É evidente que a rescindibilidade não é óbice à execução. O que obsta a execução é uma coisa julgada que nega coisa julgada anterior, ou seja, uma decisão proibida por lei e que viola os princípios estruturantes do Estado de Direito; uma coisa julgada que não produz

efeitos.

Ora, a possibilidade de invocar coisa julgada anterior em impugnação nada tem a ver com o prazo para a ação rescisória. Se a ação rescisória não obsta a dedução de coisa julgada anterior na impugnação, não há qualquer razão para pensar que a coisa julgada anterior não pode ser utilizada para fundar impugnação depois de decorrido o prazo para a ação rescisória.

Perceba-se que essa interpretação está de acordo com a necessidade de sancionar a violação à coisa julgada de forma adequada, ou melhor, em conformidade com a norma constitucional que garante a coisa julgada, com a segurança jurídica e com a cláusula do Estado de Direito. Duas decisões judiciais inversas para um caso que, segundo o direito, apenas pode ser decidido uma vez, é um atentado à garantia constitucional da coisa julgada e uma agressão aos valores que sustentam o Estado de Direito.

De modo que é correto concluir que o não uso da ação rescisória traz gravame apenas àquele que poderia rescindir a coisa julgada que violou coisa julgada que era pressuposto da decisão, mas jamais àquele que, beneficiado por coisa julgada, depois é surpreendido por coisa julgada formada em ação idêntica. Volte-se a lembrar que a decadência da ação rescisória não elimina a primeira coisa julgada, que continua a conviver com a segunda. É essa última, ao menos para quem olha para os valores do Estado de Direito, que não pode surpreender o titular da primeira. Nem se diga, como graciosamente fez Barbosa Moreira, que a segunda coisa julgada também é tutelada pela Constituição.¹¹³ Uma coisa julgada que constitui uma violência ao império do Direito não apenas não está tutelada pela Constituição; ela constitui uma clara ofensa aos pressupostos do Estado de Direito.¹¹⁴

Por isso, diante de coisas julgadas contraditórias, é acertada a interpretação que confere ao executado o poder de invocar “coisa julgada contrária” na impugnação sob o fundamento de inexigibilidade do direito. Igualmente é legítimo admitir o uso da ação declaratória de ineficácia quando, depois do decurso do prazo da rescisória, surge conflito prático entre as duas coisas julgadas antagônicas.¹¹⁵

9.7. A coisa julgada que reafirma coisa julgada anterior. Talvez fosse possível pensar, num primeiro momento, que o problema só existiria diante de coisas julgadas antagônicas. O raciocínio seria o de que a reafirmação de decisão já proferida não pode prejudicar ninguém.

Porém, é certo que, após proferida decisão revestida por coisa julgada material, não há como pretender rediscutir a questão já decidida nem redecidi-la. Todo e qualquer juiz não apenas está obstado de proferir decisão distinta a uma já proferida; está proibido de tratar de questão já solucionada e proferir outra decisão em seu lugar. “Outra” no sentido de qualquer que seja, pouco importando se diferente ou exatamente igual.

Essa proibição, não obstante decorrer do simples fato de a decisão já ter sido tomada pelo Poder Judiciário, também tem implicações práticas. Pense-se, por exemplo, na prescrição da execução da sentença. Tendo em vista que o prazo prescricional executivo tem relação com o instante em que proferida a sentença, é óbvio que duas sentenças condenatórias e duas coisas julgadas iguais afetam diretamente o prazo para o exercício da pretensão executiva.

9.8. Ação rescisória por ofensa à coisa julgada sobre questão. A coisa julgada sobre questão impede que ela venha a ser novamente discutida e decidida em outro processo. Assim, não é mais possível discuti-la na qualidade de questão prejudicial nem de questão principal. Se na ação de alimentos decidiu-se que A é filho de B, condenando-se B a pagar alimentos para A, não é possível que B proponha ação negatória para rediscutir a questão da paternidade em face de A. A coisa julgada sobre a questão obstaculiza a sua discussão como questão principal. Do mesmo modo, a questão decidida na ação de alimentos poderá ser invocada em qualquer processo futuro em que a qualidade de herdeiro apresente-se como prejudicial à solução do mérito. Nesses casos, a coisa julgada sobre a questão impede a sua rediscussão como questão prejudicial.

Portanto, a coisa julgada sobre questão impede a sua rediscussão como questão principal e

vincula a decisão do mérito que a tem como pressuposto. No caso em que a questão reaparece como prejudicial, haverá violação da coisa julgada caso o juiz permita a rediscussão da questão ou novamente a decida para resolver o mérito, uma vez que lhe incumbe apenas julgar o mérito a partir da coisa julgada formada sobre a questão. Note-se que a situação é parecida com a da coisa julgada sobre o mérito que constitui pressuposto para a decisão. Isso ocorre quando, por exemplo, em ação de investigação de paternidade decide-se que A é filho de B e, mais tarde, A propõe ação de alimentos em face de B. A coisa julgada da primeira ação obviamente será violada se o juiz da ação de alimentos permitir a rediscussão da questão da paternidade ou voltar a decidi-la.

Lembre-se que a coisa julgada também pode recair sobre questão formada a partir de fato impeditivo, modificativo ou extintivo e que obviamente não importa se a decisão da questão foi positiva ou negativa àquele que alegou o fato que deu origem à questão. Maior dificuldade ocorre quando a decisão da questão tem sentido oposto ao da sentença que julga o pedido. Ou melhor, quando a decisão da questão é desfavorável à parte que obtém sentença favorável ou vice-versa. É possível dizer que isso contraria a tradição do collateral estoppel, em que a questão, para ficar obstada de decisão em processos futuros, deve ser essencial para a resolução do litígio.¹¹⁶

Porém, não cabe aqui repetir sem reflexão o que se passa diante do collateral estoppel. É preciso, na verdade, saber o motivo pelo qual o common law entende que uma questão, para ficar coberta pela proibição de relitigação, deve ser determinante para a resolução do pedido. Tendo em vista que o direito estadunidense tem um claro apego à experiência concreta, parte-se da premissa de que uma questão não determinante do julgamento do pedido geralmente não merece atenção nem das partes nem do juiz. Supõe-se, ao exigir que a questão seja essencial ou determinante, que as partes e o juiz dedicam atenção ao que é essencial, e não às questões que não influem diretamente no julgamento do pedido.¹¹⁷ Retenha-se o ponto: a característica da essencialidade tem clara relação com a necessidade de a questão ser discutida e decidida, exigências do direito estadunidense que são reproduzidas no art. 503.

Mesmo no common law não há preocupação com uma conceituação precisa do que seja questão determinante da resolução do litígio, nem se explica de forma racional o motivo pelo qual apenas uma questão essencial pode ficar marcada pelo collateral estoppel e, assim, restar proibida de rediscussão. Se esta razão está numa regra de experiência ligada à discussão e à decisão da questão, obviamente se pode dizer que, quando há adequada e efetiva discussão e expressa e fundamentada decisão da questão, não há motivo para dizer que a questão resolvida contra a parte vencedora não possa ficar revestida de coisa julgada material.

Há vários casos em que não somente uma questão merece atenção das partes e do juiz. Pense-se no caso do acidente automobilístico. Alegando-se responsabilidade objetiva e culpa do demandado, não há motivo para supor que as partes e o juiz possam deixar qualquer das questões de lado. Se for negada a responsabilidade objetiva e acolhida a culpa do demandado, o pedido será julgado procedente e a questão da responsabilidade objetiva decidida em desfavor do autor. Não há como dizer que a questão da responsabilidade objetiva não constitui questão de que depende o julgamento do mérito. Essa questão apenas não se mostrou imprescindível para o julgamento de procedência do pedido, o que é obviamente coisa distinta. Ora, a circunstância de a questão não se mostrar necessária para o resultado final só tem relevo, conforme já dito, quando se teme tornar indiscutível uma questão que, por não ser essencial e determinante, não é adequadamente discutida e decidida. Contudo, quando se tem em conta o que realmente deve importar, ou seja, a irracionalidade de se decidir duas vezes uma mesma questão, torna-se insustentável a regra que faz parte da experiência do collateral estoppel.

As regras estadunidenses – postas no Restatement (Second) of Judgments – afirmam claramente não apenas que a questão deve ter sido discutida e decidida, mas também que deve ser essencial ao julgamento. De qualquer forma, como já dito, a essencialidade da questão é frisada para evitar que uma questão sobre a qual não recaiu adequada discussão e devida atenção possa se tornar indiscutível. Aliás, é interessante lembrar que as Cortes dos Estados Unidos também não admitem collateral estoppel quando o caso foi julgado a partir de duas questões decididas favoravelmente ao vencedor. Alega-se que, nessas situações, não há como saber qual questão foi necessária ou essencial para o julgamento. Argumenta-se que, quando não se tem certeza que uma questão foi

necessária para o julgamento, é possível que não tenha sido cuidadosa ou rigorosamente considerada.

De todo modo, há julgados de Cortes estadunidenses que admitem que, quando duas questões são decididas em favor do vitorioso, cabe outorgar efeito de collateral estoppel a ambas. Isso ocorreu em *Malloy v. Trombley*, quando a Corte de Apelação de Nova Iorque admitiu efeito de collateral estoppel às duas questões que conduziram ao julgamento proferido no caso anterior sob o fundamento de ambas terem sido plenamente consideradas.¹¹⁸ Perceba-se, em outras palavras, que celebradas decisões admitem efeito de collateral estoppel a duas questões decididas em favor da parte que venceu exatamente com base no argumento – antes exposto para justificar a coisa julgada sobre questão que não foi essencial à procedência do pedido – de que basta, para se obstar a rediscussão de uma questão, que ela tenha sido plenamente discutida e adequadamente considerada pelo juiz.

Ainda mais delicado é o problema da ofensa à coisa julgada sobre questão que beneficia terceiros. A coisa julgada sobre questão nunca prejudica terceiros, mas apenas pode beneficiá-los. De modo que, se na ação de ressarcimento proposta por um dos acidentados, decide-se que a empresa demandada não tem responsabilidade para se julgar improcedente o pedido, a empresa não pode invocar coisa julgada sobre questão na ação proposta por outro acidentado. O juiz da segunda ou outra ação poderá decidir que a empresa tem responsabilidade sem ofender a coisa julgada. Porém, se na primeira ação de ressarcimento decidiu-se que a empresa demandada é responsável pelo acidente, a coisa julgada não permitirá a rediscussão da questão na ação proposta por outro acidentado. Nesse caso a coisa julgada sobre a questão beneficia aquele que não participou do processo, na medida em que esta questão, bem vistas as coisas, é também a sua questão. Significa que o outro acidentado poderá invocar a coisa julgada sobre a questão para impedir a sua relitigação e vincular o juiz. Haverá ofensa à coisa julgada sobre a questão caso o juiz da segunda ação decida sobre a questão para julgar o mérito. O juiz da segunda ação não pode voltar a decidir a questão; deve tomar a decisão como pressuposto inarredável do julgamento do mérito. Fora daí há ofensa à coisa julgada sobre a questão, a dar ensejo a ação rescisória.

9.9. O terceiro beneficiado pela coisa julgada diante da ação rescisória. É possível perguntar i) se o terceiro pode propor ação para rescindir a decisão que, por ser contrária à parte com a qual tem identidade de posição jurídica, deixou de lhe beneficiar e ii) se o terceiro que efetivamente foi beneficiado pela coisa julgada tem direito de participar como réu ou mesmo como terceiro na ação proposta para rescindir a coisa julgada que lhe beneficia.

A primeira pergunta não gera dúvida. Lembre-se que o terceiro jamais pode ser prejudicado pela coisa julgada, mas apenas beneficiado. Portanto, sempre poderá rediscutir a questão marcada por coisa julgada formada em processo de que não participou. Assim, não tem direito de propor ação rescisória para desfazer a coisa julgada que deixou de lhe beneficiar. Se optou por não participar do processo, aceitou que não poderia discutir a questão, muito menos propor ação rescisória.

E, se a coisa julgada beneficiou terceiros, esses devem figurar como réus na ação proposta para rescindi-la? Embora se possa dizer que os terceiros adquirem posição jurídica favorável a partir da formação da coisa julgada, isso não quer dizer que tenham legitimidade para defendê-la na ação proposta pelo adversário que lhes é comum. Repita-se que o terceiro opta por não discutir a questão de direito e, assim, não tem razão para ser admitido a participar da ação rescisória. A lógica da coisa julgada em benefício de terceiro é a de que este, por ter aceito não discutir desde logo a questão, não pode argumentar perante o juiz em favor de uma solução jurídica em seu favor. O terceiro claramente optou por não argumentar perante o juiz para obter decisão favorável sobre a questão, preferindo entregar a disputa a outra pessoa, o que significa que também abriu mão de argumentar na eventual ação rescisória. Melhor dizendo: o terceiro não só optou por não discutir a questão, mas entregou a sua discussão e a defesa da coisa julgada a outro litigante.

9.10. Anterior discussão e rejeição de violação de coisa julgada e ação rescisória. Argumenta-se que, pelo fato de a lei processual admitir a rescisória sem nada dizer sobre a

alegação de coisa julgada no processo de conhecimento, não haveria como proibir a rescisória ainda que, no processo de conhecimento em que invocada a coisa julgada, houvesse sido decidido que a primeira coisa julgada não obsta a formação da segunda. É nesse sentido o entendimento de Barbosa Moreira: “O Código italiano, art. 395, n. 5,¹¹⁹ exige, como requisito de admissibilidade da revocazione, que a sentença impugnada não se haja pronunciado sobre a alegação de coisa julgada. No direito brasileiro, é irrelevante que a preliminar tenha sido ou não suscitada, ou apreciada ex officio, no processo em que se proferiu a sentença rescindenda. A circunstância de haver-se nele rejeitado a preliminar não constitui obstáculo ao exercício da rescisória, nada impede que se acolha o pedido de rescisão”.¹²⁰

O fato de o código nada dizer sobre a impossibilidade de se voltar a decidir sobre a coisa julgada não pode ter o efeito que Barbosa Moreira extraiu. O código italiano tem previsão expressa acerca do ponto para evitar que alguém caia no equívoco de imaginar que é possível negar o que já foi discutido e decidido pelo juiz. Ora, se o juiz decidiu que não havia coisa julgada a obstar a formação da coisa julgada, obviamente não se pode fingir que nada foi decidido. É por isso que, mesmo no direito brasileiro, não se deve admitir ação rescisória para rediscutir a alegação de coisa julgada anterior que foi rejeitada pelo juiz.

Trata-se simplesmente de se ter em conta a obviedade de que não se pode pretender rediscutir questão para rescindir o que já foi devidamente discutido e expressamente decidido. Do contrário, admitir-se-iam duas discussões e decisões sobre uma mesma questão, o que é completamente fora de propósito. Ora, é completamente irracional entender que, se no processo em que se formou a segunda coisa julgada discutiu-se para se decidir que não havia uma primeira coisa julgada a obstar a decisão sobre o mérito, é possível voltar a discutir a mesma questão e dar a outro juízo oportunidade para rescindir a segunda coisa julgada.

Diante do art. 503, § 1.º, isso se torna efetivamente impossível. Se a questão da anterior coisa julgada foi discutida e rejeitada no processo, há coisa julgada sobre a inexistência da primeira coisa julgada, o que certamente impede que se pretenda rescindir a segunda coisa julgada sob o fundamento de existir a primeira. Se isso ocorresse, aí sim haveria violação da coisa julgada.

10. Violar manifestamente norma jurídica

10.1. Da violação de literal disposição de lei à violação de norma jurídica. O art. 485, V, do CPC/1973 afirmava que a decisão de mérito podia ser rescindida em caso de violação de “literal disposição de lei”. A norma correspondente do CPC/2015 – art. 966, V – diz que a decisão de mérito pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica”.

Salta aos olhos da comparação entre os dois artigos a relação entre “literal disposição de lei” e “norma jurídica”. Seria possível imaginar que o legislador aludiu a “norma jurídica” para evidenciar que a ação rescisória não é cabível apenas em caso de violação de lei, mas também na hipótese de violação de princípio ou de norma consuetudinária. Essa ideia não é apenas simplista, mas antes de tudo reducionista da complexidade de uma questão teórica da mais alta importância.

A comparação entre “literal disposição de lei” e “norma jurídica” permite uma íntima relação da norma do inc. V do art. 966 com a evolução da teoria da interpretação. Seria muito improdutivo, em termos de aperfeiçoamento do direito, alterar a legislação processual sem libertá-la de teorias jurídicas ultrapassadas, mantendo-a refém de conceitos que não mais devem ser utilizados. A ideia de “violação de literal disposição de lei” é própria a uma cultura jurídica que já não mais existe, ou melhor, a uma teoria da interpretação que há muito se mostrou incapaz de dar conta da realidade da atividade do intérprete e do juiz.

Exatamente por isso, ler o inc. V do art. 966 como se apenas houvesse trocado disposição de lei por norma jurídica – ou estivesse falando de lei em sentido mais amplo – é deixar de identificar um problema teórico que nunca permitiu o uso adequado da ação rescisória e, mais do que isso, não contribuir para o desenvolvimento do direito.

10.2. Violação à literal disposição de lei como fenômeno típico do “formalismo

interpretativo". A teoria formalista da interpretação – também chamada cognitiva – tem sustentação nos princípios do Estado legislativo, em que a tarefa do juiz submetia-se à do legislador. Para essa teoria, a interpretação, enquanto atividade, tem natureza cognitiva. Investiga-se para descrever. O juiz, ao interpretar, investiga o significado do texto legal e então o descreve.¹²¹

Entende-se que a “norma jurídica” está implícita no texto legal. O juiz interpreta para afirmar o que está gravado no texto. Esse tipo de interpretação tem ao seu lado as ideias de completude e coerência do direito. Portanto, o juiz não atua com qualquer discricionariedade. Ao decidir, sempre está preso a uma norma preexistente. De modo que a interpretação, enquanto produto, é um mero enunciado descritivo, sujeito ao teste da verdade e falsidade; há apenas uma interpretação correta.¹²²

Na teoria formalista a interpretação está presa à norma que está no texto legal. A decisão é inteiramente determinada pela lei para que os valores do Estado legislativo sejam observados. A estrita aplicação da lei é o sustentáculo da segurança jurídica. Na verdade, como adverte Jerzy Wróblewski, se a interpretação judicial está vinculada à lei, a decisão consegue ser tão estável e segura quanto ela, podendo-se dizer, até mesmo, que a lei é quem decide o caso concreto.¹²³

Trata-se de posicionamento hermenêutico historicamente associado aos trabalhos da Escola da Exegese, desenvolvidos no século posterior à publicação do Código Civil francês. Nesse período, motivados pela desconfiança em relação aos juízes¹²⁴ e amparados na ideia de respeito à vontade histórica do legislador,¹²⁵ os exegetas contrariaram a orientação dos redatores do Código Civil francês¹²⁶ e declararam que ao Judiciário caberia pronunciar as palavras da lei para dar solução aos casos.¹²⁷

Embora desacreditada, essa teoria ainda está presente no pensamento jurídico comum e no estilo da fundamentação das decisões judiciais. É realmente curioso o fascínio que a teoria formalista ainda exerce sobre os tribunais e alguns institutos. Adverte Riccardo Guastini que a teoria pode ser relacionada à própria Corte de Cassação.¹²⁸ Sem dúvida, caso a função das Cortes Supremas seja resumida à tutela do legislador ou da lei, a sua tarefa interpretativa encontrará lugar confortável dentro do modelo formalista. Não é demais lembrar, aliás, que muito embora hoje exista consciência teórica de que a função das Cortes Supremas de civil law só pode ser a de atribuir sentido ao direito, algumas Cortes Supremas de países de direito altamente desenvolvido – como, por exemplo a Itália – ainda tentam exercer a função que foi concebida para a Cassação por aqueles que a viam a partir da teoria formalista da interpretação.¹²⁹

Assim, não deve haver surpresa ao se perceber que o pensamento jurídico ainda é povoado pela ideia de que o juiz pode “violiar literal disposição de lei”, como se a lei tivesse um conteúdo – a norma – que pudesse ser determinado ou como se a interpretação “correta” pudesse declará-lo. Note-se que só é possível pensar em violação de lei ou de disposição de lei quando se supõe que a lei contém a norma que deve ser aplicada pelo juiz. Quando se admite que a interpretação tem a função de declarar ou revelar a norma preexistente ao próprio conflito, a decisão judicial que invoca a lei, mas revela e aplica outra norma, logicamente viola a lei. Portanto, o mesmo motivo que admite que se diga que a decisão, diante do formalismo interpretativo, é sujeita ao teste da verdade e da falsidade, é o que permite afirmar que a decisão pode violar a lei. Há violação da lei quando a interpretação é falsa, porque destoante da norma que sempre esteve contida na lei.

10.3. A interpretação como valoração e atribuição de significado. O formalismo interpretativo foi deixado para trás quando se percebeu que o texto da lei não basta para determinar a decisão judicial. Demonstrou-se que o texto legal não tem um sentido próprio, em si, que possa ser visto como antecedente à atividade interpretativa. O texto é sempre equívoco, podendo requerer mais ou menos esforço do intérprete para uma atribuição de significado.¹³⁰

Restou claro que para se chegar ao sentido da lei é necessária uma atividade regida por critérios ou diretivas que, não só quando eleitos pelo intérprete, mas também quando utilizados, imprescindem de juízos de valor.¹³¹ A atividade interpretativa é permeada de valorações não

apenas na eleição, mas também na aplicação das diretivas de interpretação. Assim, a interpretação obviamente não é mera investigação, mas valoração. Por outro lado, o intérprete, nesta dimensão, opta racionalmente entre um dos resultados interpretativos possíveis, de modo que a interpretação-resultado, em vez de ser declaração, é atribuição de sentido à lei.

A interpretação capaz de atribuir sentido ao direito obviamente não é uma operação meramente lógica, nada obstante a lógica seja importante para aferição da correção da justificação interna da decisão. As diretivas interpretativas não constituem regras lógicas, mas critérios eleitos e preenchidos a partir de opções e valorações. A decisão não é determinada pela fórmula legislativa, mas é fruto da valoração e da vontade racionalmente justificada do juiz.¹³²

A percepção de que a decisão judicial não pode ser moldada a partir da lei apenas mediante raciocínio lógico põe às claras que o número de decisões que legitimamente podem ser extraídas de um mesmo texto normativo é diretamente proporcional ao grau da sua equivocidade. Frise-se que a equivocidade dos textos normativos não depende somente de defeitos objetivos de sua formulação, mas sobretudo da multiplicidade dos critérios interpretativos, da compreensão da dogmática jurídica e dos sentimentos de justiça dos intérpretes – que algumas vezes restam ocultos e, em outras, manifestam-se mediante explícitos juízos de valor.¹³³

Isso tem relação direta não apenas com a ação rescisória contra decisão que viola literal disposição de lei, mas também com o pragmatismo da Súmula 343 do STF – que ditou a inviabilidade da ação rescisória no caso em que há várias interpretações sobre o mesmo dispositivo legal nos tribunais.¹³⁴

10.4. A preservação da lei dita inconstitucional como primeiro estímulo à dissociação entre texto e norma. De qualquer forma, a construção da distinção entre texto e norma, embora tenha partido da ideia de que o raciocínio do intérprete não é determinado exclusivamente pela lógica nem é neutro, constituiu um claro processo de evolução histórica. É possível dizer que a elaboração teórica que foi delineada pela escola genovesa – que tem hoje em Guastini o seu maior expoente –, teve origem em uma questão prática, surgida na Itália à época em que a Corte Constitucional – projetada no pós-guerra – iniciou os seus trabalhos.

Quando a Corte Constitucional italiana efetivamente começou a funcionar – depois de um atraso de quase dez anos devido às suspeitas em relação ao judicial review –, um dos primeiros problemas que teve que resolver foi o da identificação do objeto do juízo de inconstitucionalidade.¹³⁵ A Corte não queria, na medida do possível, confrontar diretamente os elaboradores da lei e aqueles que a aplicaram e ainda a aplicavam – especialmente a Corte de Cassação. Percebeu-se que a preservação do texto legal, mediante a nulificação da interpretação dele decorrente, seria “politicamente” mais conveniente. Assim, passou-se a sustentar que o objeto do juízo de inconstitucionalidade não é o texto da lei, porém a norma por ele expressa.

É interessante lembrar que, na época em que surgiu a discussão no âmbito da Corte Constitucional, nem todos os juristas manifestaram-se a favor da preservação da lei mediante a declaração de inconstitucionalidade da interpretação. Luigi Montesano, por exemplo, ao escrever *Norma e formula legislativa nel giudizio costituzionale*, apresentou uma tese reducionista e extremamente rigorosa do controle de constitucionalidade, segundo a qual o texto legal que abre oportunidade a interpretações não conformes à Constituição não tem como não ser declarado inconstitucional.¹³⁶

Posições como a de Montesano não prevaleceram. A Corte Constitucional, no final dos anos 1950 do século passado, já trabalhava com as ditas sentenças interpretativas de acolhimento, declarando a inconstitucionalidade de determinadas interpretações do texto legal. A partir daí foi introduzida na Corte uma separação estrutural entre texto e norma que trouxe dois benefícios bastante significativos. Permitiu-se a declaração de inconstitucionalidade de norma ou interpretação, preservando-se o texto legal respectivo, e favoreceu-se a práxis da interpretação de adequação do sentido do texto legal à Constituição.¹³⁷

A influência da discussão surgida na Corte Constitucional sobre o trabalho teórico pode ser

facilmente identificada quando se vê que um dos primeiros e principais trabalhos acerca da importância da dissociação entre dispositivo legal e norma foi escrito por Vezio Crisafulli, discípulo de Santi Romano, que se tornou um dos mais importantes constitucionalistas italianos do século XX e em 1968 foi nomeado membro da Corte Constitucional. O trabalho de Crisafulli foi publicado poucos anos depois do surgimento do problema no seio da Corte Constitucional e poucos anos antes do seu ingresso na Corte.¹³⁸ Em essência, concluiu Crisafulli que a relação disposição/norma não é de correspondência biunívoca, tal e como se sugere mediante o postulado da “norma verdadeira”. Para demonstrar a sua tese, argumentou i) que existem disposições “complexas”, que contêm proposições “inseparáveis” de que podem derivar duas ou mais normas; ii) que há disposições equívocas, que expressam “normas hipotéticas”, ou seja, duas ou mais normas alternativamente; e iii) que cabe distinguir a “disposição-norma” da “norma-ordenamento” (ou norma “vivente”), sendo a primeira o significado “originário” e literal de uma disposição, identificado mediante uma interpretação centrada sobre a disposição isoladamente considerada, e a segunda o significado atual da disposição, à luz do inteiro sistema normativo, em sua abstrata objetividade, e também, em certa medida, na efetividade da sua concreta realização.¹³⁹

10.5. A dissociação entre texto e norma na teoria do direito. Como visto, ao contrário do que sustenta o formalismo teórico, inexistente significado unívoco intrínseco ao texto legal. Bem por isso descabe pensar em simplesmente investigar para declarar a norma. Não há uma relação de sinonímia entre o texto legal e o resultado obtido com a atividade interpretativa.¹⁴⁰ De modo que é totalmente equivocado pensar que a tarefa da interpretação é reproduzir a norma contida na lei.¹⁴¹

Não obstante, costuma-se chamar o texto legal de norma e afirmar que o juiz decide mediante a declaração da lei ou da norma.¹⁴² Porém, se o texto legal é sempre equívoco, o juiz realmente sempre lhe atribui um significado. Esse não pode ser confundido com o texto. A norma é exatamente o significado que o juiz atribui ao texto legal ao decidir.¹⁴³

Não é correto entender que tal dissociação exista apenas na chamada zona de penumbra ou diante de um caso difícil. Na zona de luz ou em face de um caso fácil a atribuição de significado é mais fácil ou requer menos meditação e esforço.¹⁴⁴ Contudo, é óbvio que o juiz, ao deparar com um “enunciado das fontes”, inevitavelmente lhe atribui significado ou sentido, independentemente da sua clareza. Na verdade, a atribuição de sentido é consequência imediata, natural e inevitável do contato de alguém com qualquer enunciado. A clareza só facilita a transposição da linguagem das fontes para a linguagem do emissor. Assim, a distinção que deve ser feita não está na clareza ou dubiedade do texto, mas na distinção entre linguagem das fontes e linguagem do emissor ou do intérprete. A linguagem da fonte, ainda que seja clara, nunca será a linguagem do intérprete.¹⁴⁵ Isso simplesmente porque o contato do intérprete ou do juiz com o texto legal – enunciado do discurso das fontes – transforma-o em enunciado do discurso do intérprete. Norma e lei são dois enunciados; apenas suas origens são diversas.

A velha e não bem refletida suposição de uma correspondência biunívoca entre disposição legal e resultado-interpretação não pode mais ser admitida para o bem do direito e da sua aplicação na vida das pessoas. Afinal, como diz Guastini, toda disposição legal é vaga e ambígua e, assim, tolera diversas e conflitantes atribuições de significado, de modo que a uma única disposição corresponde não somente uma norma, mas uma multiplicidade de normas, conforme as diversas interpretações possíveis.¹⁴⁶

10.6. A Súmula 343 do STF como demonstração de que a decisão baseada em lei de que o Judiciário já adscreeu várias normas jurídicas não pode ser objeto de ação rescisória: indagações daí decorrentes. Conforme demonstrado, a ideia de violação a “disposição de lei” supõe uma biunivocidade entre a disposição de lei e o produto da interpretação, como se o intérprete tivesse a função de revelar a norma contida na lei. Essa pretensa biunivocidade é característica do formalismo interpretativo, em que a interpretação consiste em descobrir e declarar a norma contida no texto legal. Perceba-se que nessa dimensão se pode falar em interpretação verdadeira e falsa e, assim, numa interpretação que viola disposição de lei.

Quando se passa a admitir que o texto legal abre oportunidade a várias interpretações, a depender de uma série de circunstâncias, torna-se não apenas equivocada, mas na verdade impossível, pensar em violação de disposição de lei. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, ao responder à indagação de se uma decisão viola disposição de lei, valeu-se de um conceito negativo, precisamente o de que não há violação de disposição de lei “quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (Súmula 343-STF).¹⁴⁷

Note-se que essa súmula, o ponto-chave encontrado para a solução da ação rescisória baseada em “violação a disposição de lei”, não só constitui admissão de que o texto legal pode abrir oportunidade a várias interpretações, como também de que a violação de disposição de lei é a negação da “clara e tranquila” interpretação da lei. Isso demonstra que a súmula distinguiu o enunciado do discurso das fontes do enunciado do discurso do intérprete, dissociando disposição de lei ou texto de interpretação ou norma.

Assim, bem vistas as coisas, a súmula elaborou a ideia de que o juiz, ao chegar no resultado- interpretação, edita uma norma que não se confunde com o texto ou com o enunciado legislativo. Essa norma nada mais é do que o significado extraído do texto legal pelo juiz. Portanto, pode ser chamada de norma jurídica ou, caso se prefira tomar em conta o seu emissor, de norma judicial. Ora, se o texto ou a disposição de lei constitui linguagem da fonte e a norma é linguagem do intérprete, quando o intérprete é o juiz nada impede que à norma seja acrescido o qualificativo de judicial. Quando o juiz interpreta a lei o resultado sempre será uma “norma”. A linguagem da fonte não varia; a linguagem do intérprete é que passa a ter um intérprete-juiz.

Não há dúvida, dessa forma, inclusive em face da Súmula 343-STF, que o problema da ação rescisória está ligado ao fato de que um mesmo texto legal pode dar origem a uma multiplicidade de normas jurídicas. Ora, quando isso ocorre não há como ver vício na decisão judicial e, assim, obviamente não há motivo para pensar na sua rescindibilidade.

Surgem, então, as questões que realmente interessam: se a decisão rescindível – na perspectiva ora considerada – sempre é uma decisão interpretativa, quando essa decisão pode violar uma norma jurídica? Tendo em vista que podem existir múltiplas normas jurídicas editadas pelos juízes e pelos tribunais, é possível pensar numa norma jurídica produzida pelo Judiciário, que pode ser violada por uma decisão?

10.7. A função das Cortes Supremas e a norma jurídica. Já se percebeu no civil law que, exatamente por não ser o juiz um mero aplicador da lei, essa não é suficiente para garantir a igualdade e a segurança jurídica. Se a lei abre oportunidade a uma multiplicidade de interpretações ou normas jurídicas e, assim, a decisões diferentes para casos similares, não há como não se preocupar com o problema da coerência do direito ou das decisões judiciais, elemento imprescindível para se ter igualdade perante o próprio direito.

É sabido que a função das Cortes Supremas da tradição do civil law era voltada à tutela do ordenamento jurídico. Lembre-se que Calamandrei escreveu a mais célebre obra sobre a história e a função da Corte de Cassação do século passado. Essa obra teve impacto sobre toda uma geração de processualistas e, portanto, sobre o modo como as Cortes Supremas eram vistas até bem pouco tempo e, em alguns lugares e por alguns, ainda são concebidas.¹⁴⁸

Embora o grande professor florentino tenha atentado para a necessidade de a Corte definir a interpretação que deve prevalecer no território nacional, raciocinou como se a Corte devesse fixar, a partir dos critérios interpretativos do formalismo, a interpretação que revela o “sentido exato da lei”. A unificação da interpretação do direito tinha o único propósito de tutelar o direito objetivo, revelando a sua devida e única identidade.¹⁴⁹

A definição da interpretação que deve prevalecer, nessa linha, equivale à fixação da interpretação que efetivamente corresponde ao texto da lei. A tarefa da Cassação, embora voltada à uniformização da interpretação, também consistia em descobrir e declarar o sentido da lei. A uniformização, assim, ocorre para tutelar o legislador.

A pretensão de uniformização da interpretação da lei, em tal contexto, não pactua com a dissociação entre lei e norma e nem é aberta à lógica argumentativa, mas, ao revés, busca responder à concepção clássica de jurisdição – própria à Calamandrei¹⁵⁰ –, em que o juiz simplesmente aplica a lei ao caso concreto, incumbindo à Cassação, por consequência, somente declarar “oficialmente a verdadeira”¹⁵¹ interpretação da lei em nome da unidade do direito objetivo.

Como a jurisdição se limita a declarar a vontade concreta da lei não há motivo para falar em igualdade perante as decisões. Basta a unificação da interpretação para garantir a unidade do direito objetivo e, por mera consequência, a igualdade de todos perante a lei. Não há necessidade de ter precedentes obrigatórios, mas apenas um sistema que permita a correção das decisões destoantes da lei.

A despreocupação com a coerência do direito no âmbito do Judiciário é consequência da desgastada suposição de que os tribunais, inclusive os de vértice, estão limitados a procurar a interpretação que revela o sentido da lei. Ora, se as decisões discutem apenas sobre a exata interpretação da lei, não pode existir incoerência no direito produzido pelo Judiciário, mas apenas equívoco na aplicação da lei. Se a norma jurídica está implícita na lei e é preexistente à interpretação, não há incoerência entre as decisões dos tribunais, mas inadequada aplicação da norma do legislador. Daí porque não se dispensa atenção à incoerência das decisões judiciais. Há somente preocupação com a correção das decisões que equivocadamente aplicam a lei.

Porém, quando se percebe que a interpretação não pode definir o “sentido exato da lei” – fim da Corte de Cassação para Calamandrei –, mas deve realizar valorações para definir o sentido atribuível ao texto legal, é óbvio que a função da Corte Suprema tem que passar a ser outra. A Corte Suprema, diante da explosão de decisões interpretativas no seio do Judiciário, não mais pode ser vista como um órgão que visa a garantir uma mítica racionalidade do ordenamento jurídico, fruto de uma razão iluminista que tanto já seduziu.¹⁵²

A Corte Suprema, hoje, só pode ter a função de atribuir sentido ao direito e dar-lhe desenvolvimento de acordo com a evolução social. A necessidade de coerência do direito deve ser vista como uma decorrência do valor das decisões da Corte. O precedente que outorga sentido à lei agrega algo de novo à ordem jurídica legislada, fixando a interpretação da lei que deve orientar a vida social e regular os casos futuros. Como consequência, o sentido do direito delineado pela Corte não pode deixar de pautar a solução dos casos iguais ou similares, vinculando ou obrigando os juízes e tribunais.

A coerência é imprescindível para que a igualdade não seja violada. A igualdade perante as decisões judiciais é fruto do dever de o Estado dar a todos que estão em uma mesma situação jurídica a solução que a Corte Suprema racionalmente delineou, oferecendo as melhores razões possíveis. Afinal, todos os homens, em condições iguais, merecem – e apenas podem exigir – a melhor solução que o Estado pode obter para lhes garantir uma vida justa.

Frise-se que o valor constitucional tutelado por esta nova Corte Suprema não é a unidade do direito objetivo, antigo mito atrás do qual se esconderam instâncias autoritárias dos mais variados gêneros, porém a igualdade, realizada empiricamente mediante a vinculação dos tribunais e juízes a um “direito” que, delineado pela Corte Suprema, é dependente da evolução da vida social, aberto ao dinamismo de um sistema voltado à atuação de princípios fundamentais munidos de inesgotável carga axiológica e atento à devida percepção das diferenças.¹⁵³

Não se pense, porém, que basta substituir o critério da “norma contida na lei” pelo do “sentido do direito” para continuar admitindo que a função da Corte Suprema é de correção. Há óbvia diferença entre corrigir para tutelar a lei e corrigir para tutelar o direito delineado pela Corte Suprema. Quando se pensa em “corrigir” em razão de a decisão do tribunal ter divergido de precedente, não há contrariedade à lei, mas contrariedade à norma jurídica eleita pela Corte Suprema.

Note-se que, como os precedentes consolidam o direito que deve ser observado pelos tribunais,

a atividade de “correção” das decisões que negam precedentes destina-se a reafirmar a função de interpretação e de desenvolvimento do direito. Essa atividade de “correção”, que é meramente supletiva, subordina-se à função de atribuição de sentido ao direito e de garantia da sua unidade. Assim, não se pode pensar que uma Corte Suprema, na atualidade, deva ter função de correção. Como é óbvio, é completamente contraditório atribuir a uma Corte Suprema que delinea o direito a função de corrigir as decisões.¹⁵⁴

Por outro ângulo, ao se supor que os precedentes da Corte que atribui sentido ao direito não precisam ser observados, a existência da Corte Suprema torna-se desnecessária. Realmente, não há motivo para se ter uma Corte cuja função é definir a interpretação adequada quando os tribunais podem dela livremente divergir. Nesse caso não apenas bastariam os tribunais, como a Suprema Corte não teria motivo algum para atribuir sentido ao direito e, portanto, para estar presente no sistema judicial.¹⁵⁵ Fechar os olhos para a verdadeira função que deve ser desempenhada por uma Corte de vértice é tê-la como um grande tribunal de apelação, como uma espécie de mágica tábua de salvação posta à disposição de qualquer litigante, com a grande desvantagem de se abrir as portas para a incoerência do direito e para a irracionalidade da distribuição da justiça e, por consequência, para a negação da igualdade e da segurança jurídica.¹⁵⁶

Se a explicitação e a frutificação do direito dependem do juiz, não há como não admitir que o direito é resultado de uma atividade compartilhada pelo Legislativo e pelo Judiciário. O juiz obviamente não pode ser mais visto como a *bouche de la loi*, mas, para usar a mesma imagem, não é errado dizer que o juiz é a boca do direito que resulta da lei. Não se quer dizer com isso que o Judiciário cria o direito. Na verdade, a discussão sobre a “criação do direito” não tem muita relevância quando se pensa que uma decisão é criativa se a sua formulação exige opções valorativas do juiz,¹⁵⁷ ou melhor, quando se tem consciência de que a ideia de “criação judicial do direito” tem muitos significados.¹⁵⁸

Tanto o juiz quanto a Corte Suprema reconstroem o direito a partir dos elementos textuais e extratextuais da ordem jurídica.¹⁵⁹ Mas a “última palavra” ou, por assim dizer, a “definição da reconstrução” é das Supremas Cortes. A tarefa de delinear ou definir – mediante as “melhores razões”¹⁶⁰ – a “norma jurídica” capaz de orientar a vida social e regular os casos futuros é do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A norma jurídica que pode ser dita do Poder Judiciário – fora raras exceções (ver adiante item 8.9) – está nos precedentes das Cortes Supremas.

10.8. Violação de norma jurídica editada pelas Cortes Supremas: o problema da identificação da *ratio decidendi*. Contudo, é preciso cautela para perceber que a norma jurídica não está em toda e qualquer decisão de Corte Suprema. Uma decisão só define a interpretação de uma norma quando a maioria do colegiado compartilha da mesma interpretação.

Assim, por exemplo, não basta que uma decisão dê ou negue provimento a um recurso especial para constituir precedente ou ter *ratio decidendi*. Uma decisão que afirma a contrariedade ou nega a contrariedade de uma lei só tem *ratio decidendi* quando a maioria dos membros do colegiado compartilha de um mesmo fundamento para a conclusão a respeito do significado da lei perante a decisão. Afirmar que uma lei foi contrariada ou não foi contrariada com base em fundamentos vários, sem que nenhum deles seja suportado pela maioria, conduz a uma afirmação privada de autoridade ou de valor enquanto entendimento ou voz da Corte.

A situação é semelhante quando se tem em conta a interpretação do texto constitucional em recurso extraordinário. Só quando a maioria da Corte compartilha do mesmo fundamento e, por conta disso, atribui ao texto o mesmo significado, há *ratio decidendi*. Da mesma forma, quando em recurso extraordinário uma lei é admitida como constitucional, dando-se a ela “interpretação de acordo”, só há *ratio decidendi* quando a “interpretação de acordo” é baseada em fundamento sustentado pela maioria. Em outro caso, existirão “interpretações de acordo” não referendadas pela Corte.

Por outro lado, quando o recurso extraordinário declara a inconstitucionalidade ou emprega as técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto, a

decisão da questão constitucional faz parte da ratio decidendi. Ainda que a Corte tenha resolvido que a lei é inconstitucional por diversidade de fundamentos, sem com que nenhum tenha sido compartilhado pela maioria, há eficácia precedental para todos os casos futuros que tratem da mesma lei.

Porém, o fundamento para a declaração de inconstitucionalidade ou para o emprego das referidas técnicas de controle de constitucionalidade terá importância quando o juiz do caso futuro tiver diante de si uma lei diferente, mas substancialmente igual ou similar, a exigir a adoção do mesmo fundamento que foi utilizado para se chegar à decisão. Caso a decisão tenha sido tomada a partir de mais de um fundamento, sem que nenhum deles tenha sido sustentado pela maioria, não haverá ratio decidendi ou precedente capaz de regular o novo caso.

A decisão de inconstitucionalidade, a interpretação conforme e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto têm efeito obrigatório ou vinculante em relação à própria lei discutida. Mas, tratando-se de outra lei, o efeito obrigatório dependerá de o fundamento da conclusão sobre a questão constitucional ter sido compartilhado pela maioria do colegiado.

Perceba-se que em tais casos pode não existir ratio decidendi para regular questão envolvendo outra lei – ainda que similar –, embora haja ratio decidendi para obstaculizar decisão diferente sobre a mesma lei. A ratio decidendi ou a autoridade de uma porção da decisão sempre dependem de maioria, mas a maioria pode concordar sobre o destino do texto legal sem harmonia quanto aos fundamentos para tanto.

A situação pode ser comparada com a da ação direta quando se percebe a distinção entre o dispositivo da decisão – cuja eficácia é erga omnes – e a ratio decidendi ou os fundamentos determinantes da decisão proferida no controle principal.¹⁶¹ Lembre-se que o Supremo Tribunal Federal discutiu se os fundamentos determinantes da decisão proferida na ADIn 1.662 teriam efeitos obrigatórios. Chegou-se à conclusão de que a ratio decidendi da decisão tomada em ação direta de inconstitucionalidade obriga os demais tribunais. Tratando de reclamação, o Supremo Tribunal Federal declarou que na decisão reclamada estaria presente “violação ao conteúdo essencial do acórdão (...). A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional”.¹⁶²

Essa decisão, que claramente declarou que os fundamentos determinantes de decisão proferida em ação de inconstitucionalidade têm eficácia obrigatória, foi reafirmada pelo plenário do STF na Rcl 2.363. Nessa ocasião, o relator, Ministro Gilmar Mendes, argumentou que “a aplicação dos fundamentos determinantes de um leading case em hipóteses semelhantes tem-se verificado, entre nós, até mesmo no controle de constitucionalidade das leis municipais. Em um levantamento precário, pude constatar que muitos juízes desta Corte têm, constantemente, aplicado em caso de declaração de inconstitucionalidade o precedente fixado a situações idênticas reproduzidas em leis de outros municípios. Tendo em vista o disposto no caput e § 1.º-A do art. 557 do CPC/1973, que reza sobre a possibilidade de o relator julgar monocraticamente recurso interposto contra decisão que esteja em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, os membros desta Corte vêm aplicando tese fixada em precedentes onde se discutiu a inconstitucionalidade de lei, em sede de controle difuso, emanada por ente federativo diverso daquele prolator da lei objeto do recurso extraordinário sob exame”.¹⁶³

Na ação direta há clara distinção entre o dispositivo que declara a inconstitucionalidade e a ratio decidendi; o primeiro diz respeito à lei atacada e a segunda pode se expandir para regular leis substancialmente similares. Note-se que uma decisão pode violar o dispositivo ou a ratio decidendi da decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que, por exemplo, afirma inconstitucional lei dita constitucional em ação de constitucionalidade viola o dispositivo da decisão. Já a decisão que deixa de aplicar outra lei, distinta da que foi declarada constitucional, mas a ela substancialmente igual, pode ser dita violadora da ratio decidendi da ação declaratória

de constitucionalidade.

Já no recurso extraordinário, o dispositivo, além de se referir somente aos litigantes, apenas dá ou nega provimento ao recurso. A conclusão sobre a inconstitucionalidade da lei é sobre uma questão que importa à resolução – parte dispositiva – do recurso, encartando-se, do mesmo modo que os fundamentos para se chegar à conclusão sobre a inconstitucionalidade, na fundamentação da decisão e, quando for o caso (maioria), na *ratio decidendi*. Em outros termos, é preciso ter claro que a questão constitucional, além de estar também na fundamentação, pode ser resolvida por maioria, ainda que com base em fundamentos compartilhados por minorias, quando apenas a solução da questão constitucional estará na *ratio decidendi*.

Pense-se, agora, no recurso que, para ser resolvido, depende do enfrentamento de diversos fundamentos, cada um deles bastante para o provimento. Imagine-se, por exemplo, recurso especial fundado em alegação de contrariedade a três leis federais distintas – obviamente que com fundamentos também distintos. Num colegiado composto de cinco Ministros, seria possível pensar em provimento do recurso com base em três votos, cada um sustentando que a decisão contrariou uma das três leis federais, sem com que nenhum dos votos concorde com que a mesma lei tenha sido contrariada. Esse é o primeiro ponto que reclama atenção. É racional prover um recurso destinado à tutela do direito federal sem com que a maioria do colegiado entenda que houve contrariedade ao direito federal? Ou, mais claramente, é racional declarar que uma decisão não deve prevalecer, sob o argumento de que contrariou lei federal, quando o colegiado não chega à conclusão – nem mesmo por maioria – de que a lei foi contrariada?

Se uma decisão só tem motivo para ser reformada em virtude de ter contrariado lei federal ou se o recurso especial só tem razão para ser provido para tutelar o direito federal, não há como entender correto que o entendimento de um dos membros do colegiado competente para o julgamento do recurso seja suficiente nem para a reforma da decisão nem, muito menos, para a afirmação do direito federal que deve prevalecer.

Na verdade, por detrás do vício em prover recurso com base em votos que afirmam contrariedade a leis diversas está a confusão entre decisão colegiada e ajuntamento de decisões individuais de membros do colegiado. Quando se tem em conta a alegação de contrariedade a diversas leis, a racionalidade do julgamento e da deliberação colegiada depende da discussão e da votação em separado de cada uma das alegações de contrariedade.

De modo que, numa situação como essa, o relator deve delimitar os textos legais afirmados contrariados pela decisão recorrida para que o julgamento se desenvolva mediante a discussão e a votação em separado de cada uma das alegações. Caso contrário, não apenas não haverá discussão adequada sobre a eventual afronta da decisão à lei, mas sobretudo não se decidirá sobre qualquer das alegações de contrariedade realizadas pelo recorrente.

Não há qualquer dúvida que, quando os membros do colegiado podem decidir diretamente o recurso a partir de várias alegações de contrariedade, não há decisão colegiada sobre o significado do texto legal dito contrariado em face da decisão recorrida. Há, isso sim, uma ou outra decisão individual dos membros do colegiado. O colegiado e, portanto, a Corte Suprema, simplesmente não decide ou, ao menos, não finaliza a decisão que têm o dever de proferir para o desenvolvimento do direito.

A decisão em separado, portanto, é imprescindível no caso em que estão em jogo alegações de contrariedade a diversos textos normativos. Note-se, porém, que não há a mesma necessidade quando se considera o emprego de decisão de inconstitucionalidade, de interpretação conforme ou de declaração parcial de nulidade. Não há razão para se decidir em separado se é o caso de declaração de inconstitucionalidade e, apenas depois e também em separado, sobre a interpretação conforme ou a declaração parcial de nulidade. Nesses casos a tutela do direito constitucional não depende de decisão em separado.

De outra parte, a questão da maioria em relação aos fundamentos utilizados para se afirmar a contrariedade a um texto tem a ver com a necessidade de se ter um entendimento da Corte a

respeito do seu significado. Quando se pensa em fundamentos para a decisão do recurso, portanto, o problema não é mais relacionado nem ao fim do recurso nem à necessidade de reforma da decisão. Não basta saber se o direito foi contrariado e, assim, se o recurso deve ser provido. Importa identificar a voz da Corte na decisão do recurso.

Quando se quer saber o entendimento da Corte sobre o sentido do direito obviamente não basta perguntar se a lei ou a Constituição foi contrariada. É preciso olhar para a justificativa. Não é por outra razão que, numa Corte de Precedentes, há que se justificar fundamentos, e não votos. A justificativa deve demonstrar a validade do fundamento determinante da decisão e, ao mesmo tempo e quando for o caso, trazer as razões dos fundamentos concorrente e dissidente.¹⁶⁴ Aliás, mais do que dar a cada fundamento uma justificativa, não convém permitir várias justificativas de um mesmo fundamento. Isso comumente ocorre quando a justificativa é relacionada com os votos, e não com o fundamento sustentado por um ou vários julgadores. Sucede que numa Corte de Precedentes não há razão para justificar o entendimento de cada um dos julgadores. A justificativa tem a ver com o entendimento da Corte e, assim, com os fundamentos do colegiado. Porém, nem sempre será possível encontrar na justificativa dos fundamentos um entendimento que possa realmente ser dito da Corte. Isso só ocorrerá quando um fundamento for compartilhado pela maioria. É quando há *ratio decidendi*.

Frise-se que não há necessidade de decidir os fundamentos em separado para identificar como a Corte os pensa.¹⁶⁵ A partir da discussão dos fundamentos, decide-se sobre – por exemplo – a contrariedade à lei para se prover ou não o recurso. Se três julgadores afirmam contrariedade à lei, ainda que com base em dois fundamentos distintos, o recurso especial deve ser provido, embora não se forme *ratio decidendi*. Há um fundamento majoritário – sustentado por dois – um fundamento concorrente – adotado por um –, e um fundamento dissidente – também sustentado por dois. É interessante notar que o fundamento majoritário empata com o fundamento dissidente. Não há fundamento que possa ser dito do colegiado. Assim, embora o recurso seja provido, não há *ratio decidendi*.¹⁶⁶

10.9. Outras normas jurídicas delineadas pelo Judiciário que podem ser objeto de ação rescisória. Também podem ser violadas as súmulas vinculantes, além de outras súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – definidoras, respectivamente, de matéria infraconstitucional e de matéria constitucional (art. 927, II e IV, CPC). Recorde-se, porém, que a técnica das súmulas esteve, sem qualquer êxito, à serviço das Cortes de correção. A súmula foi pensada para sedimentar, mediante um breve escrito, entendimento que, representando o conjunto de várias decisões num mesmo sentido, pudesse permitir o controle das decisões dos tribunais inferiores. Constituía, assim, um enunciado abstrato, completamente indiferente aos casos e às suas particularidades. Ora, foi exatamente esta neutralidade ou abstração que impediu aos tribunais analisar a aplicabilidade das súmulas aos novos e diferentes casos concretos, tornando-as completamente destituídas de utilidade. É curioso, portanto, que o Código de Processo Civil de 2015 afirme, em seu art. 926, § 2.º que, “ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”. Isso nada mais é do que a admissão de que as súmulas só têm alguma importância quando identificadas as *rationes decidendi* dos precedentes que lhe deram origem. Por consequência, ainda que o legislador tenha insistido nas súmulas, é óbvio que os precedentes das Cortes Supremas vão ocupar o seu lugar. As súmulas poderão ter espaço, ainda que sem muita eficiência, nos tribunais.

Embora seja evidente a impossibilidade de resumir precedente de Corte Suprema a decisão firmada por ocasião de julgamento de recurso repetitivo, uma vez proferida a decisão sobre a questão de direito objeto do recurso repetitivo todos os juízes de primeiro grau, tribunais e órgãos fracionários da própria Corte Suprema não podem contrariá-la. A técnica do recurso repetitivo é voltada à solução de questão prejudicial ao julgamento de recursos pendentes. Os arts. 1.037, II, 1.039 e 1.040 do CPC, ao exigirem a suspensão dos processos e recursos, subordinando a sua solução à decisão proferida no recurso repetitivo, deixam clara a intenção do legislador (ver, adiante, comentários à “Subseção II – Do Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos”).¹⁶⁷

De acordo com o art. 1.040, uma vez publicada a decisão: i) será negado seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem – se o acórdão recorrido coincidir com a decisão da Corte Suprema; ii) o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado – se o acórdão recorrido divergir da decisão da Corte Suprema; e iii) os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pela Corte Suprema. De qualquer forma, qualquer decisão que negue a decisão firmada no recurso repetitivo, resolvendo a questão de direito de modo divergente, e transite em julgado em primeiro grau, no tribunal ou mesmo na Corte Suprema, está sujeita a ação rescisória com base em violação de norma jurídica.

Igualmente podem ser violadas as decisões proferidas em incidente de assunção de competência (art. 947, CPC). As decisões proferidas para solucionar “questão de direito com grande repercussão social” e “relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”, previstas no art. 947, caput e § 4.º do CPC, vinculam “todos os juízes e órgãos fracionários”, conforme dispõe o § 3.º do mesmo art. 947. Se juiz ou órgão fracionário contraria decisão do seu tribunal que resolveu qualquer dessas questões – quando obviamente a decisão proferida no incidente de assunção não foi superada por precedente firmado por Corte Suprema –, há violação de norma jurídica.

Entretanto, é importante perceber desde logo que a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas não é uma mera decisão com eficácia obrigatória (ver, adiante, comentários ao art. 976 e ss). O incidente de resolução decide questão de direito que é prejudicial ao julgamento de demandas que se repetem. Portanto, o incidente julga questão que afeta diretamente a tutela do direito de várias pessoas, ou melhor, dos diversos litigantes das demandas repetitivas. Esses sujeitos obviamente têm o direito de discuti-la. A exclusão dos litigantes da discussão da questão de direito, sem que ao menos o “representante adequado” participe do incidente de resolução, configura inquestionável violação do devido processo. Significa que o procedimento do incidente de resolução tem que necessariamente contar com a participação dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos, descritos na Lei da Ação Civil Pública e no CDC. Nessas condições, corrigido o déficit de constitucionalidade do incidente, a sua decisão produz coisa julgada erga omnes.

Isso quer dizer que, quando uma decisão julga demanda repetitiva e nega a decisão sobre a questão prejudicial proferida no incidente de resolução, há ofensa à coisa julgada erga omnes que recaiu sobre a questão. A ação rescisória, assim, deve ser proposta com base no inc. IV do art. 966; não com fundamento em “violação de norma jurídica” (art. 966, V, CPC).

Outra decisão que não pode ser contrariada – enquanto não superada por precedente do Supremo Tribunal Federal – é a decisão proferida no incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e ss, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 949, os órgãos fracionários ficam obrigados perante a decisão do seu tribunal proferida em incidente de inconstitucionalidade. Todos os órgãos fracionários, e não apenas aquele que submeteu a questão para decisão em incidente, ficam obrigados ou vinculados perante a decisão do plenário ou do órgão especial. E isso não apenas quando a declaração é de inconstitucionalidade, mas também quando a decisão é de constitucionalidade. A eficácia obrigatória da decisão é consequência da regra do art. 97 da CF, que estabelece que a lei só pode ser declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu órgão especial.

Significa que, quando uma decisão nega decisão proferida em incidente de inconstitucionalidade, não importa se afirmando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, há violação de norma jurídica. De modo que é cabível, também nesses casos, a ação rescisória.

10.10. A importância dos §§ 5.º e 6.º do art. 966 para a confirmação do significado de “violação de norma jurídica”. Lembre-se que os §§ 5.º e 6.º do art. 966 foram inseridos no Código de Processo Civil de 2015 quase um ano depois da sua publicação. Esses parágrafos claramente enfatizam a possibilidade de ação rescisória em caso de decisão que se pauta equivocadamente em

súmula ou precedente.

O § 5.º afirma expressamente que cabe ação rescisória, com fundamento no inc. V do art. 966, contra decisão que, baseada em súmula ou precedente, não fez a distinção da questão discutida no processo, ou seja, não percebeu tratar-se de outra questão ou caso. Em outras palavras, o § 5.º quer dizer, a princípio, que a decisão que julgou questão ou caso com base em súmula ou precedente manifestamente inaplicáveis pode ser objeto de ação rescisória.

Como está claro, o § 5.º entende que há violação a norma jurídica quando a decisão julgou caso que não poderia ser regulado pelo precedente ou súmula. A violação da norma jurídica, portanto, constitui violação de norma delineada pelo Judiciário – cuja eficácia é obrigatória.

O § 6.º frisa que a ação rescisória pode ser utilizada diante de decisão que viola norma jurídica produzida pelo Judiciário. Adverte que a petição inicial da ação rescisória, quando baseada no § 5.º, deve evidenciar que a decisão rescindenda julgou caso que não podia ser regulado pela norma editada pelo Judiciário, vale dizer, que julgou caso que, além de particularizado por hipótese fática distinta ou marcado por outra questão jurídica, por conta disso impunha solução diversa.

Os dois novos parágrafos inseridos no art. 966 são claras demonstrações de que não é possível ler “violação de norma jurídica” como se lia “violação de disposição de lei”, à luz do CPC/1973. Há nesses parágrafos confirmação de que é possível violar norma jurídica delineada pelo Judiciário.

10.11. Decisão que se pautou equivocadamente (isto é, sem fazer distinção) em precedente de Corte Suprema, decisão proferida em recurso repetitivo, súmula e decisão de tribunal sobre questão

10.11.1. Significado da ausência de consideração da “existência de distinção”. O § 5.º do art. 966 afirma que pode ser rescindida a decisão “que não tenha considerado a existência de distinção” entre o caso julgado e o “padrão decisório” que foi utilizado para decidi-lo. Por “padrão decisório” entende-se a ratio decidendi – no caso de precedente Corte Suprema –, a decisão da questão de direito objeto do recurso repetitivo, as rationes decidendi ou fundamentos determinantes das decisões que deram origem à súmula, a decisão da questão de direito objeto do incidente de assunção de competência e a decisão do incidente de inconstitucionalidade.

O precedente, a súmula e a decisão de uma questão de direito são sempre “interpretados”. Afinal, é preciso analisar se devem ou não regular o caso sob julgamento. Além disso, é preciso saber se o caso a ser julgado amolda-se a eles. Isso significa que o juiz nunca aplica irracionalmente um precedente, decisão de questão ou súmula. A adoção de qualquer um destes sempre depende de uma análise racional e justificada, intimamente ligada às particularidades do caso sob solução. Lembre-se, por oportuno, que o § 1.º do art. 489 do CPC afirma que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) v – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; vi – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Quando a decisão julga o caso e aplica precedente, súmula ou decisão que não podem regulá-lo há exatamente o que se chama de “falta de percepção da distinção do caso sob julgamento”. Quando isso ocorre, a norma ou a solução jurídica são aplicadas equivocadamente, de modo que se pode afirmar que há violação de norma jurídica para efeito de ação rescisória.

O § 5.º alude a decisão que “não tenha considerado a existência de distinção”. Porém, é certo que a rescindibilidade também se apresenta viável quando se entende, de modo manifestamente equivocado, que o caso deveria ser regulado pelo precedente, decisão ou súmula. Toda vez em que a decisão aplica precedente, súmula ou decisão de questão que manifestamente não podia regular o caso, aplica-se o inc. V do art. 966, uma vez que a decisão “violou manifestamente norma jurídica”.

Note-se que até aqui se tratou de duas hipóteses de equivocada aplicação de precedente, decisão ou súmula – uma em que não é considerada a existência de distinção e outra em que se supõe equivocadamente que o caso é similar ou igual. Contudo, é ainda cabível perguntar se é possível falar em violação de norma jurídica quando a decisão deixa de aplicar precedente, decisão ou súmula.

Sem dúvida, sim. Quando, por exemplo, a decisão deixa de aplicar decisão proferida em recurso repetitivo, há violação de norma jurídica. É fácil chegar a essa conclusão quando se está diante da mesma questão de direito. Porém, no caso em que, também por exemplo, argumenta-se que não se aplicou *ratio decidendi* ou precedente firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de embargos de divergência, a rescindibilidade da decisão dependerá de essa não ter aplicado precedente que clara e indiscutivelmente aplicava-se ao caso. Note-se, desde logo, que a margem de aplicação de um precedente é muito maior do que a de uma decisão a respeito de questão de direito.

É interessante perceber que este problema permite voltar à ideia de zonas de luz e de penumbra, embora aqui com outra finalidade. Determinadas *rationes decidendi* são absolutamente claras no sentido de que regulam determinados casos. Outras, no entanto, podem deixar dúvida sobre a sua aplicabilidade a certas situações. Seria possível dizer que a dúvida está relacionada à múltipla variação dos casos, e não ao texto do precedente, de modo que o problema não teria relação com a sua clareza. Sucede que um texto só se torna obscuro quando confrontado com a realidade ou com os novos casos que surgem.

Quando a decisão justifica a não aplicabilidade do precedente, somente quando há manifesto equívoco, capaz de ser identificado em vista da clara e indiscutível aplicabilidade do precedente, torna-se possível admitir a rescindibilidade da decisão. De forma que a rescindibilidade de decisão que deixou de aplicar precedente caberá, a princípio, quando a decisão nada disser a seu respeito, ignorando-o. Porém, mesmo nessa hipótese, a rescisão ficará na dependência de a aplicação do precedente ser necessária, além de obviamente poder inverter o resultado da decisão tomada.

É claro que não se pode pensar, para efeito de ação rescisória, em aplicação equivocada de precedente – ou mesmo de súmula ou de decisão de questão – quando se está diante do próprio órgão judicial que o criou. Tal forma de pensar é incabível quando se considera o órgão competente para rever o precedente, a súmula ou a decisão em recurso repetitivo ou o órgão do tribunal que pode rever a decisão proferida no incidente de assunção de competência ou no incidente de inconstitucionalidade. Ou melhor, obviamente não há como supor violação de precedente, súmula ou decisão quando a Corte Suprema e o tribunal estão em momento e em lugar adequados para poder afastá-los – ainda que não definitivamente.

10.11.2. O problema em face de precedente de Corte Suprema. Um precedente de Corte Suprema pode ter a sua aplicação estendida ou restringida, conforme os novos casos. A Corte, ao instituir um precedente, e não obstante a necessidade deste dever ser moldado de modo a abarcar todas as situações que racionalmente exijam o mesmo tratamento,¹⁶⁸ pode deixar de considerar alguma circunstância ou situação envolvida com o caso resolvido ou com o próprio entendimento jurídico firmado. Ademais, em virtude de os casos variarem naturalmente, conforme as particularidades que lhe dão configuração, é sempre possível o surgimento de novas situações, não tratadas no precedente.

Porém, isso não quer dizer que o precedente apenas pode ter a sua aplicação estendida. A não percepção de determinada circunstância, assim como um caso posterior, podem evidenciar que o precedente, elaborado de modo amplo para abrigar várias situações, não pode regular uma situação específica que estaria, a princípio, sob o seu guarda-chuva. Nesse caso o precedente obviamente deve ter a sua aplicação restringida.

Não há dúvida que a extensão ou a limitação do alcance dos precedentes constitui forma de relacioná-los com novos casos. Dessa forma, desenvolve-se o significado do precedente, que passa a adaptar-se, sem rupturas, às situações que surgem à medida que o tempo passa.¹⁶⁹ Na verdade, um precedente deve ser aplicado até os seus limites. É essa potencialidade, inerente ao precedente,

que torna possível a sua adoção para a solução de casos particularizados por outras circunstâncias ou aspectos inicialmente não tratados. Por idênticos motivos, se a finalidade do precedente deixa de estar presente diante de nova situação, não há como aplicá-lo.

O sistema de precedentes, quando visto a partir da técnica da distinção, sem perder a sua função de preservação da estabilidade, torna-se maleável e capaz de permitir o desenvolvimento do direito, dando conta das novas realidades e das situações que não foram anteriormente tratadas, sem que seja preciso o rompimento do sistema ou a revogação do precedente que ainda é necessário e suficiente para tratar das situações que contemplou desde a sua origem. Assim, a distinção para aplicar ou deixar de aplicar um precedente é algo que milita, a um só tempo, para a estabilidade e para o desenvolvimento do direito.¹⁷⁰

Diante disso, a questão que realmente interessa à ação rescisória é a de que a ampliação ou a restrição de um precedente só tem racionalidade quando compatível com as suas próprias razões. O problema, mais uma vez, é o de que a necessidade de extensão ou restrição do precedente nem sempre é clara ou isenta de dúvida. Aliás, pode haver dúvida mesmo quando o precedente não está diante de situação diversa da inicialmente contemplada. Há hipóteses em que a dúvida está centrada apenas em saber se o caso está sujeito ao precedente. Não se parte da premissa de que há caso distinto e, então, pergunta-se se cabe a extensão ou a restrição do precedente. Indaga-se diretamente se o caso está efetivamente sujeito ao precedente.

Ora bem, como não se pode rescindir decisão que não viola manifestamente norma jurídica, a solução para a conclusão pela rescindibilidade está na determinação das zonas em que a aplicabilidade de um precedente é “certa” e “não certa”. É sempre possível identificar, em face de um precedente, uma zona de certeza positiva – em que o precedente certamente deve ser aplicado –, e uma zona de certeza negativa, em que o precedente não pode ser aplicado. Entre essas duas zonas há uma zona de incerteza ou de penumbra. É certo que, quando se está diante de aplicação extensiva ou restritiva do precedente, a zona de penumbra é mais extensa. Nessa zona intermediária há dúvida e, portanto, decisão que não pode violar manifestamente a norma jurídica. A decisão que estiver fora da zona de penumbra, no entanto, terá deixado de aplicar precedente ou terá resolvido o caso com base em precedente inaplicável. É quando, em virtude de ter a decisão violado manifestamente norma jurídica, caberá ação rescisória baseada no inc. V do art 966 do CPC.

10.11.3. A decisão diante de súmula. Com as súmulas passa-se o mesmo, uma vez que a sua correta aplicação só pode ser determinada com base nos precedentes que lhe dão origem. Nessa perspectiva, atualmente positivada no § 2.º do art. 926 do CPC, para se saber se uma súmula é aplicável a outro caso é necessário verificar os fundamentos determinantes das decisões que estão à sua base. Sem a busca da história das súmulas jamais será possível tê-las como auxiliares do desenvolvimento do direito, já que não existirão critérios racionais capazes de permitir a conclusão de que a súmula pode, racionalmente, ter o seu alcance estendido ou restrito (distinção) para permitir a solução do caso sob julgamento.

Nessa dimensão, é oportuno lembrar, por exemplo, como a súmula 691 já foi aplicada no Supremo Tribunal Federal. Essa súmula afirma que não compete “ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. Porém, no HC 85.185-1¹⁷¹ decidiu-se que a Súmula 691 não se opõe ao conhecimento de habeas corpus quando há flagrante constrangimento ilegal. Entendeu-se que, num caso como esse, é de se conhecer do pedido de habeas corpus em nome do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. A Súmula 691 foi mantida porque, como consta das decisões que lhe deram origem, há de se negar, como princípio, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão de Ministro que, em sede liminar, indefere habeas corpus. Mas, segundo o Supremo Tribunal Federal, o direito fundamental à tutela jurisdicional, diante da situação de flagrante ilegalidade, justifica o conhecimento do habeas corpus e, portanto, a não aplicação da súmula. Significa que a existência de “flagrante constrangimento ilegal” sustentou, a partir de um fundamento de natureza constitucional, uma distinção, limitando-se o alcance da súmula, que, dessa forma, continuou em vigor, porém passou a abarcar menor número de casos – exatamente aqueles em que não há flagrante ilegalidade.

A consideração dos precedentes que deram origem à súmula é imprescindível para se desvendar a sua finalidade e, assim, a racionalidade da sua limitação ou, quando for o caso, extensão. De qualquer forma, como já dito mais acima, não se pode pensar em aplicação equivocada de súmula, para efeito de ação rescisória, por parte do órgão judicial que tem poder para afastá-la. Entretanto, quando não há espaço para discricionariedade e uma súmula é aplicada ou não aplicada de forma manifestamente equivocada, ou seja, fora da zona intermédia entre as zonas de certeza positiva – em que a súmula deve ser aplicada – e negativa – em que não deve ser aplicada –, há violação de norma jurídica. Advirta-se que – também aqui – a zona de penumbra é mais ampla quando se está diante de aplicação extensiva ou restritiva de súmula do que de simples aplicação de súmula.

10.11.4. A distinção em face da decisão de questão. A decisão de questão tem importante particularidade diante da *ratio decidendi* ou do precedente quando se pensa em distinção e, especialmente, em distinção equivocada, capaz de dar origem à ação rescisória. É muito mais fácil identificar um caso que deve ser solucionado mediante o emprego de uma decisão de questão do que um caso ao qual se aplica um precedente.

O art. 1.037, § 9.º do CPC alude expressamente a distinção. Adverte para a distinção que pode ser feita para diferenciar a questão de direito presente em determinado processo em face daquela a ser resolvida no recurso repetitivo: “demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo”.

Note-se que, em caso de recurso repetitivo – e também na hipótese de incidente de assunção de competência –, importa saber se a questão de direito é a mesma. A questão de direito tem que ser igual, idêntica. Não se pensa, ao contrário do que ocorre em hipótese de *ratio decidendi*, em caso semelhante que deve ser resolvido pela mesma *ratio*.

Portanto, existem dois pontos particulares quando se tem em conta decisão de questão: em primeiro lugar não importa identificar caso, mas questão. Em segundo lugar não se pergunta sobre algo que pode ser semelhante, mas sobre algo que é igual ou idêntico.

A consequência óbvia é a de que, quando uma decisão deixa de aplicar ou aplica a decisão proferida num recurso repetitivo – ou num incidente de assunção de competência –, é muito mais simples identificar se houve um equívoco manifesto ou violação manifesta de norma jurídica.

Em alguns casos, pode-se deliberadamente deixar de aplicar a decisão da questão de direito. Em outros, a decisão pode não ser aplicada mediante o argumento de que a questão sob julgamento é distinta e, ainda em outros, pode se aplicar a decisão da questão para resolver questão diferente.

Se no primeiro caso a violação manifesta de norma jurídica está à primeira vista, não se pode pensar que nos outros dois não pode haver manifesta violação. Nessas duas últimas hipóteses não apenas pode existir violação manifesta de norma jurídica, como a sua aferição é muito mais fácil e simples do que nos casos em que há aplicação de *ratio decidendi*.

Quando não se aplicou a decisão mediante o argumento de que a questão era distinta, basta ver se a questão era igual. Porém, tendo sido utilizada a decisão para a solução de questão diferente, haverá violação manifesta quando a questão for solucionada mediante a mera aplicação da decisão, sem com que a fundamentação tenha feito qualquer ligação entre a decisão da questão e a questão resolvida. Como é óbvio, quando a decisão da questão for utilizada como argumento para a decisão da questão diferente, não há que falar em violação de norma jurídica. Há violação manifesta quando a decisão da questão é aplicada, sem reflexão, para a solução de uma questão diferente.

No caso de decisão proferida em incidente de inconstitucionalidade tudo é ainda mais fácil. Aí basta identificar se a lei é a mesma. Frise-se que, quando se pensa em decisão de questão de direito e em decisão proferida em incidente de inconstitucionalidade, não importa a *ratio decidendi*. Isso

não quer dizer que em tais decisões não pode haver ratio decidendi. Quer significar, isto sim, que nessas hipóteses o que obriga é a decisão da questão e não a ratio decidendi ou o precedente.

10.12. A petição inicial da ação rescisória fundada em manifesto equívoco na aplicação de precedente, súmula ou decisão. De acordo com o § 6.º do art. 966, “quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5.º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.

O autor, mediante a petição inicial, deve demonstrar que o caso ou a questão de direito não poderia – ou deveria – ter sido resolvido mediante a aplicação do precedente, da súmula ou da decisão. Isso é, substancialmente, o que importa constar da petição inicial.

Para tanto, o autor pode ter que evidenciar que o caso, resolvido mediante a aplicação do precedente ou da súmula, é “particularizado por hipótese fática distinta”, diferenciando-se e, por isso, não podendo ser regulado pelo precedente ou pela súmula. Mas o autor também pode pretender demonstrar que o caso, não obstante conter hipótese fática distinta, deveria ter sido resolvido pelo precedente ou pela súmula.¹⁷² Isso ocorre quando a hipótese fática do caso está inserta na categoria pertencente ao fato considerado no precedente ou aos fatos dos precedentes que deram origem à súmula.¹⁷³

Só cabe rescisão quando a decisão, em um ou outro caso, negou o significado ou a intenção do precedente ou da súmula. Assim, o autor terá que demonstrar que os fatos do caso, à luz da ratio do precedente ou das rationes dos precedentes, não permitiam a aplicação do precedente ou da súmula, ou, na hipótese inversa, exigiam-na. Não há como deixar de lembrar que a violação ao precedente ou à súmula deve ser manifesta. A aplicabilidade ou não do precedente ou da súmula, diante dos fatos do caso, deve ser clara, isenta de dúvida.

O § 6.º fala ainda em demonstração “de questão jurídica não examinada”. Se a decisão aplicou precedente – ou súmula – supondo que ele tratou de determinada questão jurídica, quando em verdade ele dela não tratou, é certo que o precedente não poderia ter sido aplicado. Contudo, esta parte do § 6.º faz mais sentido quando relacionada à decisão que aplicou decisão de questão de direito que não dizia respeito à questão solucionada.

10.13. Violação de norma jurídica “dotada de aceitabilidade”. Mas a norma jurídica que pode ser manifestamente violada não é apenas aquela elaborada pelo Judiciário. Também é possível violar norma jurídica que não foi delineada por Corte Suprema, que não está presente em decisão com eficácia obrigatória de tribunal e que poucas vezes teve que ser afirmada pelos juízes.

Se os textos legais em regra estão numa zona de incerteza ou de penumbra e, por isso, frequentemente abrem oportunidade para vários resultados-interpretação ou normas jurídicas que, posteriormente, têm que passar pelo crivo das Cortes Supremas para a definição do sentido do direito, certamente há textos legais que dificilmente dão lugar à dúvida àqueles que com eles deparam.

É claro que qualquer texto, por mais claro que seja, sempre tem a possibilidade de ser confrontado com particularidades concretas capazes de torná-lo obscuro e de interpretação complexa ou duvidosa. Porém, também é certo que existem interpretações que derivam clara e logicamente do texto, independentemente da necessidade de valoração de elementos que podem ser postos em dúvida. Assim, por exemplo, quem olha para o art. 1.003 do CPC não fica em dúvida em afirmar que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de quinze dias.

Isso não quer dizer que, dessa forma, está a se aceitar a ideia de que determinados textos têm valor em si ou independem de normas jurídicas que resultam de uma atividade adscritiva de sentido realizada pelo intérprete. Ainda que um texto não comporte dúvida interpretativa, ele sempre oportuniza interpretação, já que o texto, enquanto enunciado das fontes, nunca se confunde com o discurso daquele que o analisa. O texto legal adquire outro valor, ou seja, valor de norma jurídica, quando pronunciado pelo intérprete.

Lembre-se que o argumento do open texture dos textos legislativos, desenvolvido por Hart,¹⁷⁴ de que decorrem as ideias de zona de luz e de zona de penumbra, permitiu-lhe a conclusão de que o enunciado que está na zona de luz, ao contrário daquele que está na zona de penumbra, constitui uma norma que é predefinida, que, assim, pode ser simplesmente descrita. O propósito de tal argumento foi o de demonstrar a validade da teoria normativista. Entretanto, aqui não interessa distinguir zona de luz e zona de penumbra para afirmar a existência de uma norma que antecede a interpretação. Na verdade, aqui não se aceita a ideia de que a norma é predefinida.

Não é preciso negar que ter em conta um texto legal implica necessariamente atribuir-lhe significado, pouco importando a sua suposta clareza ou dubiedade, para admitir que determinados textos resultam em normas sobre as quais não paira discussão no comum dos casos.¹⁷⁵ Frise-se que não se está a admitir norma engastada no texto, mas se está a falar de aceitação da interpretação ou da norma que deriva do texto pelas pessoas que cotidianamente estão com ele envolvidas. Trata-se, em outras palavras, do que se pode denominar de uma norma “dotada de aceitabilidade” ou de uma “situação de consenso” a respeito da norma.

É necessário admitir a rescindibilidade de decisão que nega interpretação ou norma jurídica racionalmente “aceita” por aqueles que estão envolvidos com o texto legal ou sobre a qual há consenso. Nessas situações, em que a norma jurídica é “dotada de aceitabilidade”, certamente cabe a rescindibilidade da decisão com base em “violação manifesta a norma jurídica”, nos termos do inc. V do art. 966. Perceba-se que isso não redundaria na admissão de violação de disposição de lei, como se a norma nela estivesse encartada. A violação é de norma jurídica que, a despeito de não afirmada por Corte Suprema ou por decisão investida de particular autoridade, é “dotada de aceitabilidade”.

10.14. A ação rescisória fundada em decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade

10.14.1. A decisão que nega decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. O art. 525, § 12 do CPC afirma que “considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Porém, logo depois, no § 14 do mesmo art. 525, deixa-se claro que “a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”.

Não é apenas a decisão que declara a inconstitucionalidade de lei que pode obstaculizar a execução, mas também as decisões proferidas com base nas técnicas da “interpretação conforme” e da “declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto”. Ademais, podem ser invocadas tanto as decisões em controle principal quanto as decisões firmadas em sede de controle incidental.

É óbvio que as decisões do Supremo Tribunal Federal que podem sustentar impugnação também podem fundamentar ação rescisória. As decisões proferidas no controle concentrado de inconstitucionalidade têm eficácia erga omnes e, por isso, não podem ser negadas por qualquer juiz ou tribunal. Porém, os tribunais e juízes não estão sujeitos apenas à eficácia erga omnes – que diz respeito à parte dispositiva da decisão –, mas também à eficácia obrigatória dos fundamentos determinantes (ratio decidendi) da decisão.¹⁷⁶ Note-se que há diferença entre aplicar lei já declarada inconstitucional e aplicar lei cuja inconstitucionalidade está positivada nos fundamentos determinantes de decisão que declarou a inconstitucionalidade de outra lei. Assim, por exemplo, se há declaração de inconstitucionalidade de determinada lei municipal, os fundamentos que determinaram a conclusão da sua inconstitucionalidade devem ser observados quando se está diante de lei de outro município, mas dotada da mesma substância.¹⁷⁷

Isso significa que a decisão que nega os fundamentos determinantes de decisão proferida no controle principal ou de decisão tomada em controle incidental também pode ser objeto de ação rescisória. É claro que, neste último caso, a decisão proferida em recurso extraordinário – por

exemplo – deve ter as características de um precedente constitucional, em que os fundamentos determinantes ou a ratio decidendi estejam delineados.¹⁷⁸

Contudo, a ação rescisória igualmente cabe quando ocorre o inverso, ou seja, quando a decisão nega a constitucionalidade de lei já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em controle principal ou em controle incidental.

10.14.2. A pretendida ação rescisória fundada em ulterior decisão de inconstitucionalidade: o § 15 do art. 525 do CPC. Entretanto, diz o § 15 do art. 525 que, “se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. Vale dizer que o § 15 do art. 525 sustenta a possibilidade de ação rescisória fundada em decisão de “inconstitucionalidade” posterior à formação da coisa julgada material.

A norma do novo código merece muita atenção, pois é irremediavelmente inconstitucional. Note-se que, enquanto o § 14 do art. 525 corretamente exclui a possibilidade de a superveniente decisão de inconstitucionalidade obstaculizar a execução da sentença, o § 15 admite a sua invocação como fundamento para a ação rescisória. Trata-se de duas normas claramente contraditórias, de modo que a segunda só pode ser compreendida como resultado de uma inserção descuidada, dessas que são feitas em uma lei de grande amplitude no apagar das luzes da discussão parlamentar.

Ora, a admissibilidade de alegação de decisão de inconstitucionalidade posterior à formação da coisa julgada é uma exceção à sua intangibilidade, pouco importando se a alegação é admitida para inibir a execução ou para fundamentar a ação rescisória. Obstaculizar a executabilidade da sentença é negar o título executivo ou a coisa julgada que a sustenta. Da mesma forma, ação rescisória com base em posterior declaração de inconstitucionalidade é uma macro exceção à intangibilidade da coisa julgada material.

Porém, só haveria racionalidade na admissão da alegação de posterior decisão de inconstitucionalidade se isto não constituísse exceção à intangibilidade da coisa julgada material. Dessa forma, exatamente porque não se estaria a afetar a coisa julgada material, caberia afirmar que a admissão da dedução da posterior decisão de inconstitucionalidade em ação rescisória – e não em impugnação – constitui mera opção legislativa.

Não obstante, como tanto a obstaculização da execução quanto a rescindibilidade com base em ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal obviamente constituem exceção à intangibilidade da coisa julgada material, exigir-se-ia outra resposta do legislador. Seria necessário argumentar, como única saída para a legitimação da norma do § 15, que a intangibilidade da coisa julgada se coloca apenas no plano processual, não estando garantida pela Constituição Federal.

Esse raciocínio é ainda mais absurdo que o antecedente. A coisa julgada está claramente garantida no art. 5.º, XXXVI, da CF. Nenhuma lei pode dar ao juiz poder para desconsiderar a coisa julgada material, até porque nenhum juiz pode negar decisão de membro do Poder Judiciário. A intangibilidade da coisa julgada material é essencial para a tutela da segurança jurídica, sem a qual não há Estado de Direito, ou melhor, sem a qual nenhuma pessoa pode se desenvolver e a economia não pode frutificar.

Nem se diga que a alegação de decisão de inconstitucionalidade constituiria uma exceção constitucionalmente legítima à intangibilidade da coisa julgada, argumentando-se que a rescisão da coisa julgada fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional seria uma afirmação da constitucionalidade sobre a inconstitucionalidade. É sempre importante perceber que a garantia da coisa julgada não resguarda os efeitos de uma lei inconstitucional, porém ressalva os efeitos de um juízo constitucional que aplicou uma lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Tudo isso significa que os juízes e tribunais não devem aplicar o § 15 do art. 525 do CPC, dada a sua inescandível e insuperável inconstitucionalidade. Aliás, como será visto mais à frente, o

Supremo Tribunal Federal recentemente declarou a impossibilidade de ação rescisória baseada em ulterior precedente da sua lavra exatamente sob o fundamento de que isso configuraria violação da garantia constitucional da coisa julgada material.¹⁷⁹

10.14.3. Crítica à ideia de que não pode haver interpretação controvertida do texto constitucional. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já enxergaram uma diferença qualitativa na violação da norma constitucional diante da violação da norma infraconstitucional, ou melhor, uma diferença de natureza entre a interpretação do texto constitucional e a interpretação do texto infraconstitucional, como se a Constituição apenas admitisse uma única interpretação ou exigisse uma “interpretação correta”, ao contrário da legislação infraconstitucional, que abriria oportunidade a várias interpretações ou a “interpretações razoáveis”.

Assim, as Cortes Supremas já decidiram no sentido de que a Súmula 343 – não cabe “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” – somente se aplica aos casos em que a decisão se fundou em lei infraconstitucional. Afirmou-se que a lei constitucional “não é uma lei qualquer, mas a lei fundamental do sistema”, que não pode gerar duas ou mais interpretações razoáveis, porém apenas uma “interpretação juridicamente correta”.¹⁸⁰

Porém, não existe motivo para supor que o texto constitucional só pode admitir uma única interpretação. Ora, a interpretação é sempre uma compreensão e uma reconstrução normativa. Não há qualquer razão para entender que a interpretação constitucional seja diversa da interpretação infraconstitucional no que tange aos seus resultados. A necessidade de coerência impõe essa observação: ou há interpretação “correta” da Constituição e da legislação infraconstitucional – porque, ao fim e ao cabo, tem-se aí sempre um interpretar –, ou não há possibilidade de uma única interpretação correta em qualquer desses planos normativos. Sustentar-se a necessidade de interpretação “correta” no plano constitucional e de interpretação “razoável” no plano infraconstitucional constitui evidente *contradictio in terminis*, porque o ato de interpretar é um só no que tange à compreensão de normas jurídicas.

Contudo, equipara-se “interpretação correta” à interpretação proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, toda e qualquer decisão que adote interpretação posteriormente contrariada por pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ainda que prolatado em recurso extraordinário, é decisão que, para o efeito de ação rescisória, viola norma constitucional, e, assim, deve ser inapelavelmente desconstituída.

As decisões que admitiram a desconstituição da coisa julgada, mediante o exercício de ação rescisória baseada em pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, contêm fundamentação não convincente. Assim, por exemplo, acórdão relatado pelo Ministro Moreira Alves, que diz inexistir ofensa ao art. 5.º, XXXVI, da CF, sob o ângulo da coisa julgada e da não aplicação da Súmula 343, “pela singela razão de que o enunciado dessa súmula se situa exclusivamente no plano da interpretação da legislação processual infraconstitucional” (STF, Ag no AI 305.592-0, 1.ª Turma, j. 20.02.2001, rel. Min. Moreira Alves).¹⁸¹

Em outro caso, o Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte decisão: “4. Ação rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida, ou seja, anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de declaração rejeitados, mantida a conclusão da 2.ª Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória” (STF, RE-ED 328812, 2.ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.05.2008).

Sustenta-se que a existência de interpretações divergentes, diante de norma constitucional, não é óbice à ação rescisória. Ou melhor, entende-se que pronunciamento do Supremo Tribunal Federal é apto à desconstituição das decisões transitadas em julgado que lhe são contrárias, pouco

importando se, a respeito da interpretação da questão constitucional, havia controvérsia nos tribunais.

Diz o Ministro Gilmar Mendes, no acórdão referido por último, que “não é a mesma coisa vedar a rescisória para rever uma interpretação razoável de lei ordinária que tenha sido formulada por um juiz em confronto com outras interpretações de outros juízes e vedar a rescisória para rever uma interpretação de lei que é contrária àquela fixada pelo Supremo Tribunal Federal em questão constitucional” (STF, RE-ED 328812, 2.^a Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.05.2008). Nessa passagem, resta ainda mais claro que não há preocupação com a negação da existência de interpretações divergentes. Parte-se da premissa de que decisão do Supremo Tribunal Federal é, por si só, demonstrativo suficiente de violação literal de norma constitucional. O fundamento da rescisória está na força da decisão do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se havia dúvida nos tribunais sobre a constitucionalidade da norma. Frisando-se a força da decisão do Supremo Tribunal Federal, elimina-se a relevância da existência de interpretações divergentes e do próprio conceito de “violação literal”. Note-se que, nos termos de tal orientação, para que uma decisão possa ser desconstituída com base em “violação literal de lei” (art. 485, V, CPC/1973) basta que decisão do Supremo Tribunal Federal, posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, contrarie-a.

Não há dúvida de que a interpretação do Supremo Tribunal Federal deve prevalecer, submetendo os demais juízes. Não há racionalidade em admitir que um juiz ordinário possa atribuir a uma questão constitucional interpretação diversa da que lhe tenha dado o Supremo Tribunal Federal. Daí a importância da vinculação dos órgãos judiciais às decisões do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a racionalidade do controle incidental depende do adequado emprego da técnica vinculante, nos moldes do *stare decisis* estadunidense, para o que é imprescindível o desfazimento da confusão entre poder para controlar a constitucionalidade e poder para decidir de forma indiferente aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. Se é verdade que todo e qualquer juiz tem o dever-poder de controlar a constitucionalidade, é inegável que esse poder só pode ser exercido de forma racional quando submetido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.¹⁸²

Porém, isso não quer dizer que a interpretação do Supremo Tribunal Federal possa ou deva se impor sobre as demais interpretações judiciais pretéritas, operando a destruição ou a nulificação de decisões já transitadas em julgado. Sublinhe-se que o Supremo Tribunal Federal (BGH) alemão já declarou, com amparo em decisões do próprio Tribunal Constitucional Federal (BVerfG), que “uma alteração na interpretação do direito não serve de fundamento para a rescisão da coisa julgada (BVerfGE 2, 380, 395, 405; BGH, Urteil vom 11. März 1953 – II ZR 180/52 – BB 1953, 273; BAG, AP Nr. 1 zu § 580 ZPO; BFHE 123, 310, 311 f.)”.¹⁸³

Não obstante, a decisão relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, há pouco mencionada, confere à interpretação do Supremo Tribunal Federal a força de alcançar as decisões judiciais transitadas em julgado que lhe são distintas. O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, afirma que, “se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, em decorrência do efeito definitivo absoluto outorgado à sua decisão. Não estou afastando, obviamente, o prazo das rescisórias, que deverá ser observado. Há um limite, portanto, associado à segurança jurídica. Mas não parece admissível que esta Corte aceite diminuir a eficácia de suas decisões com a manutenção de decisões diretamente divergentes à interpretação constitucional aqui formulada. Assim, se somente por meio do controle difuso de constitucionalidade, portanto, anos após as questões terem sido decididas pelos Tribunais ordinários, é que o Supremo Tribunal Federal veio a apreciá-las, é a ação rescisória, com fundamento em violação de literal disposição de lei, instrumento adequado para a superação de decisão divergente” (STF, RE-ED 328812, 2.^a Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.05.2008).

O Supremo Tribunal Federal, na passagem acima descrita, afirma claramente a retroatividade dos seus pronunciamentos, tomados em controle incidental (mediante recurso extraordinário, por exemplo), sobre a coisa julgada, sob o argumento de que as questões submetidas ao controle incidental da constitucionalidade somente chegam ao Supremo Tribunal Federal depois de muito

tempo, quando algumas decisões proferidas pelos tribunais, interpretando a questão constitucional, já transitaram em julgado.

Entretanto, a circunstância de uma questão constitucional chegar ao Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado de decisões sobre a mesma questão certamente não é motivo para a admissão da retroatividade do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a coisa julgada. As decisões que transitaram em julgado, tratando da questão constitucional posteriormente interpretada de outra maneira pelo Supremo Tribunal Federal, expressam um juízo legítimo sobre a constitucionalidade. Este juízo nada mais é do que resultado do dever-poder judicial de realizar o controle da constitucionalidade. Ademais, o fato de a decisão transitar em julgado, antes de a questão chegar à análise do Supremo Tribunal Federal, é mera consequência do sistema de controle da constitucionalidade brasileiro.

No Superior Tribunal de Justiça também existem decisões no sentido de que pronunciamento do Supremo Tribunal Federal constitui fundamento para a rescisão da coisa julgada. Em acórdão proferido por estreita maioria, concluiu o Superior Tribunal de Justiça que, “em matéria constitucional, não há de se cogitar de interpretação razoável, mas sim de interpretação correta” (STJ, EDiv no REsp 608.122, 1.^a Seção, rel. Min. Teori Zavascki, j. 09.05.2007).

Porém, o que o Superior Tribunal de Justiça quer dizer, quando fala em “interpretação correta”, é que a interpretação correta é a que vem do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, sinônimo de interpretação correta é interpretação do Supremo Tribunal Federal. Assim, uma vez proferida a decisão correta, todas as outras que não lhe são conformes são incorretas, e, assim, sujeitam-se à ação rescisória.

A ideia de interpretação correta, infiltrada no mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, é esclarecida no voto do Ministro Teori Zavascki, particularmente na parte em que frisa que “contrariar o precedente tem o mesmo significado, o mesmo alcance, em termos pragmáticos, que o de violar a Constituição (...). É nessa perspectiva, pois, que se deve aquilatar o peso institucional dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, mesmo em controle difuso. Nisso reside a justificação para se deixar de aplicar, na seara constitucional, o parâmetro negativo da Súmula 343, substituindo-se pelo parâmetro positivo da autoridade do precedente. E a consequência prática disso é que, independentemente de haver divergência jurisprudencial sobre o tema, o enunciado da Súmula 343 não será empecilho ao cabimento da ação rescisória (juízo de admissibilidade). Mais que cabível, é procedente, por violar a Constituição, o pedido de rescisão da sentença (juízo rescindente), sendo que o novo julgamento da causa (juízo rescisório), como corolário lógico e necessário, terá de se ajustar ao procedimento da Suprema Corte” (STJ, EDiv no REsp 608.122, 1.^a Seção, rel. Min. Teori Zavascki, j. 09.05.2007).

Na realidade, quando se admite que não há diferença entre contrariar precedente constitucional – que não existia à época em que a decisão foi proferida – e violar a Constituição comete-se um equívoco que está na base da teoria da interpretação, potencializado mediante a suposição de que a única interpretação capaz de fazer ver a Constituição é a do Supremo Tribunal Federal – como se não houvesse controle incidental. Ora, a assimilação de precedente constitucional com norma constitucional revela falta de distinção entre enunciado do discurso do intérprete e enunciado do discurso das fontes. Não há correspondência biunívoca entre Constituição e precedente constitucional, como clara e concretamente demonstra a possibilidade de revogação de precedente constitucional, inclusive de precedente que declarou a inconstitucionalidade de lei.¹⁸⁴ Um precedente do Supremo Tribunal Federal não declara a norma que sempre esteve contida na Constituição ou que sempre preexistiu à interpretação judicial. O precedente constitucional atribui sentido à Constituição ou desenvolve-a de acordo com a evolução da sociedade e dos seus valores. Daí se poder falar em texto constitucional e precedente constitucional como enunciados situados em planos diversos, afastando-se a crença falaz de que existiria uma correspondência biunívoca entre Constituição e interpretação do Supremo Tribunal Federal, única que poderia fazer supor que uma decisão legitimamente proferida por juiz incumbido de realizar controle de constitucionalidade pode ser invalidada em virtude de ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal – que teria o efeito de declarar a inconstitucionalidade da lei em que a anterior decisão se fundou.

Se o Supremo Tribunal Federal deve zelar pela uniformidade da interpretação da Constituição, isso obviamente não quer dizer que a sua interpretação tenha poder para dissolver a coisa julgada material. Aliás, se a interpretação do Supremo Tribunal Federal pudesse implicar descon sideração da coisa julgada, o mesmo deveria acontecer quando a interpretação da lei federal se consolidasse no Superior Tribunal de Justiça. Não se diga que a diferença entre as duas situações está em que, no caso da declaração de inconstitucionalidade, a coisa julgada se funda em lei inválida, enquanto “uma decisão contra a lei ou que lhe negue vigência supõe lei válida”.¹⁸⁵ Ora, não admitir a rescisória a partir de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal não significa atribuir efeitos a uma lei inconstitucional, mas apenas ressaltar os efeitos de um juízo constitucional que aplicou uma lei posteriormente declarada inconstitucional.¹⁸⁶

Chega-se, assim, ao momento propício para se desnudar o equívoco. Se a ação rescisória é proposta com base em precedente do Supremo Tribunal Federal, o seu fundamento não é violação de norma constitucional. O fundamento encontrado, mas não expressamente revelado, é *ius superveniens* ou direito superveniente. Porém, como é curial, o *ius superveniens* não pode ter efeito retroativo sobre a coisa julgada.

Portanto, a Súmula 343 também deve ser aplicada nos casos de resolução de questão constitucional. A tentativa de eliminar a coisa julgada que resultou de uma dúvida de constitucionalidade não só elimina o mínimo que o cidadão pode esperar do Poder Judiciário – que é a estabilização da sua vida após o encerramento do processo –, como também descon sidera a legitimidade dos juízes e tribunais para o controle incidental da constitucionalidade.¹⁸⁷

10.14.4. “Controle da constitucionalidade da decisão transitada em julgado”, ou melhor, negação do controle incidental de constitucionalidade. Diante de tudo isso, encontrar fundamento para a ação rescisória em pronunciamento do Supremo Tribunal Federal significa mais do que a instituição de um inusitado “controle da constitucionalidade da decisão transitada em julgado” – significa destituir os juízes e tribunais do controle incidental da constitucionalidade.

Sem dúvida, a admissão da força de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a coisa julgada representa a negação do nosso sistema de controle de constitucionalidade.

10.14.5. A transformação da coisa julgada num juízo suscetível a condição imprevisível. Ademais, se ulterior precedente torna a coisa julgada rescindível, não há decisão, tomada em controle incidental de constitucionalidade, que tenha alguma utilidade. A decisão proferida em controle incidental, embora possa produzir efeitos desde logo, sempre coloca o jurisdicionado em estado de espera, sujeitando-o a uma decisão mais do que inútil; submetendo-o a uma decisão que, em vez de resolver o litígio e criar uma confiança legítima, amplifica a litigiosidade latente e potencializa os males e as angústias decorrentes da pendência da ação, deixando perceptível que o processo que se desenvolveu com custos de todos os matizes talvez fosse desnecessário.¹⁸⁸

Perceba-se que tal raciocínio leva à conclusão de que uma decisão que produz coisa julgada material, e é legitimamente proferida pelo juiz, não gera qualquer proteção à confiança nela depositada.¹⁸⁹ Ora, admitir esta conclusão significa colocar o jurisdicionado na posição de alguém que pode ser “legitimamente” surpreendido depois de ter obtido decisão jurisdicional favorável transitada em julgado. Não é preciso dizer que isso viola, de forma escancarada, a segurança jurídica, princípio concretizador do Estado de Direito.

A aceitação da retroatividade do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre as decisões proferidas pelos tribunais significa colocar a coisa julgada sob condição ou em estado de provisoriedade, o que é absolutamente incompatível com o conceito e com a razão de ser da coisa julgada. Aliás, a coisa julgada não é apenas condição para a proteção da segurança jurídica, como também necessidade indispensável para a existência de discurso jurídico e, portanto, de processo jurisdicional.¹⁹⁰

Assim, é até mesmo difícil – para não se dizer contrário aos fundamentos do direito – definir a natureza da decisão que fica sob a condição de o Supremo Tribunal Federal não a contrariar. Essa decisão, por não ser dotada do devido recrudescimento, não configura verdadeira “decisão final”,

mas mero juízo provisório. Constitui, bem vistas as coisas, um juízo sob condição negativa imprevisível e temporalmente insuscetível de dimensionamento.¹⁹¹

Lembre-se que o permissivo inconstitucional da ação rescisória fundada em ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal não se contentou com pouco. O § 15 do art. 525 teve o cuidado de dizer que o prazo da ação rescisória deve ser “contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”, o que toca às raízes do absurdo.

10.14.6. Resguardar uma decisão fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional não significa admitir efeitos a uma lei declarada inconstitucional. Por outro lado, a decisão em controle incidental de constitucionalidade é tão legítima quanto a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ambas provêm do Poder Judiciário e são legitimadas pela Constituição.

O equívoco não expresso, implícito nas decisões que admitem o desfazimento da coisa julgada em virtude de ulterior precedente do Supremo Tribunal Federal, está em não perceber que admitir uma decisão fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional não é o mesmo que admitir eficácia a uma lei declarada inconstitucional. Como é óbvio, respeitar a coisa julgada não significa reconhecer efeitos a uma lei inconstitucional, mas reconhecer efeitos a um juízo precedente sobre a inconstitucionalidade, diferente do juízo posteriormente feito na decisão de inconstitucionalidade da Corte Suprema.¹⁹²

Bem por isso, não há como aceitar o argumento de que a retroatividade do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a coisa julgada é imprescindível para fazer valer a plenitude da Constituição. Não se pense que a rescisão da coisa julgada fundada em lei declarada inconstitucional constitui a afirmação da constitucionalidade sobre a inconstitucionalidade. A decisão, ainda que fundada em lei inconstitucional, é constitucional.¹⁹³

A decisão, mesmo que fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional, é manifestação legítima do Poder Judiciário.¹⁹⁴ A coisa julgada que cobre essa decisão é imprescindível à tutela da segurança jurídica e à proteção do sistema de controle incidental de constitucionalidade. Assim, é equivocado relacionar afirmação da constitucionalidade com relativização da coisa julgada, uma vez que a coisa julgada é, inegavelmente, uma afirmação da Constituição.¹⁹⁵ Na realidade, o problema não está na opção entre privilegiar a plenitude da Constituição ou, ao contrário, a certeza do direito declarado judicialmente, porquanto a certeza do direito declarado judicialmente (ainda que inconstitucional) é ela própria uma das formas de que se reveste a certeza constitucional.¹⁹⁶

10.14.7. O verdadeiro fundamento que se pretende conferir à ação rescisória: retroatividade do ius superveniens sobre a coisa julgada. Não pode haver dúvida que se uma norma gera dúvida constitucional, expressa pela circunstância de existir dúvida interpretativa no controle incidental da constitucionalidade realizado pelos juízes e pelos tribunais, a decisão que adota uma das interpretações razoáveis não pode ser rescindida. Na realidade, pouco importa, para efeito de rescindibilidade, se a norma é constitucional ou infraconstitucional, já que ambas podem gerar dúvida interpretativa e, nessa dimensão, excluir a ação rescisória.

Portanto, a ação rescisória que se dirige contra decisão que tratou de questão prejudicial sobre a qual recaía divergência interpretativa não é fundada em violação de norma, mas em ius superveniens. Isso se torna evidente quando se percebe que esta rescisória não se preocupa com o teor da decisão rescindenda, ou seja, com a circunstância de a decisão ter ou não violado manifestamente uma norma, bastando para a procedência do pedido apenas um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal com sinal contrário ao da decisão rescindenda.

Sustenta-se que a ação é fundada em “violação de norma jurídica” (art. 966, V, CPC) porque não há, nem poderia haver, ação rescisória amparada em ius superveniens.

10.14.8. A inexistência de distinção entre decisão proferida em controle principal e controle incidental para efeito de rescindibilidade de coisa julgada. Como é evidente, não há qualquer razão para distinguir decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade de

decisão tomada em recurso extraordinário quando se pensa na possibilidade de rescindibilidade de coisa julgada com base em ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

A decisão proferida no controle principal, assim como a decisão proferida no controle incidental, não pode negar a coisa julgada. Ambas são interpretações judiciais posteriores à coisa julgada, embora a decisão proferida no controle incidental não tenha eficácia erga omnes, mas apenas eficácia obrigatória ou vinculante em relação aos seus fundamentos determinantes. Sucede que isso não tem qualquer importância para o efeito de se ter como inválida uma decisão antecedente, revestida por coisa julgada material. A decisão de inconstitucionalidade proferida no controle principal, não obstante tenha eficácia erga omnes, obviamente não tem eficácia retroativa.

A diferenciação das decisões proferidas nos controles principal e incidental, para efeito de rescindibilidade da coisa julgada, faria supor que a decisão de inconstitucionalidade é algo distinto de uma decisão judicial ou de uma decisão interpretativa de questão constitucional. A decisão de inconstitucionalidade proferida em ação direta nada mais é do que um juízo sobre a constitucionalidade, que, por isso mesmo, não pode se sobrepor a um anterior juízo também legítimo sobre a constitucionalidade, tutelado pela coisa julgada. Não é possível negar a coisa julgada sob a equivocada desculpa de se ter encontrado uma “norma verdadeira” ou uma “interpretação correta”, que jamais poderia ter sido negada para não se violar a Constituição. Como já dito, a rescisão da coisa julgada fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional não constitui afirmação da constitucionalidade sobre a inconstitucionalidade, já que a certeza do direito declarado judicialmente, ainda que inconstitucional, é uma das formas de que se reveste a certeza constitucional.¹⁹⁷

10.14.9. O precedente firmado no Recurso Extraordinário 590.809: a garantia constitucional da coisa julgada material exclui a possibilidade de ação rescisória baseada em ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, julgou recurso extraordinário que definiu a questão do cabimento de ação rescisória fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal posterior à decisão rescindenda.¹⁹⁸ Decidiu-se expressamente sobre a aplicação da Súmula 343-STF em ação rescisória fundada em violação de norma constitucional, ou melhor, sobre se a admissão da ação rescisória baseada em posterior precedente do Supremo Tribunal Federal é compatível com a tutela da coisa julgada material.

O precedente firmado nesse recurso extraordinário revogou o entendimento que até então prevalecia no Supremo Tribunal Federal,¹⁹⁹ declarando que decisão do Supremo Tribunal Federal, ulterior ao trânsito em julgado da decisão, não pode servir de fundamento para a ação rescisória. Declarou-se, ainda, que a Súmula 343 é aplicável em ação rescisória fundada em violação de norma constitucional, de modo que, quando há divergência interpretativa à época da prolação da decisão rescindenda, a ação rescisória não é viável. Decidiu-se, ademais, que a invocação de precedente constitucional ulterior à formação da coisa julgada, para o efeito de rescindi-la, é incompatível com a garantia constitucional da coisa julgada material. Ou seja, não só se ressaltou a coisa julgada em face de precedente constitucional em sentido diverso, como ainda se afirmou que a coisa julgada é garantida pela Constituição Federal.

O recurso extraordinário foi provido por sete votos a dois. Os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello, Luiz Fux, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski adotaram o fundamento de que novo entendimento ou precedente do Supremo Tribunal Federal não pode constituir base para a rescisão de decisão que com ele confronta. A Ministra Carmén Lúcia disse que a decisão rescindenda, por ter se pautado em entendimento que prevalecia no Supremo Tribunal Federal na época em que proferida, não poderia ser rescindida. O Ministro Toffoli reconheceu a decadência da ação rescisória e não se manifestou sobre a questão da possibilidade da desconstituição de decisão com base em precedente ulterior do Supremo Tribunal Federal. Os Ministros Gilmar e Teori dissentiram do fundamento da maioria, reafirmando as suas antigas posições.²⁰⁰

Disse o relator, Ministro Marco Aurélio: “a rescisória deve ser reservada a situações excepcionabilíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no

art. 485 do CPC [de 1973], incluído o constante do inc. V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete [Súmula 343/STF], não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica”. Essa passagem deixa clara a aplicabilidade da Súmula 343 mesmo em caso de interpretação de norma constitucional. Aplicando-se a Súmula 343, decidiu-se que não cabe ação rescisória, fundada em violação de norma constitucional, quando à época em que a decisão foi proferida havia controvérsia sobre a interpretação da norma.

Mas o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o precedente, não só tratou da aplicabilidade da Súmula 343. Ao enfatizar que novo entendimento do Supremo Tribunal Federal não pode ser visto como fundamento de ação rescisória, a Corte Suprema também declarou a tutela constitucional da coisa julgada material. Nas palavras do Ministro relator: “Não posso admitir, sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa apriorística do mencionado verbete [Súmula 343/STF], como se a rescisória pudesse “conformar” os pronunciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, mesmo considerada a interpretação da norma constitucional”.

A ementa do acórdão consignou que “o verbete n. 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”.²⁰¹ Ou seja, a ementa ressaltou a possibilidade de a ação rescisória ser utilizada com base em decisão proferida em “controle concentrado”. Porém, não obstante a circunstância de o próprio relator ter abordado esta questão de passagem, sem defini-la, a questão de se a decisão proferida em controle principal constitui base para ação rescisória não foi posta para julgamento ou, ainda, não constituía fundamento suficiente para se decidir se precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de controle principal, pode determinar a desconstituição da coisa julgada.

Sublinhe-se o que disse o próprio relator, Ministro Marco Aurélio: “Na origem, o acórdão foi rescindido para conformá-lo à decisão deste Tribunal no sentido de o alcance do princípio da não cumulatividade não autorizar o lançamento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI em decorrência da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Vê-se não se tratar de referência a ato por meio do qual o Supremo assentou, com eficácia maior, a inconstitucionalidade de norma. Estivesse envolvida declaração da espécie, poderia até cogitar, com muitas reservas, do afastamento do verbete em favor do manejo da rescisória apenas para evitar a vinda à baila indiscriminada de decisão judicial, transitada em julgado, fundada em norma proclamada inconstitucional, nula de pleno direito. Mas não é este o caso ora examinado. Pretende-se, na realidade, utilizar a ação rescisória como mecanismo de uniformização da interpretação da Carta, particularmente, do princípio constitucional da não cumulatividade no tocante ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, olvidando-se a garantia constitucional da coisa julgada material”.²⁰² O relator foi incisivo ao dizer que não estava envolvida decisão proferida em controle principal e, mais do que isso, que, caso “estivesse envolvida”, a cogitação sobre ação rescisória poderia ser feita “com muitas reservas”. Ora, se uma questão é reconhecida como fora do julgamento (“estivesse envolvida”) e é admitida como não decidida (“poderia até cogitar, com muitas reservas”), ela certamente constitui obiter dictum.

De qualquer forma, as mesmas razões que impedem a retroatividade da decisão proferida em recurso extraordinário sobre a coisa julgada impedem a retroatividade da decisão proferida em controle principal. Ora, se ulterior decisão de inconstitucionalidade, ainda que proferida em ação direta, tornar a coisa julgada rescindível, não haverá decisão, tomada em controle incidental de constitucionalidade, dotada de alguma utilidade; a coisa julgada sempre será provisória e sujeita a condição resolutiva, o que é uma contradição em termos. Lembre-se que a decisão judicial, mesmo que fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional, é manifestação legítima do Poder

Judiciário e que a coisa julgada que cobre essa decisão é imprescindível à tutela da segurança jurídica e à proteção do sistema de controle incidental de constitucionalidade.

10.14.10. A irretroatividade da decisão de constitucionalidade sobre a sentença que deixou de aplicar a lei por reputá-la inconstitucional. Os mesmos fundamentos que demonstram o descabimento da retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada evidenciam a impropriedade da retroatividade da decisão de constitucionalidade sobre a coisa julgada.

A sentença que deixa de aplicar uma lei, reputando-a inconstitucional, é uma sentença legítima se, no instante da sua prolação, não havia declaração de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. O juiz que proferiu essa sentença, ao fazer o seu juízo acerca da questão de constitucionalidade, nada mais fez do que cumprir o seu dever jurisdicional de controle da constitucionalidade no caso concreto.

Não obstante a decisão seja sempre um ato autônomo e desprendido da lei, é importante esclarecer que a decisão que não aplica uma lei mais tarde declarada constitucional não pode sequer ser comparada com a decisão que aplica lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Se a decisão não aplica uma lei que vem a ser declarada constitucional, isso não quer dizer que tenha aplicado uma lei inconstitucional. Em regra, a decisão que não aplica determinada lei, posteriormente declarada constitucional, não aplica lei inconstitucional. E, se aplicar lei que venha a ser declarada inconstitucional, a questão voltará a ser a da retroatividade da decisão de inconstitucionalidade.

Alguém poderia argumentar, porém, que é necessário distinguir o juízo interpretativo que entendeu por bem aplicar lei constitucional distinta da invocada pela parte do juízo que aplicou outra lei sob o fundamento de a lei deduzida pela parte ser inconstitucional. Dir-se-ia que em um caso o juiz simplesmente não aplicou a lei, enquanto, no outro, o juiz considerou a lei inconstitucional.

Note-se, porém, que em nenhum dos casos há sequer potencialidade de violação de norma constitucional. A situação, na hipótese de declaração de constitucionalidade, é completamente distinta daquela de declaração de inconstitucionalidade. Ou melhor, na segunda hipótese se pode falar de decisão que aplica lei inconstitucional, mas, na primeira, não há aplicação de lei inconstitucional ou violação de norma constitucional, porém simplesmente não aplicação de norma infraconstitucional.

Na verdade, para efeito de legitimidade da decisão diante de posterior declaração de constitucionalidade, não importa o motivo pelo qual se deixou de aplicar a norma. Se o juiz entendeu que a norma era constitucional, mas não aplicável ao caso concreto, a posterior declaração da sua constitucionalidade obviamente em nada poderá afetar a coisa julgada. Mas, se o juiz afirmou a inconstitucionalidade da norma para aplicar outra, a declaração de constitucionalidade também não terá o efeito de interferir sobre o juízo antes feito, que é tão legítimo quanto aquele que não aplicou a lei apenas por entendê-la inaplicável ao caso concreto.

Ademais, o jurisdicionado tem uma confiança legítima depositada na decisão que não aplicou a lei. Assim, a nulificação da coisa julgada em virtude da decisão de constitucionalidade tomada pelo Supremo seria pouco mais do que absurda.²⁰³

11. Falsidade da prova que determinou a decisão rescindenda, apurada em processo criminal ou na própria ação rescisória. O art. 966, VI, prevê a rescindibilidade da decisão “fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”.²⁰⁴ Esse inciso reproduz o VI do art. 485 do CPC/1973, cuja letra foi copiada.

A regra não restringe a rescindibilidade à decisão fundada em documento falso.²⁰⁵ Também

não afirma que somente é possível tomar em conta a falsidade material. Porém, a admissão da invocação da falsidade das alegações testemunhais e que fundamentaram a conclusão pericial²⁰⁶ pode significar a abertura para a rediscussão do caso ou das alegações, o que certamente está muito longe de constituir a pretensão da ação rescisória.

É difícil entender o motivo pelo qual a doutrina brasileira sempre tratou tão superficialmente a questão da rescisória baseada em prova falsa. Barbosa Moreira, por exemplo, ao tratar do ponto que realmente interessa neste tema, limita-se a dizer o seguinte: “A prova falsa pode ser de qualquer natureza. Não distingue a lei entre falsidade material e falsidade ideológica. Tampouco exige que não se tenha suscitado, no processo em que surgiu a sentença rescindenda, a questão da falsidade, nem que ao interessado não haja sido possível suscitá-la naquele processo, v.g., porque só depois veio a ter conhecimento da falsidade”.²⁰⁷ Note-se que a circunstância de a regra nada afirmar sobre a possibilidade de ser rediscutida a questão da falsidade obviamente não é sinal suficiente de que se possa admitir o resultado de que isso é possível. A solução não apenas é superficial; a interpretação é frágil e inadequada.

Portanto, é preciso esclarecer, em primeiro lugar, que a invocação de falsidade só tem razão de ser quando a decisão se fundou em documento materialmente falso, em conteúdo falso de documento, em alegação testemunhal falsa e em conclusão pericial baseada em afirmação ou premissa falsa.²⁰⁸ A falsidade deve ter determinado a decisão.²⁰⁹ Vale dizer que a falsidade só tem relevância para efeito de rescisória quando a decisão não se sustenta com base em outro fundamento.²¹⁰

Não cabe invocar a falsidade de alegação – testemunhal ou tomada em conta em laudo pericial – cuja correspondência com a “verdade” foi discutida e objeto de valoração judicial no processo em que proferida a decisão que se pretende rescindir. A alegação contida em depoimento testemunhal, para poder permitir a rescisão da decisão, não pode ter sido questionada pela parte prejudicada e, assim, valorada pelo juiz. A “veracidade-falsidade” que depende da versão de alguém, uma vez debatida, sempre será apenas rediscutida, o que obviamente não pode permitir ação rescisória. Também a premissa contida no laudo pericial, uma vez discutida ou posta em dúvida pelos assistentes das partes, não pode voltar a ser rediscutida para se pretender evidenciar a falsidade da prova pericial. É que, dessa forma, não se estaria rescindindo decisão fundada em prova falsa, mas rescindindo decisão que se fundou em prova que contém alegação que foi valorada como correspondente à verdade pelo juiz.

Perceba-se, no entanto, que uma prova pericial pode necessitar i) de dados que estão presentes em documentos, ii) de relatos sobre fatos pretéritos ou mesmo iii) de opiniões técnicas acerca de determinadas substâncias, produtos ou atividades. Se os dados são extraídos de documentos, a falsidade está no documento. Quando o perito ouve pessoas a respeito de fatos pretéritos, falsa é a versão sobre o fato. Porém, há que se distinguir informação técnica e opinião técnica. Uma informação técnica submete-se ao critério do verdadeiro-falso, na medida em que se informa X ou Y. A “opinião” técnica é o juízo de um especialista sobre uma questão que necessita ser esclarecida a partir de conhecimentos, raciocínio e juízo técnico. O juízo ou a opinião do especialista não se submete aos critérios do verdadeiro-falso. É possível dizer que a opinião do especialista está baseada em premissas inadequadas ou que não está devidamente fundamentada; mas não se pode afirmar que um juízo é falso, a menos, é óbvio, que tenha se pautado em premissas falsas ou tenha desconsiderado a realidade inconteste.

Isso quer dizer que a rescisória baseada em prova pericial falsa, a princípio, só tem cabimento em casos i) de documento falso, ii) de relato falso sobre fato pretérito e iii) de informação técnica falsa. Nas duas últimas hipóteses, quando a correspondência com a verdade do relato ou da informação técnica não foi objeto de discussão e valoração judicial. Note-se, contudo, que também é possível invocar a falsidade da prova pericial quando essa nega documento juntado no processo ou a realidade inconteste e clara.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo casos de ação rescisória em que se invoca falsidade de prova pericial. Na AR 1.291/SP, a 1ª. Seção argumentou que “o cotejo entre o laudo efetuado na ação originária e o laudo pericial (fls. 433/568), coadjuvado pelos esclarecimentos (fls.

831/840), ambos realizados pelo perito judicial nomeado na presente rescisória, revela evidente descompasso entre o laudo pericial, embasador do decisum rescindendo, e a realidade fática encartada nos autos, máxime porque realizado à revelia de fatos essenciais ao deslinde da controvérsia (fl. 476), in casu, a localização da área objeto de desapropriação, fato ensejador de apuração de quantum indenizatório divorciado da realidade e, por isso, conducente ao reconhecimento de sua falsidade, com supedâneo no art. 405, VI, do CPC (...) Consectariamente, comprovando à saciedade a falsidade ideológica da prova (art. 485, VI, do CPC), como ocorre no caso dos autos, é mister concluir-se pela procedência do pedido neste particular”.²¹¹ Ao que parece, a falsidade nesse caso está na divergência entre o local (da área desapropriada) tomado em conta pela prova pericial e a verdadeira localidade. É claro que o perito, para definir o valor da desapropriação, não pode deixar de individualizar a área e a sua localização, para o que é necessário um documento. Quando se pensa em documento capaz de evidenciar a localidade da área, a prova pericial é falsa quando se funda em documento falso ou quando nega documento idôneo. Quando não há documento capaz de permitir a identificação da área e há trabalho pericial para a sua individualização, é possível pedir a rescindibilidade com base em prova falsa apenas quando a conclusão pericial nega a verdadeira localidade sem com que a localização da área tenha sido objeto de prévia discussão pelas partes e de valoração pelo juiz. Não exclui a ação rescisória, portanto, a mera divergência do assistente ou a impugnação da parte; a rescisória apenas não cabe quando o juiz elaborou juízo sobre a localidade da área, valorando o trabalho pericial que a individualizou.

No caso em que se tem em consideração uma alegação – a versão de alguém –, só a desatenção quanto à sua correspondência com a verdade pode justificar a pretensão à rescindibilidade. Não é por acaso que, em regra, a prova falsa só pode justificar a rescisão de decisão quando é um documento em sentido técnico, ou seja, uma “coisa” que tem valor probante em si, mas que foi adulterada ou contém declaração falsa realizada por aquele que presencia ou tem o fato para elaborar o documento (e não apenas o considera como simples fato passado – o que dá origem à prova documentada; nunca a documento).

Nessa dimensão é realmente preciso distinguir documento de versão sobre fato pretérito posta em papel – a que se costuma denominar – de modo equivocado – de documento. O depoimento testemunhal ou a informação coletada pelo perito para fundamentar o laudo, nada mais são do que afirmações postas em papel, e não propriamente documentos. Como diz Carnelutti, “quem descreve por escrito um fato, enquanto o apercebe, forma um documento, porque quer representar no futuro o fato presente mediante o escrito formado; quem descreve por escrito um fato, que notou anteriormente, forma um testemunho porque quer representar atualmente um fato passado mediante o ato de escrever. Há uma atividade humana de idêntica aparência nos dois casos, mas de diversa substância: no primeiro o homem não fornece mais que o meio; no segundo fornece também a matéria da representação, já que o fato não existe mais fora, mas apenas dentro dele; no primeiro forma um aparato (exterior) para conservar o (a memória do) fato; no segundo o extrai de si mesmo, onde está conservado”.²¹² O documento representa por si o fato; é o elemento representativo do fato. O mesmo não ocorre, porém, quando a pessoa fornece a matéria da representação e é utilizado um pedaço de papel para reproduzi-la. Para ficar mais claro, é preciso perceber que tudo isso quer dizer que a representação documental é imediata, enquanto a testemunhal é mediata; enquanto “na primeira a individualidade do fato a ser representado traduz-se imediatamente em um objeto exterior; na segunda fixa-se imediatamente na memória de um homem e somente através desta se reproduz na representação”.²¹³

Isso tem importância apenas por poder demonstrar que mediante o documento o juiz conhece o fato sem a mediação de outra pessoa – que o reelabora. A interferência humana no fato cinge-se à formação do documento. Ao contrário do que acontece na prova testemunhal e na prova pericial, não há formação de juízo sobre o fato a partir da sua reconstrução ou da versão de outro a seu respeito.²¹⁴

Ora, quando um fato que tem versão testemunhal ou constitui premissa da conclusão pericial é debatido, questionando-se a sua adequada versão, bem como valorando-se as provas respectivas, não há racionalidade em retomar a sua discussão para identificar se a versão considerada pelo

juiz é falsa, na medida em que isso simplesmente seria rediscutir qual é a versão verdadeira.

Por outro lado, se as afirmações contidas em documento foram equivocadamente nele escritas – por lapso ou dolo, não importa –, o documento não é apto para representar o fato e, portanto, é falso. Se o juiz utilizou esse documento para decidir, sem que tenha ocorrido devida discussão e expressa decisão judicial afirmando a não falsidade (art. 503, § 1.º, CPC), cabe ação rescisória. Do mesmo modo, uma vez arguida a falsidade documental material – ou mesmo intelectual em caso de documento narrativo²¹⁵ –, a decisão que declarar a não falsidade certamente não poderá ser afrontada mediante ação rescisória.

Significa, portanto, que a ação rescisória só pode se basear em prova falsa quando não se discutiu sobre o fato declarado na prova (testemunhal ou pericial) ou quando não se discutiu e decidiu sobre o tema da falsidade (de documento propriamente dito), seja enquanto questão prejudicial nos termos do art. 503, § 1.º, seja mediante “arguição” de falsidade, conforme o art. 430 e ss. do CPC.

Lembre-se, contudo, que se a falsidade for “apurada em processo criminal” também é possível propor ação rescisória com base no art. 966, VI. Se houve reconhecimento do falso no processo criminal, o juízo a ser feito na rescisória parte necessariamente da declaração de falsidade, que não poderá ser negada na ação rescisória. Mas essa poderá não ser julgada procedente, por exemplo, se a decisão rescindenda não tiver se fundado na prova invocada como falsa ou se tiver outro fundamento suficiente para lhe dar sustentação. A decisão tomada no processo criminal também interfere sobre o juízo da rescisória quando reconhece a inexistência da falsidade. Assim acontecendo, não há como haver juízo sobre a falsidade na ação rescisória.

Tratando-se de falsidade do mesmo documento decidida com autoridade de coisa julgada em processo entre parte da ação rescisória e terceiro – seja em virtude de arguição de falsidade seja em razão de a questão ter sido decidida nos termos do art. 503, § 1.º –, a coisa julgada pode ser invocada por uma das partes da ação rescisória em detrimento da outra, em conformidade com o art. 506 do CPC. Recorde-se que a coisa julgada apenas não pode prejudicar aquele que não participou do processo em que a questão é decidida. Assim, se a falsidade foi reconhecida contra A em processo em que participou adequadamente, B pode propor ação rescisória em face de A invocando a coisa julgada formada em seu benefício. Afinal, A teve oportunidade de discutir a questão da falsidade e B, ainda que não tenha participado do processo em que decidida a falsidade do documento, pode invocar a coisa julgada em seu favor.

Por fim, é evidente que não se pode invocar a falsidade da presunção em que a decisão se fundou para se pedir a sua rescisão. Presunção obviamente não é prova. A presunção é o resultado do raciocínio que o juiz elabora para chegar ao fato principal ou direto a partir do fato indiciário. Tal raciocínio, como não poderia deixar de ser, necessita de uma prova sobre o fato indiciário. A prova indiciária incide sobre fato externo, que se liga a algum fato da causa mediante raciocínio lógico. Por meio da prova indiciária são provados fatos indiciários, dos quais se pode deduzir o fato direto. De modo que apenas pode existir falsidade na prova indiciária.

12. Prova nova. O inc. VII do art. 966 prevê como fundamento de rescisão a “prova nova”, obtida posteriormente ao trânsito em julgado, que o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Ao contrário do inc. correspondente do art. 485 do CPC/1973, o inc. VII do art. 966 alude a “prova nova”. Assim, deixa de limitar a “prova nova” ao “documento novo”. Agora a ação rescisória também é cabível quando prova testemunhal ou prova pericial podem assegurar pronunciamento favorável.

É certo que a prova testemunhal não tem a mesma aptidão para convencer do que as provas documental e pericial. Contudo, é possível que uma testemunha fundamental, capaz de evidenciar fato imprescindível para julgamento favorável, tenha sido “descoberta” ou tenha se tornado capaz de depor apenas depois de superada a fase instrutória – suponha-se, por exemplo, uma pessoa que estava em estado nervoso ou psicológico que lhe impedia de depor ou a posterior ciência de que

determinada pessoa tinha pleno conhecimento dos fatos.

A ideia de “prova nova” em substituição a “documento novo” certamente tem relação com as novas tecnologias capazes de evidenciar fatos, como, por exemplo, o exame “DNA”. Na verdade, a prova de “DNA” é o caso exemplar que deu origem à eliminação da restrição ao documento. Como demonstrado à época do CPC/1973,²¹⁶ se o exame de DNA pode alterar o julgamento fixado na sentença acobertada pela coisa julgada, o correto seria interpretar tal exame como uma “prova nova” que não pôde ser utilizada, mas que é capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável.

O inc. VII do art. 485 CPC/1973 falava em “documento novo” capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável, enquanto o exame de DNA é uma técnica ou prova pericial capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável. Portanto, a diferença entre exame de DNA e documento era apenas formal, uma vez que ambos têm igual capacidade de convencer e de assegurar resultado diverso ao da decisão rescindenda. E o que importa, para se equiparar o exame de DNA ao documento para fins de rescisória, é exatamente a capacidade de produzir convencimento suficiente para assegurar resultado favorável. Como se vê, bastava somente adequar o significado de “documento novo” à realidade da vida, isto é, à descoberta do exame de DNA.²¹⁷

Se a adequada interpretação era suficiente para que a regra processual passasse a fundamentar rescisória baseada em exame de DNA, chega a ser incompreensível a razão pela qual se pensava na relativização da coisa julgada em tal hipótese. Lembre-se que a 2.ª Seção do Superior Tribunal de Justiça chegou a declarar, à época do CPC/1973, que “o laudo do exame de DNA, mesmo posterior ao exercício da ação de investigação de paternidade, considera-se ‘documento novo’ para aparelhar ação rescisória (CPC/1973, art. 485, VII). É que tal exame revela prova já existente, mas desconhecida até então. A prova do parentesco existe no interior da célula. Sua obtenção é que apenas se tornou possível quando a evolução científica concebeu o exame intracitológico”.²¹⁸ Embora exista nesse julgado um pequeno equívoco, a sua substância confirma a ideia de que o exame de DNA podia ser visto como um “documento novo”. O equívoco da decisão está em dizer que o exame de DNA “revela prova já existente, mas desconhecida até então”, sob o argumento de que “a prova do parentesco existe no interior da célula. Sua obtenção é que apenas se tornou possível quando a evolução científica concebeu o exame intracitológico”. Note-se que a decisão diz que “a prova do parentesco existe no interior da célula” e que só se tornou possível com a “evolução científica”. Porém, há aí confusão entre meio de prova e objeto da prova. O que existia era o DNA, como objeto de prova, e não a técnica ou o meio de prova.

A rescisória, como é óbvio, não pode ser admitida com base em um novo objeto de prova. O objeto da prova tem de ser o mesmo, sob pena de se estar diante de uma nova ação (quando a ação rescisória não seria sequer necessária) ou em face de um fato que já deveria ter sido alegado e que, assim, está coberto pelo princípio do deduzido e do dedutível. O que funda a rescisória é a existência de um novo meio de prova, capaz, por si só, de assegurar resultado favorável. Ora, a parte só pode deixar de fazer uso de um meio de prova. É evidente que o autor da rescisória não pode alegar que não pôde fazer uso do objeto da prova ou do DNA, mas apenas que não pôde fazer uso do exame de DNA, fruto da evolução da ciência. De qualquer modo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, de grande sensibilidade jurídico-social, inseriu o exame de DNA no conceito de “documento novo” e, dessa forma, admitiu a ação rescisória com base em meio de prova descoberto posteriormente à decisão rescindenda, sinalizando para a norma que está presente no inc. VII do art. 966.

Todavia, o problema no CPC/1973 ia além, uma vez que o exame de DNA certamente poderia ter se tornado viável depois de escoado o prazo decadencial de dois anos, que era previsto para todas as hipóteses de ação rescisória.²¹⁹ Isso gerava perplexidade, uma vez que o prazo de dois anos pode ser visto como muito reduzido quando se pensa em meio de prova que pode surgir depois do trânsito em julgado, mas certamente não se pode deixar a ação rescisória sem qualquer prazo. O CPC/2015 previu termo diferenciado para o início da fluência do prazo para a propositura da ação rescisória fundada em “prova nova”, bem como para a sua decadência. De acordo com o art. 975,

§ 2.º, “se fundada a ação no inc. VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Em face do CPC/1973, que se referia a “documento novo” e não a “prova nova”, afirmava-se que o documento deveria existir à época em que os fatos eram discutidos no processo em que proferida a decisão rescindenda. Assim, por exemplo, dizia Barbosa Moreira que “documento ‘cuja existência’ a parte ignorava é, obviamente, documento que existia; documento de que ela ‘não pôde fazer uso’ é, também, documento que, noutras circunstâncias, poderia ter sido utilizado, e portanto existia”.²²⁰

Porém, quando a rescindibilidade passa a depender de “prova nova”, isto é, não apenas de documento, mas também de prova testemunhal e prova pericial, é certo que não se pode pensar em prova que existia. Em primeiro lugar, não se pode falar em prova existente, na medida em que a prova obviamente não pode ter sido produzida e, portanto, existir enquanto prova. Tratando-se de prova testemunhal, o que existia é a fonte da prova, ou seja, a testemunha, que, v. g., não pôde depor por estar em local desconhecido ou por estar em condição de saúde que lhe impedia de prestar depoimento. No entanto, no que diz respeito à prova pericial, essa se torna admissível para fundar a rescisória quando o meio técnico ou a tecnologia que permite a produção da prova pericial não existia. Aliás, nem mesmo a existência do documento pode ser vista como absoluta, embora em regra este deva existir.²²¹ Pense-se, como exceção, no documento público que apenas pôde ser confeccionado posteriormente.

O documento e as provas testemunhal e pericial só podem ser aceitos em ação rescisória quando dizem respeito a fatos articulados na ação que deu origem à decisão rescindenda. Obviamente não há como tentar provar fato que não foi alegado no processo anterior. Isso significaria propor outra ação ou violar a regra do deduzido e do dedutível, conforme o caso.²²²

A ação rescisória só é cabível quando a prova não pôde ser produzida por circunstância alheia à vontade da parte. Como é óbvio, seria irracional admitir rescisória caso a prova pudesse ter sido requerida anteriormente. Assim, só é possível invocar “prova nova” quando, por exemplo: i) a testemunha era desconhecida, não foi localizada ou estava impossibilitada de depor; ii) o documento era desconhecido ou estava em local que não se sabia qual ou na posse de depositário não localizado; e iii) o documento sobre o qual a perícia deveria recair não pôde ser encontrado ou não existia o meio ou a técnica capaz de permitir a elucidação do fato. Portanto, ou a parte “ignorava” o documento ou a parte “não pôde fazer uso” – também, por exemplo – da técnica destinada à prova pericial. Significa que o autor da ação rescisória deve demonstrar que determinada circunstância alheia à sua vontade impediu a produção da prova.

No direito italiano,²²³ em que a revocazione satisfaz-se apenas com “documento novo”, discute-se se essa é cabível quando a parte deixou de requerer a exibição de documento – que conhecia a existência – e mesmo quando aquele a quem o juiz ordenou a exibição não cumpriu a ordem, uma vez que o juiz deve, neste caso, extrair consequências do comportamento da parte para racionalizar e fundamentar a sua decisão, nos termos do art. 116 do código.²²⁴ A Corte de Cassação entende que, quando o terceiro não exhibe o documento, é possível invocar documento novo para fundamentar a revocazione.²²⁵ Lembre-se que o raciocínio do direito italiano é pautado no n. 3 do art. 395, que afirma o cabimento da revocazione quando “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”.

Frise-se que a exibição de documento só é necessária quando se sabe que o documento está na posse da parte adversa ou de terceiro. Fora daí, como é óbvio, não se pode pensar que, por não ter sido requerida a exibição, não há como propor ação rescisória com base em documento novo.

Diz o art. 400 do CPC brasileiro que, “ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: i – o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma [alguma] declaração no prazo do art. 398; ii – a recusa for havida por ilegítima”. Além disso, a parte pode requerer que o juiz adote “medidas indutivas,

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido” (art. 400, parágrafo único, CPC). Essas medidas podem ser utilizadas quando a presunção de veracidade se mostrar incabível ou inútil. Isso significa que, quando a presunção de veracidade não for suficiente e o documento não tiver sido obtido em razão da resistência da parte em entregá-lo ou em fornecer a sua localização, o posterior acesso ao documento confere à parte que não pôde anteriormente utilizá-lo a possibilidade de pedir a rescisão da decisão.

Quando o documento não obtido está na posse de terceiro,²²⁶ o posterior acesso ao documento também abre oportunidade à propositura de ação rescisória. Não apenas em razão de que nesta hipótese não se pode falar em presunção de veracidade. Mas também porque, nos casos em que a parte e o terceiro sofrem a multa pecuniária, obviamente não se pode dizer que esta constitui alguma espécie de substitutivo do documento em si.²²⁷

A prova nova, além de recair sobre fato alegado, deve ser capaz de, sozinha, propiciar resultado favorável ao autor. Por isso, o autor deve demonstrar na petição inicial que, caso o juiz houvesse valorado a prova a ser produzida na ação rescisória, o resultado poderia ter sido inverso.²²⁸ É óbvio que não se requer a demonstração de que o resultado seria outro, mas apenas de que o resultado poderia ser outro caso considerada a prova nova.²²⁹ Frise-se, no entanto, que a rescisória não é cabível com base em prova que, para propiciar julgamento favorável, deve ser valorada conjuntamente com as provas produzidas no processo em que firmada a decisão rescindenda. A prova nova não pode ser apenas mais uma prova, não suficiente para assegurar resultado favorável.

Embora o inc. VII aluda a prova obtida posteriormente ao trânsito em julgado, basta que a prova não possa ter sido produzida na fase instrutória. O autor só necessita juntar à petição inicial a prova documental; não há motivo para se ter prova pericial ou testemunhal antecipadamente produzidas. Na verdade, as prova pericial e testemunhal devem ser requeridas na petição inicial. Aliás, a prova documental também é produzida na ação rescisória, embora deva ser acostada à petição inicial.

13. Erro de fato. Também é rescindível a decisão “fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (art. 966, VIII, CPC). De acordo com o § 1.º do art. 966, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

A rescindibilidade depende de a decisão, por erro de percepção, ter admitido como existente fato inexistente ou inexistente fato existente. A decisão, para ser rescindível, deve ter se fundado no fato que não existe ou ter se baseado na inexistência do fato que existe. Em outras palavras, a equivocada suposição da existência ou da inexistência do fato deve ter sido determinante para a resolução do litígio.²³⁰

Não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido. Não se admite erro de fato quando ocorreu erro de juízo.²³¹ No caso em que há dúvida sobre uma afirmação de fato, o juízo sobre esta elimina a hipótese de “erro de fato” que justifica a rescisão da decisão. Como é óbvio, a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso. Também não se admite falar em erro de fato quando se alega a sua equivocada qualificação jurídica.²³²

O erro de fato que abre oportunidade para a ação rescisória é o que recai sobre um fato que, em face dos autos, não se duvida existente ou inexistente. De modo que o erro de fato é o que ressaí de um equívoco na percepção do que está nos autos.²³³ Supõe-se a existência ou a inexistência de um fato em contradição com o que está positivado e claro. A suposição da existência ou da inexistência do fato, evidenciada na fundamentação da decisão, deve contrastar com os elementos que se encontram nos autos e ser verificável mediante o seu exame.²³⁴

Isso significa que o erro de fato pressupõe duas representações contraditórias de um mesmo

fato: uma constante na decisão e outra contida nos autos. Se a primeira diverge da que consta nos autos, resolve-se a divergência em favor da segunda, admitindo-se a rescisão da decisão desde que a primeira representação não decorra de juízo ou de valoração da prova, mas de erro de percepção, e que a segunda derive incontestavelmente dos autos e não tenha sido controvertida pelas partes.²³⁵ Tudo isso quer dizer que jamais se pode cogitar de produção de prova para se tentar demonstrar “erro de fato”. Na verdade, pensar em prova do erro de fato significa confessar a sua inexistência ou simplesmente admitir que o processo anterior foi mal instruído.

Um maior aprofundamento sobre a questão de que o fato não pode representar “ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” permite indagar, na medida em que a regra fala apenas em “exame dos autos”, e não em “exame dos documentos”, se a declaração sobre o fato consignada nas provas testemunhal e pericial, quando não posta em dúvida pelas partes e traduzida em sentido inverso pelo juiz na fundamentação, pode abrir ensejo para ação rescisória fundada em “erro de fato”. Note-se que declaração contida em depoimento testemunhal ou laudo pericial, sem que nenhuma impugnação ou controvérsia tenha ocorrido em relação a ela, por erro de percepção do juiz pode ser traduzida em sentido inverso na fundamentação da decisão. Assim, por exemplo, o laudo pericial pode dizer textualmente que houve redução da produção em determinado período e o juiz, na fundamentação, afirmar que de acordo com a prova pericial não houve qualquer redução de produção no mesmo exato período para julgar improcedente o pedido de ressarcimento por lucros cessantes.

Seria possível dizer que nesse caso o erro não diz respeito a um fato não controvertido, mas a uma declaração de fato contida na prova. Argumentar-se-ia ainda que o erro de fato não pode ter fundamento na comparação entre a decisão e o texto da prova, mas entre a decisão e o que emerge sobre um fato – incontestado – a partir dos autos. Contudo, o erro de fato sempre considera uma declaração contida em prova, ainda que se esteja a considerar um documento (e não uma prova documentada) não impugnado como falso. A real dificuldade, assim, é que se pode pensar que estaria negado o pressuposto da incontestância do fato. Porém, o erro de percepção, nessa última hipótese, não diz respeito ao fato controvertido que foi objeto da prova. Note-se que não se está a falar em juízo sobre o fato considerado na prova nem em valoração da prova. Trata-se, isto sim, de erro de percepção em relação àquilo que está escrito no testemunho ou na perícia. Frise-se que não há controvérsia sobre o que está na prova, embora existisse controvérsia sobre o fato que por ela foi esclarecido.

De modo que, a princípio, um fato não controvertido, verificável mediante o exame dos autos, só pode ser um fato confessado, admitido no processo ou declarado num documento (não numa prova documentada) não impugnado de falso.²³⁶ No entanto, também há erro de fato, capaz de ensejar rescindibilidade, quando o juiz, por erro de percepção, afirma o que não está nas provas testemunhal e pericial para fundamentar a decisão.

Lembre-se que também não se pode falar em erro de fato quando o erro é buscado no texto da decisão, como ocorre no caso de erro material ou de cálculo.²³⁷ O erro de fato, ao contrário do erro de cálculo, é extratextual; não é verificável mediante a análise do texto da decisão, mas a partir dos documentos constantes dos autos.²³⁸ É esta a linha pela qual se deve distinguir erro de fato de erro material ou de erro de cálculo.²³⁹

O § 1.º do art. 966 afirma claramente que é indispensável “que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Deixa-se de lado, assim, a dicção do CPC/1973, que falava que era indispensável que não tivesse “havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato” (art. 485, § 2.º, CPC/1973).

A regra do § 2.º do art. 485 do CPC/1973 permitiu interpretações no sentido de que jamais caberia ação rescisória com base em erro de fato que tivesse sido considerado pelo juiz na fundamentação da decisão. Como é óbvio, isso era despropositado não apenas porque o erro de fato depende de uma afirmação judicial, mas também porque, ao ser assim, só haveria erro de fato se o fato considerado fosse omitido na decisão ou restasse registrado apenas na mente do julgador, o que toca às raias do absurdo.

Na verdade, faltou o discernimento de que só se disse que não poderia haver “pronunciamento judicial sobre o fato” para assentar a impossibilidade de se pretender rescindir decisão que valorou as provas para optar por uma das versões sobre o fato. De forma que o pronunciamento judicial deveria ter sido visto como mera consequência da controvérsia sobre o fato. O CPC/2015 resolveu esse problema ao dizer, no § 1.º do art. 966, que basta “que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Pretendeu-se deixar claro que a ação rescisória não cabe quando o fato é controvertido e, em razão disso, tem que ser analisado com base nas provas dos autos e dito existente ou inexistente pelo juiz. Como é evidente, a controvérsia sobre o fato e a necessidade de o juiz optar por uma versão em detrimento de outra não pode admitir que se fale em “erro de fato”.²⁴⁰

Portanto, quando o juiz trata na decisão de fato incontroverso, que por isso não precisaria ser objeto da sua análise e “pronunciamento” para a resolução do litígio, cabe ação rescisória se existir erro na percepção do fato, considerando-se existente fato inexistente ou inexistente fato existente. Assim, por exemplo, em caso em que a decisão rescindenda atribuiu à parte, por errônea percepção dos seus estatutos sociais, uma atividade social que não possuía, o Supremo Tribunal Federal admitiu a existência “de fato incontroverso sobre o qual a sentença pronunciou-se” e, ao reconhecer que a decisão atribuiu “objeto social inexistente” apurável mediante “simples exame dos documentos e demais peças acostadas aos autos”, julgou procedente a ação rescisória com base em “erro de fato” para “determinar a incidência da alíquota da contribuição para o Finsocial aplicável às empresas mercantis”.²⁴¹ Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que quando o juiz nega a data – incontroversa – em que ocorreu o acidente para conceder determinado benefício à parte, a verificação a partir dos autos de que a data do acidente é outra caracteriza “erro de fato”.²⁴² Do mesmo modo, quando o juiz, por equivocada percepção de informações constantes dos autos, considera intempestiva a contestação e julga procedente o pedido ou mesmo considera intempestivo recurso,²⁴³ admite-se a ação rescisória.

Como se vê, o fato pode dizer respeito a uma situação de direito substancial ou de direito processual. O que realmente importa é a existência de erro de percepção sobre fato – capaz de ser verificado mediante a análise dos autos – que não foi controvertido no processo e, assim, não precisaria ser analisado pelo juiz, mas que influiu sobre a decisão.²⁴⁴

14. Anulação de atos das partes e de outros participantes do processo. O § 4.º do art. 966 afirma que “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. Essa norma revive a regra do art. 486 do CPC/1973 e, ao mesmo tempo, elimina a necessidade da regra que constava no inc. VIII do seu art. 485.

O art. 486 do CPC/1973 afirmava que “os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil”. Por sua vez, admitia-se a rescindibilidade da decisão, nos termos do inc. VIII do art. 485, quando houvesse “fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença”.

Conforme se verifica, o art. 486 aludia a atos judiciais que não dependem de sentença ou em que esta for meramente homologatória. É claro que a norma estava a falar dos atos praticados pelas partes em juízo, e não dos atos que incumbem ao juiz, ou seja, dos atos jurisdicionais. Afinal, da rescindibilidade dos atos jurisdicionais já tratava o art. 485.²⁴⁵ A expressão “meramente”, que qualificava a sentença homologatória, não tinha intenção de sinalizar para determinado conteúdo ou espécie de sentença homologatória, mas simplesmente de enfatizar que se tratava de sentença que apenas acobertava atos privados.²⁴⁶ Da mesma forma, o vocábulo “rescindidos” lá estava mal empregado, uma vez que não se pretendia dizer que a decisão judicial poderia ser rescindida, mas apenas que o ato das partes poderia ser anulado.

Ademais, o legislador de 1973 equivocou-se ao ressaltar ação autônoma para anular ato praticado pelas partes no processo e, ao mesmo tempo, estabelecer a rescindibilidade da sentença

no caso em que há fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação (art. 485, VIII, CPC). O Superior Tribunal de Justiça, para outorgar sentido à desnecessária diferenciação realizada pelo CPC/1973, dizia que “a sentença judicial que, sem adentrar o mérito do acordo entabulado entre as partes, limita-se a aferir a regularidade formal da avença e a homologá-la, caracteriza-se como ato meramente homologatório e, nessas condições, deve ser desconstituída por meio da ação anulatória prevista no art. 486 do CPC, sendo descabida a ação rescisória para tal fim”.²⁴⁷ Advertia o Superior Tribunal de Justiça que “a sentença que homologa a transação fundamentando-se no conteúdo da avença, é desconstituível por meio de ação rescisória fulcrada no art. 485, VIII, do CPC. Não obstante, em sendo a sentença meramente homologatória do acordo, adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória do art. 485, VIII, do CPC, posto ausente requisito primordial da rescindibilidade do julgado. Nestes casos, a desconstituição da transação, pelos defeitos dos atos jurídicos em geral, se faz por meio de ação anulatória, fulcrada no art. 486, do CPC”.²⁴⁸

Bem vistas as coisas, o verdadeiro problema era a existência de dois meios de impugnação (anulatória e rescisória com base no inc. VIII do art. 485) com idênticos efeitos práticos. Assim, mais adequado afigura-se o sistema do CPC/2015 ao reservar a impugnação dos atos de disposição das partes à ação de anulação, eliminando-se qualquer cogitação sobre ação rescisória.

Quanto à partilha amigável, são aplicáveis os arts. 657 e 966, § 4.º. De acordo com o art. 657, “a partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4.º do art. 966”. Como está claro, a ação anulatória pode atacar partilha amigável, judicial ou extrajudicial. Nesta ação podem ser invocados os vícios e defeitos que invalidam a partilha (arts. 966, § 4.º, CPC, e 2.027, CC). Na ação voltada à anulação de partilha realizada em juízo, impugna-se o ato das partes, não a decisão judicial que o homologa.

Por outro lado, admite-se ação rescisória de partilha judicial quando há litígio no inventário (art. 658, CPC). Como já decidia o Superior Tribunal de Justiça à época do CPC/1973, “a análise da ação adequada à invalidação da partilha tem por pressuposto a análise do conteúdo e dos limites da sentença proferida nos autos do inventário: se homologada simplesmente a partilha mesmo que para aprovar o plano apresentado pelo inventariante, mas desde que ausente litigiosidade, deve-se ajuizar a ação anulatória; se, ao revés, na sentença forem resolvidas questões suscitadas pelos interessados quanto à divisão de bens e/ou à admissão de herdeiros, cabível é a ação rescisória”.²⁴⁹

É preciso perceber, no entanto, que não são apenas os atos homologados que podem ser objeto de ação de anulação. Também os atos que independem de homologação podem ser anulados. Assim, por exemplo, a renúncia ao direito de recorrer. A renúncia ao direito de recorrer é um claro exemplo de ato de disposição de direito que, uma vez praticado, independe de homologação. Nesse ponto, portanto, é preciso cuidado na leitura do § 4.º do art. 966, na medida em que este, ao contrário do art. 486 do CPC/1973, não fala em “atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória”, mas em “atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo”.

Os fundamentos para a anulação de atos de disposição de direito praticados pelas partes ou por outros participantes do processo estão nas normas de direito material. Isso está claro na parte final do § 4.º do art. 966, que fala em atos “sujeitos à anulação, nos termos da lei”. Se a demanda se dá entre dois ou mais privados, natural que se procure fundamento para invalidar atos praticados pelas partes no processo no Código Civil. Pode-se alegar, portanto, tanto os defeitos dos negócios jurídicos, como as suas causas de invalidade. Caso alguma das partes esteja submetida, no todo ou em parte, ao regime jurídico administrativo (pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado que participam da Administração Pública descentralizada), são invocáveis as normas que regem os atos administrativos para a desconstituição dos atos praticados em juízo por essas pessoas. Assim, se o agente da Administração Pública transaciona quando lhe falece atribuição para tanto, o ato é nulo por ofensa à legalidade (art. 37, caput, CF). Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o acordo entre os Municípios (assim como o

Termo de Ajustamento de Conduta) pode, em tese, ser rescindido nos moldes do art. 486 do CPC, desde que ocorra ofensa ao patrimônio público lato sensu, tangível ou intangível”.²⁵⁰

A ação de anulação de ato de disposição praticado no processo obviamente não se relaciona com o prazo decadencial da ação rescisória. A ação anulatória é sujeita ao prazo decadencial definido pelo direito material. Assim, em regra, é aplicável o prazo decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178, I e II, do CC.²⁵¹

Por identidade de razões, não há como supor que a ação anulatória de ato praticado no processo tenha que ser proposta no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal; a ação, como qualquer outra ação de anulação de ato jurídico, pode ser proposta no primeiro grau de jurisdição. Mais especificamente, deve ser proposta perante o juízo em que tramita ou tramitou o processo no qual praticado o ato que se busca anular (art. 61, CPC).²⁵²

A procedência do pedido formulado na ação anulatória traz alguma perplexidade teórica a quem raciocina, equivocadamente, como se a sentença houvesse sido rescindida. Lembre-se que, quando se pensa em ato da parte praticado no processo, não há como supor ato jurisdicional rescindível. O ato é apenas praticado no processo; trata-se de ato que não é do juiz, mas ato que é anulável como os atos jurídicos em geral. Bem por isso, não há sentença rescindida, mas ato anulado. Seria possível perguntar, então, se a sentença homologatória, a despeito da anulação do ato, permanece em vigor, como se nada tivesse acontecido. Sucede que, dada a anulação do ato, a sentença que o homologou deixa de ter conteúdo válido e, por isso, perde qualquer valor no processo, permitindo o seu normal prosseguimento.²⁵³

O § 4.º do art. 966 também afirma que “os atos homologatórios praticados no curso da execução” estão sujeitos à anulação. Na hipótese em que, por exemplo, a exequente renuncia ao crédito, nos termos do art. 924, IV, do CPC, a sentença homologa o ato de renúncia. É esse ato que deve ser impugnado como anulável, e não a sentença homologatória. O legislador equivocadamente fala em “ato homologatório” sujeito à anulação, sugerindo haver algo distinto da decisão de homologação e do ato que é seu objeto. Ocorre que “ato homologatório” só pode ser a decisão judicial de homologação. No entanto, aquilo que pode ser anulado não é a decisão de homologação nem o “ato homologatório”, na dicção do § 4.º do art. 966. O que se pode anular é o ato das partes, no exemplo, a renúncia ao direito.

Sem embargo, mesmo atos não sujeitos à homologação, como a arrematação, continuam sujeitos à ação anulatória. À luz do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça não tinha dúvida sobre a possibilidade de se invocar o art. 486 para pedir a anulação da arrematação.²⁵⁴ O CPC/2015, no entanto, afirma que “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4.º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos” (art. 903, caput, CPC). O referido § 4.º afirma que, “após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”. Não fosse isso, afirma o § 1.º do mesmo art. 903 que “ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: i – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício”.

Como se vê, a norma exige interpretação capaz de adequar suas várias partes. Ao mesmo tempo em que o caput afirma que a arrematação é perfeita, acabada e irretratável, ainda que julgada procedente a ação de anulação do § 4.º, esse parágrafo afirma claramente o cabimento da ação de anulação, que pode se basear em “preço vil” ou “outro vício”, conforme o § 1.º. Ora, se a arrematação não pode ser anulada é contraditório admitir a ação anulatória. A previsão do § 4.º, assim como as causas de invalidade elencadas no § 1.º, obviamente não teriam qualquer motivo para ser lembradas caso a arrematação jamais pudesse ser anulada. Ao contrário, teria que estar escrito que só é possível exercer pretensão à tutela ressarcitória. Aliás, a legislação processual jamais poderia fazer isso, ainda que desejasse; o direito à tutela de anulação da arrematação não pode ser válido e constitucionalmente usurpado do prejudicado pela arrematação dotada de vícios.

Admite-se que o caput do art. 903 foi elaborado para tutelar o arrematante, visto como terceiro de boa-fé. Como dito no Novo Curso de Processo Civil, caso o arrematante pudesse perder o bem arrematado diante da procedência da impugnação, não haveria interesse em adquiri-lo em hasta pública antes de definida a impugnação, eliminando a celeridade que se pretendeu outorgar à execução com a previsão da não suspensividade, como regra, da impugnação. Ou então, diante do risco inerente à aquisição do bem nessa condição, a sua arrematação apenas se daria por valor bem mais baixo do que o de mercado, suficiente para tornar a sua compra atraente, diante do risco da sua perda em decorrência da procedência da impugnação. Esta última situação, como é intuitivo, favoreceria apenas a especulação, causando evidente prejuízo à tutela jurisdicional dos direitos.²⁵⁵

Porém, se a arrematação não pode ser anulada em prejuízo do arrematante de boa-fé, isso não quer dizer que não possa ser anulada quando ocorreu por preço vil ou quando o arrematante estava de má-fé. O preço vil pressupõe que o arrematante não está de boa-fé. Seria absurdo não poder anular uma arrematação por preço vil sob a suposição de que o arrematante não pode ser prejudicado. Pense-se, ainda, na hipótese em que o arrematante adquire bem ciente de que este já foi pago em compromisso de compra e venda. O terceiro de boa-fé, nesse caso, é o compromissário comprador, e não o arrematante. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar o cabimento da ação anulatória – baseada no art. 486 do CPC/1973 – em caso como este, argumentando que “o terceiro adquirente de boa-fé pode promover ação de anulação da arrematação como consectário de que a todo direito corresponde uma ação que a assegura, sendo certo que para propô-la basta demonstrar interesse e legitimidade (art. 3.º do CPC/1973). O terceiro juridicamente interessado na rescisão do ato judicial de arrematação tem legitimidade para propor a ação anulatória do mesmo, independentemente do fato de ser ele o proprietário do imóvel ou o possuidor do mesmo em decorrência de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. (...) Os atos judiciais que não dependem de sentença, como sói ser a arrematação de bem imóvel em processo executivo, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. Esta é a expressa dicção do art. 486 do CPC”.²⁵⁶

Na realidade, o art. 903 apenas optou por preservar a arrematação em face do executado que mais tarde é declarado não devedor. Ou seja, a posterior declaração de que o executado não é devedor do exequente não tem o efeito de desfazer a arrematação em prejuízo do arrematante, terceiro de boa-fé. Nesse caso, o exequente deverá não só pagar o valor integral do bem arrematado ao executado, como ainda indenizá-lo pelos prejuízos sofridos, nos termos da parte final do art. 903.²⁵⁷

Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:

I – quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;

II – o terceiro juridicamente interessado;

III – o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção;

b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;

c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

IV – aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.

1. Primeiras considerações. O art. 967 define aqueles que podem propor a ação rescisória: i) quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; ii) o terceiro juridicamente interessado; iii) o Ministério Público; e iv) aquele que não foi ouvido no processo em

que lhe era obrigatória a intervenção.

A regra reproduz em parte a do art. 487 do CPC/1973. Vai além ao atribuir ao Ministério Público a possibilidade de propor ação rescisória no processo em que figurou como fiscal da lei, bem como ao outorgar essa mesma possibilidade aos entes que não foram ouvidos no processo em que tinham a obrigação de intervir. O parágrafo único ainda acrescenta a necessidade de o Ministério Público ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica.

2. Parte, sucessor a título universal ou singular e terceiro interessado. Qualquer parte que estava presente no processo no momento em que a decisão rescindenda foi proferida pode propor ação rescisória. É claro que aquele que foi excluído do processo no seu curso, exatamente por não poder ser atingido pela coisa julgada, não pode propor a ação. Essa pode ser proposta por qualquer dos litisconsortes ativos ou passivos. O litisconsórcio é facultativo e unitário; qualquer dos litisconsortes, sem a necessária presença dos demais, pode pedir a rescisão da decisão, que, como é óbvio, só pode ser rescindida ou não para todos. No caso de cúmulo subjetivo de ações, o réu de uma das ações cumuladas obviamente não pode pleitear a rescisão da decisão que concerne à outra ação.

No caso de sucessão a título universal ou singular ocorrida no curso do processo ou posteriormente ao seu encerramento, o sucessor tem legitimidade para pleitear a rescisão da decisão. Assim, por exemplo, tratando-se de ação reivindicatória em que foi proferida sentença de procedência, tanto o herdeiro (sucessor a título universal) quanto o adquirente do bem litigioso (sucessor a título singular) podem propor ação rescisória. No caso em que o sucessor ingressou no processo como parte ou assistente litisconsorcial (art. 109, §§ 1.º e 2.º, CPC), a sua posição de parte ou de assistente litisconsorcial é obviamente suficiente para sustentar a sua legitimidade para a propositura da ação, embora aqui pouco importe se o vencido era parte, assistente litisconsorcial ou apenas sucessor, uma vez que qualquer destas posições lhe confere legitimidade para a propositura da ação.

Não há dúvida que o assistente litisconsorcial (art. 124, CPC) pode propor a ação rescisória. Afinal, é titular do direito em litígio e, assim, é atingido pela coisa julgada. Mas igualmente pode propô-la, como acrescenta o inc. II do art. 967, “o terceiro juridicamente interessado”. Significa que o assistente simples (art. 119, CPC) também pode propor ação rescisória. O assistente simples, embora não sujeito à coisa julgada, é juridicamente interessado na resolução do litígio, pois titular de posição de direito material que dela depende para sobreviver. Não é por outro motivo que se diz que o assistente simples é atingido pelos efeitos reflexos da sentença. Assim, por exemplo, o sublocatário pode postular a rescisão da decisão que julgou procedente o pedido de despejo, caso obviamente exista fundamento rescindente para tanto.

3. A legitimidade do Ministério Público. Além do disposto na letra b do inc. III do art. 967, o Ministério Público pode propor ação rescisória i) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção e ii) em outros casos em que se imponha sua atuação. A primeira hipótese remonta ao CPC/1973, que continha a mesma hipótese (art. 487, III, a, CPC/1973). A previsão configura hipótese autônoma de rescisão, especificamente conferida ao Ministério Público. Note-se que a simples não intervenção do Ministério Público – em processo em que deveria ter necessariamente participado nos termos do art. 178 – representa causa para a postulação da rescisão da decisão, independentemente desta ter ou não algum dos vícios elencados no art. 966. O fundamento rescindente é a “não intervenção”, capaz de ser deduzido apenas pelo Ministério Público. Seria possível argumentar, contra a previsão legal, no sentido de que a não intervenção só deveria ser fundamento apto a propositura da ação rescisória quando associado a fundamento presente em algum dos incisos do art. 966, lembrando-se que, a despeito da não intervenção, a decisão obviamente poderia ser imaculada. Ocorre que o legislador tomou em conta a importância da participação do Ministério Público para a formação da decisão que resolve determinados litígios (art. 178, CPC) e, assim, desenhou fundamento rescindente autônomo, desligado da existência de outro vício capaz de corromper a higidez da decisão.

É claro que aí avulta o poder conferido ao Ministério Público, que não deve propor a ação simplesmente por não ter sido chamado a participar do processo. Somente deverá propor a ação

rescisória quando, além de não ter tido a oportunidade de participar, esteja diante de decisão que contraria a ordem jurídica, ou seja, a razão pela qual deveria ter atuado no processo. É importante frisar que participar na qualidade de fiscal da ordem jurídica não significa tutelar ou defender as posições do incapaz ou dos grupos que litigam pela posse. Ao contrário, o Ministério Público deve zelar pela ordem jurídica, que obviamente não tem relação direta com os direitos do incapaz e, especialmente, dos membros dos grupos que costumam litigar sobre posse de bens imóveis. Aliás, são frequentes as situações em que a ordem jurídica está sendo violada ou ameaçada de violação exatamente pelos grupos presentes nos litígios pela posse de terra rural ou urbana. Portanto, dada a inusitada e curiosa hipótese do inc. III do art. 178, é necessária muita racionalidade do Ministério Público.

A letra c do inc. III do art. 967, ao afirmar que o Ministério Público pode propor ação rescisória “em outros casos em que se imponha sua atuação”, certamente não está tratando das hipóteses em que este foi parte ou deveria ter participado como fiscal da ordem jurídica. Afinal, essas já estão previstas nos incs. I e III, a, do art. 967. A previsão dirige-se à situação em que o Ministério Público participou do processo como fiscal da ordem jurídica, mas a decisão que nele foi proferida está marcada por algum fundamento rescindente do art. 966. Se o Ministério Público deve atuar como fiscal da ordem jurídica, conforme diz o art. 178, é racional que possa propor ação rescisória quando, a despeito da sua intervenção como fiscal da lei, tenha sido proferida decisão que contraria a ordem jurídica e é gravada por hipótese rescindente prevista em um dos incisos do art. 966, que, sem dúvida, pode até mesmo ser a de “violação manifesta de norma jurídica”, delineada no seu inc. V.

O art. 487 do CPC/1973 dizia que o Ministério Público podia atuar no caso “de colusão das partes a fim de fraudar” (art. 487, III, b, CPC/1973). O art. 967, III, b do CPC/2015 afirma que o Ministério Público tem legitimidade para propor a ação rescisória “quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou colusão das partes, a fim de fraudar a lei”. Lembre-se que a colusão pode dar origem a processo fraudulento ou a processo simulado. Age com fraude quem frustra a aplicação da lei, ou seja, afasta a sua incidência ou obtém algo que ela não permite; ocorre simulação quando as partes travam um litígio aparente – que não existe – com o objetivo de simuladamente conferir ou transmitir direitos ou prejudicar terceiros. Na fraude, as partes obtêm o que desejam mediante o processo, mas em detrimento da lei. Há processo fraudulento no conhecido exemplo da ação em que as partes obtêm a dissolução do casamento fora das hipóteses previstas na lei. Na simulação, o processo não é o meio pelo qual as partes obtêm o que a lei não lhes permite, mas aquele pelo qual constituem simulacro para prejudicar terceiros.²⁵⁸ É o caso da ação trabalhista, em que a condenação e a expropriação de bens serve para fraudar os credores daquele que foi demandado.

4. Legitimidade daquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. O art. 967 define outro fundamento rescisório derivado de não intervenção no processo. Nitidamente não se trata de caso em que o litisconsórcio era necessário. Outorga-se legitimidade ao ente cuja intervenção era obrigatória no processo em que proferida a decisão. Assim, por exemplo, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – deve obrigatoriamente intervir nas ações em se pede de nulidade de registro ou de patente (arts. 57, 118 e 175 da Lei da Propriedade Industrial). O INPI evidentemente não é titular de direito em litígio nem possui interesse jurídico no resultado da demanda; tem apenas a obrigação de intervir nos processos em que se discute sobre a validade de patente ou registro e, quando isso não ocorre, tem clara legitimidade (art. 967, IV, CPC) para propor ação rescisória.

5. Ministério Público como fiscal da ordem jurídica na ação rescisória. O parágrafo único do art. 967 contém regra que prevê intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Lembre-se de que no CPC/1973 não havia previsão de intervenção do Ministério Público na ação rescisória. Agora, a intervenção do Ministério Público deve ocorrer em conformidade com o art. 178, ou seja, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: i) interesse público ou social; ii) interesse de incapaz; e iii) litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Como já foi dito, a intervenção do Ministério Público é no interesse da ordem jurídica, e não

para atuar no processo em proveito de um ou outro dos litigantes. Frise-se, embora não devesse ser preciso, que a função do Ministério Público não pode ser amesquinhada a ponto de ser confundida com a da advocacia pública. Não apenas “a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público”, nos termos do parágrafo único do art. 178, como o “interesse público” que legitima a intervenção do Ministério Público (art. 178, I, CPC) nada tem a ver com a proteção dos direitos patrimoniais dos entes públicos. Aliás, se não fosse assim haveria uma sobreposição autoritária de forças voltadas à defesa da Fazenda Pública, em total descompasso com a igualdade no processo.

6. Legitimidade passiva. A princípio, a ação rescisória deve ser dirigida contra todos aqueles que tendo participado no processo em que proferida a decisão foram atingidos na qualidade de parte pelo capítulo da decisão que se pretende rescindir.

No caso de sucessão a título universal ou singular, o sucessor deve ser citado como réu. Não há sentido em supor que, no caso de sucessão intervivos a título particular, a ação rescisória pode ser proposta contra o sucedido, argumentando-se que a alienação da coisa ou do direito litigioso por entre vivos a título particular não altera a legitimidade das partes, nos termos do art. 109 do CPC. Ora, é equivocado pretender rescindir uma decisão que tutela o direito do sucessor sem a sua participação como réu. O sucessor tem direito constitucional de participar em contraditório do processo que pretende rescindir a decisão proferida apenas em face daquele que foi sucedido.

Tratando-se de substituição processual, é necessário verificar se a legitimação extraordinária subsiste para efeito de dispensa dos titulares dos direitos na ação rescisória. Como é sabido, a legitimidade para a propositura de ação para a tutela de direitos individuais homogêneos não exclui a possibilidade da propositura de ação individual. Ou seja, o titular do direito sempre pode se afastar da ação coletiva e propor ação individual. Isso significa que a legitimidade para a tutela de direitos individuais homogêneos não elimina a legitimidade individual. Por isso, não há como excluir os indivíduos do processo em que se pretende rescindir a decisão que reconheceu seus direitos, na medida em que é muito mais grave subtrair direitos negando-se o direito de defesa do que proibir a propositura da ação individual. Esse raciocínio só seria inválido se fosse possível admitir que aquele que não propõe a ação individual sem perceber renuncia ao direito de se defender em eventual ação rescisória.

Na realidade, admite-se que a ação rescisória pode ser proposta apenas contra o legitimado à tutela de direitos individuais homogêneos por uma simples razão prática ou de eficiência do sistema processual. Entende-se que seria muito difícil citar pessoalmente aqueles que foram beneficiados pela decisão coletiva ou pela coisa julgada erga omnes. Contudo, obviamente não há como desprezar o direito fundamental de se defender daqueles que incorporaram direitos mediante uma decisão que se almeja rescindir, simplesmente por ser difícil citá-los nos moldes tradicionais. A forma da citação, nesses casos, precisa adequar-se à realidade das demandas de massa. Há que se comunicar os titulares dos direitos individuais acerca da propositura da ação rescisória mediante veículos adequados, como jornais de grande difusão, demonstrando-se que a comunicação realizada alcançou os membros do grupo envolvido.

Sublinhe-se que, além da citação daqueles que se tornaram titulares de direitos em virtude da decisão rescindenda, há necessidade de citação do ente legitimado que atuou na ação primitiva. Estes devem figurar no polo passivo por terem a incumbência de defender os direitos individuais homogêneos, mas a sua participação na ação rescisória não é suficiente para excluir a necessidade de comunicação dos titulares dos direitos individuais para eventual apresentação de defesa.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

I – cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

§ 1.º Não se aplica o disposto no inc. II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.

§ 2.º O depósito previsto no inc. II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

§ 3.º Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inc. II do caput deste artigo.

§ 4.º Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332.

§ 5.º Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda:

I – não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2.º do art. 966;

II – tiver sido substituída por decisão posterior.

§ 6.º Na hipótese do § 5.º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.

1. Requisitos da petição inicial e “documentos indispensáveis”. À primeira vista, dada a dicção do caput do art. 968, seria de se supor que a petição inicial da ação rescisória deve observar todos os requisitos definidos no art. 319. Entretanto, não há como admitir que a petição inicial da ação rescisória obrigatoriamente tenha que anunciar “a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação” (inc. VII do art. 319, CPC). Não exatamente porque não se admite conciliação para desfazer a coisa julgada, já que as partes obviamente podem conciliar sobre a situação litigiosa que, embora já resolvida com força de coisa julgada, pode adquirir nova feição com a procedência da ação rescisória. Mas porque na ação rescisória o réu não é citado para comparecer na audiência de conciliação ou mediação, e sim tão somente para apresentar resposta (art. 970, CPC). Logo, não há motivo para o autor da ação rescisória ser obrigado a declarar se tem ou não interesse em tal audiência. Eventualmente, o autor ou o réu até podem, sem vincular a parte adversa, solicitar a designação de audiência para tanto.

O requisito da causa de pedir na ação rescisória é digno de nota. Como se trata de uma ação com fundamentação vinculada, isto é, cuja argumentação deve necessariamente gravitar em torno dos incs. do art. 966, CPC, a parte tem o ônus de alegar especificamente uma das situações que legitima a propositura da ação rescisória. Se a parte sequer narra na petição inicial quaisquer das hipóteses em que se admite ação rescisória, cumpre ao juiz determinar a sua emenda, sob pena de indeferimento.

O requisito do pedido, previsto no art. 319, IV, é indicado de modo mais preciso no inc. I do art. 968, na medida em que a ação rescisória, com exceção dos casos em que a rescisão é suficiente, exige pedido rescindente cumulado com pedido rescisório.²⁵⁹

A petição inicial da ação rescisória também deve estar instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320. Além do comprovante de depósito de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, CPC), a inicial da ação rescisória, qualquer que seja o seu fundamento, deve sempre vir acompanhada de cópia da decisão rescindenda e de certidão do seu trânsito em julgado. Lembre-se que a decisão rescindenda pode ter sido tomada no curso de processo, como é o caso da decisão que julga parcialmente o pedido ou um dos pedidos cumulados (art. 356, CPC).²⁶⁰ Esta decisão, como não poderia deixar de ser, abre oportunidade para a imediata propositura de ação rescisória, muito embora o processo no qual tenha sido proferida possa prosseguir rumo à solução da outra parcela do mérito. Nesse caso, exatamente porque o processo continua para a resolução da outra parte do pedido ou do outro pedido cumulado, não há como pensar em certidão do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, mas em

certidão do trânsito em julgado da decisão rescindenda ou da última decisão relacionada à decisão rescindenda.

É claro que, conforme o fundamento rescindente utilizado na ação rescisória, aparecerá como indispensável este ou aquele documento. Assim, por exemplo, no caso de ação fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal (art. 966, VI, CPC), a petição inicial deverá vir acompanhada da decisão a respeito da falsidade presente no processo penal.

2. Indeferimento da petição inicial. De acordo com o art. 321, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 (requisitos da petição inicial) e 320 (documentos indispensáveis) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende-a ou complete-a, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência determinada, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Além disso, o art. 330 apresenta as hipóteses em que o juiz deve indeferir a petição inicial, reafirmando que o juiz deve indeferi-la quando não atendidas as prescrições do art. 321 (art. 330, IV, CPC). Na verdade, a petição inicial só deve ser indeferida quando incidir nas hipóteses do art. 330, aí incluídas as situações previstas na primeira parte do art. 321, e o autor nada fizer para corrigir a irregularidade quando o juiz ou o relator indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Assim, caso a petição não tenha observado determinado requisito do art. 319 – como o pedido rescisório – ou não esteja instruída com documento indispensável (art. 320, CPC) – por exemplo, a certidão do trânsito em julgado ou o comprovante do depósito de 5% sobre o valor da causa –, o juiz não poderá indeferir a petição inicial sem antes dar ao autor oportunidade para corrigir a omissão ou apresentar o documento. Significa que o autor tem verdadeiro direito processual à emenda da petição inicial.

Por outro lado, especificamente quanto ao pedido rescisório que deixou de ser formulado, há que se ter claro que este não precisa ser feito no prazo decadencial da ação rescisória. O que interessa para obstar a decadência é a propositura da ação rescisória, com o que se evidencia a vontade do autor de exercer o direito à desconstituição da coisa julgada. Se a ação foi exercida no prazo e o pedido rescindente nele foi realizado, não há como admitir que a falta de pedido rescisório, mero requisito formal para a passagem ao juízo rescisório, possa obstaculizar a tutela jurisdicional (o rejuízo da causa) que é devida ao autor, na medida em que esta é mera consequência lógica da rescisão. Ora, se a lógica da emenda à inicial está umbilicalmente ligada à ideia de que uma irregularidade não pode comprometer a efetividade do exercício do direito fundamental à tutela jurisdicional, não cabe afirmar que a omissão em relação ao pedido rescisório apenas pode ser suprida no prazo decadencial da ação rescisória. A menos que se queira não apenas negar o direito fundamental de ação, mas também permitir que óbices formais prevaleçam em favor da não prestação da tutela jurisdicional devida ao jurisdicionado. Frise-se que o rejuízo da causa é uma mera consequência do juízo rescindente e, nesse sentido, é devido ao autor por conta da rescisão da coisa julgada.

3. Ações rescisórias cumuladas. Como já visto (art. 966, item 5), a ação rescisória pode atacar um ou vários capítulos de uma mesma decisão. Pode impugnar um ou vários capítulos decisórios (relativos a um ou mais de um pedido) ou capítulo pertinente a determinada questão prejudicial (coisa julgada sobre questão; art. 503, CPC). Pode também impugnar decisão que julgou parcialmente o mérito (art. 526, CPC) e, ao mesmo tempo, capítulo ou capítulos da decisão final, quando há duas decisões rescindendas. Nesses casos, cada capítulo atacado corresponde a uma ação rescisória, daí surgindo várias ações rescisórias cumuladas. Além disso, também há ações rescisórias cumuladas quando é impugnado um único capítulo com base em vários fundamentos rescindentes.

A autonomia dos pedidos – já que especificamente dirigidos a capítulos distintos – e especialmente a autonomia dos fundamentos rescindentes passam despercebidas quando não se pensa em termos de ação. Sabe-se que cada ação exige específica decisão, mas é muito comum ver

decisões que não decidem separadamente sobre os fundamentos apresentados para a rescisão e mesmo decisões que encampam pedidos de rescisão de diferentes capítulos sem a individualização da decisão acerca de cada capítulo.

É indispensável ter em conta cada capítulo impugnado e cada fundamento rescindente para efeito de decisão, sob pena de julgamentos desvirtuados e resultados falsos. Não se julga procedente algum dos dois pedidos rescindentes quando, num colegiado de cinco, dois votos declaram que um capítulo deve ser rescindido e outros dois votos declaram que o outro pedido deve ser julgado procedente. Também não se julga procedente o pedido rescindente quando se afirma, em dois votos, que houve violação de norma jurídica, e, também em dois votos, que existiu erro de fato. Nessas situações, cada um dos pedidos é julgado improcedente por três a dois, embora alguém possa equivocadamente imaginar que a decisão foi rescindida por quatro a um. Na verdade, maior confusão existe no último caso, ou seja, quando existem dois fundamentos rescindentes.

4. Pedidos rescindente e rescisório. O pedido rescindente diz respeito à pretensão de desfazimento da decisão marcada por um dos vícios presentes nos incisos do art. 966. Ocorre que, ao se julgar procedente o pedido rescindente, em regra é necessário proferir outra decisão para resolver a causa que foi solucionada pela decisão rescindida. É por isso que o inc. I do art. 968 diz que o autor deve “cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. Como se vê, a norma deixou claro que a cumulação só tem razão de ser quando da rescisão decorrer a necessidade de novo julgamento.

Note-se que, quando se admite ação rescisória em caso de reprodução de ação idêntica que dá origem a decisão que ofende à coisa julgada (art. 966, IV, CPC), a rescisão da decisão, por violação à coisa julgada anterior, obviamente não reclama novo julgamento. Ora, um novo julgamento seria uma reprise da violação à coisa julgada. Contudo, é importante notar que, quando a ação rescisória é fundada em violação à coisa julgada que constituía pressuposto para a resolução do litígio – de modo que a decisão rescindenda não poderia ser tomada se o juiz, no percurso do seu raciocínio decisório, houvesse respeitado à coisa julgada que se formara em ação anterior –, a rescisão da decisão com base em violação à coisa julgada não elimina a necessidade de novo julgamento. Assim, por exemplo, a coisa julgada que acoberta sentença de procedência em ação de investigação de paternidade é violada pela sentença que julga improcedente pedido de alimentos sob o argumento de inexistência de relação de paternidade. Porém, ao se rescindir a decisão proferida na ação de alimentos por violação à coisa julgada, torna-se necessário “novo julgamento” do pedido de alimentos, partindo-se da premissa de que há relação de paternidade. Nesse último caso, a desconstituição da decisão que ofende a coisa julgada não basta, uma vez que não se pretende apenas tutelar a primeira coisa julgada. É preciso não apenas rescindir a decisão, mas também novamente julgar o pedido de alimentos.

No caso de ação rescisória fundada em incompetência absoluta (art. 966, II, CPC), a rescisão da decisão mediante o reconhecimento da incompetência absoluta não permite o re julgamento da causa pelo órgão destituído de competência. A hipótese reclama a remessa dos autos ao órgão competente, para que então seja realizado o “novo julgamento”.

5. Depósito prévio. O CPC/1973 já exigia que o autor da ação rescisória depositasse o valor equivalente a 5% sobre o valor da causa para a hipótese de a ação ser, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (art. 488, II, CPC/1973).

O depósito do valor e a possibilidade da sua perda objetivam dissuadir o autor de propor a ação quando não convencido do fundamento rescindente. A perda do valor depositado é uma multa contra o autor que pretendeu rescindir a decisão sem fundamento dotado de plausibilidade. Nesse sentido, afirma-se que o valor depositado só reverte ao demandado quando a unanimidade dos membros do colegiado declara a inadmissibilidade da ação ou a julga improcedente (arts. 968, II, e 974, parágrafo único, CPC). O depósito pode ser levantado pelo autor em qualquer caso em que a decisão de inadmissibilidade da ação ou de improcedência do pedido rescindente seja tomada por maioria de votos. Bem por isso, obviamente deve ser levantado pelo autor em caso de procedência do pedido rescisório por unanimidade de votos. Ora, se o pedido rescindente foi julgado

procedente, passando-se ao re julgamento da causa, certamente não há mais como pensar em penalização do demandante.

À época do CPC/1973 discutiu-se muito se o valor do depósito de 5% poderia ser visto como um ônus excessivo ao autor, capaz de inviabilizar o exercício do direito de ação ou o direito de acesso à justiça. No REsp 744.286/DF, a 1.^a Turma do STJ decidiu que, diante do alto valor da condenação imposta na decisão rescindenda, a fixação do valor da ação rescisória em função da condenação inviabilizaria o exercício do direito de acesso à justiça, resolvendo então fixar o valor da ação rescisória em conformidade com o valor atribuído à ação que desembocou na decisão rescindenda, corrigido monetariamente.²⁶¹

A rejeição à ideia de que óbices econômicos podem limitar o acesso à justiça, que levou a decisões como a proferida no REsp 744.286/DF, fez com que o legislador do CPC/2015 instituisse a regra presente no § 2.º do art. 968, que reza que o depósito prévio (inc. II, art. 968, CPC/2015), nunca será superior a mil salários mínimos. A intenção da regra foi impedir que, quando à ação rescisória se atribuir valor vultoso, tenha o autor que depositar valor (de 5% sobre o valor da causa) que lhe impeça o exercício do direito à ação rescisória. Assim, no CPC/2015, toda vez em que o valor de 5% sobre o valor da ação rescisória for superior a mil salários mínimos, o valor do chamado depósito prévio fica limitado a mil salários mínimos.

Inspirado no mesmo motivo, a parte final do § 1.º do art. 968 afirma que o depósito prévio é dispensado “aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. Se tal dispensa é aceitável quando conferida aos beneficiários de justiça gratuita, ela é completamente inadmissível para a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, embora o § 1.º o expressamente também lhes conceda – inconstitucionalmente – esse benefício.

6. Inconstitucionalidade da dispensa do depósito prévio. O § 1.º do art. 968 confere privilégio destituído de base à “União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público e à Defensoria Pública”, uma vez que o depósito de 5% sobre o valor da causa objetiva resguardar a seriedade na utilização da via rescisória. Sendo indiscutível que o escopo do depósito é evitar ações destituídas de fundamento e voltadas a procrastinar a satisfação dos direitos, não há porque supor que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as suas respectivas autarquias e fundações de direito público, o Ministério Público e a Defensoria Pública possam estar imunes a tal exigência.

Na verdade, a experiência demonstra que a Fazenda Pública “usa e abusa” da ação rescisória em detrimento do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e tempestiva. É incontestável que a mesma razão que legitima a imposição do depósito ao particular aplica-se a esses entes. O § 1.º do art. 968 discrimina o particular em face de tais entes, gerando-lhes vantagem destituída de racionalidade. A norma é inconstitucional – viola, de forma gritante, o princípio da igualdade. A dispensa só teria cabimento se o depósito tivesse natureza de caução ou se o valor do depósito revertesse em benefício do Estado. Porém, o art. 974 do CPC deixa claro que, em caso de inadmissibilidade ou de improcedência por unanimidade, a importância do depósito reverte em favor do réu.

7. Julgamento liminar de mérito na ação rescisória. O pedido rescindente pode ser rejeitado liminarmente, nos termos do art. 332. Vale dizer: o pedido rescindente pode ser julgado improcedente toda vez que houver precedente da Corte Suprema ou jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça no sentido contrário ao pretendido pelo autor.

8. O problema da identificação da decisão rescindenda e a oportunidade de deslocamento da causa para o juízo competente. Ao Supremo Tribunal Federal compete julgar as ações rescisórias de seus julgados (art. 102, I, j, CF). Idêntica competência toca ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, e, CF). Aos Tribunais Regionais Federais compete julgar as ações rescisórias de seus julgados ou dos juízes federais da região (art. 108, I, b, CF), assim como compete aos Tribunais de Justiça dos Estados julgar as ações rescisórias de seus julgados ou dos juízes estaduais a ele vinculados (art. 125, § 1.º, CF).

Considera-se julgada pelo tribunal a causa quando a tenha examinado em grau único ou tenha conhecido de recurso a ele endereçado. Se o tribunal não conhece de recurso a ele dirigido, então a sua decisão não substitui a decisão recorrida (art. 1.008, CPC) e não se considera por ele julgada a causa. Pouco importa, todavia, se o tribunal apenas anuncia que não conheceu de determinado recurso se, na realidade, dele conheceu, negando provimento – examinando a questão alegada no recurso. Se o tribunal conhece do recurso, ainda que anuncie o contrário, a ele compete conhecer da ação rescisória que visa à rescisão do julgado (ratio da Súmula 249, STF: “é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento a agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”). Nessa linha, observe-se ainda que “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório” (Súmula 515, STF). Para a determinação de competência para ação rescisória, o que interessa é que o tribunal tenha julgado aquilo que será debatido na ação rescisória.

A propositura da ação rescisória diante de juiz incompetente não conduz à extinção do processo sem resolução de mérito (arts. 64, § 3.º, e 968, § 5.º, CPC). Como há evidente preferência pela prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões processuais (arts. 6.º, 319, 488, 932, parágrafo único, CPC), o legislador determina que o juiz intime a parte a fim de auxiliá-la na identificação do juízo efetivamente competente para a causa. Trata-se de providência imposta pelo dever de cooperação do juiz para com as partes. Se a parte propôs ação rescisória pressupondo que decisão posterior substituiu anterior sem que isso tenha de fato ocorrido (art. 968, § 5.º, I, CPC) ou que decisão anterior não tenha sido substituída por outra posterior quando isso de fato ocorreu (art. 968, § 5.º, II, CPC), tem o juízo o dever de intimar a parte a fim de que adeque o objeto da ação rescisória e a enderece ao juízo competente.

Redimensionado o objeto da ação rescisória e corretamente endereçada, tem o órgão jurisdicional de viabilizar às partes a complementação das razões da ação rescisória. Logo em seguida tem de remeter ao juízo competente (art. 968, § 6.º, CPC).

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

1. Tutela provisória. A eficácia da decisão rescindenda só pode ser suspensa mediante a concessão de tutela provisória.²⁶² A tutela provisória pode ser fundada na urgência ou na evidência (arts. 294, 300 e 311, CPC).

O art. 969, CPC, não limita a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão rescindenda à concessão de tutela provisória fundada na urgência. Vale dizer: nada obsta a que se determine a suspensão por força da evidência do direito alegado na ação rescisória.

De outro lado, por óbvio que eventual cumprimento da decisão rescindenda não perde o caráter de cumprimento definitivo em face da propositura de ação rescisória. Descabe, nesse sentido, exigir-se caução para que possa o réu na ação rescisória levantar quantia em dinheiro na execução forçada cujo título se pretende desconstituir com a ação rescisória.²⁶³ Mesmo com a concessão da tutela provisória eventual execução que tenha como título executivo a decisão rescindente não perde a sua definitividade. A suspensão da eficácia da decisão rescindente não transforma a execução em provisória.

2. A propositura da ação rescisória não suspende a capacidade da decisão rescindenda produzir efeitos. O art. 969 diz que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão que se almeja rescindir. Porém, nem toda decisão rescindível, como é óbvio, precisa ser objeto de cumprimento ou execução. Como é sabido, as sentenças declaratória e constitutiva – ditas “satisfativas”²⁶⁴ – independem de atividade executiva.²⁶⁵

Portanto, quando se pensa nos prejuízos que podem ser acarretados por uma decisão, deve-se ter em mente que as sentenças declaratória e constitutiva podem produzir efeitos imediatamente, independentemente da prática de atos executivos ou de cumprimento. Assim, aquele que teme ser

prejudicado por tais sentenças deve pedir a suspensão dos seus efeitos.

Por outro lado, o que se pode suspender, quando se pensa em decisão que depende de cumprimento, é a sua eficácia “executiva”, ou seja, a sua capacidade de, a qualquer momento, abrir oportunidade para a prática de atos “executivos”.

Note-se que a ação rescisória não se volta propriamente nem contra uma sentença que depende de cumprimento nem contra uma sentença “satisfativa” (declaratória e constitutiva), mas contra a coisa julgada que as reveste. De modo que o art. 969 não deveria ter se dirigido a determinada modalidade de sentença – a sentença que depende de cumprimento ou de execução –, mas à coisa julgada que constitui pressuposto aos efeitos das sentenças “satisfativas” e da própria eficácia executiva. É certo que os efeitos da sentença não dependem necessariamente da coisa julgada²⁶⁶ – tanto é que os efeitos sentenciais podem ser suspensos na pendência dos recursos especial ou extraordinário –, mas quando se tem em conta a tutela de urgência na ação rescisória está a se pensar em algo que tem como pressuposto a coisa julgada que se quer rescindir. Significa que a tutela urgente deve ter em mira a eficácia sentencial (declaratória, constitutiva ou executiva) que tem como pressuposto a coisa julgada, sendo possível falar, nesse sentido, em suspensão dos efeitos ou da eficácia da decisão rescindenda.

3. Pressupostos da tutela provisória. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, em face de ação rescisória, depende da plausibilidade do fundamento rescindente (art. 966, CPC) e de dano grave que pode derivar dos efeitos da decisão que se pretende rescindir.²⁶⁷ Nos termos do art. 311, CPC, o que interessa é que a defesa na ação rescisória seja inconsistente – ou potencialmente inconsistente. Em ambos os casos, os argumentos que apontam para o fundamento rescindente devem ser capazes de convencer que o resultado da ação rescisória provavelmente será de procedência.

Ademais, no caso de tutela provisória fundada na urgência, há que se demonstrar que os efeitos da decisão rescindenda trarão dano grave, especialmente de natureza não patrimonial. Não há como elaborar raciocínio sobre a probabilidade de dano com base em premissas que não foram demonstradas pelo requerente; um dano hipotético certamente não é suficiente para a concessão da tutela de urgência. A tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se imprescindível para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva ao litigante (arts. 5.º, XXXV, CF, e 969, CPC). Do contrário, deve-se prestigiar a cognição exauriente em que lastreada a decisão rescindenda.

Os danos que podem ser ressarcidos em pecúnia, caso deseje o réu da ação rescisória, podem ser assegurados mediante caução. Não se quer dizer, obviamente, que o relator da ação rescisória possa impor caução ao réu, mas que pode facultar-lhe, uma vez presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a sua prestação. Melhor dizendo, quando o relator tem convicção de que a tutela de urgência deve ser concedida, pode autorizar o réu a prestar caução capaz de assegurar o ressarcimento dos eventuais prejuízos.

Embora o art. 300 aluda a “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o real problema da tutela de urgência está na explicitação do raciocínio que conduz à formação da convicção de probabilidade.²⁶⁸ Todo o percurso do raciocínio que leva a uma decisão se funda em critérios racionais que devem ser devidamente justificados. Esses critérios, assim como a sua justificativa, encontram plena racionalidade quando conectados ao caso concreto, ou seja, ao fundamento rescindente e às peculiaridades do dano que pode ser provocado. Aliás, a obviedade de que os casos são marcados por peculiaridades próprias é que aponta para a impossibilidade de a lei definir a espécie de prova que deve sustentar a tutela de urgência.

4. O problema da iminência da prática dos atos expropriatórios e a indevida atuação do juiz da execução. Sublinhe-se que a probabilidade de dano não pode ser encontrada na fluência regular da execução da decisão rescindenda. Embora seja costume argumentar que o exequente está prestes a levantar o dinheiro ou que o bem está na iminência de ser expropriado, essas situações não caracterizam probabilidade de dano suficiente para a concessão de tutela urgente

em ação rescisória. Se a realização da execução pudesse autorizar tutela urgente em ação rescisória, bastaria ao executado aguardar o momento em que a execução está pronta para viabilizar a tutela do direito para graciosamente propor a ação rescisória em busca da tutela de urgência. Antes da concessão da tutela urgente, há que se ver a idoneidade do patrimônio do réu da ação rescisória ou mesmo, em uma segunda hipótese, facultar-lhe a prestação de caução.

De outra parte, como a tutela de urgência só pode ser requerida ao relator da ação rescisória, é evidente que o juiz da execução não pode suspendê-la. A competência para a suspensão dos efeitos ou da eficácia da decisão rescindenda é do relator da ação rescisória ou do colegiado competente para o seu julgamento. Caso o juiz singular iniba a execução em virtude da rescisória haverá usurpação da competência do Tribunal ou da Corte Suprema em que a ação rescisória se processa.²⁶⁹

Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum.

1. Generalidades. O réu da ação rescisória tem prazo diferenciado para se defender, que pode variar de 15 a 30 dias, conforme a complexidade da causa. Esse prazo é judicial e, assim, não tem qualquer motivo para ser dobrado em benefício de Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estado, Distrito Federal, Municípios e autarquias e fundações de direito público. A citação deve ocorrer nos moldes dos arts. 246 e 247 do CPC. Tratando-se de ação rescisória, o legislador felizmente não incidiu no equívoco de exigir prévia tentativa de conciliação ou de mediação das partes. De modo que o réu não deve ser citado para comparecer à audiência do art. 334, mas apenas para apresentar resposta.

2. Resposta. Ao apresentar contestação, o réu pode alegar as matérias cabíveis elencadas nos incs. do art. 337 do CPC. A impugnação ao valor da causa, frequente em ação rescisória em virtude da necessidade do depósito de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, CPC), agora deve ser deduzida na própria contestação, conforme o inc. III do art. 337.

É possível apresentar reconvenção quando, ao lado do capítulo que o autor pretende rescindir, houver capítulo que prejudica o réu, desde que marcado por vício rescindente. É claro que, nesse caso, a reconvenção exige o cumprimento dos requisitos da ação rescisória, devendo o réu, por exemplo, realizar o depósito de 5% (art. 968, CPC). O réu não pode apresentar reconvenção se, no momento da resposta, já decorreu o prazo decadencial para impugnar a decisão. Embora se trate de capítulos da mesma decisão, só o autor impugnou o capítulo que lhe prejudica no prazo decadencial.

3. Revelia. Não cabe pensar em reconhecimento jurídico do pedido de rescisão, na medida em que o réu não pode dispor da autoridade da coisa julgada. Do mesmo modo, a não apresentação de contestação obviamente não faz surgir a presunção de veracidade dos fatos alegados. A omissão do réu não pode afastar a coisa julgada. Assim, por exemplo, se o autor alega “prova falsa” como fundamento rescindente – que deve ser demonstrado na ação rescisória –, não fica dispensado de evidenciar a falsidade.²⁷⁰

4. Procedimento. Embora a ação rescisória tenha pressupostos específicos (art. 968, CPC), após o prazo para a apresentação de resposta observar-se-á, com ou sem contestação, o procedimento comum. Assim, ultrapassada a fase postulatória devem ser observados, de acordo com o caso, a necessidade de ordenar-se providências preliminares (arts. 347 a 353, CPC) e o julgamento conforme o estado do processo (arts. 354 a 356, CPC).

Existindo cumulação de ações respeitantes a mais de um capítulo da decisão impugnada, há possibilidade de um dos pedidos exigir prova e outro estar em condições para julgamento imediato. Portanto, pode surgir a possibilidade para a fragmentação do julgamento do mérito, prevista no art. 356 do CPC. Assim, por exemplo, no caso em que um dos capítulos é impugnado com base em violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC) e outro com base em prova cuja falsidade tenha que ser demonstrada na própria ação rescisória (art. 966, VI, CPC). Se um pedido

reclama produção de prova e o outro não, em tese não há razão para atrasar a resolução do pedido em condições de julgamento imediato. Isso é tanto mais importante quanto mais relevante é o imediato julgamento de um dos pedidos cumulados, seja para rescindir a coisa julgada que encobre determinado capítulo decisório (decisão de procedência), seja para liberar definitivamente a sua eficácia, permitindo surgir a irrevocabilidade da coisa julgada que lhe diz respeito (decisão de improcedência). De modo que o julgamento de parcela do mérito, tratando-se de ação rescisória, pode interessar tanto ao autor quanto ao réu, especialmente quando foi concedida tutela urgente para suspender a eficácia da decisão rescindenda.

Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento.

Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.

1. Providência para o julgamento. O art. 971, caput, prevê providência a ser tomada para a preparação do julgamento colegiado. Depois de o relator ter analisado o caso, a secretaria do tribunal tem o dever de encaminhar cópias do relatório a todos os membros do colegiado que discutirão e decidirão a ação rescisória. Trata-se de previsão voltada a informar os julgadores a respeito do caso a ser julgado, com o claro objetivo de permitir o devido debate e adequada decisão.

2. O problema da designação do relator e da composição do colegiado diante dos julgadores que proferiram a decisão rescindida. O parágrafo único do art. 971 preceitua que a escolha do relator da ação rescisória recairá, “sempre que possível”, em julgador que não tenha integrado o colegiado que proferiu a decisão rescindenda. Nada diz sobre a possibilidade de julgadores que proferiram a decisão rescindenda participarem do colegiado que julgará a ação rescisória.

Como é evidente, não há racionalidade em admitir que qualquer dos julgadores que proferiram a decisão rescindenda julguem a ação rescisória, muito menos que um deles possa elaborar o relatório e dar o primeiro voto na sessão de julgamento. Entretanto, a regra apenas obsta que o relator seja designado entre os que participaram do colegiado responsável pela decisão que se pretende rescindir.

Não obstante, por uma questão de racionalidade e coerência, julgadores que participaram do colegiado responsável por tal decisão não devem participar do julgamento da ação rescisória. Isso só deve acontecer quando for absolutamente impossível haver julgamento de que participem outros julgadores. O relator, como diz o parágrafo único do art. 971, só poderá ser um dos que participaram do colegiado que proferiu a decisão rescindenda em caso excepcional, ou seja, quando impossível ter como relator outro julgador. O “sempre que possível”, inserto no parágrafo único, notadamente não é recomendação ao tribunal; é imposição de dever, cuja não observância gera nulidade.

Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos.

1. Instrução. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos (art. 972, CPC). Obviamente que o dispositivo não impede que o próprio relator proceda à instrução do processo.

A prova documental que conforta as alegações fáticas das partes deve vir com a petição inicial e com a contestação. Sendo admissível e necessária a produção de prova oral e de prova pericial, nada obsta que o relator do processo da ação rescisória colha uma e outra (art. 932, I, CPC).

O relator pode delegar, contudo, ao juiz de primeiro grau que funcionou no processo originário

a colheita da prova, ainda que a decisão rescindenda não seja propriamente a sua. Nada obsta, aliás, que delegue a qualquer juízo, desde que respeitado o vínculo com o juízo e com a prova a ser produzida. A inobservância do prazo judicial não gera qualquer consequência de ordem processual, na medida em que o juízo delegado tem o dever de colher a prova determinada pelo juízo delegante.

O art. 972, CPC, permite a delegação de competência para a *colheita da prova*, isto é, para a sua *produção*. A delegação da competência para a colheita da prova importa delegação dos meios para tanto, com o que todas as decisões necessárias à produção da prova são de competência do juízo delegado (como, por exemplo, a nomeação de perito e a colheita dos depoimentos das partes e das testemunhas), nada obstante suscetíveis de revisão perante o juízo delegante. A delegação para a colheita da prova, porém, não importa delegação para dispor sobre a *admissão* dos meios de prova – semelhante decisão obviamente compete ao órgão competente para o julgamento da ação rescisória²⁷¹. Para segura aferição dos limites da delegação é preciso distinguir admissão e produção da prova.

As questões mais interessantes a respeito da instrução da ação rescisória, no entanto, passam longe dos aspectos meramente procedimentais regulados no art. 972, CPC. Na verdade, as questões que realmente interessam residem na *distribuição do ônus da prova* e nos *limites da produção da prova* – acaso *admissível* – na ação rescisória, o que impõe não só a particularização do juízo rescindente no confronto do juízo rescisório, mas também dos diferentes fundamentos em que pode ser arribada.

2. Ônus da Prova. As regras sobre a distribuição do ônus da prova no processo visam a fazer frente a dois problemas diferentes. Essas regras estão previstas no processo civil brasileiro no art. 373, CPC.

Em primeiro lugar, servem como regras de julgamento. Nessa linha, visam a viabilizar que o órgão jurisdicional tenha condições de decidir mesmo diante da dúvida a respeito das alegações de fato. Quando desempenham essa função, sobressai o aspecto objetivo do ônus da prova: evitar a preferência subjetiva do juiz por qualquer uma das versões – igualmente incertas – das partes. Daí a relação que normalmente se faz entre fatos incertos e ônus da prova²⁷², indicando-se que o domínio do ônus da prova (*“Herrschaft der Beweislast”*) começa no exato instante em que termina o império da regra da livre apreciação da prova (*“Reich der freien Beweiswürdigung”*)²⁷³.

Remanescendo a dúvida depois de encerrada a instrução, tem o juiz o *dever* de julgar a causa de acordo com as regras sobre a distribuição do ônus da prova²⁷⁴. Nesse caso, o momento para a sua aplicação é o momento da própria decisão da causa. Desde a perspectiva das partes, trata-se de consequência fundada no princípio da autorresponsabilidade processual²⁷⁵ – e, portanto, no princípio da demanda. Desde a perspectiva do juiz, trata-se de consequência oriunda de seu dever de prestar tutela jurisdicional obedecendo às expectativas das partes referentes a um cenário de possível incerteza – constituindo, pois, um dever fundado no princípio da segurança jurídica²⁷⁶.

Em segundo lugar, servem como regras de comportamento. Nessa linha, abrem a oportunidade para que as partes se posicionem diante dos comportamentos probatórios que têm de assumir para não sucumbirem diante da incerteza judicial quanto às suas respectivas alegações de fato. Quando desempenham essa função, sobressai o aspecto subjetivo do ônus da prova: pautar a conduta das partes diante da necessidade de produção probatória de determinadas alegações de fato.

É claro, no entanto, que as partes podem se encontrar mais ou menos próximas às fontes das provas dos fatos que alegam, podendo chegar mesmo a uma situação de *probatio diabolica* para uma das partes, nada obstante de factível produção para a outra. Nesse caso, a liberdade que preside a figura do ônus cede o passo para a necessidade de igualdade diante da prova, o que pode levar à necessidade de alteração do ônus da prova legalmente distribuído (art. 373, § 1º, CPC)²⁷⁷. Nesse caso, o momento para a aplicação da regra do ônus da prova é um momento necessariamente anterior à decisão da causa, sempre acompanhado da respectiva oportunidade para o seu desempenho. Desde a perspectiva das partes, as regras sobre o ônus da prova

convolam-se em regras que visam a igualdade no processo civil (art. 7º, CPC). Desde a perspectiva do juiz, visam a dar cumprimento ao seu dever de colaboração na condução do processo civil, notadamente ao seu dever de auxílio (art. 6º, CPC)²⁷⁸.

Essa dupla função do ônus da prova está igualmente presente na ação rescisória. É preciso, contudo, individualizar o modo como atuam no juízo rescindente e no juízo rescisório.

2.1. Juízo Rescindente. Quanto ao juízo rescindente, vigora a regra do art. 373, *caput*, CPC: os fundamentos rescindentes, acaso demandem prova, devem ser provados pelo demandante. Obviamente que nesse caso está pressuposta a possibilidade de prova para a formação da convicção quanto ao fundamento do juízo rescindente. Sendo a questão preponderantemente de direito, é claro que as regras sobre o ônus da prova não se colocam.

Questão interessante está em saber se é possível cogitar de *alteração do ônus da prova* no que tange ao fundamento rescindente. Vale dizer: se pode o juiz distribuir de forma diversa o ônus da prova no que concerne ao fundamento capaz de desconstituir a coisa julgada (art. 373, § 1º, CPC).

A resposta só pode ser negativa.

Quer se pense a eficácia da coisa julgada como imutabilidade, conceito inspirado na tradição continental clássica, o qual remete ao conceito de certeza jurídica, que se pense a eficácia da coisa julgada como continuidade, conceito proposto pela doutrina para fazer frente aos novos contornos do princípio da segurança jurídica²⁷⁹, é certo que a coisa julgada impõe a necessidade de se considerar como *efetivamente existente* um estado de coisas valorado por uma determinada decisão judicial (art. 502, CPC). Esse vínculo se traduz no campo do processo na impossibilidade de se erigir uma presunção legal – como, no fundo, é aquela oriunda da regra da distribuição do ônus da prova, quando aplicada como regra de julgamento – em desfavor da coisa julgada. Se isso é verdade, então a dúvida quanto à alegação de fato capaz de rescindir a coisa julgada só pode ser desfeita a favor da coisa julgada, a qual tem *força de lei* (art. 503, *caput*, CPC). Logo, não há como se admitir alteração do ônus da prova no que tange ao juízo rescindente.

A mesma solução vale para outra questão igualmente muito interessante e que diz respeito à possibilidade ou não de se *reduzir o módulo da prova* para a formação do juízo rescindente²⁸⁰. Se não é possível alterar o ônus da prova em desfavor da coisa julgada diante da *probatio diabolica* e da facilidade probatória da contraparte, também não é possível reduzir o módulo da prova diante da mútua inesclarecibilidade dos fatos alegados. As razões para tanto são as mesmas que militam contra a possibilidade de alteração do ônus da prova para a formação do juízo rescindente: viabilizar a redução do módulo da prova significa apoucar o valor da coisa julgada, o que evidentemente viola os arts. 5º, XXXVI, CRFB, e 502, CPC.

2.2. Juízo Rescisório. Sendo favorável o juízo rescindente, em sendo o caso de se prosseguir no julgamento, abre-se a oportunidade para o juízo rescisório. A distribuição do ônus da prova no juízo rescisório *mantém-se a mesma da causa originária* – o que interessa aí é a posição das partes diante da causa que constitui objeto do juízo rescisório, não propriamente a respectiva posição diante do juízo rescindente.

É interessante perceber, no entanto, que vencido o juízo rescindente, a vinculação à força da coisa julgada se esvai, de modo que a regulação do ônus da prova perde a excepcionalidade por essa imposta. Isso quer dizer que *nada impede*, em sendo o caso, que a formação do juízo rescisório – isto é, o re julgamento da causa – ocorra mediante *distribuição diversa do ônus da prova*, acaso concorrentes seus pressupostos legais (art. 373, §§ 1º e 2º, CPC)²⁸¹. O mesmo vale para a *redução do módulo da prova*: o re julgamento da causa na ação rescisória nesse particular perde qualquer especificidade no que tange à distribuição do ônus da prova.

3. Objeto da Prova. Os limites da produção da prova encontram-se intimamente conectados com os limites das alegações²⁸². Daí a razão pela qual a estreita conexão entre *thema decidendum* e *thema probandum*. No que agora interessa, importa ter presente que o ônus de provar está ligado ao ônus de alegar – *só pode ser objeto de prova aquilo que pode ser objeto de alegação*.

Há, portanto, uma íntima relação entre objeto de alegação, objeto da prova e objeto da decisão. Embora possa ser mais restrito, é inequívoco que no mínimo o objeto da prova está cifrado aos limites do objeto da alegação. Fora daí o *órgão jurisdicional não tem sequer cognição*, dado o caráter limitado da causa de pedir na ação rescisória e da sua vinculação às fronteiras de revisibilidade dos julgados demarcadas pela Constituição e pela legislação.

A produção da prova na ação rescisória – como em qualquer outro processo – está condicionada à sua admissibilidade. Isso quer dizer que quando o legislador permite a produção de prova na ação rescisória (art. 972, CPC), ele nada está dispondo sobre a *admissibilidade* da prova, isto é, sobre quais as alegações que são passíveis de constituírem *objeto da prova*. Rigorosamente, esse tema depende dos fundamentos da ação rescisória (art. 966, CPC), os quais determinam o que pode ser *objeto do debate* e por consequência *objeto de prova* no processo em cada uma das fases do juízo.

3.1. Juízo Rescindente. O pedido rescindente – que visa a desconstituir a coisa julgada – só pode ser julgado procedente se há alegação e, em sendo o caso, respectiva prova de um ou de alguns dos fundamentos do art. 966, CPC. No plano horizontal, a cognição no juízo rescindente é parcial, na medida em que se encontra limitada aos fundamentos expressamente arrolados pelo legislador²⁸³. No plano vertical, é preciso distinguir o fundamento em que amparada a ação rescisória, porque por vezes a legislação impõe limitações à cognição do órgão jurisdicional desde o ponto de vista do material sobre a qual incidirá.

3.1.1. A Regra: a Cognição Parcial e Exauriente no Juízo Rescindente. Nada obstante parcializada, a cognição é exauriente nos casos em que a ação rescisória é arrimada em i) prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; ii) impedimento do juiz; iii) dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida ou ainda simulação ou colusão entre as partes com o fim de fraudar a lei; iv) prova falsa; e v) prova nova. Em todos esses casos, podem as partes se valer de quaisquer meios admissíveis para provar suas alegações (art. 369, CPC), o que obviamente implica direito à produção de prova nova no âmbito do juízo rescindente.

Dito de outro modo, qualquer meio de prova é idôneo para a demonstração das alegações que permitem o juízo rescindente nesses casos (art. 966, I, II, primeira parte, III, VI e VII, CPC). *Não há qualquer limitação à produção de prova nova para a formação do juízo rescindente*. No que tange ao juízo rescindente, o art. 972, CPC, reporta-se precisamente a essas hipóteses.

3.1.2. A Exceção: a Impossibilidade de Produção de Prova e de Reexame de Prova para a Formação do Juízo Rescindente por Juízo Absolutamente Incompetente, Violação da Coisa Julgada, Manifesta Violação de Norma Jurídica e por Erro de Fato. Existem casos, todavia, em que a cognição – além de ser parcial desde o ponto de vista horizontal – é também limitada desde o ponto de vista vertical. Em outras palavras, nessas hipóteses o legislador não admite produção de prova nova para a formação do juízo rescindente e sequer admite a reavaliação da prova já produzida nos autos da causa originária.

Em primeiro lugar, há impossibilidade de produção de prova na ação rescisória para a formação do juízo rescindente nos casos em que fundada na alegação de i) incompetência absoluta do juízo e ii) violação de coisa julgada. A limitação decorre aí do fato de as alegações de incompetência absoluta e violação da coisa julgada constituírem alegações insuscetíveis de prova, porque eminentemente de direito. Vale dizer: não constituem alegações fáticas.

Em segundo lugar, há impossibilidade de produção de prova e de reexame de prova para a formação do juízo rescindente nos casos em que a ação rescisória é fundada na alegação de i) violação manifesta de norma jurídica e ii) erro de fato. O caráter *manifesto* da violação e o próprio *conceito* de erro de fato desautorizam que se pense em reexame de prova ou permissão para a produção de prova nova.

Quanto à limitação atinente à ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, a qualificação de *manifesta* afasta qualquer possibilidade de se concluir pela viabilidade de se valorar a prova dos autos da causa originária ou permitir a produção de nova prova para se

chegar ao permissivo legal: a violação somente pode ser qualificada como manifesta se independe do exame da prova produzida na causa originária, sob pena de convalidada a ação rescisória em uma apelação com prazo excessivamente aumentado. *Se o órgão jurisdicional só consegue chegar à violação da norma jurídica mediante reexame da prova – ou, pior, mediante a produção de nova prova –, é evidente que a violação não é manifesta, flagrante, direta, porque sua configuração depende aí da mediação da prova.*

Um exemplo eloquente: não pode o órgão jurisdicional, para concluir pela violação do princípio da justa indenização na desapropriação, adentrar ao reexame do laudo pericial que embasou o julgamento. Se o reconhecimento da manifesta violação depende do reexame da prova, manifestação violação não há – e o pedido rescindente deve ser julgado improcedente.

Quanto à limitação referente à ação rescisória fundada em erro de fato, é preciso lembrar que só há erro de fato se não há erro de juízo, isto é, se não há erro na valoração da prova pelo juiz. Se o que se pretende desconstituir é o erro na valoração do fato, a ação rescisória por erro de fato é evidentemente incabível. O erro de fato é o *erro na percepção de fato* cuja ocorrência ou inoccorrência não há dúvida. Se isso é verdade, então é evidente que a cognição do órgão jurisdicional está cifrada àquele *material já constante dos autos*, o qual não pode voltar a valorar desde o ponto de vista probatório. Fora daí o erro de fato se descaracteriza, assumindo na verdade as vestes de um erro probatório.

3.2. Juízo Rescisório. O juízo rescisório deve operar dentro dos limites da causa originária. Sendo um novo julgamento, natural que se mantenha dentro do perímetro das alegações e das provas já produzidas no processo anterior.

Dependendo, contudo, da natureza do vício rescindente reconhecido e do seu alcance sob a causa originária, pode ser admissível a produção de *prova nova* no âmbito do juízo rescisório. Ao contrário do que ocorre no direito francês (art. 601) e no direito italiano (art. 402), que ligam diretamente a instrução ao juízo rescisório, o direito brasileiro fala genericamente na prova dos fatos alegados pelas partes (art. 972, CPC).

Em regra, sendo admissível instrução no juízo rescindente e no juízo rescisório, o órgão jurisdicional tem o dever de concentrá-la (art. 972, CPC). Isso porque a regra no direito brasileiro é a concentração do julgamento do juízo rescindente e do juízo rescisório (art. 974, CPC), o que obviamente pressupõe prévia instrução. Há, portanto, dupla concentração: da instrução e do julgamento²⁸⁴.

Pode ocorrer, no entanto, de o juízo entender por bem cindir a instrução, com o que cindirá também a decisão²⁸⁵. Embora pouco usual, não se pode negar essa possibilidade em um sistema que consagra a regra do julgamento parcial do mérito (art. 356, CPC). Nesse caso, nada obsta que a instrução – *quando admissível* – referente ao juízo rescisório ocorra após o julgamento do juízo rescindente. Essa contingência, contudo, obviamente não isenta o órgão jurisdicional competente para a ação rescisória de realizar também o juízo rescisório. Como parece evidente, o órgão jurisdicional competente para o juízo rescindente também é competente para proferir o juízo rescisório (art. 974, CPC), não sendo sua competência afastada pela simples necessidade de complementação da instrução para formulação do juízo rescisório.

Art. 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente.

1. Razões finais. A ausência de razões finais, acarretando prejuízo aos fins de justiça do processo, é razão para ineficácia da decisão que julga a ação rescisória. Declarada a ineficácia da decisão que julga a ação rescisória sem prévia oitiva das partes em razões finais, cumpre ao órgão jurisdicional abrir vista às partes para que se manifestem, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, haja vista a necessidade de promoção do direito fundamental ao contraditório (art. 5.º, inc.

LV, CF), entendido como direito a participar do processo influenciando o convencimento do julgador.

2. Ministério Público. Porque o julgamento da ação rescisória ostenta evidente interesse público primário (art. 178, I, CPC), o Ministério Público, não sendo o autor da ação rescisória, deverá atuar no processo como custos legis, tendo vista dos autos para manifestação final depois da apresentação das razões das partes (art. 179, I, CPC).

3. Julgamento. O julgamento dar-se-á, conforme o caso, na forma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 259/262, RISTF), do Superior Tribunal de Justiça (arts. 233/238, RISTJ), dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais dos Estados. No julgamento da ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo (Súmula 252, STF: “na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo”).

Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindir a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inc. II do art. 968.

Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2.º do art. 82.

1. Procedência. Julgando procedente o pedido rescisório, o tribunal rescindir a sentença e proferirá, se for o caso, novo julgamento. O tribunal que julga procedente o pedido rescisório só não procederá ao novo julgamento se não couber novo julgamento da causa – isto é, se a rescisão do julgado por si só for satisfatória à parte demandante. Vale dizer: sendo o caso de novo julgamento, tem o tribunal de avançar nessa seara e disciplinar a situação litigiosa existente entre as partes. Julgado procedente o pedido rescisório, o valor do depósito deve ser restituído ao demandante.

2. Inadmissibilidade. O pedido na ação rescisória é inadmissível se o demandante narrou, como causa de pedir, alegação estranha aos incs. do art. 966, CPC, ou se não concorrerem os demais pressupostos para sua admissibilidade (por exemplo, existência de decisão definitiva ou decisão impeditiva, trânsito em julgado, tempestividade etc.).

3. Improcedência. O pedido na ação rescisória é improcedente se o tribunal se convencer da inocorrência do fundamento alegado pelo demandante na causa de pedir.

4. Desempate. Em caso de eventual empate entre os membros do colegiado, há de ser feito o desempate pelo Presidente da Seção ou do Grupo. Cabe ao Presidente optar por uma ou outra das posições. Ou seja, o Presidente não pode votar pela procedência com base em causa de pedir diferente daquela que foi acolhida pelos votos que formaram a posição de procedência da rescisória. Neste caso, o voto de desempate estaria consolidando o empate, uma vez que se chegaria ao resultado de 2 x 2 x 1. O desempate não seria permitido ainda que os votantes pela rescisão voltassem atrás e acompanhassem o voto do Presidente. Nesta situação, ainda que se possa pensar em 3 x 2, não haveria desempate, mas novo fundamento que estaria permitindo a outros juízes, que não o Presidente, o desempate.

É evidente que o Presidente da Seção ou do Grupo não pode apresentar fundamento novo para o julgamento da rescisória. Se assim fosse, teria o dever de lavrar o acórdão, o que evidentemente não é possível. O Presidente da Seção tem apenas de desempatar, escolhendo entre um ou outro caminho. O voto de desempate é prerrogativa do Presidente, não podendo ser transferido a outro magistrado.

5. Multa. Julgado inadmissível ou improcedente por unanimidade o pedido na ação rescisória por unanimidade, reverterá ao demandado, a título de multa, o valor do depósito prévio exigido para propositura da ação rescisória (arts. 968, II, e 974, CPC). A liberação desse valor independe da verificação de “prejuízo concreto” ao demandado.²⁸⁶ Trata-se de multa com caráter repressivo ao

“abuso no exercício do direito de ação”, sem qualquer conotação indenizatória.²⁸⁷ A liberação do depósito para o demandado não isenta o demandante de indenizá-lo das despesas processuais (art. 82, § 2.º, CPC).

6. Recursos. Do julgamento da ação rescisória caberá, conforme o caso, embargos de declaração (art. 1.022, CPC), recurso especial (art. 105, III, CF) e/ou recurso extraordinário (art. 102, III, CF).

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1.º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2.º Se fundada a ação no inc. VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3.º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.

1. Direito à Rescisão. A ação rescisória visa à tutela de remoção do ilícito mediante desconstituição de decisão judicial em que há violação do direito ao processo justo ou à dimensão normativa da decisão justa (art. 966, CPC). O dado que interessa para determinação da natureza do prazo a que se submete o exercício da ação rescisória está na natureza *desconstitutiva* do juízo rescindente. O debate sobre a natureza da ação – e, *a fortiori*, da ação rescisória – ou da tutela de remoção do ilícito que com essa se pretende obter é capaz de facilmente desviar o foco daquilo que é realmente essencial para solução do problema²⁸⁸.

O prazo para o exercício da ação rescisória é de natureza decadencial, dado que o juízo rescindente que se pretende obter é de natureza desconstitutiva. Daí que o direito à rescisão – como direito potestativo que é – submete-se a prazo decadencial²⁸⁹. Tendo essa natureza, pode ser conhecido de ofício pelo juiz (art. 210, CC).

Como prazo decadencial, o prazo para o exercício da ação rescisória não se suspende e não se interrompe²⁹⁰. O legislador houve por bem, no entanto, prorrogar o prazo para o seu exercício “até o primeiro dia útil imediatamente subsequente”, quando “expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver expediente forense” (art. 975, § 1º, CPC). Note-se que aí não há nem suspensão e nem interrupção: o que há é simples *prorrogação*. Eventual prazo consumido durante as férias forenses, por exemplo, não volta a correr pelo restante – como ocorreria se se tratasse de suspensão – e não é devolvido à parte por inteiro – como ocorreria se se tratasse de interrupção. O que há é a simples possibilidade de propor a ação rescisória no primeiro dia útil subsequente: fora daí o prazo é consumido e a ação rescisória há de ser considerada fora do prazo.

Sendo um prazo decadencial, aplicam-se os arts. 207 a 210, CC, ao prazo para o exercício da ação rescisória. O prazo para o exercício da ação rescisória não corre contra os incapazes (arts. 3º, 198, I, e 208, CC). Se a ação rescisória tem o seu prazo consumido contra relativamente incapaz (art. 4º, CC) ou contra pessoa jurídica, esses têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que deram causa à perda do prazo ou não a alegaram oportunamente (arts. 195 e 208, CC).

A fixação de um lapso temporal para o seu exercício atende a um imperativo ligado ao princípio da segurança jurídica²⁹¹ e mais especificamente referente à necessidade de estabilidade das relações sociais. O prazo legal da ação rescisória constitui, portanto, uma concessão em favor da justiça do processo e da dimensão normativa da justiça da decisão em detrimento do princípio da segurança jurídica²⁹². Essa concessão, no entanto, não pode ignorar a necessidade de que os

litígios efetivamente terminem. Vale dizer: que ao fim e ao cabo se opere a coisa julgada – fim do processo civil classicamente apontado pela doutrina²⁹³ e que encarna melhor que qualquer outro o seu compromisso com a segurança jurídica.

O prazo para o exercício da ação rescisória é de 2 (dois) anos (art. 975, *caput*, CPC)²⁹⁴. A sua duração, no entanto, variou muito – seja do ponto de vista da história²⁹⁵, seja do ponto de vista do direito comparado²⁹⁶. No nosso direito, por exemplo, a ação rescisória já experimentou o prazo de trinta anos – anterior ao Código Civil de 1916 – e de cinco anos – com o Código Civil de 1916²⁹⁷ – antes de estabilizar-se em dois anos com o Código de 1973 e com o Código de 2015.

Obviamente, o biênio para a propositura da ação rescisória não apanha a ação anulatória de ato processual (art. 966, § 4º, CPC), cujo prazo deve ser buscado no Código Civil (arts. 178 e 179, CC) ou no Decreto n. 20.910, de 1923 (art. 1º). O prazo para o exercício da ação rescisória também não se aplica à ação anulatória de laudo arbitral (art. 33, § 1º, Lei n. 9.307, de 1996).

O termo inicial para a ação rescisória altera-se de acordo com o fundamento em que fundada a ação rescisória. Como regra, o termo inicial é o trânsito em julgado da “última decisão proferida no processo” (art. 975, *caput*, CPC). Todavia, nossa ordem jurídica prevê duas exceções: i) se a ação rescisória for fundada em prova nova, a sua descoberta será o termo inicial, respeitado o prazo máximo de cinco anos (art. 975, § 2º, CPC); e ii) se a ação rescisória for fundada em simulação ou colusão das partes, o prazo começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua ciência pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público que não participou do processo (art. 975, § 3º, CPC).

A propósito, há quem entenda que outra exceção ao termo inicial para o exercício do direito à ação rescisória está no caso de a ação rescisória ser fundada em prova falsa apurada no juízo criminal, indicando-se aí o trânsito em julgado da sentença penal como seu termo inicial²⁹⁸. Nada impede, porém, que se proponha a ação rescisória enquanto pendente o processo criminal que visa à apuração da falsidade da prova, inclusive com a indicação de eventual suspensão do processo da ação rescisória por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC)²⁹⁹. Essa solução tem a vantagem de evitar qualquer risco ligado à colisão entre duas decisões judiciais sobre o mesmo objeto e de respeitar o teor do art. 975, CPC, que poderia ter previsto expressa exceção a respeito, mas eloquentemente não o fez.

2. Trânsito em Julgado. O art. 975, *caput*, CPC, refere que o termo inicial para a propositura da ação rescisória é o trânsito em julgado da “última decisão proferida no processo”. O dispositivo tem clara inspiração na súmula n. 401, STJ: “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”.

O trânsito em julgado, como é sabido, é pressuposto para a caracterização da rescindibilidade da decisão (art. 966, *caput*, CPC). Daí que saber o momento em que esse fato ocorre constitui elemento fundamental para caracterização do termo inicial da ação rescisória.

O primeiro problema que envolve a interpretação do art. 975, *caput*, CPC, está em saber se, diante do art. 975, *caput*, CPC, é possível ou não sustentar a tese da coisa julgada parcial e do respectivo trânsito em julgado parcial. O segundo, em saber quando ocorre o trânsito em julgado nos casos em que há inadmissibilidade recursal.

Quanto ao primeiro problema, basicamente duas alternativas são oferecidas ao intérprete.

A primeira está em que o trânsito em julgado é sempre uno e único, de modo que pouco importa o momento em que determinado capítulo ou que certa decisão de mérito se torna insuscetível de recurso. Nesse caso, o termo inicial para a ação rescisória coincidirá sempre com o escoamento do último prazo recursal ligado ao processo como um todo³⁰⁰.

A segunda está em que o trânsito em julgado pode ocorrer progressivamente, conforme determinadas decisões sobre parte do pedido ou sobre um ou alguns dos pedidos cumulados ou sobre determinados capítulos da decisão tornem-se insuscetíveis de recurso. Nesse caso, o termo

inicial para a ação rescisória poderá ocorrer de maneira difusa ao longo de todo o processo, coincidindo o respectivo trânsito em julgado com a inimpugnabilidade de determinada parcela ou de determinada decisão³⁰¹.

Se é verdade que a opção pela interpretação ligada ao trânsito em julgado uno e único tem o mérito de simplificar o problema do termo inicial do prazo para a ação rescisória, sendo por essa razão pragmaticamente preferível à luz de sua pronta e inequívoca identificação, porque a torna mais segura, também é verdade que a alternativa interpretativa concernente ao trânsito em julgado parcial é preferível do ponto de vista do direito de ação, do direito à adequação da tutela jurisdicional, da igualdade entre os litigantes e da duração razoável do processo³⁰². Daí que à luz do direito ao processo justo – em cuja massa se encontram os direitos de ação, à adequação da tutela jurisdicional, à igualdade e à duração razoável – é possível sustentar como mais apropriada sistematicamente essa última interpretação do art. 975, *caput*, CPC.

Note-se que esse dispositivo refere apenas que o termo inicial da ação rescisória é fincado no “trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. Tendo em conta a necessidade de compatibilizá-lo com as exigências que emanam de outros dispositivos, nada obsta que se entenda que o trânsito em julgado concerne à última decisão proferida no processo *em relação a determinada parcela do pedido, pedido cumulado* ou ainda *em relação à determinada questão passível de configurar um capítulo decisório autônomo*.

Como o Código de 2015 encampou inequivocamente a tese do julgamento definitivo da parte incontroversa da demanda (art. 365)³⁰³, além de ter mantido a regra tradicional ligada ao efeito substituto do recurso (art. 1.008), há expresso reconhecimento do direito à execução definitiva da parte incontroversa, ainda que o processo penda para análise da parte controversa ou dos demais capítulos decisórios expressamente impugnados por determinado recurso. Diante dessa contingência, seria difícil reconhecer o valor da coisa julgada parcial e viabilizar a respectiva execução definitiva, mas não admitir como contrapartida o exercício imediato da ação rescisória a partir da configuração do trânsito em julgado parcial.

Essa dificuldade reside basicamente em quatro razões.

A uma, estar-se-ia obstando ilicitamente o direito de ação, especificamente o direito à ação rescisória, porque se estaria admitindo a formação do trânsito em julgado parcial – pressuposto à formação da coisa julgada parcial – para efeitos de execução definitiva, mas não para efeitos de rescindibilidade da respectiva decisão. Haveria aí violação do direito de ação (arts. 5º, XXXV, CRFB, e 3º, CPC).

A duas, estar-se-ia violando o direito à tutela jurisdicional adequada, porque se estaria admitindo a produção definitiva de efeitos de determinada decisão sem ao mesmo tempo viabilizar a propositura da ação adequada para sua discussão, inclusive no que tange à suspensão dos seus efeitos mediante técnica antecipatória. Haveria aí violação do direito à tutela jurisdicional adequada (arts. 5º, XXXV, CRFB, e 3º, CPC).

A três, estar-se-ia violando a igualdade entre as partes, porque o trânsito em julgado estaria configurado em diferentes momentos para as partes: para uma a partir do esgotamento dos recursos atinente à parcela do pedido, ao pedido cumulado ou a determinado capítulo da decisão e para outra apenas do escoamento do prazo recursal da última decisão prolatada no processo como um todo, sem qualquer elemento que legitime essa quebra de simetria. Haveria aí violação do direito à igualdade e à paridade de armas no processo (arts. 5º, I, CRFB, e 7º, CPC)³⁰⁴.

A quatro, estar-se-ia violando a duração razoável do processo, porque obstar a propositura da ação rescisória até o momento do trânsito em julgado final significa prolongar desnecessariamente a pendência do estado de rescindibilidade de uma decisão, o que ofenderia o direito à duração razoável da solução definitiva do litígio. Haveria aí violação do direito à duração razoável do processo (arts. 5º, LXXVIII, CRFB, e 4º, CPC).

Isso quer dizer que o trânsito em julgado ocorre, para efeitos de termo inicial da ação

rescisória, no momento em que parcela do pedido, um dos pedidos cumulados, um capítulo da decisão ou a decisão como um todo se torna insuscetível de recurso. O art. 975, *caput*, se lido na perspectiva do direito ao processo justo, é compatível com a tese da coisa julgada progressiva e do trânsito em julgado parcial.

Quanto ao segundo problema, tem se decidido que o trânsito em julgado posteriormente ao esgotamento das vias recursais, ainda que o recurso não tenha sido conhecido – isto é, tenha sido inadmitido. Em outras palavras, entende-se que a decisão de inadmissibilidade recursal produz efeitos apenas para frente, vale dizer, *ex nunc*, ressalvadas as hipóteses em que há intempestividade ou manifesto descabimento por má-fé ou erro grosseiro³⁰⁵.

O fundamento para semelhante orientação radica no princípio da segurança jurídica, mais especificamente na necessidade de proteção da confiança legítima do recorrente. O recorrente diligente e de boa-fé espera que o seu recurso seja admitido. Ocorre, porém, que muitas vezes o prazo para a apreciação da admissibilidade recursal pode superar o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. Se vingasse a orientação no sentido de que o juízo de admissibilidade negativo tem em regra efeitos *ex tunc*, retroagindo à data da interposição do recurso, bem poderia ocorrer de o recorrente receber a decisão de inadmissibilidade quando já escoado o seu prazo para a ação rescisória. Essa contingência fatalmente forçaria a prática a propor ações rescisórias condicionais visando simplesmente a obstar a fluência do prazo decadencial, o que desatenderia a necessidade de economia processual que deflui do direito à duração razoável do processo.

3. Prova Nova. O Código de 1973 não previa termo inicial diferenciado para o exercício da ação rescisória fundada em prova nova. Vários outros ordenamentos jurídicos, no entanto, contavam e ainda contam com previsão semelhante àquela hoje constante do § 2º do art. 975, CPC³⁰⁶. O Código de 2015 alinhou-se felizmente à solução vencedora.

O prazo para a propositura da ação rescisória fundada em prova nova é de dois anos – apenas a sua fluência é que ocorre a partir do dia em que descoberta a prova nova, contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente. Em nenhuma hipótese, porém, será admitida ação rescisória depois de transcorrido o prazo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda (art. 975, § 2º, CPC).

Embora o nosso legislador não mencione especificamente, ao contrário do que ocorre no direito francês (art. 596 do *Code de Procédure Civile*), o ônus da prova da data da descoberta da prova nova toca ao autor da ação rescisória. Segue-se aí a regra geral sobre a distribuição do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

Em face do Código de 1973, que se referia a “documento novo” e não a “prova nova”, afirmava-se que o documento deveria existir à época em que os fatos eram discutidos no processo em que proferida a decisão rescindenda. Assim, por exemplo, dizia Barbosa Moreira que “documento ‘cuja existência’ a parte ignorava é, obviamente, documento que *existia*; documento de que ela ‘não pôde fazer uso’ é, também, documento que, noutras circunstâncias, poderia ter sido utilizado, e portanto *existia*”³⁰⁷.

Porém, quando a rescindibilidade passa a depender de “prova nova”, isto é, não apenas de documento, mas também de prova testemunhal e prova pericial, é certo que não se pode pensar em *prova* que existia. Em primeiro lugar, não se pode falar em prova existente, na medida em que a prova obviamente não pode ter sido produzida e, portanto, existir enquanto prova. Tratando-se de prova testemunhal, o que existia é a *fonte* da prova, ou seja, a testemunha, que, *v. g.*, não pôde depor por estar em local desconhecido ou por estar em condição de saúde que lhe impedia de prestar depoimento. No que diz respeito à prova pericial, ainda, essa se torna admissível para fundar a rescisória quando o *meio técnico ou a tecnologia* que permite a produção da prova pericial *não existia*. Aliás, nem mesmo a existência do documento pode ser vista como absoluta, embora em regra esse deva existir³⁰⁸. Pense-se, como exceção, no documento público que apenas pode ser confeccionado posteriormente.

Nesses casos, deve-se pensar não propriamente na *descoberta* da prova nova como o termo inicial para a ação rescisória, mas mais especificamente no momento a partir do qual a prova nova passa a ser *acessível* à parte interessada. A descoberta da prova nova significa aí sua acessibilidade.

4. Simulação ou Colusão das Partes. Também no caso de simulação ou colusão das partes o termo inicial para a propositura da ação rescisória não flui do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas “a partir do momento da ciência da simulação ou da colusão” (art. 975, § 3º, CPC). O ônus da prova da ciência também é da parte que invoca a simulação ou a colusão para rescindir a decisão – o terceiro prejudicado, o Ministério Público, que deveria ter participado do processo e não participou, e qualquer outro que deveria ter sido “ouvido no processo que lhe era obrigatória a intervenção” (art. 967, IV, CPC)³⁰⁹.

Ao contrário do que ocorre na hipótese de ação rescisória fundada em prova nova, no caso de ação rescisória fundada em simulação ou colusão das partes o legislador não repete o prazo máximo de cinco anos do trânsito em julgado como limite para o seu exercício. O legislador apenas refere que o prazo é de dois anos, o qual flui da ciência da simulação ou da colusão. É claro, porém, que o princípio da segurança jurídica determina uma interpretação favorável à estabilidade das relações sociais, de modo que parece adequada a invocação analógica do prazo máximo de cinco anos – *ubi ratio, ubi jus*. Vale dizer: a rescindibilidade da decisão fruto da simulação ou colusão das partes não sobrevive ao prazo de cinco anos do trânsito em julgado³¹⁰.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Monograficamente, Pontes de Miranda, Tratado da Ação Rescisória, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976; Teresa Arruda Alvim Wambier, Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008; Flávio Yarshell, Ação Rescisória. São Paulo: Malheiros, 2005; Alexandre Freitas Câmara, Ação Rescisória, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014; Fabiano Carvalho, Ação Rescisória. São Paulo: Saraiva, 2010; Rodrigo Barioni, Ação Rescisória e Recursos para os Tribunais Superiores. São Paulo: Ed. RT, 2013; Sérgio Porto, Ação Rescisória Atípica. São Paulo: Ed. RT, 2009; Ronaldo Cramer, Ação Rescisória por Violação da Norma Jurídica, 2. ed. Salvador: JusPodium, 2012.

2

STJ, REsp 12.586/SP, 3.ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 08.10.1991, DJ 04.11.1991, p. 15.684.

3

“O critério básico para determinar o instante adequado para a solução do conflito e para a tutela jurisdicional do direito é o do exaurimento do contraditório. Quando os fatos litigiosos foram debatidos pelas partes e não mais precisam ser elucidados por prova, surge o momento para a definição do litígio e para a tutela do direito. Neste caso se pode dizer que o pedido está ‘maduro’ para definição. Este, aliás, é o critério que impõe e justifica o julgamento antecipado do mérito. A duração é desrazoável quando o pedido se torna maduro para julgamento e a sua definição é adiada. Se o pedido, depois de maduro, não é desde logo definido, a demora passa a violentar o direito fundamental à duração razoável. Acontece que é frequente e natural que parte de um pedido ou um dos pedidos cumulados se torne incontroverso antes da outra parcela da demanda. Ou seja, é comum que uma parte da demanda se torne incontroversa no

curso do processo. Neste caso, como é intuitivo, o processo deveria permitir a fragmentação da definição da demanda ou a cisão do julgamento do mérito. Porém, isto jamais foi possível na estrutura do processo civil clássico ou do processo civil de origem chiovendiana. Chiovenda elaborou o princípio da ‘unità e unicità della decisione’. Em poucas palavras, Chiovenda entendia não haver racionalidade em admitir a fragmentação do mérito, pois a demanda, ainda que necessitasse de provas somente em parte, seria julgada com mais qualidade e perfeição caso fosse apreciada em sua integralidade. Além disto, a cisão do momento para a definição do mérito seria descabida, uma vez que a produção das provas – no sistema oral imaginado por Chiovenda – não retardaria o desfecho do processo ou tornaria a sua duração desrazoável. Não obstante, o princípio da unidade e da unicidade, idealizado há mais de cem anos, fincou-se em premissas – especialmente na oralidade chiovendiana – que atualmente não podem mais ser admitidas como válidas. Hoje o julgamento da integralidade da demanda, quando parte dela se torna incontroversa logo no início do processo, arrasta por longo período de tempo a definição da parcela que não depende de produção de prova e, assim, do tempo da continuação do processo. Como o direito à duração razoável exige que o julgamento do mérito e a tutela do direito ocorram quando o pedido se torna maduro para definição, e a maturação da demanda pode se dar em parte no curso do processo, não há como deixar de concluir que a estrutura técnica do processo civil, para responder ao direito fundamental à duração razoável e aos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, deve necessariamente possuir uma técnica processual que permita a definição da parte incontroversa da demanda no curso do processo”. (Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1996). V. Idem, *Abuso de Defesa e Parte Incontroversa da Demanda* 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2007.

4

Michele Taruffo, “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni, *Rivista di diritto processuale*, 1972, p. 275 e ss; Diego Volpino, *L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana*. Padova: Cedam, 2007, p. 291 e ss.

5

“Prima di procedere oltre in questa illustrazione volutamente schematica degli atti introduttivi del giudizio dell’attore e del convenuto, è opportuno sin d’ora accennare alla possibilità che i fatti (costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi) rilevanti ai fini del diritto fatto valere siano o meri fatti o fatti-diritti. Per meri fatti si intendono quei fatti che rilevano unicamente come fatti costitutivi modificativi ecc. del diritto fatto valere in giudizio: es. colpa nella responsabilità extracontrattuale, prescrizione, adempimento; per fatti-diritti si intendono invece quei fatti che, oltre ad avere rilievo di fatti costitutivi, impeditivi ecc. ai fini del diritto fatto valere in giudizio dall’attore sono a loro volta l’effetto di una autonoma fattispecie, così che potrebbero anche essi costituire oggetto di una autonoma domanda: es. qualità di proprietario del convenuto ai fini del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2054 terzo comma c.c., qualità di erede dell’attore (o del convenuto) ai fini del credito (o del debito) del de cuius, qualità di proprietario ai fini del diritto al risarcimento dei danni causati al bene dell’attore, rapporto di parentela ai fini del diritto agli alimenti, novazione quale fatto estintivo del credito fatto valere ecc” (Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 2002, p. 58).

6

Como reconhecem pacificamente as cortes estadunidenses, “the doctrine of collateral estoppel will not be applied unless it appears that the party against whom the estoppel is asserted had a full and fair

7

Ao contrário do que acontece no processo legislativo, em que o ato de positivação de poder – a lei – é fruto da participação de membros eleitos, significando participação indireta, e do que ocorre diante das formas de participação direta – referendo popular, plebiscito, iniciativa popular, ação popular etc. –, o exercício do poder, no processo jurisdicional, não depende da técnica representativa e não se assenta nos fundamentos da democracia participativa, ou melhor, nas ideias voltadas a permitir a participação direta do cidadão no poder. Não há dúvida de que o juiz profere atos de positivação de poder. As suas decisões – e não se fala aqui apenas da sentença – podem ser impostas, já que o poder jurisdicional é inevitável, pouco importando a vontade do particular, que não pode se subtrair ao poder do juiz. Mas o juiz, como se sabe, não é eleito. E a participação da parte no processo jurisdicional não deriva do fato de que ela está aí preocupada em participar diretamente do poder. Isso acontece quando o cidadão propõe a ação popular, já que esta lhe confere o poder de pedir a correção dos atos que ferem a coisa pública, mas não quando alguém participa do processo como litigante, ou mais especificamente como parte. Quem toma parte em um litígio certamente será atingido pelos efeitos das decisões proferidas no processo. E, mais especificamente, pela coisa julgada material – qualidade que confere imutabilidade e estabilidade à decisão, a qual se torna sujeita apenas à ação rescisória (art. 966, CPC), que permite a desconstituição da coisa julgada em hipóteses excepcionais, como a de corrupção do juiz. No processo jurisdicional, o exercício do poder deve prestar contas aos litigantes, isto é, àqueles que são atingidos pela coisa julgada material e por todas as decisões proferidas pelo juiz. Embora a sua base esteja no princípio político da participação, entende-se que o mecanismo técnico jurídico capaz de expressar o direito de alguém participar de um processo que o afeta em sua esfera jurídica é o do contraditório, presente na Constituição Federal na qualidade de direito fundamental (art. 5.º, LV, CF).

8

Por não admitir a produção de prova diferente da documental – e assim não se expor ao tempo necessário à produção das provas testemunhal e pericial –, o mandado de segurança permite que o mérito seja definido de modo mais célere. Mas a técnica da cognição exauriente secundum eventum probationis, além de viabilizar o julgamento do mérito de forma mais tempestiva, não elimina a possibilidade de o jurisdicionado, que lançou mão do mandado de segurança, mas necessitava de outras provas além da documental, recorrer ao procedimento comum. Lembre-se de que, nos termos da Súmula 304 do STF, a “decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria”. A súmula quer dizer que, em caso de denegação do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo – falta de prova documental –, não há declaração de que o direito subjetivo material não existe.

9

É certo que os conceitos carneluttianos de “lide total” e “lide parcial” não têm pertinência no processo, já que o conflito de interesses, no domínio do processo, sempre é uma “lide total”. Tais conceitos, porém, são valiosos para quem pretende observar a efetiva relação do processo com o direito material e, em particular, como o processo limita o tratamento de determinados conflitos de interesses. O emprego desses conceitos, como é evidente, supõe uma visão do processo a partir do plano do direito material.

10

Um procedimento, quando deseja abarcar toda e qualquer situação conflitiva, possui cognição plena (no sentido horizontal) e exauriente (no sentido vertical). Dessa forma, o procedimento não limita o conflito de interesses ou não exclui a possibilidade da alegação de determinadas questões por parte do réu (cognição parcial), como também não viabiliza, em razão da urgência, o encerramento do procedimento com uma sentença baseada na denominada “fumaça do bom direito” (cognição sumária).

11

“Issue preclusion is sometimes unfair if party to be bound lacked an incentive to litigate in first trial, especially in comparison to stakes of second trial” (Peavey v. United States, United States District Court, District of Columbia, August 26, 2015, F.Supp.3d, 2015 WL 5063164).

12

Em *Otherson v. Department of Justice, I.N.S.*, declarou-se que “preclusion in second trial must not work an unfairness” (*Otherson v. Department of Justice, I.N.S.*, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, June 21, 1983, 711 F.2d 267, 228 U.S.App.D.C. 481). No mesmo sentido, *Yamaha Corp. of America v. United States*, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, April 14, 1992, 961 F.2d 245.

13

Ronald J. Allen e Michael S. Pardo, *The myth of the law-fact distinction*, *Northwestern University Law Review*, 2003.

14

Como disse Austin Scott, “the doctrine of collateral estoppel is applicable not merely to questions of fact but also to questions of law” (Austin Scott, *Collateral estoppel by judgment*, *Harvard Law Review*, 1942, p. 3 e ss); V. Geoffrey Hazard Jr., *Preclusion as to issues of law: the legal system’s interest*, *Iowa Law Review*, 1984, p. 81 e ss.

15

Diego Volpino, *op. cit.*, p. 340 e ss.

16

“A prior state court proceeding cannot bar federal court’s consideration of matters which were not actually litigated and determined in prior proceeding” (*Winters v. Levine*, United States Court of Appeals, Second Circuit. January 16, 1978).

17

Jeremy Bentham, *Rationale of judicial evidence*. London: Hunt and Clarke, 1827, p. 579.

18

O Justice White, ao justificar a sua opinion em *Parklane* – que nega a limitação do collateral estoppel às partes litigantes –, alude ao argumento de Bentham: “the cases and authorities discussed above connect erosion of the mutuality requirement to the goal of limiting the relitigation of issues where that can be achieved without compromising fairness in particular cases (...). The broader question is whether it is any longer tenable to afford a litigant more than one full and fair opportunity for judicial resolution of the same issue (...). It encompasses the concern exemplified by Bentham’s reference to the gaming table in his attack on the principle of mutuality of estoppel. In any lawsuit where a defendant, because of the mutuality principle, is forced to present a complete defense on the merits to a claim which the plaintiff has fully litigated and lost in a prior action, there is an arguable misallocation of resources” (*Parklane v. Shore*, 439 U.S. 322, 1979).

19

Bernhard v. Bank of America Nat. Trust & Saving Association, Supreme Court of California, 19 Cal2d 807, 122 P2d 892, 1942.

20

Argumentou a Suprema Corte da Califórnia que “the case justify this exception on the ground that it would be unjust to permit one who has had his day in court to reopen identical issues by merely switching adversaries” (*Bernhard v. Bank of America Nat. Trust & Saving Association*, Supreme Court of California, 19 Cal2d 807, 122 P2d 892, 1942).

21

Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 1971.

22

“The Supreme Court, Mr. Justice White, held that in patent infringement suit, patentee is estopped to assert validity of patent that has been declared invalid in prior suit in federal court against a different defendant, unless patentee demonstrates that he did not have full and fair opportunity, procedurally, substantively, and evidentially, to litigate the validity of his patent in the prior suit” (*Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 1971).

23

Há quem fale, na mesma hipótese, em “defeito de construção”: “os defeitos de projeção ou construção derivam de um erro na projeção, de uma escolha inadequada de materiais, ou, ainda, de uma técnica de fabricação. O produto é defeituoso porque ilegitimamente inseguro na sua concepção ou idealização” (Silvio Luís Ferreira da Rocha, *Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto no direito brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 102). Porém, como diz Calvão da Silva, “defeito de concepção” constitui terminologia mais impressiva e sugestiva, “visto que, tal como design defects, nos coloca imediatamente na fase da concepção, idealização ou projeto do produto, diferentemente da terminologia alemã Konstruktionsfehler, que se presta a equívocos, pois inculca a ideia de erros cometidos na fase de fabrico propriamente dito a que os autores americanos apelidam, justamente, de defeitos in construction”.

(João Calvão da Silva, Responsabilidade civil do produtor, Coimbra: Almedina, 1999, p. 657).

24

Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e tutela dos direitos. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, Parte II, Capítulo 1, Item 1.4.4 e Capítulo 3, Item 3.15.

25

Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1965.

26

Enrico Tullio Liebman, Parte o ‘capo’ di sentenza, Rivista di diritto processuale, 1964; Cândido Dinamarco, Capítulos de sentença. São Paulo: Malheiros, 2014.

27

Idem. Ibidem.

28

V. Flávio Luiz Yarshell, Ação rescisória – juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 155.

29

Não há como confundir o que aqui se propõe, ou seja, a convivência de capítulos (de mérito ou de natureza processual) que constituem unidades contidas na parte dispositiva da decisão e de capítulos de questões que lhe são prejudiciais, com a tese carneluttiana de que só há capítulos na solução de questões, na medida em que os capítulos da sentença seriam capítulos da lide – que teria uma ou várias questões. Ver Francesco Carnelutti, Sistema del diritto processuale. Padova: Cedam, 1936, vol. I.

30

Sem razão, José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil [1973]. Rio de Janeiro: Forense, 2008, vol. 5, p. 122. Igualmente confundindo decisão colegiada com reunião de decisões individuais dos membros do colegiado, Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil [1973]. Rio de Janeiro: Forense, 1975, t. 6, p. 270.

31

Curioso, para dizer o mínimo, o argumento de Pontes de Miranda: “O art. 485, I, somente cogita da ação rescisória da sentença se se trata de juiz ou de membro de tribunal. Não se afaste a hipótese de serem acusados algum ou todos na petição inicial da ação rescisória: se de um só se faz prova suficiente, sem atingir o quanto necessário da votação, a rescisão não ocorre”. (Pontes de Miranda, Comentários ao Código, cit., p. 270). Em primeiro lugar, o fato de se acusar todos os julgadores que dão composição ao colegiado de corrupção não conduz à necessidade de prova de corrupção de todos para a rescisão da

decisão. Depois, não há como estabelecer relação entre a corrupção, a prevaricação e a concussão, enquanto causas de rescindibilidade, com o número de julgadores que votaram em favor da decisão que se pretende rescindir. Ora, basta que um dos julgadores tenha incidido em uma dessas causas para que a decisão colegiada esteja contaminada e, assim, torne-se rescindível.

32

Lei 10.741/2003, Art. 80: As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

33

Sabe-se que a previsão de dolo como fundamento rescindente – já presente no art. 485, III, do CPC/1973, tem origem no direito italiano, especificamente no art. 395, 1, do CPC italiano: “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra”. Elio Fazzalari, ao tratar do tema na Enciclopedia del Diritto, assim se pronuncia: “il dolo di una delle parti in danno dell’altra (art. 395 n. 1) è vizio che inficia la condotta della parte che inganna l’altra e/o il giudice, per trarli in errore; vizio che, ovviamente, si ripercuote sulla sentenza. L’attore in revocazione assume di aver scoperto, dopo l’emanazione della sentenza, e di poter dimostrare che un determinato comportamento di quella che fu sua controparte nel processo a quo – comportamento allora apparso normale – era, invece, doloso, cioè volto a trarre in inganno ed a nuocere all’avversario. Non può trattarsi di *dolus bonus*, di uma pur criticabile furbizia, bensì di *dolus malus*, cioè di un inganno, un artifício posto in essere per daneggiare l’avversario, paralizzandone a defesa, o per sviare il giudice” (Elio Fazzalari, Revocazione (dir. proc. civ.), Enciclopedia del Diritto, vol. XL, item 6). Ver ainda Carlos Alberto Nicoletti, La revocazione della sentenza. Milano: Giuffrè, 1988; Vittorio Colesanti, Sentenza civile (revocazione della), Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI, 1969, p. 1161 e ss.

34

“O dolo a que alude o art. 485, III, do CPC, pressupõe a atuação processual ardilosa e maliciosa do vencedor em detrimento do vencido, o que não ocorreu no processo de execução, no qual o credor se limitou a dar-lhe andamento”. (STJ, AR 4.099/PR, 2 a Seção, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 08.04.2014). “Ausente a inequívoca prova de má-fé na conduta do réu, não há falar em dolo processual previsto no inc. III do art. 485 do CPC”. (STJ, AR 3.029/SP, 3 a Seção, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30.08.2011)

35

Elio Fazzalari, Revocazione (dir. proc. civ.), Enciclopedia del Diritto, vol. XL, item 6.

36

Cassazione, 5 febbraio 1987, n. 1128.

37

38

Pretura di Roma, 25 gennaio 1983, *Rivista di diritto processuale*, 1984, p. 608. Ver G. Messuti, *Silenzio della parte e dolo revocatorio*, *Rivista di diritto processuale*, 1984, p. 621 e ss.

39

“O réu, porque tem o dever de expor em juízo os fatos conforme a verdade, não pode negar o fato que sabe verdadeiro, mas apenas silenciar. O seu silêncio, contudo, conduz à presunção de veracidade do fato não contestado. O réu pode ser tentado a contestar expressamente o fato constitutivo implicitamente admitido na sua defesa indireta. Neste caso, porém, o réu deveria deixar de apresentar defesa direta, hipótese em que a presunção de veracidade decorreria, antes de tudo, da própria admissão implícita do fato constitutivo na defesa indireta. O dever de veracidade e o dever de o réu se manifestar precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial impedem que o réu aceite o fato constitutivo na defesa indireta e o negue através de defesa direta, bem como eliminam a necessidade de o juiz considerar fatos que poderiam ser contestados apenas por abuso, o que torna mais racional a prestação jurisdicional. Entretanto, caso o réu aceite o fato constitutivo na defesa indireta e o conteste na defesa direta e isto signifique incompatibilidade lógica, o juiz, considerando o dever da parte expor os fatos conforme a verdade, deve determinar o esclarecimento da defesa, até porque o dever de esclarecimento nada mais é do que um desdobramento do dever de veracidade” (Luiz Guilherme Marinoni, *Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 81-82).

40

Amplamente, Antonio Carrata, *Il Principio della non Contestazione nel Processo Civile*. Milano: Giuffrè, 1995.

41

Salvatore Patti, *Prove-Disposizioni generali*, *Commentario del Codice Civile*. Bologna/Roma: - Zanichelli/Foro Italiano, 1987, p. 69 e ss; Filippo Colia, *L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1994, p. 538 e ss.

42

Giuseppe Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*. Milano: Giuffrè, 1991, p. 112; Giovanni Verde, “Prova”, *Enciclopedia del diritto*, vol. 37, p. 613 e ss.

43

Virgilio Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*. Napoli: Jovene, 1964, vol. 1, p. 338 e ss; Ciaccia Cavallari, *La contestazione nel processo civile*. Milano: Giuffrè, 1993, vol. 2, p. 63 e ss.

44

“§ 138: 1. Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäss abzugeben. 2. Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären. 3. Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. 4. Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind”.

45

Giuliano Scarselli, *La condanna con riserva*. Milano: Giuffrè, 1989, p. 419.

46

Como já disse Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, “o dever de veracidade está implícito em uma das máximas do próprio processo dispositivo, isto é, da mihi factum – diz o juiz às partes – e dar-te-ei o direito a se aplicar – dabo tibi jus –, o que obriga sejam as partes verazes, porque o processo, no dizer escorreito de Couture, é a realização da justiça, que jamais poderá ficar apoiada na mentira, no dolo ou na fraude”. (Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, *Fraude no processo civil*. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2001, p. 88).

47

STJ, AR 3.785/RJ, 2ª Seção, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10.03.2014.

48

Ibidem.

49

Neste caso, firmou-se a seguinte ementa: “Configura o dolo processual previsto no inc. III do art. 485, do CPC, a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art. 17, II, CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito” (*Ibidem*.).

50

Ibidem.

51

Ibidem.

52

“In casu, o réu foi induzido a quedar-se inerte na esfera da ação originária, o que culminou com a decretação de sua revelia e a prolação de sentença que julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, o que evidencia a violação ao art. 485, III, 1ª parte, do diploma processual civil”. (STJ, REsp 656.103/DF, 4.ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezini, DJ 26.02.2007).

53

“O dolo disciplinado no inc. III do art. 485 do CPC, para viabilizar o processamento da ação rescisória, exige que as supostas falsas alegações tenham induzido a erro o órgão julgador. Tal circunstância não se verificou no presente caso, tendo em vista que as afirmações genéricas do autor da indenizatória acerca da ‘aposentadoria por invalidez’ e da incapacidade ‘total e permanentemente para o trabalho’ não acarretaram erro nem serviram de fundamento para o acórdão rescindendo”. (STJ, AgRg na AR 3.819/RJ, 2ª Seção, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21.09.2015)

54

Correto Rodrigo Barioni: “... costuma-se afirmar que o nexo de causalidade está demonstrado quando verificar-se que, sem o dolo, o teor da sentença seria diverso. A ideia, porém, não é exata: a exigência é por demais rigorosa, devendo-se permitir a desconstituição do julgado quando houver probabilidade de inverter-se o resultado da lide sem a ocorrência do dolo ou mesmo quando isso seja meramente possível”. (Ação rescisória e recursos para os Tribunais Superiores. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 79).

55

À luz do Código de Processo Civil de 1973, não obstante o art. 485, III, falasse apenas em “colusão entre as partes a fim de fraudar a lei”, discutia-se acerca da possibilidade de se dar interpretação extensiva ao inciso, ou melhor, sobre a rescindibilidade da sentença com base em simulação. Barbosa Moreira manifestou-se de forma contrária: “A nova lei [CPC de 1973] abriu o caminho da rescisão, em se tratando de processo fraudulento; não, porém, de processo simulado: dos dois casos contemplados no art. 129 [CPC de 1973], só aparece no dispositivo ora sob exame o de ‘colusão das partes, a fim de fraudar a lei’” (José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código, cit., p. 127). Distinta, no entanto, era a posição de Sérgio Rizzi: “... cabe ação rescisória se as partes se serviram do processo para fraudar a lei através da simulação, ou independentemente desta. Não se trata, evidentemente, de emprestar uma exegese ampliativa à regra em exame, pelo fato de se admitir a simulação fraudulenta, mas de revelar o seu exato alcance” (Sérgio Rizzi, Ação rescisória. São Paulo: Ed. RT, 1979, p. 96).

56

Trata-se de consagrada lição, que pode ser colhida, por exemplo, em Leo Rosenberg, Karl Heinz Schwab e Peter Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. ed. München: C. H. Beck, 2010, p. 869.

57

Defendendo a teoria restritiva dos limites objetivos da coisa julgada, ver, com ampla exposição, Ernesto Heinitz, I Limiti Oggettivi della Cosa Giudicata. Padova: Cedam, 1937, p. 200-215, esp. p. 205.

58

O collateral estoppel tem origem no sistema de registro ou gravação por escrito das atividades desenvolvidas pelas partes no processo. A transcrição por escrito (recorded) das alegações realizadas pela parte no curso do processo levava a uma presunção de verdade, cancelada mediante o que se chamou de estoppel by record. O estoppel by record era visto como uma técnica que impedia a parte de pôr em

dúvida as alegações e as conclusões que deram origem à decisão judicial. V. Robert Millar, *The historical relation of estoppel by record to res judicata*, Ill L. Review, 1940-1941.

59

Austin Scott, *Collateral Estoppel by judgment*, Harvard Law Review, vol. 56. 1942; Brainerd Currie, *Mutuality of Collateral Estoppel: Limits of the Bernherd doctrine*, Stanford Law Review, vol. 9, 1957; Lisa L. Glow, *Offensive Collateral Estoppel in Arizona: Fair Litigation v. Judicial Economy*, Arizona Law Review, vol. 30, 1988; Ashley C. Perea, *Broad discretion: a choice in applying offensive non-mutual collateral estoppel*, Arizona State Law Journal, vol. 40. 2008; Joshua M. D. Segal, *Rebalancing fairness and efficiency: The offensive use of collateral estoppel in § 1983 actions*, Boston University Law Review, vol. 89, 2009; Eli J. Richardson, *Taking issue with preclusion: reinventing Collateral Estoppel*, Mississippi Law Journal, vol. 65, 1995; Steven P. Nonkes, *Reducing the unfair effects of nonmutual issue preclusion through damages limits*, Cornell Law Review, vol. 94, 2009; Warren Freedman, *Res Judicata and Collateral Estoppel*. Westport: Quorum, 1988.

60

O caso *Bernhard v. Bank of America Nat. Trust & Saving Association* deu origem ao non-mutual collateral estoppel. Disse a Suprema Corte da Califórnia que “the case justify this exception on the ground that it would be unjust to permit one who has had his day in court to reopen identical issues by merely switching adversaries” (*Bernhard v. Bank of America Nat. Trust & Saving Association*, Supreme Court of California, 19 Cal2d 807, 122 P2d 892, 1942). A Suprema Corte dos Estados Unidos só firmou precedente sobre o tema em 1971, ao julgar *Blonder-Tongue Laboratories Inc. v. University of Illinois Foundation* (*Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 1971).

61

ZPO, § 280. Abgesonderte Verhandlung über Zulässigkeit der Klage. (2) Ergeht ein Zwischenurteil, so ist es in Betreff der Rechtsmittel als Endurteil anzusehen. Das Gericht kann jedoch auf Antrag anordnen, dass zur Hauptsache zu verhandeln ist.

62

ZPO, § 322. Materielle Rechtskraft

(1) Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist.

63

Francesco Menestrina, *La pregiudiziale nel processo civile*. Milano: Giuffrè, [1904] 1963.

64

Giuseppe Chiovenda, *Sulla cosa giudicata*, *Saggi di diritto processuale civile* (reimp.), vol. 2. Milão: Giuffrè, [1931] 1993.

65

Giovanni Pugliese, *Giudicato*. Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1969, vol. XVIII, n. 25.

66

Vittorio Denti, *Questioni pregiudiziali*, *Novissimo digesto italiano*, vol. 14, p. 651 e ss.

67

Michele Taruffo, “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni, *Rivista di diritto processuale*, 1972, p. 290 e ss.

68

Diego Volpino, *op. cit.*

69

“Le ragioni che possono giustificare i dubbi sull’efficacia della decisione di questioni pregiudiziali – a parte l’eventualità che manchi fra esse e la lite un autentico rapporto di pregiudizialità o che addirittura le pronunzie al riguardo siano obiter dicta – sono costituite dalla possibile incompetenza del giudice a trattare la questione in un autonomo processo, dalla possibile mancanza di legittimazione di una o di entrambe le parti allo stesso ufficio e dalla sommarietà o comunque insufficienza della sua trattazione. Possiamo tenere conto, per questo profilo, dell’esperienza americana condensata nel noto Restatement. Essa, confermando che il giudicato riguarda non solo la lite, ma anche le questioni (issues) decise per giungere alla decisione finale, indica che la decisione di una issue può essere considerata vincolante in un altro processo e venire compresa quindi nel giudicato, solo se essa sia stata effettivamente discussa tra le parti e seriamente decisa dal giudice; non basta che la questione abbia potuto bensì venire discussa, ma non lo sia effettivamente stata, e non può, in ogni modo, dare luogo a giudicato la decisione di un giudice privo di giurisdizione o di competenza a decidere la questione in modo autonomo, né quella pronunziata nei confronti di una parte contumace; ma, d’altro canto, non è richiesta nessuna domanda diretta a far decidere la questione con efficacia di giudicato. Adattando questa esperienza al nostro ordinamento e tenendo conto dell’art. 34 c.p.c., si può ritenere che la decisione di una questione pregiudiziale, compiuta sommariamente o da un giudice incompetente o fra parti non legittimate entrambe a trattare la questione in un processo autonomo, non offra le garanzie necessarie per riconoscerle valore di per sé vincolante, ma che non sia da includere in queste garanzie l’esplicita domanda di una parte. Si ha così un criterio per l’interpretazione dell’art. 34, ai fini di stabilire se la decisione di questioni pregiudiziali faccia o no parte del giudicato formatosi sulla decisione della lite” (Giovanni Pugliese, *op. cit.*).

70

Stefano Villata, *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*. Milano: Giuffrè, 2006, p. 445.

71

72

Cf. Stefano Villata, Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, op. cit., p. 451-452.

73

CPC italiano, Art. 395. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

(...)

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

(...)”.

74

Andrea Proto Pisani, op. cit., p. 535.

75

Recorde-se que, nos termos da doutrina de Chiovenda, a coisa julgada tem uma função positiva quando constringe o juiz a reconhecer a existência de uma sentença na ação que a pressupõe. (Giuseppe Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli: Jovene, [1906] 1965, p. 723 e ss)

76

Luiz Guilherme Marinoni, O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos, Revista de Processo, vol. 249, p. 406 e ss.

77

Liebman, ainda que peque ao dizer que a coisa julgada se estende à questão que podia ser discutida num processo, deixa claro o significado de não se poder voltar a discutir o que foi ou poderia ter sido discutido para o efeito de se evitar a violação à coisa julgada: “Assim, se uma questão podia ser discutida num processo, mas de fato não o foi, não obstante isso a coisa julgada se estende mesmo a ela, no sentido de que não poderá ser utilizada para se negar ou contestar o resultado a que se chegou no processo. Por exemplo: se o réu, em defesa, poderia opor uma série de argumentos, e não o fez, vindo a ser condenado, não mais poderá deles se valer para contestar a coisa julgada, pois a tanto se opõe a finalidade prática desse instituto, que exige o respeito à coisa julgada ainda quando importantes questões tenham sido discutidas por acaso de modo incompleto. Nela estão compreendidas tanto as questões que foram discutidas, como as que o poderiam ser” (Enrico Tullio Liebman, Limites objetivos da coisa julgada, Estudos sobre o processo civil. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 165-166).

78

“Isto posto, deve entender-se que é lícita uma nova decisão sobre as questões prejudiciais dirimidas no processo antecedente, e que não constituíram objeto de uma decisão por si mesmas, mas se resolveram apenas com o escopo de decidir sobre a demanda do autor. Por mais forte razão, não está o juiz obrigado a admitir como verdadeiros os fatos considerados como base do julgado anterior, nem as qualificações que se lhes atribuíram (por exemplo, que é uma relação comercial ou civil). As questões e as novas decisões sobre esses pontos somente são excluídas na medida em que possam ter como resultado volver à discussão e, por conseguinte, e o que é pior, reduzir ou desconhecer o bem reconhecido no julgado precedente” (Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1942, p. 564). V. ainda Giuseppe Chiovenda, *Sulla cosa giudicata*, *Saggi di diritto processuale civile* (reimp.), vol. 2, cit., p. 186 e ss.

79

Andrea Proto Pisani, op. cit., p. 535.

80

V. *Otherson v. Department of Justice, I.N.S.*, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, June 21, 1983, 711 F.2d 267, 228 U.S.App.D.C. 481; *Canonsburg General Hosp. v. Burwell*, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, December 1, 2015, F.3d, 2015 WL 8051408.

81

O ponto é pacífico nas cortes: “strictly speaking ‘res judicata’ bars second suit involving same parties and same cause of action on all matters that were part of first suit and all issues that could have been litigated, while doctrine of ‘collateral estoppel’ precludes relitigation only of issues that were actually litigated in initial suit, whether or not second suit is based on same cause of action”. (*Precision Air Parts, Inc. v. Avco Corporation*, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, July 24, 1984, 736 F.2d 1499)

82

“Issue preclusion is sometimes unfair if party to be bound lacked an incentive to litigate in first trial, especially in comparison to stakes of second trial” (*Peavey v. United States*, United States District Court, District of Columbia, August 26, 2015, F.Supp.3d, 2015 WL 5063164).

83

Andrea Proto Pisani, op. cit., p. 66-67.

84

Lodovico Mortara, antes de Chiovenda, já havia proposto uma concepção de jurisdição como função destinada à defesa do direito objetivo. Cf. *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*. Milano: Vallardi, 1923, p. 18 e ss; *Manuale della procedura civile*. Torino: Torinese, 1921, p. 48 e ss. Eis o que disse Chiovenda em oração em homenagem póstuma a Mortara: “Il Mortara diffuse nel nostro mondo giuridico la sensazione della insufficienza dei metodi in vigore e degli strumenti usati e con la sua critica

penetrante ed inesorabile gettò il discredito sopra idee, definizioni e figure prima adottate come vangelo. Il fatto stesso che un giurista di così grande statura facesse oggetto principale dei suoi studi una materia come la procedura civile prima negletta e quasi dispregiata, giovò sommamente ad elevare nella considerazione dei nostri teorici e dei nostri pratici la dignità della scienza processuale ed a porne in evidenza l'autonomia. (...) Fu grande merito del Mortara aver collocato (come la sua preparazione nel diritto pubblico sola poteva permettere di fare) il processo civile nella sua giusta luce di istituto di diritto pubblico, ciò che fu il punto di partenza dei progressi successivamente realizzati nel nostro campo” (Giuseppe Chiovenda, Lodovico Mortara, *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1937, p. 101-102).

85

Andrea Proto Pisani, op. cit., p. 66-67.

87

Idem, p. 67-68.

88

Idem, p. 68.

89

“La consapevolezza della gravità degli inconvenienti pratici ora denunciati impone di ritenere che, quanto meno nell'ipotesi di rapporti a prestazioni corrispettive, l'oggetto del processo e del giudicato non sia costituito solo dal diritto dedotto in giudizio dall'attore, ma anche dall'intero rapporto contrattuale (la rilevanza giuridica del contratto) su cui si fonda sia la prestazione chiesta dall'attore sia la controprestazione che spetta al convenuto (...) Orbene, se si vanno a rileggere le pagine delle Istituzioni di Chiovenda in tema di rapporti giuridici complessi e di deduzione in giudizio di una frazione di tali rapporti, si nota che il sistema di Chiovenda conosceva dei correttivi diretti ad impedire che tramite il processo si possa determinare una eccessiva frammentazione di rapporti sostanziali unitari” (Ibidem.).

90

Riccardo Guastinni, *Interpretare e argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011, p. 65.

91

Remo Caponi, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*. Milano: Giuffrè, 1991; Sergio Menchini, *I limiti oggettivi del giudicato civile*. Milano: Giuffrè, 1987.

92

Cf. Miguel Galvão Teles, *Inconstitucionalidade pretérita, Nos dez anos da Constituição*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987, p. 329.

José Augusto Delgado, Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais, Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 35. V. Cândido Rangel Dinamarco, Relativizar a coisa julgada material, Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 18 e ss; Humberto Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro de Faria, A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para o seu controle, Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro, América Jurídica, 2002, p. 30; Leonardo de Faria Beraldo, A flexibilização da coisa julgada que viola a Constituição, Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro, América Jurídica, 2002, p. 175 e ss.

J. J. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2002, p. 1227.

J. J. Gomes Canotilho, op. cit., p. 1223.

Humberto Ávila, Teoria dos princípios, 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 160-175.

Enrique Alonso García, La interpretación de la constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 426.

V. Robert Alexy, Teoria da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2001.

Na sua Teoria da argumentação jurídica, Alexy não enuncia a coisa julgada como uma das regras formas do discurso jurídico. Porém, deixa claro que as regras que apresenta servem para detectar possíveis lacunas e insuficiências, a partir do que é possível estabelecer outras regras adicionais. Mas as regras do discurso jurídico não podem ser impostas ou retiradas da prática jurídica de maneira não reflexiva – necessitam de justificação. Por ser essa fundamentação pragmático-transcendental, é preciso considerar que o discurso jurídico não é possível sem a coisa julgada. Pois bem, a coisa julgada é uma condição de possibilidade do discurso jurídico enquanto discurso institucional limitado no tempo. Não há sentido em realizar um discurso jurídico sem que a discussão jurídica tenha termo. Na verdade, um discurso jurídico perpetuamente revisável não é um discurso jurídico, mas um discurso prático-geral. Nessa dimensão, a coisa julgada é uma regra formal do discurso jurídico, uma daquelas regras que fazem do discurso jurídico um caso especial do discurso moral. A coisa julgada é uma regra de que o discurso jurídico depende para existir. Assim, a coisa julgada não pode ser relativizada pela ponderação de princípios, uma vez que só há ponderação em discurso jurídico, e, para que este discurso exista, devem ser respeitadas as regras que o tornam possível, entre elas a coisa julgada. A coisa julgada não é atingida pela ponderação por não ser um princípio cujo fundamento axiológico possa ser mensurado e comparado com os dos

outros, mas uma regra formal do próprio discurso jurídico. Se não for assim, não há possibilidade de se falar em discurso jurídico e, como decorrência, em Estado Democrático de Direito, já que o direito, mesmo em Alexy, é o medium de integração social. De modo que a regra formal do discurso jurídico contida na coisa julgada é parte estruturante do Estado Democrático de Direito. V. Robert Alexy, Teoria da argumentação jurídica, cit.

100

Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht, n. 7, 377, 411.

101

V. Alberto Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali. Padova, Cedam, 2002.

102

Nesse sentido, argumenta Humberto Ávila que a proteção da coisa julgada, “mais do que amparar um ideal de segurança sem predefinir o seu modo de realização, é uma forma de regramento do conflito entre a segurança e a igualdade particular, não podendo ser afastada mediante um mero procedimento de ponderação por meio do qual se atribua um peso maior ou menor a ela”. (Humberto Ávila, Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 124).

103

Nessa linha José Carlos Barbosa Moreira, Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material, Relativização da coisa julgada. Salvador: JusPodium, 2008, p. 235.

104

José Augusto Delgado, Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais, Coisa julgada inconstitucional, op. cit., p. 16.

105

Humberto Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro de Faria, A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para o seu controle, Coisa julgada inconstitucional, op. cit., p. 30.

106

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em acórdão relatado pelo Min. Luiz Fux, que “a rediscussão reiterada de matéria decidida e declarada por sentença transitada em julgado implica a pretensão de consagração da cognominada tese da “relativização da coisa julgada”, postulado que se choca com a cláusula pétrea da segurança jurídica, garantia fundamental do jurisdicionado, consagrada em todas as Constituições” (STJ, REsp 671182, 1.^a Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 02.05.2005).

107

108

Registre-se que o art. 625, 1, do CPC português afirma que “havendo duas decisões contraditórias sobre a mesma pretensão, cumpre-se a que passou em julgado em primeiro lugar”. Esclarecendo esse artigo, o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal já declarou que, “para que se verifique a situação de casos julgados contraditórios preceituada no n. 2, do artigo 675, Cód. Proc. Civil [CPC de 1961], é essencial que as duas decisões contraditórias incidam sobre o mesmo objecto, o que vale por dizer que a parte dispositiva das duas decisões há-de ter resolvido o mesmo ponto concreto, de direito ou de facto”. (STJ de Portugal, JSTJ 00041134, rel. Juiz Ferreira Ramos, 08.03.2001).

109

Pontes de Miranda, Tratado da ação rescisória, cit., p. 255.

110

Rodrigo Barioni, apoiado em Arruda Alvim e Sérgio Rizzi, reconhece que “a interpretação sistemática do ordenamento – constitucional e infraconstitucional – revela que a única decisão que recebe amparo é a primeira, jamais a segunda” (Op. cit., p. 93).

111

Recentemente, o Tribunal da Relação de Coimbra assim declarou: “Do caso julgado decorrem dois efeitos essenciais, a saber: a impossibilidade de qualquer tribunal, incluindo o que proferiu a decisão, voltar a emitir pronúncia sobre a questão decidida – efeito negativo – e a vinculação do mesmo tribunal e eventualmente de outros, estando em causa o caso julgado material, à decisão proferida – efeito positivo do caso julgado. Todavia, ocorrendo casos julgados contraditórios, a lei resolve apelando ao critério da anterioridade: vale a decisão contraditória sobre o mesmo objecto que tenha transitado em primeiro lugar (art. 625. n. 1, do CPC)....”. (Tribunal da Relação de Coimbra, Apelação n. 231514/11.3YIPRT.C1, rel. Juíza Maria Domingas Simões, 20.10.2015).

112

Sérgio Rizzi, embora a partir de outros fundamentos, conclui que “é de se admitir, também, que a parte vencedora da primeira demanda possa alegar, em grau de embargos à execução [CPC/1973] da segunda sentença, a existência da primeira coisa julgada” (Sérgio Rizzi, op. cit., p. 139).

113

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 227-228.

114

Como decidiu a 3.^a Turma do STJ no REsp 1.354.225, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, “aos que sustentam que a segunda sentença teria revogado a primeira, cabe relembrar que a revogação de lei

anterior por lei posterior é ato lícito e legítimo, ao passo que a prolação de outra sentença em demanda já decidida é ato manifestamente contrário ao direito, não sendo cabível, pois, aplicar essa analogia”. (STJ, Resp 1.354.225, 3.ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.03.2015).

115

Portanto, retifica-se aqui posição adotada no Novo Curso de Processo Civil, vol. 2. São Paulo: Ed. RT, 2015.

116

Assim, por exemplo, decidiu-se em *Halpern v. Schwartz*: “... the prior judgment will not foreclose reconsideration of same issue if that issue was not necessary to rendering of prior judgment, and hence was incidental, collateral, or immaterial to that judgment” (*Halpern v. Schwartz*, United States Court of Appeals, Second Circuit, May 8, 1970).

117

James, Hazard e Leubsdorf, diante de decisão da Corte de Massachusetts proferida em *Cambria v. Jeffrey*, lembram os fundamentos descritos acima no texto: “Three considerations support this ruling. First, the parties’ attention and efforts are likely to be focused on points and matters that are necessary to the result. Second, the tribunal’s attention is likely to be focused on the grounds necessary for its decision ...” (Fleming James Jr., Geoffrey Hazard Jr. e John Leubsdorf, *Civil Procedure*. Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1992, p. 612-613).

118

“It is entirely accurate to observe that the disposition in the Court of Claims was predicated both on its conclusion that there had been no proof of negligence on the part of the State of New York and on its further finding that claimant Malloy had been contributorily negligent. Indeed in introducing that portion of his decision dealing with contributory negligence on the part of the two claimants, Judge Moriarty forthrightly noted that he proceeded to those issues, ‘although unnecessary to a decision herein’. Under a strict application of the alternative determination exception to the rule of issue preclusion, neither the finding of no negligence on the part of the State nor the finding of contributory negligence on the part of the claimant would subsequently be given conclusive effect, for in a logical analysis either finding standing independently would have been sufficient to support the decision of the court; each was a literal alternative. Mechanical application on the basis of such analysis would fail to take into account the vitality of the rationale behind the doctrine of issue preclusion. There can be no doubt in this instance that the issue of Malloy’s contributory negligence was actually and fully litigated. Although it is true that Malloy and Trombley did not stand toe-to-toe in the Court of Claims, Malloy’s incentive vigorously to oppose a finding of contributory negligence was no less there than it would be in the present Supreme Court action. No suggestion is now advanced that he was in any way handicapped or inhibited in his address to the issue in the Court of Claims; he had full opportunity there and no heavier burden to establish his freedom from contributory negligence with respect to defendant State in that action than with respect to defendant Trombley in the present action. None of the grounds recognized for other exceptions to the general rule of issue preclusion are to be found in this case (see *op. cit.*, s 68.1, p. 27 et seq.). The justification for the alternative determination exception to the general rule is said to be that “the determination in the alternative may not have been as carefully or as rigorously considered as it would have been if it had been

necessary to the result, and in that sense it has some of the characteristics of dicta” (op. cit., s 68, Comment i, p. 12). The care and attention devoted to the issue by Judge Moriarty in this instance saps such a contention of any vitality. Although unnecessary to a decision herein, we note that, based upon the evidence presented at trial, neither claimant appears to have established the requisite freedom from culpable conduct necessary for success in a cause of action for negligence which accrued prior to September, 1975. (...)” (Malloy v. Trombley, Court of Appeals of New York, 427 N.Y.S.2d 969, 1980).

119

Art. 395, 5 (CPC italiano): “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: (...) 5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.

120

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 130.

121

“Secondo la teoria che converremo di chiamare ‘cognitivistica’ – ma talora della ‘formalistica’ – la quale risale alle dottrine giuridiche dell’Illuminismo, l’interpretazione (ivi inclusa quella giudiziale) è atto di scoperta o conoscenza del significato” (Riccardo Guastini, Interpretare e argomentare. Milano: Giuffrè, 2011. p. 409).

122

Riccardo Guastini, A interpretação: objetos, conceitos, teorias. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 139 e ss.

123

Jerzy Wróblewski, Functions of law and legal certainty, Anuario de Filosofia del Derecho, XVII, 1973–1974, p. 322 e ss.

124

A ideia está traduzida no parecer elaborado pelo Tribunal de Apelação Rouen, logo após a apresentação do projeto de código. Nesse documento, os juízes são chamados de flagelos destruidores da lei, que primeiro a debilitam, depois a minam pouco a pouco e finalmente usurpam os direitos: “Ces fléaux destructeurs de la loi, qui l’af faiblissent d’ahord, qui ensuite la minent insensiblement, et qui finissent par usurper ses droits, ne reparaîtront que trop tôt. Malheur au temps où, comme par le passé, on cherchera moins ce que dit la loi que ce qu’on lui fait dire l où l’opinion d’un homme, que le temps seul aura accréditée, balancera l’aulorité de la loi! où une erreur hasardée par l’un , et successivement adoptée par les autres , devien dra la vérité! où une suite de préjugés recueillis par des compilateurs aveugles ou serviles, violentera la conscience du juge , et étouffera la voix du législateur!” (Pierre-Antoine Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Paris: Videcoq, 1836, t. 5.º, p. 456).

O respeito à vontade histórica do legislador está em Montesquieu. Em sua obra, como forma de impedir os desmandos de uma magistratura corrompida e fortemente ligada ao Antigo Regime, Montesquieu busca o direito em fatores puramente objetivos, nos quais o espaço de atuação dos juízes fica propositalmente reduzido. Ver Norberto Bobbio, *Lições de Filosofia do Direito*. Trad. Márcio Pugliese, Edson Bini e Carlos Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 95 e ss.; Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2006, vol. I; Chaïm Perelman, *Lógica jurídica: nova retórica*. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 32.

No célebre discurso proferido na apresentação do projeto de Código ao Conselho de Estado, Portalis afirmou expressamente a impossibilidade de se prever em um texto legal todas as hipóteses que seriam levadas a juízo: “Tout simplifier est une opération sui laquelle on a besoin de s’entendre. Tout prévoir est un but qu’il est impossible d’atteindre. Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient- la certitude et la majesté de la législation. Mais un grand État comme la France, qui est à la fois agricole et commerçant, qui renferme tant de professions différentes, et qui offre tant de genres divers d’industrie, ne saurait comporter des lois aussi simples que celles d’une société pauvre ou plus réduite: (Jean-Étienne-Marie Portalis, *Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de la comission du gouvernement*, In: Pierre-Antoine Fenet, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*. Paris: Videcoq, 1836, t. 1.º, p. 467).

Essa interpretação era claramente defendida por vários representantes da Escola da Exegese. Apenas para citar um exemplo, Demolombe, em seus clássicos comentários ao Código Civil, sustenta de maneira categórica que interpretar é o mesmo que extrair o sentido exato da lei, sem qualquer alteração, modificação ou inovação. É o que pode ser lido já nas primeiras linhas dos comentários ao artigo 4, quando afirma que “en théorie, l’interprétation, c’est l’explication de la loi; interpréter, c’est découvrir, c’est c’ucider le sens exact et véritable de la loi. Ce n’est pas changer, modifier, innover; c’est déclarer, c’est reconnaître (Charles Demolombe, *Cours de Code Napoléon*. Paris: Lahure, 1880, vol. 1, p. 136). Sobre o tema, Leandro Rutano, *Ação Rescisória por violação à norma jurídica*, Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2016.

Riccardo Guastini, Riccardo. *Interpretare e argomentare*, cit., p. 410; Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria, *Diritto e interpretazione: Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma: Laterza, 1999, p. 321 e ss.

“A função das Cortes de Cassação de civil law foram definidas, como não poderia deixar de ser, a partir de valores e pressupostos teóricos de um determinado momento histórico. A formação positivista e cognitivista de Calamandrei [autor da mais célebre obra sobre a Corte de Cassação produzida no século XX] tem íntima ligação com a ideia de ‘uniformidade’ como meio de controle da ‘exata interpretação da lei’. Ocorre que o pressuposto teórico que determinou a ideia de que a Corte Suprema se destina a

controlar a ‘exata interpretação da lei’ foi completamente desgastado com o passar do tempo. Tal pressuposto está assentado na teoria formalista ou cognitiva da interpretação, que, por sua vez, é informada pelos valores do Estado legislativo” (Luiz Guilherme Marinoni, El precedente interpretativo como respuesta a la transformación del civil law: la contribución de Taruffo, Conferência proferida na Universidade de Girona, Espanha, por ocasião do Congresso em Homenagem a Michele Taruffo, no ano de 2015 – no prelo). Amplamente, Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes Obrigatórios, cit.; Idem, O STJ enquanto Corte de Precedentes, cit.; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, cit.; Idem, Precedentes, cit.

130

Riccardo Guastini, Interpretare e argomentare, cit., p. 415 e ss.

131

Jerzy Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid: Civitas, 2001, p. 62-65.

132

Note-se que, na linha da teoria de Wróblewski, a interpretação que exige a consideração do significado da Constituição requer, mais do que em outro lugar, que o intérprete opte entre uma ideologia da interpretação jurídica que pode ser definida como estática e outra ligada à adaptação do direito às necessidades presentes e futuras da sociedade. A adoção de uma ou outra postura tem relação de causa e efeito com a eleição das diretivas de primeiro grau – linguísticas, sistêmicas e funcionais – e com a utilização das diretivas de segundo grau – procedimentais e de preferência –, voltadas a definir o modo de aplicação e a prevalência das diretivas de primeiro grau. É claro que o intérprete que adere à ideologia estática da interpretação dá ênfase às diretivas linguísticas e sistêmicas em detrimento das funcionais e, quando aplica uma diretiva funcional, apega-se à vontade do “legislador histórico”. Por outro lado, se o intérprete é adepto da ideologia da interpretação que procura adaptar o texto à realidade social que lhe é contemporânea, prefere as diretivas funcionais em relação às linguísticas e sistêmicas, e, quando aplica as funcionais, elege a diretiva que frisa a vontade ou as valorações do intérprete. Há aí nítido e claro emprego de juízo de valor para a eleição das diretivas de interpretação, tanto de primeiro quanto de segundo grau. Ademais, quando o intérprete elege diretiva funcional que reclama a sua “vontade”, lhe é aberta a possibilidade de valorar os elementos da vida em sociedade em várias perspectivas – moral, política, econômica etc. –, tendo as suas escolhas, mais uma vez, natureza que confere à interpretação-resultado um conteúdo que, além de obviamente não declarado, não é descoberto ou meramente extraído do direito. (Jerzy Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, cit., p. 72-78).

133

Riccardo Guastini, Disposizione vs. norma, Giurisprudenza costituzionale, 1989, p. 3-14; Pierluigi Chiassoni, Disposición y norma: una distinción revolucionaria. Disposición. vs norma. Lima: Palestra, 2011, p. 14 e ss.

134

A Súmula 343, STF, diz que não cabe “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

135

Pierluigi Chiassoni, *Disposición y norma*, cit., p. 8.

136

Montesano concluiu dizendo que o sistema que procurou delinear significa, em termos práticos, que a Corte, quando nega a inconstitucionalidade, porém ao mesmo tempo revisa a fórmula legislativa em busca de aplicações contrárias à Constituição, não pode obrigar o legislador a melhorar esta fórmula, tampouco obrigar os juízes a se absterem destas aplicações, mas deve considerar-se impotente para defender a Constituição deste perigo ou eliminá-lo de vez, declarando inconstitucional a lei equivocadamente formulada (Luigi Montesano, *Norma e formula legislativa nel giudizio costituzionale*. *Rivista di diritto processuale*, 1958, p. 539). Um ano antes da publicação do artigo de Montesano, Tullio Ascarelli publicou trabalho – que contribuiu para o desenvolvimento teórico da dissociação entre disposição e norma – em sentido diametralmente oposto: “Quando analisa a constitucionalidade de uma lei, o juiz constitucional depara sempre com um texto que deve interpretar e que é equívoco. A univocidade pode ser apenas das aplicações concretizadas e não pode referir-se ao texto em função do qual se quer estabelecer a norma objeto da análise. Qualquer texto pode dar lugar a interpretações divergentes e, portanto, à formulação de normas distintas. Uma dessas poderá ser inconstitucional, diversamente de outras” (Tullio Ascarelli, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione*. *Rivista di diritto processuale*, 1957, p. 356-357).

137

Pierluigi Chiassoni, *Disposición y norma*, cit. p. 8-9

138

Vezio Crisafulli, *Disposizione (e norma)*. *Enciclopedia del diritto*, 1964.

139

Pierluigi Chiassoni, *Disposición y norma*, cit., p. 12-13.

140

O ponto remonta a Giovanni Tarello: “Sovente si dice e si scrive, impropriamente, che l’interprete ‘scopre’ il significato delle ‘norme’. In realtà né l’interprete ‘scopre’, né la sua attività ha per oggetto delle ‘norme’. Vediamo di chiarire, incominciando con ciò che si cela sotto il verbo ‘scoprire’ e passando poi ao sostantivo ‘norma’. (...) È chiaro perciò che il vocabolo ‘scoprire’, così come è usato nell’espressione ‘l’interprete scopre il significato di una norma’, è del tutto improprio, ed anzi è dannoso alla chiarezza, perchè occulta – riassumendole in una sola parola – tre attività diverse che possono essere presenti tutte, o possono non essere tutte presenti, nell’attività dell’interpretazione. Dobbiamo perciò correggere l’espressione corrente riformulandola così: ‘l’interprete rileva, o decide, o propone il significato di una

norma, ovvero compie più d'una di queste attività'. Ma questa correzione non basta. Infatti anche il vocabolo 'norma' è ingannevole. L'interprete rileva, o decide, o propone il significato da attribuire a un documento, costituito da uno o più enunciati, di cui il significato non è affatto precostituito all'attività dell'interprete, ma ne è anzi il risultato; prima dell'attività dell'interprete, del documento oggetto dell'interpretazione si sa solo che esprime una o più norme, non quale questa norma sia o quali queste norme siano: 'norma' significa semplicemente il significato che è stato dato, o viene deciso di dare, o viene proposto che si dia, a un documento che si ritiene sulla base di indizi formali esprima una qualche direttiva d'azione. L'espressione corrente deve perciò essere corretta, perché non sia ambigua, così: 'l'interprete rileva, o decide, o propone il significato di uno o più enunciati precettivi, rilevando, o decidendo, o proponendo che il diritto ha incluso, o include, o includerà una norma'" (Giovanni Tarello, *L'interpretazione della legge*. Milano: Giuffrè, 1980, p. 61, 63-64).

141

V. Mario Jori e Anna Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*. Torino: Giappichelli, 1995, p. 205 e ss; Enrico Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*. Torino: Giappichelli, 1999, p. 200 e ss; Rodolfo Sacco, *Interpretazione del diritto. Dato oggettivo e spirito dell'interprete*. Diritto, giustizia e interpretazione. Roma/Bari: Laterza, 1998, p. 111 e ss.

142

Riccardo Guastini, *Se i giudici creino diritto, Istituzioni e dinamiche del diritto*. Milano: Giuffrè, 2009, p. 395.

144

A ideia de zona de penumbra é ligada à teoria de Hart (*Positivism and the Separation of Law and Morals*, *Harvard Law Review*, vol. 71, n. 4 (02/1958), p. 593-629 e *The concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1993). Segundo Hart, em virtude da textura aberta dos textos legais, neles há sempre um núcleo iluminado ou uma zona de luz circundado por uma zona de penumbra. Nas palavras do autor, "There must be a core of settled meaning, but there will be, as well, a penumbra of debatable cases in which words are neither obviously applicable nor obviously ruled out. These cases will each have some features in common with the standard case; they will lack others or be accompanied by features not present in the standard case" (*Positivism and Separation of Law and Morals*, *Harvard Law Review*, vol. 71, n. 4 (02/1958), p. 607). Somente os enunciados que estão na zona de penumbra reclamam valoração e decisão ou opção, ou melhor, uma atividade discricionária do intérprete. Aqueles que estão na zona de luz, ao contrário, são normas predefinidas, que podem ser simplesmente descritas. Desse modo de ver as coisas deriva a divisão dos casos em fáceis e difíceis. Os casos fáceis são aqueles que se acomodam à zona de luz, que são resolvidos a partir de enunciados claros e que, por isso, não exigem opção – não ensejam mais de uma interpretação. Os difíceis são aqueles em que a aplicação do texto legal é controvertida, que estão situados na zona de penumbra. São os que abrem oportunidade a várias interpretações, requerendo valoração e decisão (ou opção). O interessante é que a ideia de penumbra, na tese de Hart, tem como objetivo demonstrar a validade da teoria normativista. A objeção dos céticos, de que as normas legais nada mais são do que fórmulas de sentido vago e indeterminado e, assim, vazias e destituídas de significado enquanto possível objeto do conhecimento científico, é confrontada por Hart exatamente mediante o argumento de que as normas são dotadas de textura aberta e, assim, contam com uma zona de penumbra e uma zona de luz – em que a interpretação é uma descrição, a dar vigor a uma ciência de normas. Cf.

Riccardo Guastini, “Trama aberta” – Ciência Jurídica, Interpretação. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 145. V. Herbert L. Hart, The concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1993; Jerzy Wróblewski, Transparency and doubt. Understanding and interpretation in pragmatics and in Law, Law and Philosophy, 1988, p. 322 e ss; Genaro Carriò, Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1979.

145

“... la norma non è cosa ontologicamente diversa dalla disposizione: è semplicemente la disposizione interpretata e pertanto riformulata, o, da un altro punto di vista, un enunciato (interpretante) di cui l'interprete assume la sinonímia con l'enunciato interpretato (la disposizione)” (Riccardo Guastini, Interpretare e argomentare, cit., p. 65).

146

“...molte disposizioni – quase tutte le disposizioni, in verità – hanno un contenuto di significato complesso: esprimono non già una sola norma, bensì una molteplicità di norme congiunte. Ad un'unica disposizione possono dunque corrispondere più norme congiuntamente” (Riccardo Guastini, Interpretare e argomentare, cit., p. 65-66).

147

Publicada nos anos 1960 do século passado, a Súmula sustenta-se no julgamento do RE 50.046. No caso, a Cooperativa Central dos Produtores de Leite, ré na ação rescisória, alegou que não teria havido violação à literalidade do art. 76 da Lei de Falências pelo fato de a decisão rescindenda ter adotado uma das interpretações possíveis acerca do dispositivo. Em seu voto, o Ministro Victor Nunes Leal afirmou que a adoção de uma das interpretações admitidas pela doutrina e pelos tribunais não poderia configurar ofensa à literalidade do dispositivo (Leandro Rutano, Ação Rescisória por violação à norma jurídica, Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2016). Extensamente sobre a Súmula 343, STF, ainda, Luiz Guilherme Marinoni, A Intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade, cit.; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, cit.

148

A obra de Calamandrei (La cassazione civile, 1920) tem uma dimensão que desborda os limites usuais dos trabalhos doutrinários, constituindo a elaboração de um modelo teórico que não só veio a ser recepcionado – ainda que em parte – pela legislação italiana, mas também uma premissa ou fundamento para quase todos os trabalhos que têm sido escritos sobre o tema. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, O STJ enquanto Corte de Precedentes, cit.; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, cit.

149

Resta evidente, mesmo na investigação de caráter histórico-dogmático realizada por Calamandrei, grande preocupação em evidenciar a necessidade de a Corte de Cassação realizar função de unificação da interpretação da lei. Porém, Calamandrei deixou absolutamente claro que a tutela da lei e a garantia de uniformidade são faces de uma mesma moeda e, assim, que as decisões da Cassação, quando definem a interpretação, fixam o exato e único sentido da lei. Não foi por outro motivo que a sua obra deixou

imortalizada a célebre ideia de que a função da Corte de Cassação é definir o “sentido exato da lei”.

150

V. Piero Calamandrei, *La genesi logica della sentenza civile*, Opere Giuridiche. Napoli: Morano, 1965, vol. 1

151

A expressão é de Calamandrei.

152

Gaetano Silvestri, *Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, *Le Corti Supreme*. Milano: Giuffrè, 2001, p. 45.

153

Cf. Gaetano Silvestri, *Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, *Le Corti Supreme*, cit., p. 45.

154

Michele Taruffo, *Precedente e giurisprudenza*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2007, p. 718; Michele Taruffo, *Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali*, *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

155

Só há lógica em dar a “última palavra” quando essa é a “última” para todos os casos similares que estão para aflorar. O contrário seria supor que uma Corte tem posição de vértice e dá a última palavra por acaso. Ou ainda que cabe à Corte Suprema dar a última palavra apenas no caso concreto, quando a sua tarefa, então, seria a de um mero tribunal de revisão, algo incompatível com a função de colaboração para o desenvolvimento do direito. Portanto, não é o caso de simplesmente dizer que os tribunais inferiores estão submetidos às Cortes Supremas, mas de perceber que os tribunais inferiores devem respeito ao direito delineado pelas Cortes que, no sistema judicial, exercem função de vértice. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, Parte II, Capítulo 4, item 4.4; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit.

156

O Estado constitucional tem dever de tutelar a segurança jurídica, garantindo a estabilidade do direito e a sua previsibilidade. Num Estado constitucional, além da estabilidade da ordem jurídica, espera-se univocidade da qualificação das situações jurídicas, sem a qual não há previsibilidade em relação às consequências jurídicas das condutas, algo que é indispensável para que o cidadão possa se desenvolver num Estado de Direito. O sistema jurídico, inclusive a estruturação e o funcionamento dos órgãos judiciais, deve ser capaz de outorgar previsibilidade. Lembre-se, aliás, que para MacCormick a previsibilidade das decisões constitui valor moral imprescindível para o homem, de forma livre e

autônoma, poder se desenvolver e, portanto, estar em um Estado de Direito (Neil MacCormick, *The ethics of legalism*, *Ratio Juris*, 1989, 2, p. 184 -193). Por sua vez, diz Massimo Corsale que um ordenamento jurídico destituído de capacidade de permitir previsões e qualificações jurídicas unívocas, e de gerar, assim, um sentido de segurança nos cidadãos, não pode sobreviver enquanto tal. (Massimo Corsale, *Certeza del diritto e crisi di legittimità*. Milano: Giuffrè, 1979, p. 31 e ss).

157

Jerzy Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, cit., p. 83.

158

“Sin adoptar posturas extremas, reconocemos con Carrió, que afirmar que los jueces crean derecho es una expresión ambigua; quizá sea esa ambigüedad la que posibilite el amplio consenso existente hoy en día al respecto. Pensamos, sin embargo, que se trata sólo de un consenso aparente, pues el significante ‘los jueces crean derecho’ encierra múltiples significados que dan lugar a las más diversas concepciones de la actividad judicial. Desde quienes pretenden asimilar la actividad de los jueces a la de los legisladores hasta aquellos que hablan de creatividad judicial en su sentido más débil como una dimensión necesaria en la tarea de decidir. Como ni uno ni otro extremo nos ofrecen un modelo de actividad judicial que resista su comparación con la realidad, creemos por el contrario que cierto grado de creación del derecho es inevitable y que en instancias tales como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo la creatividad judicial se asimila a la función del legislador en lo que se ha venido llamando legislación negativa” (Ernesto J. Vidal Gil; Cristina García Pascual, *Creación Judicial del Derecho, Sentido y razón del derecho – enfoques socio-jurídicos para la sociedad democrática*. Madrid: Hacer Editorial, 1992, p. 145-146). Ver Genaro Carrió. *Notas sobre derecho y lenguaje*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1979, p. 24 e ss; Giovanni Tarello, *Il “problema” dell’interpretazione: una formulazione ambigua*, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1966, p. 355.

159

Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 31-35; Riccardo Guastini, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 413.

160

Como diz Taruffo (*La Corte di Cassazione e la legge, Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*. Bologna: Il Mulino, 1991, p. 103), afirmar que a interpretação determina o significado “exato” de uma norma é uma afirmação privada de sentido, uma vez que a interpretação pode determinar apenas o significado fundado no emprego correto de critérios de eleição aceitáveis, ou seja, o significado fundado nas “melhores razões”. A interpretação fundada nas melhores razões tem a ver com a correção do procedimento de eleição e com a aceitabilidade dos critérios em que ela se funda, não se ligando à correção do resultado interpretativo. Fala-se, então, em “exatidão do método” de interpretação da lei; o método é correto quando a decisão é racionalmente justificada sob o perfil interno – de coerência entre as premissas e conclusões – e sob o perfil externo – de fundabilidade e aceitabilidade das premissas. A devida justificativa das opções interpretativas faz ver a racionalidade da interpretação e da decisão. Portanto, “decisão adequada” é a dotada de racionalidade, para o que é imprescindível “razões apropriadas” ou as “melhores razões”. A justificativa ou a qualidade das razões depende das características básicas da cultura

jurídica ou, mais propriamente, da própria cultura geral que apela à racionalidade (Jerzy Wróblewski, *Ideología de la aplicación judicial del derecho, Sentido y hecho en el derecho*. México: Fontamara, 2008, p. 83). Não há interpretação exata da lei ou interpretação correta se, com isso, pretende-se algo que independe de juízos de valor subjetivos. Há, isso sim, interpretação que, a partir de diretivas e de juízos de valor, é devidamente justificada; existe “decisão adequada” ou “decisão racionalmente aceitável”. Substitui-se, dessa maneira, a ideia de interpretação correta pela de “interpretação dotada de razões apropriadas”. Tutela-se a legalidade mediante a prática argumentativa e a busca da racionalidade. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. ed., cit., Part II, Capítulo 1, item 1.9; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit.

161

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, Capítulo IV, item 4.1.

162

STF, Pleno, Rcl 1.987, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.05.2004.

163

STF, Plenário, Rcl 2.363, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01.04.2005.

164

Linda Novak, *The precedential value of Supreme Court plurality decisions*, *Columbia Law Review*, 1980, p. 756-759.

165

“A ideia de se impor a decisão em separado dos fundamentos, ainda que múltiplos em relação a uma única alegação de contrariedade a norma, não pode ser admitida em virtude de contrariar a lógica do julgamento do recurso, ou melhor, em razão de negar o modo pelo qual o recurso é racionalmente julgado para se ter uma decisão ou resultado adequado ou justo. Como já dito, não há racionalidade em exigir maioria de votos ao menos em um dos fundamentos do recurso para se admitir o seu provimento. Com isso, num colegiado de cinco Ministros, ainda que os cinco reconhecessem a violação da norma, dois com base em um fundamento, dois com base em outro e o terceiro a partir de outro, não se teria como prover o recurso. Ou seja, a unanimidade dos Ministros teria visto contrariedade à norma e, ainda assim, seria proclamada a inexistência de contrariedade capaz de viabilizar o provimento do recurso” (Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, São Paulo: Ed. RT, 2015, Capítulo VI, item 6.18).

166

A doutrina e os tribunais estadunidenses se mostram angustiados com as decisões majoritárias ancoradas em fundamentos compartilhados por minorias. Isso por terem dificuldade de admitir uma decisão que não configure *ratio decidendi* ou precedente. Quando se parte da premissa de que a Corte não pode decidir sem formar precedentes, há realmente problema quando a decisão não é proferida com base em um fundamento sustentado pela maioria do colegiado. Porém, isso parece ser um equívoco próprio do

direito estadunidense, já que não se pode supor que num julgamento de que participam nove Justices sempre se tenha que ter um fundamento compartilhado por cinco. Isso equivaleria a não se poder ter uma decisão de cinco baseada em mais de um fundamento. Em verdade, isso significa confundir resolução do caso com fixação do entendimento da Corte. Mesmo num sistema de common law não deveria haver motivo para, ao não se encontrar maioria para sustentar um fundamento (ratio decidendi), não deixar a questão em aberto perante os juízos inferiores. Sobre o tema das plurality opinions da Suprema Corte dos Estados Unidos, ver Linda Novak, *The precedential value of Supreme Court Plurality Decisions*, *Columbia Law Review*, vol. 80, n. 4 (May, 1980), p. 761 e ss; John F. Davis e William L. Reynolds, *Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court*, *Duke Law Journal*, vol. 59, 1974, p. 67 e ss; Adam S. Hochschild, *The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation in Historical Perspective*, *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4 p. 279 e ss; Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, *The One and the Many: ADjudication in Collegial Courts*, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 11; Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, *The many as one: integrity and group choice in paradoxical cases*, *Philosophy & Public Affairs*, vol. 32, 2004, p. 249 e ss.

167

Em que pese não existir filtro semelhante à repercussão geral no Superior Tribunal de Justiça, é certo que esse tribunal é uma Corte Suprema que deve funcionar mediante a instituição de precedentes. Assim, a suspensão dos recursos pendentes é legítima desde que a participação dos amici curiae – cuja intervenção é admitida no recurso repetitivo – seja suficiente para dar voz aos litigantes perante a Corte.

168

Fala-se neste sentido em “universabilidade” do precedente. Quando se pensa em decisão universalizável não se está propriamente considerando o caso sob julgamento em face do precedente já firmado, mas se apontando para a necessidade de a justificativa da decisão conter razões que demonstrem a possibilidade da sua aplicação em todos os casos dotados das mesmas particularidades fáticas individualizadas como relevantes. Como escreve MacCormick, um ato só pode ser justificado como correto mediante universalização, uma vez que mostrar a sua correção é evidenciar que, sob qualquer visão objetiva do tema, o ato deveria ser praticado – ou mesmo deve ser praticado – em face das características do ato e das circunstâncias do caso (Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 131 e ss). A universabilidade tem importância para propiciar a aceitabilidade das razões justificadoras da decisão judicial e para permitir a checagem de se as decisões que lhe são posteriores ferem a igualdade. Desse modo a regra da universabilidade incide em duas perspectivas: para justificar a racionalidade da decisão e para identificar se uma decisão, posterior à firmada como precedente, nega as razões desse último. Essa segunda perspectiva, contudo, é uma consequência da adoção de um critério de racionalidade da decisão. Mas, além de contribuir para a racionalidade jurídica, a universabilidade certamente favorece a isonomia e inibe a parcialidade. Ao decidir, a Corte sabe que não poderá tratar os casos similares de modo diferente. Por isso é obrigada a proferir uma decisão que, considerando os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, tenha validade para todos os casos posteriores que se enquadrem na mesma moldura. Significa que não poderá decidir o caso sob julgamento a não ser a partir de critérios que tenham validade para todos os casos. Assim, ficará impedida de decidir de modo parcial, isto é, considerando particularidades que não são relevantes para uma decisão universal e imparcial. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. ed., cit., Parte II, Capítulo I, item 1.10; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit.; Idem, *Precedentes*, cit. Ver Paula Pessoa Pereira, *Legitimidade dos precedentes*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

169

Ver Frederick Schauer, *Thinking like a lawyer*. Cambridge: Harvard University Press, 2009, esp. itens 5, 8 e 9.

170

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, cit., Capítulo III, item 4.2.

171

STF, Plenário, HC 85.185-1, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01.09.2006.

172

Afinal, como diz Schauer, “para que uma decisão seja precedente para outra não há necessidade de que os fatos dos casos anteriores e posteriores sejam absolutamente idênticos. Caso isso fosse exigido, não haveria precedente para nenhum outro caso”. (Frederick Schauer, *Precedent*, *Stanford Law Review*, vol. 39, 1987, p. 575).

173

Lembre-se que “a tarefa de uma teoria de precedente é explicar, em um mundo em que um único evento pode ser enquadrado em várias categorias diferentes, como e por que algumas assimilações são plausíveis e outras não” (Frederick Schauer, *Precedent*, *Stanford Law Review*, vol. 39, 1987, p. 577).

174

Herbert Hart, *The concept of Law*, cit., p. 86 e ss.

175

Significa que não se nega que “una disposizione è chiara, in relazione a un qualche problema da risolvere e a un qualche caso concreto da disciplinare, soltanto dopo averla interpretata” (Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell’interpretazione giuridica*, cit., p. 62).

176

O art. 525, § 12, quando abre oportunidade para a impugnação invocar decisão tomada em “controle difuso”, afirma claramente a eficácia obrigatória das *rationes decidendi* firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

177

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., 2015, Capítulo III, item 3.5.

Luiz Guilherme Marinoni, *Julgamento nas Cortes Supremas*. São Paulo: Ed. RT, 2015, esp. capítulos 2 e 6.

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade*. São Paulo: Ed. RT, 2016, Capítulo V.

STJ, EDiv no REsp 608.122, 1.^a Seção, j. 09.05.2007, rel. Min. Teori Zavascki.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu não ter competência para definir se uma dada ação rescisória é cabível, nem mesmo socorrendo-se da Súmula 343, porque tal julgamento não acarreta, ao menos diretamente, exame de matéria constitucional (art. 102, III, a, da CF). Assim: “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (STF, AI-AgRg 456.931/MG, 2.^a Turma, rel. Min. Ellen Gracie, DJU 31.03.2006). No mesmo sentido: STF, AI-AgRg 460.439/DF, Tribunal Pleno, rel. p/acórdão Min. Sepúlveda Pertence, DJU 28.08.2006; STF, AI-AgRg 461.566/MG, 1.^a Turma, rel. Min. Carlos Britto, DJU 04.02.2005; STF, AI-AgRg 274.065/PE, 1.^a Turma, rel. Min. Sydney Sanches, DJU 22.11.2002; STF, AI-AgRg 371.721/BA, 2.^a Tuma, rel. Min. Nelson Jobim, DJU 18.10.2002.

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, cit.

BGH, Urteil vom 26. April 2006 – IV ZR 26/05 – OLG Bremen. No original: “Ein Wandel der Rechtsauffassung ist kein Restitutions-grund (BVerfGE 2, 380, 395, 405; BGH, Urteil vom 11. März 1953 – II ZR 180/52 – BB 1953, 273; BAG, AP Nr. 1 zu § 580 ZPO; BFHE 123, 310, 311 f.)”.

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, cit., Capítulo 3, itens 4 e 5.

STJ, REsp 127.510, 2.^a Turma, rel. Min. Ari Pargendler, DJU 02.03.1998.

Cf. Miguel Galvão Teles, Inconstitucionalidade pretérita, Nos dez anos da Constituição, cit., p. 329.

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade, cit., Capítulo V, item 5.2.

Como corretamente observa Bruno de Moraes Rêgo, “o inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil [1973], usado como está sendo para rescindir julgados proferidos em sede de controle de constitucionalidade, serve para impedir a ação do controle difuso” (Bruno de Moraes Rêgo, Ação rescisória e a retroatividade das decisões de controle de constitucionalidade das leis no Brasil. Porto Alegre: Fabris, 2001, p. 352).

Nessa linha, é absolutamente correta a análise de Leonardo Greco, no sentido de que rescisória que ressuscite questão de direito ampla e definitivamente resolvida no juízo rescindendo, com fundamento no art. 485, V, do CPC [1973], viola claramente a garantia da coisa julgada (Leonardo Greco, Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior, Relativização da coisa julgada. Salvador, JusPodium, 2008, p. 251 e ss.).

“... o recrudescimento da decisão judicial, ápice do discurso jurídico, é imprescindível para que o próprio discurso tenha razão de ser e, assim, realmente exista enquanto discurso jurídico. A coisa julgada, portanto, não é uma regra preocupada com o conteúdo do discurso, mas sim uma condição para que o discurso seja um discurso institucional limitado no tempo e, destarte, um discurso jurídico propriamente dito. Na verdade, se a discussão jurídica não tiver um termo a partir do qual a decisão não possa ser questionada, não haverá sentido em falar em discurso jurídico nem muito menos em realizá-lo. Ora, um discurso jurídico incapaz de se estabilizar é uma contradição em termos, já que o poder, fundamento do discurso jurídico, impescinde do recrudescimento. É por isto que um discurso aberto à eterna discussão jamais será um discurso jurídico ou um discurso do poder estatal, mas tão somente um discurso prático-geral” (Luiz Guilherme Marinoni, A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade, cit., Capítulo III, item 3.1).

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade, cit., Capítulo V, item 5.2.

Cf. Miguel Galvão Teles, Inconstitucionalidade pretérita, Nos dez anos da Constituição, cit., p. 329.

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade, cit., Capítulo V, item 5.2.

No sentido do descabimento de ação rescisória com base em ulterior declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, está o acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: “Tributário – Ação rescisória – Violação a literal disposição de lei – FGTS – Expurgos inflacionários – Súmula 343/STF – Declaração ulterior de inconstitucionalidade – Interpretação controvertida nos tribunais – Indeferimento liminar da petição inicial. 1. ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’ (Súmula 343 do STF). 2. Um dos pilares da segurança jurídica é exatamente o respeito à coisa julgada. Deveras, a eliminação da lei inconstitucional, em geral, deve obedecer os princípios que regulam a vigência das leis, impedindo-as de retroagir. 3. Desta sorte, salvo manifestação expressa nos acórdãos das ações de declaração de inconstitucionalidade, em controle concentrado, as decisões judiciais anteriores não podem ficar à mercê de rescisórias, sob o fundamento de terem sido proferidas com base em lei inconstitucional. 4. Posicionamento diverso implica em violar dois institutos preservados pela Constituição, um instrumental e outro substancial: a saber, a coisa julgada e a segurança jurídica. 5. Aliás, não é por outra razão que a Lei 9.868/1999, que regula a declaração de inconstitucionalidade, reclama termo a quo dos efeitos da decisão, expressamente consignados no acórdão, consoante o disposto no art. 27 da referida Lei. 6. A ratio essendi da Súmula 343 aplica-se in casu, por isso que se, à época do julgado, a lei estava em vigor, sem qualquer eiva de inconstitucionalidade, em prol do princípio da segurança jurídica prometida pela Constituição Federal, não se pode entrever violação àquela pelo acórdão que a prestigiou. 7. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no Ag 461.196/DF, 1.^a Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 02.12.2002).

“A rescisão seria, assim, um veículo de restauração do controle concentrado sobre o controle difuso e não apenas a defesa da supremacia da Constituição. Seria, por assim dizer, um modo de fazer prevalecer os valores do controle concentrado sobre os valores do controle difuso. Seria prevalecer a generalidade sobre a especificidade. Tal concepção deve ser afastada, já que o controle difuso continua a ser a regra e é graças a ele que se torna possível a defesa dos direitos e garantias individuais” (Bruno de Moraes Rêgo, Ação rescisória e a retroatividade das decisões de controle de constitucionalidade das leis no Brasil, cit., p. 355).

Cf. Rui Medeiros, A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica Ed., 1999, p. 550.

Rui Medeiros, A decisão de inconstitucionalidade, cit., p. 550.

STF, RE 590.809, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014.

199

STF, RE-ED 328812, 2.^a Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.05.2008.

200

STF, RE-ED 328812, 2.^a Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.05.2008 STJ; STJ, EDiv no REsp 608.122, 1.^a Seção, rel. Min. Teori Zavascki, j. 09.05.2007.

201

STF, RE 590.809, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014. Rigorosamente, o mesmo raciocínio vale para a superveniência de precedente federal diante do anterior estado de controvertibilidade jurisprudencial da questão federal: aplica-se a súmula n. 343, STF, conforme vem decidindo reiteradamente o STJ (por exemplo, 3.^a Turma, AgInt no AREsp n. 1.125.200/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 10.04.2018, DJe 13.04.2018).

202

Idem, ibidem.

203

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade, cit., Capítulo III, item 3.9.

204

“Possibilidade de rescisão de julgado fundamentado em prova pericial falsa, cuja demonstração ocorra no próprio seio da ação rescisória. Previsão expressa do art. 485, inc. VI, parte final, do CPC”. (STJ, REsp 885.352/MT, 3. a. Turma, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.04.2011).

205

O n. 2 do art. 395 do CPC italiano igualmente admite que qualquer prova falsa possa fundamentar a revocazione. Carpi, Colesanti e Taruffo enfatizam que “la norma si riferisce infatti a tutte le prove e non solo ai documenti (Satta; Andrioli), ad eccezione del giuramento, la cui falsità, anche se accertata giudizialmente, non può dar luogo a revocazione (...). Tra le prove la cui falsità è rilevante ai fini della revocazione va ricompresa anche la consulenza tecnica” (F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile. Padova: Cedam, 1988, p. 597).

206

“A eventual falsidade das premissas adotadas pelo perito implica falsidade do próprio laudo, sobretudo se ficar comprovado que seus cálculos foram realizados com base em área de fato inexistente ou, ao menos, jamais inundada”. (STJ, REsp 1290177/MS, 3. a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.12.2012). “A

questão acerca da suposta ausência de formulação de quesitos objetivos, quanto à falsidade da perícia realizada no bojo da ação de desapropriação, não foi fundamental ao deslinde da controvérsia”. (STJ, REsp 1179444/DF, 2.ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2012)

207

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 134.

208

“É admissível Ação Rescisória fundada no art. 485, VI, do CPC, em que se alega a falsidade da prova pericial em razão da falta de correspondência entre o objeto analisado e o laudo produzido”. (STJ, AgRg na AR 3.290/SP, 1.ª Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.11.2009). “Hipótese em que, entretanto, não se alegou falsidade, que seria do laudo pericial, mas, apenas, que não se teria chegado a um resultado correto em virtude da deficiência da química disponível quando de sua realização”. (STJ, REsp 127.023/DF, 3.ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 05.02.2001).

209

Ao abordarem o n. 2 (se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza) do art. 395 do Código de Processo Civil italiano, afirmam Comoglio, Ferri e Taruffo que “la prova deve avere un’efficacia causale diretta rispetto agli elementi di convincimento sui quali il giudice ha fondato l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza soggetta a revocazione” (Luigi P. Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, Lezioni sul processo civile. Bologna: Il Mulino, 1995, p. 737).

210

“O art. 485, VI, do CPC é absolutamente claro no sentido de não bastar que a prova supostamente falsa tenha sido juntada nos autos do julgado rescindendo, fazendo-se indispensável que o julgado rescindendo esteja fundamentado no mencionado elemento probatório”. (STJ, REsp 929.654/PR, 4.ª Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.04.2014). “A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo”. (STJ, AR 3.553/SP, 3.ª Seção, rel. Min. Felix Fischer, DJe 06.04.2010).

211

AR 1.291/SP, 1.ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.06.2008.

212

Francesco Carnelutti, La prova civile, 2.ª ed. Roma: Atteneo, 1947, p. 182.

213

Idem, p. 140.

214

“No testemunho o ato é o próprio fato representativo, onde a representação é o seu efeito imediato; no documento o ato não é jamais o fato representativo, mas um momento precedente a este, porque não representa por si, mas cria um objeto capaz de representar. Quem quiser ter uma impressão brusca desta diferença compare o ato do narrador ao ato do fotógrafo: o primeiro age representando, o segundo age preparando uma coisa, que representará. O ponto de contato entre os dois tipos de fatos representativos é, portanto, a formação mediante a atividade humana; o ponto de divergência é o pressuposto desta atividade, que no documento opera sobre um fato presente e se projeta no futuro, no testemunho opera sobre um fato não presente e se projeta no passado”. (Francesco Carnelutti, *La prova civile*, cit., p. 181). No mesmo sentido, diz Couture que na prova documental “o intermediário fica reduzido tão somente à conversão do fato em coisa” (Eduardo Couture, *Fundamentos del derecho procesal civil*. Buenos Aires: Depalma, 1951, p. 266).

215

Francesco Carnelutti, *La prova civile*, cit., p. 158 e ss.

216

Luiz Guilherme Marinoni, *Coisa julgada inconstitucional*. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 191 e ss. V. Luiz Guilherme Marinoni, *A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

217

Ao que se saiba, essa forma de interpretar o texto legal nada mais é do que uma obrigação do intérprete. Recorde-se que o texto da norma não se confunde com a norma jurídica, que é o resultado da interpretação. O juiz deve ler o texto legal em face da Constituição e dos valores da sua época, adequando-o às novas realidades. Interpretando-se o texto, chega-se a uma conclusão – ou resultado –, que nada mais é do que a norma jurídica. Nessa perspectiva, se o texto da norma pode envelhecer, ele deve ser reavivado através da interpretação judicial, que estabelece a norma jurídica. Desse modo, a normatividade deve ser vista como um “processo”, e não como uma qualidade do texto. Ela não é; ela age. Ver Cristina Queiroz, *Direitos fundamentais (teoria geral)*. Coimbra, Coimbra Ed., 2002, p. 87.

218

STJ, REsp 300.084, 2.^a Seção, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 06.09.2004.

219

Sobre este ponto, foi escrito no livro *Coisa Julgada Inconstitucional*, publicado em 2008: “Entretanto, se o prazo não pode ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão que se quer impugnar, porque não se trata de algo que já existia na época da ação, mas de um meio que passou a existir não se sabe quanto tempo depois do trânsito em julgado, aparece uma nova questão: é certo deixar que o vencido na ação de investigação de paternidade, seja autor ou réu, possa rever a sentença a qualquer tempo, sem subordiná-lo a qualquer prazo? Será que a biologia não estaria se sobrepondo à própria necessidade da definição da

relação de filiação, a qual é imprescindível para o surgimento do afeto necessário para a vida entre pai e filho, ou mesmo tornando indefinida a vida das pessoas? Perceba-se que a eterna abertura à discussão da relação de filiação consistiria algo que sempre estaria a estimular a desconfiança dos envolvidos. É claro que, mesmo em relação à investigação de paternidade, o estabelecimento de prazo para a rescisão da sentença é um imperativo da natureza do ser humano e da vida em sociedade e, assim, da própria necessidade da jurisdição. É correto concluir que a sentença da ação de investigação de paternidade somente pode ser rescindida a partir de prazo contado da ciência da parte vencida sobre a existência do exame de DNA. Não obstante, a dificuldade de identificação desta ciência é somente mais uma razão a recomendar a imediata intervenção legislativa. Como esta ação possui relação com a evolução da tecnologia, ou melhor, com uma forma de produção de prova impensável na época em que o art. 485 do CPC/1973 passou a reger a ação rescisória, é imprescindível que este artigo seja alterado para que seja evidenciada a possibilidade do uso da ação rescisória com base em exame de DNA, bem como o seu prazo” (Luiz Guilherme Marinoni, Coisa julgada inconstitucional, cit., p. 196-198). V. Luiz Guilherme Marinoni, A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade, cit.

220

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 138-139.

221

No direito italiano, afirma Elio Fazzalari: “documenti ‘nuovi’ non perché creati dopo la sentenza de qua, sibbene perché non esibiti nel precedente processo. (Elio Fazzalari, Revocazione (dir. proc. civ.), Enciclopedia del diritto, vol. XL, 1989, item 6). No mesmo sentido, Carpi, Colesanti e Taruffo: “Il documento, e non solo il fatto documentato, deve preesistere alla lite” (F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, cit., p. 598).

222

“Deve trattarsi poi di una prova documentale diretta dei fatti di causa e non di un documento che dia prova di fatti diversi e successivi a quello dedotto in causa, capaci di fornire indizi (Corte di Cassazione 74/1288)” (F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, cit., p. 598).

223

F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, cit., p. 598.

224

Art. 116: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.

225

Corte de Cassação, 80/691; 85/589; Cf. F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, Commentario breve al Codice di

226

“Se o magistrado acolher o pedido de exibição, ordenará ao terceiro ‘que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de cinco dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver’ (art. 403, CPC). Na eventualidade de o terceiro não cumprir a ordem judicial, sujeitar-se-á à busca e apreensão da coisa ou do documento, se necessário com o apoio de força policial, a par de outras sanções, criminais, civis ou processuais (medidas sub-rogatórias e coercitivas) que se mostrem adequadas para o caso (art. 403, parágrafo único, CPC). Assim, além de sujeitar-se à busca e apreensão, o réu pode incorrer em crime de desobediência, podendo ainda incidir em multa processual (art. 77, IV, c/c seu § 2, CPC) ou qualquer outra medida coercitiva ou sub-rogatória necessária” (Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. 2, p. 354).

227

É similar o entendimento da Corte di Cassazione italiana, conforme relatam Carpi, Colesanti e Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, cit., p. 598.

228

Comoglio, Ferri e Taruffo, quando tratam do n. 3 (se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu’ documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario) do art. 395 do Código de Processo Civil italiano, escrevem que “decisivo è il documento dal quale risultino fatti tali che se il giudice avesse potuto valutare la decisione sarebbe stata diversa: si tratta di fatti rilevanti per la decisione con significato tale da far apparire possibile che la loro mancata considerazione abbia potuto influire in modo determinante sulla decisione del giudice” (Luigi P. Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, Lezioni sul processo civile, cit., p. 737).

229

“È decisivo il documento idoneo a fornire elementi i quali, se si fossero potuti esaminare, avrebbero potuto indurre a diversa decisione (Corte di Cassazione, 86/4847; 84/2299)”. (F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, cit., p. 598).

230

“Não há de se falar em rescisão de decism, sob alegação de erro de fato, que, apesar de considerar um fato inexistente, não se fundamenta nele para concluir pela prescrição da pretensão dos autores”. (AR 3.680/RJ, 3. a Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 11.04.2011).

231

“Non deve trattarsi di un errore di valutazione ma di un errore nella percezione: non errore di giudizio, ma errore su un fatto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure errore su un fatto supposto inesistente, ma la cui verità è invece positivamente stabilita e accertata” (Luigi P. Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, Lezioni sul

232

“Em primeiro lugar, não existe erro de fato no caso concreto. O que os autores querem discutir agora não é incorreta premissa de fato, mas a valoração jurídica tomada pela Min. Laurita Vaz para fins de contagem e aferição do prazo prescricional. Erro de fato não se confunde com possível erro na qualificação jurídica dos fatos”. (AgRg na AR 4.786/PR, 1.ª Seção, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18.11.2011). “O critério hermenêutico adotado pelo aresto rescindendo para concluir que o autor mantinha vínculo econômico com o GDF não pode ser discutido em ação rescisória embasada no art. 485, IX, do CPC, pois não se cuida de fato inexistente, mas de valoração jurídica sobre os fatos narrados no processo” (AgRg na AR 3.204/DF, 1.ª Seção, rel. Min. Castro Meira, DJ de 20.03.2006).

233

“La non verità del fatto asserito (dal giudice) o la verità del fatto da lui escluso non può essere provata con nuovi elementi da addurre in sede di revocazione, ma deve già risultare ictu oculi dagli elementi raccolti nella fase che ha messo capo alla sentenza; l'errore del giudice non discende da un suo ragionamento distorto, cioè dall'aver egli motivato il proprio assunto di fatto con argomentazioni lacunose o incongrue circa le risultanze in atti (se così fosse, egli sarebbe incorso in errore di motivazione, id est di ragionamento, su fatto decisivo, da denunciare in Cassazione, a' sensi del n. 5 dell'art. 360), sibbene da un abbaglio, da una svista a livello di percezione (per esempio, la sentenza indica una certa data di nascita, mentre da un certificato, in atti, risulta una data diversa)” (Elio Fazzalari, Revocazione (dir. proc. civ.), Enciclopedia del Diritto, vol. XL, item 6).

234

“Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não fica viabilizada a ação rescisória, fundada no art. 485, IX, do CPC, quando: 1) a comprovação do erro de fato efetue-se por meio de documento expedido após proferida a decisão rescindenda, ou seja, que não compõe o material fático-probatório da causa originária”. (AgRg no AREsp 134.429/DF, 2.ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2012).

235

F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, cit., p. 599.

236

“Constitui o erro de fato a que se refere o inc. IX, do art. 485, do Código de Processo Civil, autorizando o manejo da ação rescisória, a afirmação de ausência de prova material, quando esta se encontra efetivamente acostada à peça inicial da ação originária e não foi considerada”. (AR 643/SP, 3.ª Seção, rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 10.03.2003).

237

“Ovviamente, l'errore in discorso, come si diversifica da quello – di ragionamento – di cui all'art. 360 n. 5,

così non ha niente a che vedere con 'l'errore materiale', che si rileva dalla lettura della sentenza e cui si rimedia con la correzione" (Elio Fazzalari, Revocazione (dir. proc. civ.), Enciclopedia del Diritto, vol. XL, item 6).

238

Andrea Proto Pisani, op. cit., p. 535.

239

Como já decidiu a 2.ª Turma do STJ, "o erro material é aquele que não decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes. O erro material não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional". (AgRg nos EDcl no REsp 1242507/SP, 2.ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJe 01.06.2011)

240

"Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2.º do inc. IX do art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de ação rescisória. Identificada extensa controvérsia dirimida no acórdão rescindendo entre as partes acerca dos fatos alegados, impossível o juízo rescisório". (AgRg na AR 4.754/MG, 2.ª Seção, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013).

241

"3. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado [art. 485, IX, do CPC] deve ser apurável mediante simples exame dos documentos e demais peças acostadas aos autos. Não se admite produção de prova tendente a demonstrar a inexistência do fato admitido pelo juiz ou a ocorrência de fato considerado inexistente. 4. O preceito do § 2.º do art. 485 do CPC exige, para a rescisão do julgado, apenas a existência de fato incontroverso sobre o qual a sentença pronunciou-se. 5. O acórdão rescindendo atribuiu à autora objeto social inexistente. O fato — ser ela uma empresa exclusivamente prestadora de serviços — não foi objeto de controvérsia. A simples leitura dos seus estatutos, por sua vez, permite a verificação do erro de fato de que trata o art. 485, IX, do CPC. 6. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão rescindendo e determinar a incidência da alíquota da contribuição para o FINSOCIAL aplicável às empresas mercantis" (AR 1607, Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, rel. p/Acórdão Min. Eros Grau, DJ 29.09.2006).

242

"2. A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.296.673/MG, rel. Min. Herman Benjamin, processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que "a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2.º e 3.º, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997". Incidência da Súmula 507/STJ.

3. Pela leitura da petição inicial do réu no processo originário (e-STJ fls. 32) e do acórdão proferido pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 55/59), verifica-se que o acidente em questão ocorreu em 1999, quando o segurado já recebia a aposentadoria por tempo de contribuição e na vigência da Lei 9.528/97.

4. Como o julgado rescindendo considerou como inexistente um fato existente – a ocorrência do acidente em data anterior à edição da Lei 9.528/1997 –, torna-se evidente o erro de fato.

5. Ação rescisória procedente”. (AR 4.196/SP, 3. a Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06.11.2015).

243

“É possível rescindir, por erro de fato, decisão que, com base em certidão errônea de secretaria de tribunal, considerou extemporâneo recurso tempestivamente protocolado visando à reforma de sentença de mérito. Precedentes do STJ”. (EDcl no REsp 439.753/SP, 4. a Turma rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.12.2012).

244

“A existência de controvérsia entre as partes sobre o ponto em debate e a ocorrência de pronunciamento judicial acerca do tema afastam a viabilidade da ação rescisória fundada no art. 485, IX, do CPC”. (AgRg no REsp 1419365/SC, 3. a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26.09.2014). No mesmo sentido: REsp 1248464/SC, 2. a Turma rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.09.2011.

245

“A ação anulatória, prevista no art. 486 do Código de Processo Civil, tem cabimento para a desconstituição de atos jurídicos em geral levados a efeito em juízo e alvo de mera homologação judicial. Assim, para que seja utilizada no ataque a sentença transitada em julgado, imperioso é que a atividade exercida pela autoridade judiciária tenha se revestido de caráter meramente secundário, visando apenas conferir oficialidade à vontade manifestada pelos litigantes (acordos, transações etc) ou a emprestar eficácia ao negócio jurídico realizado em procedimento judicial (arrematação, adjudicação etc). Quando, ao contrário, a sentença acobertada pela eficácia da coisa julgada material, não é meramente homologatória, e deriva do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário competente, resolvendo o mérito da lide (art. 269 do CPC), somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória (art. 485 do CPC), restando imprestável a esse fim a demanda disciplinada no art. 486 do CPC”. (REsp 1286501/GO, 4. a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02.03.2012).

246

“A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o pleito de desconstituição de sentença homologatória de alimentos demanda ação própria, prevista no art. 486 do CPC” (AgRg no REsp 1152702/MT, 3.ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.05.2014).

247

AgRg no REsp 1440037/RN, 4. a Turma rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.09.2014.

REsp 450.431/PR, 1. a Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.10.2003.

REsp 1238684/SC, 3. a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.12.2013. “A partilha amigável (CC/16, art. 1.773; CC/2002, art. 2.015) é passível de anulação, nos termos dos arts. 486, 1.029 e 1.031 do CPC, enquanto a partilha judicial é rescindível, conforme preconizam os arts. 485 e 1.030 do CPC”. (REsp 803.608/MG, 4. a Turma, rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.04.2014).

REsp 884.742/PR, 2. a Turma rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.04.2011. “Acordo extrajudicial homologado por sentença, em sede de ação civil pública, com a concordância expressa do órgão ministerial, e lesivo aos interesses da administração pública, é passível de anulação, in abstracto, na forma do art. 486, do CPC, sob os fundamentos que autorizam a ação popular”. (REsp 450.431/PR, 1. a Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.10.2003).

“O prazo decadencial para o ajuizamento entre particulares da ação anulatória de arrematação em execução judicial rege-se pelo art. 178, § 9.º, V, b, do CC/16 e pelo art. 178, II, do CC/2002, sendo de 4 (quatro) anos a contar da data da assinatura do auto de arrematação (art. 694, CPC). Já o prazo decadencial para o ajuizamento da mesma ação contra a Fazenda Pública rege-se pelo art. 1.º do Dec. 20.910/32, sendo de 5 (cinco) anos, com o mesmo termo inicial”. (REsp 1254590/RN, 2. a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.08.2012).

“A ação anulatória de sentença homologatória de acordo, prevista no art. 486 da Lei Adjetiva (CPC/1973), possui nexó etiológico com a ação originária em que fora homologada a transação celebrada entre as partes. Nos termos do art. 108 do CPC/1973, “a ação acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal”, regra que traduz hipótese de modificação de competência. A acessoriedade prevista no art. 108 do CPC/1973 abrange a relação entre as duas demandas supramencionadas e legitima a prevenção do juízo homologante para apreciação da ação anulatória, tendo em vista as melhores condições do juízo de direito originário para apreciá-la. Premissa estabelecida em precedente da Segunda Seção: CC 120556/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2013, DJe 17.10.2013”. (REsp 1150745/MG, 4. a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19.02.2014)

“A rigor, o objeto da anulação é o ato jurídico subjacente (ajuste entre as partes), e não exatamente a sentença, meramente homologatória”. (REsp 884.742/PR, 2. a Turma rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.04.2011).

“Conforme jurisprudência sedimentada no STJ, é cabível ação anulatória para atacar arrematação realizada em feito executivo. Precedentes: REsp 66.596/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 28.11.1995; REsp 11.535/RS, 4.^a Turma, Rel Min. Athos Carneiro, j. 10.12.1991; REsp 150.115/DF, 3.^a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.12.1998; REsp 442.238/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 27.05.2003; AgRg no Ag 638.146/GO, 4.^a Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 21.06.2005; REsp 859.614/RS, 1.^a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2008; REsp 130.588/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 16.08.2005”. (REsp 1254590/RN, 2.ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.08.2012). “Uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a desconstituição do ato nos próprios autos da execução, sendo necessário o ajuizamento da ação anulatória (art. 486 do CPC). (REsp 1219329/RJ, 3.ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29.04.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 94.259/SP, 4.ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.09.2012; AgRg no Ag 945.726/MG, 6.ª Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18.10.2010.

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil, cit., p. 978.

REsp 810.355/RS, 1.ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.05.2008.

Caso o executado tenha sofrido dano em virtude da perda do bem, tem não só o direito de ser reembolsado pela quantia equivalente ao valor do bem – que deve ser novamente avaliado para este efeito –, mas também o direito ao ressarcimento pelo equivalente ao dano que sofreu, aí incluídos o dano imediato provocado pela perda do bem e eventuais lucros cessantes (Cf. Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil, cit., p. 978).

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil [1973], vol. 5, cit., p. 127.

“Embora preveja expressamente o art. 488, I, do CPC a obrigatoriedade do autor de cumular o pedido de rescisão e, se for o caso, de novo julgamento, a cumulação de pedidos não é exigência formal absoluta, devendo ser abrandado o rigor do referido dispositivo” (REsp 783.516/PB, 2.ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29.06.2007). “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se implicitamente requerido o novo julgamento da causa, desde que seja decorrência lógica do pedido na ação rescisória” (STJ, AgRg no REsp 1070825, 3.ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03.02.2014).

261

REsp 744.286/DF, 1.ª Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 03.04.2006.

262

Sobre a tutela provisória, com as devidas indicações bibliográficas, Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da Tutela*, 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012; Daniel Mitidiero, *Antecipação da Tutela – da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

263

STJ, 2.ª Turma, Resp 651.241/SP, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 20.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 184.

264

“Nelle sentenze di accertamento l’attestazione autoritativa dell’esistenza di una concreta volontà di legge – che stabilisce quale sia la tutela degli interessi delle parti in un dato rapporto giuridico – esaurisce i provvedimenti che le parti possono o vogliono chiedere al giudice, dato il modo con cui si è determinata la situazione di insoddisfazione dei loro interessi (...) Tale elemento nelle sentenze di condanna è la pronunzia sulla possibilità di un’ulteriore attività giurisdizionale per assicurare la tutela degli interessi protetti: nelle sentenze costitutive è un’ulteriore attività del giudice che addirittura realizza nella stessa sentenza quella soddisfazione degli interessi cui è stato accertato che una parte ha diritto. Questa soddisfazione è data da un cambiamento della preesistente situazione di diritto materiale” (Alessandro Rassei, *Sentenze determinative e classificazione delle sentenze*, Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti. Padova: Cedam, 1950, vol. 2, p. 580). Crisanto Mandrioli, na mesma linha, afirmou que “nelle sentenze di mero accertamento e nelle sentenze costitutive la tutela giurisdizionale si esaurisce fruttuosamente, mentre nella sentenza di condanna si esaurisce soltanto una fase di quella tutela” (Crisanto Mandrioli, *L’azione esecutiva*. Milano: Giuffrè, 1955, p. 310). Cristina Rapisarda, mais tarde, ao tentar classificar as sentenças a partir do efeito declarado no plano do direito material, concluiu que determinados provimentos (o declaratório e o constitutivo) realizam autônoma e integralmente a tutela concedida pela norma à fattispecie substancial declarada, podendo, assim, receber a designação de “satisfativos” (Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*. Padova: Cedam, 1987, p. 231 e ss.).

265

“A ideia de sentença autossuficiente pode ser associada à de sentença satisfativa. Trata-se da sentença que é suficiente por si só, vale dizer, da sentença que satisfaz o jurisdicionado sem precisar interferir na esfera jurídica do réu ou modificar de maneira forçada a realidade dos fatos. Como é fácil perceber, essa distinção corresponde à separação entre as sentenças declaratória e constitutiva, de um lado, e as sentenças condenatória, mandamental e executiva, de outro. A mera prolação da sentença declaratória ou constitutiva é suficiente ou satisfativa, enquanto as sentenças condenatória, mandamental e executiva jamais poderão satisfazer quando destituídas de meio executivo capaz de conformar os fatos” (Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 155 e ss).

266

Ver Federico Carpi, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*. Milano: Giuffrè, 1979; Gianpaolo Impagnatiello, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1992, p. 47 e ss.

267

STJ, AgRg na AR 3.715/PR, 1.^a Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJ 27.08.2007.

268

Luiz Guilherme Marinoni, *A antecipação da tutela*, 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, item 4.10.9.

269

Conforme já declarou o Superior Tribunal de Justiça, “a competência para determinar a suspensão da execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do Tribunal competente para apreciar a referida ação. Com efeito, as tutelas de urgência devem ser requeridas no juízo competente para julgamento da causa (arts. 273 e 800 do CPC/1973). Dessarte, na espécie resta inequívoca a usurpação da competência deste Sodalício pelo juízo da execução, que, com base no poder geral de cautela, determinou a suspensão da execução sob a alegação de que foi proposta ação rescisória nesta Corte” (STJ, REsp 618.745/RS, 2.^aTurma, rel. Min. Franciulli Netto, DJ 06.03.2006).

270

STJ, AR 193/SP, 1.^a Seção, rel. Min. Adhemar Maciel, DJ 05.03.1990.

271

Sérgio Porto, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 380, vol. VI; Alexandre Freitas Câmara, *Ação Rescisória*, 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 126.

272

Gian Antonio Micheli, *L'Onere della Prova*. Milano: Giuffrè, 1942, pp. 151 e seguintes.

273

Leo Rosenberg, *Die Beweislast*, 3. Ed. München: C. H. Beck, 1953, p. 62.

274

Vitor de Paula Ramos, *Ônus da Prova no Processo Civil – Do Ônus ao Dever de Provar*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 111/116.

275

Gian Antonio Micheli, *L'Onere della Prova*. Milano: Giuffrè, 1942, p. 85.

276

Leo Rosenberg, *Die Beweislast*, 3. Ed. München: C. H. Beck, 1953, p. 65.

277

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Prova e Convicção*, 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; Artur Carpes, *Ônus Dinâmico da Prova*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, pp. 51 e seguintes.

278

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 136.

279

Antonio do Passo Cabral, *Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas*. Salvador: JusPodium, 2013, pp. 298/299.

280

Sobre a possibilidade de redução do módulo da prova em geral, Gerhard Walter, *Libre Apreciación de la Prueba*, tradução de Tomás Banzhaf. Bogotá: Temis, 1985, pp. 229 e seguintes; Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 181/182, vol. VI.

281

Flávio Yarshell, *Ação Rescisória*. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 383.

282

Michele Taruffo, *“Fatti e Prove”*, *La Prova nel Processo Civile*. Milano: Giuffrè, 2012, pp. 22 e seguintes.

283

Kazuo Watanabe, *Da Cognição no Processo Civil*, 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 132. Como é notório, Kazuo Watanabe ensina que “a cognição pode ser vista em dois planos distintos: horizontal (extensão, amplitude) e vertical (profundidade). No plano horizontal, a cognição tem por limite os elementos objetivos do processo” (pressupostos processuais, condições da ação e mérito). Nesse plano, “a cognição pode ser plena ou limitada (ou parcial), segundo a extensão permitida. No plano vertical, a cognição pode ser classificada, segundo o grau de profundidade, em exauriente (completa) e sumária (incompleta)” (Da Cognição no Processo Civil, 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 118). Anote-se, ademais, que a cognição pode ainda ser modulada em cognição *secundum eventum probationis* (conforme a suficiência da prova permitida no procedimento para conhecimento das questões), *secundum eventum defensionis* (conforme a

apresentação ou não de defesa pelo réu) e *secundum eventum litis* (conforme o resultado do processo). Sobre o assunto, ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Tutela de Urgência e Tutela da Evidência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 29/40.

284

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 198, vol. V.

285

Flávio Yarshell, Ação Rescisória. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 387.

286

STJ, 4.^a Turma, REsp 107.136/AM, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 02.08.2001, DJ 03.09.2001, p. 225.

287

STJ, 1.^a Seção, EAR, 568/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.11.2001, DJ 18.02.2002, p. 211.

288

Para uma ilustração da afirmação, Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp. 347 e seguintes, tomo VI.

289

A ligação entre direitos potestativos (também conhecidos como direitos formativos) e prazos decadenciais e direitos a prestações e prazos prescricionais é vencedora na doutrina e está à base da disciplina da matéria no Código Civil (por todos, Humberto Theodoro Júnior, Comentários ao Código Civil, 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 421/423, vol. III, tomo II). No plano do direito processual, o balizamento do exercício de ônus e direitos pelas partes no tempo dentro do processo ocorre por força da preclusão temporal (Giuseppe Chiovenda, “*Cosa Giudicata e Preclusione*”, *Saggi di Diritto Processuale Civile* (1894 – 1937). Milano: Giuffrè, 1993, pp. 231/283, vol. III; Heitor Sica, Preclusão Processual Civil, 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2008; Antonio do Passo Cabral, Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodium, 2013). A hipótese aqui cogitada, porém, é a de exercício do direito de invalidar dando lugar a um novo processo – daí ser apropriado falar em decadência e não em preclusão temporal.

290

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 221, vol. V.

291

Sérgio Porto, Ação Rescisória Atípica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 143.

Lembre-se que a justiça das decisões é um dos objetivos da tutela dos direitos, notadamente da tutela dos direitos em uma perspectiva individual, expressamente abraçado entre nós no art. 6º, CPC. A colocação da justiça da decisão como um dos “goals” da Justiça Civil, aliás, é um dos resultados que emergem da comparação entre diferentes sistemas jurídicos (Alan Uzelac, “Goals of Civil Justice and Civil Procedure in the Contemporary World”, in *Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary World*. Dordrecht: Springer, 2014, pp. 6 e 11).

James Goldschmidt, *Der Prozess als Rechtslage*. Berlin: Springer, 1925, pp. 151 e seguintes.

Existem duas exceções a esse prazo: a primeira é aquela constante do art. 8º-C, Lei n. 6.739, de 1979, que prevê o prazo de oito anos para o exercício da ação rescisória relativa à decisão que diga respeito à transferência de terras públicas rurais (a lembrança é de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, 13. Ed. Salvador: JusPodium, 2016, p. 459, vol. III); a segunda é aquela constante do art. 22, I, j do Código Eleitoral: a ação rescisória em matéria eleitoral, cabível apenas contra as decisões que declaram a inelegibilidade, deve ser proposta dentro de cento e vinte dias (a lembrança é de José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 219, vol. V). A Fazenda Pública não tem prazo diferenciado para a propositura de ação rescisória, submetendo-se ao prazo comum de dois anos.

Exemplificativamente, Piero Calamandrei, *La Cassazione Civile, Opere Giuridiche*. Napoli: Morano, 1976, pp. 135/136 (que lembra os prazos de determinados estatutos medievais italianos, que variam de trinta dias a um ano); Moacyr Lobo da Costa, *A Revogação da Sentença*. São Paulo: Ícone, 1995, p. 131 (que lembra o prazo de vinte anos para o exercício da querela nas *Siete Partidas* espanholas, posteriormente reduzido para sessenta dias).

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 217, vol. V. Referindo-se às experiências estrangeiras, observa Barbosa Moreira que “os prazos costumam ser pequenos: um mês no direito alemão e no austríaco, dois no português e no francês, três no espanhol. Algumas legislações fixam, ademais, um prazo máximo, que não pode ser excedido em caso algum, de modo que, uma vez esgotado, a sentença já não comportará impugnação, embora ainda em curso qualquer dos prazos menores; esse prazo máximo – que é de cinco anos em Portugal (Código de Processo Civil, art. 772, 2ª alínea) e na Alemanha (ZPO, § 586, 2ª alínea, *fine*), e de dez anos na Áustria (ZPO, § 534, 3ª alínea) – é que começa a correr do trânsito em julgado em julgado da sentença”. A propósito, o CPC português de 2013, art. 697, limita-se a repetir o art. 772, indicado por Barbosa Moreira.

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 347,

298

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 352, tomo VI.

299

José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 218, vol. V; Alexandre Freitas Câmara, Ação Rescisória, cit., p. 169.

300

Essa interpretação é aquela *gramaticalmente* mais orientada pela súmula n. 401, STJ, e pelo art. 975, *caput*, CPC. É também a posição que adotamos em nosso Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, e em nosso Novo Curso de Processo Civil, 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, vol. II, ambos em parceria com Sérgio Cruz Arenhart, e que ora reformamos pelas razões que serão expostas adiante.

301

Essa interpretação é aquela *sistematicamente* mais orientada, sugerida por Pontes de Miranda, Tratado da Ação Rescisória, 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 353, e adotada, por exemplo, pelo STF, 1ª Turma, RE n. 666.589/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 25.03.2014, DJE 03.06.2014.

302

Nessa linha, Humberto Theodoro Júnior, “A Ação Rescisória no Novo Código de Processo Civil”, Revista Brasileira de Direito Processual. Belo Horizonte: Fórum, 2015, n. 90; Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, 13. Ed. Salvador: JusPodium, 2016, pp. 461/463, vol. III; José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 218, vol. V; Alexandre Freitas Câmara, Ação Rescisória, 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 176.

303

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Antecipatória, Julgamento Antecipado e Execução Imediata da Sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996; Id., Abuso de Defesa e Parte Incontroversa da Demanda. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

304

Sobre a igualdade no processo civil, Rafael Abreu, Igualdade e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

305

STJ, 1ª Turma, REsp n. 544.870/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 18.11.2004, DJ 06.12.2004, p. 201: “em

caso de inadmissibilidade ou intempestividade do recurso interposto, quando não constatado erro grosseiro ou má-fé do recorrente, considera-se mesmo assim que o prazo decadencial terá início após o seu julgamento”.

306

Assim, por exemplo, o art. 326 do *Codice di Procedura Civile* italiano, o § 586, 2, *Zivilprozessordnung* alemã (de onde o legislador provavelmente retirou o prazo máximo de cinco anos para a propositura da ação rescisória) e a *Rule 60 (c) (1)* das *Federal Rules of Civil Procedure* estadunidenses.

307

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, cit., pp. 138/139, vol. V.

308

No direito italiano, afirma Elio Fazzalari: “*documenti 'nuovi' non perché creati dopo la sentenza de qua, sibbene perché non esibiti nel precedente processo*” (Elio Fazzalari, “Revocazione (Diritto Processuale Civile)”, *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1989, item 6, v. XL). No mesmo sentido Carpi, Colesanti e Taruffo: “Il documento, e non solo il fatto documentato, *deve preesistere alla lite*” (F. Carpi, V. Colesanti e M. Taruffo, *Commentario Breve al Codice di Procedura Civile*, cit., p. 598).

309

Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, *Curso de Direito Processual Civil*, 13. Ed. Salvador: JusPodium, 2016, p. 464, vol. III.

310

Por todos, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, *Curso de Direito Processual Civil*, 14. Ed. Salvador: JusPodium, 2016, pp. 464/465, vol. III.

86

Idem, p. 67.

143

De acordo com Guastini, “l’operazione intellettuale che conduce dall’enunciato al significato – o, se si preferisce, l’operazione di identificazione del significato – altro non è che l’interpretazione. La disposizione è dunque l’oggetto dell’interpretazione, la norma è il suo risultato. O, detto altrimenti, ‘la disposizione è fonte della norma attraverso l’interpretazione’”. (Riccardo Guastini, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 63-64).

Índice Alfabético-remissivo

Alteração da Tese Jurídica

–Vide Superação

Ampliação do Julgamento

–Hipóteses, **Art. 942**, 1, 2 e 3

–Não se Aplica, **Art. 942**, 4

–Prosseguimento, **Art. 942**, 5

Arguição de Inconstitucionalidade

–Incidente, **Arts. 948 a 950**

Assunção de Competência

–Incidente, **Art. 947**, 1 a 8

Casos Repetitivos

–Julgamento, **Art. 928**, 1

–Jurisprudência Vinculante, **Art. 927**, 2.3

–Precedentes, **Art. 927**, 2.2

–Questões Processuais e Questões Materiais, **Art. 928**, 2

Coerência

–Conceito, **Art. 926**, 8

Coisa Julgada

–Proteção contra a Indevida Irretroatividade do Precedente, **Art. 927**, 6.2.3

Colaboração

–Dever de Prevenção, Primazia do Mérito e Cortes de Justiça, **Art. 932**, 4

–Dever de Prevenção, Primazia do Mérito e Cortes Supremas, **Art. 932**, 4; **Art. 1.029**, 8

Concessão de *Exequatur*

–Eficácia, **Art. 961**, 1

–Limite da Cognição, **Art. 960, 1; Art. 963, 2**

–Procedimento, **Art. 963, 3**

–Requisitos, **Art. 963, 2**

Confiança Legítima

–Superação para Frente, **Art. 927, 6.2.2**

Conflito de Atribuições

–Conceito, **Art. 959, 1**

Conflito de Competência

–Conceito, **Art. 951, 1**

–Conflito Interno, **Art. 958, 1**

–Incidente, **Arts. 951 a 959**

–Legitimidade, **Art. 951, 2 e 3; Art. 952, 1 e 2**

–Procedimento, **Arts. 953 a 957**

Controle de Constitucionalidade

–Controle Concreto, Incidental e Difuso, **Liv. III, Tít. I, Cap. IV, 1**

–Incidente, **Arts. 948 a 950**

–Precedente, **Art. 927, 2.1**

Cortes

–Cortes de Controle, **Art. 926, 1, 3.1**

–Cortes de Interpretação, **Art. 926, 1, 3.2**

–Cortes de Justiça, **Art. 926, 1, 3.1**

–Cortes de Precedentes, **Art. 926, 1, 3.2**

–Cortes Supremas, **Art. 926, 1, 3.2**

–Cortes de Uniformização de Jurisprudência, **Art. 926, 1, 3.1**

–STF, STJ e TST como Cortes Supremas, **Art. 926, 1, 3.2 e 3.3**

–TJ, TRF e TRT como Cortes de Justiça, **Art. 926, 1, 3.1 e 3.3**

Decisão Colegiada

–Julgamento, **Art. 941, 2**

Decisão Plural

–Julgamento, **Art. 941, 2**

Decisão-Surpresa

–Vedação à Decisão-Surpresa e Dever de Dialogar, **Art. 931, 2; Art. 933, 1**

Distinções (*Distinguishing*)

–Conceito, **Art. 927, 5**

–Função de Correção na Aplicação e de Desenvolvimento do Direito, **Art. 927, 5**

Fato Superveniente

–Consideração, **Art. 933, 1 e 2**

–Vedação à Decisão-Surpresa e Dever de Dialogar, **Art. 933, 2**

Homologação de Sentença Estrangeira

–Conceito, **Art. 960, 1**

–Cumprimento, **Art. 965, 1**

–Direito, **Art. 960, 2**

–Eficácia da Sentença Estrangeira, **Art. 961, 1 a 5**

–Homologação Parcial, **Art. 961, 2**

–Limite da Cognição, **Art. 960, 1; Art. 963, 1**

–Procedimento, **Art. 963, 3**

–Requisitos, **Art. 963, 1**

–Tutela da Evidência, **Art. 962, 4**

–Tutela de Urgência, **Art. 962, 1, 2 e 3**

–Vedação, **Art. 964, 1**

Integridade

–Conceito, **Art. 926, 8**

Julgamento

–Alteração do Voto, **Art. 941, 3**

–Ampliação, **Art. 942, 1 a 5**

–Conceito, **Art. 941, 1**

–Decisão Colegiada, **Art. 941, 2**

–Decisão Plural, **Art. 941, 2**

–Etapas, **Art. 937, 1**

–Juízes Vencidos, **Art. 939, 2**

–Métodos, **Art. 941, 2**

–Não Surpresa, **Art. 937, 4**

- Ordem, **Art. 936, 1; Art. 946, 1**
- Pauta, **Art. 935, 1 a 3**
- Preliminares, **Art. 938, 1 e 2**
- Principal, **Art. 939, 1**
- Publicidade, **Art. 934, 1; Art. 943, 3; Art. 944, 1**
- Substituição por Notas, **Art. 944, 1**
- Suporte, **Art. 943, 1**
- Vícios Sanáveis, **Art. 938, 3**
- Vista, **Art. 940, 1**
- Voto Vencido, **Art. 941, 4**

Jurisprudência

- Conceito, **Art. 926, 1, 4; Art. 927, 2**
- Dever de Considerar, Dever de Interpretar, Dever de Aplicar, **Art. 926, 7; Art. 927, 1**
- Jurisprudência Vinculante, **Art. 927, 2.3**

Modulação dos Efeitos

- Vide Superação

Obiter Dictum

- Conceito, **Art. 927, 4.2 a 4.2.2**
- Obiter Dictum* no *Common Law*, **Art. 927, 4.2.1**
- Obiter Dictum* no Direito Brasileiro, **Art. 927, 4.2.2**

Overruling

- Vide Superação

Ratio Decidendi

- Vide Precedente

Poderes do Relator

- Hipóteses, **Art. 932, 1 a 5**

Precedente

- Adequação do Procedimento, **Art. 927, 3**
- Conceito, **Art. 926, 1, 4; Art. 927, 2 e 2.2**
- Controle de Constitucionalidade, **Art. 927, 2.1**
- Dever de Considerar, Dever de Interpretar, Dever de Aplicar, **Art. 926, 7; Art. 927, 1**

- Igualdade, **Art. 926, 2**
- Liberdade, **Art. 926, 2**
- Publicidade, **Art. 927, 7**
- Ratio Decidendi*, **Art. 927, 4.1 a 4.1.5**
- Ratio Decidendi* no *Common Law*, **Art. 927, 4.1.1, 4.1.2**
- Ratio Decidendi* no Direito Brasileiro, **Art. 927, 4.1.3 a 4.1.5**
- Razões, **Art. 927, 4**
- Segurança Jurídica, **Art. 926, 2**

Prevenção

- Distribuição, **Art. 929, 1**
- Protocolo, **Art. 930, 1 e 2**

Sistemática da Matéria

- Opção do Código de 2015, **Liv. III, 1**

Stare Decisis

- Conceito, **Art. 926, 6**

Súmula

- Conceito, **Art. 926, 5; Art. 927, 2.4**

Superação (*Overruling*)

- Alteração da Tese Jurídica, **Art. 927, 6.2**
- Conceito, **Art. 927, 6**
- Espécies de Superação, **Art. 927, 6.1.2**
- Proteção da Confiança Legítima, **Art. 927, 6.2.2**
- Requisitos, **Art. 927, 6.2.1**

Sustentação Oral

- Direito, **Art. 937, 2**
- Feitos que Admitem, **Art. 937, 3**

Tribunais

- Vide Cortes

Tutela dos Direitos

- Decisão Justa e Unidade do Direito, **Liv. III, 2; Art. 926, 1**
- Ordem dos Processos nos Tribunais, **Liv. III, 2**

Unidade do Direito

–Hierarquia e Coerência, **Art. 926, 8**

© desta edição [2018]

Referências Bibliográficas

AARNIO, Aulis. *The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987.

ABBUD, André. *Homologação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras*. São Paulo: Atlas, 2008.

ALEXY, Robert. *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

_____. *Theorie der juristischen Argumentation*. Frankfurt im Main: Suhrkamp, 1983.

_____. *Teoria da argumentação jurídica*. São Paulo: Landy, 2001.

ALLEN, Ronald; PARDO, Michael. *The myth of the law-fact distinction*, Northwestern University Law Review, 2003.

ALONSO GARCÍA, Enrique. *La interpretación de la constitución*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984.

ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. *O Juiz e o Princípio do Contraditório*, Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 1993. n. 71.

_____. *A Garantia do Contraditório. Do Formalismo no Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. *Do Formalismo no Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____; MITIDIERO, Daniel. *Curso de Processo Civil*. São Paulo: Atlas, 2012. v. II.

AMARAL, Guilherme Rizzo. *Comentários às Alterações do Novo CPC*. São Paulo: Ed. RT, 2015. ANDRIOLI, Virgilio. *Commento al codice di procedura civile*. Napoli: Jovene, 1964. v. 1.

ANSANELLI, Vincenzo; DONDI, Angelo; COMOGLIO, Paolo. *Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata*. Milano: Giuffrè, 2015.

APRIGLIANO, Ricardo. *Ordem Pública e Processo*. São Paulo: Atlas, 2011.

_____. *A Apelação e seus Efeitos*. São Paulo: Atlas, 2003.

ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. *A Correição Parcial*. Curitiba, 1958.

ARENHART, Sérgio Cruz. *A Tutela Coletiva de Interesses Individuais*. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____. *O Recurso de Terceiro Prejudicado e as Decisões Vinculantes*. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; NERY JUNIOR, Nelson (coords.). *Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins*. São Paulo: Ed. RT, 2007. v. XI.

_____; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. I.

- ____; ____; _____. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. II.
- ____; ____; _____. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- ASCARELLI, Tulio. *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*. Rivista de diritto processuale. Padova: Cedam, 1957.
- ASSIS, Araken de. *Manual dos Recursos*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- _____. *Manual dos Recursos*, 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- ATIYAH, P. S.; SUMMERS, Robert. *Form and Substance in Anglo-American Law*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- ÁVILA, Ana Paula. *A Modulação dos Efeitos Temporais pelo STF no Controle Concentrado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- ÁVILA, Humberto. *Teoria dos Princípios* (2003). 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- _____. *Segurança Jurídica*. São Paulo: Malheiros, 2011.
- _____. *Teoria da igualdade tributária*. São Paulo: Malheiros, 2008.
- AZEVEDO, Luiz Carlos de. *Origem e Introdução da Apelação no Direito Lusitano*. São Paulo: FIEO, 1976.
- ____; CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Lições de História do Processo Civil Romano*. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- ____; _____. *Lições de História do Processo Civil Lusitano*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- BAHIA, Alexandre; NUNES, Dierle; PEDRON, Flávio; THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Novo CPC – Fundamentos e Sistematização*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- BAPTISTA, Sônia Márcia Hase de Almeida. *Dos Embargos de Declaração*. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. v. I.
- _____. *Curso de Processo Civil*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000. v. I.
- _____. *Processo e Ideologia – O Paradigma Racionalista*. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários ao Código de Processo Civil* (1974). 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. V.
- _____. *Questões Prejudiciais e Questões Preliminares*. Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.
- _____. *Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material*. Relativização da coisa julgada. Salvador: JusPodivm, 2008.
- BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. *Precedentes Judiciais e Segurança Jurídica*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- BARIONI, Rodrigo. *Ação rescisória e recursos para os Tribunais Superiores*. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____. *Efeito Devolutivo da Apelação Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2007.

- _____. Preclusão Diferida, o Fim do Agravo Retido e a Ampliação do Objeto da Apelação no Novo Código de Processo Civil, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2015. n. 243.
- BARSOTTI, Vittoria. *L'Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti*. Torino: Giappichelli, 1999.
- BARZOTTO, Luís Fernando. *O Positivismo Jurídico Contemporâneo – uma Introdução a Kelsen, Ross e Hart* (1999). 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Efetividade do Processo e Técnica Processual*. São Paulo: Malheiros, 2006.
- BENDITT, Theodore. *The Rule of Precedent*. In: GOLDSTEIN, Laurence (coord.). *Precedent in Law*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- BENNETT, Robert. *Judicial Review in the United States*. *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*. Nápoles: Edizione Scientifiche Italiane, 2011.
- BENTHAM, Jeremy. *Rationale of judicial evidence*. London: Hunt and Clarke, 1827.
- BERALDO, Leonardo de Faria. *A flexibilização da coisa julgada que viola a Constituição. Coisa julgada inconstitucional*. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.
- BERMUDES, Sérgio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1977. v. VII.
- BIX, Brian. *A Dictionary of Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- BOBBIO, Norberto. *Teoria Generale del Diritto* (1957 – 1958). Torino: Giappichelli, 1993.
- _____. *Il Positivismo Giuridico* (1960-1961) (1979). 2. ed. Torino: Giappichelli, 1996.
- _____. *Lições de Filosofia do Direito*. Trad. Márcio Pugliese, Edson Bini e Carlos Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.
- BONDIOLI, Luís Guilherme Aidar. *Embargos de Declaração*. São Paulo: Saraiva, 2005.
- BOVE, Mauro. *Il Sindacato della Corte di Cassazione – Contenuto e Limiti*. Milano: Giuffrè, 1993.
- BRAGA, Paula Sarno; DIDIER JÚNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. *Curso de Direito Processual Civil* (2007). 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. II.
- BRAGHITTONI, R. Ives. *Recurso Extraordinário*. São Paulo: Atlas, 2007.
- BRENNER, Saul. *Granting Certiorari by the United States Supreme Court: An Overview of the Social Science Studies*. *Law Library Journal*. v. 92. n. 2. Chicago, 2000.
- BUENO, Cássio Scarpinella. *Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro – Um Terceiro Enigmático*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. *Bustamante, Teoria do Precedente Judicial – A Justificação e a Aplicação de Regras Jurisprudenciais*. São Paulo: Noeses, 2012.
- BUZAID, Alfredo. *Do Agravo de Petição no Sistema do Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1956.
- CABRAL, Antonio do Passo. *Nulidades no Processo Moderno*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- _____. *O Novo Procedimento-Modelo (Musterverfahren) Alemão: uma Alternativa às Ações Coletivas*. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2007. n. 147.

- _____. Il Principio del Contraddittorio come Diritto d'Influenza e Dovere di Dibattito, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 2005.
- CADIET, Loïc. Le rôle institutionnel et politique de la cour de cassation en France: tradition, transition, mutation? *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.
- _____; JEULAND, Emmanuel. *Droit Judiciaire Privé* (1992). 8. ed. Paris: LexisNexis, 2013.
- _____; NORMAND, Jacques; MEKKI, Soraya Amrani. *Théorie Générale du Procès*. Paris: PUF, 2010.
- CALABRESI, Guido. *A Common Law for the Age of Statutes*. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- CALAMANDREI, Piero. La Cassazione Civile. In: CAPPELLETTI, Mauro (org.). *Opere Giuridiche*. Napoli: Morano Editore, 1976. v. VII.
- _____. Sopravvivenza della Querela Nullitatis nel Processo Civile Vigente, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1951.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015.
- _____. *Ação Rescisória*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- CAMINKER, Evan H. Sincere and Strategic Voting Norms on Multimember Courts. *Michigan Law Review*. v. 67. 1999.
- CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*. Coimbra: Almedina, 2002.
- CAPONI, Remo. L'Appello nel Sistema delle Impugnazioni Civili (Note di Comparazione Anglo-Tedesca), *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 2009.
- _____. La Riforma dei Mezzi di Impugnazione, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2012.
- _____. *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*. Milano: Giuffrè, 1991.
- CAPPELLETTI, Mauro. Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato. Milano: Giuffrè, 1968.
- _____. Il Processo Civile Italiano nel Quadro della Contrapposizione "Civil Law" – "Common Law" (Appunti Storico-comparativi), *Processo e Ideologie*. Bologna: Il Mulino, 1969.
- _____. *Processo, Ideologias e Sociedade*. Trad. Hermes Zaneti Júnior. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2010. v. II.
- CARDOZO, Benjamin. *The Nature of Judicial Process*. New Haven: Yale University Press, 1921.
- CARNELUTTI, Francesco. *Sistema del diritto processuale*. Padova: Cedam, 1936. v. I.
- _____. *La prova civile*. 2. ed. Roma: Atteneo, 1947.
- CARPI, Federico. *La provvisoria esecutorietà della sentenza*. Milano: Giuffrè, 1979.
- _____; COLESANTI, Vittorio; TARUFFO, Michele. *Commentario breve al Codice di Procedura Civile*. Padova: Cedam, 1988.
- CARRATA, Antonio. *Il Principio della non Contestazione nel Processo Civile*. Milano: Giuffrè,

1995.

CARRIÒ, Genaro. *Notas sobre Derecho e Language*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1979.

CARVALHO, Fabiano. *Ação Rescisória*. São Paulo: Saraiva, 2010.

CAVALLARI, Ciaccia. *La contestazione nel processo civile*. Milano: Giuffrè, 1993. v. 2.

CERINO-CANOVA, Augusto. *Impugnazioni Civili, Studi di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1992.

CHIASSONI, Pierluigi. *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007.

_____. *I Precedenti Civili sono Vinculanti? Considerazioni sull' art. 360-bis CPC, Diritti Umani, Sentenze Elusive, Clausole Ineffabili – Scritti di Realimo Militante*. Roma: Aracne, 2011.

_____. *The Philosophy of Precedent: Conceptual Analysis and Rational Reconstruction, On the Philosophy of Precedent*. Stuttgart: Franz Steiner, 2012.

_____. *Positivismo Giuridico – Una Investigazione Analitica*. Modena: Mucchi Editore, 2013.

_____. *Disposición y norma: una distinción revolucionaria. Disposición. vs norma*, Lima: Palestra, 2011.

CHINCOLI, Vanessa. *O Direito Fundamental ao Contraditório no Processo Civil. Conceito e Possíveis Aplicações*. In: MITIDIERO, Daniel (coord.). *O Processo Civil no Estado Constitucional*. Salvador: JusPodivm, 2012.

CHIOVENDA, Giuseppe. *Principii di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 1906.

_____. *Instituições de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1965. v. I.

_____. *Sulla cosa giudicata, Saggi di diritto processuale civile*. reimp. Milano: Giuffrè, 1993. v. II.

_____. *Lodovico Mortara. Rivista di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1937.

CLERMONT, Kevin. *Principles of Civil Procedure*. 3. ed. St. Paul: West, 2012.

COING, Helmut. *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1950). 5. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1993.

COLESANTI, Vittorio. *Sentenza civile (revocazione della)*. *Novissimo Digesto Italiano*, 1969. v. XVI.

_____; CARPI, Federico; TARUFFO, Michele. *Commentario breve al Codice di Procedura Civile*. Padova: Cedam, 1988.

COLLIA, Filippo. *L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro*, *Rivista di Diritto Processuale*. Milano: Giuffrè, 1994.

COMASTRI, Michele. *Giudizio di Cassazione e Poteri Ufficiosi in Ordine alle Questioni di Merito*. Torino: Giappichelli, 2012.

COMOGLIO, Luigi Paolo. *La Garanzia dell' Azione ed il Processo Civile*. Padova: Cedam, 1970.

_____. *Le Garanzie Fondamentali del “Giusto Processo”. Etica e Tecnica del “Giusto Processo”*. Torino: Giappichelli, 2004.

_____. *Note Riepilogative su Azione e Forme di Tutela, nell' Ottica della Domanda Giudiziale*, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1993.

- ____; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. Bologna: Il Mulino, 1995.
- COMOGLIO, Paolo; DONDI, Angelo; ANSANELLI, Vincenzo. Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata. Milano: Giuffrè, 2015.
- CORDRAY, Margareth; CORDRAY, Richard. The philosophy of Certiorari: jurisprudential considerations in Supreme Court case selection. Washington University Law Quarterly. v. 82. n. 2. Saint Louis, 2004.
- CORSALE, Massimo. Certeza del diritto e crisi di legittimità. Milano: Giuffrè, 1979.
- COSTA, Moacyr Lobo da. O Agravo no Direito Lusitano. Rio de Janeiro: Borsoi, 1974.
- COUTO, Mônica Bonetti. Recurso Adesivo – Um Exame à Luz da Teoria Geral dos Recursos. Curitiba: Juruá, 2007.
- COUTURE, Eduardo. Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil (1948). Estudios de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Ediar, 1948. t. I.
- ____. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1951.
- CRAMER, Ronaldo. Ação Rescisória por Violação da Norma Jurídica. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2012.
- CRISAFULLI, Vezio. Disposizione (e norma). Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1964.
- CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law (1961). 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- ____; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de História do Processo Civil Romano. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- ____; _____. Lições de História do Processo Civil Lusitano. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Atendibilidade dos Fatos Supervenientes no Processo Civil – Uma Análise Comparativa entre o Sistema Português e o Brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012.
- ____. Jurisdição e Competência (2008). 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- ____; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil (2006). 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. III.
- CURRIE, Brainerd. Mutuality of Collateral Estoppel: Limits of the Bernherd Doctrine. Stanford Law Review. v. 9. 1957.
- DALL´AGNOL JÚNIOR, Antônio. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2000. v. II.
- DANTAS, Bruno. Repercussão Geral. São Paulo: Ed. RT, 2008.
- DANTAS, Marcelo. Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2000.
- DAVIS, John F.; REYNOLDS, William J. Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court. Duke Law Journal. v. 59. 1974.
- DAVIS, R. A Re-examination of the Doctrine of MacPherson v. Buick and its Application and Extension in the State of New York. Fordham Law Review. 1955.

- DELANEY, Sarah K. *Stare decisis v. The “New Majority”: the Michigan Supreme Court’s Practice of Overruling Precedent, 1998-2002*. Albany Law Review. v. 66. 2003.
- DELGADO, José Augusto. *Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. Coisa julgada inconstitucional*. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.
- DEMOLOMBE, Charles. *Cours de Code Napoléon*. Paris: Lahure, 1880. v. I.
- DENTI, Vittorio. *La Giustizia Civile* (1989). 2. ed. Bologna: Il Mulino, 2004.
- _____. *Un progetto per la giustizia civile*. Bologna: Il Mulino, 1982.
- _____. *Questioni pregiudiziali*. Novissimo digesto italiano, v. 14.
- DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. *Fraude no processo civil*. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2001.
- DICIOTTI, Enrico. *Interpretazione della legge e discorso razionale*. Torino: Giappichelli, 1999.
- _____. *Verità e Certezza nell’ Interpretazione della Legge*. Torino: Giappichelli, 1999.
- DIDIER JÚNIOR, Fredie. *Pressupostos Processuais e Condições da Ação*. São Paulo: Saraiva, 2005.
- _____. *Recurso de Terceiro*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- _____. *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português*. Coimbra: Coimbra Editora, 2010.
- _____. *Curso de Direito Processual Civil* (2003). 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. I.
- _____. *O Direito de Ação como Complexo de Situações Jurídicas*, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2012. n. 210.
- _____. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- _____; CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Curso de Direito Processual Civil* (2006). 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. III.
- _____; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. *Curso de Direito Processual Civil* (2007). 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. II.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. v. I.
- _____. *Capítulos de sentença*. São Paulo: Malheiros, 2014.
- _____. *Relativizar a coisa julgada material. Coisa julgada inconstitucional*. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.
- DOMIT, Otávio. *Iura Novit Curia e Causa de Pedir – O Juiz e a Qualificação Jurídica dos Fatos no Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- DONDI, Angelo; ANSANELLI, Vincenzo; COMOGLIO, Paolo. *Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata*. Milano: Giuffrè, 2015.
- DUXBURY, Neil. *The Nature and Authority of Precedent*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- DWORKIN, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1977.

- _____. *A Matter of Principle*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1985.
- _____. *Law's Empire*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1986.
- _____. *Justice for Hedgehogs*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2011.
- _____. *Law as Interpretation*, *Texas Law Review*. v. 60.
- EISENBERG, Melvin. *The Nature of the Common Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- ESSER, Joseph. *Richterrecht, Gerichtsgebrauch und Gewohnheitsrecht*. In: ESSER, Josef; THIEME, Hans (coords.). *Festschrift für Fritz von Hippel zum 70 Geburtstag*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1967.
- FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. *A Ação Declaratória Incidental*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- FARIA, Juliana Cordeiro; THEODORO JÚNIOR, Humberto. *A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para o seu controle. Coisa julgada inconstitucional*. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.
- FARIA, Márcio Carvalho. *As Funções das Cortes Superiores, os Recursos Excepcionais e a Necessária Revisão dos Parâmetros Interpretativos em Relação à Lealdade Processual (Parte Um)*, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2015. n. 247.
- _____. *As Funções das Cortes Superiores, os Recursos Excepcionais e a Necessária Revisão dos Parâmetros Interpretativos em Relação à Lealdade Processual (Parte Dois)*, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2015. n. 248.
- FAZZALARI, Elio. *Revocazione (dir. proc. civ.)*. *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1989. v. XL.
- FEDERMAN, Howard. *Judicial Overruling. Time for a New General Rule*. *Michigan Bar Journal*, 2004.
- FENET, Pierre-Antoine. *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*. Paris: Videcoq, 1836. Tome Cinquième.
- FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. *Embargos de Declaração*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- FERRAND, Frédérique. *Cassation Française et Révision Allemande*. Paris: PUF, 1993.
- _____. In: GUINCHARD, Serge (coord.). *Droit Processuel – Droit Commum et Droit Comparé du Procès Équitable*. 4. ed. Paris: Dalloz, 2007.
- _____. *La Jurisdiction Judiciaire Suprême en Droit Comparé: Missions, Filtrage, Intensité du Contrôle*. In: DRAGO, Guillaume; FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte; GORÉ, Marie (coords.). *L'Accès au Juge de Cassation*. Paris: LGDJ, 2015.
- FERRARESE, Maria Rosaria. *Dal “verbo” legislativo a chi dice l’“ultima parola”: le Corti Costituzionali e la rete giudiziaria*. *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.
- FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. v. VII.
- FERREIRA NETO, Arthur Maria. *Metaética e a Fundamentação do Direito*. Porto Alegre: *Elegantia Juris*, 2015.

- FERRI, Corrado. *Profili dell' Appello Limitato*. Padova: Cedam, 1979.
- _____; COMOGLIO, Luigi Paolo; TARUFFO, Michele. *Lezioni sul processo civile*. Bologna: Il Mulino, 1995.
- FISS, Owen. The political theory of the class action. *Washington and Lee Law Review*. v. 53. 1996.
- FRANCIS, Joseph. Three Cases on Possession – Some Further Observations. *St. Louis Law Review*. 1928, n. 14.
- FREEDMAN, Warren. *Res Judicata and Collateral Estoppel*. Westport: Quorum, 1988.
- FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- GARCÍA PASCUAL, Cristina; VIDAL GIL, Ernesto. *Creación Judicial del Derecho. Sentido y razón del derecho – enfoques socio-jurídicos para la sociedad democrática*. Madrid: Hacer Editorial, 1992.
- GERHARDT, Michael. *The Power of Precedent*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- GINSBURG, Tom. *Judicial review in new democracies: constitutional courts in Asian cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- GLOW, Lisa. Offensive Collateral Estoppel in Arizona: Fair Litigation v. Judicial Economy. *Arizona Law Review*. v. 30. 1988.
- GOLDMAN, Brian. Should the Supreme Court stop inviting amici curiae to defend abandoned lower court decisions? *Stanford Law Review*. v. 63. 2011.
- GOLDSCHMIDT, James. *Der Prozess als Rechtslage*. Berlin: Springer, 1925.
- GOODHART, Arthur. Determining the Ratio Decidendi of a Case. *Essays in Jurisprudence and the Common Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1931.
- _____. Three Cases on Possession, *The Cambridge Law Journal*. 1928, n. 3. _____. Precedent in English and Continental Law. *Law Quaterly Review*. v. 50. 1934.
- GORLA, Gino. *Diritto Comparato e Diritto Comune Europeo*. Milano: Giuffrè, 1981.
- _____. *L' Interpretazione del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1941.
- GOTTWALD, Peter; SCHWAB, Karl Heinz. *Verfassung und Zivilprozeß*. Bielefeld: Giesecking, 1984.
- _____; ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz. *Zivilprozessrecht*. 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.
- GRECO, Leonardo. *Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. Relativização da coisa julgada*. Salvador, JusPodivm, 2008.
- GRIMM, Dieter. *Human rights and judicial review in Germany*. Human rights and judicial review. London: Springer, 1994.
- GUASTINI, Riccardo. *Teoria e Dogmatica delle Fonti*. Milano: Giuffrè, 1998.
- _____. *Teoria del Diritto – Approccio Metodologico*. Modena: Mucchi Editore, 2002.

- _____. Interpretare e Argomentare. Milano: Giuffrè, 2011.
- _____. A interpretação: objetos, conceitos, teorias. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- _____. Trama aberta – Ciência Jurídica, Interpretação. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- _____. Disposizione vs. norma. Giurisprudenza costituzionale. 1989.
- _____. Se i giudici creino diritto. Istituzioni e dinamiche del diritto. Milano: Giuffrè, 2009.
- HART, Herbert. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- HARTNETT, Edward. Questioning Certiorari: some reflections seventy-five years after the judges' bill. Columbia Law Review. v. 100. n. 7. New York, nov. 2010.
- HAZARD JR., Geoffrey. Preclusion as to issues of law: the legal system's interest. Iowa Law Review, 1984.
- _____; JAMES JR., Fleming; LEUBSDORF, John. Civil Procedure, Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1992.
- HEINITZ, Ernesto. I Limiti Oggettivi della Cosa Giudicata. Padova: Cedam, 1937.
- HERSHKOFF, Helen. Aggregation of parties, claims, and actions. In: CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen (coords.). Civil litigation in comparative context. New York: Thomson/West, 2007. HOCHSCHILD, Adam. The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation in Historical Perspective. Washington University Journal of Law & Policy. v. 4.
- HOLMES JUNIOR, Oliver Wendell. The Common Law (1881). Cambridge: Harvard University Press, 1963.
- IMPAGNATTIELO, Gianpaolo. La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. 1992.
- _____. La Provvisoria Esecuzione e l'Inibitoria nel Processo Civile. Milano: Giuffrè, 2010.
- JAMES JR., Fleming; HAZARD JR., Geoffrey; LEUBSDORF, John. Civil Procedure. Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1992.
- JEULAND, Emmanuel; CADIET, Loïc. Droit Judiciaire Privé (1992). 8. ed. Paris: LexisNexis, 2013.
- JOBIM, Marco Félix. A Técnica do Distinguishing a Partir da Análise do Julgamento do Caso Escola vs. Coca-Cola Bottling Co., Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2014. n. 237.
- JOLOWICZ, J. A. The Role of the Supreme Court at the National and International Level. In: YESSIOU-FALTSI, Pelayia (coord.). The Role of the Supreme Courts at the National and International Level – Reports for the Thessaloniki International Colloquium. Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 1998.
- JORGE, Flávio Cheim. Apelação Cível. São Paulo: Ed. RT, 1998.
- JORI, Mario; PINTORE, Anna. Manuale di teoria generale del diritto. Torino: Giappichelli, 1995.
- KARLAN, P.; TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; SEIDMAN, P.; STONE, G. Constitutional law. 5. ed. New York: Aspen, 2005.
- KAUFMANN, Arthur. Rechtsphilosophie (1994). 2. ed. München: C. H. Beck, 1997.

- KELSEN, Hans. *Reine Rechtslehre* (1. ed., 2. ed., 1960). 2. ed. Wien: Österreich, 2000.
- _____. *Jurisdição constitucional*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- KEMMERICH, Clóvis. *O Direito Processual da Idade Média*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2006.
- KERN, Christoph. *The Role of the Supreme Court*, *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2014. n. 228.
- KNIFFIN, Margaret. *Overruling Supreme Courts Precedents: Anticipatory Action by United States Courts of Appeals*, *Fordham Law Review*. 1982.
- KNIJNIK, Danilo. *O Recurso Especial e a Revisão da Questão de Fato pelo Superior Tribunal de Justiça*. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- KORNHAUSER, Lewis; SAGER, Lawrence. *The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts*. *California Law Review*. v. 81. 1993.
- _____. _____. *The many as one: integrity and group choice in paradoxical cases*. *Philosophy & Public Affairs*. v. 32. 2004.
- KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. *Embargos de Declaração – Teoria Geral e Efeitos Infringentes*. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- KRIELE, Martin. *Theorie der Rechtsgewinnung entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation*. Berlin: Duncker & Humblot, 1967.
- KRISLOV, Samuel. *The amicus curiae brief. From friendship to advocacy*. *Yale Law Journal*. Vol. 72. 1963.
- LACERDA, Galeno. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. v. VIII, t. I.
- LANES, Júlio. *Fato e Direito no Processo Civil Cooperativo*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- LEAL, Victor Nunes. *Passado e Futuro da Súmula do STF*. *Revista de Direito Administrativo*. n. 145. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1981.
- LEDERMAN, Howard Yale. *Judicial overruling*. *Michigan Bar Journal*. v. 83. 2004.
- LEUBSDORF, John; JAMES JR., Fleming; HAZARD JR., Geoffrey. *Civil Procedure*. Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1992.
- LIEBMAN, Enrico Tullio. *Parte o ‘capo’ di sentenza*. *Rivista di diritto processuale*. Padova: Cedam, 1964.
- _____. *Limites objetivos da coisa julgada*. *Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 1947.
- _____. *Manual de Direito Processual Civil*. Trad. Cândido Rangel Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984. v. I.
- LOWMAN, Michael. *The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?* *The American University Law Review*. vol. 41. 1992.

LUCERTINI, Elena. La Riforma dell' Appello Civile in Germania: il Declino del Giudizio "de Novo". *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2006.

LUCON, Paulo. *Eficácia das Decisões e Execução Provisória*. São Paulo: Ed. RT, 2000.

MACCORMICK, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory* (1978). Oxford: Oxford University Press, 2003.

_____. *Why Cases Have Rationes and What These Are*. *Precedent in Law*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

_____. *The ethics of legalism*. *Ratio Juris*. 1989. vol. 2.

_____. *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

_____; SUMMERS, Robert. *Interpreting Precedents – A Comparative Study*. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997.

MACÊDO, Lucas Buril de. *Precedentes Judiciais e o Direito Processual Civil*. Salvador: JusPodivm, 2015.

MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. *Do Xadrez à Cortesia – Dworkin e a Teoria do Direito Contemporânea*. São Paulo: Saraiva, 2013.

MACHADO, Fábio Cardoso. *Por que realmente os precedentes importam?*. In: MACEDO, Elaine; HIDALGO, Daniela (coords.). *Jurisdição, Direito Material e Processo – Os Pilares da Obra Ovidiana e seus Reflexos na Aplicação do Direito*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Recurso Extraordinário e Recurso Especial*. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 1999.

MANDRIOLI, Crisanto. *L'azione esecutiva*, Milano: Giuffrè, 1955.

MARANHÃO, Juliano. *Positivismo Jurídico Lógico-Inclusivo*. São Paulo: Marcial Pons, 2012.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela Antecipatória, Julgamento Antecipado e Execução Imediata da Sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1997.

_____. *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

_____. *Antecipação da Tutela*. 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

_____. *Precedentes Obrigatórios* (2010). 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

_____. *O STJ enquanto Corte de Precedentes* (2013). 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

_____. *A Ética dos Precedentes*. São Paulo: Ed. RT, 2014.

_____. *Julgamento nas Cortes Supremas*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. *A Intangibilidade da Coisa Julgada diante da Decisão de Inconstitucionalidade* (2008). 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

_____. *Abuso de Defesa e Parte Incontroversa da Demanda*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2007.

_____. *O "problema" do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos*. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. 249.

_____; MITIDIERO, Daniel. *Código de Processo Civil Comentado*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____; _____. *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

- ____; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. I.
- ____; ____; _____. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. II.
- ____; ____; _____. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- ____; MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo. Curso de Direito Constitucional (2012). 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- MARKMAN, Stephen. Precedent: Tension between Continuity in the Law and the Perpetuation of Wrong Decisions, Texas Review of Law and Politics. 2004.
- MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- MATTOS, Sérgio. Devido Processo Legal e Proteção de Direitos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica Ed., 1999.
- MEDINA, José Miguel Garcia. O Prequestionamento nos Recursos Extraordinário e Especial. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- MELLO, Cláudio. Verdade Moral e Método Jurídico na Teoria Constitucional de Ronald Dworkin. In: LISBOA, Wladimir; STORCK, Alfredo (coords.). Normatividade & Argumentação – Ensaios de Filosofia Política e do Direito. Porto Alegre: Linus Editores, 2013.
- MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- MEKKI, Soraya Amrani; CADIET, Loïc; NORMAND, Jacques. Théorie Générale du Procès. Paris: PUF, 2010.
- MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile. Milano: Giuffrè, 1987.
- MENDES, Leonardo Castanho. O Recurso Especial. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- MENDONÇA JÚNIOR, Delosmar Domingos de. Agravo Interno. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- MENESTRINA, Francesco. La Pregiudiciale nel Processo Civile. Milano: Giuffrè, 1963.
- MERKL, Adolf. Sul Problema dell' Interpretazione (1916). Il Duplice Volto del Diritto – Il Sistema Kelseniano e altri Saggi. Trad. Carmelo Geraci. Milano: Giuffrè, 1987.
- MERRYMAN, John Henry. The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- MESSUTI, G. Silenzio della parte e dolo revocatorio. Rivista di diritto processuale. Padova: Cedam, 1984.
- MICHELMAN, Frank. Justification (and justifiability) of law in a contradictory world. Nomos XXVIII: Justification. v. 71. New York: New York University Press, 1986.
- MICHELON JÚNIOR, Cláudio. Aceitação e Objetividade – Uma Comparação entre as Teses de Hart e do Positivismo Jurídico Precedente sobre a Linguagem e o Conhecimento do Direito. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- ____. Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica. In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (coords.). Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições. São Paulo: Saraiva, 2011.

MILLAR, Robert Wyness. The historical relation of estoppel by record to res judicata. Illinois Law Review. 1940-1941.

MITIDIERO, Daniel. Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos (2009). 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente (2013). 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

_____. Antecipação da Tutela – da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória (2012). 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

_____. Precedentes – da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Ed. RT, 2016.

_____. O Processualismo e a Formação do Código Buzaid, Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2010. n. 183.

_____. Fundamentação e Precedente – Dois Discursos a Partir da Decisão Judicial, Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2012, n. 206.

_____. Por uma Reforma da Justiça Civil no Brasil: um Diálogo entre Mauro Cappelletti, Vittorio Denti, Ovídio Baptista e Luiz Guilherme Marinoni, Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2011. n. 199.

_____. A Tutela dos Direitos como Fim do Processo Civil no Estado Constitucional, Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2014. n. 229.

_____; ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Curso de Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2012. v. II.

_____; MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

_____; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. I.

_____; _____. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. II.

_____; _____. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____; _____. SARLET, Ingo. Curso de Direito Constitucional (2012). 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

MONTESANO, Luigi. Norma e formula legislativa nel giudizio costituzionale. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1958.

MONTROSE, J. L. Ratio decidendi and the House of Lords. The Modern Law Review. v. 20. 1957.

_____. The ratio decidendi of a case. The Modern Law Review. v. 20. 1957.

MORATO, Leonardo. Reclamação e sua Aplicação para o Respeito da Súmula Vinculante. São Paulo: Ed. RT, 2007.

MORTARA, Lodovico. Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile. Milano: Vallardi, 1923.

_____. Manuale della procedura civile. Torino: Torinese, 1921.

MÜLLER, Julio Guilherme. O Papel Fundamental do Superior Tribunal de Justiça no Contexto

do Estado Democrático de Direito: Reflexões a Partir do Interesse Público de Uniformização da Interpretação da Legislação Infraconstitucional. Revista de Processo. n. 238. São Paulo: Ed. RT, 2014.

MÜßIG, Ulrike. El Juez Legal – Una Comparación Histórica, desde el Derecho Canónico hasta la Convención Europea de los Derechos Humanos, con Especial Énfasis en el Desarrollo del Derecho en Alemania, Inglaterra y Francia (2003). Trad. Anne Cullmann, Ignacio Czeguhn e Antonio Sánchez Aranda. Madrid: Dykinson, 2014.

NELSON, Caleb. Stare Decisis and Demonstrably Erroneous Precedents, Virginia Law Review. n. 87. 2001.

NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015.

NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

____; NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015.

NEVES, Antonio Castanheira. O Instituto dos “Assentos” e a Função Jurídica dos Supremos Tribunais. Coimbra: Coimbra Editora, 1983.

NICOLETTI, Carlos Alberto. La revocazione della sentenza. Milano: Giuffrè, 1988.

NONKES, Steven. Reducing the unfair effects of nonmutual issue preclusion through damages limits. Cornell Law Review. v. 94. 2009.

NORMAND, Jacques; CADIET, Loïc; MEKKI, Soraya Amrani. Théorie Générale du Procès. Paris: PUF, 2010.

NORONHA, Carlos Silveira. Do Recurso Adesivo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

____. Do Agravo de Instrumento. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

NOVAK, Linda. The precedential value of Supreme Court plurality decisions. Columbia Law Review. 1980.

NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. RT, 2009.

____. Recurso Especial. São Paulo: Ed. RT, 2002.

OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Agravo Interno e Agravo Regimental. São Paulo: Ed. RT, 2014.

OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil (2007). 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. II.

ORESTANO, Riccardo. L´ Appello Civile in Diritto Romano. 2. ed. Torino: Giappichelli, 1953.

OTEIZA, Eduardo. La Función de las Cortes Supremas en la América Latina – Historia, Paradigmas, Modelos, Contradicciones y Perspectivas. In: ____ (coord.). Reforma Procesal Civil. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores, 2010.

PACHECO, José da Silva. A “Reclamação” no STF e no STJ de acordo com a Nova Constituição. Revista dos Tribunais. São Paulo: Ed. RT, 1989. v. 646.

- PANTOJA, Fernanda. *Apelação Cível: Novas Perspectivas de um Antigo Recurso – Um Estudo Crítico de Direito Nacional e Comparado*. Curitiba: Juruá, 2010.
- PARDO, Michael; ALLEN, Ronald. The myth of the law-fact distinction. *Northwestern University Law Review*. 2003.
- PATTI, Salvatore. *Prove-Disposizioni generali. Commentario del Codice Civile*. Bologna/Roma: Zanichelli/Foro Italiano, 1987.
- PECZENIK, Aleksander. The Binding Force of Precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert (coords.). *Interpreting Precedents – A Comparative Study*. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997.
- _____. *On Law and Reason* (1989). 2. ed. Dordrecht: Springer, 2009.
- PEDRO, Flávio; BAHIA, Alexandre; NUNES, Dierle; THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Novo CPC – Fundamentos e Sistematização*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. *O Recurso de Agravo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
- PEREA, Ashley. Broad discretion: a choice in applying offensive non-mutual collateral estoppel. *Arizona State Law Journal*. v. 40. 2008.
- PEREIRA, Paula Pessoa. *Legitimidade dos Precedentes – Universabilidade das Decisões do STJ*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- PERELMAN, Chaïm. *Lógica jurídica: nova retórica*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- PEREZ, Marcela Melo. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAEMER, Ronaldo (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- PICARDI, Nicola. *La Vocazione del Nostro Tempo per la Giurisdizione*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2004.
- PINO, Giorgio. *Diritti e Interpretazione – Il Ragionamento Giuridico nello Stato Costituzionale*. Bologna: Il Mulino, 2010.
- PINTORE, Anna; JORI, Mario. *Manuale di teoria generale del diritto*. Torino: Giappichelli, 1995.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários ao Código de Processo Civil* (1975). 3. ed. Atualizada por Sérgio Bermudes. Rio de Janeiro: Forense, 1999. t. VII.
- _____. *Tratado da ação rescisória*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976.
- PORTES, Maira. Instrumentos para Revogação de Precedentes no Sistema de Common Law. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *A Força dos Precedentes – Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito Processual Civil da UFPR*. Salvador: JusPodivm, 2010.
- PORTO, Sérgio. *Ação Rescisória Atípica*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- _____; USTÁRROZ, Daniel. *Manual dos Recursos Cíveis*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- POSTEMA, Gerald. *Legal Philosophy in the Twentieth Century: the Common Law World*. Dordrecht: Springer, 2011.
- POZZA, Pedro. *Sentença Parcial de Mérito*. Curitiba: Juruá, 2015.
- PROTO PISANI, Andrea. *Lezioni di Diritto Processuale Civile*. 4. ed. Napoli: Jovene Editore, 2002.

- PUGLIESE, Giovanni. Giudicato. Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1969. v. XVIII.
- QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais (teoria geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002.
- RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: Saraiva, 2010.
- RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitoria. Padova: Cedam, 1987.
- RASSELLI, Alessandro. Sentenze determinative e classificazione delle sentenze. Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti. Padova: Cedam, 1950. v. 2.
- REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito (1973). 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- RÊGO, Bruno de Moraes. Ação rescisória e a retroatividade das decisões de controle de constitucionalidade das leis no Brasil. Porto Alegre: Fabris, 2001.
- REYNOLDS, William J.; DAVIS, John F. Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court. Duke Law Journal. v. 59. 1974.
- RICHARDSON, Eli. Taking issue with preclusion: reinventing Collateral Estoppel. Mississippi Law Journal. v. 65. 1995.
- RIMMELSPACHER, Bruno. Materiellrechtlicher Anspruch und Streitgegenstandsprobleme im Zivilprozess. München: Beck, 1970.
- RIZZI, Sergio. Ação rescisória. São Paulo: Ed. RT, 1979.
- ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz; GOTTWALD, Peter. Zivilprozessrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.
- ROSITO, Francisco. Teoria dos Precedentes Judiciais. Curitiba: Juruá, 2012.
- RUDER, David. The development of legal doctrine through amicus participation: the SEC experience. Wisconsin Law Review. 1989.
- RUTANO, Leandro. Ação Rescisória por violação à norma jurídica. Dissertação de mestrado, Paraná, Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2016.
- SACCO, Rodolfo. Interpretazione del diritto. Dato oggettivo e spirito dell'interprete. Diritto, giustizia e interpretazione. Roma/Bari: Laterza, 1998.
- SAGER, Lawrence; KORNHAUSER, Lewis. The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts. California Law Review. v. 81. 1993.
- ____; _____. The many as one: integrity and group choice in paradoxical cases. Philosophy & Public Affairs. v. 32. 2004.
- SALLES, Carlos Alberto. Precedentes e Jurisprudência no Novo CPC: Novas Técnicas Decisórias? O Novo Código de Processo Civil – Questões Controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015.
- SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010.
- SARAIVA, José. O Recurso Especial e o STJ. São Paulo: Saraiva, 2002.
- SARLET, Ingo. Valor de Alçada e Limitação ao Acesso ao Duplo Grau de Jurisdição: Problematização em Nível Constitucional à Luz de um Conceito Material de Direitos Fundamentais. Revista da Ajuris. Porto Alegre, 1996. n. 66.
- ____; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional (2012). 5.

ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

SAVIGNY, Karl Friedrich von. System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit und Comp., 1840. t. I.

SCARSELLI, Giuliano. La condanna con riserva. Milano: Giuffrè, 1989.

SCHAUER, Frederick. Thinking like a Lawyer. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009.

_____. Precedent. Stanford Law Review. v. 39. n. 3. 1987.

SCHWAB, Karl Heinz; GOTTWALD, Peter. Verfassung und Zivilprozeß. Bielefeld: Giesecking, 1984.

_____; ROSENBERG, Leo; GOTTWALD, Peter. Zivilprozessrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.

SCOFIELD, Robert. Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century. King's College Law Journal. v. 16. 2005.

SCOTT, Austin. Collateral estoppel by judgment. Harvard Law Review. 1942.

SEGAL, Joshua. Rebalancing fairness and efficiency: The offensive use of collateral estoppel in § 1983 actions. Boston University Law Review. v. 89. 2009.

SEIDMAN, P.; TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; KARLAN, P.; STONE, G. Constitutional law. 5. ed. New York: Aspen, 2005.

SHANNON, Bradley Scott. The Retroactive and Prospective Application of Judicial Decisions. Harvard Journal of Law & Public Policy. v. 26. Cambridge, 2003.

SHAPIRO, David. Some thoughts on intervention before Courts. Agencies, and arbitrators. Harvard Law Review. 1968. vol. 81.

SHAPIRO, M. Stability and change in judicial decision-making: incrementalism or stare decisis? Law and the behavioral sciences. Indianápolis-Kansas-Nova Iorque: Ed. L. M. Friedman & S. Macaulay, 1977.

SILVA, Paula Costa e. Acto e Processo. Coimbra: Coimbra Editora, 2003.

SILVESTRI, Elisabeta. L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 1997.

SILVESTRI, Gaetano. Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei. Le Corti Supreme. Milano: Giuffrè, 2001.

SIMPSON, A. W. B. The ratio decidendi of a case. The Modern Law Review. v. 20. 1957.

_____. _____. _____. v. 21. 1958.

SOUZA, Miguel Teixeira de. Sobre o Sentido e a Função dos Pressupostos Processuais. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 1991. n. 63.

SOUZA, André Pagani. Vedação das Decisões-Surpresa no Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2014.

SOUZA JÚNIOR, Sidney Pereira de. Sentenças Parciais no Processo Civil – Consequências no Âmbito Recursal. São Paulo: Método, 2009.

- STONE, G.; TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; KARLAN, P.; SEIDMAN, P. Constitutional law. 5. ed. New York: Aspen, 2005.
- STONE, Julius. The Ratio of the Ratio Decidendi. The Modern Law Review. v. 22. 1959.
- SUMMERS, Robert; ATIYAH, P. S. Form and Substance in Anglo-American Law. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- _____; MACCORMICK, Neil. Interpreting Precedents – A Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997.
- SUNSTEIN, C.; TUSHNET, M.; KARLAN, P.; SEIDMAN, P.; STONE, G. Constitutional law. 5. ed. New York: Aspen, 2005.
- TARELLO, Giovanni. Il Realismo Giuridico Americano. Milano: Giuffrè, 1962.
- _____. L' Interpretazione della Legge. Milano: Giuffrè, 1980.
- TARUFFO, Michele. La Motivazione della Sentenza Civile. Padova: Cedam, 1975.
- _____. Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile. Bologna: Il Mulino, 1991.
- _____. Precedente e Giurisprudenza. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 2007.
- _____. Le Funzioni delle Corti Supreme. Cenni Generali. Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.
- _____. Idee per una Teoria della Giusta Decisione. Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile. Bologna: Il Mulino, 2002.
- _____. “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1972.
- _____; COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado. Lezioni sul processo civile. Bologna: Il Mulino, 1995.
- _____; CARPI, Federico; COLESANTI, Vittorio. Commentario breve al Codice di Procedura Civile. Padova: Cedam, 1988.
- TARZIA, Giuseppe. Il Progetto Vassalli per il Processo Civile. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1989.
- _____. I Provvedimenti Urgenti sul Processo Civile Approvati dal Senato. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1990.
- _____. Lineamenti del nuovo processo di cognizione. Milano: Giuffrè, 1991.
- TELES, Miguel Galvão. Inconstitucionalidade pretérita. Nos dez anos da Constituição. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987.
- THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para o seu controle. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.
- _____; BAHIA, Alexandre; NUNES, Dierle; PEDRON, Flávio. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- THURMON, Mark Alan. When the Court Divides: Reconsidering the Precedential Value of Supreme Court Plurality Decisions. Duke Law Journal. v. 42. 1992.

- TOMMASINI, Raffaele. Invalidità: b) Diritto Privato. Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1972. v. XXII.
- TRAYNOR, Roger. Quo Vadis, Prospective Overruling: a Question of Judicial Responsibility. *Hastings Law Journal*. v. 50. 1999.
- TREANOR, William Michael. Prospective Overruling and the Revival of Unconstitutional Statutes. *Columbia Law Review*. v. 93. New York, 1993.
- TROCKER, Nicolò. *Processo Civile e Costituzione*. Milano: Giuffrè, 1974.
- TUNC, André. La Cour Suprême Idéale. In: BELLET, Pierre; TUNC, André (coords.). *La Cour Judiciaire Suprême – Une Enquête Comparative*. Paris: Economica, 1978.
- TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; KARLAN, P.; SEIDMAN, P.; STONE, G. *Constitutional law*. 5. ed. New York: Aspen, 2005.
- USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sérgio. *Manual dos Recursos Cíveis*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- UZELAC, Alan; VAN RHEE, C. H. Appeals and other Means of Recourse against Judgments in the Context of the Effective Protection of Civil Rights and Obligations. In: UZELAC, Alan; VAN RHEE, C. H. (coords.). *Nobody's Perfect – Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions Matters*. Cambridge: Intersentia, 2014.
- VAN RHEE, C. H.; UZELAC, Alan. Appeals and other Means of Recourse against Judgments in the Context of the Effective Protection of Civil Rights and Obligations. In: UZELAC, Alan; VAN RHEE, C. H. (coords.). *Nobody's Perfect – Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions Matters*. Cambridge: Intersentia, 2014.
- VANBERG, Georg. *The politics of constitutional review in Germany*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- VASCONCELLOS, Rita de Cássia Corrêa de. *Princípio da Fungibilidade – Hipóteses de Incidência no Processo Civil Brasileiro Contemporâneo*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- VELLUZZI, Vito. Sulla Nozione di “Interpretazione Giuridica Corretta”. *Tra Teoria e Dogmatica – Sei Studi intorno all' Interpretazione*. Pisa: Edizioni ETS, 2012.
- VERDE, Giuseppe. *Prova*. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1988. v. XXXVII.
- VERGOTTINI, Giuseppe de. *Diritto costituzionale*. Padova: Cedam, 2010.
- VESPAZIANI, Alberto. *Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali*. Padova: Cedam, 2002.
- VIDAL GIL, Ernesto; GARCÍA PASCUAL, Cristina. *Creación Judicial del Derecho. Sentido y razón del derecho – enfoques socio-jurídicos para la sociedad democrática*. Madrid: Hacer Editorial, 1992.
- VILLA, Vittorio. *Il Positivismo Giuridico: Metodi, Teorie e Giudizi di Valore*. Torino: Giappichelli, 2004.
- _____. *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell' Interpretazione Giuridica*. Torino: Giappichelli, 2012.
- VILLATA, Stefano. *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*. Milano: Giuffrè, 2006.
- VIOLA, Francesco; ZACCARIA, Giuseppe. *Diritto e interpretazione: Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*. Roma: Laterza, 1999.

- VOLPINO, Diego. *L'oggetto del giudicato nell'esperienza americana*. Padova: Cedam, 2007.
- WAMBAUGH, Eugene. *The Study of Cases* (1892). 2. ed. Boston: Little, Brown & Co., 1894.
- WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008.
- _____. *Os Agravos*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- _____. *Omissão Judicial e Embargos de Declaração*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- _____. *Introdução*. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Direito Jurisprudencial*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- WASSERMANN, Rudolf. *Der soziale Zivilprozess*. Neuwied-Darmstadt: Luchterhand, 1978.
- WEBER, Max. *A ética protestante e o "espírito" do capitalismo* (edição de Antônio Flávio Pierucci). São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- WIEACKER, Franz. *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung* (1967). 2. ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.
- WRÓBLEWSKI, Jerzy. *The Judicial Application of Law*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992.
- _____. *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*. Madrid: Civitas, 2001.
- _____. *Sentido y hecho en el derecho*. México: Fontamara, 2008.
- _____. *Functions of law and legal certainty*. *Anuario de Filosofia del Derecho*. vol. XVII. 1973-1974.
- _____. *Transparency and doubt. Understanding and interpretation in pragmatics and in Law. Law and Philosophy*. 1988.
- _____. *Legal syllogism and rationality of judicial decision. Rechtstheorie*. Berlin: Duncker & Humblot, 1974. v. 5.
- YARSHELL, Flávio. *Ação rescisória – juízos rescindente e rescisório*. São Paulo: Malheiros, 2005.
- ZACCARIA, Giuseppe. *La Giurisprudenza come Fonte di Diritto – Un'Evoluzione Storica e Teorica*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007.
- _____. *Complessità della ragione giuridica. Questioni di interpretazione*. Padova: Cedam, 1996.
- _____; VIOLA, Francesco. *Diritto e interpretazione: Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*. Roma: Laterza, 1999.
- ZANETI JÚNIOR, Hermes. *A Constitucionalização do Processo*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- _____. *O Valor Vinculante dos Precedentes*. Salvador: JusPodivm, 2014.
- _____. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- ZIPPELIUS, Reinhold. *Rechtsphilosophie* (1982). 6. ed. München: C. H. Beck, 2011.
- ZUFELATO, Camilo. *Precedentes Judiciais Vinculantes à Brasileira no Novo CPC: Aspectos Gerais. O Novo Código de Processo Civil – Questões Controvertidas*. São Paulo: Atlas, 2015.

